

Introdução

ao estudo do direito

PROCESSUAL CIVIL

Fábio Victor da Fonte Monnerat

5ª Edição

saraiva *jur*

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva.

A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

ISBN 9788553616121

Monnerat, Fabio

Introdução ao estudo do Direito Processual Civil / Fabio Monnerat. – 5. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.

616 p.

Bibliografia

1. Processo civil I. Título.

20-0142

CDD 340

Índices para catálogo sistemático:

1. Direito processual civil 347.9

Direção executiva *Flávia Alves Bravin*

Direção editorial *Renata Pascual Müller*

Gerência editorial *Roberto Navarro*

Gerência de produção e planejamento *Ana Paula Santos Matos*

Gerência de projetos e serviços editoriais *Fernando Penteado*

Consultoria acadêmica *Murilo Angeli Dias dos Santos*

Planejamento *Clarissa Boraschi Maria (coord.)*

Novos projetos *Melissa Rodriguez Arnal da Silva Leite*

Edição *Marisa Amaro dos Reis*

Produção editorial *Rosana Peroni Fazolari*

Arte e digital *Mônica Landi (coord.) | Amanda Mota Loyola | Camilla Felix Cianelli Chaves | Claudirene de Moura Santos Silva | Deborah Mattos | Fernanda Matajs | Guilherme H. M. Salvador | Tiago Dela Rosa | Verônica Pivisan Reis*

Planejamento e processos *Clarissa Boraschi Maria (coord.) | Juliana Bojczuk Fermينو | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Fernando Penteado | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Projetos e serviços editoriais *Juliana Bojczuk Fermينو | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Diagramação (Livro Físico) *Marcelo Brandão*

Revisão *Daniela Georgeto*

Capa *Herbert Junior*

Livro digital (E-pub)

Produção do e-pub *Guilherme Henrique Martins Salvador*

Data de fechamento da edição: 3-10-2019

Dúvidas?

Acesse sac.sets@somoseducacao.com.br

Sumário

Agradecimentos

Prefácio

Nota à 5ª Edição

Apresentação da 1ª Edição

Capítulo 1 - Noções Introdutórias

Capítulo 2 - O Direito Processual Civil

2.1 Direito Processual e Direito Material

2.2 Classificação do Direito Processual

- a) Direito Processual Civil e Direito Processual Penal
- b) Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho
- c) Direito Processual Civil e Direito Processual Eleitoral
- d) Direito Processual Civil e Direito Processual Constitucional
- e) Direito Processual Civil e o denominado “Processo Administrativo”
- f) Direito Processual Civil e seu caráter geral e supletivo

2.3 Fontes do Direito Processual Civil: a norma processual civil e sua consagração

2.3.1 Normas processuais: conceito e classificação

2.3.1.1 Espécies de normas processuais

2.3.2 Fontes do Direito Processual Civil

- a) Constituição Federal
- b) Leis federais
- c) Constituição e leis estaduais

d) Regimentos internos dos tribunais

e) A jurisprudência e os precedentes judiciais como fonte do Direito Processual Civil

2.3.3 Aplicação das normas processuais

Capítulo 3 - Jurisdição e Demais Meios de Resolução de Litígios (Autotutela, Meios Consensuais e Arbitragem)

3.1 Da autotutela à jurisdição estatal: os meios de resolução da lide

3.1.1 Autotutela: conceito, vedação e admissibilidade excepcional

3.1.2 Meios consensuais de resolução de litígios

3.1.2.1 A resolução do litígio por meio da transação, da renúncia e do reconhecimento jurídico do pedido

3.1.2.2 Técnicas de promoção da solução consensual de litígios: mediação e conciliação

3.1.2.3 Arbitragem

3.1.3 Jurisdição: noções preliminares

3.2 Jurisdição: conceito, características e distinção em relação às demais funções do Estado

3.2.1 Poder jurisdicional: distinção e relação com as demais funções do Estado

3.2.1.1 Função jurisdicional e função executiva

3.2.1.2 Função jurisdicional e função legislativa

3.2.2 Especialmente sobre a função jurisdicional

3.2.2.1 Características da jurisdição

Capítulo 4 - Tutela Jurisdicional

4.1 Tutela jurisdicional: conceito

4.2 Classificação da tutela jurisdicional

4.2.1 Tutela jurisdicional de conhecimento e tutela jurisdicional executiva

a) Tutela jurisdicional de conhecimento

a.1) Subclassificação da tutela jurisdicional de conhecimento: tutela meramente declaratória, tutela constitutiva e tutela condenatória

b) Tutela jurisdicional executiva

4.2.2 Tutela jurisdicional provisória e definitiva

a) Tutela provisória de urgência: tutela cautelar e tutela antecipada

a.1) Especialmente sobre os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência

b) A tutela de evidência

4.2.3 Tutela jurisdicional individual e coletiva

4.2.4 Tutela jurisdicional contenciosa e voluntária

Capítulo 5 - Jurisdição e Poder Judiciário

5.1 Classificação da jurisdição e organização do Poder Judiciário

5.1.1 Classificação da jurisdição segundo o grau de jurisdição exercido

5.1.2 Especialmente sobre a jurisdição de sobreposição e os tribunais superiores no ordenamento brasileiro

5.1.3 Classificação da jurisdição segundo a espécie de direito processual e material aplicado

a) Jurisdição constitucional e Supremo Tribunal Federal

b) Jurisdição trabalhista e os órgãos da Justiça especializada com competência para seu exercício

c) Jurisdição eleitoral e os órgãos da Justiça especializada com competência para seu exercício

d) Jurisdição penal comum e militar e os órgãos da Justiça comum e especializados com competência para seu exercício

e) Jurisdição civil e os órgãos da Justiça comum com competência para seu exercício

5.2 Quadro de organização do Poder Judiciário

Capítulo 6 - Normas Fundamentais do Processo Civil Brasileiro

6.1 Normas fundamentais na Constituição Federal

6.1.1 Estrutura normativa do Direito Processual Civil na Constituição Federal: os princípios e regras processuais constitucionais

6.1.2 As regras processuais na Constituição Federal

6.1.3 Princípios processuais constitucionais: características e funções

6.1.3.1 Características dos princípios processuais constitucionais

- a) O status de direito fundamental
- b) A natureza de cláusula pétrea dos princípios e garantias processuais constitucionais
- c) A dupla dimensão dos princípios processuais constitucionais: as dimensões objetiva e subjetiva
- d) Os vários destinatários dos princípios processuais constitucionais
- e) A aplicabilidade imediata dos princípios processuais constitucionais
- f) A tendência dos princípios constitucionais de entrarem em conflito e a necessidade de solução pela aplicação da proporcionalidade

6.1.3.2 As diversas funções dos princípios processuais constitucionais no ordenamento jurídico

6.1.4 Normas fundamentais de Direito Processual Civil na Constituição Federal: elenco dos princípios processuais constitucionais

6.1.4.1 Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à Justiça (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal)

6.1.4.2 Princípio do contraditório

6.1.4.3 Princípio da ampla defesa

6.1.4.4 Princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos

6.1.4.5 Princípio da motivação das decisões judiciais

6.1.4.6 Princípio da publicidade

6.1.4.7 Princípio do juiz natural e da vedação de tribunais de exceção

6.1.4.8 Princípio do duplo grau de jurisdição

6.1.4.9 Princípio da duração razoável do processo

6.1.4.10 Princípio do devido processo legal

6.1.4.11 Princípio da isonomia no processo civil: a dupla perspectiva do princípio da igualdade para o processo

6.1.4.12 Princípio da assistência judiciária integral e gratuita

6.1.4.13 Princípio da definitividade das decisões judiciais (coisa julgada)

6.2 Normas fundamentais no Código de Processo Civil

6.2.1 Art. 1º do CPC: Princípio da conformidade com a Constituição e princípio do devido processo legal

6.2.2 Art. 2º do CPC: Princípios do dispositivo, do impulso oficial e inércia jurisdicional

6.2.3 Art. 3º do CPC: Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à Justiça e princípio da preferência pela solução consensual de conflitos

6.2.4 Art. 4º do CPC: Princípio da efetividade do processo, princípio da preferência pela solução integral de mérito e (re)afirmação do princípio da duração razoável do processo

6.2.5 Art. 5º do CPC: Princípio da boa-fé objetiva

6.2.6 Art. 6º do CPC: Princípio da cooperação

6.2.7 Art. 7º do CPC: Princípio da igualdade (paridade de armas) e dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório

6.2.8 Art. 8º do CPC: Princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, eficiência e dever de atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum

6.2.9 Arts. 9º e 10 do CPC: O contraditório prévio e substancial e a vedação de decisões surpresa

6.2.10 Art. 11 do CPC: Princípios da publicidade e motivação

6.2.11 Art. 12: Ordem cronológica de julgamento

Capítulo 7 - Funções Essenciais à Justiça

7.1 Ministério Público

7.1.1 Estrutura e carreiras integrantes do Ministério Público

7.1.2 Especialmente sobre os papéis do Ministério Público no Processo Civil

a) Ministério Público, autor de ações coletivas

b) Ministério Público, fiscal da ordem jurídica

7.2 Advocacia Pública

7.3 Defensoria Pública

7.3.1 Estrutura e carreiras integrantes da Defensoria Pública

7.4 Advocacia

Capítulo 8 - Ação

8.1 Considerações iniciais

8.2 Conceito de ação e sua evolução histórica

8.3 Elementos da ação

a) Partes

b) Pedido

c) Causa de pedir

8.4 Condições da ação

a) Legitimidade de partes

b) Interesse de agir

8.5 Formas de arguição e verificação e consequências da decretação das irregularidades relativas às condições da ação

8.5.1 Especialmente sobre a dinâmica de arguição de ilegitimidade passiva

8.6 Especialmente sobre a subsistência da categoria condições da ação no Código de Processo Civil de 2015

Capítulo 9 - Processo

9.1 Processo: método, relação processual e procedimento

9.1.1 Classificação do processo e procedimento

9.2 Relação processual: os sujeitos do processo

9.2.1 Do juiz: deveres e poderes do juiz

9.2.1.1 Deveres do juiz

- a) Dever de prestar jurisdição
- b) Dever de conduzir o processo e de zelar por sua regularidade
- c) Dever de tratar as partes com igualdade
- d) Dever de promover a autocomposição
- e) Dever de obstar que as partes, em conluio, atinjam, por meio do processo, objetivos proibidos por lei
- f) Dever de zelar pela sua imparcialidade
- g) Dever de adstrição ao pedido

9.2.1.2 Dos poderes do juiz

- a) Poder decisório
- b) Poder ordinatório
- c) Poder instrutório
- d) Poder sancionatório
- e) Poder executório

9.2.2 Auxiliares da Justiça

9.2.2.1 Dos auxiliares permanentes

- a) Do escrivão ou chefe de secretaria e dos escreventes
- b) Do oficial de justiça
- c) Os conciliadores e mediadores

9.2.2.2 Auxiliares eventuais

- a) Perito
- b) Tradutores e intérpretes

c) Administradores e depositários

9.2.3 Partes

9.2.3.1 Direitos das partes

- a) Generalidades sobre os direitos das partes de requerer, alegar e provar
- b) Especialmente sobre os direitos de ação e a uma resposta jurisdicional do autor
- c) Especialmente sobre o direito à ciência da existência do processo e do andamento do procedimento
- d) Especialmente sobre o direito de defesa
- e) Direito de provar e o ônus da prova
- f) Direitos das partes e ônus processual
- g) Especialmente sobre direitos processuais e alegações que não precluem

9.2.3.2 Deveres das partes

Capítulo 10 - Pressupostos Processuais de Existência, Constituição e Desenvolvimento Válido e Regular do Processo

10.1 Considerações iniciais

10.2 Pressupostos processuais de existência

10.3 Pressupostos processuais de validade

- a) Competência absoluta
- b) Imparcialidade
- c) Petição inicial apta
- d) Citação válida
- e) Capacidade de ser parte
- f) Capacidade processual (de estar em juízo)
- g) Capacidade postulatória

10.3.1 A correção da tríplice capacidade mediante sucessão de partes, representantes e procuradores

- a) Sucessão de parte
- b) Substituição do representante da parte
- c) Substituição do advogado

10.4 Pressupostos processuais negativos

- a) Litispendência
- b) Coisa julgada material
- c) Perempção
- d) Convenção de arbitragem

10.5 Formas de arguição e verificação de consequências da decretação das irregularidades relativas aos pressupostos processuais

- a) Competência absoluta
- b) Imparcialidade
- c) Petição inicial apta
- d) Citação válida
- e) Capacidade de ser parte
- f) Capacidade processual (de estar em juízo)
- g) Capacidade postulatória
- h) Litispendência
- i) Coisa julgada material
- j) Perempção
- k) Convenção de arbitragem

Capítulo 11 - Formação, Suspensão e Extinção do Processo

11.1 Considerações iniciais

11.2 Da formação do processo

11.3 Suspensão do processo

11.3.1 Hipóteses de suspensão do processo relacionadas à tríplice capacidade

das partes

- a) Suspensão por morte da parte
- b) Suspensão por morte do representante da parte
- c) Suspensão por morte do advogado da parte
- d) Suspensão por perda da capacidade da parte, de seu representante legal ou de seu advogado

11.3.1.1 Dos efeitos da decretação da suspensão do processo por morte ou perda da capacidade das partes, de seus representantes ou seus procuradores

11.3.2 Demais hipóteses de suspensão do processo

- a) Suspensão por convenção das partes
- b) Suspensão por arguição de impedimento ou suspeição
- c) Suspensão pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas
- d) Suspensão por existência de questão prejudicial
- e) Suspensão do processo “por motivo de força maior”
- f) Suspensão nos demais casos que o Código regula
- g) Suspensão por parto ou adoção pela advogada ou paternidade do advogado

11.4 Extinção do processo

11.4.1 Extinção do processo sem resolução do mérito

- a) Indeferimento da petição inicial
- b) Extinção por negligência das partes
- c) Extinção por abandono do autor
- d) Extinção por ausência de pressupostos processuais de validade
- e) Extinção por existência de litispendência, coisa julgada ou preempção
- f) Extinção por ausência de condições da ação
- g) Extinção por acolhimento de alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência

h) Extinção por desistência da ação

i) Extinção pela morte da parte e intransmissibilidade do direito discutido em juízo

j) Extinção em outras hipóteses previstas no Código

11.4.2 Extinção do processo com resolução do mérito

a) Extinção por julgamento do pedido

b) Extinção por homologação de transação, renúncia e o reconhecimento jurídico do pedido

Capítulo 12 - Atos Processuais

12.1 Atos jurídicos em geral, atos jurídicos processuais e fatos processuais

12.2 Classificação dos atos processuais

12.2.1 Classificação segundo o sujeito que os pratica

a) Atos da parte

b) Especialmente sobre os negócios processuais

c) Atos do juiz e dos auxiliares da Justiça

d) Especialmente sobre os atos decisórios do juiz

e) Especialmente sobre os atos de comunicação processual

12.2.2 Atos processuais formais, orais e materiais

12.3 Forma dos atos processuais

12.4 Do lugar dos atos processuais

12.4.1 A sede do juízo e os atos praticados fora dos limites territoriais

12.5 Tempo dos atos processuais

12.6 Prazos processuais

12.6.1 Os prazos processuais no Código de Processo Civil

12.6.2 Classificação dos atos processuais

a) Classificação segundo a fonte de fixação

- b) Prazos dilatórios e peremptórios
- c) Prazos próprios e impróprios
- 12.6.3 Fluência e contagem dos prazos processuais
- 12.6.4 Prazos especiais
- 12.6.5 Suspensão e interrupção dos prazos processuais
- 12.6.6 Descumprimento dos prazos processuais e preclusão

Capítulo 13 - Nulidades do Processo e dos Atos Processuais

- 13.1 Generalidades
- 13.2 Caracterização das nulidades
- 13.3 Classificação das nulidades
 - a) Nulidades absolutas e nulidades relativas
 - b) Nulidades cominadas e nulidades não cominadas
 - c) Nulidades sanáveis e nulidades insanáveis
- 13.4 Critérios orientadores da decretação das nulidades
- 13.5 Normas orientadoras das consequências da decretação das nulidades sobre os demais atos do processo
- 13.6 Dinâmica da verificação e declaração da nulidade dos atos processuais

Capítulo 14 - Os Custos Financeiros do Processo

- 14.1 Generalidades
- 14.2 Custas judiciais
- 14.3 Honorários advocatícios
- 14.4 Demais despesas processuais
- 14.5 Ônus de prévio recolhimento das custas e demais despesas processuais
- 14.6 Responsabilidade pelo pagamento das custas, honorários e demais despesas processuais em razão da sucumbência
 - 14.6.1 Especialmente sobre a sucumbência recíproca

14.7 Regime das custas, honorários advocatícios e demais despesas nos processos que envolvem entes públicos

14.8 Gratuidade da Justiça

- a) Dinâmica da concessão da Justiça gratuita no que tange às custas judiciais
- b) Dinâmica da concessão da Justiça gratuita em relação aos honorários advocatícios
- c) Dinâmica da concessão da Justiça gratuita em relação às demais despesas processuais

14.8.1 Aspectos procedimentais do requerimento e da concessão da Justiça gratuita

Capítulo 15 - Competência

15.1 Generalidades

15.2 Parâmetros normativos para a definição da competência

15.2.1 Critérios genéricos de repartição de competência

- a) Competência em razão da matéria (critério material)
- b) Competência em razão da pessoa (critério pessoal)
- c) Competência funcional
- d) Competência territorial
- e) Competência em razão do valor da causa

15.3 Metodologia de aplicação das normas de repartição de competência

15.4 Limites da jurisdição nacional

15.5 Identificação da competência originária dos tribunais superiores mediante a aplicação das normas específicas e excepcionais

15.6 Repartição de competência entre as “Justiças” mediante aplicação dos critérios genéricos de repartição de competência

15.7 Identificação da competência originária dos tribunais de segundo grau

15.8 Identificação do foro competente mediante aplicação do critério territorial de repartição de competência

15.9 Identificação da competência dos juizados especiais mediante aplicação dos critérios matéria e valor da causa

15.10 Identificação da vara competente mediante aplicação dos critérios matéria, pessoa ou função

15.11 O desrespeito às normas de competência e respectivas consequências processuais

15.11.1 Competência absoluta e relativa

15.11.2 Consequências processuais do desrespeito aos critérios de competência absoluta

15.11.3 Consequências processuais do desrespeito aos critérios de competência relativa

15.12 Modificação da competência

15.12.1 Modificação por convenção das partes

15.12.2 Modificação por prorrogação de competência

15.12.3 Modificação por conexão, continência ou risco de decisões conflitantes

15.13 Conflito de competência

Capítulo 16 - Litisconsórcio

16.1 Litisconsórcio: conceito e cabimento

16.2 Classificação do litisconsórcio

a) Classificação segundo a posição das partes: litisconsórcio ativo, passivo e misto

b) Classificação segundo a obrigatoriedade de sua formação: litisconsórcio necessário e facultativo

c) Classificação segundo o resultado: litisconsórcio unitário e simples

d) Classificação segundo o momento de sua formação: litisconsórcio inicial e ulterior

16.3 Poderes dos litisconsortes

16.4 Prazo dos litisconsortes

Capítulo 17 - Intervenções de Terceiros

17.1 Considerações iniciais

17.2 Classificação dos terceiros e das modalidades de intervenção

17.3 Modalidades de intervenção de terceiros voluntárias

17.3.1 Assistência simples

17.3.1.1 Conceito, cabimento e finalidade

17.3.1.2 Poderes do assistente simples

17.3.1.3 Coisa julgada e justiça da decisão para o assistente

17.3.2 Assistência litisconsorcial

17.4 Modalidades de intervenção de terceiros provocadas

17.4.1 Denúnciação da lide

17.4.1.1 Conceito, cabimento e finalidade

17.4.1.2 Procedimento e dinâmica da relação processual após a denúncia à lide

17.4.2 Chamamento ao processo

17.4.2.1 Conceito, cabimento e finalidade

17.4.2.2 Procedimento e dinâmica da relação processual após o chamamento ao processo

17.4.3 Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica

17.4.3.1 Premissas para a compreensão

17.4.3.1.1 Pressupostos materiais para a desconconsideração da personalidade jurídica

17.4.3.1.2 A desconconsideração da personalidade jurídica inversa

17.4.3.2 Hipóteses de cabimento, legitimidade e finalidade

17.4.3.3 Procedimento e dinâmica da relação processual após a instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica

17.5 Amicus curiae

17.5.1 Generalidades

17.5.2 Legitimidade para intervir na qualidade de amicus curiae

17.5.3 Atuação do amicus curiae: limites e possibilidades

17.6 Outras modalidades de intervenção de terceiros fora do capítulo específico do Código de Processo Civil

17.6.1 Recurso de terceiro prejudicado

17.6.2 Ampliação subjetiva do processo via reconvenção

17.6.3 Integração de terceiros decorrente da alegação de ilegitimidade passiva

17.6.4 Embargos de terceiro

17.6.5 Intervenção de terceiros por ordem do juiz

Referências

Fábio Victor da Fonte Monnerat

Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Doutorando, mestre e especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Procurador Federal. Membro da Câmara Permanente de Orientação Judicial em Processo Civil da Procuradoria-Geral Federal. Coordenador e professor do Curso de Especialização em Direito Processual Civil da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo – ESA/OAB-SP. Professor convidado dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) da Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas, da Universidade Católica de Salvador – UNICSAL, da Escola Paulista de Direito – EPD e do Damásio Educacional. Ex-diretor da Escola da Advocacia-Geral da União em São Paulo e ex-coordenador nacional de Direito Processual Civil da EAGU. Professor de Direito Processual Civil do curso de graduação da Universidade São Judas Tadeu – USJT. Membro do Conselho Editorial da Revista da Advocacia-Geral da União. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Membro da Comissão de Processo Civil da OAB Nacional.

Antes de explicar meu livro aos outros, aguardo que os outros o expliquem a mim. Querer explicá-lo primeiro significaria limitar o seu sentido, pois, ainda que saibamos aquilo que quisemos dizer, não sabemos, todavia, se dissemos apenas isso.

(André Gide, Paludes)

Dedico este livro aos meus alunos, primeiros destinatários destas despretensiosas lições, que com seus questionamentos, dúvidas e, muitas vezes, com simples olhares moldaram a forma e o conteúdo desta Introdução.

Agradecimentos

Quero agradecer a todos aqueles que fizeram esta obra possível.

Em primeiro lugar, àqueles que me apresentaram o Direito Processual Civil em sala de aula, na pessoa de meu professor de Teoria Geral do Processo na Universidade Católica de Pernambuco, Ubiratan de Couto Maurício.

Também agradeço àqueles que, por meio de suas obras, me fizeram conhecer, gostar para, então, entender o Direito Processual Civil e que, depois, tive a honra de conhecer pessoalmente: Humberto Theodoro Júnior, Alexandre Freitas Câmara, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco.

Agradeço àqueles que me permitiram ser mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que tão bem me acolheram nos estudos da pós-graduação e cujas aulas, debates, provocações e observações permitiram reflexões e conclusões às quais nunca teria chegado sozinho.

Para estes verdadeiros provocadores, no melhor sentido da palavra, Nelson Nery Jr., Cassio Scarpinella Bueno, Sérgio Shimura, Maria Helena Diniz, Gilson Delgado Miranda, Willis Santiago Guerra Filho e, em especial, minha orientadora, Teresa Arruda Alvim, deixo aqui meu sincero agradecimento.

Agradeço também àqueles que me permitiram ser professor: Marcus Vinícius de Abreu Sampaio, Renato Montans de Sá, Gisele Kodani Yoshida e Fernando Herren Aguillar, que com gestos, sobretudo de confiança, me permitiram dar aulas de Direito Processual Civil.

Agradeço àqueles que me permitiram ser diretor da Escola da Advocacia-Geral da União, em São Paulo, e me confiaram a Coordenação Nacional de

Direito Processual Civil da Escola da AGU, em especial à Juliana Sahione Mayrink Neiva e àquela que sempre me apoiou nesta jornada, Damaris Rodrigues Zago Carreira.

Por fim, agradeço àqueles que me fazem ser quem realmente sou, pai, filho, marido e neto: aos meus filhos, Duda e Dante, aos meus pais, Hermano e Janine, aos meus avós, Geraldo, Terezinha, Maria da Natividade e Flávio, e à minha amada esposa, Danielle.

Prefácio

Normalmente, bons processualistas escrevem obras densas, profundas, muito frequentemente quase inacessíveis para aqueles que estão começando. Por outro lado, infelizmente, livros mais simples, com pretensões didáticas, são obra daqueles que nestes trabalhos põem tudo o que sabem.

Portanto, merecem aplausos os bons processualistas que abrem mão do prazer de verticalizar o estudo e a reflexão sobre um tema específico, para substituí-lo por outro: dizer só o necessário, de forma organizada e didática, para, altruisticamente, contribuir para a formação de bons profissionais.

É o caso de Fábio Monnerat. Está na lista dos ótimos alunos que tive no mestrado/doutorado da PUC-SP. Estudioso, sério, profundo: um processualista que deve formar jovens. Foi o que fez neste trabalho.

Fábio compartilha comigo a ideia de que faculdades devem exercer função de formar bons profissionais. Ainda mais num país em desenvolvimento como o nosso. As universidades não podem e não devem formar críticos. São críticos “de araque”: criticam o que pouco ou nada conhecem.

Universidades que formam “críticos” produzem estereótipo daqueles que se limitam a repetir chavões e jamais conseguem se colocar profissionalmente. Frustrados e derrotados, culpam o “sistema” pela sua incapacidade de se situar na sociedade.

O livro de Fábio quer apresentar, de forma desmistificada, o direito processual ao aluno que nunca teve contato com a matéria, ou mesmo com o Direito. E faz isto de forma eficiente. Quer que o aluno entenda, se interesse, queira saber mais.

Em todas as áreas do conhecimento deveria haver obras assim, em que o

autor leva o aluno pela mão, devagar, até que ele possa andar sozinho.

Teresa Arruda Alvim

Professora Livre-Docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Relatora da comissão encarregada da elaboração do projeto de lei para um novo Código de Processo Civil brasileiro.

Nota à 5ª Edição

Todo livro é uma obra em constante construção. No caso de um livro didático, como pretende ser esta Introdução ao estudo do Direito Processual Civil, essa construção se dá, sobretudo, em sala de aula e em diálogos com as obras e ideias de outros pensadores da ciência processual, mas também, desde já, com um olhar também voltado para a realidade, para a prática do dia a dia do foro.

O Código de Processo Civil de 2015, mesmo ano de lançamento da 1ª edição deste livro, sem sombra de dúvida intensificou as discussões acerca do processo civil, a produção de trabalhos científicos e os debates sobre o tema em todo o Brasil.

Como coordenador nacional de Direito Processual Civil da Escola da Advocacia-Geral da União (EAGU) entre os anos de 2015 e 2016, pude viver intensamente esses diálogos, participando de congressos, seminários, cursos de atualização e eventos em todo o território nacional, de norte a sul, de leste a oeste, percorrendo todos os Estados da Federação durante o período de vacatio legis do CPC/2015.

O novo Código, ademais, despertou o interesse de estudiosos e doutrinadores de outros países, como Itália e Portugal.

Nesse contexto, tive a honra de participar de importantes cursos fora do Brasil, tais como o seminário “Sistemi Processuali a confronto: il Nuovo Codice di Procedura Civile del Brasile tra tradizione e rinnovamento”, em Roma, Itália (2015); o “2º Colóquio Luso-brasileiro de Direito Processual Civil”, em Lisboa, Portugal (2016); o curso “O Processo civil contemporâneo: estudos comparados Brasil-Itália”, também em Roma (2016, 2017 e 2018); e o curso “Tutela jurisdicional em uma perspectiva comparada: Europa-Brasil”, em Sevilha, Espanha (2019).

Ademais, foram inúmeras as participações em cursos de pós-graduação em Direito Processual Civil, como os ministrados na Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – seção São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e de Campinas (PUC-Camp), na Universidade Católica de Salvador e na Universidade Federal do Mato Grosso, entre outras instituições.

Não se pode deixar de fora dessa mistura as aulas do curso de doutorado da PUC de São Paulo, casa que me acolhe desde 2004 nos estudos de pós-graduação, e o Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), instituição plural e democrática que congrega, regularmente, cerca de 600 professores e estudiosos de diversas correntes e escolas para debater o Direito Processual Civil.

É em ambientes como esses que lições e ideias surgem, são externadas, testadas e debatidas. A partir da reação e das respostas dos destinatários e participantes do debate, torna-se possível aperfeiçoá-las, modificá-las e aprimorá-las.

Ocasões como essas proporcionam diálogo para além dos livros, com as pessoas por trás das obras e das ideias, de maneira democrática, falada, discutida. Impressionam, nesse contexto, a retidão e o compromisso acadêmico de estudiosos como Fredie Didier Jr., Alexandre Freitas Câmara, Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier, tão citados neste livro, entre outros inúmeros mestres participantes do FPPC.

Igualmente, na PUC de São Paulo, as sempre instigantes lições e debates com seu corpo docente de excelência, dentre ele Teresa Arruda Alvim, Nelson Nery Jr., Cassio Scarpinella Bueno, Arlete Aureli, Marcus Vinícius Abreu Sampaio, Olavo de Oliveira Neto, William Santos Ferreira e Sérgio Shimura, além do próprio corpo discente, são constante estímulo para o aprimoramento e avanço acadêmico.

Poder viver este momento e estar ao lado de verdadeiros professores, no sentido mais literal da palavra, é um privilégio que tento refletir nas linhas desta Introdução.

Ademais, a prática na Procuradoria Regional Federal da 3ª Região e o contato diário com as primeiras aplicações do Código de Processo Civil de 2015, certamente sugerem novas reflexões, novas abordagens, somente possíveis a partir do direito processual vivido no dia a dia do foro.

Nesse contexto prático-profissional, cumpre destacar, também, as oportunidades de contribuir com a Câmara Permanente de Orientação em Processo Civil e de gerenciar o Projeto IRDR PRÓ ATIVO, ambos da Procuradoria-Geral Federal, atividades que permitem uma visão aprofundada e uma análise detalhada de institutos e temas fundamentais do Direito Processual Civil que acabam por influenciar nas reflexões postas na obra.

Acima de tudo, a sala de aula, não apenas na graduação, mas também em escolas de aperfeiçoamento e atualização de profissionais, atuantes e com problemas reais, tais como a própria Escola da AGU, onde continuo presente, agora como professor convidado, a Escola Superior da Ordem dos Advogados do Brasil, não apenas de São Paulo, onde coordeno o curso de pós-graduação, como também de outros Estados, como Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde, sempre que posso, atuo como debatedor, palestrante ou professor convidado e onde, além de falar, tenho o privilégio de ouvir, aprender e refletir sobre problemas reais e soluções necessárias para o aperfeiçoamento do sistema processual.

O mesmo ocorre em Escolas da Magistratura onde pude estar, também na posição de professor convidado, como nos Estados de Sergipe, Amazonas, Piauí, Maranhão e Santa Catarina, que, igualmente enriquecem pela possibilidade de perceber o ponto de vista dos membros do Judiciário, juízes e seus auxiliares, sujeitos perante os quais todo o processo se opera

e se desenvolve.

Salas de aula nesses ambientes abrigam reflexões fruto de situações práticas, o que possibilita atingir o objetivo de oferecer lições introdutórias e preparar o estudioso do processo para a realidade futura.

Assim, pequenos exemplos e situações vividas pelos operadores do Processo Civil no dia a dia do foro ajudam a moldar a forma e o conteúdo destas lições.

Os anos que separam o lançamento desta Introdução, em 2015, e esta 4ª edição foram anos de intensos debates e testes que permitiram o aprimoramento das ideias e lições aqui despretensiosamente lançadas.

Já na 2ª edição (2017) ocorreu um acréscimo significativo de considerações acerca das normas fundamentais do Processo Civil brasileiro, com a inclusão de 12 itens no Capítulo 6 da obra original, todos aqui mantidos, além do acréscimo de um capítulo dedicado à “competência”, inexistente na 1ª edição (Capítulo 15).

A 3ª edição (2018), por sua vez, além de novas reflexões sobre vários temas (por exemplo, jurisprudência e os precedentes como fonte do Direito Processual Civil; a tutela provisória de urgência e de evidência; o litisconsórcio; as condições da ação), traz um novo capítulo sobre as diversas modalidades de intervenção de terceiros, inexistente nas duas primeiras edições (Capítulo 16).

A 4ª edição não consagrou novos capítulos, o que não impediu a inserção de novas reflexões e novas ideias, a par da reestruturação de alguns capítulos, tais como o Capítulo 3, dedicado aos meios de resolução da lide, e, em menor medida, o Capítulo 6, dedicado às normas fundamentais do Processo Civil brasileiro.

A presente edição traz o deslocamento do conteúdo relacionado ao estudo do litisconsórcio, antes integrante de um item do Capítulo 9, que agora passa a ocupar um capítulo próprio (Capítulo 16) apenas para fins

didáticos e organizacionais, o que implicou, por consequência, a renumeração do capítulo subsequente – dedicado às intervenções de terceiros, que, na presente edição, passa a ser o Capítulo 17.

Ademais, a 5ª edição permitiu a inclusão de dois novos itens não constantes nas edições anteriores: a) o item 2.3.3, no Capítulo 2, dedicado ao estudo da aplicação da lei processual (arts. 13 a 15 do CPC), assim como b) o item 12.2.1, “e”, no Capítulo 12.

O primeiro item volta-se ao estudo da lei processual no espaço (art. 13 do CPC) e no tempo (art. 14 do CPC), assim como do regramento previsto no Código para a aplicação supletiva e subsidiária do Direito Processual Civil aos processos do trabalho, eleitoral e administrativo (art. 15 do CPC).

Já o item 12.2.1, “e”, do Capítulo 12 volta-se a uma melhor sistematização dos atos de comunicação processuais, ou seja, das citações, intimações e cartas, temas que, em edições anteriores, apenas eram referidos de maneira esparsa ao longo da obra.

Tal como já afirmado em outras reedições, todo livro é uma obra em construção. Segue nas próximas páginas a obra original com mais algumas pedras, exemplos e detalhes voltados à busca constante do aperfeiçoamento desta Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil.

Apresentação da 1ª Edição

Anualmente, milhares de alunos egressos do ensino médio ingressam no sistema de educação superior sem nunca terem tido qualquer contato com essa nova realidade, com esse ambiente, com a metodologia e, sobretudo, com a linguagem técnica utilizada em sala de aula.

Como professor, deparo anualmente com estas dificuldades, sendo certo que o estabelecimento de uma linguagem técnica com aqueles que a ela nunca tiveram acesso é o primeiro e mais importante desafio do professor e do aluno, pois sem o estabelecimento deste padrão de comunicação torna-se impossível a continuidade do diálogo rumo ao aprendizado.

No mundo jurídico, para aqueles que militam no dia a dia do foro e em sala de aula, a utilização de conceitos e expressões jurídicas soa tão natural que eles parecem ser de conhecimento comum de todos.

Entretanto, como professor de alunos iniciantes em letras jurídicas, minha primeira lição foi perceber que é preciso partir do pressuposto de que, de rigor, essa linguagem comum e rotineira para os operadores do Direito é, para o estudante iniciante, absolutamente nova, sendo esclarecer estas expressões e conceitos minha primeira e mais importante missão.

A proposta desta obra é exatamente se dirigir àqueles que nunca tiveram contato com o Direito Processual Civil, partindo do pressuposto de que tudo é desconhecido pelo leitor, que deve, portanto, ser levado, pela leitura, a descobrir esse novo mundo a partir dos conceitos e institutos mais básicos e fundamentais.

Trata-se de um livro despretensioso do ponto de vista científico, no sentido de que não se pretende nele abordar questões técnicas e doutrinárias polêmicas ou sofisticadas por um motivo muito simples: tais questionamentos não fazem sentido para o leitor que não conhece os

conceitos básicos.

A intenção do trabalho, portanto, é simplificar sem nunca omitir questões conceituais relevantes, e sempre com um foco introdutório.

Assim, não se trata de um livro completo e definitivo, se é que algum livro pode ter essa pretensão, mas de um livro introdutório que irá, a partir da apresentação de conceitos e instituições, de maneira clara e didática, permitir ao aluno continuar estudando o Direito Processual Civil.

Ter esta perspectiva introdutória, por outro lado, não implica produzir um livro omissivo ou incompleto, pois todos os conceitos básicos e fundamentais do processo civil serão enfrentados, explicados e esclarecidos.

São Paulo, maio de 2015.

Fábio Victor da Fonte Monnerat

Capítulo 1 Noções Introdutórias

Historicamente, duas realidades acompanham o ser humano nos diversos estágios do desenvolvimento social, cultural e econômico: a primeira delas, a que o homem vive em sociedade; e a segunda, na verdade uma consequência da primeira, que a vida em sociedade deve ser regulada por meio de normas disciplinadoras de condutas.

O Direito surge, portanto, como um complexo de normas de conduta, de caráter obrigatório voltado a disciplinar a vida em sociedade. É nesse sentido que deve ser entendida a máxima “onde está o homem está a sociedade e onde está a sociedade está o Direito”.

As funções do Direito escapam ao objeto desta Introdução, sendo certo que as disposições normativas que o integram voltam-se a, entre outras coisas, estabelecer, de maneira geral e abstrata, as normas de condutas a serem seguidas pelos indivíduos integrantes de determinada sociedade, objetivando, com isso, esclarecer, nortear e orientar a conduta destes sujeitos.

Estes desideratos são alcançados pela descrição de condutas em um plano geral e abstrato e pela respectiva valoração destas, por meio da classificação da conduta descrita como proibida, permitida ou obrigatória.

Assim, temos três grandes grupos de normas integrantes do Direito voltadas a disciplinar a vida em sociedade, a saber: a) normas proibitivas de determinadas condutas; b) normas que geram a obrigatoriedade de outras espécies de conduta; bem como c) normas simplesmente permissivas de outra gama de comportamentos.

Podemos tomar como exemplos do primeiro grupo (normas proibitivas) as normas que estabelecem a proibição de veiculação de propaganda enganosa por parte de uma empresa anunciante, de emissão de gases

poluidores da atmosfera por uma indústria ou a proibição de realização de construções sem a observância de determinados parâmetros de segurança.

O segundo grupo (normas obrigatórias) poderia ser exemplificado com as normas que estabelecem o dever do causador de determinado dano de indenizar aquele que sofreu o prejuízo, ou simplesmente a obrigação daquele que contrair o empréstimo pagar a dívida.

O terceiro conjunto de normas de condutas, as que estabelecem faculdades, ou permissões, poderia ser exemplificado com as normas que estabelecem amplamente o direito de ir e vir, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, ou os direitos e possibilidades de uso e fruição que possui o proprietário de determinada coisa.

Não se quer aqui reduzir o Direito a um simples conjunto de normas com estruturas simples, em que há sempre a previsão de uma conduta, seguida de uma valoração, proibitiva, permitida ou obrigatória, até porque, conforme se verá adiante, muito do fenômeno jurídico hoje está consagrado em princípios jurídicos, normas com estruturas mais abertas e que, por possuírem alto grau de generalidade e abstração, podem ser realizados gradativamente, a depender das condições fáticas e jurídicas¹.

Fato é que, quer por meio de normas com estrutura de regras, quer por normas com estrutura de princípios, o Direito se volta a orientar a vida em sociedade, regulando, nesta medida, as condutas humanas, a situação dos bens jurídicos e as relações entre as pessoas.

Essa necessidade se coloca, entre outros motivos, em função de um dos pilares das ciências econômicas, segundo o qual, as necessidades humanas são ilimitadas, ao passo que os meios de satisfação destas necessidades são, por definição, escassos.

Por “meios de satisfação destas necessidades” devem ser entendidos o consumo de bens ou de serviços voltados à satisfação de uma necessidade.

De maneira bastante simples, podemos pensar o Direito como um

conjunto de normas voltado a resolver este conflito que surge entre as necessidades ilimitadas e as formas de satisfação, por definição, finitas, estabelecendo quais interesses serão protegidos pelo Direito e, por exclusão, aqueles que não terão proteção jurídica.

Nesse contexto, surge o conceito de interesse juridicamente protegido, assim entendido, a proteção pelo Direito do interesse de determinado sujeito que pode, com o apoio das normas jurídicas, impor seu interesse em detrimento dos demais.

Assim, ao regular a propriedade, por exemplo, o Direito nada mais faz do que proteger o interesse de determinado sujeito, o proprietário, em detrimento dos demais, “elegendo” o interesse daquele identificado como proprietário em usar, fruir ou dispor da coisa como juridicamente protegido, excluindo a possibilidade de uso, fruição ou disposição por parte de qualquer outro que não seja identificado como proprietário ou por este autorizado a satisfazer seus interesses.

É o Direito, portanto, que, por meio de regras jurídicas, identifica as formas de aquisição da propriedade de modo a identificar aquele que terá seu interesse protegido, além de estabelecer que interesses decorrem desta proteção, ou deste status jurídico.

Da mesma forma, ao regular a compra e venda, a aposentadoria ou a tributação, o Direito nada mais faz do que traçar condições para que o sujeito se coloque em uma posição jurídica tal que o permita satisfazer seu interesse e exigir inclusive que a conduta de outro (ou outros sujeitos) seja voltada à satisfação deste interesse.

Assim, ao estabelecer os conceitos de comprador e vendedor e estabelecer a relação entre estes dois sujeitos, o Direito passa a proteger o interesse do vendedor em receber o preço e o do comprador em receber a coisa nas condições acordadas.

Da mesma forma, ao estabelecer as condições para a aposentadoria

(idade, tempo de contribuição etc.) o Direito estabelece quem passa a ter condições de exigir o pagamento do benefício previdenciário, sem deixar obviamente de identificar quem deve satisfazer esta pretensão, isto é, subordinar-se a este interesse.

Por fim, apenas para ilustrar o terceiro exemplo suscitado, temos a situação do Direito Tributário, na qual identifica-se determinada situação como geradora da obrigação de recolher aos cofres públicos determinado valor a título de tributo, por exemplo, por parte daquele que auferir renda, que deve, em função de uma norma jurídica (tributária), recolher imposto de renda.

Nesse contexto, a norma jurídica tributária nada mais faz do que identificar os elementos de uma obrigação de um sujeito, o contribuinte, que praticou o fato gerador previsto na norma e que, por isso, deve satisfazer o interesse de outro sujeito em receber o tributo previsto em lei, no caso, a Fazenda Pública.

É de se notar, em todos os exemplos, a natureza bilateral das relações jurídicas, em que é sempre possível identificar um sujeito como detentor de uma pretensão juridicamente protegida e, de outro lado, outro sujeito que deve satisfazer tal pretensão, ou seja, subordinar-se ao interesse alheio sempre que este for juridicamente protegido.

Em suma, a situação dos bens jurídicos e as relações entre as pessoas são definidas pelas normas jurídicas, que devem definir os sujeitos detentores de interesses juridicamente protegidos, a extensão e o objeto desta proteção e, de outro lado, o(s) sujeito(s) que deve(m) se subordinar e satisfazer esta pretensão.

Obviamente, toda esta estrutura jurídico-normativa voltada a regular a situação das pessoas e das coisas só faz sentido se o Direito tiver de ser obrigatoriamente observado.

Em outras palavras, as normas jurídicas, para que sejam capazes de

cumprirem seu papel, devem possuir autoridade suficiente para que possam se fazer observar de maneira impositiva, pois pouco eficiente seria o Direito se, simplesmente, previsse uma conduta como obrigatória ou proibida, mas não pudesse se valer de meios coercitivos para fazer observar seus comandos normativos.

Ademais, a desobediência aos comandos jurídicos também é uma realidade social que não pode ser ignorada pelo Direito que, em função disso, passa a regular também esta situação, prevendo, ao lado das condutas obrigatórias, proibidas ou permitidas, as consequências negativas que deve sofrer aquele que descumprir a norma jurídica.

Às consequências jurídicas que devem experimentar aqueles que descumprirem os comandos normativos dá-se o nome de sanção.

Em resumo, o caráter impositivo do Direito, somado à previsão normativa das sanções, faz com que os comandos jurídicos, uma vez estabelecidos na norma: a) sejam observados; ou b) devam se fazer observar, à força se necessário.

Assim, ou os comandos jurídicos são obedecidos pelos membros de uma sociedade, especialmente por aquele que deve se subordinar a um interesse alheio, ou a situação se torna litigiosa.

A situação de litígio, portanto, surge quando a pretensão de um sujeito que, apoiado no Direito, entende ter um interesse juridicamente protegido, ao invés de ser satisfeita pelo sujeito tido pelo primeiro como obrigado, encontra, por parte deste, uma resistência.

Nesse contexto, é fundamental a identificação do conceito de lide formulado pelo processualista italiano Francesco Carnelutti, para quem a lide é “um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida”.

Tal resistência pode surgir por diversas razões, como a diversidade de entendimento acerca da norma jurídica aplicável a determinada relação jurídica por parte dos sujeitos nela envolvidos, por divergências na

interpretação e na definição do sentido desta norma, ou mesmo pelo simples desejo, declarado ou implicitamente demonstrado, de uma das partes em não cumprir seus deveres jurídicos em relação a outrem.

Fato é que, por qualquer que seja o motivo, uma vez caracterizada a situação litigiosa que contraponha o interesse de dois ou mais sujeitos de direito, surge uma necessidade social e jurídica de solucionar-se a lide, determinando, de maneira definitiva, qual das partes tem razão.

Em outras palavras, uma vez caracterizada uma lide, passa a ser um problema jurídico sua resolução, assim entendida a definição do destino do bem jurídico, por meio da satisfação da pretensão inicialmente resistida, ou da legitimação da resistência.

A forma mais primitiva de resolução da lide é pelo uso da força por uma das partes envolvidas no litígio sobre a outra, a denominada autodefesa, justiça privada ou autotutela.

Entretanto, a autotutela, modernamente, não é admitida pelo Direito, nem poderia ser, pois não garante a vitória da parte cujo interesse é juridicamente protegido, mas sim a vitória da parte que tem mais força.

Por esse motivo, o Direito, via de regra², veda a autotutela estabelecendo ser um fato ilícito e, inclusive, caracterizador de crime fazer justiça com as próprias mãos, ainda que legítimo o Direito (art. 345 do Código Penal).

Ao vedar a via da autotutela como alternativa para a resolução do litígio, o Estado passa a admitir apenas métodos de solução consensuais, como acordos e transações, a seguir estudados³, concentrando em si o poder de impor a solução do litígio não solucionado pelo consenso.

Portanto, a partir da vedação da autotutela pelo Direito, decorrem algumas consequências fundamentais, quais sejam:

a) a concentração do Poder de resolver todos os conflitos de interesses nas mãos do Estado;

b) o dever do Estado de resolver todos os conflitos de interesse que lhe sejam apresentados;

c) o direito do cidadão que se encontre em situação litigiosa de exigir do Estado sua solução;

d) o direito dos demais sujeitos do conflito, especialmente daquele(s) que exerce(m) a resistência, de apresentarem as razões desta resistência ou, em outras palavras, apresentarem, perante o Estado, sua defesa;

e) a necessidade de um conjunto de normas voltadas a disciplinar a forma com que o Estado resolverá a lide com a participação dos sujeitos litigantes.

Ao poder/dever do Estado de resolver todos os conflitos de interesses que lhes sejam apresentados ("a" e "b") dá-se o nome de **jurisdição**.

Já o direito do cidadão de exigir do Estado a prestação jurisdicional ("c") é o direito de **ação**, isto é, o direito de acionar o Estado e exigir deste a solução do conflito por meio do exercício da jurisdição.

O Estado, por sua vez, para que possa solucionar a lide, declarando quem tem razão, deve ouvir não apenas aquele que exerce a pretensão (o autor da ação), mas também aquele que oferece a resistência.

O direito à ampla **defesa** perante o Estado ("d"), bem como o direito de participação de ambas as partes na solução do litígio, constitui, ao lado da ação e da jurisdição, um dos objetos centrais do Direito Processual Civil.

Nesse contexto, o **processo** ("e") nada mais é do que o método pelo qual o Estado, no exercício do Poder Jurisdicional, resolverá a lide, com a participação dos sujeitos litigantes, isto é, o complexo de normas voltado a disciplinar os direitos de ação e de defesa perante o Estado-juiz, que deve atuar, nesta condição, na resolução da lide sempre que provocado.

Jurisdição, ação, defesa e processo são os pontos centrais do Direito Processual Civil.

Capítulo 2 O Direito Processual Civil

Conforme afirmado no capítulo anterior, o Estado, no exercício da jurisdição, tem o poder/dever de resolver todos os conflitos de interesse que lhe sejam apresentados, sendo tão importante quanto definir os direitos e as obrigações, definir o método de resolução de conflitos todas as vezes que as normas gerais e abstratas forem descumpridas ou, mais amplamente, que em função delas nascer um litígio.

É o processo o método de resolução de conflitos por meio da atividade jurisdicional, sendo o Direito Processual Civil o ramo do Direito especificamente ocupado da regulamentação deste fenômeno.

A regulamentação do processo se dá, basicamente, pela disciplina dos poderes e deveres dos sujeitos do processo (juiz, seus auxiliares, partes – autor e réu – e seus respectivos advogados) e pela forma com que estes sujeitos exercem seus poderes, direitos e deveres.

Entretanto, o primeiro passo, no estudo do Direito Processual Civil, é anterior ao estudo das normas processuais civis, haja vista que, antes de estudarmos as normas processuais, em si mesmas consideradas, é preciso identificar onde elas estão consagradas, isto é, identificar as fontes do Direito Processual Civil.

Ademais, é importante a análise da correlação do Direito Processual Civil com os demais ramos do direito material, como o direito constitucional, o direito civil, o direito tributário, o direito ambiental, o direito previdenciário etc., e com o direito processual não civil, como o penal, o trabalhista e o eleitoral.

2.1 Direito Processual e Direito Material

A razão de ser do direito processual decorre da necessidade social,

política e também jurídica de se resolver a lide, assim entendido o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida.

Ocorre que nem todas as relações jurídicas são litigiosas, muito pelo contrário, a esmagadora maioria das relações jurídicas nascem, se desenvolvem e se extinguem sem que haja a caracterização da lide, sendo certo que a regulamentação das relações jurídicas neste estágio não litigioso é tão, ou até mais, importante do que a normatização do processo voltada à solução do litígio.

Por esse motivo, o Direito, por meio de diversos ramos, se ocupa de sistematizar as normas voltadas à disciplina das relações jurídicas, estabelecendo direitos e obrigações entre os sujeitos. A este conjunto de normas, dá-se o nome de direito material que, em última análise, criam, definem e regulam as relações jurídicas e as situações dos bens jurídicos.

Assim, as normas de direito material são necessárias não apenas para orientar os sujeitos, ao estabelecerem as condições para o surgimento, o desenvolvimento, a modificação e a extinção de direitos e obrigações, como também são estas mesmas normas o norte para que o juiz, em situações de litígio, aplicando-as, analise e resolva a lide.

São muitos os ramos do direito material, como o direito civil, o direito tributário, o direito ambiental e o direito previdenciário. Cada um destes ramos se ocupa de regular um grupo específico de relações jurídicas: o direito civil, por exemplo, se ocupa das relações privadas entre os sujeitos de direito particulares; o direito tributário, em apertada síntese, se ocupa de regular a relação entre o Estado-arrecadador e o contribuinte; o direito ambiental, por sua vez, se ocupa da disciplina das normas protetivas do meio ambiente estabelecendo, por exemplo, as condutas proibidas de serem praticadas por serem lesivas ao ecossistema, bem como os deveres e as responsabilidades daqueles que interagem com ele. Já o direito previdenciário se ocupa, basicamente, de estabelecer parâmetros, como tempo de contribuição, idade e demais condições para que o sujeito adquira

o direito de receber sua aposentadoria ou outro benefício previdenciário.

Assim, é o direito material que estabelecerá as condições para a criação e o desenvolvimento dos direitos e obrigações, sendo suas normas, via de regra, suficientes e bastantes para orientar os sujeitos integrantes da relação jurídica, desde que, obviamente, estes sujeitos tenham o mesmo entendimento sobre as normas jurídicas, bem como cumpram os comandos normativos nelas estabelecidos.

Assim, na hipótese de os dois sujeitos de uma relação de compra e venda, regulada pelo direito civil, cumprirem seus deveres e obrigações e entenderem por satisfeito o seu direito, com o comprador pagando o preço no montante e no prazo acertados e recebendo a mercadoria nas condições preestabelecidas, o direito material, por si só, foi suficiente para disciplinar a relação jurídica.

Da mesma forma, se o contribuinte, assim identificado pelo direito tributário, reconhecendo que deve o tributo, realizar o pagamento nos termos ditados pelas normas tributárias, satisfazendo, sem resistência, a pretensão do Estado de receber o valor, a relação jurídica tributária se dará por resolvida apenas com a incidência de normas de direito material.

O mesmo se poderia dizer, se o cidadão entendesse ter preenchidos os requisitos para o recebimento de sua aposentadoria e a mesma interpretação e conclusão fosse a tida pelo órgão responsável por esta análise que, em função disso, procedesse, a partir de então, o pagamento do benefício pretendido, sem resistência.

Em todas as situações descritas, a relação jurídica foi resolvida e, especialmente, a pretensão de um dos sujeitos dela integrantes foi atendida pela parte contrária sem resistência, sendo, nestes contextos, a atuação de normas processuais desnecessária.

O direito processual surge apenas quando esta conclusão consensual e sem resistência não ocorre.

Voltando aos exemplos citados, o direito material, sozinho, deixa de ser o único plexo de normas suficiente para resolução da relação jurídica caso o comprador deixe de pagar o preço ou não receba a mercadoria, caso o contribuinte não pague o tributo, ou caso o responsável pelo pagamento da aposentadoria se recuse a efetuar-lo. Todas essas situações têm em comum, essencialmente, a pretensão exercida de um lado e a resistência, de outro.

Só então, caracterizada a lide pela pretensão resistida, surge a necessidade de atuação do direito processual.

Ao contrário do direito material, o direito processual não se ocupa de regular novamente os direitos e as obrigações, mas sim a forma de se resolver a lide por meio da atuação do poder jurisdicional.

Nesse sentido, o direito processual é o complexo de normas voltado a regular a relação entre os sujeitos em situação de conflito, e entre estes sujeitos e o Estado-juiz que atua na resolução do litígio. O direito processual, portanto, regula a relação jurídica processual que se forma entre aquele que exerce a pretensão (denominado autor), o sujeito que oferece a resistência (réu) e o Estado-juiz, que atua no exercício da jurisdição com a finalidade de ditar a solução do litígio apresentado.

De rigor, ambos os ramos do Direito caminham juntos e devem ser observados pelos sujeitos e, em especial, pelo juiz, que se valerá das normas de direito processual ao conduzir o procedimento e das normas de direito material para, ao final do processo, declarar quem tem razão.

Nesse sentido, o direito processual deve ser entendido como um instrumento do direito material, ou seja, um ramo do Direito que define um método de atuação do Estado-juiz para que este, no exercício do poder jurisdicional, imponha a observância das normas jurídicas.

2.2 Classificação do Direito Processual

No item anterior, procurou-se deixar claro que o direito processual é um complexo de normas instrumentais instituidoras de um método (o processo)

voltado à resolução dos conflitos de interesses, necessário sempre que as normas de direito material não se mostrarem suficientes para tanto, quer porque simplesmente descumpridas, quer por qualquer outro motivo que tenha levado as partes ao litígio.

Esta natureza do direito processual, de se ocupar em estabelecer um método de resolução de litígios, leva a doutrina a destacar o caráter instrumental desse ramo do direito, no sentido de ser o processo um instrumento do direito material.

Entretanto, esta característica de instrumentalidade não torna um processo um mero capítulo do direito material, sendo um ramo de direito autônomo, voltado a regulamentar os direitos e deveres das partes, bem como o procedimento voltado à solução do litígio.

Ademais, é bom que se deixe claro que não há um ramo do direito processual equivalente a cada um dos ramos do direito material existentes, pois o Direito Processual Civil é o complexo de normas voltado a estabelecer o método de resolução de litígio oriundo de inúmeros ramos do direito material.

Assim, de rigor, o Direito Processual Civil estabelece o instrumental para a resolução de litígios oriundos do próprio direito civil, mas também de outros ramos do Direito, como o direito empresarial, o direito tributário, o previdenciário, o administrativo⁴, o direito ambiental, entre muitos outros.

Em outras palavras, os litígios surgidos em qualquer um destes ramos do direito são processados e julgados de acordo com as normas estabelecidas no Direito Processual Civil havendo, nestes casos, no máximo, uma adaptação procedimental para fins de ajuste do processo à situação litigiosa, variação procedimental esta que não gera uma autonomia de “ramos do direito processual”.

Os ramos do direito material que possuem um ramo autônomo de disciplina processual são: o direito penal e o direito do trabalho, cujos

litígios deles oriundos são processados e julgados nos termos de outro complexo de regras, o direito processual penal e o direito processual do trabalho.

A par destes dois casos, existe certa autonomia para os ramos processuais voltados ao exercício da jurisdição e à resolução de conflitos no âmbito do direito eleitoral e no próprio direito constitucional que, em razão de peculiaridades, no plano do direito material, acabam por demandar um direito processual específico.

Desta feita, o Direito Processual Civil possui uma vocação generalista, sendo o complexo de normas instrumentais aplicáveis a quase todas as espécies de litígios, existindo, na qualidade de ramo autônomo do direito processual: a) o direito processual penal; b) o direito processual do trabalho; c) o direito processual eleitoral; d) o direito processual constitucional; com algumas peculiaridades dignas de nota que os diferenciam do Direito Processual Civil.

Além disso, cumpre destacar a existência do “processo administrativo” (item “e”, infra), que, por não regular a atividade jurisdicional, mas, sim, atividade interna do Poder Executivo, sequer pode ser tido como um ramo integrante do Direito Processual no sentido utilizado nesta obra, sendo certo, por outro lado, que se trata de um método (não jurisdicional) de resolução de litígios envolvendo o Estado.

Nos subitens a seguir serão tecidas brevíssimas considerações sobre cada um destes ramos autônomos do direito processual, seu objeto e suas peculiaridades, bem como será abordada a questão do processo administrativo que, por não ser jurisdicional, sequer pode ser classificado como ramo do direito processual no sentido aqui utilizado.

Na sequência, será analisado o caráter genérico e supletivo do Direito Processual Civil (item “f”, infra).

a) Direito Processual Civil e Direito Processual Penal

O direito penal se ocupa de sistematizar um “conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os pratica”⁵.

Nesse sentido, o direito processual penal, como complexo de normas procedimentais voltadas a impor e fazer observar o direito (material) penal, possui objetivos bem distintos do Direito Processual Civil.

Assim, pelas peculiaridades das funções do direito penal e, por via de consequência do processo penal, a ciência jurídica e o legislador destacam o método de atuação do juiz penal, bem como das partes em um processo penal, da disciplina geral estabelecida no Direito Processual Civil, consagrando um ramo autônomo do direito processual, o Direito Processual Penal, e um complexo de normas codificados em outra lei, o Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/41) e leis extravagantes.

Portanto, todas as vezes que a pretensão do autor da ação for apurar a prática de um ato tipificado como crime pelo direito penal, atribuir esta prática a determinado sujeito (o acusado) e estabelecer a sanção penal a este sujeito, se demonstrada para o juiz a culpa do acusado, a atividade das partes e do juízo, bem como os princípios orientadores da atividade processual e todo o procedimento não são regulamentados pelo Direito Processual Civil, mas sim pelo Direito Processual Penal, dotado, portanto, de autonomia científica e de regras próprias com as quais as normas estudadas neste trabalho não se confundem.

b) Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho

Já é longa a tradição de nosso Direito de destacar do regulamento genérico das relações sociais, as relações de trabalho.

Por relação de trabalho devem ser entendidas as relações frutos de contrato, verbal ou escrito, em que alguém presta serviços de maneira pessoal, habitual, subordinada e remunerada a outrem.

Os reflexos das peculiaridades das relações de trabalho nas normas jurídicas voltadas a sua regulação não se restringem ao direito material do trabalho, alcançando a disciplina da relação processual voltada à solução da lide trabalhista, assim entendida o conflito de interesses oriundos de uma das relações disciplinadas pelo direito material do trabalho.

Nesse caso, o mesmo conjunto de leis que conglobera as normas de direito material do trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, se ocupa de regulamentar a atividade do Estado-juiz quando de sua atuação jurisdicional voltada à resolução das lides trabalhistas.

Ademais, o próprio Estado-juiz, neste caso, é representado por um órgão autônomo, competente exclusivamente para a aplicação do direito material e processual do trabalho e a resolução das lides trabalhistas, ou seja, uma Justiça especializada nesta espécie de litígio, a Justiça do Trabalho, prevista entre os arts. 111 a 116 da Constituição Federal que estabelecem tal atribuição às varas e tribunais do trabalho.

No exercício deste mister, a Justiça do Trabalho, quando instada a atuar, deve se valer das normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, conduzindo o processo nos termos ditados por suas regras e princípios processuais.

A existência de um conjunto de normas em apartado, somada às peculiaridades do próprio direito material do trabalho e à existência de uma Justiça especializada na matéria, acabam por configurar um ramo autônomo do direito processual, exclusivamente ocupado da disciplina dos poderes, direitos e deveres das partes, dos juízes e de seus auxiliares no curso do procedimento voltado à resolução da lide trabalhista, o Direito Processual do Trabalho.

Entretanto, em que pese esta autonomia, é preciso ressaltar que o Direito Processual do Trabalho é incompleto, no sentido de não possuir normas processuais suficientes para a disciplina integral do processo

trabalhista sendo, em função destas lacunas, aplicáveis de uma maneira supletiva, as normas pertencentes ao Direito Processual Civil.

c) Direito Processual Civil e Direito Processual Eleitoral

Outro ramo do direito que, tal como o direito do trabalho, tem peculiaridades tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista processual, possuindo, portanto, um conjunto, ainda que incompleto, de normas processuais, é o Direito eleitoral.

Além disso, também a exemplo do Direito do Trabalho, as lides originárias do Direito Eleitoral são processadas e julgadas por órgãos autônomos do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral.

O Direito Processual Eleitoral, portanto, destaca-se do Direito Processual Civil na medida em que: 1) possui um conjunto de regras procedimentais específicas e exclusivamente aplicáveis às lides eleitorais; e 2) possui um conjunto próprio de órgãos jurisdicionais especializados na matéria, o que acaba por consagrar um ramo do direito processual próprio cuja função é, em síntese, disciplinar o procedimento de solução das lides eleitorais.

O direito (material) eleitoral, em resumo, se ocupa da resolução de litígios oriundos das eleições para os cargos de chefia do Poder Executivo e para os cargos do legislativo, ambos nos planos federal, estadual e municipal.

As normas disciplinadoras das eleições são estabelecidas no Código Eleitoral e na legislação eleitoral extravagante que, a par de veicularem normas de direito material, também disciplinam a atividade das partes e do juízo eleitoral rumo à solução de litígios, estabelecendo, por exemplo, prazos diferenciados e recursos exclusivamente cabíveis na Justiça Eleitoral, normas processuais, portanto.

Assim, os juízes eleitorais, bem como os advogados e todos aqueles que atuam perante a Justiça Eleitoral nos processos voltados à resolução das lides surgidas no curso das eleições, devem se valer destas regras próprias

integrantes do direito processual eleitoral.

Contudo, tal como o Direito Processual do Trabalho, o Direito Processual Eleitoral encerra um sistema incompleto de normas processuais, fazendo-se necessária a aplicação supletiva do Direito Processual Civil aos processos eleitorais quando ausente norma processual específica no Código Eleitoral ou legislação extravagante.

d) Direito Processual Civil e Direito Processual Constitucional

A par de estabelecer normas processuais civis, notadamente com estrutura de princípios, mas também com estrutura de regras, a Constituição Federal se ocupa de disciplinar processos exclusivamente constitucionais.

Desta feita, além de ser a principal fonte do Direito Processual Civil⁶, a Constituição Federal consagra, em seu texto, normas específicas de um sistema de processo constitucional.

Por processo constitucional, devem ser entendidos os mecanismos processuais e procedimentos previstos na Constituição Federal como instrumentos de exercício da denominada “jurisdição constitucional”.

A jurisdição constitucional, por sua vez, deve ser considerada o exercício, pelo Poder Judiciário, do controle concentrado de constitucionalidade, isto é, da fiscalização da compatibilidade entre os atos e normas produzidos pelo Poder Público e as normas constitucionais ou, em um sentido mais amplo, a atribuição do Judiciário de tutelar, preservar e concretizar as normas fundamentais consagradas na Constituição Federal⁷⁻⁸.

Assim, ao lado da jurisdição civil, da jurisdição penal, da jurisdição trabalhista e da jurisdição eleitoral, o ordenamento jurídico brasileiro consagra uma jurisdição constitucional voltada à limitação, ao controle e à racionalização do poder estatal⁹.

Como todo o Poder Jurisdicional, a jurisdição constitucional deve ser

exercida pelo Poder Judiciário, no curso de um procedimento, observados os princípios e as regras processuais que estabelecem a competência dos órgãos jurisdicionais, os poderes e deveres do juiz, bem como os direitos e deveres das partes, a forma, o prazo e demais detalhes dos atos processuais, sendo certo, portanto, que deve ser disciplinado, para fins do exercício desta jurisdição, um processo constitucional.

O Direito Processual Constitucional, portanto, é o sistema de normas voltado a disciplinar o procedimento e demais aspectos processuais do exercício da jurisdição constitucional pelos órgãos incumbidos desta tarefa pela própria Constituição Federal.

São exemplos de processos constitucionais os decorrentes das ações diretas de constitucionalidade (ADIN, ADC e ADPF) e da ação de Mandado de Injunção.

É preciso destacar, entretanto, que nem todas as normas processuais da Constituição Federal são normas integrantes do Direito Processual Constitucional, pois a Constituição também é riquíssima em normas processuais civis, voltadas a disciplinar o exercício da Jurisdição civil e integrantes, portanto, do Direito Processual Civil.

Por esse motivo, Nelson Nery Jr.¹⁰ diferencia, para fins didáticos, o Direito Constitucional Processual do Direito Processual Constitucional. O primeiro é o conjunto de normas de Direito Processual que se encontra na Constituição Federal; ao passo que o Direito Processual Constitucional consiste na reunião de princípios para fins de regular denominada jurisdição constitucional.

Assim, a par de um Direito Processual Constitucional, a Constituição de 1988 contém regras de Direito Constitucional Processual, portanto normas integrantes do Direito Processual Civil.

Estas normas processuais civis com sede constitucional são especialmente previstas na Constituição Federal na forma de princípios,

como o contraditório, a ampla defesa e o juiz natural, a serem estudados no Capítulo 6, e regras, que serão estudadas no item 6.2, como as que estabelecem o cabimento de recursos especial e extraordinário e a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar determinadas causas cíveis.

Em suma, a par de ser a fonte primordial do Direito Processual Constitucional, a Constituição Federal, conforme se verá a seguir, também é a principal fonte do Direito Processual Civil, portanto, a fonte deste ramo do direito voltado ao exercício da jurisdição civil.

e) Direito Processual Civil e o denominado “Processo Administrativo”

Não obstante possa se falar na existência de um processo administrativo, não jurisdicional, não existe, enquanto ramo autônomo do Direito, um direito processual administrativo.

O processo administrativo, apesar desta nomenclatura, não se ocupa de regulamentar uma atividade jurisdicional, mas apenas a atividade interna das repartições públicas em resposta a pleitos dos cidadãos e resolução de questões interna corporis.

Em suma, o processo (ou procedimento) administrativo deve ser entendido como um conjunto de atos praticados pelo Estado, com ou sem a participação de um particular, voltado ao atingimento de uma finalidade pela Administração Pública.

Não se trata, portanto, de um método voltado, necessariamente, à resolução de litígios, até porque, é por meio de um processo administrativo que, por exemplo, a Administração Pública adquire bens e serviços (processo licitatório), bem como contrata servidores públicos para o exercício de suas funções (procedimento de concurso público).

É possível, até mesmo, a resolução de conflitos por intermédio do processo administrativo, sendo certo, entretanto, que, por não se tratar de

uma resolução ditada pelo Poder Judiciário no exercício da jurisdição, a decisão administrativa não resolve definitivamente o conflito, que ainda pode ser levado à Justiça.

Ademais, a processo administrativo não é o método adequado para que todas as pretensões do Estado ou contra o Estado sejam analisadas ou concedidas, sendo os litígios administrativos, assim entendidos, as pretensões resistidas entre cidadão e Poder Público, resolvidas pelo Poder Judiciário, salvo se cessada a pretensão ou a resistência pela via administrativa.

Desta feita, quando o Estado pretende demandar alguém, ou quando o Estado for demandado perante o Poder Judiciário, as atividades de ambos, na qualidade de partes da relação processual, bem como a do juiz e de seus auxiliares, enquanto condutores do procedimento, serão ditadas pelo Direito Processual Civil, nestes casos, no máximo, com algumas regras especiais aplicáveis aos processos que envolvem o Estado.

A existência destas regras, contudo, não permite a conclusão da existência de um ramo autônomo e separado do Direito Processual Civil, caracterizando-se, no máximo, um Direito Processual Civil afetado pela presença do Poder Público em juízo¹¹.

Por esses motivos, o processo administrativo não dá origem a um ramo do Direito, sendo as regras procedimentais internas de atuação dos agentes públicos e os métodos não jurisdicionais de resolução de conflitos em sede administrativa, meros capítulos do Direito (material) Administrativo. Os processos voltados à resolução jurisdicional de litígios que envolvem o Estado são disciplinados pelo Direito Processual Civil com algumas regras especiais aplicáveis a estes feitos pelo fato de o Poder Público ser uma das partes.

Nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil, as disposições do CPC aplicam-se de maneira supletiva e subsidiária ao processo administrativo,

na ausência de norma específica que regule a situação.

f) Direito Processual Civil e seu caráter geral e supletivo

Conforme já asseverado, exceção feita a quatro ramos do direito material: direito penal; do trabalho; eleitoral; e constitucional, no que se refere à jurisdição constitucional, é o Direito Processual Civil o complexo de normas disciplinadoras do método de atuação do Poder Judiciário para a solução dos litígios oriundos de qualquer outro ramo do direito.

Desta feita, independentemente de a pretensão se fundar em direito civil propriamente dito, direito tributário, empresarial ou previdenciário, as normas de atuação do juiz e das partes e todo o procedimento rumo à solução do litígio seguirá os termos do Direito Processual Civil.

É pelo sistema previsto no Direito Processual Civil que é disciplinado o processo no qual o Poder Público é parte quer como autor, exercendo uma pretensão contra o particular, quer como réu, demandado por outro sujeito de direitos, o que implica dizer que o Estado, enquanto sujeito processual, se submete ao mesmo sistema normativo processual que os demais sujeitos, havendo, quando muito, algumas peculiaridades nestes casos.

Nesse sentido, o Direito Processual Civil também é o método de atuação no plano jurisdicional do Direito Administrativo.

Ademais, conforme se demonstrou, especialmente nos itens “b” e “c” deste capítulo, as normas processuais civis possuem caráter supletivo e se aplicam, por exemplo, nos processos do trabalho e eleitoral na falta de normas específicas componentes do direito processual eleitoral e do direito processual trabalhista.

Feitas estas observações e esclarecido o papel das normas processuais civis, o passo seguinte para se continuar o estudo do Direito Processual Civil é conhecer os veículos normativos em que estas normas estão consagradas, ou seja, conhecer as fontes do Direito Processual Civil, o que será feito a seguir.

2.3 Fontes do Direito Processual Civil: a norma processual civil e sua consagração

Pensar o Direito enquanto um conjunto de normas voltado a reger a vida em sociedade e o Direito Processual como um conjunto voltado a regulamentar a atividade jurisdicional e a atuação das partes no curso do procedimento, pode ser considerado o ponto de partida para se estudar o Processo Civil.

Ocorre que duas noções anteriores a estas precisam ser preestabelecidas antes de estudarmos o sistema processual enquanto um “conjunto de normas” voltadas a delinear o desenvolvimento da relação processual entre autor, réu e Estado-juiz.

A primeira delas é o conceito de norma jurídica e, especialmente, o conceito de norma processual civil.

A par disso, tão importante quanto o conhecimento da norma enquanto unidade, cujo conjunto forma o sistema jurídico, é imperioso conhecermos onde tais normas restam consagradas, isto é, o que faz delas normas jurídicas com vigência, validade e eficácia e, portanto, de obrigatória observância pelas partes, pelo juiz e pelos demais sujeitos processuais.

Tal resposta emerge do estudo das fontes do Direito Processual Civil, ou seja, do conhecimento de quais são os diplomas normativos que consagram a norma que, no caso da norma processual civil, são: a) a Constituição Federal; b) as leis federais; e, em menor medida, c) as constituições e leis estaduais; e d) os regimentos internos dos tribunais.

Além disso, dado o sempre presente, e crescente, papel da jurisprudência no Processo Civil brasileiro, também deve ser investigado seu papel e sua influência enquanto fonte do Direito Processual.

2.3.1 Normas processuais: conceito e classificação

Partindo da dicotomia existente entre o direito material e direito

processual, Cintra, Dinamarco e Grinover¹² asseveram que são normas jurídicas materiais as que disciplinam a cooperação entre os sujeitos e os conflitos de interesse ocorrentes na sociedade, ao passo que as normas processuais disciplinam a resolução dos conflitos interindividuais pelo Estado.

Portanto, é correto afirmar que toda norma jurídica voltada a regulamentação: a) da atividade jurisdicional, incluídas, neste conjunto, as normas de criação e estruturação dos próprios órgãos do Poder Judiciário; b) dos direitos e deveres das partes e do juízo; bem como c) do modo de exercer estes direitos; é norma processual, independentemente de onde esteja consagrada, se no Código de Processo Civil ou fora dele.

Isso porque, conforme será demonstrado a seguir, o Código de Processo Civil, enquanto lei federal¹³, é apenas uma das leis federais que regem o processo, sendo ademais, as leis, propriamente ditas, apenas uma entre outras fontes do Direito Processual Civil.

2.3.1.1 Espécies de normas processuais

Partindo do conceito de norma jurídica processual exposto, a doutrina elenca três espécies de normas processuais, a saber: a) normas de organização do Poder Judiciário; b) normas que regulam a relação jurídica processual; e c) normas procedimentais.

Normas de organização do Poder Judiciário (“a”) são todas as normas voltadas a criação, estruturação e repartição de competências dos órgãos jurisdicionais.

Entre elas, portanto, estão todas as normas que preveem a existência dos tribunais, bem como sua composição e competência.

A Constituição Federal possui normas desse tipo especialmente no que tange a criação, estruturação e competência de tribunais, como em seu art. 101, que dispõe: “o Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta

e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada”.

Previsões semelhantes podem ser encontradas, na Constituição Federal, no art. 104, que prevê a existência e a competência do Superior Tribunal de Justiça, e no art. 106, no que se refere aos juízes e aos tribunais regionais federais, entre outros.

A par de preverem a existência dos órgãos jurisdicionais, é natural que as normas de organização judiciária estabeleçam a competência desses órgãos, definindo a espécie de causa que deve ser processada e julgada perante cada um deles.

Ademais, é muito comum que o regramento da repartição de competências seja detalhado e complementado pela lei, como são exemplos as normas que estabelecem critérios de repartição de competências considerando o objeto do litígio, o domicílio das partes, entre outros critérios, cuja análise escapa ao objeto deste item¹⁴.

Outro grupo de normas são aquelas que regulam a relação jurídica processual (“b”), ou seja, que estabelecem os direitos e deveres das partes do processo, bem como os poderes e deveres do juiz.

São normas processuais reguladoras da relação processual, por exemplo, aquelas que consagram o direito de as partes apresentarem requerimentos, alegações e praticarem atividade probatória no curso do processo, assim como aquelas voltadas a estabelecer o dever do juiz de conduzir o processo e solucionar a lide. A esta espécie de normas processuais, indispensável para a compreensão do Direito Processual Civil, será dedicado o Capítulo 9 desta Introdução.

Por fim, são normas processuais, por óbvio, todas aquelas voltadas a regular o procedimento, assim entendido a sequência lógica dos atos processuais, bem como a forma, o prazo, o momento e a possibilidade de exercê-los.

Assim, são normas procedimentais todas aquelas que regulam o

momento e a forma da prática do ato processual e suas consequências no âmbito do procedimento, como os arts. 319, 320 e 321 do CPC, que disciplinam a petição inicial, os arts. 335, 336 e 337, que dispõem sobre a forma, o prazo e o conteúdo da contestação a ser apresentada pelo réu, e o art. 361 do CPC, que disciplina a produção de provas em audiência.

O Direito Processual Civil é o sistema que emerge da conjugação de todas estas espécies de normas que, por sua vez, podem estar consagradas em algumas fontes, em especial, a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, e outras leis e veículos normativos, como o regimento interno dos tribunais.

A cada uma destas fontes do Direito Processual Civil será dedicado um subitem na sequência.

2.3.2 Fontes do Direito Processual Civil

Conforme visto no item anterior, as normas processuais civis são todos os comandos jurídicos voltados a regulamentar a atividade jurisdicional, os direitos e deveres das partes e do juiz, bem como o rito procedimental do processo.

Dito isso, é fundamental conhecermos onde estas normas estão consagradas, isto é, o que faz com que estes comandos sejam tidos como válidos e integrantes do sistema jurídico processual.

Essa consagração se dá por meio das fontes do Direito, ou seja, da previsão destas normas em textos e outros institutos tidos pelo próprio Direito como instrumentos formais aptos a criar e estabelecer normas jurídicas.

O estudo completo das fontes do Direito extrapola, portanto, o Direito Processual Civil, sendo pertencente à própria teoria geral do Direito.

Nesta Introdução, faz-se necessário, apenas, assinalar que é de nossa tradição jurídica termos por fontes do Direito textos escritos consagrados em alguns veículos normativos existentes no sistema.

Essa tradição se reflete no Direito Processual Civil, que possui como principais fontes: a) a Constituição Federal; b) as leis federais; e, em menor medida, c) as constituições e leis estaduais; e d) os regimentos internos dos tribunais.

Além disso, dado o sempre presente, e crescente, papel da jurisprudência no Processo Civil brasileiro, também deve ser investigado seu papel e sua influência enquanto fonte do Direito Processual.

Assim, é a partir do conhecimento das normas jurídicas consagradas nas fontes arroladas anteriormente que o operador do Direito Processual estará apto a identificar quais são as normas integrantes do sistema.

Importante ressaltar, desde já, que entre estas fontes do Direito existe uma relação de hierarquia, o que implica dizer que, a depender da fonte na qual a norma jurídica esteja consagrada, esta possui maior grau de importância, não podendo ser desrespeitada por normas consagradas em fontes de hierarquia inferior.

Nesse contexto, a fonte mais importante de todo o sistema jurídico e, por consequência, do Direito Processual Civil, é a Constituição Federal, estando, neste diploma, as normas mais importantes e fundamentais do sistema.

Na sequência, em um grau inferior na hierarquia, estão as leis federais que, nos termos da própria Constituição, são o principal veículo de normas processuais responsáveis por regulamentar toda a atividade processual desde que, obviamente, as normas previstas em lei respeitem e estejam de acordo com as normas constitucionais.

Assim, há uma relação entre as leis e a Constituição, sendo esta o veículo das normas mais gerais e fundamentais do sistema processual, e aquelas o veículo normativo responsável por completar e detalhar o sistema processual.

Conforme será visto adiante, a Constituição Federal consagra as normas processuais fundamentais, via de regra, com estrutura de princípios, sem,

contudo, adentrar em detalhes específicos, deixando a previsão e a regulamentação de tais detalhes para a lei federal.

A título de exemplo desta relação de complementaridade, podemos aludir à previsão constitucional e à regulamentação legal da defesa processual. Sobre este tema, a Constituição Federal dedica apenas uma norma, que, de maneira geral e fundamental, consagra o direito de “ampla defesa” a todos os litigantes em seu art. 5º, inc. LV, que dispõe “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Entretanto, a Constituição Federal não adentra em detalhes acerca do direito de defesa, não dispondo, por exemplo, de que forma e em que prazo essa defesa deve ser apresentada.

Isso porque a previsão desse detalhamento, não obstante importantíssima para o andamento do processo, não é papel da Constituição Federal como norma fundamental do sistema jurídico.

Considerando a distinção entre as normas com estrutura de princípios e aquelas com estrutura de regras, à qual será dedicado o item 6.1, seria correto afirmar que a Constituição Federal é rica em normas com estrutura de princípios, apesar de conter algumas regras. O detalhamento do conteúdo, o alcance e os desdobramentos destes princípios são feitos pelas regras processuais previstas na lei infraconstitucional.

Assim, voltando ao direito de defesa constitucionalmente consagrado no art. 5º, inc. LV, notaremos que está na lei federal a regulamentação dos detalhes do exercício da defesa, ou seja, está na lei federal a forma e o prazo em que a defesa deve ser exercida, via de regra, pela contestação, no prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 335, 336 e 337 do Código de Processo Civil.

Em resumo, não obstante estarem na Constituição as normas processuais

mais importantes, sob o aspecto quantitativo é a lei federal a fonte do direito que consagra o maior número de normas processuais.

Entre as leis federais, aquela que merece o maior destaque é o Código de Processo Civil¹⁵, diploma que, como via de regra os códigos são elaborados, procura compilar e sistematizar todas as normas processuais que integram o sistema jurídico e portanto, funcionar como a principal, ainda que não única, fonte do direito processual.

Entretanto, mesmo em sistemas codificados como o brasileiro, o Código de Processo Civil nunca pode ser tido como a única fonte do Direito Processual, a começar pelo fato de existir, e estar acima de todos os códigos e de todas as leis do país, a Constituição Federal que, conforme já dito e será detalhado em capítulo próprio¹⁶, consagra as mais importantes normas processuais do país.

A par disso, nada impede que outras leis regulem algum aspecto do sistema processual, coexistindo, portanto, ao lado do Código de Processo Civil, outras leis processuais, de igual hierarquia, que também consagram normas processuais civis. Tais leis, por estarem fora do código e ainda assim regularem o processo civil, ganham a qualidade de leis extravagantes, ou esparsas.

Contudo, dada a idêntica hierarquia entre o Código de Processo Civil e a legislação extravagante, ambas leis federais, é indiferente que a norma esteja consagrada neste ou naquele diploma, pois ambos são fontes do Direito Processual Civil.

Via de regra, as leis extravagantes estabelecem normas complementares e específicas de determinado procedimento ou microssistema processual-especial. São exemplos de leis processuais extravagantes a Lei n. 9.099/95, que regula, fora do Código de Processo Civil, o procedimento do microssistema dos juizados especiais, e a Lei n. 12.016/2009, que se volta a regulamentar o procedimento do mandado de segurança.

Ainda assim, mesmo nestes procedimentos regulados por leis extravagantes, as normas gerais do Código de Processo Civil acabam por exercer um papel importante, o de complementar as normas não previstas na legislação especial.

Outro ponto que merece destaque no estudo das fontes do Direito Processual Civil é o fato de toda a legislação infraconstitucional do Processo Civil brasileiro ser eminentemente de cunho federal.

Isto se dá por expressa exigência constitucional (art. 22, inc. I, da Constituição Federal) e visa uniformizar a disciplina do Direito Processual Civil em todo o território nacional, posto que, do contrário, cada Estado da federação, ou quiçá cada Município, poderia ter seu conjunto de regras processuais.

Assim, para evitar tal profusão de normas e sistemas processuais, o Direito Processual Civil brasileiro possui, como fonte primordial, além da Constituição, a lei federal, por óbvio, válida em todo o território nacional e, portanto, apesar de cada Estado da federação possuir sua própria Constituição estadual e sua própria legislação, é, em grande medida, vedado a estes diplomas locais disporem sobre normas processuais.

Há duas exceções, contudo, à afirmação anterior: a) a possibilidade de a Constituição e as leis estaduais disporem sobre a organização do Poder Judiciário do próprio Estado; e b) a possibilidade de as leis estaduais disporem sobre procedimento em matéria processual.

A primeira possibilidade diz respeito, portanto, à liberdade que cada Estado tem de, por meio de sua constituição ou de leis estaduais, criar, modificar ou extinguir órgãos jurisdicionais da Justiça estadual.

Tal possibilidade se justifica não apenas porque o orçamento do Poder Judiciário estadual é de responsabilidade de cada Estado, mas também pelo fato de a necessidade de criação ou extinção de órgãos da Justiça estadual ser muito mais facilmente sentida pelos representantes locais da

Assembleia Legislativa do que pelos representantes nacionais atuantes no Congresso Nacional.

Note-se que esta autorização, de criar, modificar ou extinguir os órgãos jurisdicionais da Justiça estadual, não autoriza que as Constituições e leis estaduais regulamentem e consagrem normas locais em matéria processual, mas apenas autorizam a normatização e a adaptação, à realidade local de cada Estado, desse aspecto do Direito Processual Civil, basicamente quantos são e quais são os órgãos jurisdicionais.

Uma vez criados estes órgãos, não obstante pertencerem à Justiça estadual, a condução dos processos por seus juízes deve se dar nos termos da Constituição e das leis federais, como dito, as fontes do Direito Processual Civil uniformes para todo o território nacional.

A outra possibilidade em que a Constituição autoriza que leis estaduais regulem o processo é para estabelecerem procedimento em matéria processual.

Aqui, mais uma vez, segundo a maioria da doutrina, o intuito da Constituição é permitir que o legislador estadual por, em tese, perceber melhor a realidade daquela região, possa estabelecer regras procedimentais mais condizentes com o Estado no qual atua.

Esta autorização, contudo, não permite que a lei estadual restrinja ou mesmo crie direitos e garantias processuais diferentes da lei federal, pois isso feriria a uniformização do sistema processual prevista na Constituição Federal ao consagrar a lei federal como fonte do Direito Processual Civil.

Ademais, a par das leis e da própria Constituição, em uma medida ainda menor e hierarquicamente abaixo destes diplomas, devem ser considerados fonte do Direito Processual Civil os regimentos internos dos tribunais.

Tais veículos normativos voltam-se a regulamentar questões internas de cada tribunal, como horário de funcionamento, composição e competência de cada um de seus órgãos fracionários e consequente distribuição de

tarefas e deveres.

Essas questões, por não estarem previstas em lei ou, muito menos, na Constituição, precisam ser regulamentadas por estes diplomas normativos, que cada um dos tribunais cria, e que, por óbvio, possuem força apenas no âmbito de sua esfera de competência.

É de se ressaltar, neste ponto, que não cabe aos regimentos internos dos tribunais criar novos direitos ou procedimentos não previstos em lei, nem, muito menos, contrariar o disposto nas leis e na Constituição, funcionando, assim, apenas e tão somente como um diploma complementar e interno, regulador de questões não disciplinadas pelas fontes de superior hierarquia.

Em caso de confronto entre uma norma regimental e uma norma prevista em lei, esta última sempre deve prevalecer.

Por fim, não pode ser desconsiderado o papel da jurisprudência como fonte do Direito Processual Civil.

Por jurisprudência, deve ser entendido o conjunto de decisões reiteradas proferidas pelos tribunais sobre uma mesma matéria em um mesmo sentido.

Assim, todas as vezes que um tribunal passa a se manifestar reiteradas vezes sobre a interpretação ou a aplicação de determinada norma jurídica, ao conjunto destas decisões proferidas repetidas vezes dá-se o nome de jurisprudência.

Assim, sobretudo nos casos em que as normas legais e constitucionais dão margem a dúvidas ou duplas interpretações, é na jurisprudência que o operador do Direito pode vir a ter certeza do conteúdo, do alcance e da correta interpretação da norma.

Tal papel de fonte do Direito, inclusive do Direito Processual, que possui a jurisprudência ganha força sobretudo a partir do momento em que o sistema processual e a própria Constituição Federal atribuem efeito vinculante a determinadas expressões da jurisprudência, notadamente, as

súmulas e os precedentes formalizados em determinados incidentes.

As súmulas, quando editadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca do alcance, da constitucionalidade e da interpretação de determinada lei, devem ser seguidas por todos os órgãos do Poder Judiciário e Executivo, orientando, portanto, todos os operadores do sistema processual de maneira obrigatória.

Assim, se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal se manifestar e editar uma súmula vinculante estabelecendo que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições previdenciárias é de cinco anos, todos os juízes e tribunais, assim como os órgãos públicos responsáveis pela sua arrecadação, devem observar o referido prazo.

Por força disso, é inegável serem a jurisprudência e, em especial, a súmula e precedentes vinculantes fontes do Direito Processual Civil.

Os subitens a seguir serão dedicados às peculiaridades de cada uma das fontes do Direito Processual Civil.

a) Constituição Federal

Um fenômeno que vem atingindo os mais diversos ramos do Direito desde o final do século XX, não só no Brasil, mas também nos ordenamentos jurídicos estrangeiros, é a denominada constitucionalização do Direito, inclusive do Direito Processual Civil.

Por constitucionalização do Direito Processual Civil deve ser entendida a inserção de normas processuais no texto da Constituição Federal, muitas delas com status de verdadeiros direitos fundamentais.

A Constituição Federal é a principal fonte normativa do ordenamento jurídico brasileiro, sendo suas normas hierarquicamente superiores a todas as demais normas consagradas em outros veículos normativos.

A par da superioridade hierárquica, a Constituição Federal se caracteriza por ser o diploma normativo voltado a estabelecer: a) a forma e a estrutura

do Estado; b) os Poderes do Estado e a forma de inter-relação entre os poderes; c) o método de produção legislativa; e d) os direitos fundamentais.

Assim, é a Constituição Federal que estabelece ser o Brasil uma República e um Estado Democrático de Direito, bem como é a Constituição que prevê a existência de três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si, sendo de status constitucional as principais regras que dispõem sobre as funções e a estrutura do Poder Judiciário.

Só o fato de as principais normas de organização do Poder Judiciário estarem na Constituição Federal a torna uma fonte do Direito Processual Civil e obriga o estudioso e aplicador do direito processual a se ocupar do estudo das normas constitucionais, já que é no Poder Judiciário que se desenvolve o processo, sendo esta estrutura e seus membros os principais responsáveis pela condução e pela resolução do processo.

Entretanto, as normas de organização do Poder Judiciário não são as únicas normas processuais inseridas na Constituição Federal, isso porque, especialmente em seu art. 5º, mas não apenas nele, a Constituição arrola os direitos e as garantias fundamentais do cidadão que, dada a superioridade hierárquica das normas constitucionais, não podem ser afastados pela legislação ordinária e devem ser respeitados e aplicados ainda que ausente norma infraconstitucional que discipline a garantia no caso concreto, sendo certo que, entre os referidos direitos fundamentais, encontram-se diversos direitos e garantias de natureza processual.

Portanto, hoje, o desenho do processo é extraído diretamente da Constituição Federal, a começar pela garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional disposta no art. 5º, inc. XXXV, que consagra em sede constitucional o direito de ação, isto é, o direito de exigir do Poder Judiciário uma prestação jurisdicional que atualmente, muito mais do que um direito a uma sentença de mérito ou uma simples resposta do

Estado-juiz acerca do direito discutido no processo, deve ser entendida como o direito a uma tutela jurisdicional justa, efetiva e em tempo razoável.

Igualmente, o processo, ou seja, o método pelo qual o direito de ação é atendido e a tutela jurisdicional é prestada, encontra-se moldado pela Constituição Federal, que garante a todos os litigantes o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), a publicidade dos atos processuais, o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX), bem como seu desenvolvimento em tempo razoável, nos termos do art. 5º, inc. LXXVIII, introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004.

Tais princípios e garantias, de maneira geral, abarcados pela cláusula do devido processo legal (art. 5º, LVI)¹⁷, encerram o que se pode chamar de modelo constitucional de processo civil¹⁸.

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno¹⁹ sustenta estar na Constituição Federal o “modelo constitucional de processo civil” e afirma que “o plano constitucional delimita, impõe, molda o modo de ser de todo o Direito Processual Civil e cada um dos seus temas e institutos”.

Este capítulo, e principalmente este subitem, tem por objetivo estudar a Constituição Federal como fonte do Direito Processual Civil e o papel das normas constitucionais na disciplina do processo. Já no Capítulo 6, serão estudados cada um dos princípios processuais constitucionais, em espécie, seus fundamentos, alcance e principais desdobramentos.

O Capítulo 5 será dedicado à análise da estrutura do Poder Judiciário estabelecida, conforme já asseverado, as normas estabelecidas na Constituição Federal.

b) Leis federais

Se por um lado a Constituição Federal possui as normas mais importantes do Direito Processual Civil, dada sua superioridade hierárquica e a consagração das normas fundamentais do Processo Civil brasileiro, a lei

federal é, do ponto de vista quantitativo, a principal fonte para o estudioso e operador do Direito Processual.

Isso porque na lei federal está a maior parte das normas processuais civis, a começar pelo próprio Código de Processo Civil, que nada mais é do que uma lei federal (Lei n. 13.105/2015).

Portanto, enquanto a Constituição Federal possui as normas-chave e fundamentais do sistema processual, normalmente consagradas nos princípios, a lei federal traz as regras processuais, detalhando, concretizando e densificando os direitos genericamente consagrados na Carta Magna.

Em outras palavras, ao passo que a Constituição Federal estabelece os direitos fundamentais de maneira genérica e abstrata, as normas constantes em lei federal, em especial, no Código de Processo Civil, estabelecem a forma, o prazo e o momento de se exercer cada um destes direitos, além de detalhar e definir com mais precisão seu alcance e sentido.

A título de exemplo, pode ser citada a densificação dos princípios do contraditório e ampla defesa, previstos, nestes termos generalíssimos e abstratos, no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, que dispõe “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, direitos que, na lei federal, e, em especial, no Código de Processo Civil, são detalhados, ou seja, pormenorizados e regulamentados, sendo as regras legais as responsáveis pela definição de como e quando o contraditório e ampla defesa podem ou devem ser exercidos.

Nesse sentido, se decorrem diretamente da interpretação do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, genericamente, os direitos de informação, reação e participação das partes do processo²⁰, o Código de Processo Civil detalha e regulamenta exaustivamente as formas de se

praticarem estes atos de comunicação, reação e participação.

Só os atos de comunicação, por exemplo, que no plano constitucional é uma simples decorrência da regra generalíssima que garante o contraditório, são disciplinados pelo Código de Processo Civil em 40 artigos (arts. 236 a 275) nos quais estão pormenorizados os métodos e as formas das citações e intimações, bem como as hipóteses em que elas devem ser realizadas, se pelo correio, pelo oficial de justiça e por publicações on-line.

Da mesma forma, se decorre da previsão constitucional do direito à “ampla defesa” o direito de as partes produzirem provas durante o processo, o Código de Processo Civil, em mais de cem artigos, regulamenta os meios de prova (pericial, testemunhal, documental etc.), bem como o procedimento e as demais regras de produção probatória.

Outro exemplo que ilustra esta relação de densificação entre a lei federal e a Constituição pode ser encontrado nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. Isso porque o art. 5º, inc. LVIII, da Constituição Federal consagra o princípio do juiz natural, que garante a todos, entre outras coisas, o direito de ser julgado por um juiz imparcial²¹.

Ocorre que a Constituição se limita a consagrar o princípio do juiz natural sem, entretanto, se preocupar em estabelecer quais as hipóteses em que a imparcialidade do juiz é tida por comprometida. Este grau de detalhamento é feito pela lei, no caso, pelos citados arts. 144 e 145 do CPC, que possuem um rol de situações específicas em que o juiz é tido por parcial, como ser cônjuge, ascendente ou descendente de uma das partes ou de um dos advogados.

Situações como estas se multiplicam no Código de Processo Civil e na legislação extravagante, sendo fundamental, para um estudo completo do Direito Processual Civil, partir dos princípios constitucionalmente consagrados para, na sequência, voltar-se ao conhecimento, à sistematização, à interpretação e à aplicação das regras processuais

constantes nas leis federais, sempre à luz dos princípios constitucionais.

Desta feita, a relação entre a Constituição e a lei federal é de complementação, sendo o papel da lei, no sistema jurídico processual, descer a um maior grau de detalhe, respeitando, concretizando e viabilizando os direitos constitucionalmente garantidos.

Alguns pontos a respeito da lei federal merecem destaque neste item, a começar pela sua posição de inferioridade hierárquica em relação às normas constitucionais, o que implica dizer que as leis federais infraconstitucionais devem respeitar os ditames constitucionais e buscar viabilizar o exercício dos direitos consagrados na Constituição Federal.

Portanto, obviamente, não deve haver leis federais que contrariem os dispositivos constitucionais e, caso isso ocorra, a lei federal deverá ser considerada e declarada nula em função de sua inconstitucionalidade.

A necessidade de a lei processual ser federal decorre da previsão constitucional consagrada no art. 22, inc. I, da CF, que dispõe competir à União legislar, entre outras coisas, sobre “direito processual”.

Em razão disso, apenas o Congresso Nacional pode disciplinar o processo, ou seja, criar, extinguir e modificar regras processuais civis, o que torna o Direito Processual Civil único em todo o território nacional.

Com isso, o método de atuação de todos os juízes, advogados e todos aqueles que atuam no processo civil é padronizado e idêntico em todo o território nacional dada a sua regulamentação por lei federal, principalmente no Código de Processo Civil, mas também nas leis processuais extravagantes.

Por leis processuais extravagantes, devem ser entendidas todas as leis processuais que veiculem qualquer norma voltada a organizar o Poder Judiciário, disciplinar os direitos e deveres das partes, do juiz e dos demais sujeitos do processo, bem como o procedimento, e que estejam fora do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil é a lei federal (Lei Federal n. 13.105/2015) que pretende sistematizar e consolidar a maioria das normas processuais, sendo certo que, por mais completo que um Código seja, sempre se faz necessária sua complementação pela edição de outras leis que, por serem exteriores ao texto do Código, são denominadas extravagantes.

Contudo, é bom que se deixe claro que não há hierarquia entre as leis extravagantes e as normas do Código de Processo Civil, uma vez que ambas são espécies legislativas idênticas e, portanto, com a mesma eficácia normativa.

Outro ponto digno de destaque, neste contexto, é a possibilidade de o Código de Processo Civil vir a ser modificado, para tanto sendo suficiente a edição, pelo próprio Congresso Nacional, de uma lei federal que se volte a revogar, modificar ou incluir um artigo ou grupo de artigos no Código de Processo Civil.

Este mesmo Congresso, aliás, pode optar por, mediante a edição de uma única lei federal, simplesmente substituir todo o Código de Processo Civil, revogando-o e instituindo um novo Código, como ocorreu recentemente com a promulgação da Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil em substituição ao CPC de 1973.

De rigor, a opção por editar uma lei extravagante, uma lei que modifique pontualmente o Código de Processo Civil ou uma lei mais ampla que estabeleça um novo Código de Processo Civil, apesar de ser importantíssimo para o operador do Direito Processual, escapa do objeto do estudo do processo.

Apesar de a vocação das leis federais ser o estabelecimento de regras com maior grau de detalhamento, se comparado aos princípios constitucionais, nada impede que a lei federal também consagre alguns princípios, que, dado o veículo em que são consagrados, são classificados como princípios infraconstitucionais.

Nesse sentido, vários princípios infraconstitucionais são identificados pela doutrina como consagrados no Código de Processo Civil, sendo certo que o fato de estarem consagrados na lei não lhes retira a importância ou o caráter de norma geral e abstrata.

De rigor, o fato de estes princípios estarem na lei, e não na Constituição Federal apenas nos permite concluir que estas normas estão em uma posição de inferior hierarquia, podendo, inclusive, ser modificadas ou extintas por outra lei, mas, enquanto vigentes, devem ser consideradas e respeitadas pelos atores do sistema processual.

Ademais, muitos dos denominados princípios infraconstitucionais são desdobramentos de princípios constitucionais com estrutura e texto ainda mais genéricos.

É o caso, por exemplo, do art. 10 do Código de Processo Civil, que detalha o princípio do contraditório constitucionalmente consagrado ao dispor que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, regra mais clara e precisa, se comparada ao genérico direito ao contraditório garantido pelo art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal²².

Nestas hipóteses, revela-se mais uma vez o caráter complementar e elucidativo das normas consagradas na lei federal, em relação àquelas previstas na Constituição.

Para o intérprete, aplicador e estudioso do Direito Processual Civil é imprescindível não só o conhecimento dos dois conjuntos de normas, como também a capacidade de correlacionar estes dois subsistemas de consagração de princípios e regras processuais.

c) Constituição e leis estaduais

Conforme demonstrado no item anterior, a vocação do Direito Processual Civil é ser padronizado e uniforme em todo o território nacional, em função da previsão constitucional estabelecida no art. 22, inc. I, da Constituição Federal, que atribui à União o poder de legislar sobre o “direito processual”.

Entretanto, em que pese a exclusividade da União para legislar sobre Direito Processual Civil, em uma pequena medida, as leis e as constituições dos Estados podem influenciar o Direito Processual Civil e, nesta diminuta proporção, serem consideradas fontes do Direito Processual Civil.

Esta possibilidade decorre, basicamente, de dois fatores: a) a determinação constitucional para que cada Estado da federação estruture e organize o seu Poder Judiciário; e b) a previsão constitucional de as leis estaduais disciplinarem “procedimento em matéria processual”.

Por ser o Poder Judiciário um dos principais atores da relação processual e o responsável pela condução do processo civil, as regras que o estruturam são importantíssimas para a disciplina do processo, devendo, sempre, as normas de organização do Poder Judiciário, ser consideradas fontes do Direito Processual Civil.

Nos termos do art. 98 da Constituição Federal, compete aos Estados-membros estruturarem e organizarem seu próprio Poder Judiciário.

Para se desincumbirem desta atribuição constitucional, cabe aos Estados legislarem sobre a organização de seu Poder Judiciário, criando os órgãos jurisdicionais e estabelecendo sua estrutura e competência mediante a edição da Constituição e de leis estaduais.

Dessa forma, as constituições e leis dos Estados devem ser consideradas fontes do Direito Processual Civil, na medida em que organizam o Poder Judiciário estadual.

É bom que se deixe claro que possuir competência para legislar sobre normas de organização do Poder Judiciário não dá aos Estados-membros o poder de legislar sobre a forma que os órgãos jurisdicionais por eles criados

devam atuar e conduzir o processo.

Em outras palavras, a competência dos Estados se esgota com a criação das varas e demais órgãos jurisdicionais, por meio das leis e constituições estaduais, sendo o modo de atuação destes órgãos, isto é, o método de condução do processo, ditado pelas leis federais e, em especial, pelo Código de Processo Civil, conforme visto no item anterior.

A única ressalva que deve ser feita neste campo é a possibilidade, por expressa previsão constitucional, de os Estados poderem legislar sobre procedimentos em matéria processual nos termos do art. 24, inc. XI, da Constituição Federal.

Entretanto, o poder de legislar sobre procedimento em matéria processual deve ser entendido como um conceito limitado, dado que a regulamentação do processo deve ser uniforme em todo o território nacional, devendo o Direito Processual ser disciplinado em lei federal.

Assim, é vedado aos Estados, por exemplo, criar ou extinguir recursos, modificar prazos ou estabelecer direitos e deveres para as partes, para o juiz e para todos aqueles que atuem no processo, por meio de leis e constituição estaduais.

d) Regimentos internos dos tribunais

Apesar de caber ao Poder Legislativo a capacidade de editar as normas integrantes do sistema jurídico, inclusive processual, e, por este motivo, estarem na Constituição e nas leis, sobretudo federais, a estruturação e o método de atuação dos órgãos jurisdicionais, alguns aspectos do funcionamento interno de cada tribunal não estão previstos em lei, quer por se tratar de aspecto tão específico que o legislador sequer pode conceber, quer por não se tratar de aspecto do qual deva se ocupar o legislador.

Nesse contexto, é perfeitamente admissível que alguns detalhes ou pequenos aspectos procedimentais não sejam disciplinados pela lei, levando à possibilidade de complementação por um sistema de regras consagradas

pelos próprios tribunais.

Os tribunais, nesta medida, possuem competência para editar este conjunto de regras peculiares a sua própria organização interna, pela edição de um Regimento Interno.

Assim, naquilo que a lei for omissa ou fizer expressa remissão à possibilidade ou à necessidade de disciplina pelos tribunais, surge o espaço para a incidência das regras integrantes dos Regimentos Internos como fontes do Direito Processual Civil.

Em determinadas situações, a própria lei faz expressa remissão à necessidade deste detalhamento pela via do regimento interno, como é o caso do art. 1.028²³ do Código de Processo Civil, que atribui expressamente a regulamentação infralegal pela via dos regimentos internos.

É importante, contudo, que se deixe claro que os Regimentos Internos possuem um grau de hierarquia inferior ao da lei, não podendo, em primeiro lugar, contrariar disposições legais, e, muito menos, constitucionais.

Em outras palavras, o campo de atuação dos regimentos internos se resume a aspectos de organização interna e a detalhes de que a Constituição e as leis não se ocupam, sendo certo que, sempre que a lei disciplinar uma questão, não caberá ao Regimento interno dela tratar, salvo se para pormenorizar algum aspecto já implicitamente previsto na norma legal.

Ademais, não cabe ao regimento interno inovar em matéria processual sendo absolutamente inválidas previsões normativas consagradas neste diploma que criem ou estabeleçam direitos e deveres processuais como multas ou recursos, bem como que disciplinem procedimentos e prazos, salvo quando expressamente autorizados pela lei.

Em suma, os regimentos internos dos tribunais são fontes do direito Processual Civil de caráter secundário e complementar às normas consagradas na lei e na Constituição.

e) A jurisprudência e os precedentes judiciais como fonte do Direito Processual Civil

Uma dificuldade constante e onipresente em todos os sistemas jurídicos consiste na potencial existência de interpretações e aplicações conflitantes de uma mesma norma jurídica.

Esta dualidade ou até multiplicidade de entendimentos ocorre, ou pode ocorrer, por mais simples que seja o texto da norma jurídica, e tende a se tornar ainda mais acentuada em um sistema como o brasileiro, que consagra uma série de princípios e conceitos jurídicos indeterminados em sua Constituição e na própria lei federal.

A atividade cotidiana do Poder Judiciário, pela própria natureza de sua função de, não apenas interpretar, mas também de aplicar a lei aos casos concretos que lhe são apresentados, acaba por, mediante esta prática, esclarecer o sentido da norma, seu alcance e seu âmbito de aplicação.

Esta atividade, via de regra, é realizada reiteradas vezes, pois geralmente o Poder Judiciário é levado a decidir, com base nas mesmas normas jurídicas, vários casos semelhantes.

A partir desta repetida prática de interpretação e aplicação de uma mesma lei, o Poder Judiciário passa a formar um conjunto de julgados ao qual dá-se o nome de jurisprudência.

A jurisprudência, assim entendida como o conjunto de decisões reiteradas sobre uma mesma matéria proferidas por tribunais, sempre, em maior ou menor medida, exerceu algum papel mais ou menos relevante no sistema jurídico.

Rodolfo de Camargo Mancuso²⁴ aduz que a jurisprudência desempenha diferentes papéis conforme o regime político do país e a família jurídica a que ele esteja filiado. No Estado de Direito filiado à família romano-germânica da civil law, segundo Mancuso, a jurisprudência uniformizada, em especial os enunciados e súmulas formalizados, exerce relevantíssimos

papéis, pois: “a) opera como uma segura diretriz para o Poder Judiciário, funcionando como um importante subsídio para subsunção dos fatos ao Direito, na medida em que sinaliza a interpretação predominante em casos análogos; b) contribui para consecução de uma ordem jurídica justa, ou isonômica, por modo que casos semelhantes possam receber respostas qualitativamente uniformes; c) complementa a formação da convicção do magistrado, atuando como fator de atualização do Direito Positivo e como elemento moderador entre o fato e a fria letra da lei”²⁵.

O mesmo citado autor, mais adiante²⁶, elenca a importância do respeito à jurisprudência reiterada e dominante para que o próprio Direito realmente tenha eficácia prática e credibilidade social, tendo em vista que “tratar igualmente situações assemelhadas é algo imanente a esse ramo do conhecimento humano”.

A par disso, Mancuso²⁷ também destaca o papel da jurisprudência no esclarecimento e na definição do verdadeiro significado dos, cada vez mais utilizados pelo Direito, conceitos jurídicos indeterminados, cujo alcance e conteúdo foram intencionalmente deixados fluidos pelo legislador, para que o Judiciário os interpretasse e os aplicasse concretamente.

Por esse motivo, é correto afirmar que a jurisprudência deve ser considerada fonte do Direito Processual Civil, uma vez que, muitas vezes, ante a dualidade ou a multiplicidade de interpretações possíveis, o operador do Direito deve buscar na interpretação consagrada pelos tribunais o verdadeiro sentido da norma.

É de se ressaltar que a consideração e o respeito à jurisprudência como fonte do Direito são formas de se permitir o respeito ao princípio da igualdade, dando a todos os litigantes o mesmo tratamento processual e a mesma resposta jurisdicional a todos aqueles que se encontrem na mesma situação processual.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim²⁸ elenca três vantagens advindas desse sistema de valorização da jurisprudência, a saber: a) mais efetividade

do processo, na medida em que, uma vez decidida a questão de maneira reiterada, o gasto de atividade jurisdicional e das partes tende a ser menor na solução da mesma questão em casos futuros; b) maior respeito ao princípio da isonomia, por se estar dando tratamento igual, ou seja, a mesma resposta jurisdicional a casos idênticos; e c) maior previsibilidade e tranquilidade para o jurisdicionado, representações do princípio da segurança jurídica que estaria sendo prestigiado a partir do momento em que há um sistema voltado a garantir que a resposta do Poder Judiciário, órgão constitucionalmente competente para dar a última palavra sobre a interpretação e aplicação da lei, é respeitada nos casos pendentes e futuros.

Ainda segundo a citada autora, o próprio Direito tem como escopo exatamente essas três finalidades.

Por esses motivos, o ordenamento jurídico brasileiro vem, nos últimos anos passando por uma série de modificações voltadas a prestigiar e fortalecer os entendimentos jurisprudenciais, o que, em última análise, reforça a ideia da jurisprudência como fonte do Direito.

Maior prova disso é a criação, pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004, da “súmula vinculante”, que nada mais é do que o resumo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, uma vez consolidada e consagrada no texto da súmula, torna-se de obrigatória observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário e, por consequência, por todos os demais atores que, perante seus órgãos, atuam no processo.

Assim, quando o Supremo Tribunal Federal entende e declara, em uma súmula vinculante, que “competete à justiça estadual julgar causa entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia”²⁹, este entendimento, nesta sede consagrado, passa a integrar o sistema e deve ser observado não apenas pelo juiz, mas por todos os operadores do processo civil.

A súmula vinculante é apenas uma forma de se consolidar e sistematizar a jurisprudência, sendo esta, por força da previsão constitucional de sua eficácia vinculante, aquela expressão da jurisprudência que tem mais similitudes com as fontes formais do Direito, assim entendidas as normas gerais e abstratas, via de regra, consagradas pelo Poder Legislativo.

Entretanto, não apenas a jurisprudência consagrada em súmula vinculante deve ser considerada fonte do direito processual, uma vez que outras expressões da jurisprudência podem conter, se não verdadeiras inovações normativas, disposições esclarecedoras do texto constante da lei e Constituição, sendo, nesta medida, importantíssimas fontes de consulta para o interprete e operador do Direito Processual.

Neste contexto, revela-se importante também a conceituação do precedente judicial, sobretudo se produzido em determinados incidentes previstos no Código de Processo Civil especificamente voltados a uniformização de entendimento e fixação de uma tese jurídica.

Isso porque os julgamentos proferidos em procedimentos previstos em lei voltados à formação de um precedente qualificado, como o incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento de recursos excepcionais repetitivos, são aptos a expressar o entendimento do tribunal sobre uma questão de direito e a serem aplicados nos demais casos que envolverem a mesma matéria, e por isso, inegavelmente, devem ser considerados fontes do direito processual.

Aliás, vale registrar que a força emprestada pelo direito processual a algumas expressões da jurisprudência, como as súmulas e os precedentes qualificados, autoriza a conclusão no sentido de que esses pronunciamentos jurisdicionais são fontes de todo o Direito, não apenas o processual³⁰.

De rigor, a jurisprudência, enquanto fonte do Direito, pode ser classificada, uma vez que variável sua carga de autoridade e capacidade de influência, no sistema jurídico.

Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso, após ressaltar que “a palavra jurisprudência não apresenta um conteúdo unívoco, ao longo da evolução do Direito, no tempo e no espaço”³¹, conceitua o termo no sentido técnico processual como “uma coleção de acórdãos, sobre um mesmo tema, reiterados harmonicamente, provindos de um tribunal – em seu pleno ou frações – ou mesmo no âmbito de uma dada Justiça”³².

Entretanto, é importante observar que, apesar de, em regra, a jurisprudência formar-se a partir da reiteração de julgados, é possível que um único precedente forme ou retrate a jurisprudência de determinado tribunal, como ocorre na hipótese do julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no caso da declaração de existência ou inexistência da repercussão geral, ou da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso especial repetitivo, hipóteses em que, desde já, é possível falar em jurisprudência daquela corte³³.

Se, por um lado, é correto afirmarmos que a jurisprudência é uma fonte do Direito Processual Civil, por outro lado nem todos os conjuntos de julgados sobre um tema possuem a mesma autoridade e influência na atividade processual.

Em outras palavras, é possível classificarmos a jurisprudência a partir de alguns critérios, especialmente: a) pelo grau de pacificação do entendimento em sede de tribunais; b) pelo fato de esses entendimentos estarem ou não estarem uniformizados e consagrados em súmulas ou precedentes qualificados; e c) pelo grau hierárquico do tribunal em que ela é consagrada, uma vez que, obviamente, quanto mais elevada a posição da corte na organização judiciária, maiores o peso e a força da jurisprudência.

Pelo critério grau de uniformização, combinado com a formalização da verificação, é possível classificar a jurisprudência em: a) jurisprudência divergente; b) jurisprudência dominante; c) jurisprudência pacificada; e d) jurisprudência sumulada.

A jurisprudência divergente é aquela caracterizada pela existência de vários julgados sobre a mesma matéria em sede de tribunais, havendo, porém, um número relevante de julgados em mais de um sentido.

Jurisprudência dominante pode ser caracterizada, tal como a divergente, pela existência de vários julgados sobre a mesma matéria em sede de tribunais com uma quantidade considerável de julgados em mais de um sentido, mas onde é possível a constatação de que a um dos entendimentos possui maior aplicação.

Já a jurisprudência pacificada é aquela em que há vários julgados sobre a mesma matéria em sede de tribunais em um mesmo sentido, sendo inexistentes ou, se existentes, em quantidade irrelevante ou superados, julgamentos que consagrem um entendimento em sentido diverso.

A jurisprudência sumulada, por sua vez, representa, formalmente, a jurisprudência pacífica, ou dominante, e emerge de um procedimento específico de reconhecimento da pacificação ou domínio do entendimento jurisprudencial.

Além de valorizar a jurisprudência e as súmulas, o sistema processual brasileiro consagra uma série de técnicas voltadas à formação de alguns precedentes qualificados, de obrigatória observância pelos demais juízes e tribunais e, portanto, com significativa capacidade de influenciar o procedimento e o julgamento de casos semelhantes. É o caso dos julgamentos proferidos em incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e julgamento de recursos excepcionais repetitivos.

Esses procedimentos são especificamente voltados à formação de um precedente qualificado apto a expressar o entendimento do tribunal sobre uma questão de direito e, até por isso, legitimado a funcionar como fonte do Direito a ser aplicada em outros processos que envolvam a mesma matéria.

Tais precedentes são hipervalorizados pelo sistema processual, especialmente por terem de ser obrigatoriamente observados pelos demais juízes e tribunais, razão pela qual devem ser denominados precedentes qualificados. São qualificados tanto pela forma como são produzidos quanto pelos efeitos vinculantes e impactos procedimentais que proporcionam, o que os destaca dos demais pronunciamentos judiciais exclusivamente voltados a resolver o litígio entre as partes e que, no máximo, quando reiterados, contribuem para formação da jurisprudência³⁴.

Prova do estímulo à observância da jurisprudência e do precedente e sua categorização como fonte do Direito, não apenas processual, é encontrada no art. 927 do Código de Processo Civil, que determina que “os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

Os inúmeros desdobramentos do referido dispositivo escapam ao objeto desta Introdução, sendo suficiente, nesta sede, o registro do reconhecimento pelo sistema processual da jurisprudência e dos precedentes judiciais como fontes do Direito.

2.3.3 Aplicação das normas processuais

Os arts. 13 a 15 do Código de Processo Civil tratam da aplicação da lei processual, ocupando-se do que a doutrina costuma denominar de disciplina da lei processual no tempo e no espaço, além de consagrar o já aludido caráter supletivo do direito processual civil³⁵ e, especialmente, do CPC, em relação aos demais ramos do direito processual não penal, a saber, o direto

processual do trabalho, o direito processual eleitoral e o processo administrativo.

O primeiro dispositivo do capítulo (art. 13 do CPC), ao dispor que “a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte”, disciplina a lei processual no espaço.

O normativo, de fácil compreensão, em primeiro lugar, deixa claro que a disciplina do Processo Civil é eminentemente federal, ressalvados os pequenos espaços para as normas estaduais, como no caso de custas processuais e organização judiciária.

A par disso, o dispositivo deixa clara a possibilidade de que normas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja signatário venham a ser aplicadas pelo juiz brasileiro. De rigor, a positivação dessas normas previstas em instrumentos de direito internacional precisam ser internalizadas pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inc. I, da Constituição Federal, podendo, inclusive, se versarem sobre direitos humanos, incorporar o ordenamento jurídico com status de emenda à Constituição, nos termos do art. 5º, §§ 2º e 3º, da CF.

Portanto, na prática, as normas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte só vinculam os sujeitos processuais brasileiros após devidamente incorporadas ao direito interno.

Outra conclusão, por demais óbvia, que pode ser extraída do art. 13 do Código de Processo Civil, é a impossibilidade de o juiz brasileiro, no exercício da jurisdição nacional, se submeter ou ter de observar normas de direito processual estrangeiro, independente da nacionalidade das partes, do local dos fatos que deram origem ao litígio ou do cumprimento da obrigação.

Em outras palavras, o simples fato de o processo se desenvolver perante

a autoridade judiciária brasileira é suficiente para torná-lo inteiramente regido pelo direito processual civil pátrio e, no máximo, pelas normas previstas em tratado, convenção ou acordos internacionais, o que, de rigor, não escapa a esta regra, dada a exigência de internalização dessas normas para fins de incorporação do direito nacional.

Nesse aspecto, conforme salientam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery³⁶, há uma significativa distinção entre a disciplina da lei processual no espaço e a forma com que esse aspecto da lei material é regulado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, visto que esta admite que leis materiais incidam sobre situações jurídicas que se desenvolvam em território nacional.

O art. 14 do Código de Processo Civil regula a aplicação da lei processual no tempo, estabelecendo que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

O dispositivo ocupa-se de regulamentar o impacto das modificações da lei processual nas relações processuais em curso.

Para tanto, consagra dois princípios de direito intertemporal: a) o princípio da irretroatividade da lei processual; e b) o princípio da aplicabilidade imediata da lei processual.

Pelo princípio da irretroatividade da lei processual, os atos praticados ao tempo e modo da lei revogada, porém vigente à época da prática do ato, são considerados válidos e não precisam ser refeitos ou adaptados. Trata-se de uma proteção ao ato jurídico perfeito, resguardado pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XXXVI) e pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 6º.

Por outro lado, de acordo com o princípio da aplicabilidade imediata da lei processual, a “lei nova” passa a incidir em todos os processos em curso,

influenciando desde logo as etapas e os atos processuais subsequentes à sua entrada em vigor, consagrando, portanto, a máxima *tempus regit actum*.

Conjugando os dois princípios regentes do direito intertemporal processual consagrados no art. 14 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão pela necessidade do isolamento dos atos processuais. Em síntese, pela teoria do isolamento dos atos processuais, nos casos de modificação da lei processual, consideram-se válidos os atos praticados ao tempo e modo da lei revogada, devendo os atos subsequentes ser praticados na forma da lei nova desde sua entrada em vigor.

As conclusões extraídas do art. 14 do Código de Processo Civil são compatíveis e coerentes com os já aludidos art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, que protege a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, assim como o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe, verbis: “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”, sendo certo que “reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” (art. 6º, § 1º, da LINDB).

Por todas essas razões, os atos processuais já praticados devem ser preservados e não sofrem os impactos da lei nova, ao passo que, independentemente da data de início do processo, as modificações legislativas impactam nos feitos pendentes, salvo expressa previsão legal em sentido contrário.

Na hipótese de a modificação da lei processual se dar no curso de um prazo, já iniciado ao tempo da lei revogada, o ato a que a parte tinha direito deve ser praticado nos termos da lei revogada, haja vista que, nesses casos, desde a abertura do prazo a parte já tinha o direito adquirido de praticar o ato nos termos da lei vigente, direito este que se preserva mesmo diante da modificação legislativa ocorrida no curso do prazo

processual. Assim, a parte intimada de uma decisão, quando da vigência de uma lei que consagrava o direito de recorrer, poderá fazê-lo mesmo que a lei venha a ser revogada antes da interposição do recurso.

Todavia, cumpre ressaltar que a norma disposta no art. 14 do Código de Processo Civil ora em comento é regra geral, incidente nas situações em que a lei processual nova não disponha em sentido contrário.

A entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, por exemplo, consagrou a regra geral no art. 1.046 integrante do livro complementar dedicado às disposições finais e transitórias, estabelecendo que, “ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 [CPC/1973]”.

Entretanto, excepcionalmente, no que se refere ao direito probatório, o CPC/2015 optou por preservar a vigência do Código revogado, estabelecendo, no que diz respeito às provas requeridas ou determinadas de ofício à luz da lei revogada, no art. 1.047, que “as disposições de direito probatório adotadas neste Código se aplicam apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência”.

Igualmente por exceção, o art. 1.046, § 1º, do CPC/2015 preserva a vigência do Código de Processo Civil de 1973 para fins de observância e aplicação aos feitos pendentes submetidos ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais revogados até o proferimento da sentença. Essa exceção se justifica tendo em vista a inexistência de normas equivalentes no CPC/2015, o que implica a necessidade de ultratividade da norma até então vigente mesmo após sua revogação.

Encerrando o capítulo dedicado à aplicação das normas processuais, o art. 15 do Código de Processo Civil destaca a aplicação subsidiária e supletiva de suas normas a outros ramos do direito processual, bem como ao processo administrativo.

Conforme já ressaltado, o direito processual possui outros ramos além do processo civil, quais sejam: o direito processual penal (comum e militar), o direito processual do trabalho, o direito processual eleitoral e o direito processual constitucional. Todos esses ramos possuem algumas peculiaridades dignas de nota que os diferenciam do Direito Processual Civil, o que não impede a incidência supletiva e subsidiária do Código nos processos regidos por esses ramos. Além disso, o processo administrativo, método de solução de litígio não jurisdicional que se desenvolve no âmbito interno do Poder Executivo, também sofre influência de normas processuais civis de maneira supletiva e subsidiária.

Isso porque, partindo da premissa de que esses ramos do Direito Processual possuem um regramento insuficiente, o art. 15 do Código de Processo Civil dispõe que, “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.

Por aplicação subsidiária e supletiva deve ser entendida, segundo Cassio Scarpinella Bueno³⁷, a capacidade das normas do Código de Processo Civil de suprir lacunas (caráter supletivo), “auxiliar e contribuir na compreensão” das normas integrantes dos outros sistemas de direito processual (caráter subsidiário).

No mesmo sentido, Alexandre Freire e Leonard Schimitz³⁸, em comentários ao art. 15 do Código de Processo Civil, afirmam que, a par do papel de suprir lacunas (caráter supletivo), o caráter subsidiário permite que as normas processuais civis do Código sejam aplicadas quando, existente texto normativo para o caso, sua aplicação não conduza a um resultado adequado. Os autores arrolam uma série de exemplos de aplicação subsidiária, tais como: a) a observância do contraditório substancial do art. 10; b) o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137); c) o julgamento parcial de mérito do art. 356, entre outros.

Apesar da ausência de referência expressa, é possível sustentar que ao processo constitucional também se aplicam, de maneira subsidiária e supletiva, as normas do Código de Processo Civil naquilo que a Constituição e a legislação de regência forem silentes.

Assim, dispositivos relacionados a contagem de prazo e formas de intimação, por exemplo, aplicam-se na forma prevista no Código de Processo Civil aos procedimentos típicos de processo constitucional.

O único ramo do direito processual que, em princípio, não sofre influência das normas dispostas no Código de Processo Civil é o direito processual penal, que, além de ter escopos e funções muito distintos, é regulamentado por um Código próprio, o Código de Processo Penal. Por essas razões, o Código de Processo Civil não faz alusão sequer à possibilidade de aplicação subsidiária e supletiva de normas processuais civis ao processo penal.

Capítulo 3 Jurisdição e Demais Meios de Resolução de Litígios (Autotutela, Meios Consensuais e Arbitragem)

3.1 Da autotutela à jurisdição estatal: os meios de resolução da lide

Conforme afirmado no capítulo introdutório, uma vez caracterizado o conflito de interesses, surge uma necessidade política, social e jurídica de que a lide venha a ser resolvida.

O escopo político do processo liga-se, segundo Cândido Rangel Dinamarco³⁹, à necessidade de afirmação da autoridade do Estado e de seu ordenamento, devendo ser protegidos, pelo poder jurisdicional, os principais valores nele consagrados, sempre que lesados ou ameaçados.

Já o escopo social do processo deve ser entendido como a necessidade de este eliminar conflitos mediante critérios justos⁴⁰, gerando, na sociedade, a consciência de que o Direito deve ser cumprido, sob pena de consequências negativas a serem impostas pelo Poder Judiciário por meio do processo.

Solucionar a lide, portanto, é necessário não apenas para restabelecer a ordem jurídica e garantir o respeito aos direitos subjetivos lesados ou ameaçados, mas também para reafirmar a autoridade do Estado e do Direito, bem como gerar paz social⁴¹ e a conscientização de que o Direito deve ser cumprido.

Em última análise, a não resolução da lide redundaria em um descrédito do Estado e do próprio Direito, em uma sensação de insegurança, bem como no desrespeito a direitos subjetivos lesados ou ameaçados.

Esta necessária resolução da lide, de rigor, pode ser realizada de várias formas, sendo o método jurisdicional/estatal uma das possibilidades, dentre outras, via de regra, admitidas e até estimuladas pelo Direito.

Isso porque genericamente podemos afirmar que qualquer método ou

comportamento das partes litigantes que faça cessar a pretensão ou resistência originariamente oferecidas pelos sujeitos da relação jurídica é, conceitualmente, um método de resolução da lide.

Dentro desta categoria amplíssima, podemos inclusive considerar a autotutela, que se caracteriza por fazer cessar, pelo exercício da força e da violência das próprias partes interessadas, a pretensão ou a resistência oferecida pela outra, como um meio de resolução da lide, ainda que, salvo exceções, vedado pelo Direito.

Ao contrário da autotutela, via de regra vedada, outros meios de resolução da lide são, além de admitidos, até estimulados pelo Direito, como é o caso, em especial, dos denominados meios compositivos, que dependem, em maior ou menor medida, da vontade das partes litigantes em encerrar o litígio.

Nesse contexto, devem ser destacados a transação, a renúncia e o reconhecimento jurídico do pedido, que podem resultar na resolução do litígio, pela livre manifestação de vontade das partes, ou por meio do emprego de técnicas de estímulo e promoção destas manifestações, com ou sem a participação de terceiros, encerrando-o em função e nos termos da vontade manifestada pelas partes litigantes.

A par destes métodos, obviamente, impõe-se a categorização da jurisdição como meio de resolução da lide, meio este que conta com a participação do Estado-juiz, detentor do dever/poder de resolver os litígios que lhes sejam apresentados, e que, ao contrário dos meios compositivos, não necessita da concordância ou, mais amplamente, do concurso de vontade das partes litigantes.

Ademais, é admitida pelo ordenamento jurídico a opção das partes no sentido de, consensualmente, escaparem do Poder Judiciário submetendo o litígio a um árbitro ou câmara arbitral, confiando a estes a solução da controvérsia.

Nesse sentido, a arbitragem se coloca como um meio de resolução da lide amplamente admitido pelo Direito, salvo expressas hipóteses vedadas pelo ordenamento jurídico.

Os subitens a seguir se dedicarão à análise da autotutela, sua vedação e admissibilidade excepcional; aos meios consensuais de resolução de litígios e respectivas técnicas voltadas à sua promoção; à arbitragem e à jurisdição.

3.1.1 Autotutela: conceito, vedação e admissibilidade excepcional

Conforme já asseverado, denomina-se autotutela o meio de resolução da lide caracterizado pela imposição do interesse de uma parte sobre outra pela força, independentemente, portanto, da participação do Estado ou de qualquer terceiro imparcial, bem como sem a observância de qualquer norma jurídica.

Por esse motivo, a autotutela, via de regra, é vedada pelo Direito, sendo inclusive tipificada como crime à luz do Direito penal⁴².

Tal vedação se justifica na medida em que a autotutela não garante a vitória da parte que possua razão nos termos do Direito, mas sim a vitória da parte mais forte, que impõe sua vontade independentemente de estar amparada pelo ordenamento jurídico.

Entretanto, em algumas situações de conflito, o Direito, excepcionalmente, autoriza o uso da força pela parte interessada, descaracterizando a ilicitude do exercício da autotutela em razão de particularidades descritas na norma.

Estando no campo das exceções à regra geral três pontos referentes à autotutela, de antemão devem ser destacados: a) em primeiro lugar, faz-se necessária expressa previsão legal para o exercício legítimo da autotutela; b) em segundo, todas as condições autorizadoras de tal exercício devem estar presentes para que o uso privado da força seja considerado lícito; c) a par disso, o uso da força deve se limitar a fazer cessar a situação que autorizava a autotutela, não sendo concebível, em nenhuma hipótese, que

o uso da força seja ilimitado ou livre de contornos jurídicos.

Um bom exemplo de autorização excepcional do exercício da autotutela encontra-se no art. 1.210 do Código Civil, que autoriza a denominada legítima defesa da posse.

O referido dispositivo reza que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”, no que é complementado pelo seu § 1º, que dispõe que “o possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”.

Nestas hipóteses, portanto, em razão da norma expressa que excepciona a vedação de exercício da autotutela, resta permitido pelo Direito o uso da força pela parte interessada (possuidor), sem que seja caracterizada qualquer ilicitude.

Note-se que, para a legitimidade da defesa da posse, nestes casos, todas as condições autorizadoras, bem como as condições do exercício da força estabelecidas no dispositivo, devem estar presentes.

Assim, para que seja considerado lícito o exercício da autotutela para defesa da posse, o esbulho ou turbação deverá ser recente, dado que o exercício da força deve ser imediato, uma vez que o dispositivo se vale da expressão “contando que o faça logo”.

Com isso se exclui qualquer possibilidade de defesa da posse por meio da autotutela após a situação de esbulho se consolidar no tempo.

Nesta hipótese, o desrespeito à posse, ainda que ilícito, não poderá ser corrigido por exercício da força pelo próprio possuidor, restando-lhe a possibilidade da busca da tutela jurisdicional do Estado.

Além da condição, imposta pela regra excepcional, de o exercício da força para a autodefesa da posse ser imediato, o mesmo dispositivo impõe

que os atos de desforço sejam limitados aos necessários para fazer cessar a lesão ou ameaça à posse.

Os atos de força praticados fora destes parâmetros são ilícitos e, por esse motivo, o sujeito praticante responde pelo excesso.

De se notar, portanto, que, mesmo nos casos em que a autotutela é excepcionalmente admitida pelo ordenamento jurídico, seu exercício envolve riscos do ponto de vista fático e jurídico, razão pela qual é possível concluir que, mesmo nestes casos, ainda que não por motivos ligados à ilicitude da conduta, o seu exercício passa longe de ser a melhor forma de resolver litígios possessórios.

Conforme se verá adiante, a tutela jurisdicional, mesmo nas situações em que se admite excepcionalmente a autotutela, permanece à disposição do possuidor turbado ou esbulhado, sendo este um método mais seguro e mais eficiente do ponto de vista jurídico, pelos motivos que serão demonstrados no item dedicado ao estudo da jurisdição.

3.1.2 Meios consensuais de resolução de litígios

3.1.2.1 A resolução do litígio por meio da transação, da renúncia e do reconhecimento jurídico do pedido

Ao contrário da autotutela, via de regra vedada pelo Direito e, mesmo quando admitida, cercada de riscos fáticos e jurídicos, outros métodos de solução de litígios não jurisdicionais são admitidos e até mesmo estimulados pelo sistema jurídico.

Um deles é a autocomposição, que se caracteriza por um acordo de vontades entre as partes litigantes, voltado a fazer cessar a pretensão, ou a resistência.

Desta feita, havendo uma manifestação de vontade de uma das partes, ou de ambas, que venha a fazer cessar a pretensão ou a resistência, resolve-se a lide, sem a participação de nenhum terceiro e muito menos do

Estado-juiz.

Cintra, Dinamarco e Grinover⁴³ subdividem as formas de autocomposição em três: uma, fruto de um verdadeiro acordo de vontades entre as partes do conflito; e outras duas, frutos de manifestação unilateral de vontade que, por fazer cessar a pretensão ou a resistência, resolve o litígio.

O método autocompositivo mais comum é a denominada transação, que nada mais é do que um acordo de vontades em que as partes, mediante concessões recíprocas, abrem mão parcialmente da pretensão e aceitam, também parcialmente, a resistência.

A transação, portanto, implica um acordo, onde as partes litigantes abdicam de parte daquilo que originalmente sustentavam e, nessa medida, encerram o litígio.

São muito comuns ações de cobrança em que o sujeito apontado como devedor reconhece que deve parte da quantia, mas não aceita pagar a totalidade da pretensão do autor, por entender tratar-se de juros abusivos, por exemplo.

Na hipótese, caso a parte que pretendia inicialmente todo o valor aceite receber o valor oferecido pelo devedor, dando quitação total para a dívida pleiteada, celebra-se uma transação, suficiente para encerrar a lide.

O mesmo ocorre em situações em que um sujeito que sofrera um dano demande uma quantia a título de indenização contra o causador, e este até aceite a pretensão de ter de indenizar os prejuízos causados, mas discorde no que tange ao quantum pretendido. É perfeitamente possível e até estimulado pelo ordenamento jurídico processual que, caso a parte prejudicada aceite receber a título de indenização um valor que a parte contrária aceite pagar, encerre-se a lide pela autocomposição.

A autocomposição, quando celebrada antes da provocação do Poder Judiciário, isto é, antes do ajuizamento da ação, evita a formação da relação processual.

Entretanto, quando celebrada após o início do processo, deverá ser comunicada ao juiz para que o processo seja extinto, dada a perda de seu objeto, pela resolução da lide por meio de acordo de vontades entre as partes⁴⁴.

Outras duas formas de autocomposição capazes de encerrar o litígio, tornando desnecessária a atuação jurisdicional, são atos unilaterais de uma das partes litigantes: a renúncia; e o reconhecimento jurídico do pedido.

Em ambas as situações, dá-se o encerramento do litígio por ato de disposição de uma das partes, que passa a abdicar de toda a pretensão ou de toda a resistência.

A diferença entre elas diz respeito a qual das partes exerce este ato de liberalidade.

Quando a parte que exerce a pretensão (e por este motivo configura a lide) deixa de exercê-la, caracteriza-se a renúncia, com a consequente extinção da lide.

Já quando a parte que originalmente vinha oferecendo a resistência deixa de oferecê-la e reconhece juridicamente o pedido formulado pelo autor, também restará extinta a lide, em função do reconhecimento jurídico do pedido.

Tal como nas hipóteses de transação, a renúncia ou o reconhecimento da pretensão, quando ocorrem antes do início do processo, obviamente tornam o ajuizamento da ação desnecessário, sendo certo que, caso sejam realizados após a formação da relação processual, tal fato deverá ser formalmente comunicado ao juiz, para que este extinga o processo, declarando a resolução da lide⁴⁵.

3.1.2.2 Técnicas de promoção da solução consensual de litígios: mediação e conciliação

A par de poder ser alcançada pela livre manifestação de vontade das partes, a solução consensual do conflito pode ser promovida por um terceiro

estranho ao litígio, caracterizando a heterocomposição.

A diferença entre a autocomposição e a heterocomposição está no fato de que, nesta última, um terceiro estranho à lide participa da discussão voltada à busca de uma solução consensual. Já a semelhança reside no fato de ambas precisarem de um acordo de vontades entre as partes litigantes voltado a solucionar a lide.

Assim, a heterocomposição pode ser entendida como meio de resolução da lide que se caracteriza por um acordo de vontade entre as partes, com a participação de um terceiro imparcial, estranho ao conflito, eleito ou aceito pelas partes, que participa da resolução do litígio, propondo ou viabilizando uma solução.

A depender do grau de atuação e condução do diálogo por este terceiro imparcial, pode-se classificar este método como mediação ou conciliação.

Na mediação, o terceiro estranho à lide exerce um papel de facilitador do diálogo, auxiliando as partes a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que possam, por si mesmas, identificar uma solução consensual⁴⁶.

Já a conciliação se caracteriza por uma participação mais ativa do terceiro no processo de negociação, o qual pode, inclusive, sugerir soluções para o litígio⁴⁷.

É de se destacar que se exclui do supracitado conceito de heterocomposição a solução da lide por meio da participação do Estado no exercício da jurisdição, visto que esta, conforme se verá com mais vagar a seguir, não se caracteriza como uma solução proposta, mas sim imposta pelo Poder Judiciário.

Entretanto, isso não quer dizer que o Poder Judiciário não possa, no curso de um processo jurisdicional, estimular a solução consensual da lide por heterocomposição.

Aliás, o próprio sistema processual estabelece ser dever do juiz

promover, a qualquer tempo, a composição entre as partes, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, conforme determinado pelo art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil.

Considerando que o objetivo do processo é resolver a lide, toda vez que o juiz alcançar tal resolução por autocomposição deverá extinguir o processo, sem exatamente ter de julgá-la, isto é, sem impor a solução do litígio.

Os métodos heterocompositivos, ademais, por visarem uma solução consensual aceita pelas partes litigantes, e não imposta pelo Poder Jurisdicional, podem ser buscados, mesmo no curso do processo, por outros servidores do Poder Judiciário, que, neste contexto, devem ser entendidos como auxiliares da Justiça.

Portanto, nada impede que os Estados, por meio de leis estaduais, criem no âmbito de suas Justiças a carreira de conciliador ou mediador para atuar após o ajuizamento da ação, mas antes do desenvolvimento da atividade jurisdicional propriamente dita.

O mesmo pode ocorrer com a União, no âmbito da Justiça federal e especializadas.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é expresso ao fazer referência aos conciliadores e mediadores como auxiliares da Justiça (art. 149) e, além disso, disciplinar a conciliação e a mediação, em uma sessão própria, em que, dentre outras regras, resta estabelecido que “os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição” (art. 165).

Ademais, o sistema codificado prevê a realização de uma audiência de conciliação antes da apresentação da defesa, com claro intuito de buscar a conciliação das partes antes do avanço do procedimento.

Nesse sentido, dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil que, “se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”, no que é complementado pelo § 1º do dispositivo, que reza que “o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária”.

Desta feita, é clara a disposição do Código de Processo Civil em promover a solução consensual do litígio pela atuação de servidores do Poder Judiciário que, apesar de não serem dotados de jurisdição, atuam na pacificação do conflito levado a juízo, com a convergência de vontade das partes.

Sempre que alcançada esta solução antes do desenvolvimento da atividade processual, por intermédio do próprio juiz, ou de seus auxiliares, mediadores ou conciliadores, é possível afirmar não apenas que o Estado cumpriu sua missão do ponto de vista jurídico, político e social, resolvendo a lide, como também que esta resolução, dado que expressamente aceita pelas partes, seja a melhor forma de solucionar o litígio.

Por essas razões, o Código de Processo Civil dispõe, já no capítulo destinado à consagração de suas normas fundamentais, especialmente no art. 3º, §§ 2º e 3º, ser dever do Estado promover a solução consensual de conflitos e atribuição dos juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no processo judicial, estimular a mediação, conciliação e outros métodos de solução consensual, o que permite a conclusão acerca da existência do princípio da preferência pela solução consensual de conflito em nosso sistema processual⁴⁸.

Obtida, em qualquer fase do processo, a solução consensual para o litígio, quer pelos mediadores e conciliadores do Judiciário, quer pelo

próprio juiz, deixa de se fazer necessário o julgamento da pretensão propriamente dita, devendo o processo ser extinto e declarado resolvido o litígio nos termos acordados pelas partes⁴⁹.

Além da possibilidade de obtenção da heterocomposição após já ajuizada a ação, pela atuação do próprio juiz, ou de mediadores ou conciliadores, é plenamente possível a obtenção deste mesmo resultado sem o ajuizamento da ação e, portanto, fora do ambiente processual.

Assim, desde que as partes estejam em comum acordo e cheguem a um consenso no sentido de que é preferível a tentativa de resolução do litígio por outra maneira que não a jurisdicional estatal, nada impede que ambas busquem o auxílio de profissionais qualificados para a tentativa de composição da lide.

Outra forma de heterocomposição sem a participação do Poder Judiciário no exercício da jurisdição, mas já com algumas características de atividade jurisdicional, é a arbitragem, a seguir comentada.

3.1.2.3 Arbitragem

Conforme mencionado no item anterior, a arbitragem é uma forma heterocompositiva de resolução da lide, que, por um lado, conta com o concurso de vontade das partes e, de outro, com a participação de um terceiro livremente escolhido por elas, mas que não se limita a propor uma solução.

Por esse motivo, apesar de a arbitragem poder ser classificada como método heterocompositivo, no qual a vontade das partes em buscar a solução por um terceiro imparcial por eles escolhidos é imprescindível, este método de resolução se aproxima da jurisdição estatal, pois se volta à imposição da solução por um terceiro imparcial.

Em outras palavras, ao contrário dos demais meios heterocompositivos, o concurso de vontades das partes na arbitragem só é relevante nas etapas de aceitação da submissão do litígio à arbitragem e na escolha do árbitro ou

da câmara arbitral, sendo certo que, uma vez manifestada a vontade das partes nestes termos, torna-se irrelevante a concordância delas com a decisão proferida pelo árbitro.

Neste ponto, a imposição da decisão do árbitro, independentemente da concordância das partes, aproxima a arbitragem da jurisdição estatal, na qual também a decisão do juiz lhes é imposta, independentemente da anuência delas.

Entretanto, conforme se verá adiante, a jurisdição, por suas características, não demanda a vontade das partes em nenhum momento, nem na aceitação em submeter o litígio ao Judiciário, nem na escolha do juiz e, muito menos, na aceitação da decisão jurisdicional, dado que a jurisdição é, entre outras coisas, imperativa, inevitável, inafastável e substitutiva da vontade das partes, conforme demonstrado a seguir.

A arbitragem é regulamentada pela Lei n. 9.307/96, que impõe como condições para sua viabilidade, notadamente: a) serem as pessoas envolvidas no litígio capazes de contratar; e b) ser o direito litigioso submetido à decisão do árbitro um direito patrimonial disponível. Nesse sentido, a arbitragem não é admissível caso a situação litigiosa envolva incapazes ou o direito discutido seja indisponível, como questões de estado, guarda de menores, adoção ou alimentos.

A característica impositiva da decisão arbitral e sua proximidade com a atividade jurisdicional estatal são retratadas no art. 31 da mesma lei, que dispõe que a sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.

O árbitro, por sua vez, é um sujeito imparcial, da confiança das partes e escolhido por elas, tendo suas principais características e funções descritas precipuamente nos arts. 13 e 18 da Lei n. 9.307/96.

Nesse sentido, é forçoso concluir-se que o árbitro é exatamente um

terceiro escolhido pelas partes que, de maneira imparcial, deve conhecer do litígio e impor a solução que, para todos os efeitos, terá o mesmo tratamento que a sentença judicial, nos termos do art. 18 da Lei de Arbitragem, que dispõe: “O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário”.

Os demais desdobramentos procedimentais da resolução de litígios pela via da arbitragem disciplinados pela Lei n. 9.307/96 escapam aos objetivos deste item, que se volta basicamente a conceituar a arbitragem e categorizá-la como um meio de resolução da lide fora do Poder Judiciário, desde que haja consenso entre as partes, ao menos, sobre a opção por este método.

3.1.3 Jurisdição: noções preliminares

Em que pese a existência dos meios de resolução da lide acima elencados, fato é que nem todos os litígios podem ser resolvidos por meio deles.

Isso porque a autotutela, salvo exceções, é vedada pelo Direito e, mesmo quando admitida, envolve riscos, muitas vezes desnecessários de serem aceitos pela parte interessada e autorizada a exercê-la.

Já os meios consensuais e a arbitragem, não obstante serem admitidos e até estimulados pelo Direito, por vezes não são aptos a produzir a resolução do litígio, pelo simples fato de que a vontade das partes em solucionarem de maneira consensual o conflito não é exercida, impedindo que esses métodos de solução sejam utilizados em todos os casos.

Por estes motivos, surge para o Direito a necessidade de estruturar outro meio de resolução da lide que possa atingir tal objetivo em todas as situações em que o consenso entre as partes não seja possível, impondo a solução.

Trata-se do método jurisdicional, que conta com a participação do

Estado, que, como terceiro imparcial, impõe a solução da lide independentemente do concurso de vontade das partes.

A jurisdição, nesse contexto, deve ser entendida como o meio de resolução da lide pelo qual o Estado-juiz, terceiro imparcial e estranho ao litígio, impõe uma solução ao conflito que lhe seja apresentado, depois de dada a oportunidade de participação a todos os sujeitos envolvidos e interessados na solução.

Os itens e subitens seguintes destinam-se ao estudo mais aprofundado do conceito e das características da jurisdição.

3.2 Jurisdição: conceito, características e distinção em relação às demais funções do Estado

3.2.1 Poder jurisdicional: distinção e relação com as demais funções do Estado

3.2.1.1 Função jurisdicional e função executiva

A Constituição Federal, como diploma instituidor dos Poderes do Estado e definidor de suas funções, atribui ao Estado outras funções, além da jurisdicional, especialmente a legislativa e a executiva.

Por função executiva deve ser entendida a atividade estatal de administração da máquina pública nela compreendida, desde a chefia do Estado até a gestão do patrimônio público. A função administrativa é exercida pelo Poder Executivo que, mediante a prática de atos concretos, volta-se à realização dos fins estatais e à satisfação das necessidades coletivas⁵⁰.

O Poder Executivo é constituído nas três esferas federativas – federal, estadual e municipal – e responsável pela prestação dos serviços públicos, pela administração dos bens públicos e, mais amplamente, por toda a gestão da máquina pública.

A disciplina da atividade do Poder Executivo em todos os graus e esferas

é ditada por diversos ramos do Direito Público, a começar pelo Direito Constitucional e pelo Direito Administrativo, além de outros ramos, como o financeiro, o tributário, o econômico e o regulatório, entre outros.

Não compete, portanto, a um trabalho voltado à introdução ao estudo do Direito Processual Civil adentrar na investigação das normas reguladoras das atividades executivas do Estado e da conduta de seus servidores e agentes públicos.

Entretanto, é bom que se deixe claro que, como decorrência máxima do Estado Democrático de Direito consagrado pela Constituição Federal, toda a estrutura do Estado, bem como todos os seus agentes sujeitam-se ao Direito, o que implica dizer que o Estado, tal como todos os demais sujeitos, deve obedecer à lei e à Constituição.

A afirmação acima tem ou pode ter reflexos processuais por um motivo muito simples: caso o Estado, por meio de seus servidores e agentes, a pretexto de atingir seus objetivos, pratique atos capazes de lesar ou ameaçar direitos de outros sujeitos, é possível que estes procurem a tutela do Poder Judiciário contra as atitudes lesivas ou abusivas do Poder Executivo.

Além disso, caso as pretensões do Estado (como sujeito de direitos) que podem ser exercidas contra as demais pessoas se tornem litigiosas, isto é, caso sofram resistência da parte que o Estado pretender submeter aos seus interesses, deverá o Estado-administração (Poder Executivo) buscar o Estado-juiz (Poder Judiciário) visando a tutela jurisdicional.

Em outras palavras, o mesmo “Estado”, obviamente por intermédio de órgãos (ou Poderes) diferentes, pode ser parte litigante (Estado-administração ou Poder Executivo) e juiz (Estado-jurisdição ou Poder Judiciário).

Tal dicotomia só é possível em razão da clássica forma de tripartição das funções, consagrada pelo art. 2º da Constituição Federal, que estabelece a

independência entre os Poderes do Estado em um sistema de freios e contrapesos, tornando possível o controle de um Poder contra os abusos e ilegalidades do outro.

Para que o Poder Judiciário exerça seu papel com independência e imparcialidade, a Constituição Federal estabelece algumas garantias institucionais para o próprio Judiciário e para seus membros, com a finalidade de evitar a submissão dos magistrados às autoridades integrantes do Poder Executivo.

Neste contexto, os magistrados possuem as garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídios, nos termos do art. 95 da Constituição Federal.

Atualmente, é muitíssimo comum a presença do Estado em juízo como parte em um processo, sendo os entes públicos os responsáveis por mais da metade dos processos em curso no Brasil.

Apesar de o Estado, como parte, a priori, submeter-se às mesmas regras processuais civis previstas no Código de Processo Civil e na legislação extravagante, aplicável a todos os feitos, a presença do Poder Público em juízo acaba por atrair a incidência de normas processuais especiais aplicáveis somente aos processos que envolvam o Estado, tema que escapa ao objeto deste item⁵¹.

3.2.1.2 Função jurisdicional e função legislativa

Conforme asseverado desde o capítulo inicial, é função do Estado produzir o Direito, especialmente pela criação de normas gerais e abstratas, que descrevem condutas e as qualificam como proibidas, permitidas ou obrigatórias, ou por meio de enunciados mais genéricos, que consagram determinado valor fundamental para o ordenamento jurídico.

No nosso sistema constitucional, a edição de tais normas compete especialmente, ainda que não exclusivamente, ao Poder Legislativo, que o exerce pela edição de leis e outros atos normativos previstos na

Constituição Federal como fontes do Direito⁵².

O Poder Legislativo, dentro das limitações impostas pela Constituição, é livre para fazer escolhas políticas, criando, modificando e estabelecendo direitos, deveres e obrigações, por meio da edição e da alteração de leis e demais veículos normativos, de acordo com a vontade manifestada pelos seus integrantes legitimamente eleitos para tal função, desde que respeitados os parâmetros materiais (princípios e regras constitucionais) e procedimentais (processo legislativo).

Já o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, não é dotado pelo sistema jurídico pátrio de liberdade ou de discricionariedade política para definir ou criar o Direito, produzindo normas gerais e abstratas.

De rigor, o papel do Poder Judiciário é, à luz do caso concreto que se apresente, aplicar a lei, ou mais amplamente as normas gerais e abstratas editadas pelo Legislativo, determinando as providências individuais e concretas para fins de se fazer cessar a lesão ou ameaça a direito reconhecido durante o processo.

Desta feita, não se confundem as atividades legislativa e jurisdicional do Estado, tanto do ponto de vista do Poder dotado de atribuição constitucional para o exercício de cada uma destas funções quanto em relação à atividade a ser desempenhada por cada um destes poderes: ditar normas gerais e abstratas, no caso do Poder Legislativo; e aplicá-las, produzindo comandos individuais e concretos, no caso do Poder Judiciário.

Entretanto, obviamente, a inter-relação das atividades legislativa e jurisdicional é muito grande, dado que, ao interpretar e aplicar as normas gerais e abstratas produzidas pelo Legislativo, o Poder Judiciário acaba por formar sua jurisprudência e a consagrar, em seus precedentes, entendimentos sobre o conteúdo, o alcance e o sentido das normas jurídicas gerais e abstratas produzindo, a partir desta atividade, ainda que de forma derivada, outros comandos igualmente tidos como fontes do Direito⁵³.

Aliás, a influência do Poder Legislativo em relação ao Poder Judiciário é dupla, pois, além de indicar e orientar pela via da edição de normas gerais e abstratas o sentido e o conteúdo da decisão judicial, são as normas produzidas pelo Legislativo, notadamente o Código de Processo Civil e a legislação processual extravagante, que ditam a forma como o processo deverá ser conduzido, ou seja, quais são os poderes e deveres do juiz, bem como quais os direitos e deveres das partes e de todos aqueles que atuem no processo.

É certo, contudo, que, em razão da supremacia normativa da Constituição Federal, a margem de escolha política do Poder Legislativo não é absoluta ou ilimitada, devendo a edição de leis e atos normativos em geral respeitar os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, além de ser absolutamente indispensável para fins de validade do comando normativo a observância do procedimento de edição da legislação, igualmente disciplinado pelo Direito Constitucional, notadamente pelos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.

Em razão desta necessidade de observância dos parâmetros constitucionais e da possibilidade de o Legislativo editar normas incompatíveis com a Constituição Federal, surge a necessidade de um controle de constitucionalidade destes atos normativos, atividade realizada pelo Poder Judiciário.

Assim, por força do sistema de freios e contrapesos, cabe ao Poder Judiciário decidir sobre a adequação de uma norma produzida pelo Poder Legislativo em relação às normas hierarquicamente superiores constantes da Constituição Federal. É incumbência de seu órgão máximo, o Supremo Tribunal Federal, realizar o denominado controle concentrado de constitucionalidade da lei e de outros atos normativos, sendo possível que os demais órgãos do Poder Judiciário verifiquem esta compatibilidade quando da aplicação da lei ao caso concreto.

A atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de

constitucionalidade é prevista na própria Constituição Federal, dando origem à denominada jurisdição constitucional, assim entendida a atividade do Poder Judiciário de fiscalização e julgamento da compatibilidade dos atos do próprio Estado com a Constituição Federal.

O exercício da jurisdição constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, obviamente, deve se dar por um procedimento regulado pela lei e pela própria Constituição, sendo este método de exercício da jurisdição constitucional o denominado processo constitucional a que se fez referência no item 2.2, “d”, supra.

Outra distinção entre as atividades legislativa e jurisdicional está ligada à definitividade de seus comandos jurídicos.

Isso porque, enquanto o comando jurisdicional, individual e concreto, possui a tendência de ser indiscutível e imutável, as normas gerais e abstratas produzidas pelo Legislativo não são necessariamente definitivas, podendo, a partir da modificação da vontade política da sociedade manifestada por seus representantes, serem alteradas ou revogadas, respeitadas as situações consolidadas e julgadas pelo Poder Judiciário, conforme se verá no item 6.1.4.13.

3.2.2 Especialmente sobre a função jurisdicional

De todo o exposto até aqui, é forçoso concluir que escapa ao estudo do Direito Processual Civil a análise das atividades executivas e legislativas do Estado. É certo que tais atividades são estudadas por outros ramos do Direito, notadamente o Direito Administrativo e o Direito Constitucional, sendo a relação do Direito Processual com estes ramos, bem como a da jurisdição com estas outras funções do Estado, referidas nos itens anteriores.

Já o estudo, a sistematização e a total compreensão da função jurisdicional, seu conceito, alcance, características e peculiaridades são imprescindíveis para o estudioso do processo, haja vista ser este o método

de exercício da jurisdição.

Não faria sentido tentar compreender o processo e seus desdobramentos, sem que anteriormente, como pressuposto, não esteja pré-compreendida sua razão de ser, bem como a verdadeira finalidade da relação processual e de tudo que a cerca: o exercício da jurisdição e, ao final, a concessão da tutela jurisdicional à parte que demonstre ter razão.

Por esse motivo, o item seguinte será dedicado a explicitar cada uma das características da jurisdição que, somadas e combinadas, dão a ideia da importância e da dimensão do poder jurisdicional, ao passo que o capítulo subsequente será voltado ao estudo da tutela jurisdicional como produto do exercício da jurisdição por meio do processo.

3.2.2.1 Características da jurisdição

Do conceito acima exposto, depreende-se que a jurisdição possui algumas características que a diferem dos demais meios de resolução da lide e das demais funções do Estado.

A prestação jurisdicional é um serviço público (em sentido amplíssimo), devendo seu exercício ser realizado por pessoas regularmente investidas da autoridade estatal, que devem observar sempre a ordem jurídica, tanto na condução do processo quanto no oferecimento da resposta, pois ambas as atividades devem estar pautadas pelo Direito.

Nesse contexto, a jurisdição é um meio de resolução de conflitos de interesses que se caracteriza por:

- a) não depender do concurso de vontade das partes litigantes, que ficam submetidas à autoridade jurisdicional e a seus comandos, independentemente de aceitarem esta submissão;
- b) ser inerte, só atuando mediante provocação da parte interessada;
- c) impor a solução do conflito, sem a necessidade de aceitação ou concordância das partes litigantes com os termos da decisão;

d) alcançar toda sorte de conflitos jurídicos, sem exceção, independentemente de seu valor econômico, natureza ou pessoas envolvidas;

e) voltar a solucionar a lide de maneira definitiva, tornando imutáveis e indiscutíveis o sentido e o alcance da decisão jurisdicional;

f) como expressão da soberania estatal, poder efetivar e materializar os seus comandos pela força, se necessário;

g) ter de ser prestada de maneira imparcial, o que implica dizer que, no exercício da jurisdição, o sujeito investido da autoridade jurisdicional não pode ter qualquer relação com as partes litigantes ou com o objeto litigioso.

Portanto, são características da jurisdição: a) a inevitabilidade; b) a inércia; c) a substitutividade; d) a inafastabilidade; e) a definitividade; f) a imperatividade; e g) a imparcialidade.

Todas essas características integrantes da jurisdição não apenas a diferem dos demais meios de solução de litígios, como também acabam por definir os contornos e a autoridade do produto da prestação jurisdicional, isto é, a decisão, assim como moldam o modo de ser dessa prestação, ou seja, o processo de tomada da decisão.

O conhecimento das características da jurisdição, portanto, permite vislumbrar seus elementos essenciais, sua abrangência, bem como as consequências e a eficácia da prestação jurisdicional.

Muitas dessas características estão ligadas à ideia de que a jurisdição – ao contrário de outros meios de resolução de conflitos de interesses, acima elencados, como os métodos consensuais e a arbitragem – independe da vontade dos interessados em se submeter ou não se submeter ao Estado-juiz, ou mesmo aceitar ou acolher a determinação jurisdicional, sendo, por outro lado, imprescindível a provocação da parte interessada para que seja exercida.

Nesse sentido, diz-se que a jurisdição é inevitável, inerte e substitutiva

da vontade das partes.

A inevitabilidade ("a") traduz o alcance do Poder Jurisdicional em relação a todos os sujeitos de direito, independentemente da concordância ou aceitação deles em se submeter à autoridade jurisdicional do Estado.

Afirmar que a jurisdição é inevitável conduz à conclusão de que as partes não são sequer consultadas a respeito da vontade de aceitar o juiz, como terceiro imparcial responsável pela solução da lide apresentada, nem mesmo sobre a necessidade ou interesse em utilizar o método jurisdicional como forma de resolver o litígio.

Considerando o caráter inevitável da jurisdição, a única importância do elemento volitivo das partes se revela na vontade unilateral do autor de provocar a jurisdição pelo exercício do direito de ação⁵⁴.

Tal provocação é, a um só tempo, necessária e fundamental para a prestação jurisdicional, uma vez que sem ela não se presta a jurisdição.

Isso porque o Estado-juiz é inerte ("b") e só atua no exercício da jurisdição quando provocado, sendo certo que, uma vez realizada esta provocação, ambas as partes inevitavelmente serão submetidas ao poder jurisdicional.

Em complemento à ideia de inevitabilidade, deve ser destacada outra característica da jurisdição, a substitutividade ("c"), pois, da mesma forma que a vontade das partes em se submeter ao poder jurisdicional é indiferente quando do início do processo, também a aceitação da decisão produzida por meio de seu exercício é absolutamente prescindível e desnecessária para validade e eficácia dela.

Por ser a jurisdição substitutiva da vontade das partes, a decisão jurisdicional é imposta às partes e vale independentemente de aceitarem ou não o comando judicial.

A inevitabilidade e a substitutividade da jurisdição a tornam absolutamente distinta dos demais meios de resolução de conflitos de

interesses, como a arbitragem, na qual o terceiro deve ser aceito ou eleito pelas partes, podendo, por consequência, ser recusado (não possuindo, portanto, a característica da inevitabilidade), ou a solução consensual, na qual as partes precisam concordar com os termos da resolução do conflito (não existindo, portanto, neste ambiente, a substitutividade).

Nesse sentido, a solução encontrada pela via das técnicas consensuais, conciliação e mediação, por exemplo, é apenas e tão somente proposta ou viabilizada pelo terceiro, podendo ser aceita ou recusada pelas partes, ou seja, a solução consensual não substitui, por si só, a vontade das partes, que precisam se manifestar em concordância com a proposta de resolução para que o conflito seja resolvido por esse meio.

A jurisdição, como colocado, possui características próprias, pois tanto o juiz quanto sua decisão se impõem, independentemente da vontade das partes, revelando-se nestes termos as características da inevitabilidade ("a") e da substitutividade ("c"), devendo, apenas, para que esta autoridade seja exercida, o Poder Judiciário ser provocado pela parte interessada, uma vez que a jurisdição é inerte ("b"), só podendo o juiz exercê-la quando provocado.

Deve ser somada à inevitabilidade, à substitutividade e à inércia a capacidade de a jurisdição alcançar toda a sorte de conflitos, o que se denomina inafastabilidade ("d").

A característica da inafastabilidade está consagrada na Constituição Federal como um direito fundamental, não podendo, em função disso, ser afastada por lei ou por qualquer comando jurídico⁵⁵.

Por essa razão, nenhuma questão jurídica, isto é, nenhuma lesão ou ameaça a direito, pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, o que implica dizer que o controle jurisdicional é inafastável, por lei ou qualquer outro ato normativo ou poder estatal.

Desta feita, no que tange à sua abrangência, a ideia de inafastabilidade

(“d”) permite concluir que a atuação jurisdicional pode alcançar toda e qualquer situação jurídica litigiosa, sem exceção, independentemente de seu valor econômico, natureza ou pessoas envolvidas.

A inafastabilidade aqui comentada distingue a jurisdição dos demais meios de resolução da lide, uma vez que determinados tipos de conflitos, por envolverem direitos classificados como indisponíveis, não podem se submeter a outras formas de solução que não a jurisdicional.

Em outras palavras, o ordenamento jurídico pode proibir a utilização da arbitragem, da conciliação e da mediação na resolução de determinados tipos de litígios, afastando o emprego desses meios de solução de conflitos quando o direito discutido envolver, por exemplo, pessoas incapazes ou direitos indisponíveis. Já a jurisdição, por ser inafastável, alcança inclusive esses litígios, sendo, nessas situações, o único meio de resolução possível.

Desta feita, questões relacionadas à adoção de menores, por exemplo, entre outros direitos indisponíveis, são excluídas pela lei do alcance da arbitragem e dos meios de solução consensual, devendo ser decididas, exclusivamente, mediante o exercício da jurisdição.

Por outro lado, vale dizer que a inafastabilidade não impede que as partes, em comum acordo, optem por escaparem do Poder Judiciário e submeterem o conflito à arbitragem. Em outras palavras, uma vez manifestada a vontade de submeter o conflito à arbitragem, resta inviabilizada a busca do Poder Judiciário, o que não é incompatível com inafastabilidade da jurisdição, exatamente porque essa vedação de acesso é fruto de expressa manifestação de vontade dos sujeitos em conflito⁵⁶⁻⁵⁷.

Além de tudo isso, outras duas características fundamentais que aderem à decisão jurisdicional são: a definitividade (“e”) e a imperatividade (“f”).

Dizer que a decisão jurisdicional é dotada de definitividade (“e”) significa que, uma vez finalizado o processo e esgotados todos os meios de defesa e recursos cabíveis, o comando jurisdicional não mais poderá ser questionado

em outro processo, quer perante outro órgão jurisdicional, quer, muito menos, perante outro órgão estatal não jurisdicional.

Ademais, conforme será demonstrado no item 6.1.4.13 do Capítulo 6, nem mesmo uma nova lei, editada pelo Poder Legislativo, poderá modificar ou revogar uma decisão jurisdicional definitiva.

A imperatividade ("f"), por sua vez, demonstra a autoridade e a eficácia da decisão jurisdicional, que deve ser obedecida e cumprida pela parte, independentemente de sua aceitação, sob pena de execução forçada, isto é, de uso da força estatal para se fazer cumprir o comando jurisdicional.

Em razão da imperatividade ("f"), a decisão judicial deverá ser cumprida e, em caso de descumprimento, a atividade processual voltar-se-á à concretização deste comando por meio da prestação de uma tutela jurisdicional executiva⁵⁸.

Em função de todo esse peso e da autoridade que possui o comando jurisdicional revelado por todas as suas características, o mínimo que o Estado-juiz deve garantir é que o sujeito investido de jurisdição não tenha qualquer interesse na vitória de uma das partes.

A jurisdição, para que seja prestada corretamente, deve ser dotada da característica da imparcialidade ("g").

A imparcialidade, portanto, é um atributo que deve sempre estar presente quando do exercício da jurisdição, sob pena de este exercício e de seu produto, a tutela jurisdicional, restarem contaminados e, portanto, imprestáveis para o Direito.

Até para que se mantenha a imparcialidade supramencionada, todo o aparato jurisdicional e o próprio exercício da jurisdição só entram em movimento caso haja provocação por uma das partes envolvidas no conflito, sendo vedada a prestação jurisdicional por iniciativa do próprio Estado-juiz.

Por esse motivo, outra característica da jurisdição digna de nota é a já citada inércia ("b"), assim entendida a impossibilidade de o juiz agir antes

da provocação, conforme já asseverado.

Portanto, considerando o peso, representado pela ideia da definitividade e da imperatividade da jurisdição, somado ao alcance da jurisdição sobre toda a sorte de conflitos jurídicos (inafastabilidade), independentemente de as partes envolvidas concordarem em se submeter a ela (inevitabilidade) ou de concordarem com a decisão jurisdicional, pelo fato de tal decisão substituir a vontade das partes litigantes (substitutividade), surge a necessidade de se regulamentar a atividade jurisdicional do Estado, controlando a autoridade estatal e permitindo a participação ampla dos sujeitos envolvidos no conflito na tomada de decisão pelo juiz.

O processo, na qualidade de método de atuação do Estado-juiz no exercício da jurisdição, e seus principais desdobramentos, como as formas, prazos e oportunidade de participação das partes conflitantes, são definidos pelo Direito Processual Civil, que se expressa por meio de normas consagradas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, notadamente as leis federais.

Estas normas, a começar pelas de maior hierarquia e, por consequência, fundamentais para o sistema processual, ou seja, as normas processuais consagradas na Constituição Federal, serão objeto de estudo a partir do Capítulo 6.

Antes disso, nos Capítulos 4 e 5, serão tecidas considerações sobre o produto do exercício da jurisdição pelo Estado, a denominada tutela jurisdicional, bem como acerca das pessoas e órgãos que estão investidos desta função estatal, o Poder Judiciário.

Capítulo 4 Tutela Jurisdicional

4.1 Tutela jurisdicional: conceito

Tutela jurisdicional é toda a proteção concedida pelo Estado, no exercício da jurisdição, por meio do processo, aos direitos controvertidos que lhe sejam apresentados.

Portanto, em última análise, pode-se afirmar que a tutela jurisdicional é o produto do processo, isto é, o resultado de toda a atividade processual das partes, do juiz e de seus auxiliares.

Conforme muito bem assevera José Roberto dos Santos Bedaque, ao contrário do direito de ter acesso ao Poder Judiciário, que é de todos e decorre do art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, o direito à tutela jurisdicional garante a prestação jurisdicional em favor daquele que tem razão nos termos do direito material.

O mesmo doutrinador salienta, com propriedade, que “o estudo do processo pela perspectiva do direito de acesso ao Poder Judiciário não satisfaz. (...) Necessário que o consumidor do serviço jurisdicional obtenha a satisfação total de seus interesses legitimamente postulados, pois apenas esse resultado atende à promessa estatal de proteção aos direitos”⁵⁹.

Deve receber a tutela jurisdicional aquele que esteja amparado pelas normas de direito material.

Assim, caso o autor demonstre ao juiz que possui razão em seu pleito, a ele deverá ser entregue a tutela jurisdicional, assim entendida a verdadeira reparação ou mesmo inibição da ocorrência da lesão ao direito ameaçado, sendo, nesse contexto, a tutela jurisdicional, enquanto proteção ao direito lesado ou ameaçado, o conjunto de atividades voltadas a (re)estabelecer tudo aquilo e exatamente aquilo a que o autor tem o direito de obter.

O processo, na clássica lição de Chiovenda, deve proporcionar àquele

que teve seu direito lesado, na medida do possível, o mesmo direito que teria se não houvesse ocorrido a transgressão.

Contudo, caso a pretensão seja tida pelo juiz como infundada, a tutela jurisdicional deve ser concedida ao réu, que, com o provimento de improcedência, tem assegurado o direito à integridade de sua esfera jurídica⁶⁰.

Por haver uma grande diversidade de situações jurídicas no plano do direito material, ao qual a tutela jurisdicional está intimamente ligada, diversas são as espécies de tutela jurisdicional, o que implica dizer que não existe um único processo ou uma única forma de se tutelar uma situação litigiosa.

As diversas formas de se tutelar uma situação litigiosa autorizam a possibilidade de classificação da tutela jurisdicional.

Entretanto, é certo que a atividade de classificar é um procedimento lógico de dividir em conjuntos uma série de objetos a partir de critérios preestabelecidos. É recorrente na doutrina a afirmação que não existem classificações certas e erradas, mas classificações úteis e inúteis.

Teresa Arruda Alvim⁶¹ assevera, acerca das classificações jurídicas, que “no direito, além de as classificações serem úteis por, de certo modo, auxiliar na compreensão do(s) objeto(s) estudado(s), há também uma outra forma de classificações, que é, precisamente, enquadrar determinado objeto classificado em determinado regime jurídico preestabelecido”.

Portanto, se, de um lado, é correto afirmar que qualquer pronunciamento ou decisão judicial capaz de proteger o direito lesado ou ameaçado objeto do processo pode ser genericamente classificado como tutela jurisdicional, de outro, é igualmente certo e importante que, dentro deste universo, é possível identificar algumas espécies ou formas de proteção que, por força destas diferenças, acabam por influenciar a atividade das partes do juízo e, por via de consequência, o processo e o procedimento.

Por estas razões, é importante que o sistema processual classifique as espécies de tutela jurisdicional, dividindo-as em grupos que, em função das finalidades a serem alcançadas e das peculiaridades de cada uma delas, delineiam a relação processual, o procedimento e a própria prestação jurisdicional.

As quatro classificações propostas neste capítulo partirão de critérios de grande repercussão prática e que realmente diferenciam e influenciam o modo de ser do processo enquanto instrumento de prestação da tutela jurisdicional, ou seja, influenciam não apenas no procedimento, mas em institutos processuais básicos como a legitimidade para agir, a extensão da coisa julgada, os direitos, os poderes e os deveres das partes, do juiz e de todos aqueles que atuem no processo.

Serão objeto de análise e comparação as classificações da tutela jurisdicional: a) à luz da atividade preponderantemente desempenhada pelas partes e pelo juízo, que separa as tutelas jurisdicionais em de conhecimento e executiva; b) à luz da definitividade do provimento jurisdicional que concede a tutela, que divide a tutela jurisdicional em definitiva e provisória; c) à luz da existência ou inexistência de conflito a ser resolvido pelo juiz por meio do processo, que opõe a jurisdição contenciosa (regra) à jurisdição voluntária; e d) à luz da espécie de direito tutelado pelo processo, se individual ou coletivo.

4.2 Classificação da tutela jurisdicional

4.2.1 Tutela jurisdicional de conhecimento e tutela jurisdicional executiva

a) Tutela jurisdicional de conhecimento

A dicotomia que permite a classificação da tutela jurisdicional em de conhecimento ou de execução baseia-se na atividade precípua desenvolvida pelas partes e pelo juízo e, por via de consequência, pela finalidade do

processo.

Definir se a tutela jurisdicional pretendida é de conhecimento ou de execução é importante critério distintivo que influenciará sobremaneira a atividade das partes e do juízo, bem como o modo de ser do procedimento.

A tutela jurisdicional de conhecimento se caracteriza por ser uma atividade que, em última análise, volta-se a declarar qual das partes litigantes tem razão e, portanto, possui o direito de ver reconhecido e entregue o bem jurídico litigioso objeto do processo.

Nos capítulos iniciais desta obra, a maioria dos exemplos e situações trazidas encerram hipóteses de litígios que demandam uma tutela jurisdicional de conhecimento.

Assim, todas as vezes que dois ou mais sujeitos afirmem ser titulares de um mesmo bem jurídico, dar-se-á, de um lado, a pretensão e, de outro, a oposição característica da resistência, o que é suficiente para gerar uma lide e tornar necessária a prestação da tutela jurisdicional.

A prestação desta tutela jurisdicional é feita pelo juiz, por meio do processo de conhecimento em cujo procedimento estão estabelecidas etapas voltadas exatamente à possibilidade de produção de alegações (de fato e de direito) pelas partes, à produção de provas e, ao final, ao julgamento.

Assim, instaura-se o processo, método voltado a viabilizar ao magistrado conhecer do litígio para, uma vez conhecedor da controvérsia, julgar, isto é, declarar quem tem razão.

Toda a atividade voltada ao julgamento, ou seja, à prestação de tutela jurisdicional de conhecimento, deve se dar no denominado processo de conhecimento.

O processo de conhecimento possui esta nomenclatura pois, para que seja possível a consecução de seu objeto final, o julgamento, faz-se necessário que o magistrado conheça todos os elementos do litígio.

Assim, apesar de toda a atividade e o produto final da tutela de conhecimento ser o julgamento, as atividades das partes e do juiz e de seus auxiliares voltam-se muito mais à demonstração dos fatos e demais aspectos relevantes para a resolução do litígio.

No processo voltado à prestação da tutela jurisdicional de conhecimento, as atividades primordiais das partes são o oferecimento de alegações, por meio de petições, contestações ou, mais amplamente, defesa e produção de provas todas as vezes que se mostrar necessária a demonstração, para o magistrado, da ocorrência de fatos relevantes para o julgamento da causa.

O juiz, por sua vez, nos processos voltados à prestação da tutela jurisdicional de conhecimento, possui como atividade precípua conhecer do litígio para, ao final do procedimento, julgar a lide.

a.1) Subclassificação da tutela jurisdicional de conhecimento: tutela meramente declaratória, tutela constitutiva e tutela condenatória

A tutela jurisdicional de conhecimento admite uma subclassificação, de acordo com a pretensão do autor da ação, que influencia diretamente o conteúdo e a eficácia do pronunciamento do juiz.

Nesse sentido, subdivide-se a tutela jurisdicional de conhecimento em três: a) tutela meramente declaratória; b) tutela constitutiva; e c) tutela condenatória⁶².

A tutela jurisdicional de conhecimento, de natureza meramente declaratória, tem lugar sempre que a intenção da parte e, por via de consequência, o objeto do processo, for a resolução de uma crise de certeza.

Nesse sentido, a tutela jurisdicional meramente declaratória (“a”) é voltada, única e exclusivamente, à declaração da existência ou da inexistência da relação jurídica ou à declaração de veracidade ou falsidade

de um documento.

Tal declaração, por si só, é suficiente ao autor da demanda e capaz de solucionar o litígio e pacificar o conflito.

Um exemplo clássico de tutela jurisdicional meramente declaratória ocorre nos processos cujo mérito é a investigação e, se for o caso, a declaração de paternidade, que tem lugar ainda que a parte interessada na declaração não possua nenhum outro interesse econômico ou patrimonial direto decorrente de tal declaração, haja vista que o estado de filiação, por si só, importa ao ordenamento jurídico em grau suficiente para que se justifique a atividade jurisdicional voltada a sua definição.

A tutela jurisdicional meramente declaratória é expressamente admitida pelo Código de Processo Civil, que dispõe, em seu art. 19 que “o interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II – da autenticidade ou da falsidade de documento”, no que é complementado pelo art. 20, que estabelece ser “admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito”.

Assim, em todas as vezes que a existência de uma relação jurídica, que se demonstre questionada ou controversa, se revelar juridicamente relevante para determinado sujeito, tem lugar o pedido de prestação de tutela jurisdicional de conhecimento meramente declaratória, para que o juiz, por meio do processo, após ouvidas as partes interessadas e conhecidos os elementos do litígio, se pronuncie acerca da existência ou da inexistência da relação jurídica controvertida.

O mesmo ocorre nos casos em que a dúvida existente recai sobre a falsidade ou a autenticidade de um documento, em função da relevância que os documentos têm para o ordenamento jurídico como um todo e, em especial, para a prova da existência de atos e relações jurídicas.

Assim, sempre que se verificar a controvérsia acerca da autenticidade de

documento, como certidões de nascimento, casamento ou óbito e até mesmo de assinaturas constantes de um documento, é admitido que o sujeito interessado na declaração da autenticidade ou da falsidade ajuíze uma ação requerendo a declaração judicial sobre o ponto, almejando a prestação de uma tutela jurisdicional meramente declaratória, portanto.

A principal inovação, assim entendida a melhora na situação jurídica do sujeito que tem razão quando da prestação da tutela jurisdicional de conhecimento meramente declaratória, consiste na certeza da existência ou da inexistência da relação objeto do processo, uma vez que tal tutela é definitiva, imperativa e substitutiva da vontade das partes e, por isso, estabelece uma “verdade jurídica” que, em si mesma, pode não apenas tutelar o direito do interessado como satisfazê-lo.

Já a tutela jurisdicional de conhecimento constitutiva (“b”) tem por escopo, além da declaração, a modificação da situação jurídica posta em juízo.

Nesse contexto, se comparada à tutela meramente declaratória, que se ocupa de investigar e declarar a existência de uma situação já consolidada, tendo, portanto, como fator diferencial, a certeza emprestada pela função jurisdicional, a tutela constitutiva representa, quando prestada, uma inovação na ordem jurídica, pois cria ou modifica uma situação até então inexistente.

Um bom exemplo de tutela jurisdicional constitutiva ocorre nas ações cujo objeto é a nomeação de um curador, isto é, de um responsável legal por uma pessoa que, por força de uma enfermidade, não detenha capacidade civil.

Nesse contexto, ajuizada uma ação em que alguém apresente a situação de necessidade de constituição de curatela e pretenda ser assim constituído, ocorrerá, se acolhido o pedido, a prestação da tutela jurisdicional de conhecimento constitutiva, na qual restará, ao final do processo, criada uma situação jurídica até então inexistente entre curador e

incapaz.

Ademais, além de criar, a sentença constitutiva pode tanto modificar quanto extinguir direitos, admitindo-se, portanto, uma espécie de tutela desconstitutiva no último caso.

Retomando o exemplo anterior, será prestada a tutela desconstitutiva quando restar demonstrado, em um processo, que o curador do incapaz age de maneira prejudicial e contrária aos interesses do curatelado, devendo a decisão judicial que reconhece tal prejuízo, extinguir a relação de curatela neste caso.

Outras inúmeras situações de tutela jurisdicional constitutiva decorrem de processos em que se discute a validade dos contratos e outras relações contratuais, em que estas podem ser extintas, quando reconhecida a ilicitude do contrato; modificadas, quando reconhecida a nulidade de algumas cláusulas contratuais; e até mesmo criadas, quando, por exemplo, acolhida a pretensão do autor de uma ação que pretenda converter uma promessa de compra e venda em um contrato de compra e venda.

Por fim, a tutela jurisdicional de conhecimento pode ser subclassificada como condenatória, caracterizada por ser uma espécie de tutela jurisdicional que agrega à decisão judicial que declara quem tem razão uma determinação do juiz para que a parte contrária (condenada) pague determinada quantia, entregue algo, ou, mais amplamente, faça ou deixe de fazer alguma coisa.

Portanto, tutela jurisdicional condenatória ("c"), a par de estabelecer a certeza quanto a um direito, cria condições necessárias para a que haja a reparação do dano⁶³, ou impede a efetivação da lesão, autorizando, nos casos de descumprimento da ordem judicial condenatória pela parte condenada, a prática de atos executivos consistentes na prestação de uma outra espécie de tutela jurisdicional, a executiva.

Assim, a tutela condenatória, neste contexto, seria aquela voltada à,

além de declarar o direito, autorizar o acesso à via jurisdicional executiva.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim e José Miguel Garcia Medina⁶⁴ afirmam que “a sentença condenatória supõe a ideia de que é possível após a realização de cognição exauriente e definitiva, a obtenção de grau razoável de certeza acerca do direito que autorize a realizar a execução”.

Luiz Guilherme Marinoni também tem concepção semelhante acerca da sentença condenatória e afirma que a doutrina que a definiu estabeleceu uma correlação entre ela e os meios de execução tipificados em lei, asseverando que “afora os casos de adimplemento espontâneo do direito contido na sentença condenatória a tutela do direito dependeria da propositura da ação de execução, oportunizada ao vencedor pela sentença”⁶⁵.

Portanto, se de um lado as sentenças que prestam tutela jurisdicional declaratória e constitutiva valem por si sós, sendo desnecessária qualquer outra atividade jurisdicional para a proteção do direito pleiteado, declarado ou constituído pela sentença, a sentença que presta tutela jurisdicional condenatória necessita do cumprimento voluntário pelo condenado ou da prestação de outra espécie de tutela jurisdicional voltada a sua efetivação, a tutela jurisdicional executiva, a seguir estudada.

b) Tutela jurisdicional executiva

Apesar de o processo, por pressupor litígio, via de regra, clamar por um julgamento, ou seja, por um pronunciamento jurisdicional sobre quem tem razão, nem sempre é esta a espécie de tutela jurisdicional necessária para a pacificação do conflito.

Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antônio Carlos Cintra do Amaral⁶⁶ afirmam que, além de formular concretamente a regra jurídica válida para o caso concreto, é necessário atuá-la, modificando a situação de fato existente, adaptando-a ao comando jurisdicional.

Assim, na hipótese de descumprimento da ordem jurisdicional contida no

comando condenatório, torna-se necessária a prestação de outra espécie de tutela jurisdicional voltada à efetivação deste comando.

Portanto, nestas hipóteses, não se estará diante da necessidade de prestação da tutela jurisdicional de conhecimento por ser dispensável o julgamento e necessária, na verdade, a prática de atos voltados à efetivação do direito já expressamente reconhecido como existente.

Esta espécie de tutela jurisdicional voltada à realização, ou seja, à concretização e à efetivação, no plano dos fatos, de um direito já consagrado e reconhecido pelo ordenamento jurídico como existente se dá por meio da denominada tutela jurisdicional de execução.

Desta feita, o escopo dos procedimentos voltados à prestação da tutela de execução é a realização de atos materiais pelo Estado-juiz, por intermédio do processo, para concretização, no plano fático, de um comando contido em uma decisão judicial ou em um título dotado por lei de eficácia executiva.

Portanto, se de um lado temos processos voltados à prestação da tutela jurisdicional de conhecimento, ou seja, à análise de fatos e normas jurídicas, com a finalidade de conhecer e declarar o direito aplicável ao caso concreto, de outro temos processos e procedimentos voltados à prestação de tutela jurisdicional de execução, que se ocupam muito menos da investigação de existência do direito, e muito mais da realização prática de atos voltados à efetivação do direito constante no título, invadindo coercitivamente a esfera jurídico-patrimonial do executado.

Por serem completamente diferentes os objetos do processo de execução e do processo de conhecimento⁶⁷, diferentes também são os atos processuais praticados pelo juiz em cada uma das espécies de prestação jurisdicional.

No processo de conhecimento, o juiz ouve as partes acerca de suas alegações de fato e de direito, designa audiência, a preside, inquire

testemunhas, delibera acerca da produção e da valoração das provas e, por fim, toma uma decisão.

Já no processo de execução, o juiz, no desempenho da atividade executiva, realiza atos de natureza radicalmente diversa daqueles proferidos no processo de cognição⁶⁸. O magistrado, no processo de execução, pratica ou determina a prática, precipuamente, de atos executivos.

Os atos executivos, portanto, são aqueles proferidos pelo juiz da execução, visando a invasão da esfera patrimonial do executado, quer de maneira direta, quer de maneira indireta, para satisfazer o direito que o exequente pleiteia realizar por meio do processo de execução.

Araken de Assis, em sua clássica obra⁶⁹, exemplifica e classifica os atos executivos em: a) atos de apreensão e constrição, dos quais a penhora é exemplo típico; b) atos de transformação, como a execução de obrigação de fazer fungível; c) atos de custódia, como o depósito de coisa penhorada; d) atos de dação, v.g., a entrega do dinheiro produzido pela expropriação; e) atos de transferência, como a arrematação; f) atos de pressão, de execução indireta, por visar a realização do ato satisfativo do direito do exequente pelo próprio executado, por meio de instrumentos de pressão psicológica, como a multa pecuniária e a prisão do executado, nos casos em que esta é admitida.

Todos estes atos processuais possuem em comum a capacidade de concretizar e realizar direitos, transformando a realidade dos fatos.

Assim, são atos típicos do processo de execução, o bloqueio de contas-correntes e aplicações financeiras do devedor e a consequente transferência destes valores para a esfera do credor; a busca e apreensão de bens para entrega ao efetivo titular; a retirada de pessoas ou coisas de locais quando determinado pelo magistrado.

Obviamente, tais atos de desforço e constrictivos de direitos devem se dar

nos termos da lei e no curso do processo, sendo este o instrumento de prestação da tutela jurisdicional executiva.

Dada a grande repercussão, na esfera jurídica do executado, a prática de atos executivos como os elencados possuem um indispensável pressuposto sem o qual não se inicia a atividade jurisdicional executiva: a existência de um título executivo que retrate o direito a ser executado.

Desta feita, o grande pressuposto autorizativo para a prestação da tutela jurisdicional executiva é o título executivo.

Por título executivo, deve ser entendido todo o documento, tipificado em lei, apto a autorizar a tutela jurisdicional executiva voltada à efetivação de um direito líquido, certo e exigível que esteja nele representado.

Do conceito exposto, destaca-se, em primeiro lugar, a condição do título como documento indispensável para que o titular do direito tenha acesso à tutela jurisdicional executiva, sendo certo, por outro lado, que a existência do título é condição suficiente para prestação desta espécie de tutela.

Cassio Scarpinella Bueno⁷⁰ leciona que o título executivo é o pressuposto necessário e suficiente para a prática de atos executivos. Necessário, pois não há execução sem título; e suficiente porque “basta a apresentação do título para o início dos atos executivos pelo Estado-juiz, independentemente de qualquer juízo de valor expresso acerca do direito nele retratado”⁷¹.

Por serem o único meio de acesso à tutela jurisdicional executiva, os documentos só adquirem a natureza de títulos executivos se, expressamente, assim tipificados em lei.

Em outras palavras, apenas a lei federal pode atribuir a um documento a qualidade de título executivo apto a autorizar a prestação da tutela jurisdicional executiva.

Essa tipificação é feita, especialmente, pelos arts. 515 e 784 do Código de Processo Civil, que arrolam, respectivamente, os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, sendo certo que outras leis federais, igualmente,

podem atribuir esta natureza a outros documentos.

São títulos executivos judiciais, nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil: “I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; II – a decisão homologatória de autocomposição judicial; III – a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; IV – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal; V – o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; VI – a sentença penal condenatória transitada em julgado; VII – a sentença arbitral; VIII – a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; IX – a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os títulos executivos judiciais, portanto, são decisões jurisdicionais, ou pronunciamentos a estas equiparados por lei, fruto, portanto, de um procedimento em contraditório voltado ao julgamento de uma situação litigiosa.

O principal título executivo judicial é exatamente a decisão judicial que reconhece a exigibilidade de uma obrigação, nos termos previstos no art. 515, inc. I, do CPC, ao qual muito se assemelham as situações descritas nos incs. II a V do mesmo artigo, todos, em última análise, frutos de procedimentos de órgãos jurisdicionais no exercício da jurisdição civil.

Situações distintas que, para fins de viabilidade da execução, recebem o mesmo tratamento legislativo são as previstas nos incs. VI e VII do art. 515 do CPC.

Isso porque, nestas duas situações, as decisões que reconhecem a existência do direito, classificadas como títulos executivos judiciais e que, portanto, autorizam a execução pela via jurisdicional, são frutos de procedimentos que não podem ser enquadrados como de jurisdição civil.

A primeira situação diz respeito à sentença penal condenatória transitada em julgado que, nos termos do art. 515, inc. VI, do Código de Processo Civil, é título executivo judicial autorizador da execução civil, apesar de ser fruto do exercício da jurisdição penal⁷².

Assim, partindo do pressuposto que o ilícito penal reconhecido ao fim do processo penal também é um ilícito civil e que a prática do delito penal tem, potencialmente, a capacidade de causar prejuízos de ordem patrimonial à vítima, o Código de Processo Civil permite o aproveitamento da condenação penal para fins de autorização da prestação da tutela jurisdicional executiva voltada à efetivação do direito a indenização.

É certo, contudo, que a sentença penal condenatória não define todos os contornos do direito relativos à indenização, uma vez que o objetivo do processo penal é a verificação da prática delituosa, sua autoria e a aplicação da sanção penal.

Por essa razão, via de regra, para que se inicie a prestação da tutela jurisdicional civil executiva, faz-se necessária a identificação dos contornos restantes da obrigação civil (indenização) e, em especial, o seu quantum.

Portanto, a execução da sentença penal condenatória pressupõe a liquidação do julgado, assim entendido, a apuração do valor da indenização causada pela prática delituosa reconhecida pela sentença penal.

Outra situação que escapa à jurisdição civil estatal é a formação da sentença arbitral, título executivo judicial, nos termos do art. 515, inc. VII, do CPC e do art. 31 da lei de arbitragem (Lei n. 9.307/96), apesar de o árbitro não integrar o Poder Judiciário.

De rigor, portanto, considerando que o árbitro privado eleito pelas partes não se confunde com os membros do Poder Judiciário, é correta a afirmação da doutrina no sentido de que a sentença arbitral é reconhecida como título executivo judicial por equiparação legal, no caso, pelo art. 515, inc. VII, do Código de Processo Civil.

A necessidade de ingresso da execução, perante o Poder Judiciário, da sentença arbitral descumprida pela parte condenada nesta sede decorre do fato de, ao contrário da atividade de conhecimento que, por convenção das partes, pode ser delegada a particulares pela instituição de arbitragem, a atividade de execução, ou seja, o poder de praticar atos executivos, ser monopólio do Estado.

Em outras palavras, o Direito brasileiro admite que a atividade de cognição e julgamento seja exercida por particulares (Lei n. 9.307/96 – que regula a arbitragem no Brasil). Contudo, os árbitros não possuem o poder de realizar atos coercitivos, de invasão da esfera patrimonial do devedor, para concretizar o decidido na sentença arbitral.

O vencedor, na demanda arbitral, caso não obtenha o cumprimento espontâneo por parte do sucumbente, deve, valendo-se da sentença do árbitro (que possui natureza, nos termos do art. 515, inc. VII, do CPC, de título executivo judicial), executá-la perante o Poder Judiciário, dado o monopólio estatal da jurisdição executiva.

Em suma, é correto afirmar que o Estado detém o monopólio dos atos executivos, e é o Poder Judiciário o ente estatal competente para realizá-los, por ser o encarregado do exercício da jurisdição.

Desse modo, sempre que reconhecido o direito e, ainda assim, subsistir a insatisfação em função do inadimplemento pelo obrigado, nasce a necessidade de execução forçada e, por via de consequência, a necessidade de a parte interessada provocar o judiciário demandando a prestação de tutela jurisdicional executiva.

De toda forma, dada a categorização estabelecida pelo art. 515 do Código de Processo Civil, a sentença arbitral equipara-se à sentença judicial e aos demais títulos executivos judiciais para fins de execução de seus comandos.

Os desdobramentos procedimentais da execução dos títulos judiciais se

desenvolvem por meio do denominado cumprimento de sentença, disciplinado entre os arts. 513 e 538 do Código de Processo Civil, cujos prazos, formas e demais aspectos procedimentais escapam ao objeto deste item.

Já os títulos executivos extrajudiciais se caracterizam por serem documentos tipificados em lei como autorizadores da prestação da tutela jurisdicional executiva sem a necessidade de atividade jurisdicional de conhecimento para sua constituição.

Em outras palavras, os títulos executivos extrajudiciais são documentos constituídos pelas partes que, desde que observada a forma e os demais requisitos previstos em lei, tornam desnecessária a atividade de conhecimento e viabilizam, desde já, a atividade jurisdicional voltada à efetivação do direito nele representado.

O art. 784 do Código de Processo Civil identifica como títulos executivos extrajudiciais: "I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II – a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V – o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI – o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII – o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII – o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X – o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia

geral, desde que documentalmente comprovadas; XI – a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.

A exigência de tipificação em lei federal não condiciona a caracterização de um documento como título executivo extrajudicial no referido dispositivo ou mesmo no Código de Processo Civil, sendo possível a criação de um título com esta natureza em qualquer outra legislação processual extravagante.

Nesse sentido, por exemplo, a Lei n. 8.906/94 que, em seu art. 24, estabelece ser título executivo o contrato escrito que estipular honorários advocatícios e a Lei n. 12.529/2011 que, em seu art. 93, estabelece que “a decisão do Plenário do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, cominando multa ou impondo obrigação de fazer ou não fazer, constitui título executivo extrajudicial”.

Obviamente, por força do art. 22, inc. I, da Constituição Federal, nenhum outro diploma normativo que não seja a lei federal ou, obviamente, a própria Constituição⁷³, é capaz de tipificar um documento como título judicial.

Nesse sentido, deve ser compreendida a cláusula constante no art. 784, inc. XII, do Código de Processo Civil.

Fora destas hipóteses, qualquer outro documento representativo de um direito deve ser apresentado como prova pelo seu pretendente no curso de um processo voltado à prestação da tutela jurisdicional de conhecimento para que, uma vez demonstrada sua existência e reconhecida judicialmente por sentença (título executivo judicial), seja viabilizada a execução e a materialização do referido direito.

O estudo e a sistematização de cada um dos títulos executivos, bem

como a dinâmica procedimental da prestação da tutela jurisdicional executiva, escapam ao objeto desta Introdução, sendo suficiente, nesta sede, o registro de seu conceito e sua finalidade, bem como de seu pressuposto fundamental, qual seja, o reconhecimento do direito em um título executivo, judicial ou extrajudicial.

É importante observar que a forma de se prestar a tutela jurisdicional executiva é diferente, caso o direito esteja fundado em um título extrajudicial, se comparada aos direitos reconhecidos em títulos executivos judiciais.

Isso porque, enquanto os títulos executivos extrajudiciais são executados pela via do processo de execução, uma relação jurídica até então inexistente e especificamente constituída e voltada à efetivação do direito nela retratado, os direitos consagrados nos títulos executivos judiciais são efetivados pela via do cumprimento de sentença, uma mera “fase executiva” que se sucede ao procedimento de conhecimento.

Por esse motivo, tutela jurisdicional executiva (ou simplesmente execução), não deve ser tida como sinônimo de processo de execução. Isso porque, entre os dois termos, na realidade, há uma relação de gênero e espécie, ou seja, a tutela jurisdicional executiva, gênero, pode ser prestada por meio do processo de execução, ou por outros mecanismos processuais, como o cumprimento de sentença, já referido.

4.2.2 Tutela jurisdicional provisória e definitiva

Outra forma de classificar a tutela jurisdicional opõe a tutela definitiva e a tutela provisória.

A definitividade, assim entendida a capacidade adquirida pela decisão judicial de se tornar indiscutível e imutável, conforme já asseverado⁷⁴, é uma das características essenciais da jurisdição, indispensáveis para que esta cumpra seu papel de solucionar o litígio.

Isso porque, se fosse possível rediscutir em outro processo a solução

imposta pelo juiz ao conflito apreciado e julgado, de rigor não se estaria diante de uma verdadeira resolução da lide. Em suma, só se pode considerar o litígio resolvido caso essa resolução seja definitiva, indiscutível e imutável.

Ocorre que, para que a definitividade da decisão seja legitimamente alcançada e imposta às partes interessadas, faz-se necessário que previamente lhes sejam dadas todas as oportunidades processuais decorrentes do contraditório e ampla defesa⁷⁵, tais como a oitiva de suas alegações de fato e de direito, produção de provas e até mesmo interposição de recursos.

Toda essa atividade processual, naturalmente, demanda tempo, sendo este, portanto, um “preço” a pagar para o alcance legítimo da definitividade do comando jurisdicional.

Em outras palavras, a definitividade da tutela jurisdicional é alcançada ao final do processo, após esgotadas todas as oportunidades processuais.

Assim, é a tutela prestada ao final do processo aquela com a capacidade de se tornar definitiva, exatamente, por ser este o momento em que pode se pressupor ter sido realizada uma atividade processual plena e uma cognição exauriente.

Por cognição exauriente deve ser entendida a atividade de conhecimento completa, em que todas as formas de exercício dos direitos de alegar e provar tenham sido exercidas pelas partes e conhecidas pelo juízo ou, ao menos, oportunizadas.

É certo, ademais, que, por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é possível que a tutela final venha a ser questionada por meio de recursos interpostos pela parte derrotada, o que implica dizer que mesmo a tutela final não se torna imediatamente definitiva.

De todo modo, quer porque não interpostos todos os recursos cabíveis, quer porque todos estes foram manejados e esgotados, em algum

momento a tutela jurisdicional tornar-se-á definitiva, permitindo o atingimento do escopo da jurisdição.

Assim, o momento processual em que a tutela jurisdicional torna-se definitiva pode variar a depender do comportamento das partes e da quantidade de recursos cabíveis e efetivamente interpostos, mas, de qualquer forma, é certo que, em algum momento, após esgotadas todas as oportunidades e atividade processual, a tutela jurisdicional será indiscutível e imutável⁷⁶.

Essas qualidades, conforme dito, decorrem do esaurimento de todas as etapas do processo, quer porque foram efetivamente praticados todos os atos processuais possíveis pelas partes e pelo juízo, quer porque foi dada a oportunidade de esses atos serem praticados e, no entanto, não o foram, por decisão ou omissão dos sujeitos da relação processual.

O esgotamento de toda essa atividade processual, como dito, obviamente, consome tempo, não apenas em razão da atividade, em si mesma considerada, mas também em função dos prazos estabelecidos na lei para que a prática dos atos seja requerida pelas partes, analisada pelo juiz, e efetivamente realizada.

Ocorre que, em determinadas situações, o tempo que naturalmente é necessário para que a tutela final e definitiva seja prestada é incompatível com a situação jurídica e litigiosa carecedora de tutela jurisdicional.

Em outras palavras, muitas vezes, a situação posta em juízo não pode aguardar a prática de todos os atos inerentes à tutela definitiva, devendo ser tutelada de maneira célere, ainda que provisoriamente.

Por essa razão, ao lado da denominada tutela definitiva, o sistema processual admite a prestação da tutela jurisdicional provisória.

A tutela jurisdicional provisória se caracteriza por ser prestada antes do esgotamento da atividade processual e, por esse motivo, fica sujeita a uma confirmação, modificação ou revogação posterior sempre que o decidido,

provisoriamente, pelo juiz se mostrar, com o desenvolvimento do processo, correto ou equivocado.

Tutela provisória, portanto, são “tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em uma cognição sumária, isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capazes de levar um juízo de probabilidade e não de certeza”⁷⁷. Essa menor profundidade característica da cognição sumária e o juízo de mera probabilidade (e não de certeza) decorem diretamente da incompleta atividade processual que precede a tutela provisória.

Nesse contexto, é preciso ter em mente que a tutela provisória é excepcional, dado que prestada em detrimento do contraditório e ampla defesa, que são sacrificados, pelo menos em um primeiro momento, uma vez que conforme ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini ⁷⁸, “a concessão de uma providência antes do momento em que o julgador estaria propriamente em condições de definitivamente decidir sobre ela implica restrição aos direitos do contraditório e ampla defesa da parte que sofrerá a medida”.

Portanto, apenas em situações excepcionais admite-se a prestação de uma tutela jurisdicional antes do esgotamento de todas as oportunidades processuais conferidas às partes, sendo a regra o prévio esgotamento da atividade processual e prestação de tutela definitiva.

Duas são as situações excepcionais em que se admite a prestação da tutela jurisdicional provisória: a) as situações de urgência; e b) as situações em que for altíssima a probabilidade de o autor sair vitorioso ao final do processo, denominadas tutelas de evidência.

Em termos quantitativos, a prática forense revela que a concessão de tutela provisória é muito mais comum em razão da urgência, se comparada à concessão de tutela provisória de evidência.

Por situação de urgência deve ser entendida toda situação que não pode aguardar a demora natural do processo, sob pena de ineficácia ou

inutilidade da medida.

A razão de ser da tutela provisória de urgência reside no risco ou, até mesmo, na certeza, de ineficácia do provimento final e definitivo caso seja necessário aguardar o esgotamento de todas as etapas do processo.

Nesses casos, o Poder Judiciário se vê diante da necessidade de tutelar célere e provisoriamente a situação, sob pena de não oferecer a proteção ao direito levado a juízo, ou seja, não prestar a tutela jurisdicional constitucionalmente garantida.

Portanto, sempre que a situação jurídica litigiosa exigir uma providência jurisdicional imediata, abre-se espaço para a concessão de uma tutela jurisdicional provisória.

Inúmeros são os exemplos de situações de urgência que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, como na hipótese do portador de uma doença grave que demanda o fornecimento de medicamentos ou uma intervenção cirúrgica, situação que, por óbvio, não pode aguardar a prestação jurisdicional final e definitiva, em razão do tempo necessário à prática de todos os atos processuais.

O mesmo problema se coloca nos casos em que uma revista ou publicação baseada em informações falsas ou obtidas ilicitamente esteja em vias de ser publicada, caso em que a proibição da publicização do material tem de ser feita de maneira célere, ainda que em caráter provisório, sob pena de, uma vez tornada pública a informação, absolutamente inútil seria a tutela final que reconhece sua ilicitude.

Nesses casos, sem adentrar no mérito das questões que venham a surgir do embate entre a liberdade de expressão e as garantias igualmente constitucionais relativas a honra, imagem, intimidade e privacidade (que seria, neste exemplo, o mérito do processo), fato é que, se demonstrada, ainda que aparentemente, a existência do direito a não circulação do material, a tutela jurisdicional precisa ser prestada imediatamente, pois só

o tempo necessário para o oferecimento da resposta já seria suficiente para a divulgação da notícia, o que tornaria absolutamente inútil a prestação jurisdicional final que reconhecesse o direito de proteção à intimidade, à honra e à imagem e, conseqüentemente, a ilicitude da publicação.

Portanto, para situações como estas, o juiz, ainda que baseado em um juízo de probabilidade, e não de certeza, poderá antecipar a concessão da tutela jurisdicional de maneira célere e, por isso, provisória.

Outra situação admitida pelo ordenamento jurídico como autorizadora de tutela jurisdicional provisória, prestada antes do esgotamento de todas as etapas procedimentais e, por este motivo, ainda sujeita a revogação, modificação ou confirmação, ao final do processo, ocorre quando caracterizada a grande probabilidade de o autor sair vitorioso, considerando a situação posta e a defesa apresentada pelo réu.

Luiz Guilherme Marinoni⁷⁹ afirma que, nestas hipóteses, o tempo necessário ao esgotamento da atividade processual não deve ser suportado pelo autor que, a priori, claramente demonstra ter razão. Isso porque “o tempo do processo não pode prejudicar o autor e beneficiar o réu, já que o Estado, quando proibiu a justiça de mão própria, assumiu o compromisso de, além de tutelar de forma pronta e efetiva os direitos, tratar os litigantes de forma isonômica”⁸⁰.

Para o referido processualista, “a preocupação exagerada com o direito de defesa, fruto de uma visão excessivamente comprometida com o liberalismo, não permitiu, por muito tempo, a percepção de que o tempo não pode ser um ônus somente do autor”, e, com apoio em Edoardo Ricci, conclui que “as resistências dilatórias são tanto mais encorajantes quanto mais o processo – graças a sua duração – se presta a premiar a resistência como fonte de vantagens econômicas, fazendo mais conveniente esperar a decisão desfavorável do que adimplir com pontualidade”⁸¹.

A tutela provisória, contudo, é excepcional e só pode ser concedida quando configuradas as situações previstas em lei, notadamente, as

situações de urgência ou de evidência.

A regra geral é o prévio esgotamento de todas as etapas processuais para que, só então, ao final do processo seja prestada a tutela jurisdicional baseada em um juízo de certeza e, por isso, definitiva.

Os subitens a seguir se ocuparão, ainda que brevemente, das diversas hipóteses de concessão de tutela provisória (de urgência e de evidência) e dos mecanismos processuais diretamente relacionados a essa modalidade de tutela jurisdicional.

O item a seguir, “a”, será dedicado à tutela provisória de urgência que, por sua vez, se subdivide em a.1), tutela cautelar; e a.2) tutela antecipada; ao passo que o item “b” será dedicado aos principais aspectos da tutela de evidência.

a) Tutela provisória de urgência: tutela cautelar e tutela antecipada

Conforme já asseverado, a urgência, apesar de não ser o único fundamento para a concessão da tutela provisória, constitui a principal causa de pedidos desta forma excepcional de prestação de tutela jurisdicional no dia a dia forense.

Tradicionalmente, o nosso direito processual previa a possibilidade de concessão da tutela provisória, em razões de urgência, por meio de um processo autônomo denominado processo cautelar.

Assim, a redação originária do Código de Processo Civil de 1973 estabelecia a possibilidade de, em situações de urgência, o titular do direito lesado ou ameaçado buscar proteção provisória por meio de medida cautelar, a ser analisada e, eventualmente, concedida, em um processo autônomo voltado exclusivamente para esse fim.

Parte da doutrina, à época, fazia duras críticas à necessidade de um processo autônomo e exclusivamente voltado à análise da situação de

urgência, que, por ser apto apenas a conceder uma tutela provisória, tornava necessária a instauração de outro processo, o principal, este, sim, voltado à prestação da tutela jurisdicional definitiva.

A par disso, autorizadas vozes da doutrina viam na tutela cautelar a possibilidade de concessão, apenas e tão somente, de uma medida de apoio voltada à preservação do direito lesado ou ameaçado cujo reconhecimento se daria, em definitivo, no processo principal. Para esta corrente doutrinária, destarte, a medida pleiteada a título cautelar não poderia se confundir com o bem jurídico realmente pretendido pelo autor.

Exemplo típico de medida cautelar, nesse sentido, seria o arresto (ou bloqueio de bens) do sujeito apontado pelo autor como devedor, que, com suas atitudes, demonstrasse a intenção de se desfazer rapidamente de seu patrimônio, com um claro intuito de inviabilizar a cobrança e a execução da dívida. Nestas hipóteses, a medida de bloqueio caracteriza-se como tipicamente cautelar por não se confundir com a pretensão final do autor, que é o recebimento do dinheiro.

Tal medida cautelar claramente possuía, ademais, natureza provisória, uma vez que não vocacionada a perdurar em definitivo, mas, apenas, vigorar até que a dívida fosse suficientemente provada, momento em que o bloqueio cautelar se converteria na entrega do valor bloqueado ao credor. Por outro lado, caso a atividade processual voltada à cognição exauriente demonstrasse a inexistência da dívida, o arresto deveria ser revogado e os bens bloqueados, liberados.

De toda forma, em ambos os casos, a medida cautelar (bloqueio de bens) sempre seria provisória e, portanto, tendente a deixar de vigorar.

Entretanto, ainda segundo a interpretação clássica, a concessão célere e provisória do próprio direito pretendido pelo autor escaparia aos limites da tutela cautelar, haja vista que esta parte da doutrina sempre entendeu ser inadmissível a possibilidade de concessão de uma cautelar satisfativa.

Contudo, em diversas situações de urgência, o combate à ineficácia ou à inutilidade de uma medida jurisdicional tardia só poderá ser feito pela concessão do próprio direito pleiteado pelo autor a título de tutela final, ou seja, pela concessão de uma medida de urgência satisfativa.

É o típico caso, já referido a título de exemplo, em que sujeito titular do direito à tutela jurisdicional de sua vida e/ou de saúde precisa, de maneira urgente, utilizar determinado medicamento ou passar por um procedimento cirúrgico.

Nessas hipóteses, a única forma de prevenir a ineficácia de uma futura medida jurisdicional que reconheça definitivamente seu direito ao tratamento médico é antecipando o próprio pedido de tutela final.

Essa possibilidade de antecipação de tutela satisfativa em casos de urgência, apesar de não prevista originalmente no Código de Processo Civil de 1973, passou a ser amplamente admitida no sistema processual brasileiro, a partir de 1994, com a nova redação, dada pela Lei n. 8.952, de 13 de dezembro de 1994, ao art. 273 do Código de Processo Civil, que passou a dispor que “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Assim, a partir de 1994, o sistema processual civil brasileiro passou a contar com dois sistemas de concessão de tutela provisória baseada na urgência, a tutela antecipada, de cunho satisfativo, prevista na nova redação do art. 273 do CPC, e a tutela cautelar, prevista nos arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 desde sua redação originária.

Entretanto, ao contrário do processo cautelar, o pedido, a análise e a concessão da tutela antecipada satisfativa poderiam se dar no curso do próprio processo em que se discute a tutela final, ao passo que a medida

cautelar exigia, neste sistema, um processo autônomo dedicado exclusivamente a este fim.

A par da diferença formal e procedimental existente no regime revogado do CPC/1973, a melhor doutrina distinguia a tutela cautelar da tutela antecipada em função de seu conteúdo, ou seja, enquanto a tutela cautelar pode apenas conceder uma medida de apoio, que nunca se confunde com o direito pleiteado (como o aludido bloqueio de bens para uma futura entrega do próprio bem ou de seu produto voltada à satisfação do credor), a antecipação de tutela satisfativa é exatamente aquilo que o autor da ação receberia definitivamente quando da prestação da tutela final (a realização da própria cirurgia pretendida a título de tutela final).

Apesar de ser possível a realização destas distinções, certo é que a tutela antecipada satisfativa e a tutela cautelar possuem muito mais pontos em comum do que pontos divergentes, como os fatos de: a) ambas se caracterizarem por serem concedidas antes do momento adequado à prestação da tutela final (definitiva); b) ambas serem provimentos céleres com base em um juízo de probabilidade; c) ambas serem provimentos jurisdicionais provisórios, assim entendidos sujeitos a confirmação; d) ambas serem provimentos modificáveis, ou seja, passíveis de alteração ou revogação caso verificada a inadequação da medida provisoriamente procedida.

Exatamente por estes pontos em comum, o Código de Processo Civil de 2015 unificou os provimentos jurisdicionais provisórios de urgência, tanto cautelares como antecipatórios/satisfativos, sob a égide do regime da “tutela provisória de urgência”, extinguindo o processo cautelar autônomo tal como previsto no CPC de 1973.

Assim, no atual sistema codificado, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada/satisfativa podem ser requeridas, incidentalmente, no curso do mesmo processo em que se pleiteia a tutela definitiva.

Entretanto, apesar da aproximação formal do procedimento de pedido,

análise e concessão das tutelas cautelar e antecipada, ainda subsiste, como não poderia deixar de ser, uma diferença substancial entre as duas espécies de medidas de urgência, qual seja: enquanto a tutela antecipada concede, célere e provisoriamente, o mesmo provimento que seria naturalmente entregue quando da tutela final, a tutela cautelar concede, célere e provisoriamente, uma medida de apoio voltada à preservação da tutela final, mas que com esta não se confunde.

Portanto, não obstante a aproximação do tratamento procedimental dado às tutelas antecipada e cautelar, entre elas ainda existe uma distinção substancial, pois, enquanto a tutela antecipada possui um caráter satisfativo no sentido de entregar exatamente o bem jurídico pleiteado a título de tutela definitiva, a tutela cautelar constitui uma medida conservativa, de preservação do bem jurídico pleiteado, que poderá vir a ser possivelmente concedido no futuro quando da prestação da tutela definitiva.

Nesse sentido, João Batista Lopes, após afirmar que a tutela antecipada se caracteriza fundamentalmente pela satisfatividade, aduz que “a tutela antecipada tem em comum com a tutela cautelar a revogabilidade e a sumariedade mas dela se estrema por não ter caráter de mera garantia ou simplesmente instrumental, mas sim satisfativa”⁸², e conclui: “a tutela antecipada implica em adiantamento de efeitos da sentença de mérito, enquanto a tutela cautelar se limita a garantir a utilidade da decisão final de mérito”⁸³.

Esta distinção substancial entre as tutelas antecipada e cautelar acaba por gerar alguns desdobramentos procedimentais diferentes de acordo com a natureza da medida pleiteada, tema, entretanto, que escapa ao objeto desta Introdução.

Outro ponto importante ligado à temática dos provimentos jurisdicionais provisórios de urgência diz respeito às liminares, medidas judiciais comumente utilizadas na prática forense.

O primeiro ponto que merece registro é o fato de que as liminares não são um terceiro gênero de provimento de urgência, ao lado das cautelares e das medidas antecipatórias de tutela satisfativas.

Na verdade, as denominadas liminares são uma forma de concessão destes dois tipos de provimentos de urgência.

A origem da palavra liminar vem da expressão latina *in limine litis*, que, em uma tradução livre, significa “no início do litígio”.

Assim, o que caracteriza uma medida liminar é o fato de ser um provimento jurisdicional concedido no início do processo, via de regra, em razão da urgência que impõe a necessidade de o juiz, logo no início do litígio, de maneira célere, ainda que provisória, conceder a medida pleiteada sob pena de inutilidade ou inefetividade do provimento final.

Portanto, o que caracteriza uma medida liminar é o fato de ser proferida no início do litígio, baseada em um juízo de probabilidade e, até mesmo por isso, ser provisória, podendo o conteúdo da medida liminar ser tanto de natureza antecipatória/satisfativa quanto cautelar.

Assim, se a medida liminar autorizasse, *in limine litis*, a fruição, em caráter provisório, exatamente do bem jurídico pretendido pela parte a título de tutela final, estar-se-ia diante de uma medida liminar antecipatória/satisfativa.

Contudo, caso a medida liminar não coincida com o provimento final pleiteado, sendo apenas um provimento protetivo voltado à preservação de um provimento final, estar-se-á diante de uma medida liminar cautelar.

a.1) Especialmente sobre os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência

Conforme já asseverado, a tutela provisória é excepcional, uma vez que a regra é que a tutela seja definitiva.

Por esse motivo, dois requisitos devem sempre estar presentes para a

concessão da tutela provisória de urgência, antecipada/satisfativa ou cautelar: a) probabilidade do direito pleiteado; b) o risco de dano em caso de não concessão do provimento provisório.

A probabilidade do direito, tradicionalmente relacionada à expressão latina *fumus boni juris*, ou fumaça do bom direito, se traduz na necessidade de demonstração, ainda que incompleta, da pertinência da alegação e da ocorrência dos fatos narrados pelo autor, obviamente baseada em uma cognição sumária.

Esta probabilidade do direito é expressamente exigida como o primeiro e indispensável requisito para a concessão da medida de urgência no art. 300 do Código de Processo Civil.

A par disso, o requerente da medida de urgência deverá demonstrar a excepcionalidade de sua situação, que não pode aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final, sendo este o sentido da exigência de demonstração de “perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”, também constante do art. 300 do CPC.

A demonstração destes dois fatores concomitantemente autoriza a concessão de um provimento jurisdicional de urgência, cautelar ou satisfativo, que valerá até sua confirmação ou possível revogação, quando da prestação da tutela definitiva, ao final do processo.

Entretanto, para a concessão da tutela de urgência antecipada/satisfativa o art. 300, § 3º, do Código exige que os efeitos da decisão sejam reversíveis, sendo vedada, pelo menos a priori, a concessão de uma tutela antecipada irreversível.

A exigência se justifica exatamente pelo fato de ser a tutela antecipada provisória passível de posterior modificação ou alteração.

Assim, por exemplo, não é possível a concessão, a título de tutela provisória, de uma autorização judicial para que se proceda o corte de

árvores de determinada área em um processo que discuta a legalidade deste desmatamento, ou a publicação de uma obra em um processo que discuta eventual ofensa à honra, à imagem ou à privacidade das pessoas retratadas na obra questionada, pelo simples fato de que, uma vez publicada a obra ou realizado o corte de árvores com base em uma decisão judicial provisória, o eventual reconhecimento de sua incorreção não surtiria efeitos práticos.

Por essa razão, as medidas e providências irreversíveis têm de ser efetivadas com apoio em pronunciamentos judiciais definitivos.

Ademais, também em razão da possibilidade de modificação ou revogação, típica dos provimentos de urgência, o juiz pode exigir que o beneficiário da medida preste, por meio de caução, uma garantia de que reparará os danos que a outra parte possa vir a sofrer caso demonstre, ao final, ter razão.

b) A tutela de evidência

Conforme já asseverado, não apenas em situações de urgência a tutela pode ser antecipada, isto é, provisoriamente concedida antes do momento adequado para a concessão do provimento final após esgotadas todas as etapas processuais.

Isso porque o Código de Processo Civil também autoriza a concessão de tutela provisória antes do esgotamento do procedimento, sempre que presente grande probabilidade de vitória do autor.

Tais situações são denominadas tutela de evidência e se justificam nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil quando, independentemente da caracterização da situação de urgência: "I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

Conforme se pode inferir das situações descritas no art. 311, as hipóteses de autorização da concessão da tutela provisória de evidência estão relacionadas a uma grande probabilidade de vitória do autor demonstrada de plano.

Luiz Guilherme Marinoni⁸⁴ identifica a tutela de evidência como uma “técnica de distribuição do ônus do tempo do processo” que possibilita, sem que se sacrifique o direito de defesa em sua totalidade, que ao autor seja entregue a tutela jurisdicional pleiteada, ainda que provisoriamente, quando demonstradas a evidência do direito e a fragilidade da defesa.

A denominada “evidência”, neste contexto, se revela pela robustez da prova documental assim como das alegações de direito do autor, contrapostas pela fragilidade das provas e argumentos aduzidos pelo réu.

A robustez da prova produzida pelo autor é fator determinante, por exemplo, para a concessão da tutela de evidência fulcrada nos incisos III e IV do art. 311, que se referem à “prova documental adequada do contrato de depósito” e à “prova documental suficiente dos fatos constitutivos”.

Vale registrar que, na segunda hipótese, faz-se necessária a conjugação da prova suficiente com a fragilidade da defesa do réu que venha a ser tida por incapaz de “gerar dúvida razoável”.

Por outro lado, a defesa abusiva ou manifestamente protelatória do réu pode vir a ser, por si só, autorizadora da concessão da tutela provisória de evidência, conforme previsto no art. 311, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a solidez dos fundamentos jurídicos do autor pode funcionar como um fator legitimador da concessão da tutela provisória de evidência,

em especial quando fulcrados em súmulas e precedentes qualificados, que, no sistema do Código, possuem eficácia vinculante⁸⁵.

Em suma, em todas essas situações o sistema processual entende existir uma altíssima probabilidade de vitória do autor, o que autoriza a concessão da tutela provisória com base em evidência, ainda que isso não implique o encerramento do processo, mas apenas a transferência para o réu, que, provisoriamente, já passa a sofrer consequências negativas, o ônus do processamento de sua defesa, tida, pelo menos a priori, como manifestamente infundada, abusiva, protelatória e, portanto, com uma alta tendência de vir a ser malsucedida.

Apesar de ser concedida com base nessa grande probabilidade, a tutela de evidência possui as características de toda tutela provisória, notadamente a modificabilidade e a sujeição à confirmação ao final do processo, podendo, inclusive, ser revogada caso a defesa, a priori vista como abusiva e protelatória, ao final se mostre correta e possuidora de fundamento.

4.2.3 Tutela jurisdicional individual e coletiva

O Código de Processo Civil, de maneira geral, pode ser entendido como um diploma destinado à resolução de litígios individuais, assim entendidos os conflitos que envolvem duas ou mais pessoas, plenamente identificadas, e que, em nome próprio, defendem o que entendem ser seu direito.

Em outras palavras, a estrutura do processo e do procedimento do CPC pressupõe a pretensão exercida por um ou mais sujeitos contra outro sujeito de direito plenamente identificado e presente na relação processual. Maior prova disso é o disposto no art. 18 do CPC, que estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, tema que será objeto do item 8.4, “a”, infra.

Ocorre que determinadas situações litigiosas, quando instaladas,

repercutem na esfera de inúmeras pessoas, quando não de toda a sociedade.

É o caso, por exemplo, de transgressões a normas estabelecidas pelo Direito Ambiental que causam uma lesão ao ecossistema, como a poluição de um rio ou do ar, lesão esta sofrida por um grupo de pessoas impossíveis de serem individualmente identificadas.

Da mesma forma, o desrespeito ao Direito do Consumidor, como o oferecimento de um produto defeituoso ou a veiculação de uma propaganda enganosa na mídia, atinge ilicitamente a esfera jurídica de um grupo indeterminável de pessoas.

Nesse contexto, é correto afirmar que, na verdade, não são apenas dois os sujeitos envolvidos na situação litigiosa e interessados em uma solução, mas sim um grupo, classe ou categoria de pessoas.

Como exemplos de grupo, classe ou categoria de pessoas, podem ser vistos toda uma população ribeirinha e qualquer um que tenha contato com um manancial ilicitamente poluído, e os consumidores de determinado serviço ou produto ofertado sem a qualidade mínima esperada e em desrespeito ao Direito do Consumidor, entre inúmeros outros grupos, como os usuários de determinado plano de saúde, os servidores públicos ou os trabalhadores de um mesmo setor ou de uma mesma categoria.

Estas situações, portanto, demandam outra forma processual de solução de litígios, distinta da jurisdição individual prestada no processo iniciado pelo titular do direito contra aquele a quem a pretensão é exercida.

Para a resolução de situações em que a relação jurídica litigiosa envolve um grupo, classe ou categoria de pessoas ou mesmo toda a sociedade, o processo e a jurisdição nele prestada é, por esta razão, coletiva.

A jurisdição coletiva, portanto, pode ser definida como um método de prestação jurisdicional que, em apertada síntese, caracteriza-se por se voltar a tutelar direitos metaindividuais, por meio da autorização para agir

em juízo concedida a órgãos e entidades tidos pela lei como representativos de grupos sociais ou de toda a sociedade, aliada à atribuição de eficácia erga omnes ou ultra partes às decisões proferidas naquela sede.

Assim, tem lugar a jurisdição coletiva sempre que verificada a lesão ou a ameaça a um direito classificado como difuso, coletivo ou individual homogêneo.

Portanto, são situações que demandam o exercício da jurisdição coletiva aquelas em que se faz necessária a resolução de um litígio que envolva: a) direitos difusos; b) direitos coletivos; ou c) direitos individuais homogêneos.

Por direitos ou interesses difusos, devem ser entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, cujo exemplo clássico é o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Os direitos ou interesses coletivos, por sua vez, se caracterizam por serem transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas, entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base, como os usuários de um plano de saúde ou os estudantes de uma universidade.

Por fim, também tutelável pela via processo coletivo, são os direitos individuais homogêneos, que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, são aqueles decorrentes de origem comum, de natureza divisível e que abarcam um grupo de indivíduos, como as vítimas de um mesmo acidente de ônibus ou avião e os consumidores de determinado produto defeituoso.

A legitimação para agir na jurisdição coletiva, justamente por voltar-se à tutela de direitos e interesses metaindividuais, é desvinculada do clássico modelo de legitimidade atribuída ao titular do direito no plano do direito material⁸⁶.

Isso porque, exatamente em função da impossibilidade de identificar as

peessoas lesadas ou por este grupo ser bastante numeroso, ao invés de se atribuir a possibilidade de ir a juízo aos titulares do direito litigioso, admite-se a propositura da demanda por um ente representante do grupo, da classe ou da categoria.

O processo coletivo, portanto, elege representantes adequados, assim entendidos organismos, associações ou entidades de natureza pública ou privada, tidas pela lei como representantes suficientes do interesse da coletividade⁸⁷.

Neste ponto, a lei não optou por eleger um representante único, o que poderia implicar inclusive a limitação ao acesso à tutela coletiva, tendo preferido vários legitimados para propor as ações coletivas, até porque vários são os organismos aptos e capazes de serem tidos como representantes adequados.

Nesse contexto, são tidos como legitimados a propor uma ação coletiva o Ministério Público⁸⁸, a Defensoria Pública⁸⁹, o Poder Público, por meio da Advocacia Pública⁹⁰, e as associações civis, desde que constituídas a pelo menos um ano e que incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao direito objeto do processo coletivo.

Ademais, outra característica da jurisdição coletiva é a produção de efeitos erga omnes ou ultra partes, ou seja, a tendência de a decisão proferida nesta sede atingir não apenas as partes do processo, mas todos os integrantes do grupo, da classe ou da categoria de pessoas tidas pela decisão como lesadas.

Nesse sentido, uma única decisão proferida no processo coletivo é capaz de alcançar e tutelar todo o grupo de indivíduos, ainda que não identificáveis ou de difícil identificação, e até mesmo toda a sociedade, de maneira idêntica⁹¹.

Rodolfo de Camargo Mancuso destaca que, enquanto na jurisdição singular a lógica é que a eficácia da coisa julgada material não atinja os

terceiros que não participaram do processo, na jurisdição coletiva, a eficácia do julgado depende, por definição, de que os efeitos da decisão extrapolem a esfera das partes (autor e réu) do processo, ou seja, “que se projetem extra-autos (erga omnes, ou ao menos ultra partes), justamente por que nesse plano os interesses tuteláveis se estendem por faixas mais ou menos extensas, ao largo do universo coletivo”.

Dada essa característica, a jurisdição coletiva se apresenta como um instrumento muito mais racional, dos pontos de vista econômico e jurídico, para o trato dos conflitos de massa, nos quais o que se debate é uma única questão de direito relevante para um grande grupo que se encontra na mesma situação, como contribuintes, aposentados, consumidores de determinado serviço ou de determinado medicamento etc.

Do ponto de vista econômico, haja vista que um único processo coletivo substitui uma enorme gama de processos individuais voltados a discutir a mesma questão de direito. E, do ponto de vista jurídico, porque a decisão é, ou deve ser, única e com efeitos idênticos para todos os sujeitos que se encontrem na situação tutelada.

Mancuso destaca que “a jurisdição coletiva é a alternativa técnica que se oferece como um instrumento eficaz para a desejável uniformização da resposta judiciária nos chamados conflitos de massa, que até agora, com algumas exceções, vêm sendo judicializadas de maneira equivocada”, em especial, pela tolerância de concomitante tramitação de ações de natureza individual, ou mais de uma coletiva, sobre um mesmo tema⁹².

O CPC, contudo, ciente de que várias demandas individuais, no fundo, podem representar uma lide coletiva, estabelece a possibilidade de tratamento coletivizado de demandas individuais repetitivas.

Nesse contexto, admite-se a possibilidade de concentração da solução jurisdicional quando detectado um grande número de processos individuais envolvendo causas repetitivas, assim entendidos os que repetem situações pessoais idênticas, acarretando a tramitação paralela de significativo

número de ações coincidentes em seu objeto e na razão de seu ajuizamento.

São exemplos de demandas repetitivas, causas envolvendo a mesma tese jurídica, como aquelas de interesses de funcionários públicos e contribuintes ou interesses transindividuais de particular relevância ou de pertinência a grupos bastante numerosos que ajuizaram inúmeros processos individuais.

Estas situações podem e, do ponto de vista da eficiência, até mesmo deveriam ser tuteladas pela via do processo coletivo, mas a possibilidade desta via não exclui a possibilidade de ajuizamento de ações individuais pelos sujeitos integrantes do grupo, da categoria ou da classe de pessoas que se sintam lesados e que optem pelo processo individual.

Assim, ao lado da jurisdição individual e da jurisdição coletiva, o Código de Processo Civil promove uma espécie de tratamento coletivizado de demandas repetitivas que, em apertada síntese, se caracteriza por: a) concentração da solução da questão múltipla; b) sobrestamento de processos idênticos; c) aplicação acelerada do precedente consagrado nos demais processos que envolvam a mesma questão jurídica.

Os melhores exemplos de tratamento coletivizado de ações individuais repetitivas são o incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987 do CPC) e o julgamento de recursos excepcionais repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 do Código), cujos contornos escapam ao objeto desta Introdução⁹³.

De toda sorte, a depender da natureza da jurisdição exercida, seu produto, isto é, a tutela jurisdicional, pode ser classificada como individual ou coletiva.

Na primeira, orientada pela regra da legitimidade ordinária e coisa julgada intra partes, o resultado do processo volta-se a tutelar a situação conflituosa que envolve os sujeitos integrantes da relação processual,

dizendo respeito apenas a eles. Por ser a proteção jurisdicional concedida através do processo nesses casos passível de individualização, dá-se a esta espécie a classificação de tutela jurisdicional individual.

Já a tutela jurisdicional coletiva, promovida por entes com legitimação extraordinária e com a capacidade de produzir coisa julgada erga omnes ou ultra partes, possui a capacidade de proteger uma gama muito maior de sujeitos, não integrantes da relação processual, mas pertencentes ao grupo, classe ou categoria de pessoas representadas pela parte da ação coletiva.

4.2.4 Tutela jurisdicional contenciosa e voluntária

De tudo o que se expôs até o momento, resta claro que o processo civil se volta precipuamente à resolução de situações litigiosas.

Nesse sentido, a atuação da jurisdição é, como regra geral, necessária quando verificado um litígio, isto é uma contenda.

Em outras palavras, o Estado-juiz atua, exercendo jurisdição, declarando a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, constituindo ou desconstituindo uma situação jurídica até então inexistente, condenando alguém a fazer ou a deixar de fazer algo, ou praticando atos materiais voltados à realização do direito quando verificada uma pretensão exercida por um sujeito e uma resistência oposta por outro.

Ocorre que, excepcionalmente, em determinadas situações expressamente estabelecidas em lei, o Direito exige a atuação do Estado-juiz mesmo sem a caracterização de um litígio.

Em outras palavras, ainda que por exceção, a jurisdição pode vir a ser necessária independentemente da configuração de uma situação contenciosa, caracterizada pela pretensão resistida.

À jurisdição exercida comumente, que se faz necessária apenas quando as partes estão em situação de litígio, dá-se o nome de jurisdição contenciosa, ao passo que a jurisdição prestada não porque resta caracterizada uma "contenda", mas sim por força de uma exigência legal de

atuação do Estado-juiz, denomina-se jurisdição voluntária.

Nesse contexto, a jurisdição voluntária pode ser definida como a atividade jurisdicional voltada à constituição de uma situação jurídica nova em que a vontade dos sujeitos interessadas não é suficiente para tal constituição, fazendo-se necessária a atuação do Estado-juiz.

Assim, como regra geral para a constituição e a desconstituição de relação jurídicas, a vontade das partes, por si só, é suficiente, sendo absolutamente desnecessária a atuação jurisdicional.

Nesse sentido, duas pessoas, para realizarem um contrato de compra e venda ou de empréstimo, e se colocarem na situação de comprador-vendedor ou de credor-devedor, apenas precisam, entre si, celebrar um negócio. A discussão judicial acerca de um contrato, sua validade e necessidade de constituição ou desconstituição só tem lugar quando as partes contratantes entrarem em conflito, ou seja, quando caracterizada a lide.

Por outro lado, em determinados casos, a lei expressamente impede a constituição da situação jurídica apenas pela vontade dos sujeitos interessados, e exige a necessidade de atuação do Estado-Juiz que, na inexistência de litígio, exerce a denominada jurisdição voluntária.

São situações que precisam da atuação jurisdicional independentemente de litígio – jurisdição voluntária, portanto –, a constituição de um tutor para os menores na falta de seus pais, ou de um curador para os demais incapazes, assim como a atuação do juiz nos processos de adoção e emancipação de menores.

Nessas situações, por expressa previsão legal, o Poder Judiciário deve atuar, sendo o exercício da jurisdição voluntária indispensável para a constituição ou a desconstituição da tutela ou curatela.

A ausência do litígio a ser solucionado como meta a ser alcançada ao final do processo caracteriza o exercício dessa jurisdição como voluntária.

O resultado produzido pelos procedimentos de jurisdição voluntária, assim entendida a constituição da nova situação jurídica pelo Poder Judiciário por meio do exercício da jurisdição em um contexto de ausência de conflito a ser solucionado, pode ser categorizado como tutela jurisdicional voluntária.

Escapam ao objeto desta Introdução o estudo de cada uma das situações em que a jurisdição voluntária é exigida pelo Direito, restando suficiente, nesta sede, a referência a sua existência e a distinção, quando comparada à jurisdição contenciosa.

A disciplina do exercício da jurisdição voluntária encontra-se entre os arts. 719 a 770 do Código de Processo Civil sem prejuízo à possibilidade de a legislação extravagante dispor sobre a necessidade e o procedimento de atuação do Estado-juiz em outras situações não litigiosas.

Capítulo 5 Jurisdição e Poder Judiciário

5.1 Classificação da jurisdição e organização do Poder Judiciário

Como “Poder do Estado” incumbido de solucionar, de maneira imperativa e definitiva, todos os conflitos de interesse por meio do processo e, dessa maneira, fazer observar o disposto no direito material, o Poder Judiciário se ocupa da interpretação e da aplicação dos mais diversos ramos do Direito.

Devido a este vasto espectro de atuação, o Poder Judiciário se divide em órgãos, estruturados em várias “Justiças”, algumas especializadas e com competência para determinadas matérias e outras com competência residual.

São justiças especializadas com competência para processar e julgar causas que envolvam determinados litígios oriundos de específicos ramos do direito material, as justiças do trabalho, eleitoral e militar.

A existência destas “justiças especializadas” leva à possibilidade de classificação da própria jurisdição que, não obstante ser uma expressão do poder soberano do Estado, admite uma categorização, de acordo com a natureza do litígio e, conseqüentemente da “Justiça” que irá processar e julgar a causa.

Ademais, ao lado das denominadas Justiças especializadas, há a Justiça comum, com competência para processar e julgar todas as causas que não estejam submetidas a uma das três Justiças especializadas.

Portanto, caso o litígio não verse sobre matéria trabalhista, eleitoral ou militar a ação será processada e julgada por um dos órgãos da Justiça comum.

Dentro deste amplo espectro de competência residual abrangida pela Justiça comum, ainda é possível classificar a jurisdição por ela exercida em dois grandes grupos: jurisdição civil e jurisdição penal.

A jurisdição penal é voltada à aplicação do direito penal material e, portanto, voltada basicamente à verificação da ocorrência de crimes, sua autoria e a medida da punição ao criminoso, ao passo que a jurisdição civil pode ser categorizada por exclusão, pois são submetidas à jurisdição civil todas as matérias não penais e não submetidas às Justiças especializadas.

Portanto, o mesmo corpo de juízes exerce a jurisdição penal e a jurisdição civil, não havendo uma Justiça especializada nesta ou naquela matéria.

O que há, no máximo, é a repartição de competências internas entre os órgãos da Justiça comum, sendo possível, entretanto, sobretudo em localidades de pequeno porte, que um mesmo juiz acumule a competência e o exercício jurisdicional civil e penal.

Nada impede, sendo inclusive recomendável, dadas às grandes distinções, tanto do ponto de vista do direito material quanto do ponto de vista do direito processual, que, na medida do possível, o Judiciário se organize internamente com o intuito de repartir o exercício da jurisdição civil e da jurisdição penal.

De toda forma, os magistrados estaduais e federais aplicarão diplomas processuais diferentes caso exerçam a jurisdição penal ou a jurisdição civil, uma vez que a espécie de direito processual, isto é, o complexo de normas jurídicas que norteará a atividade processual das partes, do juiz e de seus auxiliares, é disciplinada por dois sistemas codificados e autônomos para o exercício de cada uma das jurisdições (ou prestação de tutela jurisdicional): o Direito Processual Penal e o Direito Processual Civil.

Ademais, cabe ressaltar que o exercício da jurisdição civil e da jurisdição penal é repartido entre duas "Justiças", ou seja, dois "braços" do Poder Judiciário: a Justiça (comum) federal e a Justiça (comum) estadual. Ambas atuam exercendo tanto jurisdição civil quanto jurisdição penal.

A jurisdição comum federal é exercida pelos órgãos da Justiça federal,

notadamente pelos juízes federais e pelos tribunais regionais federais, e possui sua competência estabelecida pelos arts. 108 e 109 da Constituição Federal.

Não pertence a este item a análise pormenorizada da competência da Justiça federal, restando suficiente, neste passo, registrar que, caso o processo envolva uma das hipóteses arroladas pelos arts. 108 e 109 da Constituição Federal, faz-se necessária a atuação da Justiça federal, único braço do Judiciário competente para processar e julgar tais causas assim identificadas pela Constituição.

Excluídas as hipóteses de competência da Justiça federal, além de, obviamente, das Justiças especializadas, a competência para processar e julgar a lide é da Justiça estadual, que possui, desta feita, a denominada competência residual, devendo lidar, literalmente, com todas as demais causas e litígios oriundos de qualquer ramo do direito material.

A justiça comum estadual, portanto, se ocupa de uma enorme variedade de litígios, desde situações relacionadas a direito de família, passando por todos os demais ramos do direito civil, do direito tributário, do direito agrário, do direito ambiental, do direito do consumidor, do direito empresarial, do direito administrativo e qualquer outro, salvo, repita-se, se sujeito à competência da Justiça federal ou das Justiças especializadas.

Conforme esclarecido no item 2.2, “f”, independentemente do ramo do direito material aplicável ao litígio, o juiz estadual, no exercício da jurisdição comum, sempre se valerá das normas integrantes do Direito Processual Civil, notadamente, pelo Código de Processo e pela legislação processual extravagante.

Aliás, é importante destacar que a dicotomia jurisdição federal/jurisdição estadual não redundará em uma dicotomia Direito Processual Civil federal/Direito Processual Civil estadual, dado que, independentemente da esfera de atuação do juiz, seu método de atuação no processo, seus poderes e deveres, bem como todo o procedimento, são ditados pelo

Código de Processo Civil, lei federal incidente sobre todos os processos que tramitem quer pela Justiça federal, quer pela Justiça estadual.

Ademais, é típico dos Estados de Direito contemporâneos, dentre os quais o brasileiro, a atribuição ao Poder Judiciário da competência para controlar os atos executivos e legislativos do próprio Estado, ou seja, para aferir a compatibilidade entre os atos estatais e a Constituição Federal.

A Constituição Federal brasileira de 1988 atribui esta tarefa ao órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que neste contexto exerce a denominada jurisdição constitucional.

A atuação do Supremo Tribunal Federal, neste contexto, volta-se à limitação e controle dos atos estatais, inclusive da própria lei e demais atos normativos que por se subordinarem ao texto constitucional se sujeitam ao controle de constitucionalidade. Ao exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário dá-se o nome de jurisdição constitucional.

Nesse sentido, é possível classificar a jurisdição em: a) jurisdição constitucional; b) jurisdição trabalhista; c) jurisdição eleitoral; d) jurisdição penal (militar “d.1” e comum “d.2”); e e) jurisdição civil; esta última, a residual no sentido de ser aquela voltada à resolução de todos os litígios não sujeitos às demais espécies de jurisdição.

Tal classificação revela-se importantíssima, não apenas por definir a Justiça competente para processar e julgar a causa, mas também para definir o complexo de normas materiais e processuais incidentes na hipótese que definirão o método de atuação destes órgãos.

Isso porque, conforme demonstrado no item 2.2, a Justiça do Trabalho atua nos termos ditados pelo Direito Processual do Trabalho, a Justiça Eleitoral segue as regras do Direito Processual Eleitoral e a Justiça Militar, por possuir competência exclusivamente penal, pauta-se pelo Direito Processual Penal Militar.

O Direito Processual Civil, portanto, possui incidência plena nos processos em curso perante a denominada Justiça comum (federal e estadual), sem prejuízo da sua aplicação subsidiária nas Justiças do Trabalho e Eleitoral⁹⁴.

Além disso a classificação suprarreferida possui relação direta com a forma de organização do Poder Judiciário que será tratada no item subsequente, pois em síntese temos que a jurisdição constitucional ("a") é exercida pelo Supremo Tribunal Federal; a jurisdição trabalhista ("b") é exercida pelos órgãos da Justiça do Trabalho; c) a jurisdição eleitoral ("c") é exercida pelos órgãos da Justiça eleitoral; a jurisdição penal militar ("d.1") pela Justiça Militar, ao passo que a jurisdição penal comum ("d.2") e a jurisdição civil ("e") são exercidas pelos órgãos integrantes da Justiça comum, federal e estadual.

Dada a importância desta classificação para o exercício da jurisdição e compreensão da organização do Poder Judiciário, o item 5.1.3 infra trará uma análise pormenorizada de cada uma das espécies de jurisdição e dos órgãos que precipuamente a exercem.

Antes disso, serão tecidas considerações sobre outra forma de se classificar a jurisdição, extremamente relevante para a organização do Poder Judiciário: a classificação em graus de jurisdição, outro tema, portanto, que será tratado antes do enfrentamento da questão da organização judiciária propriamente dita.

5.1.1 Classificação da jurisdição segundo o grau de jurisdição exercido

O caráter definitivo e imperativo da jurisdição não implica dizer que o primeiro pronunciamento de um órgão do Poder Judiciário já deva ser tomado como a única e imutável decisão sobre a questão posta em juízo.

Isso porque, a par da possibilidade de erro por parte do órgão julgador, é da natureza do ser humano o inconformismo com as decisões contrárias aos seus interesses.

Por estas razões, o sistema processual brasileiro consagra o denominado princípio do duplo grau de jurisdição⁹⁵ que, em apertada síntese, garante a todos aqueles que não se conformarem com uma decisão judicial, a possibilidade de interposição de recursos contra tal decisão.

Os recursos, portanto, são os instrumentos processuais que viabilizam a revisão e a eventual reforma ou a cassação de uma decisão judicial.

Para que seja possível este sistema de revisão, o Poder Judiciário se organiza em diversos graus de jurisdição, sendo o primeiro deles aquele em que o juiz tem o primeiro contato com a causa, com o pedido, com as provas e com a defesa, para, ao final, proferir a primeira decisão.

Esta atividade equivalente ao primeiro grau de jurisdição é exercida pelo juiz que, monocraticamente, conduz o processo e profere a decisão.

Diz-se monocrática tal atuação porque um único magistrado, sozinho, possui a incumbência de exercer a jurisdição, conduzindo o processo e, ao final, decidindo a causa.

Os órgãos jurisdicionais ocupados pelos juízes que exercem jurisdição de primeiro grau, são as varas, via de regra, sediadas no fórum, denominação dada aos prédios ocupados por estes órgãos de primeiro grau.

A depender do seu porte, determinada localidade (comarca ou seção judiciária) pode ter uma única vara ou dezenas de unidades destes órgãos de primeiro grau, hipótese em que as varas podem se tornar especializadas em determinado tipo de matéria ou de causas.

Os recursos, como dito, viabilizam a revisão da decisão de primeiro grau pelos órgãos jurisdicionais de segundo grau de jurisdição.

A jurisdição de segundo grau é exercida por outro corpo de magistrados, os denominados desembargadores, que exercem sua função nos tribunais.

Assim, caso a parte inconformada recorra da decisão de primeiro grau, o recurso interposto será processado e julgado por outro órgão, também integrante da estrutura do Poder Judiciário, e hierarquicamente superior aos

juízes de primeiro grau, denominado tribunal de segundo grau.

Nesse sentido, integram a estrutura do Poder Judiciário vários tribunais de segundo grau, com competência para rever, em sede recursal, as decisões proferidas pelos magistrados de primeiro grau a eles vinculados.

Tal vinculação se dá por critérios territoriais e em razão da matéria, havendo, portanto, em cada uma das “Justiças”, uma série de tribunais (regionais federais, regionais do trabalho, regionais eleitorais e tribunais de justiça estaduais) divididos por regiões ou por unidades da federação, com competência e hierarquia sobre os juízes de primeiro grau pertencentes àquele território.

Desta feita, conforme se verá adiante, existem 27 tribunais de segundo grau na Justiça Estadual, 27 tribunais regionais eleitorais, 24 tribunais regionais do trabalho e 5 tribunais regionais federais⁹⁶, possuindo estes órgãos jurisdicionais, em comum, a vocação e a competência primordial para o exercício da jurisdição de segundo grau.

Apenas excepcionalmente, em casos expressamente estabelecidos na lei ou na Constituição, os tribunais exercem jurisdição de primeiro grau, ou seja, ao invés de atuarem em grau de recurso, processam e julgam a causa pela primeira vez.

Tais situações, repita-se, são excepcionais, haja vista que, como regra, o processo tem início perante os juízes de primeiro grau⁹⁷.

O exercício da jurisdição pelos desembargadores integrantes dos tribunais de segundo grau é, via de regra, colegiado, ao contrário da regra geral da jurisdição de primeiro grau, exercida monocraticamente.

Em outras palavras, a tomada de decisão nos recursos é realizada por um grupo (turma, câmara etc.) de desembargadores que expressa sua decisão por meio de um voto, cujo resultado será no sentido da maioria dos magistrados.

Assim, via de regra, a revisão, em sede recursal, de uma decisão de

primeiro grau proferida por um juiz singular será realizada por um colegiado de desembargadores.

Apenas em situações excepcionais e expressamente autorizadas em lei, a exemplo do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, os desembargadores estão autorizados a atuarem monocraticamente no exercício da jurisdição de segundo grau.

Esta lógica do exercício da jurisdição de primeiro grau por juízes e a competência recursal pelos tribunais só não se aplica aos procedimentos sujeitos aos juizados especiais, unidades do Judiciário com competência para processar e julgar causas de menor complexidade, assim definidas em lei⁹⁸.

Isso porque, nestas hipóteses, a competência para processar e julgar os recursos contra as decisões dos juízes de primeiro grau dos juizados é da “turma recursal”, órgão jurisdicional composto por juízes que não integram a estrutura dos tribunais.

Também no sistema dos juizados especiais, a jurisdição de primeiro grau é exercida singularmente pelos juízes, ao passo que o julgamento, em sede recursal, pela turma, como regra, é colegiado.

5.1.2 Especialmente sobre a jurisdição de sobreposição e os tribunais superiores no ordenamento brasileiro

Pelo fato de haver inúmeros órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus é natural que ocorra, em maior ou menor medida, a denominada dispersão jurisprudencial, assim entendidas manifestações diferentes por parte dos tribunais a respeito da interpretação ou da aplicação de uma mesma norma jurídica, ou, mais amplamente, o proferimento de decisões dando soluções jurídicas distintas para situações idênticas.

Por mais que este fenômeno seja, em primeiro momento, previsível e até tido como aceitável pelo Direito, dadas as diferenças culturais, sociais, políticas e até mesmo ideológicas entre os membros do Poder Judiciário,

responsáveis por aplicar isonomicamente a norma ao caso concreto, fato é que este mesmo sistema deve estabelecer mecanismos, isto é, técnicas processuais e órgãos judiciais competentes para combater ou evitar esta indesejável, ainda que, a priori, aceitável e previsível dispersão.

Para fins de uniformização da interpretação e da aplicação das leis e da Constituição Federal, surge a necessidade de criação e estruturação de tribunais com jurisdição sobre todo o território nacional e competência para dar a última palavra acerca da interpretação e da aplicação da legislação federal.

Estes órgãos são os denominados tribunais superiores, que possuem sede em Brasília e jurisdição sobre todo território nacional, e, a esta espécie de jurisdição, voltada a uniformizar a interpretação e a aplicação do direito, dá-se o nome de jurisdição de sobreposição⁹⁹.

Cada uma das “Justiças”, comum e especializadas, possui um tribunal superior que exerce a jurisdição de sobreposição.

Na Justiça do Trabalho, a jurisdição de sobreposição é exercida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST; na Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE; e na Justiça comum, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Acima de todos os tribunais de sobreposição exclusivos de cada uma das “Justiças” está o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, com competência para decidir, em última instância, todas as causas julgadas por qualquer uma das “Justiças”, comum ou especializadas, sob a ótica da compatibilidade desta decisão com a Constituição Federal.

A par de exercer a competência recursal de última instância, via recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal também exerce seu papel de guardião da Constituição Federal por meio das denominadas ações de controle concentrado de constitucionalidade, procedimentos exclusivos do STF, pelos quais o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro exerce a

denominada “jurisdição constitucional”, tema a ser enfrentado no item 5.1.3, “a”, infra.

Em suma, cada uma das “Justiças” possui, no mínimo, duas instâncias de sobreposição, cabendo a estes órgãos de cúpula, no exercício deste mister, uniformizar a interpretação e a aplicação do Direito federal no plano nacional, no respectivo tribunal superior (STJ, TST, TSE,), com competência para dar a última palavra sobre a legislação infraconstitucional, e, acima destes, no Supremo Tribunal Federal, principal e definitivo intérprete da Constituição.

Para o Direito Processual Civil, os dois tribunais superiores mais relevantes são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, dada a riqueza de normas processuais inseridas na Constituição e considerando a competência do Supremo Tribunal Federal para interpretar, em última instância, as normas constitucionais, importantíssimas questões processuais são pacificadas pelo STF.

Já o STJ, por possuir competência para o exercício da jurisdição de sobreposição em matéria infraconstitucional, coloca-se como o derradeiro e definitivo intérprete de toda a legislação processual infraconstitucional, de todo o Código de Processo Civil e legislação processual extravagante, portanto.

5.1.3 Classificação da jurisdição segundo a espécie de direito processual e material aplicado

a) Jurisdição constitucional e Supremo Tribunal Federal

É típica das cartas constitucionais consagradoras de um Estado Democrático de Direito a atribuição de competência ao Poder Judiciário para tutelar a própria ordem constitucional e limitar a atuação do Poder Público, inclusive legislativo.

Via de regra, esta competência é dada ao órgão de cúpula do Poder

Judiciário, que exerce, neste contexto, a denominada jurisdição constitucional.

Por jurisdição constitucional, portanto, deve ser entendida a atividade do Poder Judiciário voltada à limitação, à racionalização e ao controle dos poderes estatal, executivo e legislativo, especialmente por meio de pronunciamentos e controle abstratos da constitucionalidade dos atos destes poderes¹⁰⁰.

A especificidade do objeto e da finalidade da jurisdição constitucional é refletida nos mecanismos de atuação do Poder Judiciário nestas hipóteses, o que dá origem ao denominado “processo constitucional”, que para alguns constitui um ramo autônomo do direito processual, mas que, rigorosamente, confunde-se e, em grande medida, se aproxima do direito constitucional material¹⁰¹.

É possível, entretanto, fazer esta distinção entre o direito material constitucional e o direito processual constitucional. Este último é o ramo do direito processual ocupado do estudo e da sistematização das formas de atuação do Poder Judiciário no exercício da jurisdição constitucional.

No ordenamento jurídico brasileiro, a jurisdição constitucional é exercida eminentemente pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de maior hierarquia do Poder Judiciário nacional, com sobreposição a todos os demais órgãos jurisdicionais.

Contudo, o exercício da jurisdição constitucional não é o único papel reservado pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, a par do controle concentrado de constitucionalidade, típico do exercício da jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal atua como órgão de sobreposição de todas as “Justiças”, pela via do recurso extraordinário, e, ainda que excepcionalmente, possui competência recursal ordinária e até mesmo competência originária para processar e julgar determinadas ações, civis e penais.

Portanto, resta impossível resumir o papel do Supremo Tribunal Federal ao exercício da jurisdição constitucional, pois o rol de função deste órgão de cúpula do Poder Judiciário é extenso e heterogêneo.

O complexo conjunto de atribuições do Supremo Tribunal Federal escapa não só ao objeto desta Introdução, como também do próprio Direito Processual Civil, uma vez que o estudo de grande parte das funções deste órgão pertence, sobretudo, ao Direito Constitucional.

De todo modo, vale destacar que, a par da jurisdição constitucional aqui categorizada, é certo que o Supremo Tribunal Federal também exerce jurisdição penal, civil, trabalhista e eleitoral, nos termos ditados pela Constituição Federal, notadamente, do art. 102, que possui nada menos do que 17 hipóteses de competência originária, duas de competência recursal ordinária e quatro de competência recursal extraordinária, nem todas, como dito, ligadas ao exercício da jurisdição constitucional.

Em apertada síntese, é possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal exerce jurisdição por quatro vias processuais: a) ações voltadas ao controle concentrado de constitucionalidade (típicas do exercício da jurisdição constitucional); b) recursos extraordinários, mecanismos típicos de controle difuso de constitucionalidade que permitem ao Supremo atuar como tribunal de sobreposição; e excepcionalmente: c) julgamento de recursos ordinário e d) processamento e julgamento de ações originárias.

Do elenco acima, destacam-se as duas primeiras funções do STF, exercício da jurisdição constitucional, via controle concentrado de constitucionalidade ("a") e controle difuso de constitucionalidade, via recurso extraordinário ("b").

Portanto, o controle de constitucionalidade pode ser feito pelo Supremo Tribunal Federal de duas formas distintas: via controle difuso ou via controle concentrado.

Pelo primeiro, via recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal

julga a validade de uma decisão judicial à luz da Constituição Federal, apreciando a aplicação da norma constitucional ao caso concreto, e, nesta qualidade, se coloca como o órgão de última instância de todas as “Justiças”, com competência para analisar a compatibilidade da decisão proferida nas instâncias ordinárias com a Constituição Federal.

Nessas hipóteses, conforme já afirmado no corpo do presente trabalho, o julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal também cumpre um importante papel na uniformização da interpretação e da aplicação das normas constitucionais ainda que, a priori, a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso gere efeitos apenas dentro do processo no qual foi proferida, ou seja, para as partes integrantes da relação processual.

Entretanto, não pode ser desconsiderado o fato de julgamentos reiterados em sede de recurso extraordinário darem origem à denominada jurisprudência dominante, que, mais adiante, pode ser cristalizada em súmulas.

Nesse contexto, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, o julgamento reiterado de recursos extraordinários sobre a mesma matéria e no mesmo sentido passou a autorizar o Supremo Tribunal Federal a editar súmula vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a teor do art. 103-A da Constituição Federal.

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de o recurso extraordinário vir a ser processado e julgado pela sistemática prevista nos arts. 1.036 a 1.041, será formado um precedente qualificado¹⁰², que deverá ser observado por todos os demais juízes e tribunais do país.

Em outras palavras, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, poderá o Supremo Tribunal Federal afetar uma causa como representativa da controvérsia e pacificar a questão constitucional,

possuindo o acórdão proferido nessa sede força vinculante, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC¹⁰³.

Além do controle de constitucionalidade da lei e dos atos normativos no caso concreto (via controle difuso de constitucionalidade), o direito constitucional brasileiro admite o controle concentrado de constitucionalidade, no qual o Supremo Tribunal Federal avalia, em sede abstrata, a constitucionalidade da lei em tese.

No controle concentrado de constitucionalidade, não há conflito de interesses, pelo menos no sentido comumente utilizado no processo civil, dado que não há direito subjetivo discutido no processo.

O Supremo Tribunal Federal, nesses casos, é provocado por um dos legitimados para propor as ações voltadas à realização do controle concentrado (Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ação Declaratória de Descumprimento de Preceito Fundamental), para manifestar-se acerca da constitucionalidade da lei em tese.

Portanto, as ações diretas de inconstitucionalidade possuem natureza diversa das demais ações propostas com a finalidade de discutir direito subjetivo.

Isso porque, entre outras coisas, o Supremo Tribunal Federal pode funcionar, inclusive, como legislador negativo, caso declare a inconstitucionalidade formal ou material da lei, ou seja, uma vez declarada, em sede de controle abstrato, a inconstitucionalidade da lei, ela é retirada do mundo jurídico por essa decisão, independentemente da realização de qualquer outro ato do Poder Judiciário ou dos demais Poderes.

Em outras palavras, declarada a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo federal, a decisão terá efeito retroativo (*ex tunc*) e para todos (*erga omnes*), desfazendo, desde a sua origem, o ato declarado inconstitucional, com todas as consequências dele derivadas.

Na situação contrária, ou seja, caso o Supremo Tribunal Federal declare a norma compatível com a Constituição ou dê a essa norma uma interpretação conforme a Constituição, excluindo, portanto, as demais interpretações, essa decisão possuirá efeito erga omnes, retroativo e vinculante em relação aos órgãos dos poderes Executivo e Judiciário.

Assim, o Supremo Tribunal Federal, pela via do controle concentrado de constitucionalidade, também exerce o papel uniformizador da interpretação e aplicação da Constituição Federal, quer quando declara a inconstitucionalidade de uma lei, dado que, nesse caso, o dispositivo legal é retirado do universo do direito positivo; quer quando declara constitucional determinada disposição normativa, constitucionalidade essa que deixa de poder ser contestada ou declarada pelos demais órgãos do Poder Judiciário; e quer, ainda, quando dá uma interpretação conforme a Constituição, interpretação essa que, igualmente, vincula e deve ser seguida pelos demais órgãos jurisdicionais do País.

A afronta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, também está sujeita a cassação pela célere via da reclamação constitucional¹⁰⁴⁻¹⁰⁵, tal como a decisão que afronta texto de súmula vinculante.

Em virtude da especificidade da jurisdição constitucional, as ações e os processos voltados ao seu exercício possuem significativas diferenças, se comparados aos processos voltados ao exercício da jurisdição civil, e, portanto, a análise desses procedimentos escapa ao objetivo desta Introdução ao estudo do Direito Processual Civil. Essas ações constitucionais são objeto de estudo e sistematização do Direito Processual Constitucional.

Já o exercício da jurisdição pelo Supremo Tribunal Federal pela via dos recursos ordinários ("c") e das ações de competência originária ("d") é excepcionalíssimo e somente possível quando expressamente previsto na Constituição Federal, sendo vedado à lei estabelecer novas hipóteses de atuação do Supremo¹⁰⁶.

Assim, as únicas hipóteses de atuação do STF nestes casos são aquelas expressamente arroladas na Constituição Federal, notadamente nos incs. I e II da Constituição Federal, por exemplo, “processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Presidente da República” (art. 102, inc. I, “d”), “as ações penais comuns contra o Presidente da república, o Vice-Presidente e os membros do Congresso Nacional” (art. 102, inc. I, “b”), julgar em sede de recurso ordinário o “crime político”, entre outras.

b) Jurisdição trabalhista e os órgãos da Justiça especializada com competência para seu exercício

Conforme já asseverado no item 2.2, “b”, é longa a tradição do Direito brasileiro em separar a regulamentação das relações de trabalho das demais relações jurídicas por questões políticas, econômicas e sociais.

Três são os reflexos práticos mais sensíveis deste destaque: a) a existência de um direito material do trabalho; b) a criação de uma Justiça especializada em matéria trabalhista; e, para a atuação desta justiça especializada, c) um conjunto de regras processuais específicas, integrantes do Direito Processual do Trabalho.

A aplicação das normas materiais do Direito do Trabalho, durante o processo trabalhista, pela Justiça do Trabalho, autoriza a categorização de uma espécie de jurisdição, a trabalhista.

Em outras palavras, a jurisdição trabalhista, exercida pelos órgãos da Justiça do Trabalho, volta-se a processar e a julgar as lides trabalhistas, assim entendidas aquelas surgidas no âmbito das relações de trabalho, como os litígios entre empregado e empregador.

Seguindo a tradição de nosso Direito, a jurisdição trabalhista é exercida monocraticamente pelos juízes do Trabalho em exercício nas varas do trabalho, órgãos da Justiça do Trabalho que, portanto, têm o primeiro contato com a causa e julgam o litígio pela primeira vez.

A atuação destes juízes, como, quiçá, se caracteriza o exercício da jurisdição de primeiro grau, é singular, sendo a condução do processo e o julgamento proferidos por um único magistrado.

Esta decisão de primeiro grau proferida pelos juízes do trabalho, por força do princípio do duplo grau de jurisdição, desafia recurso que deverá ser dirigido ao Tribunal Regional do Trabalho – TRT, que, nessa medida, exerce a jurisdição de segundo grau.

Cada Estado da federação possui um Tribunal Regional do Trabalho, sediado em sua capital, à exceção do Estado de São Paulo que, além do TRT, com sede na capital do Estado, possui outro tribunal, na cidade de Campinas, com competência para exercer a jurisdição trabalhista de segundo grau em relação aos magistrados integrantes da sua região e algumas regiões (8ª, 10ª, 11ª e 14ª) que abrangem duas unidades federativas.

Portanto, a organização territorial da Justiça do Trabalho totaliza 24 Regiões, uma por Estado, sendo duas em São Paulo, com juízes do trabalho exercendo, monocraticamente, o primeiro grau de jurisdição e 24 TRT exercendo a jurisdição de segundo grau.

A jurisdição de sobreposição da Justiça trabalhista é exercida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nessa medida, é o órgão jurisdicional responsável por uniformizar a interpretação e a aplicação de toda a legislação trabalhista em território nacional.

O Tribunal Superior do Trabalho, como todos os demais tribunais superiores, tem sede em Brasília e jurisdição sobre todo o território nacional. Acima dele está o Supremo Tribunal Federal, que, como órgão máximo do sistema judiciário, tem competência para reanalisar as decisões da Justiça trabalhista à luz das normas consagradas na Constituição Federal.

c) Jurisdição eleitoral e os órgãos da Justiça especializada com

competência para seu exercício

Também escapa à tutela, pela via da jurisdição civil, o processamento e o julgamento de causas oriundas de litígios decorrentes dos processos eleitorais para a escolha, por meio do voto direto, secreto e universal, dos titulares dos cargos de chefia do executivo e dos cargos do Poder Legislativo.

As eleições para estes cargos são reguladas por normas constitucionais e pela legislação infraconstitucional composta pelo Código Eleitoral e pelas leis extravagantes que, somadas e sistematizadas, formam o Direito Eleitoral.

Pela dinâmica do Direito Eleitoral e, conseqüentemente, dos litígios dele oriundos, há, ao lado de um corpo de normas de direito material, um subsistema de normas processuais que caracterizam o Direito Processual Eleitoral¹⁰⁷.

A aplicação destas normas de Direito Eleitoral, material e processual, a exemplo do que acontece com o Direito do Trabalho, se dá por um “braço” autônomo do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral.

Portanto, a Justiça Eleitoral exerce a denominada jurisdição eleitoral, assim entendida a atuação do Estado-juiz voltada a resolver os conflitos de interesses surgidos nas disputas eleitorais.

São exemplos de causas afetas à jurisdição eleitoral, a impugnação e os demais questionamentos referentes às condições de elegibilidade de um candidato, as lides decorrentes de propaganda fora dos parâmetros permitidos pela lei eleitoral, e o uso ilegal do poder econômico ou político durante as eleições.

Nesse sentido, compete aos juízes eleitorais, no exercício da jurisdição eleitoral, tutelar a lisura das eleições e o cumprimento das normas constitucionais e legais integrantes do direito (material) eleitoral.

A especificidade do litígio e do bem jurídico tutelado, somadas à

existência de regras materiais e processuais próprias, e de órgãos próprios (Justiça Eleitoral), permitem, à luz dos critérios aqui estabelecidos, a categorização da jurisdição eleitoral como uma espécie de jurisdição distinta da jurisdição civil.

Não obstante esta distinção, é certo que, na ausência de regras processuais próprias e específicas, a Justiça Eleitoral exerce sua jurisdição, no âmbito de sua competência, observando as normas integrantes do Direito Processual Civil, que possui, conforme já asseverado no item 2.2, “f”, aplicação subsidiária nos processos judiciais eleitorais.

O exercício da jurisdição eleitoral se dá, em primeiro grau de jurisdição, monocraticamente, pelos juízes eleitorais atuantes nas varas eleitorais, sendo certo que o preenchimento destes cargos se dá por juízes federais ou estaduais investidos de jurisdição eleitoral.

Isso porque a Justiça Eleitoral não organiza uma carreira autônoma de magistrados. Portanto, os juízes eleitorais são juízes integrantes das carreiras da magistratura federal ou estadual cedidos à Justiça Eleitoral e, como decorrência desta cessão, investidos de jurisdição eleitoral.

Em segundo grau de jurisdição, a Justiça Eleitoral se estrutura com um Tribunal Regional Eleitoral por Estado, também com sede na capital, totalizando, portanto, 27 TRE, órgãos responsáveis pelo exercício do segundo grau de jurisdição da Justiça Eleitoral.

A jurisdição de sobreposição da Justiça Eleitoral é exercida pelo Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília e competência para uniformizar a interpretação e a aplicação das normas eleitorais em âmbito nacional.

As decisões do TSE podem ser revistas pelo Supremo Tribunal Federal que, como órgão máximo do sistema judiciário, tem competência para reanalisar suas decisões à luz da Constituição Federal.

d) Jurisdição penal comum e militar e os órgãos da Justiça comum e especializados com competência para seu exercício

Conforme já asseverado, as justiças comuns federal e estadual possuem competência tanto em matéria civil quanto em matéria penal, o que não impede a realização de uma classificação levando em consideração o objetivo do exercício da jurisdição, o bem jurídico tutelado e, por via de consequência, as espécies de direito material e processual aplicadas.

O exercício da jurisdição penal se volta à tutela da ordem pública e do interesse de toda a sociedade em aplicar a punição ao sujeito, autor de uma conduta tipificada como crime pelo direito (material) penal.

Diz-se que o direito tutelado é de toda a sociedade, e não apenas da vítima do delito, dado que a lógica do direito penal consiste exatamente em tipificar como crime, proibindo determinadas condutas que, de tão graves, são tidas como ofensivas a todos, e não apenas àquele diretamente prejudicado pela ação delituosas, ou seja, a vítima do crime.

Conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete, no instante em que alguém pratica um fato previsto na lei penal como crime, surge o dever do Estado de punir o autor da infração, sendo a punição do autor “a justa reação do Estado em nome da defesa da ordem social e da boa convivência entre os cidadãos”.

Depreende-se da afirmação acima que a aplicação da punição não encerra apenas um direito potestativo do Estado, mas um verdadeiro dever, sendo obrigação funcional do Estado impor medidas penais, voltadas, em última análise, à manutenção ou à reintegração da ordem jurídica.

Ocorre que a realização da pretensão punitiva pelo Estado, em um regime Democrático de Direito, como o ditado pela Constituição Federal de 1988, exige, para fins de legitimidade e validade de aplicação da pena, a observância do devido processo legal, o que nos leva à necessidade de atuação do Estado-juiz¹⁰⁸, no exercício da função jurisdicional, por meio de um processo.

A jurisdição penal, portanto, é a atividade do juiz voltada à verificação da

infração penal, bem como de sua autoria e consequente aplicação da pena prevista em lei, ou seja, no direito (material) penal.

O juiz, no exercício da jurisdição penal, não se ocupa de outras consequências do ato ilícito, como eventuais prejuízos causados à vítima e, conseqüentemente, o dever de reparação destes prejuízos, tema que deverá, se for o caso, ser discutido em outro processo, perante o juiz titular no exercício da jurisdição civil.

O exercício da jurisdição penal tem objetivos próprios, que não se confundem com os objetivos da jurisdição civil e, dadas as características de tal atividade, o próprio processo, como método de atuação do poder jurisdicional, possui outra dinâmica, por isso é regulamentado por outro conjunto de regras processuais, previstas no Código de Processo Penal e na legislação processual extravagante integrante do Direito Processual Penal.

Não obstante todo esse grau de especificidade, a jurisdição penal, salvo crimes específicos, é exercida pelos órgãos da Justiça comum, federal ou estadual, de acordo com a natureza do crime praticado e o bem jurídico lesado, não havendo, portanto, um quadro de juízes exclusivamente penais ou uma carreira específica da magistratura penal, como há na trabalhista.

Desta feita, a jurisdição penal é exercida pelos juízes estaduais ou federais que, uma vez investidos nos quadros do Judiciário, podem atuar em ambos os ramos da jurisdição comum.

O que pode haver é, no máximo, uma especialização do órgão da Justiça comum em matéria criminal, algo que acontece sobretudo nas localidades em que há um grande número de varas.

É possível, contudo, nas regiões em que há uma única vara, a cumulação do exercício das jurisdições penal e civil em um único magistrado, federal ou estadual.

O exercício da jurisdição penal comum, portanto, acontece dentro da mesma estrutura organizacional da jurisdição civil, conforme será visto

adiante, pelos juízes federais ou estaduais, monocraticamente, em sede de primeiro grau de jurisdição, pelos tribunais de Justiça dos Estados ou pelos tribunais regionais federais, em segundo grau, e pelo Superior Tribunal de Justiça, em grau de sobreposição, tema que será pormenorizado no item subsequente.

Ademais, compete ao Supremo Tribunal Federal exercer a jurisdição penal de sobreposição, especialmente, em matéria constitucional, sendo este órgão a última instância do Judiciário no que tange às questões penais.

Uma especialização do Direito Penal, relevante para fins de organização do Poder Judiciário, é o Direito Penal Militar, assim entendidos os crimes definidos pelo Código Penal Militar, praticados, portanto, no contexto do exercício desta atividade específica.

A competência para processar e julgar os acusados de prática de crimes militares é de uma Justiça especializada nesta matéria, a Justiça Militar, prevista nos arts. 122 a 124 da Constituição Federal.

A Justiça Penal Militar se organiza, no primeiro grau, por um órgão colegiado composto por um juiz togado e dois oficiais militares, sendo, desta feita, a única exceção ao exercício monocrático da jurisdição de primeiro grau.

O segundo grau de jurisdição da Justiça Militar é exercido, especificamente, pelo Tribunal de Justiça Militar ou, nos Estados em que estes não existem, pelo próprio Tribunal de Justiça da Justiça Comum.

Tal como a jurisdição penal comum, a jurisdição penal militar, bem como a estrutura organizacional dos órgãos do Judiciário que a exercem, escapa ao objeto desta Introdução ao estudo do Direito Processual Civil.

e) Jurisdição civil e os órgãos da Justiça comum com competência para seu exercício

Exceção feitas às jurisdições penal, trabalhista, eleitoral e constitucional,

acima referidas, todos os demais litígios, qualquer que seja o seu objeto e o direito material aplicável à relação jurídica, são tutelados pela jurisdição civil.

Nesse sentido, a jurisdição civil extrapola, e muito, a tutela das relações jurídicas disciplinadas pelo Direito Civil, pois abrange também todas as demais reações litigiosas que não configurem objeto de atuação das demais espécies de jurisdição.

O Estado-juiz, no exercício da jurisdição civil, portanto, a par de se ocupar com a resolução de litígios civis propriamente ditos, assim entendidos os regulamentados pelo direito (material) civil, se ocupa também da resolução das lides empresariais, ambientais, tributárias, previdenciárias, consumeristas, entre outras.

Por essa razão, é forçoso concluir que a jurisdição civil é aquela que possui maior abrangência em relação à variedade e à quantidade de ramos do direito material por ela tutelados.

Dada esta abrangência, é até possível a subclassificação da jurisdição civil ou, mais especificamente, da tutela jurisdicional e dos procedimentos voltados à prestação desta espécie de jurisdição, sendo certo, todavia, que, inobstante o objeto do processo, o direito material regulamentador da relação jurídica litigiosa e do procedimento adotado, todo o exercício da jurisdição não penal, trabalhista, eleitoral ou constitucional, é abarcado pela jurisdição civil.

O método de atuação (processo) dos órgãos competentes para o exercício da jurisdição civil é regulamentado por um único ramo do direito processual, o Direito Processual Civil, que até admite, obviamente, variações procedimentais, de acordo com a espécie de tutela jurisdicional a ser prestada, mas que integra, de maneira amplíssima, todos os litígios, independentemente da natureza e das pessoas envolvidas.

A jurisdição civil é exercida pelos órgãos do Poder Judiciário integrantes

d a Justiça comum federal e da Justiça comum estadual, que são os responsáveis pela interpretação e aplicação do Direito Processual Civil brasileiro.

A Justiça comum federal é organizada e mantida pela União, que, no primeiro grau, exerce a jurisdição federal por meio dos juízes federais integrantes das diversas varas federais espalhadas por todo o território nacional.

Para fins organizacionais, a Justiça federal é dividida em cinco Regiões Federais, estando, portanto, cada um dos juízes federais vinculados a uma destas regiões.

A 1ª Região Federal abrange os Estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Amapá, Goiás, Minas Gerais e Bahia, além do Distrito Federal; a 2ª Região, os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; a 3ª Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul; a 4ª Região, o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e a 5ª Região, os Estados de Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte.

Cada uma destas Regiões possui um Tribunal Regional Federal com competência para, em sede recursal, exercer a jurisdição de segundo grau no âmbito da Justiça federal.

Aos juízes federais, nos termos do art. 109 da Constituição, compete processar e julgar: "I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades

autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; V – A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; VII – os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; VIII – os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; XI – a disputa sobre direitos indígenas”.

Assim, se presente uma das pessoas referidas em um dos incisos do art. 109 da CF ou se a causa versar sobre uma das matérias ali elencadas, o processo deve se desenvolver em primeiro grau de jurisdição perante um dos órgãos da Justiça federal, notadamente, as varas federais.

Como se pode notar a partir da simples leitura do rol do art. 109 da Constituição Federal, a competência dos juízes federais é tanto para o exercício da jurisdição civil como da jurisdição penal.

A jurisdição comum de segundo grau, no plano federal, por sua vez, é exercida por cinco tribunais regionais federais estrategicamente espalhados pelo território nacional, possuindo como sedes: a) Brasília (TRF 1ª Região); b) Rio de Janeiro (TRF 2ª Região); c) São Paulo (TRF 3ª Região); d) Porto Alegre (TRF 4ª Região); e e) Recife (TRF 5ª Região). Cada juiz federal está

necessariamente vinculado a um destes cinco tribunais regionais federais¹⁰⁹.

Acima dos tribunais regionais federais, exercendo jurisdição de sobreposição sobre toda a Justiça federal, está o Superior Tribunal de Justiça – STJ, com competência para rever, em sede de recurso especial, as decisões de última instância proferidas pelos TRF, desde que presentes os requisitos de cabimento do referido recurso, além de outras tarefas que lhe são atribuídas pela Constituição Federal, notadamente, em seu art. 105.

Por se tratar de uma jurisdição de sobreposição, não cabe ao STJ reanalisar toda decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, mas apenas verificar a compatibilidade do entendimento consagrado naquela sede com a legislação federal infraconstitucional e com a jurisprudência sobre matéria do próprio tribunal superior.

Isso porque a jurisdição de sobreposição não representa um “terceiro grau” de jurisdição. Compete ao órgão jurisdicional que a exerce a análise da causa voltada, única e exclusivamente, à uniformização da interpretação e aplicação da legislação federal, o que não se confunde com uma ampla e irrestrita reanálise da matéria julgada em segundo grau.

Por esse motivo, algumas questões julgadas em segundo grau pelos tribunais regionais federais, simplesmente não podem ser revistas ou reanalisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a reanálise de provas ou, mais amplamente, matéria de fato, bem como a interpretação de cláusulas contratuais.

A jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de toda a jurisdição de sobreposição, limita-se a questões ligadas à interpretação e à aplicação da legislação federal com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca destes textos normativos em todo o território nacional.

A par do STJ, é possível a revisão dos julgados dos tribunais regionais

federais pelo Supremo Tribunal Federal desde que a análise da decisão se dê pela ótica da Constituição Federal, exercendo, o STF, nestas hipóteses, o papel de órgão máximo da jurisdição comum federal.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, que também exerce jurisdição de sobreposição, não ocorrerá uma ampla reanálise da causa, como a reavaliação de provas e fatos, mas apenas uma averiguação da compatibilidade da decisão recorrida com o texto constitucional.

Além dos órgãos da Justiça federal, também exercem jurisdição comum os órgãos da Justiça estadual.

Compete à Justiça estadual processar e julgar todas as causas, civis e penais, não afetas às Justiças especializadas (do trabalho, eleitoral e militar) nem à Justiça federal.

Dado este critério de definição de competência por exclusão, diz-se que a Justiça estadual possui a competência residual.

O art. 125 da Constituição Federal obriga todos os Estados-membros da federação a criarem e manterem sua respectiva estrutura judiciária ao dispor que “os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição”.

Em razão de sua competência residual, cabe à Justiça comum estadual, portanto, o processamento e o julgamento de uma enorme variedade de litígios regulamentados pelos mais diversos ramos do direito, salvo aqueles sujeitos à Justiça federal ou às Justiças especializadas.

Entretanto, conforme já asseverado no item 2.2, “f”, independentemente do ramo do direito material aplicável ao litígio, o juiz estadual, no exercício da jurisdição comum, sempre se valerá das normas integrantes do Direito Processual Civil, notadamente, pelo Código de Processo e pela legislação processual extravagante, para fins de condução do processo.

Já quando do julgamento do mérito do processo, o direito material aplicável variará sensivelmente, de acordo com a natureza do litígio,

podendo ser civil, empresarial, ambiental, tributária, entre muitas outras, desde que não afetas às Justiças do trabalho, eleitoral, militar e federal.

A exemplo das demais “Justiças” até aqui tratadas, o Poder Judiciário estadual se estrutura de modo a viabilizar seu exercício, em primeiro grau de jurisdição, por meio de órgãos jurisdicionais monocráticos (varas) ocupados por juízes regularmente investidos da função jurisdicional.

A instância recursal é exercida pelos Tribunais de Justiça, órgãos máximos na estrutura da Justiça dos Estados, hierarquicamente superiores aos juízes e aos demais órgãos da Justiça estadual.

Portanto, cada Estado possui um tribunal de Justiça com sede em sua capital e competência para processar e julgar os recursos contra as decisões de primeiro grau proferidas pelos juízes estaduais.

Acima dos tribunais de Justiça estaduais, com competência para rever suas decisões, em sede recursal, no exercício da jurisdição de sobreposição, está o Superior Tribunal de Justiça, órgão de cúpula de toda a Justiça comum, uma vez que, além da Justiça estadual, também exerce a mesma competência em relação aos órgãos da Justiça federal comum.

Compete ao STJ, portanto, a uniformização da aplicação e da interpretação de toda a legislação federal infraconstitucional, sendo sobremaneira relevante para o Direito Processual Civil, a jurisprudência e os precedentes desta Corte em matéria processual.

Tanto a Justiça federal quanto as Justiças estaduais, a par da estrutura suprarreferida, possuem uma estrutura paralela denominada “juizados especiais”.

Os juizados especiais são previstos no art. 98, inc. I, da Constituição Federal e regulamentados, no plano federal, pela Lei n. 10.259/2001 e, no plano das Justiças estaduais, pelas Leis n. 9.099/95 e n. 12.153/2009.

A competência destes órgãos é definida pelos referidos diplomas legislativos e, em apertada síntese, é possível afirmar que os juizados

especiais podem ser tidos como órgãos jurisdicionais com competência para processar e julgar causas de menor complexidade, assim definidas em lei.

Nesse contexto, são consideradas causas de menor complexidade sujeitas aos juizados especiais cíveis estaduais, pela Lei n. 9.099/95: a) as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; b) as enumeradas no art. 275, inc. II, da Lei n. 5.869/73 (CPC/73), nos termos do art. 1.063 do Código de Processo Civil; c) a ação de despejo para uso próprio; d) as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao valor equivalente a quarenta vezes o salário mínimo.

No plano federal, a Lei n. 10.259, de 2001, define como causas de menor complexidade aquelas de competência da Justiça federal até o valor de sessenta salários mínimo, excluindo-se algumas matérias e ações identificadas no art. 3º, § 1º, da referida lei.

As causas sujeitas aos juizados especiais, além de serem subordinadas a uma diferente estrutura, a seguir referida, também se sujeitam a um procedimento especial estabelecido pelas Leis ns. 9.099/95 e 10.259/2001 sem, portanto, a incidência de inúmeras regras estabelecidas no Código de Processo Civil.

No que diz respeito à estrutura dos juizados especiais, a par de o primeiro grau de jurisdição ser exercido por órgãos diferentes integrantes da estrutura do próprio juizado, há também distinções no plano recursal e de sobreposição.

Isso porque os recursos cabíveis contra os juízes de primeiro grau dos juizados especiais federais e estaduais não são dirigidos aos tribunais de Justiça e aos tribunais regionais federais, conforme o caso, haja vista que tais recursos são processados e julgados pelas denominadas “turmas recursais”, compostas não por desembargadores, mas por outros juízes de primeiro grau, neste contexto, exercendo competência recursal.

Em outras palavras, os processos sujeitos aos juizados especiais não são,

no plano recursal, apreciados pelos tribunais de segundo grau.

Ademais, contra as decisões das turmas recursais não é cabível recurso para o Superior Tribunal de Justiça, o que implica dizer que o STJ não exerce seu papel de órgão de sobreposição quando a causa tramita no âmbito dos juizados especiais.

O papel do STJ, no âmbito dos juizados especiais federais, em certa medida, é exercido pela “turma nacional de uniformização”, órgão de cúpula da estrutura dos juizados especiais com competência para processar e julgar o incidente de uniformização de interpretação de lei federal em questões de direito material: I – fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais dos JEF, de diferentes Regiões; II – em face de decisão de Turma Recursal de JEF proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça; ou III – em face de decisão de Turma Regional de Uniformização dos JEF, proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a função do STF, de guardião da Constituição, é resguardada na estrutura organizacional dos juizados, uma vez que esse órgão exerce seu papel mesmo nos casos sujeitos aos juizados especiais, dado que cabível contra as decisões de última instância proferidas nesta sede, o recuso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

As peculiaridades do procedimento especial dos juizados e dos recursos cabíveis nos processos sujeitos a sua competência escapam ao objeto deste item, sendo suficiente, nesta sede, o registro de que estes órgãos jurisdicionais estruturados no âmbito do Poder Judiciário exercem jurisdição sobre as causas de menor complexidade, assim definidas por lei.

5.2 Quadro de organização do Poder Judiciário

Da combinação da classificação da jurisdição e dos reflexos na criação de diversas “Justiças” com a existência, em cada uma delas, de órgãos de

primeiro e segundo graus de jurisdição, além dos tribunais superiores, no exercício da jurisdição de sobreposição, emerge o seguinte quadro de organização do Poder Judiciário:

Jurisdição constitucional	Supremo Tribunal Federal				
	Superior Tribunal de Justiça		Tribunal Superior do Trabalho	Tribunal Superior Eleitoral	Superior Tribunal Militar
Jurisdição de sobreposição	Superior Tribunal de Justiça		Tribunal Superior do Trabalho	Tribunal Superior Eleitoral	Superior Tribunal Militar
Jurisdição de segundo grau	Tribunais de Justiça (2V)	Tribunais regionais federais (O)	Tribunais regionais do trabalho (2Σ)	Tribunais regionais eleitorais (2V)	–
Jurisdição de primeiro grau	Vara estadual	Vara federal	Vara do trabalho	Vara eleitoral	Auditorias militares
“Justiça”	Justiça estadual	Justiça federal	Justiça do trabalho	Justiça eleitoral	Justiça militar
Espécie de jurisdição	Jurisdição civil e penal comum	Jurisdição civil e penal comum	Jurisdição trabalhista	Jurisdição eleitoral	Jurisdição penal militar

Juizados especiais:

Jurisdição constitucional	Supremo Tribunal Federal	
	Supremo Tribunal Federal	
Jurisdição de sobreposição	Turma nacional de uniformização	–
Jurisdição de segundo grau	Turma recursal	Turma recursal
Jurisdição de primeiro	Varas de juizados especiais federais	Varas de juizados especiais cíveis

grau	(JEF)	(JEC)
–	Jurisdição civil federal	Jurisdição civil estadual

Capítulo 6 Normas Fundamentais do Processo Civil Brasileiro

6.1 Normas fundamentais na Constituição Federal

Já no Capítulo 2, desta Introdução, no item dedicado às fontes do Direito Processual Civil, restou claro que a Constituição Federal consagra as principais normas processuais civis na medida em que os direitos e garantias fundamentais processuais encontram-se nela estabelecidos.

Considerando a superioridade hierárquica das normas constitucionais, que não podem ser afastadas pela legislação ordinária e que devem ser respeitadas e aplicadas ainda que ausente norma infraconstitucional que discipline a garantia no caso concreto, os direitos fundamentais processuais consagrados na Constituição Federal são o desenho do Processo Civil brasileiro, sendo os valores e princípios ali consagrados os vetores que devem nortear o legislador, o intérprete da lei processual, bem como todos os operadores e sujeitos atuantes no processo.

Em outras palavras, conforme já asseverado, é a Constituição Federal que delineia o processo, ou seja, o método pelo qual o direito de ação é atendido e a tutela jurisdicional prestada, garantindo a todos os litigantes o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), a publicidade dos atos processuais, o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX), bem como seu desenvolvimento em tempo razoável, nos termos do art. 5º, inc. LXXVIII, introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004.

Dada importância das normas constitucionais para o estudo do Direito Processual Civil é indispensável o conhecimento da forma e do conteúdo das normas processuais civis consagradas na Constituição Federal.

Este capítulo será dedicado a três pontos centrais deste contexto: a) a estrutura das normas processuais civis constitucionais, que podem ser

divididas em regras e princípios; b) o papel destas normas, e em especial dos princípios fundamentais, no sistema jurídico processual, e; c) o estudo das normas fundamentais em espécie consagradas constitucionalmente.

O estudo da estrutura normativa da Constituição Federal e do papel das normas constitucionais no ordenamento processual implica um estudo teórico muito importante que passa pela distinção entre regras e princípios constitucionais, pela análise do grau de eficácia das normas constitucionais e pela metodologia de interpretação e aplicação específica dessas normas, temas que serão objeto dos itens subsequentes.

Já o estudo dos princípios constitucionais em espécie voltar-se-á à análise de treze princípios fundamentais que moldam e influenciam a interpretação e aplicação de todas as demais regras processuais. Tais princípios, todos com status de direitos fundamentais, estão previstos no rol do art. 5º, bem como no art. 93, todos da Constituição Federal¹¹⁰.

6.1.1 Estrutura normativa do Direito Processual Civil na Constituição Federal: os princípios e regras processuais constitucionais

Atualmente, é pacífico o entendimento em sede de Teoria Geral do Direito de que o gênero norma jurídica se subdivide em duas espécies, quais sejam, princípios jurídicos e regras jurídicas¹¹¹.

Os primeiros, na lição de Robert Alexy¹¹², caracterizam-se por serem mandamentos de otimização e por poderem ser satisfeitos em diversos graus a depender das possibilidades fáticas e jurídicas; já as regras jurídicas se estruturam como uma determinação de se fazer exatamente aquilo que se determina, nem mais nem menos.

Ainda segundo o citado autor, as regras já contêm em sua estrutura a determinação daquilo que é fática e juridicamente possível, sendo, por esse motivo, a distinção entre regras e princípios uma distinção qualitativa¹¹³.

Ronald Dworkin ensina que a diferença entre princípios e regras jurídicas

é de ordem lógica, ambos voltados a orientar decisões particulares acerca de obrigações jurídicas, distinguindo-se, contudo, no que se refere à natureza da orientação que oferecem¹¹⁴.

Para o referido autor, as regras são aplicadas da maneira do tudo ou nada; ao passo que os princípios possuem uma dimensão de peso ou importância que permite levar-se em conta, em cada caso concreto, a força relativa de cada um¹¹⁵. Já as regras, continua Dworkin¹¹⁶, não têm essa dimensão e, quando duas regras entram em conflito, não se trata de se investigar qual delas possui maior importância naquele caso, mas sim de se saber qual regra é válida e aplicável e qual regra, por ser inaplicável, em nada contribui para a solução do caso.

Para Canotilho¹¹⁷, é possível estabelecer as seguintes distinções entre regras e princípios: a) grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida; b) grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação direta; c) caráter de fundamentalidade no sistema das fontes do direito: os princípios são normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido a sua posição hierárquica no sistema de fontes ou a sua importância estruturante dentro do sistema jurídico; d) proximidade da ideia de direito: os princípios são standards juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça; as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional; e) natureza normogenética: os princípios são fundamentos das regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante.

Conforme já asseverado, é na Constituição Federal em que se encontram as principais normas do Direito Processual Civil, sendo certo que a

apresentação destas normas pode se dar por meio de duas estruturas normativas diversas: as regras e os princípios.

Willis Santiago Guerra Filho¹¹⁸ aduz que os princípios “devem ser entendidos como indicadores de opção pelo favorecimento de determinado valor, a ser levada em conta na apreciação jurídica de uma infinidade de fatos e situações possíveis, juntamente com outras tantas opções dessas, outros princípios igualmente adotados, que em determinado caso concreto podem se conflitar uns com os outros, quando já não são mesmo, in abstracto, antinômicos entre si”.

Disso decorre um dos principais traços característicos dos princípios, a saber, sua relatividade, dado que não há princípio que possua natureza absoluta, ou seja, aplicável e inafastável em toda e qualquer hipótese, pois a obediência unilateral e irrestrita a determinada pauta valorativa consagrada em um princípio leva, ou pode levar, a aniquilação ou violação a outra norma de igual hierarquia.

Destarte, uma das distinções possíveis entre as normas jurídicas da espécie regras dos princípios é a de que as regras seriam normas com alto grau de determinação, aplicáveis ou inaplicáveis ao caso concreto; e os princípios, por possuírem alto grau de generalidade e abstração, podem ser realizados gradativamente, a depender das condições fáticas e jurídicas, possuindo por isso caráter relativo e não absoluto como as regras.

Por isso, em caso de choque de princípios, conforme salienta Willis Santiago Guerra Filho¹¹⁹, a prevalência de um (ou alguns) princípios sobre outro em determinado caso concreto não infirma a validade da norma preterida, apenas diminui, circunstancial e pontualmente, sua eficácia¹²⁰.

José Joaquim Gomes Canotilho¹²¹ sobre o tema arremata que “os princípios são normas de natureza ou com papel fundamental no ordenamento jurídico devido a sua posição hierárquica no sistema de fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado Democrático de Direito)”. Para o

referido autor, os princípios constitucionais devem ser compatibilizados e harmonizados entre si¹²².

Portanto, em suma, pode-se afirmar que, enquanto as regras processuais possuem uma estrutura mais concreta e mais simples de serem aplicadas dado que basta ao intérprete verificar se a realidade fática se ajusta ou não a hipótese descrita na norma, os princípios, por possuírem uma estrutura mais aberta, demandam um método de aplicação diferente, pois sua simples subsunção do fato à norma por si só não é suficiente até porque os princípios não descrevem situações fáticas, mas apenas prescrevem determinado valor.

Um exemplo de regra processual pode ser extraído do art. 335, inc. III, do Código de Processo Civil, que dispõe que o prazo para contestar é de 15 dias contados a partir do primeiro dia útil a juntada do mandado citatório aos autos do processo, norma jurídica muito mais precisa e concreta do que uma norma com estrutura de princípio como a encontrada no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, que dispõe apenas que “aos litigantes em geral é garantido o contraditório e ampla defesa”¹²³.

Assim, enquanto o intérprete e aplicador da regra constante do art. 335, inc. III, do Código de Processo Civil pode concluir com imenso grau de exatidão o dia do fim do prazo para a contestação bastando, para tanto, identificar o dia da juntada do mandado citatório aos autos do processo e, então, contar o prazo de quinze dias a partir do primeiro dia útil seguinte, o intérprete e aplicador do contraditório encontrará muito mais margem e dificuldade para definir o que é “contraditório”, o que vem a ser “ampla defesa”, e quais são os desdobramentos concretos destes comandos na atividades das partes e do juiz.

Não obstante a existência das duas espécies normativas no corpo da Constituição Federal, é na forma de princípios constitucionais que se apresenta a maioria dos direitos fundamentais, categoria em que se incluem inúmeras normas processuais¹²⁴.

O conteúdo e as funções dos princípios processuais constitucionais serão estudados neste capítulo.

Antes disso, serão tecidas algumas considerações sobre as regras processuais no item subsequente.

6.1.2 As regras processuais na Constituição Federal

Não obstante a vocação principiológica das normas constitucionais, a Constituição Federal de 1988 é igualmente rica em normas processuais com estrutura de regras, isto é, normas que se caracterizam por maior grau de determinabilidade e menor abstração e por conterem mandamentos definitivos passíveis de aplicação por meio de subsunção, nos termos já referidos nos itens precedentes.

As normas com estrutura de regras consagradas na Constituição, para Canotilho¹²⁵, podem ser denominadas de regras jurídico-organizatórias, que, por sua vez, ainda segundo o constitucionalista português, podem ser subdivididas em três grupos: a) regras de criação de órgãos ou normas orgânicas, que se caracterizam por preverem a criação ou instituição de certos órgãos; b) regras de competência, isto é, normas que fixam atribuições e delimitam a competência de um órgão estatal; e c) regras de procedimento.

É certo que muitas dessas regras constitucionais jurídico-organizatórias não são de natureza processual civil, por se referirem, por exemplo, a criação e atribuição de competência a órgãos dos poderes Legislativo e Executivo.

Contudo, muitas das regras constitucionais de natureza jurídico-organizatórias possuem natureza processual, quer porque dizem respeito ao Poder Judiciário, sua estrutura e repartição de competências (normas orgânicas e regras de competência respectivamente), quer por consagrarem institutos tipicamente de direito processual ou estabelecerem incidentes processuais, o que, seguindo a lição de Canotilho¹²⁶, poder-se-ia classificar

como regras constitucionais de procedimento.

Grande parte das regras processuais constitucionais de natureza jurídico-organizatória é pertinente ao estudioso do Direito Processual Civil, a começar pelas regras que estabelecem a competência e as funções dos tribunais superiores, e as que criam e estruturam as hipóteses de cabimento de recursos a serem dirigidos a essas cortes, bem como as que preveem a existência e as respectivas competências das diversas “Justiças”, federal, estadual, do trabalho, eleitoral e militar.

Ademais, é de se ressaltar que, dentre os princípios e as regras constitucionais, há uma relação de densificação¹²⁷, que se traduz em uma marcha rumo à concretização que vai desde os princípios estruturantes, com maior carga de abstração, às regras constitucionais mais concretas, passando pelos subprincípios, assim entendidos aqueles que, ainda mantendo a estrutura normativa de princípio, têm grau de abstração menor se comparados aos princípios estruturantes.

Assim, os valores segurança (no sentido de previsibilidade) e igualdade¹²⁸, positivados constitucionalmente pelos princípios da isonomia e segurança jurídica, são densificados na própria Constituição Federal pela via da previsão de regras que estabelecem o respeito à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional ou que garantem o respeito à coisa julgada¹²⁹ (art. 5º, XXXVI).

Igualmente, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV), entendido como uma garantia de acesso ao Judiciário, e a ampla defesa (art. 5º, LV), são concretizados pela própria Constituição Federal quando estabelece que àqueles que não possuem meios econômicos para pagar às custas de um processo é garantida a assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV).

Ademais, a relação entre princípios e regras não se desenvolve apenas em uma única direção, de baixo para cima, do abstrato para o concreto,

mas também na direção inversa em um processo de esclarecimento recíproco¹³⁰.

Essa constatação nos permite concluir pela possibilidade de se extraírem princípios constitucionais implícitos na Constituição Federal a partir da consagração de determinadas regras processuais constitucionais.

Exemplo disso é a extração do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição a partir das regras de criação de órgãos (normas orgânicas) e regras de competência recursal dos tribunais superiores, e de segundo grau de jurisdições estaduais e federais.

É de se ressaltar que o princípio do duplo grau de jurisdição, pelo fato de não estar expresso na Constituição Federal, mas, sim, ser um princípio derivado de regras constitucionais, não pode ser taxado de um princípio menor, ou possuidor de carga de eficácia reduzida, pelo simples motivo de não estar expressamente consagrado no texto constitucional.

É certo que, como todo e qualquer princípio, o duplo grau de jurisdição não encerra um valor absoluto, devendo ser cotejado e limitado pelos demais princípios constitucionais. Porém, feita essa observação, a garantia do duplo grau de jurisdição orienta e limita as possibilidades de atuação do legislador e do Judiciário na busca por um processo mais célere e efetivo, conforme se verá no item 6.1.4.8.

6.1.3 Princípios processuais constitucionais: características e funções

Conforme já asseverado no capítulo dedicado às fontes do Direito Processual Civil, as normas constitucionais, pelo só fato de estarem consagradas na Constituição Federal, possuem uma posição hierarquicamente superior às demais normas processuais infraconstitucionais.

A Constituição Federal, como principal diploma normativo do ordenamento jurídico, possui uma vocação para trazer normas com

estrutura de princípios, apesar de também existirem em nossa Constituição normas com estrutura de regras, como as que estabelecem a competência de tribunais e a própria existência, estrutura e composição dos órgãos do Poder Judiciário.

Portanto, não obstante a existência de regras constitucionais processuais, é por meio de consagração de princípios que a Constituição exerce seu maior grau de influência no sistema processual.

Conforme já asseverado no item 6.1.1, ao contrário das regras que possuem uma estrutura que permite a subsunção de determinado fato à norma, os princípios são normas intencionalmente abertas, com um grande grau de generalidade e abstração que, por um lado, carecem de precisão e objetividade e, por outro, são as normas orientadoras e definidoras dos principais valores do sistema processual.

Estas características de grande generalidade e abstração dos princípios, somadas ao fato destas normas estarem consagrados na Constituição Federal, dão aos princípios processuais constitucionais um importantíssimo papel no ordenamento processual, tornando os valores neles consagrados os pontos fulcrais e fundamentais do Processo Civil brasileiro.

Por esse motivo, torna-se muito importante o estudo de cada um dos princípios constitucionais em espécie, seu sentido, alcance e desdobramentos.

Antes disso, porém, faz-se necessária a análise de algumas características dos princípios, bem como das diversas funções por eles exercidas.

São características dos princípios processuais constitucionais: a) possuírem status de direito fundamental, e por este motivo; b) serem cláusulas pétreas; c) possuírem aplicabilidade imediata; d) possuírem uma dimensão objetiva e outra subjetiva; e) terem vários destinatários; f) tenderem a entrar em conflito e terem de ser solucionados pela aplicação

da proporcionalidade em razão de seu alto grau de abstração.

Por suas características e posição superior na hierarquia normativa, os princípios cumprem diversas funções no sistema normativo, notadamente: a) função fundamentadora; b) função interpretativa; c) função supletiva; d) função integrativa; e) função limitadora.

6.1.3.1 Características dos princípios processuais constitucionais

a) O status de direito fundamental

De tão importantes para o sistema processual e para o sistema jurídico como um todo, os princípios processuais possuem status de verdadeiros direitos fundamentais no sistema processual, irradiando ou podendo irradiar efeitos e comandos normativos para as próprias partes e seus advogados, para o juiz e seus auxiliares e até para os órgãos legislativos responsáveis pela elaboração das demais regras processuais.

Por direito fundamental devem ser entendidos, do ponto de vista formal, todos aqueles assim caracterizados pela Constituição, o que nos leva a conclusão de que sua definição pode variar de acordo com o ordenamento constitucional e o próprio modelo de Estado adotado em cada país.

A partir da análise da Constituição Federal brasileira, pode-se concluir que são direitos fundamentais, em primeiro lugar, todos aqueles caracterizados como tal pelo art. 5º da Constituição, aos quais pode ser acrescentada qualquer outra norma esparsa no texto constitucional que, de algum modo, consagre um direito ou valor indispensável e essencial para a caracterização do ordenamento jurídico como um Estado Democrático de Direito, como a vida, a liberdade, a igualdade, entre tantos outros.

Assim, considerando que o ordenamento brasileiro se propõe a ser um Estado Democrático de Direito, são direitos fundamentais todos aqueles direitos que não podem ser suprimidos pelo Estado sob pena de descaracterização deste modelo, a começar pelo direito à vida, à liberdade

e à igualdade que se vão desdobrando e densificando no próprio texto constitucional, até que sejam consagrados em um extenso rol no qual se inclui uma série de direitos processuais.

Escapa ao objeto desta Introdução o estudo e sistematização de todos os direitos fundamentais, sua evolução histórica, suas categorias e “gerações”, sendo, nesse passo, pertinente apenas a identificação, estudo e sistematização dos direitos fundamentais processuais.

É certo, contudo, que, de rigor, dois são os aspectos consagrados pela Constituição Federal ligados ao Direito Processual: um deles refere-se à caracterização de determinados direitos processuais como direitos fundamentais; e o outro, à concepção do processo como o método voltado à proteção (garantia) de todos os demais direitos fundamentais consagrados no ordenamento, quer eles se encontrem lesados, quer estejam ainda no plano da mera ameaça.

Com isso se quer dizer que, além de serem direitos fundamentais em si mesmos considerados, os princípios processuais constitucionais funcionam como verdadeiras garantias dos demais direitos fundamentais consagrados pela Constituição, sendo o exercício dos direitos processuais a forma de se buscar, pela via do processo jurisdicional, a proteção de todos os demais direitos fundamentais lesados ou ameaçados.

Estudar e sistematizar os princípios processuais constitucionais, portanto, é identificar e compreender todas as possibilidades de influência destas normas constitucionais sobre todos os atores do sistema jurídico processual, a começar pelo próprio legislador, e obviamente passando pelo juiz, pelas partes e seus advogados e por todos aqueles que de alguma maneira participem da atividade processual.

A caracterização destes princípios como verdadeiros direitos fundamentais traz a reboque algumas consequências jurídicas importantíssimas a que se fará referência nos subitens subsequentes, a começar pelo fato de serem cláusulas pétreas.

b) A natureza de cláusula pétrea dos princípios e garantias processuais constitucionais

A supremacia hierárquica da Constituição Federal não a torna, em todos os seus aspectos, imutável, sendo possível a modificação ou revogação das normas constitucionais.

Ocorre que estas alterações só podem ocorrer por meio de um processo legislativo mais solene e dificultoso do que o existente para edição das demais espécies legislativas, para que sejam capazes de produzir “emendas à Constituição”.

O processo de emenda à Constituição é regulamentado no art. 60 da Constituição Federal e, diferentemente do processo de edição de leis infraconstitucionais, exige uma aprovação, em dois turnos, por uma maioria qualificada em cada uma das duas casas do Congresso Nacional.

Desta forma, o Congresso Nacional, no exercício do denominado Poder Constituinte derivado, pode modificar o texto constitucional.

Ocorre que nem todas as normas da Constituição Federal podem ser alteradas por emendas à Constituição, sendo vedada, nos termos do art. 60, § 4º da Constituição, a proposta de emenda tendente a abolir: a) a forma federativa de Estado; b) o voto direto, secreto, universal e periódico; c) a separação dos Poderes; d) os direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido, uma primeira decorrência da categorização dos princípios processuais constitucionais como direitos fundamentais é elevá-los a categoria de cláusulas pétreas além de inatingíveis pela lei, imutáveis até mesmo por emenda à Constituição.

Nada impede outrossim que sejam adicionados à Constituição outros direitos fundamentais por meio de emendas à Constituição, sendo certo que o intuito da norma instituidora das cláusulas pétreas é evitar que direitos e garantias fundamentais sejam suprimidas ou reduzidas, não acrescentadas

ou ampliadas.

O acréscimo de direitos fundamentais processuais pela via de emenda à Constituição ocorreu, por exemplo, por ocasião da Emenda Constitucional n. 45/2004, que acrescentou no rol de direitos e garantias fundamentais do art. 5º da Constituição o direito a duração razoável do processo.

O contrário, ou seja, a supressão ou limitação de um direito ou garantia processual como o acesso ao Judiciário, contraditório e ampla defesa é absolutamente intolerável pela Constituição Federal, que sequer admite uma proposta de emenda com esta tendência.

c) A dupla dimensão dos princípios processuais constitucionais: as dimensões objetiva e subjetiva

Os princípios processuais constitucionais, como direitos fundamentais, possuem duas dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva.

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais representa o caráter normativo dos princípios constitucionais de servir de imposições legiferantes ou de imposições constitucionais fundamentadoras de um dever concreto de o Estado e poderes públicos dinamizarem, dentro das possibilidades de desenvolvimento econômico e social, a criação de instituições, procedimentos e condições materiais indispensáveis à realização e ao exercício efetivo dos direitos fundamentais¹³¹.

No plano do processo civil, são exemplos da dimensão objetiva dos princípios processuais consagrados na Constituição a necessidade de o Estado manter e colocar à disposição do cidadão uma estrutura judiciária independente, imparcial e subordinada diretamente à Constituição, bem como elaborar, por força dos mesmos comandos constitucionais, um sistema processual dentro dos parâmetros ali estabelecidos e voltados à realização dos valores consagrados constitucionalmente.

Outro exemplo de reflexos da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é o dever do Estado de criar, estruturar e manter a

Defensoria Pública, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, o que implica, em última análise, a concretização do princípio assistência jurídica integral e gratuita consagrada no art. 5º, inc. LXXIV da Constituição Federal.

Já a dimensão subjetiva consiste na aptidão de os direitos fundamentais integrarem o patrimônio jurídico do cidadão, que tem o direito de exigir do Estado a prestação e posturas neles consagrados, constituindo verdadeiros direitos subjetivos públicos.

Na esfera processual, possuem o status de direitos subjetivos públicos e fundamentais, entre outros, o direito consagrado no art. 5º, inc. LIV – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”; no art. 5º, inc. LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”; e no art. 5º, inc. LXXVIII – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, todos da Constituição Federal.

Via de regra, portanto, os princípios processuais constitucionais possuem este duplo caráter, objetivo e subjetivo.

Assim, por exemplo, especificamente sobre o direito constitucional à tutela jurisdicional¹³², o constitucionalista português Joaquim José Gomes Canotilho destaca este duplo aspecto: o primeiro garantístico, de acesso aos tribunais, que retrata a dimensão subjetiva do direito de ação, mas que convive com um segundo aspecto, de dimensão objetiva, nesse caso retratada pelo dever do Estado de criar órgãos judiciários e processos adequados e também de assegurar prestações jurisdicionais tendentes a

evitar a denegação de justiça¹³³.

O mesmo se pode dizer em relação ao princípio do contraditório e ampla defesa que, em sua dimensão objetiva, obriga o legislador a viabilizar seu exercício criando por meio de lei mecanismos processuais capazes de permitir a ampla participação das partes e o exercício da defesa sem qualquer limitação ou condição constitucionalmente intolerável.

Já a dimensão subjetiva do princípio do contraditório e ampla defesa insere na esfera jurídica do cidadão o direito de exigir do Estado o respeito a esta participação e a possibilidade de exercer livremente a defesa ampla.

Isso, somada a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, a seguir comentada, possibilita o exercício do contraditório e ampla defesa, ainda que não haja previsão infraconstitucional específica para a participação da parte em um incidente ou momento processual.

Em outras palavras, o ideal é que o legislador, atingido pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais, seja preciso e completo ao regulamentar tais direitos, possibilitando o exercício de todos os direitos fundamentais que integram, por força da dimensão subjetiva, a esfera jurídica do cidadão. Por outro lado, é certo que tais direitos subjetivos integram o patrimônio jurídico desses sujeitos independentemente desta regulamentação infraconstitucional pelo simples fato de estarem consagrados na Constituição Federal.

d) Os vários destinatários dos princípios processuais constitucionais

Considerando as dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, é correto concluir que os comandos constantes nos princípios processuais constitucionais possuem vários destinatários, produzindo diversos efeitos e devendo ser observados por todos os atores do sistema jurídico processual, a começar pelo legislador, produtor das normas processuais, passando pelos demais operadores do Direito, como

advogados, auxiliares do juízo, além de obviamente pelo próprio magistrado.

Em outras palavras, as normas constitucionais de Direito Processual Civil se destinam ao Poder Legislativo, produtor de normas processuais infraconstitucionais, e ao Poder Judiciário, aplicador do direito, norteando as atividades de interpretação e aplicação das normas processuais.

Nesse contexto, o primeiro destinatário dos princípios processuais constitucionais é o próprio legislador que possui o dever constitucional de estabelecer em lei as regras e procedimentos voltados ao exercício pleno dos direitos e garantias fundamentais constitucionalmente consagradas.

Nesta função, em matéria processual civil, o legislador deve se nortear pelos valores consagrados na Constituição Federal como fundamentais para o modelo constitucional de processo, como também deve procurar moldar o sistema infraconstitucional, de modo a viabilizar a consecução desses valores queridos e determinados pela Carta Constitucional.

Este sistema processual deve ser moldado pelo legislador de uma forma necessariamente equilibrada a ponto de respeitar todos os valores constitucionalmente consagrados, de modo que o desenvolvimento do devido processo legal se dê em tempo razoável, mas sem que se desrespeite o contraditório, a ampla defesa ou qualquer outra norma processual inserida na Constituição, que, a seguir, serão comentadas.

Portanto, é extremamente necessário o recurso ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, em muitos casos, o legislador e o juiz terão de optar por um princípio constitucional processual em detrimento de outro, em razão da situação fática e jurídica apresentada, hipótese em que a escolha deve justificar-se à luz desse princípio, bem como à luz dos demais postulados hermenêuticos constitucionais, sob pena de se esvaziarem o sentido e o conteúdo do modelo constitucional de processo civil.

Além do legislador, um outro importante destinatário dos princípios processuais constitucionais é o juiz, principal responsável pela condução do processo que, nesta função, deve sempre zelar pelo desenvolvimento válido e regular do mesmo.

Portanto, toda a atividade do magistrado no curso do procedimento deve ser orientada pelas normas constitucionais, sendo os valores nela consagrados o verdadeiro norte para o magistrado quando da interpretação e aplicação da lei processual.

Nesse sentido, é clara a influência interpretativa da Constituição, em especial dos princípios constitucionais, na interpretação das leis e normas hierarquicamente inferiores, que deve ser realizada sempre em conformidade com o sistema constitucional, sendo dever do magistrado, sempre que a lei ou norma infraconstitucional permitir interpretações dúbias, optar por aquela que mais se coadune com os princípios constitucionais.

Ademais, em função da capacidade dos princípios constitucionais de integrarem o sistema e preencherem eventuais lacunas normativas do plano infraconstitucional, deve o magistrado, na hipótese de omissão legislativa, valer-se das previsões genéricas constantes dos princípios constitucionais, permitindo, inobstante a omissão legislativa, a fruição e o exercício do direito constitucionalmente garantido.

Por fim, dada a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, os princípios constitucionais possuem como destinatários os próprios titulares dos direitos nele consagrados e seus representantes, isto é, notadamente os cidadãos e seus respectivos advogados.

Por esse motivo, é dever do advogado, como profissional tecnicamente habilitado para representar a parte em juízo e praticar em nome desta os atos processuais voltados à tutela jurisdicional de seus direitos, conhecer, não apenas as regras e procedimentos, como também e sobretudo os

princípios processuais constitucionais.

Esta influência das normas processuais constitucionais na interpretação e aplicação da lei processual é estabelecida já no art. 1º do Código de Processo Civil, que determina que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.

e) A aplicabilidade imediata dos princípios processuais constitucionais

Conforme demonstrado anteriormente, a mera previsão constitucional de direitos e garantias fundamentais genericamente estabelecida na Constituição Federal impõe o dever de o legislador estabelecer em lei mecanismos e procedimentos viabilizadores destes direitos constitucionalmente garantidos.

Assim, a simples previsão constitucional de um direito obriga o legislador a disciplinar e viabilizar o exercício deste direito por meio de lei.

Entretanto, dado o status de direito fundamental dos princípios processuais constitucionais, fato é que os direitos nesta sede consagrados podem ser exercidos ainda que não haja regramento infraconstitucional que o viabilize.

Em outras palavras, a ausência de previsão infraconstitucional de normas reguladoras de uma garantia processual com status constitucional não afasta sua incidência, sendo as garantias processuais, nessa linha, verdadeiras normas de eficácia plena.

Isso porque os princípios processuais, na Constituição Federal, não são meros valores ou pautas ético-valorativas, mas normas de direito positivo, com caráter intencionalmente abstrato, voltados a dar coerência lógica e racionalidade ao ordenamento, no caso o processual.

Portanto, apesar do grau de abstração dos princípios, e de eles não possuírem caráter frontalmente descritivo de comportamento, não se pode negar que sua interpretação pode, mesmo em um nível abstrato, indicar as espécies de comportamento a serem adotadas¹³⁴ e, simultaneamente, vedar determinadas condutas por parte dos sujeitos de direito.

Obviamente, esta aplicabilidade não afasta a necessidade de previsão de regras infraconstitucionais, que são, em grande medida, úteis e importantes para fins de definição dos contornos generalíssimos dos princípios.

Entretanto, a aplicabilidade imediata dos princípios impõe necessidade de observância e concretização dos direitos neles consagrados, independentemente de regramento infraconstitucional, não sendo a ausência de regra infraconstitucional, por si só, um fator capaz de obstar a irradiação de efeitos dos princípios constitucionais.

A conclusão, portanto, deve ser no sentido de que a carga de abstração dos princípios não implica, em hipótese alguma, uma menor carga de eficácia normativa dessas normas.

Nesse contexto, necessária a crítica à doutrina que defende a existência de diferentes cargas de eficácia das normas constitucionais, para a qual existiria entre as normas constitucionais diferentes níveis de aplicabilidade, indo das denominadas normas com eficácia plena e aplicabilidade imediata a normas meramente programáticas¹³⁵.

Não por coincidência, tal doutrina confere às regras constitucionais uma carga de eficácia maior (normas de eficácia plena), dado o caráter mais concreto dessas espécies normativas, o que não pode ser aceito por ser absolutamente contrária à ideia aqui defendida, de que os princípios constitucionais são a base estruturante e fundamental de todo o ordenamento jurídico.

Rigorosamente, o só fato de ser norma fundamental consagrada na Constituição Federal caracteriza um direito subjetivo público exercitável

pelo indivíduo independentemente de lei infraconstitucional, haja vista a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais a que se fez referência no item “c”, supra.

f) A tendência dos princípios constitucionais de entrarem em conflito e a necessidade de solução pela aplicação da proporcionalidade

Ao contrário das normas com estrutura de regra, cujos conflitos resolvem-se por critérios objetivos, hierárquicos, cronológicos e da especialidade, os quais, quando aplicados, determinam a incidência da única norma existente e, portanto, aplicável, o conflito entre princípios “não se resolve com a determinação imediata de prevalência de um princípio sobre o outro, mas é estabelecido em função da ponderação dos princípios colidentes, uma função da qual um deles, em determinadas circunstâncias concretas, recebe a prevalência”¹³⁶.

Essa constatação revela uma das principais características dos princípios, qual seja, a tendência de entrarem em conflito, quer porque inconciliáveis no caso concreto, quer porque, já em abstrato, são antagônicos entre si¹³⁷.

Por via de consequência, essa tendência impõe a necessidade de solução de conflitos entre princípios, o que pode ser realizada pela aplicação da proporcionalidade.

Em outras palavras, atribui-se ao princípio da proporcionalidade o papel de solucionar os conflitos entre direitos fundamentais, sendo especialmente do juiz, à luz do caso concreto, o dever de aplicá-lo, sempre que se mostrar impossível o respeito pleno e concomitante a dois ou mais princípios constitucionais.

Sobre o fundamento jurídico da proporcionalidade, é recorrente na doutrina a busca por sua fundamentação na cláusula do devido processo legal e no próprio princípio da igualdade, temas que serão retomados nos itens 6.1.4.10 e 6.1.4.11, respectivamente.

Dessa forma, é perfeitamente sustentável que o princípio da proporcionalidade encontra-se inserido na fórmula aristotélica da igualdade e, por via de consequência, está consagrado no texto constitucional, pois se traduz na garantia de igualdade por meio do tratamento igual aos iguais, e desigual aos desiguais, na medida (ou na proporção) de suas desigualdades.

A necessidade da proporcionalidade para a correta aplicação e integração do modelo constitucional do processo civil pode ser sentida a partir da clássica lição de Cândido Rangel Dinamarco¹³⁸, para quem é preciso não se ofuscar tanto com o brilho dos princípios, nem ver na obcecada imposição de todos e cada um a chave mágica da justiça como modo infalível de evitar injustiças, pois nenhum princípio é um objetivo em si mesmo e todos eles, em seu conjunto, devem valer como meios de melhor proporcionar um sistema processual justo.

A proporcionalidade, segundo Alexy¹³⁹, possui, na verdade, três máximas parciais: a da adequação, a da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e a da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento de sopesamento propriamente dito).

Na esteira dessa doutrina, Paulo Bonavides¹⁴⁰ esclarece que os três elementos, ou subprincípios que compõem o princípio da proporcionalidade, podem assim ser entendidos: a) a adequação determina que a medida seja suscetível de alcançar seu objetivo; b) a necessidade representa a ideia pela qual a medida não deve exceder os limites indispensáveis à conservação do fim almejado; e c) a proporcionalidade em sentido estrito, ou sopesamento propriamente dito, traduz a ideia pela qual o aplicador deve escolher o meio, dentre os meios adequados e necessários, levando em conta os interesses em jogo.

Adequação, portanto, consiste em uma análise da relação empírica entre o meio e o fim, o que significa que a comparação entre os meios que o legislador, o intérprete ou aplicador do direito terão de escolher terá de se

mostrar a melhor, mais eficiente e mais correta para consecução daquele fim¹⁴¹.

Já o exame da necessidade¹⁴² envolve duas etapas. A primeira, a da "igualdade de adequação de meios", o que implica uma identificação das possíveis formas que, igualmente, viabilizam a consecução da finalidade pretendida. Em seguida, cumpre ao operador identificar o meio "menos restritivo", que se traduz em uma comparação entre a restrição gerada pelo meio escolhido, que deve, entre os meios adequados para o atingimento do objetivo, ser o menos restritivo aos demais direitos fundamentais.

Por fim, a proporcionalidade, em sentido estrito, exige a realização de sopesamento entre o princípio que se pretende realizar em face de seu princípio antagônico¹⁴³, sendo certo que, quanto maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá de ser a importância da satisfação de outro.

Assim, a opção pela diminuição de um prazo processual para algumas horas ou mesmo poucos dias, em detrimento da ampla defesa, a pretexto de prestigiar a duração razoável do processo, não passa sequer pelo crivo da adequação, pois é sabido que a demora na prestação jurisdicional não está diretamente ligada ao estabelecimento de prazos muito longos, mas é, sim, fruto da interposição muitas vezes abusiva de recursos e de incidentes manifestamente infundados, bem como da inércia do mecanismo judiciário nas denominadas etapas mortas do processo, sendo, portanto, a exagerada redução de prazo, uma medida inadequada para os fins a que se propõe.

Já a supressão de um incidente processual ou recurso, por exemplo, pelo fato de seu objeto já ter sido rechaçado inúmeras vezes pela jurisprudência, justifica-se pela ótica da proporcionalidade, tendo em vista que, nesse caso, a indesejável demora excessiva do processo poderá de fato ser combatida, ainda que a custo da relativização, pontual e proporcional da garantia da ampla defesa ou do princípio do duplo grau, nessa hipótese, justificada pela previsibilidade do insucesso do incidente ou recurso.

Inúmeros são os exemplos de sopesamento entre princípios processuais de igual hierarquia constitucional em razão das possibilidades fáticas e jurídicas em determinado processo, muitas das quais a que se fará referência ao longo deste estudo.

Marcelo Magalhães Bonício¹⁴⁴, por exemplo, sopesando os valores processuais abstratamente conflitantes, chega à conclusão, respaldada no princípio da proporcionalidade, de que “não é desejável, por exemplo, que o juiz, a título de exigir um grau de certeza muito elevado para julgar, acabe sacrificando, burocraticamente, o direito material em discussão, isso porque a ele compete julgar diante de um grau razoável de probabilidade, que nunca será propriamente um juízo de certeza”, e adiante conclui: “assim, exacerbar o ônus da prova, injustificadamente, por exemplo, significa também provocar um atraso considerável e desnecessário no andamento do processo”.

Por outro lado, conforme visto no item 4.2.2, “a”, determinadas situações concretas como fornecimento de medicamentos e cirurgia para um sujeito portador de uma doença grave pode ser incompatível com o tempo que naturalmente é necessário para o exercício do contraditório e ampla defesa pela parte contrária.

Tem-se, nestas hipóteses, uma clara situação de conflito entre o princípio do contraditório e ampla defesa, de um lado, e o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional que garante o direito a uma tutela jurisdicional justa e efetiva, de outro lado, que, no caso, seria aniquilado, caso a vida ou a saúde do autor fosse comprometida pelo tempo necessário para o exercício da ampla defesa.

Esta clássica situação de conflito entre o contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional presente nas situações de urgência sempre leva a aplicação do princípio da proporcionalidade, sendo dever do juiz sopesar os valores em jogo, sacrificando, ainda que pontualmente e o mínimo possível, um dos princípios conflitantes.

Nestas hipóteses específicas de urgência, o próprio legislador regulamenta em parte a solução do conflito autorizando a concessão de uma tutela antecipada e provisória, sempre que se revelar ser este o único momento adequado para a efetiva proteção do direito.

Para a concessão da antecipação de tutela, portanto, o juiz deve demonstrar fundamentadamente que se faz necessário o sacrifício de um ou mais princípios, no caso o contraditório e ampla defesa, para que seja atendido um outro, no momento mais importante, a garantia de uma tutela efetiva decorrente do princípio da inafastabilidade.

Ainda assim, vale ressaltar que a aplicação da proporcionalidade nestes e em outros casos não implica absoluto e total desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa dado que a proporcionalidade, conforme afirmado, sugere o mínimo sacrifício possível dos princípios afastados, o que, nas hipóteses de urgência, traduz-se na provisoriedade da medida antecipada e pela possibilidade do exercício do contraditório após a concessão da medida provisória¹⁴⁵.

O art. 8º do Código de Processo Civil estabelece expressamente a necessidade de o juiz, na condução do processo e no julgamento da lide, valer-se da proporcionalidade, entre outros postulados de interpretação e resolução de conflitos entre normas jurídicas ao dispor que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”¹⁴⁶.

6.1.3.2 As diversas funções dos princípios processuais constitucionais no ordenamento jurídico

Considerando tudo o que foi dito até aqui, é correto concluir-se que os princípios processuais dispostos na Constituição Federal exercem múltiplos papéis, pois, a um só tempo, o mesmo comando normativo: a) norteia a

atividade do legislador, quando da elaboração das normas processuais infraconstitucionais, pautando a forma e o conteúdo das leis e demais veículos normativos; b) limita a atuação do legislador e do aplicador do Direito, impedindo a consagração de comandos normativos e a prática de atos processuais contrários aos valores e determinações constantes dos princípios; c) institui, de plano, direitos subjetivos públicos integrantes do patrimônio jurídico do cidadão capazes de, por si sós, estabelecerem deveres do Estado e consagrar direitos das partes, independentemente de regulamentação infraconstitucional; d) orienta o intérprete e aplicador da lei processual, estabelecendo condutas e vedando posturas dos sujeitos do processo.

Nessa esteira, pode-se afirmar que os princípios exercem as funções: a) fundamentadora; b) limitadora; c) supletiva; d) interpretativa.

A função fundamentadora (“a”) dos princípios se traduz na concepção dos princípios como normas chaves do sistema normativo, encabeçando o sistema em grau de positivação, e na aptidão dos princípios de guiarem e fundamentarem todas as demais normas da ordem jurídica¹⁴⁷.

Nesse sentido, a garantia do acesso à Justiça e a promessa de uma assistência Judiciária integral e gratuita, constantes do art. 5º, incs. XXXV e LVII, da Constituição Federal, respectivamente, impõem e fundamentam a atividade do Estado voltada a criar e manter Instituições voltadas não apenas ao recebimento da provocação, isto é, o próprio Judiciário, como também de outras instituições voltadas ao atendimento das promessas constitucionais em sua completude, no caso a Defensoria Pública¹⁴⁸.

Por outro lado, os princípios funcionam como verdadeiros freios da atividade estatal legislativa e judiciária, sendo aos primeiros vedada a edição de normas infraconstitucionais com caráter limitativo ou supressivo de direitos constitucionalmente garantidos fora dos parâmetros admitidos pela própria Constituição, e ao Judiciário vedadas posturas concretas que, no curso do procedimento, impeçam o exercício dos direitos processuais.

Nesse sentido, a função limitadora (“b”) dos princípios impede, por exemplo, a edição de normas infraconstitucionais capazes de restringir ou inviabilizar o exercício dos direitos de ação, consagrado no art. 5º, inc. XXXV, e do contraditório e ampla defesa, constantes do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Leis com esse viés restritivo, em primeiro lugar, não devem ser editadas e, caso editadas em confronto aos princípios constitucionais, deverão ser consideradas inválidas em função da inconstitucionalidade.

A função limitadora dos princípios também se manifesta em relação ao juiz, que, como condutor do processo e destinatário destas normas constitucionais, tem sua atividade cingida pelos comandos constitucionais.

Determinadas posturas e atitudes do magistrado são simplesmente inadmissíveis por força dos princípios constitucionais, sendo, nesta linha, inconcebíveis decisões e condenações proferidas sem o prévio contraditório, restrições ou cerceamento do direito de defesa ou pronunciamentos decisórios desprovidos de motivação, à luz do que determina o art. 5º, inc. LV, e o art. 93, inc. IX, da Constituição, conforme adiante será demonstrado com mais vagar¹⁴⁹.

Os princípios também exercem um importante papel supletivo (“c”) e, nessa medida, contribuem para o preenchimento de lacunas legislativas do sistema processual infraconstitucional.

Entretanto, é bom que se deixe claro que, ao contrário de uma concepção ultrapassada, os princípios não servem à lei, nem funcionam como fonte secundária de baixo grau hierárquico.

De toda forma, na ausência de norma regulamentadora ou mais amplamente na falta de previsão legislativa expressa a respeito do caso concreto, os princípios atuam de uma maneira supletiva, complementando o ordenamento infraconstitucional, cabendo ao operador e aplicador do Direito, na hipótese de omissão legislativa, valer-se das previsões genéricas

constantes dos princípios constitucionais.

Desta feita, se, em determinado incidente processual, a lei deixar de prever expressamente a necessidade de comunicação e possibilidade de manifestação de todas as partes do processo, o juiz deve proceder essa comunicação e franquear a participação das partes pela incidência direta e imediata do princípio do contraditório. Da mesma forma, a despeito do que diga a lei em cada uma das situações processuais possíveis, por força da aplicabilidade imediata do princípio da igualdade, deve o juiz a todo o tempo conceder às partes igualdade de tratamento¹⁵⁰.

Por fim, mas não menos importante, merece destaque a função interpretativa ("d") dos princípios constitucionais.

Interpretar uma norma implica atribuir um significado aos símbolos linguísticos escritos na lei e na própria Constituição, sendo antiga e extensa a discussão e doutrina produzida acerca dos métodos interpretativos.

Certo é que, sobretudo em função da ideia imposta pela interpretação sistemática, os princípios, como normas fundamentais do sistema, exercem grande influência na interpretação dos demais dispositivos normativos.

Assim, além de serem normas e, portanto, carentes em si mesmas de interpretação, os princípios processuais insertos na Constituição Federal cumprem um papel de guia do intérprete e aplicador da lei processual, que deve sempre buscar a interpretação que mais se ajuste aos valores constitucionais inseridos nos princípios.

Nesse sentido, por serem voltadas ao intérprete e aplicador do direito e possuírem uma estrutura normativa aberta¹⁵¹, os princípios processuais na Constituição Federal funcionam como mandamentos de otimização¹⁵² da aplicação da lei e demais normas do sistema processual e possuem, ao contrário das regras, uma dimensão de peso ou importância capaz de auxiliar o agente que vai resolver o conflito que deverá levar em conta a força relativa de cada um, cabendo ao magistrado, no caso de conflito, na

situação concreta, ponderar os valores consagrados nos princípios e encontrar a solução.

É fundamental a influência interpretativa da Constituição, em especial dos princípios constitucionais, na interpretação das leis e normas hierarquicamente inferiores, que deve ser realizada sempre em conformidade com o sistema constitucional.

Tal axioma permite aos órgãos jurisdicionais, a par de declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, neste último caso afastando completamente sua validade, também interpretar a legislação conforme a Constituição, afastando determinada interpretação tida por inconstitucional, sem deixar de aplicar a norma.

A declaração de interpretação conforme a Constituição consiste em delimitar, entre as diversas possibilidades de interpretação da norma, aquela que possui compatibilidade com o texto constitucional, excluindo-se eventuais interpretações em tese possíveis, porém tidas por inconstitucionais.

6.1.4 Normas fundamentais de Direito Processual Civil na Constituição Federal: elenco dos princípios processuais constitucionais

No item precedente, foi feita uma explanação sobre a importância da Constituição Federal para o Direito Processual Civil e a forma com que as normas constitucionais se apresentam, influenciam e moldam o modelo infraconstitucional.

Neste item, serão individualmente identificados e analisados quais são e em que medida os princípios processuais constitucionais exercem essa influência, assim como qual é o alcance e os principais desdobramentos de cada um deles.

Serão estudados, nesta sede, portanto, os contornos genéricos desses princípios, e especialmente os efeitos destas normas na interpretação,

integração e aplicação da lei processual e no desenvolvimento do processo, e, por via de consequência, na atividade das partes e do juízo, assim como na atividade legislativa, isto é, de produção de normas processuais civis infraconstitucionais.

6.1.4.1 Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à Justiça (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal)

O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito e com isso consagra o denominado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Ao se dirigir diretamente ao legislador, o referido dispositivo deixa clara a posição hierarquicamente superior da Constituição Federal e de seus princípios, sendo isso possível, exatamente, por ser a Constituição a única fonte do direito capaz de ditar comandos para o próprio legislador.

O Poder Legislativo, portanto, fica proibido de criar regras jurídicas infraconstitucionais que inviabilizem, dificultem ou restrinjam o acesso ao Poder Judiciário, sendo garantido constitucionalmente o mais amplo e irrestrito acesso à Justiça.

Obviamente, não se quer com isso dizer que todos os pedidos devem ser atendidos pelo Poder Judiciário, pois, muitas vezes, aquele que procura a Justiça não possui razão em seu pleito. Entretanto, é inatingível, inclusive pela lei, o direito do cidadão de procurar e de ser ouvido pelo Poder Judiciário e de obter dele uma resposta, ainda que de improcedência.

O direito de provocar o Poder Judiciário, exigindo do Estado-juiz, por meio do processo, a prestação jurisdicional, é conhecido como direito de ação, isto é, o direito de acionar o Poder Judiciário exigindo a proteção dos direitos lesados ou ameaçados.

O denominado direito de ação constitui um dos pontos mais importantes de uma introdução ao estudo do Direito Processual Civil, e a ele será

dedicado todo o Capítulo 8, ficando, desde já, aqui registrado que o referido direito possui uma proteção constitucional contra restrições ou cerceamento, nos termos do art. 5º, inc. XXXV ora em comento.

A restrição do princípio do acesso à Justiça, pela via da mitigação do direito de ação por meio da lei, seria a mais maléfica supressão de garantia processual, pois de nada valeria um processo justo, célere, e com amplo contraditório garantido, caso fosse possível afastar-se a viabilidade desse processo perfeito a determinadas situações.

Com isso se quer dizer que o princípio em comento constituiu a cláusula de abertura do Direito Processual Civil, impedindo que a atuação jurisdicional seja inviabilizada ou dificultada por qualquer motivo ou por qualquer Poder constituído.

Daí a afirmação de Cândido Rangel Dinamarco¹⁵³ no sentido de que o acesso à Justiça constituiu, a um só tempo, o princípio síntese e o objetivo final do processo, fundamentando e orientando o modo de ser de todas as demais garantias e normas processuais.

Nelson Nery Jr.¹⁵⁴, por sua vez, destaca que, embora o destinatário principal dessa norma seja o legislador, o comando jurisdicional atinge a todos indistintamente, sendo vedado, não apenas ao legislador, mas a todos, impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão.

De fato, um dos principais desdobramentos do princípio da inafastabilidade é dirigido ao Poder Judiciário, que resta obrigado a sempre entregar a prestação jurisdicional, em todos os casos que lhes são apresentados, pois de nada adiantaria abrir as portas do Judiciário em função da norma, se a “saída” não fosse igualmente garantida.

Reflexo disso é a regra estabelecida no art. 140 do Código de Processo Civil, que dispõe que “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico”.

Portanto, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional garante,

a um só tempo, o direito de acesso ao Judiciário e o direito a uma resposta jurisdicional justa, efetiva e em tempo razoável, o que remete obviamente à necessidade de leitura e aplicação do referido princípio a par de outros igualmente integrantes do modelo constitucional de processo civil.

Ademais, considerando que a Constituição prevê a possibilidade de acesso à Justiça na busca para a tutela contra a ameaça a direito, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional também garante constitucionalmente a tutela preventiva, assim entendida a proteção jurisdicional prestada por meio do processo, antes mesmo que a lesão se configure ou se consolide.

A tutela preventiva, apesar de nem sempre poder ser alcançada, sem sombra de dúvidas, constitui a melhor maneira de se prestar jurisdição, servindo, nesse contexto, o processo, para evitar a lesão, impedindo que a ofensa ao direito ocorra.

Muitas vezes aliás, a tutela preventiva é a única forma de se proteger plenamente determinados direitos, tais como os direitos à vida, à saúde, à intimidade e à privacidade que, pela sua natureza e características, demandam uma proteção prévia à efetivação da lesão, sob pena de absoluta ineficácia e inutilidade da tutela após o dano.

Portanto, além de autorizar, de uma maneira irrestrita, o acesso ao Poder Judiciário para reparação de lesões a direito, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, garante a tutela preventiva contra a mera ameaça do direito que se pretender proteger.

6.1.4.2 Princípio do contraditório

O princípio do contraditório é uma garantia constitucional assegurada a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo (art. 5º, LV da Constituição Federal), sendo o mesmo essencial ao próprio conceito de processo.

Historicamente, a doutrina processual sempre tratou o princípio do contraditório como uma garantia às partes de terem conhecimento do processo, bem como de todos os seus atos, somada a possibilidade de as partes poderem reagir aos atos que lhes sejam desfavoráveis, no que se convencionou chamar de binômio “informação/reação” ou “ciência/resistência”, sendo a primeira garantia indispensável ao processo, e a segunda, eventual ou possibilitada¹⁵⁵.

Em tempos atuais, a doutrina vem acrescentando outros elementos ao conceito de contraditório, somando, além da necessidade de informação (ciência) e da possibilidade de reação, as garantias de participação e cooperação, bem como a garantia de consideração judicial.

Nessa linha, Cassio Scarpinella Bueno¹⁵⁶ afirma “que o contraditório, no contexto dos ‘direitos fundamentais’, deve ser entendido como direito de influir, de influenciar na formação da convicção do magistrado ao longo de todo o processo”, e, mais adiante, arremata que “o contraditório deve ser entendido como diálogo, como cooperação”¹⁵⁷.

Nelson Nery Jr.¹⁵⁸, com apoio em doutrina alemã, destaca que o contraditório implica paridade de armas, significando que devem ser dadas as mesmas oportunidades para as partes (Chancengleichheit) e os mesmos instrumentos processuais (Waffengleichheit) “para que possam valer seus direitos e pretensões, ajuizando ação, deduzindo resposta, requerendo e realizando provas, recorrendo das decisões judiciais etc.”.

Cândido Rangel Dinamarco¹⁵⁹, com sua costumeira propriedade, destaca a dupla destinação da garantia do contraditório imposta pela Constituição, pois, a um só tempo, destina-se ao legislador, que deve instituir meios para que as partes participem efetivamente do processo; e ao juiz, que deve franquear esses meios aos litigantes.

Com isso se quer dizer que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório, o legislador deve estabelecer, no sistema processual infraconstitucional, ferramentas e instrumentos processuais capazes de

permitirem às partes e a todos aqueles que, de algum modo, participem do processo o direito de terem ciência, de participarem, de reagirem e, mais amplamente, cooperarem com ele em todas as fases do procedimento.

Ademais, por ter o juiz como destinatário do princípio constitucional do contraditório, obviamente, este possui o dever de promover o diálogo ao longo do processo¹⁶⁰, permitindo a participação e cooperação das partes em todas as fases e incidentes do processo.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 16 do Código de Processo Civil francês, que reza que “o juiz deve, em todas as circunstâncias, fazer observar e observar ele próprio o princípio do contraditório”.

No mesmo sentido, o art. 7º do Código de Processo Civil brasileiro, que dispõe: “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”¹⁶¹.

Ademais, um outro desdobramento do contraditório se revela no dever do juiz de considerar em sua decisão os argumentos e elementos trazidos pelas partes, pois de nada adiantaria dar-se ciência e oportunidades às partes, se o juiz não estiver obrigado a considerá-la.

Esta perspectiva do contraditório, aliás, leva ao estudo a uma outra garantia processual consagrada no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, que estabelece o dever de motivação das decisões judiciais¹⁶².

Nesse sentido, William Santos Ferreira¹⁶³ aduz que “de nada adiantaria o cumprimento das etapas prévias ciência e oportunidade, quando o ato realizado é desconsiderado pelo juiz”, e complementa, “o contraditório não é exclusivamente uma garantia da parte, é um instrumento do sistema concebido para atuar imantado à determinação de que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas”.

Há casos, porém, notadamente naqueles em que a demanda se funda

em um pedido de tutela de urgência, em que a estrita observância do princípio do contraditório pode ensejar ofensa a valores com igual status constitucional, em especial, a inafastabilidade do controle jurisdicional entendido como direito a uma resposta jurisdicional efetiva.

Inúmeros são os exemplos, mas, apenas a título ilustrativo, pode-se imaginar uma situação em que a pretensão do autor é a sua participação como candidato em um concurso público que se realizará dentro de quinze dias em que a entidade organizadora do concurso se nega a autorizar sua inscrição sob um fundamento ilegal.

Nesse caso, o tempo para o esgotamento do contraditório, com ciência, resistência, cooperação e participação, certamente consumiria um tempo superior a quinze dias, o que implicaria a inutilidade da decisão que determinasse a participação do candidato no concurso se este já tivesse sido realizado.

Para que se evite a ofensa à garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, que ficaria caracterizada pelo atraso e inutilidade do provimento jurisdicional, nestas hipóteses, o modo de ser da garantia do contraditório sofre mutação justamente para solucionar o conflito de princípios de igual hierarquia em um caso concreto.

Nesse contexto, portanto, excepcionalmente, admitir-se-á a postergação do contraditório para após a decisão e, muitas vezes, efetivação do comando judicial; a primeira sempre revogável, e a última, em regra, condicionada a reversibilidade fática e jurídica do provimento.

Desta feita, o contraditório constitui um elemento inerente ao processo, de obrigatória observância por imposição constitucional pelo legislador e pelo Judiciário, que, em suma, abarca as garantias de ciência obrigatória pelas partes do processo e dos atos processuais, aliada a uma real e efetiva possibilidade de reação, participação e cooperação a todas as partes interessadas na solução do litígio e ao dever do juiz de levar em consideração os atos praticados ao longo desta participação.

Toda essa atividade decorrente do contraditório deve, via de regra, ser praticada antes do proferimento da decisão judicial admitindo-se excepcionalmente uma decisão anterior ao exercício do contraditório, apenas nos casos em que a decisão tenha de ser proferida prontamente sob pena de inutilidade do provimento jurisdicional, sendo certo que, nestes casos, tal decisão é apenas provisória e o contraditório será exercido posteriormente¹⁶⁴.

6.1.4.3 Princípio da ampla defesa

O mesmo dispositivo constitucional que garante o direito ao contraditório (art. 5º, LV da CF) consagra o princípio da ampla defesa, “com todos os meios e recursos a ela inerentes”.

De certa forma, o direito à ampla defesa pode ser tido como um desdobramento da garantia do contraditório na medida em que este consagra amplamente o direito à reação, ao qual está intimamente ligada a ideia de defesa.

De todo modo, longe de ser maléfica, a previsão genérica e redundante do direito de ampla defesa deve ser vista como um complemento e esclarecimento quanto ao modo de ser da garantia do contraditório.

Em se tratando de direitos e garantias fundamentais, esta redundância sempre é benéfica, pois evita dúvidas e interpretações restritivas e, por outro lado, não implica qualquer defeito ou dificuldade para o intérprete e operador do sistema.

É de se destacar que a Constituição Federal não garante simplesmente o direito de defesa, mas o direito a uma ampla defesa que nos leva à conclusão que não basta, por exemplo, para que o dispositivo constitucional seja atendido, que seja dada à parte uma simples ou limitada possibilidade de manifestação, fazendo-se necessário que a oportunidade prevista em lei e operacionalizada pelo juiz seja apta a efetivamente permitir às partes o exercício deste direito de defesa.

Nesse sentido, o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal estabelece o direito das partes de terem prazos razoáveis para apresentação da defesa e demais manifestações, sendo incompatível com o dispositivo a previsão de prazos tão exíguos que tornem inviável o exercício de uma defesa ampla.

Ademais, também é um desdobramento do princípio da ampla defesa o direito à produção de provas e de participação em toda a atividade probatória.

Esta garantia, que deve ser sempre lida em conjunto com o princípio do contraditório, neste contexto, se traduz na possibilidade de, por exemplo, a parte se manifestar toda vez que for juntado um documento pela parte contrária, ou, sempre que determinada uma perícia judicial, as partes possam dela participar, indicando assistentes técnicos de sua confiança e formulando quesitos para o perito, e sempre que ouvida uma testemunha, ambas as partes possam participar da audiência e formular perguntas durante o depoimento.

Portanto, mais do que indicar ou requerer a realização de provas, o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal consagra o direito da parte de participar e influenciar a atividade de produção voltada à demonstração da verdade dos fatos, sem os quais o direito não pode ser reconhecido pelo juiz.

Entretanto, em que pese a importância das provas para o exercício do direito de defesa garantido constitucionalmente, a própria Constituição Federal estabelece um limite à atividade de produção probatória, ao estabelecer em seu art. 5º, inc. LVI o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas.

6.1.4.4 Princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos

Pelo princípio da vedação das provas obtidas por meios ilícitos, consagrado no art. 5º, inc. LVI da Constituição Federal, "são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos".

Desta feita, para que a prova venha a ser admitida no processo e, portanto, apta a ser apresentada e considerada pelo juiz como meio de demonstração da verdade de um fato controvertido e relevante para o julgamento da lide, a forma de obtenção desta prova deve se dar de acordo com o direito e sem infringência às regras jurídicas.

Portanto, não é dado ao legislador infraconstitucional, nem muito menos ao juiz, no caso concreto, decidir sobre a admissibilidade da prova ilícita sopesando os prós e contras desta admissão, dado que a escolha pela imprestabilidade da prova ilícita foi feita pela Constituição Federal.

O dispositivo, de rigor, protege de uma maneira geral o ordenamento jurídico e impede que o Poder Judiciário compactue com o desrespeito às normas legais ou constitucionais, ao levar em consideração provas obtidas ilicitamente.

A opção contrária à constante no dispositivo em comento levaria a uma conclusão de que os fins (busca de uma proteção jurisdicional justa) justificam os meios (ilicitudes ocasionais durante a produção das provas), o que, em última análise, levaria a um descrédito do próprio ordenamento jurídico e ao estímulo ao descumprimento das leis, sempre que a parte, a pretexto de proteger seu direito discutido em juízo, precisasse transgredir uma regra jurídica para produzir uma prova a seu favor.

Justamente para que se evite esta incoerência, a Constituição Federal optou, de maneira geral e abstrata, por tornar imprestáveis para fins de demonstração da verdade dos fatos as provas obtidas por meios ilícitos.

Por ilicitude da prova deve ser entendida toda a prova que, em seu processo de produção, causou um desrespeito a uma ou mais normas do sistema jurídico.

Inúmeros são os exemplos de provas ilicitamente obtidas, sendo suficientes nesta sede a referência a apenas algumas situações ilustrativas como uma confissão obtida mediante tortura, ou documentos e imagens

obtidas por meio da violação dos sigilos telefônico, de correspondência, à intimidade, ou privacidade, garantidas constitucionalmente.

Obviamente, caso a quebra do sigilo telefônico ou de correspondência se dê dentro dos parâmetros legais, a prova, dado que lícita, deverá ser admitida¹⁶⁵.

Ademais, determinadas provas serão inadmissíveis, mesmo quando obtidas “licitamente”, sempre que restar demonstrado que para a obtenção desta prova “lícita” fora utilizada alguma informação obtida ilicitamente.

Desta feita, qualquer irregularidade ou ilicitude na cadeia de produção da prova contamina todas as demais provas produzidas a partir de uma informação ou procedimento ilícito em sua origem.

William Santos Ferreira¹⁶⁶ oferece um interessante exemplo ao afirmar que, “se um documento é obtido mediante violação de correspondência, e deste são levantados números de contas bancárias e o juiz determina que a instituição financeira apresente os extratos de movimentação nos últimos cinco anos e, mediante a análise dos extratos obtidos, verifica-se que um dos sócios desviou recursos financeiros da empresa, a prova do desvio não poderá ser admitida, pois, se a informação que levou a produção da prova documental foi obtida por meio ilícito, a reposta aos ofícios também o serão”.

Este raciocínio de contaminação da prova é denominado “teoria de frutos da árvore envenenada” e foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 72.588 em que restou decidido que “as provas obtidas por meios ilícitos contaminam as que são exclusivamente delas decorrentes; tornam-se inadmissíveis no processo e não podem ensejar a investigação criminal e, com mais razão, a denúncia, a instrução e o julgamento (CF, art. 5º, LVI) (...)”¹⁶⁷.

A Lei n. 11.690/2008 consagrou, no plano infraconstitucional, este desdobramento do princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por

meios ilícitos, dispondo, em seu art. 157, que: “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais” e que “são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”.

O dispositivo, apesar de constante no Código de Processo Penal, possui aplicação também no processo civil, considerando seu assento constitucional.

Assim, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, o ordenamento jurídico pátrio veda tanto a produção de provas ilícitas, como também não admite as provas lícitas derivadas de informações obtidas por meios ilícitos.

Como decorrência do princípio da vedação das provas obtidas por meios ilícitos é dever do juiz, em primeiro lugar, verificar a licitude da prova e, caso não caracterizada, determinar a sua exclusão dos autos do processo sempre que detectada a ilicitude de sua obtenção.

Portanto, os fatos, a priori, demonstrados como ocorridos pelas provas ilícitas não poderão ser levados em consideração pelo magistrado, salvo se, obviamente, restarem provados por outros meios de prova lícitos constantes do processo.

Entretanto, caso a prova ilícita seja a única capaz de demonstrar a existência do fato controvertido e relevante para o julgamento da causa, por força do art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal o fato terá de ser tido como não provado.

Antes que se pense ser possível a exclusão formal da prova ilícita dos autos do processo sem que isso implique sua desconsideração, vale lembrar que todas decisões judiciais, conforme se verá a seguir, deverão ser motivadas, devendo o juiz demonstrar as razões e as provas que o fez chegar às conclusões sobre os fatos.

Assim, não poderá o magistrado ter como provado um fato cuja única prova foi obtida ilicitamente e por isso excluída dos autos do processo, sendo possível esse controle, pela parte, por força do princípio da motivação das decisões judiciais, estudado na sequência.

6.1.4.5 Princípio da motivação das decisões judiciais

A Constituição Federal, em seu art. 93, inc. IX, dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, “e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”, consagrando, dessa feita, o princípio da motivação das decisões judiciais.

Nelson Nery Jr.¹⁶⁸ afirma que “fundamentar significa o magistrado dar razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira”.

O mesmo doutrinador complementa afirmando que a exigência de fundamentação ditada pela Constituição possui uma implicação substancial, e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas ao seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão e conclui que não podem ser consideradas “substancialmente” fundamentadas as decisões que afirmam que, “segundo os documentos e as testemunhas ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo pelo qual julgo procedente o pedido”¹⁶⁹.

Portanto, é garantido, pela Constituição Federal, não apenas que a decisão judicial seja motivada, mas também que esses motivos sejam claros, coerentes e suficientes, sob pena de nulidade da decisão¹⁷⁰.

Esta completude e suficiência da motivação das decisões judiciais é exigida pela Constituição Federal em dois aspectos: a fundamentação de fato e a fundamentação jurídica (de direito).

As questões de fato dizem respeito às situações e eventos cuja real ocorrência seja capaz de influenciar diretamente a decisão jurisdicional, devendo sua existência ser provada nos autos do processo.

Desta feita, todos os fatos relevantes e controvertidos, assim entendidos os alegados pelas partes e tidos pelo juiz como fundamentais para a solução do litígio, devem ser trazidos para o processo e demonstrados para o juiz por meio da atividade probatória¹⁷¹.

É indispensável que sejam exatamente estas provas, constantes dos autos do processo, as levadas em consideração pelo magistrado ao fundamentar a ocorrência ou inoccorrência de um determinado fato arguido pela parte e contestado pela outra.

Por essa razão, é corrente na doutrina e no dia a dia do foro a expressão, “o que não está nos autos não está no mundo”, que significa, portanto, que apenas aquilo que conste do processo e que tenha sido nele produzido pode ser levado em consideração pelo magistrado para fundamentar sua decisão.

Ao contrário de uma mera formalidade ou exigência formalista, a adstrição do juiz às provas produzidas durante o procedimento e constantes dos autos do processo é uma garantia de preservação da imparcialidade do magistrado e uma forma de se verificar a observância e o respeito ao contraditório e à ampla defesa exercidos pelas partes.

Assim, o juiz, ao fundamentar sua decisão, deverá afirmar qual das versões dos fatos trazidos pelas partes é verdadeira e, mais do que isso, demonstrar o porquê de serem estas as conclusões realizadas, à luz do conjunto probatório constante dos autos do processo.

Tal conclusão é reafirmada no plano infraconstitucional, pois o art. 371 do Código de Processo Civil, que complementa o princípio da motivação das decisões judiciais, estabelece a vinculação do juiz ao material probatório constante dos autos do processo, dispondo que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A doutrina, a partir desta disposição legislativa, alude ao princípio do convencimento motivado, segundo o qual, o magistrado pode apreciar a

prova e decidir, fundamentadamente e à luz dos elementos constantes dos autos do processo, sobre as questões de fato específicas e relevantes para cada processo.

O convencimento motivado combate o que poderia ser denominado como sistema de tarifamento da prova, segundo o qual cada meio de prova teria um valor preestabelecido de uma maneira geral e abstrata pela lei, o que, certamente, levaria a artificialismos e injustiças no caso concreto.

Por esses motivos, a opção do sistema processual é no sentido de que o juiz seja livre para apreciar as provas e tirar suas próprias conclusões sobre os fatos, desde que se atenha ao conjunto probatório constante nos autos do processo e cumpra a exigência constitucional de demonstrar fundamentadamente as razões de sua conclusão.

Além da fundamentação concernente às questões de fato, a partir do quadro fático-probatório, é dever constitucional do magistrado fundamentar juridicamente sua decisão judicial.

Nesse sentido, o art. 93, inc. IX da Constituição Federal impõe ao juiz o dever de explicitar o porquê da incidência de determinadas regras jurídicas que, segundo seu entendimento, são aplicáveis ao caso concreto, explicitando, ademais, o sentido, o alcance e a interpretação dos dispositivos utilizados como fundamentadores da decisão.

Além disso, por força da perspectiva do contraditório no sentido de ser direito subjetivo da parte ter suas manifestações, alegações e razões levadas em consideração pelo juiz, a atividade das partes ao longo do processo, em grande medida, pauta a extensão e o conteúdo da motivação das decisões judiciais.

Assim, a natureza e o fundamento do pedido, da defesa e demais manifestações das partes deverão ser consideradas, analisadas e justificadamente acolhidas ou rejeitadas pelo magistrado, devendo toda esta explicação constar da decisão judicial, sob pena de nulidade.

Por essa razão, a suficiência e a legitimidade da fundamentação devem ser medidas a partir do teor das alegações de fato e de direito produzido pelas partes ao longo do procedimento.

Em outras palavras, integra o dever de motivação a necessidade de o magistrado fundamentadamente afastar os argumentos jurídicos trazidos pelas partes com os quais não concorde ou entenda como inaplicáveis ao caso, sempre justificando os motivos do afastamento.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, dispõe que: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Sobre o tema Fredie Didier Jr.¹⁷², ao comentar o referido dispositivo, sustenta que “embora seu conteúdo já pudesse ser extraído do dever de fundamentar que decorre da Constituição Federal, é bastante salutar que algumas hipóteses em que se considera não fundamentada a decisão estejam previstas no texto legal. Isso permite um controle, mais efetivo dos pronunciamentos judiciais, reduzindo a margem de subjetividade quanto à percepção do que é e do que não é uma decisão fundamentada”.

Portanto, integra o dever de motivação das decisões judiciais a obrigação

do juiz de fundamentar fática e juridicamente as razões que levaram a conclusão, ao que se soma a necessidade de contra-argumentar as demais razões jurídicas trazidas pelas partes que, segundo o magistrado, não são pertinentes ou aplicáveis ao caso concreto, bem como correlacionar estas razões de fato e de direito àquilo que concretamente foi produzido no curso do processo e consta de seus autos.

Assim, se, de um lado, o juiz não é obrigado a acolher todas as alegações das partes, o que inclusive seria logicamente impossível, de outro, ele possui o dever constitucional de levar em consideração todos os argumentos por elas deduzidos e respondê-los, justificando os motivos jurídicos de seu não acolhimento.

É a própria Constituição Federal que estabelece a consequência da ausência de motivação completa e suficiente da decisão judicial, taxando-a de nula.

Portanto, a par de ser um comando claro e direto para o magistrado, a ausência de fundamentação das decisões gera uma consequência seriíssima para o processo, ou mais precisamente, para a decisão judicial não fundamentada, qual seja, a nulidade.

Tal nulidade pode ser combatida pela parte prejudicada pela ausência de fundamentação da decisão por meio do recurso de embargos de declaração previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil¹⁷³, cuja análise escapa ao objeto desta Introdução.

De toda sorte, fica aqui asseverado que a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão judicial e que esta nulidade pode ser corrigida pela via recursal, notadamente por meio dos embargos de declaração.

6.1.4.6 Princípio da publicidade

O princípio da publicidade é garantido pela Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, que dispõe que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Portanto, via de regra, a existência e os elementos integrantes de um processo, tais como seus participantes, seu objeto e demais informações, não são dados sigilosos ou de acesso restrito apenas às partes do litígio, seus advogados e servidores do Judiciário, mas abertos e acessíveis ao público em geral.

Em outras palavras, qualquer cidadão interessado pode obter informações e dados acerca dos processos existentes, independentemente de demonstração de interesse jurídico direto ou de ser parte no processo, pelo simples fato de a publicidade do processo ser garantida constitucionalmente.

Assim, a regra geral é a publicidade do processo, verdadeiro desdobramento do princípio democrático, pois, conforme aduz Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz¹⁷⁴, “a publicidade é princípio essencial ao sistema processual democrático. Em face de seu caráter público, o processo não pode ter nada a esconder. Garante às partes uma participação efetiva no processo, obrigando poder estatal a prestar contas de seus atos à sociedade que, por sua vez, conhecerá as decisões dos juízes, fiscalizando-os (...)”.

São decorrências diretas desta garantia: a) a livre consulta dos autos e documentos do processo; b) o livre acesso a audiências que devem ser realizadas “às portas abertas”; c) a publicidade e o livre acesso às sessões de julgamento dos recursos e demais ações nos tribunais; d) a livre consulta, física ou on-line, dos resultados dos julgamentos e das demais decisões dos tribunais e juízes, e até mesmo; e) a transmissão televisiva ou por meio da internet das atividades dos órgãos jurisdicionais como é o caso da transmissão via TV Justiça¹⁷⁵.

Todavia, a publicidade do processo, tal como genericamente prevista no dispositivo em comento, em determinadas situações, pode violar outros direitos e garantias igualmente constitucionais, como a proteção à intimidade, à privacidade e à imagem, também garantidas pela Constituição Federal¹⁷⁶.

Nessas situações, o art. 5º, inc. LX, da Constituição Federal dispõe que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” ao passo que o 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece que poderá “a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Desta feita, a publicidade do processo e dos atos processuais só cede lugar nas hipóteses em que outros princípios e garantias constitucionais fiquem suprimidos ou injustificadamente ameaçados pela publicização do processo, uma clara demonstração de aplicação do princípio da proporcionalidade pela própria Constituição Federal¹⁷⁷.

Concretizando a referida limitação constitucional, o art. 189 do Código de Processo Civil estabelece situações em que, segundo a lei, a ofensa à privacidade e intimidade, protegida pela Constituição, ocorrerá caso o processo seja público, como nas de ações que envolvam questões de estado, divórcio, alimentos ou poder familiar.

Ademais, o inc. I do dispositivo se vale de um conceito jurídico indeterminado, dando certa margem para que o juiz restrinja a publicidade por razões de interesse social.

É de se ressaltar que, mesmo nas hipóteses em que o princípio da publicidade não possui incidência plena, por voltar-se a preservar outros valores, ainda assim não se está admitindo processos ou sessões de julgamentos secretos.

Isso porque, mesmo quando restringida a publicidade, resta garantido o acesso ao processo, às partes e a seus respectivos advogados, não tendo sido acolhidos pelo sistema constitucional de 1988, por exemplo, dispositivos regimentais de tribunais que previam sessões secretas.

Igualmente, qualquer dispositivo nesse sentido, ainda que introduzido por lei ou mesmo por Emenda à Constituição, não encontra amparo no sistema constitucional, sendo sempre garantido, se não a ampla publicidade, o conhecimento dos termos do processo e da sessão de julgamento pelas partes interessadas e seus representantes.

O princípio da publicidade, ademais, é reafirmado no art. 11 do Código de Processo Civil, dentro portanto do capítulo dedicado às normas fundamentais.

6.1.4.7 Princípio do juiz natural e da vedação de tribunais de exceção

A Constituição Federal, no art. 5º, inc. LIII, dispõe que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” e, dessa forma, consagra o princípio do juiz natural.

O dispositivo é complementado e densificado pela própria Constituição, que dispõe em seu art. 5º, inc. XXXVII, que “não haverá juízo ou tribunal de exceção”.

Tais normas, em síntese, garantem que: a) todos têm direito de se submeter ao julgamento por juiz competente, assim entendido o juiz constituído na forma da lei; b) todos têm o direito de ser julgados por um juiz imparcial; c) ninguém será processado por tribunal de exceção, assim entendido o juízo ou tribunal constituído após o fato; d) é vedada a escolha do juiz pelo autor ou qualquer sujeito.

Por essas razões, faz-se necessária a investigação das normas de competência insertas na legislação, a começar pela própria Constituição Federal, pois será considerado como juiz natural “aquele que a Constituição indicar como competente ou, quando menos, quando ela, a Constituição

Federal, permitir que o seja”¹⁷⁸, o que remete o operador do Direito a uma análise da legislação infraconstitucional de organização judiciária e repartição de competências, tema que será retomado no capítulo 15 desta obra.

A repartição de competência se faz necessária em função da existência de diversos órgãos jurisdicionais, tema já enfrentado no Capítulo 5, sendo certo que cada um destes órgãos atua em uma determinada espécie de litígio nos termos dos critérios estabelecidos pela lei e pela Constituição.

Vários são os critérios utilizados pelas normas de repartição de competência, sendo os principais: a) a matéria que está sendo discutida no processo; b) as pessoas que integram a lide; c) a função exercida pelo órgão jurisdicional; d) o domicílio das partes; e e) o valor da causa, sendo a combinação destes critérios a forma de se determinar o juiz natural da causa¹⁷⁹.

A desobediência a estas normas implica uma ofensa ao princípio constitucional do juiz natural.

Ademais, considerando que o princípio do juiz natural impede a escolha do juiz pelas partes, caso a aplicação dos diversos critérios de repartição de competência aponte para mais de um juízo competente para julgar a causa, impõe-se a necessidade de uma distribuição do feito por sorteio.

Isso ocorre, sobretudo, em grandes centros onde há mais de um juízo com a mesma competência para determinada matéria (várias varas cíveis, várias varas de família, várias varas previdenciárias), hipótese em que o princípio do juiz natural impõe a distribuição por sorteio que determinará, enfim, qual dos órgãos competentes conduzirá o processo e julgará a lide.

O princípio do juiz natural possui um outro desdobramento que inclusive é densificado na Constituição Federal, que, em seu art. 5º, inc. XXXVII, veda os denominados tribunais de exceção.

Por tribunais de exceção devem ser entendidos os órgãos jurisdicionais

criados após os fatos e acontecimentos que serão considerados por ocasião do julgamento, ou seja, juízos até então inexistentes que passam a existir como intuito de julgar litígios já configurados.

Tais tribunais de exceção são expressamente vedados pela Constituição Federal e, portanto, não podem ser criados pelo legislador, e, caso criados, nulos seriam seus pronunciamentos e decisões sobre fatos e eventos já ocorridos.

Portanto, só pode ser considerado juiz natural e único juízo legitimado para processar e julgar a causa aquele que: a) já tenha sido criado e estabelecido antes da configuração do litígio e da ocorrência dos eventos relevantes para o julgamento; b) possua, previamente, nos termos da lei que os criou e estabeleceu suas funções, competência para julgar a lide.

A par de estabelecer a necessidade de existência prévia de um juízo competente, o princípio do juiz natural também garante a todos o direito de ser processado e julgado por um juiz imparcial, assim entendido o juiz que não tenha qualquer interesse na causa e não possua nenhuma relação com as partes litigantes.

Isso porque qualquer relação com as partes ou interesse no resultado do processo compromete, ou pode comprometer, a capacidade do juiz de conduzir o processo e julgar o litígio de uma maneira justa e conforme o Direito.

Concretizando este desdobramento do juiz natural, os arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil arrolam circunstâncias em que o magistrado é considerado impedido ou suspeito, sendo ambas as situações comprometedoras da imparcialidade do juiz.

A distinção entre o impedimento e suspeição pode ser feita à luz de dois critérios: a) o grau de comprometimento da imparcialidade; e b) a objetividade (ou subjetividade) para sua caracterização.

Nesse sentido, é correto afirmar que as situações tidas pela lei como de

impedimento são vícios mais graves e de objetiva caracterização, ao passo que as situações de suspeição são vícios, até certo ponto, menos graves e, sobretudo, de mais difícil caracterização, dado serem circunstâncias mais subjetivas.

Assim, o art. 144 do Código de Processo Civil considera impedido de exercer suas funções o juiz no processo: “I – em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II – de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III – quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V – quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI – quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII – em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII – em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado”.

Todos os casos de impedimento, cujo exame pormenorizado escapa ao objeto deste item, são fatos objetivamente constatáveis e cuja caracterização prescinde de maiores interpretações e subjetividades.

Já as hipóteses de suspeição, estabelecidas no art. 145 do Código, são menos objetivas, dado que estabelecem situações um pouco mais fluidas e subjetivas.

Isso porque o art. 145 do CPC considera suspeito o juiz: “I – que for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.

Algumas hipóteses de suspeição, se comparadas às hipóteses de impedimento, permitem maior margem de subjetividade, especialmente a caracterização da amizade íntima, inimizade e interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes.

Por outro lado, cumpre ressaltar que algumas causas caracterizadoras de suspeição são objetivamente constatáveis, tais como ser credor ou devedor de uma das partes (art. 145, III), o que facilita sobremaneira a caracterização desta qualidade.

Apesar desta distinção, o processamento e julgamento da causa por juiz suspeito ou impedido são igualmente vedados pelo princípio constitucional do juiz natural, sobretudo, porque o juiz suspeito, tal como o impedido, por possuir relação com uma das partes ou com o objeto litigioso, passa a não ter a necessária imparcialidade constitucionalmente exigida.

Por esse motivo, o primeiro fiscal de sua imparcialidade é o próprio juiz que, verificando ser, nos termos da lei, suspeito ou impedido, deve, imediatamente e independentemente de provocação, afastar-se do processo e encaminhá-lo ao seu substituto legal.

Caso o juiz não se autodeclare suspeito ou impedido, e a parte venha a ter ciência da situação comprometedora da imparcialidade, esta também possui, como maior interessada em ser processada e julgada por um juiz imparcial, o direito de provocar a declaração de impedimento ou suspeição.

A arguição de impedimento ou suspeição é prevista no art. 146 do Código de Processo Civil, e seus desdobramentos procedimentais escapam ao objetivo deste item.

Ademais, deve ser ressaltado que, ainda que não declarado pelo juiz e não oposta a exceção pelas partes, a condução do processo por um juiz suspeito ou impedido, ou mais amplamente, interessado no julgamento da causa, por ofender ao princípio do juiz natural, pode ser decretado em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo nulas as decisões proferidas por um juiz com a parcialidade comprometida.

6.1.4.8 Princípio do duplo grau de jurisdição

É da natureza do ser humano o inconformismo com as decisões contrárias aos seus interesses, sobretudo nas situações postas em juízo que, dado o caráter, imperativo e definitivo da jurisdição, resolve, de forma impositiva, as mais diversas situações da vida e patrimônio das pessoas.

A par disso, o juiz, como ser humano, também carrega outra característica humana, tão comum quanto o inconformismo, a falibilidade.

Portanto, enquanto um sistema operado por seres humanos, falíveis por definição e dirigidos a outros seres humanos com forte tendência a não se conformarem com a decisão contrária a seus interesses, o Direito Processual Civil estabelece a possibilidade de interposição de recursos contra as decisões judiciais.

Os recursos, portanto, são os instrumentos processuais que viabilizam a revisão e eventual reforma ou cassação de uma decisão judicial.

Para que seja possível este sistema de revisão, o Poder Judiciário se organiza em diversos graus de jurisdição, sendo o primeiro grau de jurisdição aquele em que o juiz tem o primeiro contato com a causa, com o pedido, com as provas e com a defesa, para, ao final, proferir a primeira decisão.

A estrutura do Poder Judiciário¹⁸⁰, detalhada no Capítulo 5 supra, estabelece que o primeiro grau de jurisdição é exercido por juízes que, monocraticamente, conduzem o processo e proferem a decisão.

Os recursos, como dito, viabilizam a revisão desta decisão de primeiro grau, proferida pelos juízes, pelos tribunais, órgãos jurisdicionais de segundo grau de jurisdição.

Assim, caso a parte inconformada recorra da decisão de primeiro grau, o recurso interposto será processado e julgado por um outro órgão, também integrante da estrutura do Poder Judiciário, e hierarquicamente superiores aos juízes de primeiro grau, denominados tribunais.

Os tribunais são os órgãos jurisdicionais de segundo grau de jurisdição que, como regra, exercem a denominada competência recursal.

O princípio do duplo grau de jurisdição deve ser entendido como a garantia de sujeição de determinada decisão judicial à revisão por outro órgão integrante do Poder Judiciário, pela via recursal.

Em outras palavras, o princípio do duplo grau de jurisdição garante o direito de a parte de recorrer para os tribunais contra as decisões que lhes sejam desfavoráveis.

Ocorre que a Constituição Federal não dispõe de um artigo ou mesmo inciso que declare expressamente que “todos os litigantes possuem o direito de recorrer” ou que “a todos é garantido o duplo grau de jurisdição”, o que não quer dizer que direito ao duplo grau de jurisdição não seja constitucionalmente garantido.

Isso porque, apesar da ausência de uma norma expressa que garanta tal direito, é a Constituição Federal que prevê a existência dos tribunais e atribui a estes órgãos jurisdicionais a competência para processar e julgar os recursos.

Assim, de maneira indireta, está consagrado na Constituição Federal o direito das partes de recorrerem contra as decisões judiciais que lhes são

desfavoráveis aos tribunais de segundo grau previstos constitucionalmente.

Em suma, o princípio do duplo grau de jurisdição, apesar de não estar expresso na Constituição Federal, deve ser tido como integrante do modelo constitucional de processo civil em função das regras de criação e atribuição de competências, especialmente de tribunais, em que estão previstas inúmeras hipóteses de competência recursal, ex vi arts. 108, inc. II¹⁸¹, 102, inc. II¹⁸², e 105, inc. II¹⁸³, da Constituição.

Assim, apesar da não consagração expressa da garantia de revisão da decisão pelo Poder Judiciário como um direito de todos os litigantes, o princípio do duplo grau de jurisdição está, implicitamente, consagrado pelo texto constitucional.

Entretanto, pela ausência de norma constitucional que consagre expressamente o direito de recorrer aos tribunais em todas as situações, o princípio do duplo grau de jurisdição comporta algumas mitigações¹⁸⁴.

Tais mitigações são estabelecidas pela lei e pela própria Constituição Federal, devendo sempre serem vistas como hipóteses excepcionais.

Três são as formas de mitigação do princípio do duplo grau de jurisdição: a) a vedação pura e simples do direito de recorrer; b) a previsão de cabimento de um recurso para o mesmo órgão jurisdicional prolator da decisão atacada, e não para um outro órgão de hierarquia superior; c) a previsão de cabimento dos recursos para outro órgão jurisdicional que não os tribunais de segundo grau.

A primeira limitação, de não cabimento de recurso contra determinada decisão judicial, é prevista pela própria Constituição Federal, quando estabelece algumas causas que devem ser julgadas originariamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I da CF), em que o órgão máximo da estrutura judiciária brasileira excepcionalmente exerce o primeiro grau de jurisdição.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal é órgão jurisdicional da

mais alta hierarquia, não havendo, portanto, nenhum juízo ou tribunal acima dele, contra a decisão do STF, ainda que proferida em primeiro grau de jurisdição, não cabe recurso, a não ser embargos de declaração que serão julgados pelo próprio Supremo com a finalidade de esclarecer ou integrar a decisão proferida.

É certo, contudo, que o processamento e julgamento de causa pelo Supremo Tribunal Federal como órgão de primeiro grau de jurisdição, que é excepcionalíssima e apenas admitida quando expressamente prevista no texto constitucional, fugindo, portanto, das situações comuns.

Outra forma de mitigação do princípio do duplo grau de jurisdição é a previsão de um recurso dirigido ao mesmo órgão prolator da decisão, em vez de um órgão de hierarquia superior.

Tal situação também é excepcionalíssima, mas é prevista, por exemplo, no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830 de 1980), que, para a causa de valores inferiores a 50 OTNs, sujeita à revisão pelo mesmo juízo prolator da decisão impugnada.

Ao analisar este dispositivo, a doutrina chega à conclusão de que o princípio do duplo grau não é uma garantia absoluta, e, portanto, possível de ser restringido ou afastado pela lei em algumas situações¹⁸⁵ não se fazendo necessário que a decisão seja revista por um órgão jurisdicional diferente do prolator da decisão, ou mesmo de jurisdição superior.

Assim, se, de um lado, a previsão excepcionalíssima de cabimento de recurso apenas para o mesmo órgão prolator da decisão recorrida mitiga o princípio do duplo grau de jurisdição, tal mitigação não chega ao ponto de tornar a lei, de plano, inconstitucional, dado que tal princípio, apesar de consagrado implicitamente no texto constitucional, não é absoluto.

Uma outra forma de mitigação é a previsão de cabimento de um recurso, que, porém, será julgado por um outro órgão jurisdicional que não exatamente os tribunais de segundo grau previstos na Constituição Federal.

Esta exceção pode ser verificada nos procedimentos dos juizados especiais, órgãos jurisdicionais com competência para causas de menor complexidade e de baixo valor¹⁸⁶.

Nesses casos, o recurso cabível contra a decisão do juiz de um juizado especial será apreciado por uma turma recursal, também composta de juízes, órgão que não faz parte da estrutura do tribunal de segundo grau.

De toda forma, ainda que não haja um julgamento por um tribunal de segundo grau, é correto concluir que o princípio do duplo grau de jurisdição foi, ainda que de uma forma mitigada, atendido, dado ter sido possível a parte questionar a decisão judicial pela via recursal.

Apesar destas três exceções, é preciso se ter em mente que, na maioria esmagadora das situações processuais, as partes têm o direito constitucional de recorrer aos tribunais de segundo grau com o intuito de questionarem e buscarem a modificação ou anulação da decisão judicial, sendo o cabimento de recursos a regra geral por força do princípio do duplo grau de jurisdição.

6.1.4.9 Princípio da duração razoável do processo

Remonta a Chiovenda a ideia de que o tempo é um mal necessário ao processo, e que demoras injustificadas do procedimento devem ser combatidas, haja vista que justiça tardia, por definição, é justiça falha.

Assim, para que se alcancem plenamente os objetivos do processo, a tutela jurisdicional deve ser prestada dentro de um procedimento que não dure além do tempo necessário para a solução da lide.

Nesse contexto, a Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu o inc. LXXVIII ao art. 5º da Constituição Federal, que dispõe: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Entretanto, é certo que, entre nós, o direito à duração razoável do

processo é reconhecido como um direito fundamental processual muito antes da citada reforma constitucional.

Luiz Guilherme Marinoni¹⁸⁷, por exemplo, sustenta que “o art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal, embora afirme apenas que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, garante a tempestividade da tutela jurisdicional” e prossegue: “para deixar expresso que o Estado tem o dever de prestar a justiça em prazo razoável e o cidadão tem o direito de obter a tutela jurisdicional de modo tempestivo, a Emenda Constitucional n. 45/2004 agregou ao art. 5º inciso que institui o direito fundamental à duração razoável do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Marcelo Bonicio¹⁸⁸, por sua vez, aduz que a duração razoável, antes de sua previsão expressa no texto constitucional, encontrava respaldo normativo no princípio no devido processo legal, dada a vocação supletiva desse princípio.

O mesmo autor¹⁸⁹, com apoio na lição de José Rogério Cruz e Tucci, salienta que, por meio de uma interpretação sistemática, a partir do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, a duração razoável do processo já se encontrava positivada no ordenamento jurídico brasileiro desde a adesão do Brasil ao Pacto de San Jose da Costa Rica, que, em seu art. 8º, inc. 1, consagra que toda pessoa tem direito a ser ouvida, no processo, dentro de um prazo razoável.

De toda forma, a adição do inc. LXVIII ao rol de direitos individuais do art. 5º da Constituição Federal deixa clara a consagração do direito fundamental a razoável duração do processo.

Vários elementos são capazes de contribuir para a duração do processo, em especial: a) o arcabouço normativo, ou seja, o sistema processual positivado em lei; b) a estrutura do Poder Judiciário; c) a complexidade do assunto posto em juízo; d) o comportamento dos litigantes; e) a atuação do órgão jurisdicional na condução do processo e no proferimento da decisão

judicial.

Em função destas variáveis, não cabe à lei, à doutrina ou à jurisprudência definir de uma forma objetiva a quantidade de dias, semanas ou meses de duração de um processo, pois, na verdade, o tempo do processo e a própria concepção do que seja uma duração razoável podem variar em função destes fatores.

A complexidade da causa pode ser oriunda de questões fático-probatórias, em que obviamente o tempo de duração razoável do processo deve ser aquele exigido para a produção de todas as provas necessárias para esclarecer os fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da causa.

Não se pode, por exemplo, a pretexto de se acelerar o procedimento e encurtar o processo, impedir a produção de provas pelas partes, o que violaria o princípio da ampla defesa.

Entretanto, caso a matéria de fato não seja controvertida, ou seja, de fácil esclarecimento, sem que se fale em violação ao contraditório e à ampla defesa, pode-se ter um processo mais célere.

Além disso, a complexidade da causa pode ser eminentemente jurídica, assim entendida aquelas em que, não obstante a clareza dos fatos relevantes, a solução a ser encontrada demanda análise mais profunda da doutrina, jurisprudência e normas jurídicas em geral e até mesmo maior reflexão pelo magistrado.

Nestas hipóteses, a duração razoável do processo está ligada ao tempo necessário para que as partes apresentem suas razões e o magistrado investigue e interprete as normas integrantes do sistema jurídico aplicável ao caso, aí incluída a pesquisa de correntes doutrinárias e os posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

Por essa razão, é perfeitamente compreensível que um processo que veicule uma tese jurídica complexa ou nova, porque novo o texto da lei ou o

pleito do autor, tenha um tempo de maturação e, por via de consequência, uma duração maior do que um processo que veicule uma tese simples ou repetidas vezes já proposta e julgada pelo Poder Judiciário e, quiçá, pelo próprio magistrado.

Nesse contexto, a jurisprudência e os precedentes judiciais, como fontes do direito, podem influenciar não apenas no conteúdo da decisão, como também na duração do processo, contribuindo para a aceleração do procedimento a partir da aplicação de uma tese previamente pacificada pela jurisprudência.

Assim, sob o aspecto do grau de complexidade, certo é que a natureza da causa e as atividades que precisarão ser desenvolvidas no processo influenciam diretamente em sua duração, sendo plenamente razoável que um processo dure mais de um ano em função da necessidade de ampla instrução probatória, com oitiva de várias testemunhas e realização de mais de uma perícia, mas sendo inadmissível, à luz do princípio da duração razoável, que um processo simples sem nenhuma complexidade, jurídica ou probatória, dure tempo idêntico.

De rigor, o que o princípio da duração razoável do processo não tolera é o desperdício de atividade processual e a mera paralisação ou interrupção do curso do processo sem que haja uma justificativa ou razão para tanto, algo que infelizmente acontece na realidade do foro, mas que é vedado pela Constituição Federal.

Também é possível que a atividade das partes influencie diretamente na duração do processo, pelo simples motivo que qualquer manifestação ou produção de prova demanda uma atividade processual, como a oitiva da parte contrária por força do contraditório, a consideração e análise pelo juiz, e demais providências, e, portanto, consuma tempo.

Assim, a atividade das partes, quando inúteis ou desnecessárias e, portanto, injustificadamente perniciosas à duração razoável do processo, devem ser tidas como uma ameaça à duração razoável do processo e

passíveis de caracterização como litigância de má-fé¹⁹⁰.

Nesse sentido, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil dá ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias requeridas pela parte, ao passo que os arts. 77, inc. II, e 80, incs. VI e VII, entre outros do Código de Processo Civil, autorizam o juiz a punir a parte litigante de má-fé.

Ademais, a atividade das partes pode ser limitada pela vinculação ao entendimento jurisprudencial ou mesmo pela força emprestada à jurisprudência consolidada, que são capazes de justificar a perda do direito de praticar atos processuais contrários ao entendimento pacificado, ou seja, com a proibição de propositura de incidentes ou interposição de recursos inúteis ou desnecessários.

Em outras palavras, a utilização de argumentos de defesa já anteriormente rechaçados pela jurisprudência pode caracterizar abuso de direito de defesa, que, nos termos do art. 311, inc. I, do Código de Processo Civil, autoriza concessão da tutela de evidência, o que, se não entrega definitivamente a prestação jurisdicional, por se tratar de uma medida provisória e sujeita a confirmação, contribui para a efetividade do processo.

Em suma, a atividade das partes, em prol de uma duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, deve ser, não só estimulada, como também controlada pelo juiz, cabendo a este impedir a prática de atos processuais inúteis, infundados ou meramente protelatórios, nos termos estabelecidos pelos arts. 77, 80 e 370, parágrafo único, entre outros do Código de Processo Civil que serão oportunamente analisados¹⁹¹.

O dever de controlar a atividade meramente procrastinatória das partes é apenas um dos deveres do juiz, decorrentes do princípio da duração razoável do processo.

Como sujeito do processo responsável pela prática de uma série de atos processuais relevantes para o desenvolvimento e o julgamento do feito, a

atividade do juiz deve sempre estar pautada pelos ditames do princípio da duração razoável, devendo o magistrado, não apenas como destinatário do comando normativo, mas também como principal responsável pelo cumprimento das normas processuais, ser o primeiro a combater a demora excessiva do processo, praticando os atos de sua responsabilidade sem demoras ou atrasos injustificados.

Além de seus próprios atos, vale ressaltar que o juiz é o superior hierárquico dos auxiliares da justiça, sujeitos processuais que, conforme se verá adiante¹⁹², devem praticar, sob a supervisão e comando do juiz, uma série de atos processuais importantes para o andamento do feito, como a efetivação das citações e intimações, atos sem os quais o procedimento não avança rumo a resolução da lide.

Ademais, é dever do próprio juiz determinar o andamento do feito rumo a resolução de mérito, sendo o princípio da duração razoável um verdadeiro guia para o exercício dessa atividade.

Em síntese, são desdobramentos concretos do princípio da duração razoável do processo nas atividades do juiz os deveres de: a) determinar e viabilizar o andamento do feito evitando ao máximo paralisações do procedimento e lapsos temporais sem atividade processual; b) praticar os atos ordinatórios que lhes cabe; c) determinar a prática dos atos de movimentação e comunicação processuais pelos seus auxiliares, na medida de suas atribuições; d) evitar a prática de atos desnecessários e meramente protelatórios pelas partes; e e) proferir a decisão no momento adequado e em tempo compatível com a complexidade da causa, equilibrando as garantias processuais das partes com o tempo estritamente necessário para o esgotamento desta garantia e amadurecimento do julgamento de mérito¹⁹³.

Obviamente, uma atuação eficiente do magistrado voltada a dar a máxima efetividade ao princípio da duração razoável do processo não depende apenas de sua vontade, mas também de uma boa estrutura,

material e de pessoal, para que ele desenvolva suas atividades, bem como de um eficiente arcabouço normativo para que o mesmo possa, ao obedecer e aplicar a lei processual, extrair de sua atividade os melhores resultados práticos possíveis.

Por esses motivos, é certo que o princípio da duração razoável do processo possui outros dois destinatários: o legislador e o administrador do Judiciário.

A ideia do legislador como destinatário dos princípios constitucionais foi objeto de exposição no item 6.1.3.1, “d”, e especificamente no que tange ao princípio da razoável duração do processo resta claro que cabe ao legislador: a) estabelecer técnicas processuais eficientes, que respeitem os demais direitos e garantias constitucionais, mas que, ao mesmo tempo, permitam o processo chegar ao fim em um prazo razoável; b) prever mecanismos legais de combate e punição de práticas procrastinatórias pelas partes e pelos próprios membros do Poder Judiciário.

Em outras palavras, sem violar as garantias constitucionais, como as do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, o legislador deve estabelecer limites para as práticas processuais, pois quanto maior o número de incidentes e recursos, indubitavelmente, mais demorado será o processo.

Aqui, mais uma vez, revela-se necessária a aplicação, desde o plano legislativo do princípio da proporcionalidade, que impõe, neste contexto, o equilíbrio entre o tempo necessário para o exercício dos direitos processuais fundamentais e a duração razoável do processo.

Ademais, técnicas voltadas a punição e combate a ações e omissões das partes e do juízo, com intuito meramente protelatório, tais como as já aludidas sanções por litigância de má-fé, devem sempre estar previstas na legislação como forma de se evitar e apenar aqueles que se valham das normas e garantias processuais para atuar de modo contrário à duração razoável do processo.

Por derradeiro, cumpre destacar que, como toda estrutura organizacional, o Poder Judiciário necessita de ser administrado, devendo essa administração ser pautada, como toda Administração Pública, pelo princípio da eficiência que, no caso do processo civil, não deve ser apenas a busca por um processo regular e capaz de proporcionar um resultado justo, como também capaz de proporcionar este resultado em um prazo razoável.

A duração razoável do processo e o princípio da eficiência também são consagrados no plano infraconstitucional, na medida em que o Código de Processo Civil, em seu art. 4º, dispõe que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e, no art. 8º, estabelece que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

6.1.4.10 Princípio do devido processo legal

O devido processo legal é consagrado na Constituição Federal no rol dos direitos e das garantias fundamentais, mais precisamente no art. 5º, inc. LXVI, que dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

O referido princípio possui clara inspiração na cláusula do due process of law, do direito anglo-saxão e remonta à Carta Magna inglesa de 1215¹⁹⁴.

Rigorosamente, segundo a doutrina clássica, o princípio do devido processo legal abarca todas as demais garantias processuais, como o contraditório, a ampla defesa e o juiz natural, e o direito a uma decisão fundamentada¹⁹⁵.

A doutrina, majoritariamente, destaca essa redundância, que, em princípio, poderia ser considerada inútil ou desnecessária, mas que, na verdade, constitui um dado relevante e benéfico para o sistema.

Humberto Ávila¹⁹⁶, por exemplo, aduz que “o princípio do devido processo legal impõe a interpretação das regras que garantem a citação e a defesa de modo a garantir protetivamente a defesa do cidadão” e conclui: “embora vários dos subelementos do princípio do devido processo legal já estejam previstos no próprio ordenamento jurídico, o princípio do devido processo legal não é supérfluo, pois permite que cada um deles seja ‘realizado’ ou ‘interpretado’ conforme ele”.

Nessa esteira, o devido processo legal pode ser considerado uma verdadeira cláusula de encerramento do sistema jurídico processual, exercendo uma função interpretativa sobre os próprios princípios constitucionais, bem como uma função integrativa e supletiva, atuante no preenchimento de lacunas ou contradições aparentes entre eles.

A par da perspectiva processual, a cláusula do devido processo legal possui um alcance substancial, atuando, portanto, no que respeita ao direito material, sendo, por exemplo, o fundamento do princípio da legalidade do direito administrativo e da liberdade de contratar no direito privado¹⁹⁷.

O duplo caráter, processual/formal e material/substancial, do devido processo legal e a aproximação dessa garantia em seu aspecto substancial dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são reconhecidos, inclusive, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende da decisão do Ministro Celso de Mello, em seu voto na ADI 1.755-85, em que resta sustentado que “a cláusula do devido processo legal – objeto de expressa proclamação pelo art. 5º, inc. LIV, da constituição e que traduz um dos fundamentos dogmáticos do princípio da proporcionalidade – deve ser entendida, na abrangência de sua noção conceitual, não só sob o aspecto meramente formal, que impõe restrições de caráter ritual de atuação do Poder Público, mas, sobretudo, em sua dimensão material, que atua como decisivo obstáculo a edição de atos legislativos revestidos de conteúdo arbitrário ou irrazoável”.

No mesmo voto o Ministro Celso de Mello conclui que: “a essência do substantive due process of law reside na necessidade de proteger os direitos e liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se revele opressiva ou destituída do necessário coeficiente de razoabilidade”.

Sobre o tema e, mais precisamente, sobre a evolução da interpretação e o alcance normativo da cláusula do devido processo legal, Gustavo Ferreira Santos¹⁹⁸ aduz que, historicamente, podem-se destacar três fases da noção de princípio do devido processo legal, na trajetória da jurisprudência da Suprema Corte americana.

A primeira fase foi caracterizada por sua natureza processual, em que restou estabelecido constarem da cláusula do devido processo legal as garantias processuais a um procedimento regular, à publicidade, à defesa adequada, dentre outros.

Ainda, conforme o citado autor¹⁹⁹, uma segunda fase se caracterizou por um alargamento no conceito de due process, no qual o princípio permitiria ao julgador verificar os fundamentos de justiça da própria decisão do legislador.

A terceira fase caracteriza-se por uma ampliação da cláusula do devido processo legal a contextos não econômicos como proteção à privacidade, direito à imagem, liberdade de culto.

As duas últimas fases, ainda segundo o referido autor, abarcariam o devido processo legal de sua perspectiva substancial, aspecto que aproxima o princípio em comento do princípio da proporcionalidade²⁰⁰.

Certo é que, o princípio do devido processo legal, de maneira amplíssima, pode ser entendido como a norma constitucional que, em primeiro lugar, representa a garantia constitucional de que todas as normas processuais na Constituição e na lei devem ser observadas, sob pena de nulidade do processo e, além disso, funciona como uma cláusula de encerramento

supletiva e integrativa dos demais princípios e regras constitucionais e legais do Direito Processual Civil.

6.1.4.11 Princípio da isonomia no processo civil: a dupla perspectiva do princípio da igualdade para o processo

O princípio da igualdade é um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito delineado na Constituição Federal de 1988, tendo sido consagrado no caput do art. 5º da Carta Magna, que abre o rol de direitos fundamentais.

O dispositivo chega a ser redundante, pois afirma que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”.

Entende-se uniformemente que essa garantia não se restringe a nivelar os cidadãos perante a norma posta, dado que também determina que a própria edição de uma norma deve dispensar tratamento igual às pessoas²⁰¹.

Nesse sentido, tem-se que a igualdade, como é comum aos princípios constitucionais, possui um duplo destinatário: o legislador, que fica vedado de editar normas em desconformidade com a isonomia, e o aplicador da lei, entre os quais o Poder Judiciário, que deve oferecer o mesmo tratamento a todos os indivíduos sujeitos à norma²⁰².

Por esse motivo, duas são as acepções da isonomia identificáveis; a primeira delas, a igualdade formal, traduzida pela noção de igualdade perante a lei, o que veda que esta estabeleça privilégios, isenções ou regalias a indivíduos ou grupo de pessoas²⁰³.

Entretanto, a par da igualdade formal²⁰⁴, impõe a Carta Constitucional uma igualdade substancial, em que a lei e seus aplicadores devem levar em consideração as desigualdades existentes entre os sujeitos e buscar, mesmo que pela via de um tratamento diferenciado, o reequilíbrio da

situação.

Robert Alexy²⁰⁵ chama a atenção para a tendência de colisão entre as duas acepções do princípio da igualdade, uma vez que todo tratamento jurídico desigual para fomento de uma igualdade fática é uma restrição à realização do princípio da igualdade jurídica.

Portanto, é imprescindível a identificação dos critérios que justificam um tratamento diferenciado, pelo legislador ou aplicador, da norma, sem que reste ofendido o princípio da igualdade.

Nesse ponto, lapidar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello²⁰⁶ para quem o reconhecimento das diferenciações sem quebra da isonomia deve ser feito a partir de três etapas: a) a primeira delas investigando-se o critério tomado, pelo legislador, intérprete ou aplicador, como discriminatório; b) na sequência, deve ser verificada a correlação lógica entre o fator de desigualação e a disparidade de tratamento jurídico; e c) por fim, deve-se verificar a correlação lógica do tratamento diferenciado estabelecido com os valores absorvidos pelo sistema constitucional²⁰⁷.

O grande mestre do Direito Público brasileiro exemplifica a aplicação destes critérios da seguinte forma: “suponha-se a hipotética lei que permitisse funcionários gordos afastamento remunerado para assistir a congresso religioso e o vedasse aos magros. No caricatural exemplo aventado, a gordura ou esbeltez é o elemento tomado como fator discriminativo. Em um exame perfunctório parecerá que o vício de tal lei, perante a igualdade constitucional, reside no elemento fático (compleição corporal) adotado como critério. Contudo, este não é, em si mesmo, fator suscetível de ser tomado como deflagrador de efeitos jurídicos específicos”²⁰⁸.

Nesse contexto, o referido mestre conclui que “o que tornaria inadmissível a hipotética lei seria a ausência de correlação entre o elemento de *discrímen* e os efeitos jurídicos atribuídos a ela. Não faz sentido facultar a obesos faltarem ao serviço para congresso religioso porque entre uma

coisa e outra não há qualquer nexó plausível. Todavia, em outra relação, seria tolerável considerar a tipologia física como elemento discriminador. Assim, os que excederam certo peso em relação à altura não podem exercer, no serviço militar, funções que reclamem presença imponente”²⁰⁹.

A lei não pode adotar fatores discriminatórios sem qualquer relação com distinção que estabelece, sob pena de ofensa à igualdade substancial. Desta feita, lei processual deve proporcionar as mesmas oportunidades e prazos às partes litigantes, salvo se houver um fator de *discrímen* que justifique o tratamento desigual, como é o caso do prazo em dobro para a Defensoria Pública e Advocacia Pública que, entre outras peculiaridades, não possuem a capacidade de recusar causas ou escolher feitos, sendo dever funcional de seus membros manifestar-se em todas as causas que envolvam seus representados²¹⁰.

Da mesma forma, não seria suficiente a igualdade formal perante a lei processual sendo tão importante quanto esta a igualdade na aplicação da lei, durante o processo, pelo juiz na condução do feito e no julgamento da causa.

Nesse sentido, é correto concluir que, no processo civil, o princípio da igualdade exerce esta dupla influência sobre o legislador e sobre o magistrado, condutor do processo.

A primeira delas diz respeito à igualdade de tratamento e oportunidades a serem dadas aos litigantes no curso do procedimento; e a segunda, à necessidade de o processo ser disciplinado e conduzido de modo a viabilizar que todos os sujeitos que estejam em uma mesma situação no plano do direito material obtenham a mesma resposta jurisdicional.

Reflexo do primeiro desdobramento é a previsão constante do art. 7º do Código de Processo Civil, que dispõe que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”, mais adiante reafirmada pelo art. 139, que a dispôr sobre os deveres do juiz estabelece no inc. I que “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I – assegurar às partes igualdade de tratamento”.

Nesse sentido, Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz²¹¹ afirma que a igualdade constitui princípio fundamental e revela-se no tratamento paritário das partes e, ainda, que o acesso à justiça e o direito ao processo exigem o respeito às normas processuais portadoras de garantias isonômicas dos sujeitos do processo.

Ademais, o citado autor²¹² salienta que “não basta a igualdade formal, sendo relevante a igualdade técnica e econômica. A igualdade formal diz respeito à identidade de direitos e deveres estabelecidos pelo ordenamento jurídico ao cidadão”; já a igualdade material leva em consideração os casos em que os cidadãos exercitam seus direitos e cumprem seus deveres.

Nelson Nery Jr.²¹³, apoiado na fórmula aristotélica da igualdade, aduz que a garantia da isonomia significa dar tratamento isonômico aos iguais e desigual aos desiguais, na exata medida de suas desigualdades, o que se traduz em uma autorização constitucional para que existam dispositivos processuais discriminadores sempre que estes se voltem a reequilibrar situações faticamente desiguais, como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O referido autor destaca, como decorrência da igualdade, o princípio da paridade de armas²¹⁴, que significa dar as mesmas oportunidades e instrumentos processuais para as partes, para que ambas possam fazer valer seus direitos e pretensões.

Ainda segundo Nery²¹⁵, a igualdade de armas não significa paridade absoluta, devendo as partes estarem diante de uma mesma realidade e igualdade de situações²¹⁶.

Cândido Rangel Dinamarco²¹⁷, por sua vez, destaca que, por força da isonomia, o magistrado deve oferecer oportunidades iguais aos participantes do processo e pô-los em situações equilibradas, e assevera, com propriedade, que a prática da isonomia não se limita a sua conduta de direção do processo, mas deve também estar presente ao julgar a causa.

Portanto, o princípio da igualdade, um dos pilares do nosso ordenamento constitucional, determina que o processo deve ser um instrumento capaz de produzir respostas jurisdicionais uniformes a todos os que se encontram na mesma situação jurídica no plano do direito material.

Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim²¹⁸ ressalta que “o princípio da isonomia se constitui na ideia de que todos são iguais perante a lei, o que significa que a lei deve tratar todos de modo uniforme, e que, correlatamente, as decisões dos tribunais não podem aplicar a mesma lei de forma diferente a casos absolutamente idênticos, num mesmo momento histórico”.

Isso porque não basta aplicar a mesma lei. A lei deve ser aplicada da mesma forma, com o mesmo sentido e a mesma interpretação, o que significa dizer que a lei deve ser aplicada tendo em vista não apenas o seu texto, como também o entendimento que têm a doutrina e, em especial, a jurisprudência.

O alcance desta perspectiva da igualdade passa pelo respeito aos precedentes e à jurisprudência dos tribunais, sobretudo dos tribunais superiores.

Assim, por força de uma interpretação sistemática, a partir desta perspectiva do princípio da igualdade e sua influência no processo civil, é possível concluir-se que o juiz, ao conduzir o processo e julgar a lide, deve observar e zelar pela estabilidade da jurisprudência.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni²¹⁹, após asseverar que “não apenas o juiz e o órgão judicial devem respeito ao que já fizeram, ou seja,

às decisões que tomaram, mas também às decisões dos tribunais que lhes são superiores, claramente quando estes decidem conferindo interpretação a uma lei ou atribuindo qualificação jurídica a determinada situação. Trata-se de algo que, além de advir de mera visualização da tarefa atribuída aos tribunais superiores, decorre da percepção da lógica do sistema de distribuição de justiça e da coerência que se impõe ao discurso do Poder Judiciário”.

A valorização da jurisprudência e dos precedentes é muito clara no Código de Processo Civil, notadamente nos arts. 926 e 927.

O art. 926 determina que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, ao passo que o art. 927 determina que “os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

O CPC, nesse ponto, combate a concepção antiga, de que cada processo e cada um dos autos é “um mundo”, o que implica aceitar a já denominada loteria jurisdicional e tolerar que duas pessoas, em uma mesma situação jurídica, recebam tratamento rigorosamente oposto, por terem sido julgadas por juízes com diferentes “entendimentos”.

Os dispositivos, portanto, voltam-se a concretizar a perspectiva de igualdade no sentido de ser direito de todos a uma resposta jurisdicional que aplique isonomicamente as leis ao valorizar a jurisprudência dos tribunais, em especial a do Supremo Tribunal Federal e a dos tribunais superiores, e a indicar práticas voltadas a garantir as buscadas estabilidade

e uniformidade das decisões jurisdicionais.

Assim, pela sistemática adotada pelo Código, deve ser observado, pelos órgãos de jurisdição inferior, o entendimento consolidado sobre questões de direito pelos órgãos colegiados de jurisdição superior, notadamente o plenário ou corte especial do Tribunal, conforme o caso.

Da mesma forma, outros órgãos fracionários numericamente menores que a Corte especial ou plenário, sobretudo se representarem todos os demais órgãos fracionários com competência para a matéria (seções, câmaras reunidas etc.), devem ter seus entendimentos jurisprudenciais respeitados e observados.

O art. 927 do CPC impõe a necessidade de observância da jurisprudência do Tribunal a todos os demais órgãos a ele vinculados, assim entendidos juízes de primeiro grau, relatores e magistrados dos juizados especiais, tanto de 1ª instância quanto as turmas recursais.

Especialmente, as decisões do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores, dado o caráter nacional e a própria missão constitucional dessas cortes, são destacadas, restando consignado nos incs. I, II e IV do mesmo art. 927, que a jurisprudência desses órgãos deve nortear a atuação dos demais tribunais e juízos de primeiro grau com o declarado intuito de prestigiar os princípios da legalidade e da isonomia.

Tal sistema de valorização, respeito e preferência pela estabilidade dos entendimentos jurisprudenciais, portanto, rende homenagem ao princípio da igualdade, permitindo que o processo dê tratamento idêntico a todos os jurisdicionados, e tenha uma maior margem de segurança jurídica e previsibilidade.

6.1.4.12 Princípio da assistência judiciária integral e gratuita

A Constituição Federal, no art. 5º, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e, desta forma, consagra o princípio da assistência

jurídica integral e gratuita.

Assim, o hipossuficiente econômico, assim entendido aquele que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, sem prejuízo ao seu sustento ou de sua própria família, tem direito de, não apenas ter o acesso gratuito à tutela jurisdicional, como também de ter uma representação técnica profissional provida pelo Estado.

O conceito de hipossuficiência para fins de fruição da assistência judiciária gratuita vem sendo estendido pela doutrina e jurisprudência para as pessoas jurídicas, desde que esta demonstre não possuir condições econômicas de exercer plenamente seus direitos processuais por impossibilidade financeira.

É de se notar que o direito fundamental consagrado no art. 5º, inc. LXXIV, não encerra apenas um direito processual, uma vez que a promessa constitucional é por uma assistência jurídica integral, sendo a assistência judiciária, ou seja, a assistência às partes litigantes em um processo judicial uma das espécies do gênero assistência jurídica.

Desta feita, a Constituição Federal garante aos hipossuficientes econômicos outras formas de assistência jurídica que não apenas a ação e a defesa no plano judicial, como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ou a promoção extrajudicial de resolução de conflitos.

De toda forma, em função dos objetivos desta Introdução, serão tecidas as considerações acerca dos principais desdobramentos da garantia da assistência jurídica integral e gratuita no plano processual, ou seja, a assistência judiciária ou “Justiça” gratuita.

No plano estritamente processual, o princípio da assistência jurídica integral e gratuita representa um exemplo de densificação de princípios processuais constitucionais ainda mais genéricos na própria Constituição, pois garantir a todos uma assistência jurídica integral e gratuita, entre

outras coisas, significa concretizar os princípios do acesso à Justiça e ampla defesa para aqueles que, do ponto de vista econômico, estariam impossibilitados de exercerem estes direitos caso tivessem de pagar para isso.

Ademais, a garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita é uma forma de concretização do direito de igualdade em sua perspectiva substancial dado que viabiliza o acesso à justiça e o exercício dos demais direitos processuais a todos independentemente da condição financeira.

Os principais desdobramentos do princípio da assistência jurídica integral e gratuita residem: a) no dever constitucional do Estado de manter estruturas e profissionais habilitados para prestar tal serviço público à população; e b) no dever de estabelecer a isenção de custas e demais despesas processuais²²⁰ para aqueles que não possuem condições econômicas para arcar com estes custos.

O dever do Estado de criar e manter uma Instituição voltada a prestação da assistência jurídica integral e gratuita se materializa por meio das Defensorias Públicas, instituição, nos termos do art. 135 da Constituição Federal, essencial à Justiça que tem por missão, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, o princípio da assistência jurídica integral e gratuita é regulamentado especialmente na Lei Complementar n. 80/94 e pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, respectivamente a lei orgânica da Defensoria Pública e a seção do CPC dedicada à “Gratuidade da Justiça”.

Assim, é a Defensoria Pública, que concretiza no plano institucional a promessa constitucional e o dever do Estado de prestar a assistência

jurídica integral e gratuita, não apenas no plano processual, como também fora dele²²¹.

Nas localidades em que a Defensoria Pública ainda não está estruturada a ponto de poder atender a todas as demandas dos hipossuficientes, a Ordem dos Advogados do Brasil, mediante convênio, mantém um cadastro de advogados interessados em prestar esta assistência judiciária gratuita.

A par da dificuldade financeira para pagar um advogado, que deve ser suprida pela Defensoria Pública, o hipossuficiente econômico pode também não possuir condições de arcar com as custas processuais, assim entendidas as taxas devidas ao próprio Poder Judiciário em função do ajuizamento de ações ou prática de atos ou diligências processuais.

Por esse motivo, outro desdobramento concreto da garantia prevista no art. 5º, inc. LXXIV, é a isenção de custas e demais despesas processuais para os que comprovarem ser hipossuficientes²²².

Apesar de a Constituição exigir a comprovação da condição de hipossuficiente, o art. 99, § 2º, do CPC estabelece que a gratuidade da Justiça pode ser concedida a partir da afirmação pela parte de sua condição de hipossuficiente cabendo ao juiz “indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Além do juiz, as partes também podem impugnar o pedido de justiça gratuita formulado pelo adversário.

De toda forma, nos termos do art. 99, § 2º, do Código, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Os demais desdobramentos e detalhes decorrentes da concessão da “gratuidade da justiça” consagrado no art. 5º, inc. LXXIV da Constituição Federal serão analisados no item 14.8, do Capítulo 14 dedicado às custas e

demais despesas processuais.

6.1.4.13 Princípio da definitividade das decisões judiciais (coisa julgada)

Considerando que o processo é um meio de pacificação social por meio da resolução da lide, seria um contrassenso admitir-se que o litígio, após ser definitivamente julgado, ao final do procedimento, pudesse ser objeto de discussão e nova decisão em outro processo.

É por esse motivo que a definitividade da decisão judicial consiste em uma característica essencial à jurisdição, conforme demonstrado no Capítulo 3, sendo impossível o Poder Jurisdicional cumprir o seu papel, caso suas decisões, não obstante proclamadas ao final do procedimento, pudessem ser questionadas infinitamente em outros processos.

O que o sistema admite, até por força do princípio do duplo grau de jurisdição acima comentado, é a possibilidade de se discutir o comando judicial no mesmo processo, por meio da interposição de recursos, sendo certo, portanto, que a formação da coisa julgada e a efetivação dos seus efeitos ocorrerão quando a decisão não for mais passível de reforma pela via recursal.

Tal característica essencial ao conceito de jurisdição possui assento constitucional e, por isso, traduz-se em um dos aspectos fundamentais do modelo constitucional de processo civil.

Nesse sentido, dispõe o art. 5º, inc. XXXVI que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A coisa julgada é a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

Nos termos do art. 485, inc. V do CPC, verificada a coisa julgada, pela repetição da ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, o mérito da segunda ação não deve sequer ser (re)apreciado.

Da combinação dos dispositivos, constitucional e legal, chega-se à

conclusão de que o sistema processual possui, como um de seus fundamentos basilares, o respeito à coisa julgada.

Nesse sentido, Nelson Nery Jr. chega a afirmar que a coisa julgada é a finalidade central do processo, por criar uma “segurança intangível para a singularidade da pretensão”, possuindo a força de estabelecer a imodificabilidade do direito material deduzido em juízo e resolvido pela sentença de mérito.

Por se dirigir a inúmeros destinatários, a disciplina constitucional da coisa julgada impõe o dever de obediência e a impossibilidade de se discutir ou se negar o estabelecido em um comando jurisdicional transitado em julgado a diversos atores do ordenamento jurídico, como o legislador, o magistrado, e aos sujeitos de direito em geral.

O primeiro destinatário é o próprio legislador que fica proibido de, por meio de comandos legais, pretender atingir os comandos judiciais já transitados em julgado.

Nesse contexto, aliás, a coisa julgada pode ser vista como um princípio constitucional fundamental para a concepção do Estado Democrático de Direito, e de um de seus principais desdobramentos, qual seja, a segurança jurídica.

Nesse sentido, Nelson Nery Jr. afirma que “para as atividades do Poder Judiciário, a manifestação do Estado Democrático de Direito ocorre por intermédio da coisa julgada”.

Assim, em função do disposto no art. 5º, inc. XXXVI, ora em comento e do próprio princípio da segurança jurídica, a lei não pode atingir os comandos judiciais acobertados pela coisa julgada.

Se considerada a natureza de cláusula pétrea do direito fundamental ao respeito à coisa julgada, é possível concluir-se que sequer uma alteração na ordem constitucional, pela via de uma Emenda à Constituição, pode afetar os comandos judiciais transitados em julgado.

Outro reflexo desta norma processual, voltada para os sujeitos de direito e ao próprio Poder Judiciário, consiste na impossibilidade de um novo ajuizamento de uma mesma ação idêntica a uma já transitada em julgado, caracterizando-se, nesse sentido, a coisa julgada como verdadeira cláusula de impedimento de ajuizamento de uma ação, o que é comumente categorizado pela doutrina, e assim será estudado nesta Introdução como um dos pressupostos processuais negativos, assim entendidos exatamente os aspectos que, se verificados, impedem a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo²²³.

A consagração constitucional da proteção à coisa julgada e a sua categorização como um direito fundamental eleva à máxima potência a importância do Poder Jurisdicional e, por via de consequência, do processo como método de seu exercício, uma vez que seu produto, a tutela jurisdicional, torna-se indiscutível e inatingível por qualquer outro comando jurídico.

Nesse sentido, a coisa julgada deve funcionar como um norte ao intérprete e aplicador do direito processual, ao juiz como condutor do processo e a todos os demais sujeitos da relação processual, que devem sempre atuar cientes de que o procedimento de resolução do litígio constitui a única e derradeira oportunidade de se resolvê-lo, uma vez que os termos ditados por esta solução se tornam imutáveis e indiscutíveis²²⁴.

6.2 Normas fundamentais no Código de Processo Civil

Se, por um lado, a Constituição Federal de 1988 é riquíssima em normas processuais, por outro, é certo que o sistema processual ali desenhado é incompleto, sobretudo em razão do caráter intencionalmente genérico e do alto grau de abstração de suas normas com estrutura de princípios.

Disso decorre a necessidade de a legislação infraconstitucional complementar o sistema, detalhando e concretizando os princípios constitucionais, tema enfrentado no Capítulo 2 e em especial no item 2.3.2.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil deve ser compreendido como um instrumento complementar à Constituição Federal voltado a sistematizar, dar coerência e detalhar princípios e regras constitucionais²²⁵.

Este caráter complementar do Código de Processo Civil enquanto legislação infraconstitucional subordinada às normas consagradas na Constituição Federal resta claro da leitura do art. 1º do CPC, que dispõe que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.

O referido dispositivo, além de ser o primeiro do Código de Processo Civil, é o dispositivo inaugural do rol de normas que o próprio Código reputa como fundamentais.

Assim, ainda que não possa se falar em hierarquia entre os dispositivos integrantes do CPC, ao elencar as normas categorizadas como fundamentais, o Código de certa maneira estabelece aqueles valores que lhe são mais caros, mais importantes para a estruturação do sistema.

Nesse sentido, o CPC consagra em seus doze primeiros artigos suas normas fundamentais, todas elas desdobramentos e concretizações de normas processuais previstas na Constituição Federal.

Em outras palavras, entre as normas processuais constitucionais e as normas fundamentais consagradas no Código de Processo Civil há uma relação de complementaridade, funcionando esta primeira seção do CPC como um elo entre os princípios constitucionais e as demais regras dispostas ao longo de seus outros 1.060 artigos.

As normas fundamentais do Código de Processo Civil, portanto, estabelecem uma sintonia fina entre a Constituição Federal e toda a legislação processual infraconstitucional.

Nesse sentido, sempre será possível estabelecer uma correlação entre as normas fundamentais do Código e um ou mais princípios constitucionais.

Assim, por exemplo, é inegável a conexão entre o princípio do contraditório, consagrado no art. 5º inc. LV da Constituição Federal, e os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, a seguir comentados²²⁶, enquanto o art. 4º do CPC claramente deve ser entendido como uma extensão e concretização das garantias de amplo acesso à Justiça e da duração razoável do processo dispostas no art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII da CF, que, conforme já asseverado acima, precisam ser entendidas como a consagração do direito a uma resposta justa, efetiva e em tempo razoável.

Já o princípio da igualdade (art. 5º, caput da CF) manifesta-se de maneira mais concreta nas normas fundamentais do Código de Processo Civil, especialmente no art. 7º, que dispõe ser “assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (...)” e também, em certa medida, no art. 12, que estabelece a necessidade de observância de uma ordem cronológica quando do julgamento dos feitos.

Em grande medida, ademais, as normas fundamentais dispostas nos doze primeiros artigos do CPC são complementadas por outras regras ao longo do Código, como fazem o art. 489, § 1º em relação ao art. 11 e o art. 334 em relação ao disposto no art. 3º, §§ 2º e 3º.

Nesse contexto, por exemplo, o art. 11 sintoniza o sistema do Código com o sistema constitucional, no que é complementado por outras normas codificadas, permitindo ao intérprete concretizar e estabelecer com mais precisão o alcance e o sentido de um princípio constitucional.

No caso da motivação, esta relação de complementaridade fica clara, pois temos que, da leitura do art. 93, IX da Constituição Federal, e do art. 11 do CPC, conclui-se que toda decisão judicial deve ser motivada, sendo útil o art. 489, § 1º para esclarecer como tal exigência deve ser atendida, a partir de uma interpretação a contrário senso.

Da mesma forma, se em um primeiro momento o Código de Processo Civil estabelece ser uma norma fundamental à promoção, pelo Estado e por todos os sujeitos do processo, da solução consensual de conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º do CPC), o seu art. 334 estrutura dentro do procedimento do processo de conhecimento a “audiência de conciliação e mediação” concretizando a norma fundamental ao estabelecer o momento procedimental e a forma por meio da qual esta busca deve ser realizada pelas partes e pelo juízo.

Ademais, vale destacar que, tal como os princípios constitucionais, as normas fundamentais do Código de Processo Civil, a par de serem comandos jurídicos em si mesmo considerados, também cumprem um papel integrador do sistema, funcionando como vetores interpretativos, influenciando, portanto, o sentido e o alcance de todas as demais normas processuais.

É imperativo, portanto, que o intérprete e aplicador do Código de Processo Civil e mais amplamente o estudioso do Direito Processual tenham sempre em mente o conteúdo e os valores consagrados na Constituição Federal e no capítulo do CPC dedicado às normas fundamentais, pois são estes os valores essenciais e fundantes de todo o sistema e, desta feita, norteadores da interpretação e capazes de dar unidade e integridade a todo o sistema processual.

Assim, sempre que o juiz deparar com um pedido ou defesa deve ter em mente seu dever de respeitar o direito das partes a uma resposta de mérito, justa e efetiva, dentro de um prazo razoável conforme exige o art. 4º do Código, sempre oportunizando a oitiva prévia da parte contrária, a teor do art. 9º, que concretiza no plano infraconstitucional um dos desdobramentos do princípio do contraditório consagrado constitucionalmente.

Conforme já asseverado, de certa forma, tudo aquilo que é tido pelo Código de Processo Civil como norma fundamental já possui uma previsão,

ainda que implícita na Constituição Federal, funcionando os doze primeiros artigos do Código ora como pura e simples reafirmação destes princípios, ora como um dispositivo esclarecedor e complementar que revela o verdadeiro sentido, extensão e alcance do valor consagrado pela Constituição.

Portanto, vale destacar de antemão três importantes funções desempenhadas pelas normas fundamentais: a) função complementar, em relação às normas constitucionais, explicitando desdobramentos concretos dos princípios nelas consagrados; b) função interpretativa, funcionando portanto como vetores interpretativos dos demais dispositivos e técnicas disciplinadas pelo Código; c) função supletiva, uma vez que, enquanto normas em si mesmas consideradas, as normas fundamentais por si sós já são capazes de gerar direitos e deveres para as partes, para o juiz e demais sujeitos do processo, algo útil notadamente quando o sistema codificado não possuir norma específica capaz de disciplinar determinada situação processual.

Por outro lado, vale destacar que o simples fato de não estar arrolado entre os doze primeiros artigos do Código não descaracteriza algumas normas processuais como fundamentais, a começar por aquelas consagradas na Constituição Federal que não foram reproduzidas pelo CPC, como o princípio do juiz natural e a vedação dos tribunais de exceção constantes do art. 5º incs. XXXVII e LIII, tratados no item 6.1.4.7.

Isso porque normas fundamentais são todas aquelas que possuem a capacidade de influenciar em todo o processo e em praticamente todas as técnicas processuais, e capazes de cumprir um papel integrativo, dando coerência e logicidade ao sistema, um papel supletivo, preenchendo lacunas na falta de norma expressa e específica, e, além disso, um papel interpretativo, funcionando como comandos norteadores do intérprete e aplicador da lei processual.

O critério topológico (estar dentro do capítulo do Código denominado

“Das normas fundamentais”), portanto, não pode ser o único utilizado para identificação das normas fundamentais do sistema processual brasileiro, o que implica dizer que normas fora deste capítulo podem ser igualmente consideradas fundamentais.

Isso porque outros dois critérios podem ser utilizados pelo estudioso do Direito Processual Civil para caracterizar uma norma processual como fundamental: o critério hierárquico e o critério sistemático/funcional.

Pelo critério hierárquico é possível caracterizar como norma fundamental todas as normas processuais consagradas na Constituição Federal, uma vez que, em razão da supremacia normativa típica das constituições, são capazes de influenciar todo o processo e todas as técnicas processuais e, além disso, a própria produção e interpretação de normas processuais infraconstitucionais.

Em função disso, são normas fundamentais todas as normas processuais constitucionais a que se fez referência no item 6.1.4, algumas repetidas e concretizadas entre os doze primeiros artigos do Código e outras não diretamente referidas neste específico capítulo, mas, nem por isso, sem o caráter de norma fundamental em razão de sua previsão constitucional.

Ademais, o critério sistemático/funcional permite a identificação de normas fundamentais “espalhadas” pelo Código, fora, portanto, do capítulo assim denominado.

Devem ser consideradas fundamentais, em função do critério sistemático/funcional, todas as normas do CPC que tenham a capacidade de influenciar todo o processo e praticamente todas as técnicas processuais, independentemente de sua “localização”.

É o caso, por exemplo, do art. 927 do CPC, que estabelece um rol de pronunciamentos de obrigatória observância por todos os juízes e tribunais, norma capaz de influenciar todos os tipos de processo, todas as fases do procedimento e todas as técnicas de julgamento.

É certo que os critérios topológico e hierárquico são mais seguros e precisos, no sentido de tornar indiscutível o caráter fundamental das normas arroladas entre os doze primeiros artigos do Código de Processo Civil e as consagradas pela Constituição Federal sendo, contudo, essencial a utilização também do critério sistemático/funcional para caracterizar algumas normas fundamentais não obstante estarem topologicamente fora destes “espaços”.

Em síntese, é possível afirmar que são normas fundamentais: a) pelo critério hierárquico, todas aquelas consagradas pela Constituição Federal, a exemplo do art. 5º, inc. XXXV, LV, LVI, LXXVIII, entre outros incisos; art. 93, IX etc.; b) pelo critério topológico, os doze primeiros artigos do Código de Processo Civil; e c) pelo critério sistemático/funcional, algumas normas “espalhadas” pelo CPC, com a capacidade de influenciar todos os tipos de processos e praticamente todas as técnicas processuais, a exemplo do art. 927 e art. 489, § 1º.

Ademais, o Código de Processo Civil é riquíssimo em regras que, de rigor, constituem desdobramentos concretos de normas fundamentais, sendo o cotejo entre estes dois planos a forma segura e correta de se compreender o Direito Processual.

Portanto, a compreensão das normas fundamentais do Código de Processo Civil deve ser realizada em um contexto onde, de um lado, estas normas esclarecem e concretizam princípios constitucionais e, de outro, serão estas mesmas normas concretizadas e esclarecidas por outras inúmeras regras dispostas ao longo do próprio Código e eventualmente na legislação extravagante.

Os subitens a seguir serão dedicados ao estudo das normas fundamentais do CPC em espécie, focando este duplo aspecto: em que medida estão mais bem delineadas as garantias processuais constitucionalmente consagradas e de que forma estas normas influenciam e irradiam efeitos ao longo do sistema infraconstitucional codificado, sendo

certo que será absolutamente inevitável a remissão aos itens anteriores dedicados aos princípios constitucionais, sobretudo àqueles aos quais as normas fundamentais estão direta e intimamente ligados.

Considerando que as normas fundamentais, assim identificadas pelo critério hierárquico, já foram tratadas no item antecedente do presente capítulo²²⁷, o foco da análise nos itens subsequentes serão as normas fundamentais caracterizadas pelo critério topológico e, em menor medida, algumas normas fundamentais assim caracterizadas em razão do critério sistemático funcional.

6.2.1 Art. 1º do CPC: Princípio da conformidade com a Constituição e princípio do devido processo legal

Conforme já afirmado no item anterior, as normas fundamentais do Código de Processo Civil não são em si, necessariamente, fontes criadoras de direito e deveres processuais, uma vez que muitas das suas previsões já encontram respaldo na Constituição Federal e, portanto, parte daquilo que foi nelas estabelecido já poderia ser extraída do sistema a partir da interpretação e aplicação de um dos princípios constitucionais.

De certa forma, isso pode ser dito da norma fundamental consagrada no art. 1º do Código de Processo Civil, que dispõe que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”, o que, em si, não traz novidades normativas.

Em outras palavras, mesmo que inexistente o referido dispositivo seria imperativa a conclusão no sentido de que o processo deve ser conduzido de acordo com os valores e normas constitucionais e que o juiz ao conduzir o processo deve observar e aplicar as normas constitucionais e codificadas.

Entretanto, o art. 1º do Código de Processo Civil deve ser entendido como uma norma no mínimo útil do ponto de vista pedagógico e com um

sensível valor simbólico dado o seu textual comprometimento com a Constituição Federal²²⁸ e a (re)afirmação da superioridade normativa da Constituição.

Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina afirma que “longe de ser mera redundância, a referência a princípios constitucionais ao longo do Código tem importante papel pedagógico”²²⁹.

No mesmo sentido, Fredie Didier Jr.²³⁰, após afirmar que do ponto de vista normativo o enunciado constante do art. 1º reproduz uma obviedade pois qualquer norma jurídica brasileira só pode ser construída e interpretada de acordo com a Constituição Federal, conclui que do ponto de vista simbólico o enunciado é muito importante pois “embora se trata de uma obviedade, é pedagógico e oportuno o alerta de que as normas de direito processual não podem ser compreendidas sem o confronto com o texto constitucional, sobretudo no caso brasileiro, que possui um vasto sistema de normas processuais constitucionais”.

Ademais, o art. 1º do Código positiva as funções integrativa e interpretativa a que se fez referência no item 6.1.3.2, do presente capítulo, ao dispor que o processo deve ser ordenado e disciplinado conforme os valores e princípios constitucionais e que as normas processuais devem ser interpretadas de acordo com tais normas fundamentais.

Em síntese, a primeira norma do Código de Processo Civil consagra expressamente o princípio da conformidade com a Constituição orientando o intérprete, estudioso e aplicador das regras do Código a interpretá-las e aplicá-las no sentido admitido pelo texto constitucional excluindo qualquer interpretação incompatível com os valores constitucionalmente consagrados.

Além disso, o art. 1º do Código pode ser visto como uma reafirmação e concretização – ainda que óbvia – do princípio do devido processo legal, uma vez que estabelece que as normas a serem seguidas, ou seja, os parâmetros normativos que devem pautar o desenvolvimento do processo

são aqueles consagrados na Constituição Federal e no próprio Código.

6.2.2 Art. 2º do CPC: Princípios do dispositivo, do impulso oficial e inércia jurisdicional

O art. 2º do Código de Processo Civil consagra dois princípios processuais: a) um ligado ao início do processo: o princípio da inércia jurisdicional; e b) um segundo, ligado ao seu desenvolvimento, uma vez regularmente iniciado: o princípio do impulso oficial.

Pelo princípio da inércia (também consagrado na doutrina como princípio do dispositivo), o juiz não age senão quando provocado, sendo vedado ao órgão jurisdicional dar início à relação processual sem provocação.

O ato de provocação deve ser necessariamente da parte que o faz através do exercício do direito de ação²³¹ formalizado na petição inicial.

Ademais, decorre do princípio da inércia jurisdicional o fato de o juiz ficar adstrito aos limites da provocação, sendo-lhe vedado investigar, analisar e decidir sobre um tema que não tenha sido objeto de pedido pelo autor.

Assim, além de não poder dar início a uma relação processual, mesmo nas relações processuais regularmente iniciadas pelo autor, fica o magistrado proibido de julgar além do pedido e de conceder um provimento jurisdicional diferente do pleiteado.

Segundo Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini²³², “duas nobres razões” justificam o princípio da inércia jurisdicional “(1ª) o juiz poderia ter sua imparcialidade afetada, se ele mesmo desse início aos processos: ao reputar que determinada tutela jurisdicional é necessária, o juiz já estaria tomando uma posição acerca da lide; (2ª) a instauração de processos de ofício (i.e., sem provocação do interessado) normalmente não contribuiria para a pacificação social: se as partes não foram ao Judiciário, isso significa, muitas vezes, que não reputam o litígio relevante para tanto.”

Os mesmos autores²³³, a par disso, destacam que “de todo modo, em casos em que, por razões relevantes não se deve deixar a opção da

iniciativa jurisdicional unicamente à mercê do interessado, o ordenamento jurídico atribui a outros órgãos ou pessoas, que não o juiz, o poder de pedir a instauração do processo como é o caso do Ministério Público”.

Vale destacar que, mesmo nestes casos, o poder de dar início ao processo não é do juiz ou mesmo do Judiciário, mas de outros órgãos e pessoas de direito público notadamente as denominadas funções essenciais à Justiça²³⁴.

Apesar de estar intimamente ligado ao início do processo, o princípio da inércia jurisdicional possui algumas (poucas) manifestações ao longo do procedimento por expressa previsão legal.

Em outras palavras, além de sempre exigir iniciativa da parte para que o processo tenha início, a lei condiciona também determinadas etapas e incidentes processuais a uma nova provocação da parte. É o caso, por exemplo, do início da fase executiva (de cumprimento de sentença) e da instauração do incidente de falsidade documental, que dependem, para serem instaurados, de um pedido expresso da parte interessada.

Contudo, como regra geral, uma vez iniciado o processo cabe ao juiz, de ofício, dar andamento ao feito rumo à prestação jurisdicional, zelando não só pelo seu desenvolvimento, como também pela sua regularidade e validade.

Em outras palavras, uma vez provocado, o juiz tem o dever de promover o andamento do feito, ou seja, determinar, de ofício e independentemente de “novas provocações” da parte, o desenvolvimento válido e regular do processo até a efetiva prestação jurisdicional.

Dizer que o juiz tem este dever, entretanto, não implica dizer que cabe apenas ao órgão jurisdicional promover o andamento do processo, haja vista que, conforme se verá adiante, decorre do princípio da cooperação consagrado no art. 6º do Código de Processo Civil uma responsabilidade de “todos os sujeitos do processo” que, por isso, “devem cooperar entre si para

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”²³⁵.

De todo modo, a norma consagrada no art. 2º do CPC estabelece o dever do juiz de zelar pelo desenvolvimento válido e regular do processo, praticando tempestivamente os atos que lhe cabem, e de comandar e supervisionar os atos dos auxiliares da Justiça, bem como fiscalizar os atos das partes e demais sujeitos que de alguma forma participem do processo.

A leitura do referido dispositivo e o cumprimento deste dever devem se dar, ademais, em conjunto com o princípio da duração razoável do processo, que, neste contexto, impõe que a prática destes atos de impulsionamento e desenvolvimento devem se dar assim que possível, isto é, imediatamente após a complementação da etapa anterior, evitando-se injustificáveis paralisações do feito, denominadas de “etapas mortas” do processo, exatamente por serem lapsos temporais nos quais o processo não tem andamento pela omissão do juiz em praticar ato que deveria praticar de ofício.

Em outras palavras, o atraso injustificado do juiz e de seus auxiliares na prática de um ato voltado a dar andamento ao processo e que deveria ser praticado de ofício, além de ferir o princípio do impulso oficial consagrado no art. 2º do CPC, desrespeita o princípio constitucional da razoável duração do processo.

6.2.3 Art. 3º do CPC: Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à Justiça e princípio da preferência pela solução consensual de conflitos

O art. 3º disciplina no âmbito infraconstitucional o princípio do acesso à Justiça consagrado na Constituição Federal no art. 5º, inc. XXXV, já comentado por ocasião do item 6.1.4.1, e, considerado em seu conjunto (caput e parágrafos), consagra quatro normas fundamentais: a) a repetição do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional; b) a reafirmação da arbitragem enquanto meio de solução de litígios; c) o dever do Estado,

através de seus agentes e de todos os demais membros das funções essenciais à Justiça, de promover a solução consensual dos litígios; e d) a preferência pela solução consensual de conflitos, ainda que já judicializados.

Nesse sentido, seu caput dispõe que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”, no que é complementado por três incisos, verbis:

“§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Assim, podemos afirmar que o art. 3º do Código de Processo Civil consagra: a) a (re)afirmação do acesso à Justiça; b) a admissibilidade (expressa) da arbitragem; c) o dever do Estado de promover a solução consensual; e d) os meios consensuais como a forma preferencial de solução de controvérsia.

A regra do caput, rigorosamente em nada acrescenta ao sistema processual, dada a repetição da regra constante do art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, objeto do item 6.1.4.1 do presente capítulo.

Nesse sentido, é reafirmado o amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário independentemente do valor econômico do bem tutelado ou de qualquer outra condição para o ajuizamento da ação, como esgotamento de instâncias administrativas ou obrigatoriedade de tentativa prévia de solução por outras vias.

Ademais, tal como na Constituição, resta expresso no art. 3º do CPC a possibilidade de tutela preventiva, isto é, tutela contra mera ameaça, antes que o dano se concretize.

Portanto, vale, neste contexto, tudo aquilo que restou afirmado por ocasião dos comentários ao princípio da inafastabilidade consagrado no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, norma apenas reproduzida pelo caput do art. 3º do CPC.

De outro lado, é importante destacar as referências à arbitragem e aos métodos consensuais de solução de conflitos subordinadas a um caput que contextualiza estes métodos de solução de controvérsia como aptos a atender a garantia constitucional de acesso à Justiça.

Em outras palavras, resta claro, a partir da interpretação sistemática do § 1º do art. 3º do Código, a legitimidade da arbitragem e sua caracterização como um meio de acesso à Justiça (ou a ordem jurídica justa), tema aliás pacífico na doutrina e jurisprudência mesmo antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015.

A arbitragem no Brasil, regulamentada pela Lei n. 9.307/1996, permite aos sujeitos maiores e capazes pactuarem que a solução de litígios que versem sobre direitos disponíveis será excluída, por expressa manifestação de vontade, da apreciação do Poder Judiciário e transferida ao árbitro escolhido consensualmente pelas próprias partes litigantes.

O art. 3º, § 1º do CPC nesse ponto apenas reafirma a plena admissibilidade da arbitragem desde que respeitados os requisitos legais, no caso, especialmente a Lei n. 9.307/1996.

Importantes contribuições à concretização e detalhamento do princípio do acesso à Justiça constitucionalmente consagrado estão nos §§ 2º e 3º do art. 3º e no art. 4º do CPC, este último, a ser comentado no item subsequente.

O § 2º do art. 3º do Código cumpre dois importantes papéis, pois não apenas deixa claro que a solução consensual de conflitos deve ser compreendida como meio de promoção do “acesso à Justiça”, sendo assim uma forma de se cumprir a promessa constitucional, como estabelece que

este método é preferencial à jurisdição propriamente dita.

Ademais, o dispositivo estabelece ser dever do Estado promover tais soluções consensuais que deve, portanto, prover meios para que estas sejam alcançadas antes de impor a solução jurisdicional.

O § 3º do art. 3º do CPC, por sua vez, distribui o ônus por esta busca pela solução consensual a todos os profissionais que atuem no processo, juízes, por eles mesmos ou mediante apoio de seus auxiliares, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, que têm o dever de promoverem esta busca.

Em suma, os §§ 2º e 3º do art. 3º do CPC não apenas consagram expressamente a mediação, conciliação e outros métodos de solução de litígios como meios legítimos de extinção da lide, como estabelecem serem estes métodos preferenciais se comparados à jurisdição, sendo dever do Estado-juiz e dos membros das demais funções essenciais à Justiça a busca pela resolução da controvérsia por um destes meios.

Assim, conforme já asseverado, sobretudo no Capítulo 3, o método jurisdicional de solução de controvérsias, mediante o qual o Estado-juiz impõe a solução do litígio, é apenas um entre outros métodos de solução da lide.

Desta feita, além de ser plenamente admissíveis, os denominados métodos consensuais de solução de controvérsias são inclusive preferidos pelo sistema, devendo portanto serem buscados antes da solução impositiva da decisão jurisdicional, substituindo-se, na expressão de Kazuo Watanabe²³⁶, “a cultura da sentença” pela “cultura da pacificação” podendo esta última ser alcançada sem a necessidade de solução imposta pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, a aceitação expressa e o estímulo do Código de Processo Civil aos métodos consensuais de solução de litígio são muito mais claros e intensos se comparados ao CPC de 1973, que, igualmente, admitia tais

métodos apenas de maneira tímida ao dizer, por exemplo, que o juiz deveria a todo momento conciliar as partes (art. 125 CPC 1973), sem estabelecer a preferência por estes métodos e sem se ocupar de criar mecanismos processuais e sujeitos do processo especificamente voltados à obtenção da solução consensual.

Nessa perspectiva, Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Jr.²³⁷ aduzem que os §§ 2º e 3º do CPC colocam a solução consensual de conflitos “em primeiro plano, em nível de norma fundamental do Processo Civil brasileiro”.

Assim, o Código de Processo Civil além de, no art. 3º ora em comento, ser bastante contundente no estímulo à utilização de métodos consensuais, os regulamenta de maneira mais precisa, por exemplo: a) estabelecendo o dever de os tribunais criarem “centros de judiciários de solução de conflitos” (art. 165, § 1º); b) prevendo a existência de auxiliares do juízo especializados na conciliação e mediação (art. 165, §§ 2º e 3º); e c) estabelecendo etapas procedimentais dedicadas à busca da solução consensual de controvérsias já apresentadas ao Judiciário, cujo melhor exemplo é a “audiência de conciliação ou mediação” prevista no art. 334.

Ademais, o art. 167 do Código admite o credenciamento de câmaras privadas de conciliação e de mediadores e conciliadores fora dos quadros do Poder Judiciário, aptos a promoverem a busca da solução consensual, e determina, no art. 174, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem criar câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, com o objetivo de dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da Administração Pública e avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da Administração Pública, por exemplo.

Outro desdobramento concreto importantíssimo que implica uma mudança de paradigma do Processo Civil brasileiro pode ser encontrado no

art. 334 do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade da audiência de conciliação e mediação, só podendo ser dispensada caso ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; ou quando, pela natureza do direito, não se admitir a autocomposição.

Assim, como regra, o primeiro diálogo entre as partes do processo não se dará em um contexto adversarial, em que cada uma delas apresenta suas razões por definição contrapostas, mas sim em uma audiência cujo objetivo é promover o diálogo e o consenso e obter uma solução acordada. Esta audiência, inclusive, deve, preferencialmente, ser conduzida por profissionais habilitados e especializados nesta busca, ou seja, os mediadores e conciliadores referidos no art. 165 e seguintes do Código.

Todos esses dispositivos reforçam a ideia de que a busca pela solução consensual dos conflitos é uma norma fundamental do sistema processual que deve, na medida do possível, evitar a solução jurisdicional imposta às partes.

É necessário, portanto, que a solução imperativa e impositiva ditada pelo Estado-juiz seja, como regra, precedida de uma tentativa de solução consensual e apenas colocada quando fracassada esta tentativa por ausência de acordo entre as partes litigantes.

6.2.4 Art. 4º do CPC: Princípio da efetividade do processo, princípio da preferência pela solução integral de mérito e (re)afirmação do princípio da duração razoável do processo

A exemplo do que ocorre com todos os dispositivos que estabelecem as normas fundamentais do Código de Processo Civil, o art. 4º não se resume à consagração de um único princípio.

Na verdade, sua leitura permite a identificação de três normas fundamentais para o Processo Civil brasileiro: a) o princípio da efetividade do processo; b) o princípio da preferência pelo exame do mérito; e c) o

princípio da duração razoável do processo.

Em comum, todos os princípios consagrados no art. 4º do CPC possuem o fato de serem desdobramentos da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto no art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal, que, conforme já asseverado, não se esgota com o simples “acesso” à Justiça, uma vez que o dispositivo constitucional igualmente consagra o direito a uma resposta jurisdicional justa, efetiva e em tempo razoável.

É a observância e o respeito às exigências do art. 4º do Código de Processo Civil que proporciona o alcance do cumprimento desta promessa constitucional.

Em outras palavras, o cumprimento pelo Estado do dever imposto pela Constituição implica a necessidade de o Judiciário: a) enfrentar o mérito do processo, pronunciando-se sobre a solução da controvérsia; b) além de proclamar a solução, promover a efetivação, isto é, a transformação do plano dos fatos do direito reconhecido; e c) realizar ambas as tarefas em um tempo razoável.

O direito à obtenção da tutela em prazo razoável, de rigor, é mera repetição do art. 5º, inc. LXXVIII da Constituição Federal, e, neste contexto, não há nenhuma inovação ou complementação do dispositivo constitucional pelo Código de Processo Civil, sendo, por esta razão, suficientes todas as considerações realizadas no item 6.1.4.9.

Já a referência a “atividade satisfativa” constante do final do dispositivo explicita a necessidade de compreensão dentro da garantia de acesso à Justiça de toda a atividade executiva voltada à concretização no plano dos fatos do direito reconhecido com existente.

Assim, resta clara da leitura do Código a conclusão de que tão fundamental quanto o reconhecimento do direito é a materialização deste direito, ou seja, sua transformação em realidade.

Portanto o Estado-juiz não satisfaz o direito de ação quando recebe a

pretensão do jurisdicionado nem cumpre seu dever por completo quando se pronuncia acerca do direito posto em juízo, pois “ao lado de uma jurisdição, tem de haver uma juris-satisfação”²³⁸.

Nas palavras de Marinoni²³⁹ “não há como admitir, no Estado constitucional, que o direito fundamental a tutela jurisdicional efetiva possa se limitar ao ato que instaura o processo, como se esse direito fundamental pudesse ser apenas o direito de propor a ação ou pedir a tutela jurisdicional. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva é o direito de agir em juízo em busca da tutela jurisdicional efetiva do direito material, e isso está a quilômetros de distância dos antigos conceitos de ir a juízo e de direito de pedir a tutela jurisdicional”.

Nesse contexto, é forçosa a conclusão no sentido de que o Estado não presta a tutela jurisdicional até que realmente entregue o bem jurídico objeto do processo a quem de direito (e não simplesmente conheça ou declare este direito).

Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno²⁴⁰, a tutela jurisdicional efetiva impõe a realização concreta dos direitos declarados existentes pelo Estado-juiz.

Esta doutrina é consagrada pelo disposto no art. 4º, in fine, do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 4º do CPC consagra o direito da parte de obter a “solução integral do mérito”.

Por mérito do processo, deve ser entendido o seu objeto, que se traduz na pretensão (pedido) formulada pelo autor²⁴¹.

Segundo Alexandre Câmara, o mérito (objeto) do processo é a pretensão, trazida para o processo pela demanda e revelada pelo pedido do autor²⁴², e por isso tem-se por mérito do processo “a exigência do demandante no sentido de obter um atuar ou um fazer, ou, com mais precisão, a intenção manifestada pelo demandante de obtenção de um

provimento capaz de lhe assegurar tutela jurisdicional²⁴³”.

Portanto, quando o art. 4º estabelece que as partes têm direito a uma solução integral de mérito, resta claro que a busca a ser feita pelo juiz e por todos aqueles que participem do processo deve ter por objetivo uma solução dada à pretensão apresentada pela parte.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. afirma que “o CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra (...)”. Para tanto, a demanda deve ser julgada.

Reflexos e desdobramentos concretos deste princípio podem ser encontrados em diversos dispositivos do Código de Processo Civil que deixam clara a preferência pelo enfrentamento do mérito determinando a superação do vício, irregularidade ou dificuldade que impeça a análise do pedido, sempre que possível.

Como exemplos podem ser citados os arts. 317 e 488 do Código.

O primeiro é lapidar e dispõe: “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”²⁴⁴.

Também no plano recursal o Código privilegia o exame do mérito, estabelecendo que, caso o vício que impeça a análise do pedido recursal seja passível de correção, deve o magistrado relator do recurso dar oportunidade ao recorrente para que o defeito seja sanado (art. 932, parágrafo único).

Ademais, é possível afirmar que toda a estrutura do sistema de nulidades do Código, como os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas, tem por fundamento esta perspectiva da norma fundamental do art. 4º, que dá preferência ao exame do mérito²⁴⁵.

Portanto, sempre que possível, o juiz e demais sujeitos do processo devem procurar superar o vício ou irregularidade que impede o exame do

mérito de modo a viabilizar a integral resolução do litígio.

6.2.5 Art. 5º do CPC: Princípio da boa-fé objetiva

O art. 5º do Código de Processo Civil estabelece que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” e, nessa medida, positiva como norma fundamental o dever de boa-fé.

O princípio da boa-fé tem origem no Direito Privado, sendo importante regra de hermenêutica sobretudo no campo contratual.

A doutrina processual, em parte inspirada no Direito Privado e também em razão da previsão das penalidades por litigância de má-fé, já aduzia, mesmo à luz do Código de Processo Civil de 1973, a existência do princípio da boa-fé e lealdade processual.

Nesse sentido Humberto Theodoro Jr.²⁴⁶ já afirmava que “o Estado e a sociedade, de maneira geral, apresentam-se profundamente empenhados em que o processo seja eficaz, reto, prestigiado e útil ao seu elevado desídio”, daí a preocupação da lei processual “em assentar seus procedimentos sob os princípios da boa-fé e lealdade das partes e do juiz”.

O atual CPC, além de manter o regramento das condutas e penalidades de má-fé, inovou elencando o princípio da boa-fé como uma de suas normas fundamentais.

Nesse sentido, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro²⁴⁷ aduz tratar-se de “importantíssimo princípio de ordem geral contido logo na parte inaugural do novo Código de Processo Civil, o qual deve ser interpretado como norma fundamental de comportamento dirigida a todas as pessoas que participam do processo”.

Por isso, o autor citado destaca que, longe de ser um conceito vago, de interpretação subjetiva, o princípio da boa-fé tem duas funções precípuas²⁴⁸: a) estabelecer comportamentos probos e éticos aos diversos personagens do processo; e b) restringir ou proibir a prática de atos

considerados abusivos.

Portanto, o princípio da boa-fé objetiva, que atinge todos os sujeitos do processo, possui um aspecto positivo, no sentido de impor determinados comportamentos e deveres processuais, e um aspecto negativo, no sentido de proibir determinadas atitudes.

Importante destacar a lição de Fredie Didier Jr.²⁴⁹ no sentido de que duas são as perspectivas da boa-fé no Direito: uma objetiva e outra subjetiva, sendo a boa-fé objetiva a consagrada pelo art. 5º do Código.

A boa-fé subjetiva é relacionada à intenção do sujeito, sendo o elemento volitivo da parte indispensável para sua caracterização. Já a boa-fé objetiva é uma norma de conduta com capacidade de impor e proibir comportamentos, além de criar situações jurídicas ativas e passivas.

É esta acepção objetiva da boa-fé a consagrada pelo art. 5º do Código de Processo Civil.

Concretamente, é possível extrair quatro funções do princípio da boa-fé objetiva no Processo Civil brasileiro, pois ele é capaz de: a) funcionar como um critério hermenêutico interpretativo; b) criar deveres anexos ou colaterais; c) regulamentar o exercício de direito; e d) proibir comportamento incoerente.

Como toda norma fundamental, o princípio da boa-fé objetiva tem, em primeiro lugar, um caráter hermenêutico ("a"), sendo, nesse sentido, um dos vetores interpretativos não apenas da lei processual, como também dos próprios atos processuais, das partes e do juiz.

Em pelos menos dois dispositivos o Código de Processo Civil destaca a importância da boa-fé na interpretação dos atos processuais. O art. 322 dispõe que "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" e o art. 389, § 3º estabelece que também "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".

Como norma criadora de deveres colaterais ou anexos ("b"), a boa-fé objetiva estabelece, de um lado, uma série de comportamentos que necessariamente precisam ser observados pelos sujeitos do processo e, de outro, fundamenta verdadeiras proibições de determinadas condutas.

Inúmeras normas do Código de Processo Civil concretizam a referida perspectiva do princípio da boa-fé, valendo destaque para o art. 77, que dispõe serem deveres das partes: "I – expor os fatos em juízo conforme a verdade; II – não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III – não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito", entre outros deveres processuais.

A certeza que, para o sistema do Código, tais condutas têm por fundamento o dever de boa-fé está na tipificação como litigância de má-fé das posturas contrárias aos deveres suprarreferidos realizada pelo art. 80, que dispõe que "considera-se litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Nota-se da leitura do referido rol de condutas de má-fé a terceira função do princípio da boa-fé, qual seja, regulamentar o exercício de direito ("c").

Nessa perspectiva, o princípio da boa-fé objetiva constitui o verdadeiro fundamento da vedação ao abuso de direito, que pode se revelar a partir da prática abusiva de um ato processual ou mesmo pelo abuso do próprio processo.

Rodrigo D'Ório²⁵⁰ oferece um importante parâmetro para detecção da abusividade do direito: o desvio de finalidade. Assim, para o referido autor,

“no ato abusivo, haveria a implicação, ao menos em uma primeira leitura, da aparência de um regular exercício de direito do agente – que, após uma análise mais profunda, demonstraria o exercício irregular do direito, pelo desvio de finalidade”.

Assim, se arrolar testemunhas para serem ouvidas em audiência ou suscitar a suspeição do juiz são direitos das partes acobertados pelas garantias do contraditório, ampla defesa e juiz natural, é certo que provocar esta atividade de oitiva ou instaurar este incidente processual, apenas e tão somente com o intuito de atrasar a prestação jurisdicional, configuram claramente um ato abusivo e contrário ao princípio da boa-fé.

É nesse contexto que se insere o disposto no art. 80 do CPC, que nos incs. I, VI, VII proíbe o exercício de pretensões e o manejo de recursos e incidentes manifestamente infundados ou protelatórios que, obviamente, sem retirar o direito de deduzir pretensão, defesa, recorrer e suscitar incidentes, deixam claro que quando detectado o desvio de finalidade nestas atitudes da parte deve o ato ser tido como inadmissível.

Portanto, a boa-fé opera como um verdadeiro limitador do exercício de direitos processuais sempre que a prática de determinado ato escapar a sua finalidade precípua e revelar um propósito ilícito, infundado ou meramente protelatório.

6.2.6 Art. 6º do CPC: Princípio da cooperação

A par de litigarem dentro dos limites da boa-fé tal como exigido pelo art. 5º do Código de Processo Civil, as partes, por força da norma consagrada no art. 6º, possuem o dever de cooperar com o desenvolvimento do processo, sendo estas, tanto quanto o juiz e seus auxiliares, responsáveis pela qualidade do processo e da própria tutela jurisdicional.

Assim, ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” o art. 6º do Código de Processo Civil deixa claro que a

responsabilidade pela duração razoável do processo, pela justiça e efetividade da prestação jurisdicional não é apenas das partes, bem como não é apenas do Estado-juiz, mas sim de todos estes sujeitos processuais.

No modelo cooperativo imposto pelo Código de Processo Civil a condução do processo deixa de ser determinada apenas pela vontade das partes, bem como não está vinculada apenas à “vontade” do órgão jurisdicional.

Para Fredie Didier Jr.²⁵¹, o princípio da cooperação implica um redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol de sujeitos do diálogo do processo, e não um mero espectador do duelo das partes. Em suma, o art. 6º do Código de Processo Civil impõe uma condução cooperativa, sem destaque ou protagonismo de qualquer sujeito processual²⁵².

Nesse contexto, é necessária a leitura conjunta entre os deveres decorrentes dos arts. 5º e 6º do Código, uma vez que integra o modelo cooperativo a necessidade de que as partes e o próprio juiz ajam, sobretudo, de boa-fé.

Assim, cabe às partes, ainda que na defesa de seus interesses, agirem de modo a não causarem embaraços à efetividade da prestação jurisdicional, bem como à duração razoável do processo, e além disso é dever das partes contribuírem positivamente com as referidas efetividade e duração razoável, assim como com a busca pela decisão de mérito.

Ademais, no modelo cooperativo desenhado pelo Código de Processo Civil, o juiz não é apenas um observador ou fiscalizador da atividade das partes, sendo, ao lado de seus auxiliares, responsável pela qualidade do processo e da tutela jurisdicional, uma vez que este dever de prestar jurisdição justa, efetiva, em tempo razoável e preferencialmente de mérito, é do Estado e deve ser buscado e alcançado mediante cooperação de todos.

Desta feita, tanto na esfera do juiz quanto das partes, o princípio da cooperação possui uma perspectiva positiva e outra negativa, de um lado,

impondo determinadas condutas que favoreçam a duração razoável do processo, a decisão de mérito e a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, impedindo condutas meramente protelatórias e contrárias a estes valores.

Nesse contexto, a norma fundamental consagrada no art. 6º do Código não pode ser vista como uma pauta de intenções ou uma norma ético/valorativa, mas sim como uma norma capaz de irradiar efeitos concretos ora proibindo, ora impondo condutas aos sujeitos do processo.

Portanto, tal como a boa-fé, o princípio da cooperação é uma norma de conduta capaz de: a) irradiar efeitos concretos por si só; b) servir de critério interpretativo da norma e dos atos praticados pelos sujeitos processuais; e c) ser um fundamento concretizado em diversas regras constantes do Código de Processo Civil.

Considerando que o princípio da cooperação é norma de conduta capaz de irradiar efeitos por si só, Lúcio Grassi de Gouveia²⁵³, com apoio na doutrina do processualista português Miguel Teixeira de Sousa, destaca que apenas para o juiz a cooperação impõe os deveres de: a) esclarecimento, b) prevenção, c) consulta e d) auxílio.

Para o referido autor²⁵⁴, o dever de esclarecimento consiste na necessidade de o juiz ou tribunal “buscar esclarecer junto às partes eventuais dúvidas que tenha sobre as suas alegações, pedidos ou posições processuais em juízo, de forma a evitar que a decisão tenha por base a falta de informação e não a verdade apurada”. Assim, antes de indeferir determinada pretensão por não entender perfeitamente seu alcance e sentido deve o juiz franquear à parte a oportunidade de explicar suas razões e seu pedido.

Do dever de prevenção, ainda segundo Grassi²⁵⁵, decorre a necessidade de o juiz “prevenir as partes de eventuais insuficiências ou defeitos ligados aos atos processuais por ela praticados, o que deve ser conjugado com a oportunidade de estas falhas serem corrigidas pelo sujeito interessado”.

Já o dever de consulta impõe ao juiz o dever de dar oportunidade para que as partes se manifestem sobre questão ou fundamento verificado como aplicável à causa pelo próprio juiz no exercício de sua atividade judicante. Em razão disso, sempre que o juiz entender aplicável ao caso um fundamento não debatido pelas partes deve, antes de decidir com base neste fundamento, dar a oportunidade para que as partes se manifestem sobre ele, regra, aliás, expressamente constante do art. 10 do CPC a seguir comentado.

Por fim, o dever de auxílio consiste “no dever de auxiliar as partes na remoção de dificuldades ao exercício de seus direitos e faculdades e no cumprimento de ônus e deveres processuais”. Tal dever de auxílio é revelado, por exemplo, no disposto no art. 319, § 1º, que autoriza o autor da ação requerer ao juiz diligências voltadas à obtenção de informações úteis ou necessárias para a identificação do réu, como endereço, estado civil ou número de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (CNPJ).

Lúcio Grassi, igualmente, destaca o caráter hermenêutico/interpretativo do princípio da cooperação afirmando que no processo civil “deverão o intérprete, aplicador e os demais sujeitos do processo, ao interpretarem suas normas compatibilizarem-na com o princípio da cooperação intersubjetiva”, que interferirá na interpretação dos demais dispositivos legais contidos na legislação processual civil²⁵⁶.

Exemplos de regras concretizadoras do princípio da cooperação podem ser encontrados no art. 321 do CPC, que determina que o juiz “ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”; bem como na norma prevista no art. 339 do Código, que dispõe “quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito

passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento (...)."

Já na execução, um exemplo de cooperação pode ser tirado do art. 774 do CPC, que combinado com seu parágrafo único estabelece que o executado uma vez intimado possui o "dever de indicar ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de multa", tendo assim o dever jurídico de colaborar com a efetividade da execução.

Ademais, o art. 357 do Código, em seu § 3º, estabelece que "se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações".

Em comum, todas estas situações possuem o estabelecimento de deveres a sujeitos não diretamente interessados ou responsáveis pela prática do ato processual, mas que, apesar disso, possuem o dever de colaboração para que o ato seja praticado pelo outro sujeito da melhor maneira possível de modo a contribuir com o desenvolvimento do processo, este sim um interesse maior e de todos, inclusive do Estado.

A referência a todos estes dispositivos no contexto dos comentários ao art. 6º do Código de Processo Civil se faz necessária para que se deixe claro que o princípio da cooperação nele consagrado não é apenas uma pauta de intenções ou uma norma programática, mas sim uma fonte geral e abstrata de criação de um dever genérico de colaboração entre todos os sujeitos do processo.

Como todo dever jurídico-processual, o seu descumprimento não é uma opção livre de consequências por parte do sujeito, mas sim um imperativo cuja desobediência atrai uma implicação sancionatória.

Assim, o descumprimento do dever de cooperação pela parte enseja uma punição, via de regra, mediante a incidência de multa, como é o caso da já

referida situação em que cabe ao executado indicar bens penhoráveis de seu patrimônio quando assim determinado pelo juiz.

A não observância do princípio da cooperação pelo juiz também gera consequências negativas, como a nulidade do processo ou da decisão judicial proferida em desobediência a este comando.

É o caso, por exemplo, do eventual indeferimento da petição inicial sem que antes o juiz dê ao autor a oportunidade de corrigi-la ou emendá-la.

Ademais, o dever de colaboração atinge terceiros conforme deixam claro os arts. 370 e 372.

O primeiro dispõe que “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, ao passo que o segundo, concretizando essa regra, determina que “incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: I – informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento; II – exhibir coisa ou documento que esteja em seu poder”.

Igualmente cabe aos terceiros, assim como às partes, cooperarem com a efetivação dos comandos judiciais.

Nesse sentido, dispõe o art. 77, inc. V, que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “(...) cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”.

Por se tratar de verdadeiro dever de cooperação, o não cumprimento do disposto no art. 77, inc. V, pelas partes ou por terceiros acarreta a incidência de multa de até vinte por cento do valor da causa, sem prejuízo de outras sanções na esfera civil, criminal e administrativo, conforme estabelece § 2º do art. 77 do CPC.

O § 5º do mesmo art. 77 ressalva a responsabilização dos advogados nos termos do § 2º, o que não permite a conclusão de que o advogado não possui o dever de cooperar, mas apenas que eventuais faltas devem ser

apuradas pelos órgãos próprios de fiscalização, devendo eventuais punições serem impostas à luz do regime jurídico específico que rege a conduta e a ética destes profissionais.

6.2.7 Art. 7º do CPC: Princípio da igualdade (paridade de armas) e dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório

O art. 7º do Código de Processo Civil faz uma importante associação entre os princípios constitucionais da igualdade e do contraditório estabelecendo ser dever, sobretudo do juiz, zelar para que tais garantias sejam observadas ao longo do processo.

Essa fundamental, e correta, associação entre o contraditório e a igualdade de tratamento, a partir da interpretação do art. 5º, caput e inc. LV da Constituição Federal, já era feita pela doutrina pátria antes mesmo da vigência do CPC de 2015, bem como pela doutrina e legislação estrangeiras.

Nesse sentido, Nelson Nery Jr.²⁵⁷, com apoio em doutrina alemã, destaca que o contraditório implica paridade de armas, significando que deve ser dada as mesmas oportunidades para as partes (Chancengleichheit) e os mesmos instrumentos processuais (Waffengleichheit) “para que possam valer seus direitos e pretensões, ajuizando ação, deduzindo resposta, requerendo e realizando provas, recorrendo das decisões judiciais etc.”.

Na doutrina estrangeira, Comoglio, Ferri e Tarufo²⁵⁸ elencam o que entendem por conteúdo mínimo do contraditório, que abarcaria as seguintes garantias: a) igualdade das partes, não apenas em sentido formal, mas também em sentido material; b) possibilidade de defesa técnica mediante assistência profissional qualificada; c) adequação das possibilidades de alegação e produção de provas; d) direito à informação dos atos processuais; e e) direito à motivação das decisões.

O Código Civil francês, no art. 16, estabelece que “o juiz deve, em todas as circunstâncias, fazer observar e observar ele próprio o princípio do contraditório”, o que em grande parte é repetido pela norma do art. 7º do

CPC brasileiro, que dispõe “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Assim, é imperativa a conclusão no sentido de que o alcance, a extensão e as possibilidades de exercício do contraditório devem ser os mesmos para ambas as partes, sendo vedada a concessão de uma oportunidade processual apenas a uma das partes, o que desequilibraria a relação processual.

Portanto, ofenderia o disposto no art. 7º e seria intolerável a postura do juiz que sancionasse o réu em razão de determinado comportamento e deixasse de punir o autor quando este praticasse a mesma conduta, bem como resta proibido pela norma fundamental em comento permitir a apenas uma das partes participar de determinada audiência ou, mais amplamente, de toda a atividade instrutória, por exemplo.

A par do direito ao tratamento isonômico, o art. 7º do CPC deixa claro ser dever do juiz zelar por este tratamento igualitário e pelo efetivo contraditório.

Nesse sentido, vale a lição de Cândido Rangel Dinamarco²⁵⁹, para quem o juiz é um dos destinatários do princípio do contraditório, que o exerce pela prática de atos de direção, produção de prova e diálogo ao longo do processo.

Ademais, a norma responsabiliza o juiz pela efetividade do contraditório.

Segundo Dierle Nunes²⁶⁰, no sistema processual brasileiro o contraditório deve ser visto como uma “garantia de influência e não surpresa no qual se consagra o conteúdo substancial do comando normativo constitucional (art. 5º. LV) que impede, salvo exceções legais, que o juiz profira decisões com conteúdos que as partes não tenham podido debater. Assim, o contraditório não poderá mais ser aplicado tão somente como mera garantia formal de

bilateralidade de audiência, ou como garantia de simétrica paridade de armas”, pois a esta perspectiva se soma “a necessária aplicação do princípio do contraditório como uma garantia da possibilidade de influência (Einwirkungsmöglichkeit) e de debates sobre o desenvolvimento do conteúdo a ser julgado (mérito), os aspectos processuais e a formação de decisões racionais com inexistentes ou reduzidas possibilidades de surpresa”.

Tais exigências constam expressamente previstas nos arts. 9º e 10 do CPC a seguir comentados, deixando claro o art. 7º ser dever e responsabilidade do juiz ao conduzir o processo e fundamentar suas decisões, observar e promover o conteúdo destes dispositivos.

Nesse sentido portanto, cabe ao juiz tomar medidas voltadas a reequilibrar a relação processual sempre que detectar situações onde uma das partes esteja sendo excessivamente onerada ou impedida de exercer plenamente o contraditório.

Bom exemplo deste poder de reequilibrar a relação processual se revela no art. 373, § 1º do CPC, que autoriza o juiz a, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma parte produzir prova, determinar que o ônus probatório seja da parte contrária, em função de esta ter uma maior facilidade de obtenção da prova.

Em outras palavras, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso do disposto na regra geral de distribuição, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Igualmente, constituem desdobramentos concretos deste poder-dever do juiz a possibilidade de dilação dos prazos processuais nas localidades de difícil transporte e em caso de calamidade pública ou justa causa (art. 223 do CPC) e a necessidade de o magistrado nomear curador especial e intimar o Ministério Público nas causas que envolver interesse de incapaz, a teor

dos arts. 72, inc. I, e 178, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

6.2.8 Art. 8º do CPC: Princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, eficiência e dever de atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum

O art. 8º do Código de Processo Civil destaca ser fundamental que o juiz, tanto na condução do processo quanto por ocasião do julgamento, observe uma série valores e princípios não exatamente processuais, vez que mais genéricos e pertencentes a outros ramos do Direito, como o direito constitucional e direito administrativo, e a própria teoria geral do Direito.

São eles: a) a dignidade da pessoa humana, b) a proporcionalidade, c) a razoabilidade, d) a legalidade, e) a publicidade, f) a eficiência, bem como g) o atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum.

Fredie Didier Jr.²⁶¹ destaca que o dispositivo é uma espécie de consolidação em um mesmo período de diversos enunciados normativos construídos em momentos distintos da história do direito brasileiro, o que torna difícil sua interpretação harmônica.

José Miguel Garcia Medina²⁶², por sua vez, aduz que “rigorosamente, seria desnecessário fazer constar na lei ordinária que aprovou o CPC/2015, referência expressa a disposições constitucionais mais amplas, que se aplicam a todo o sistema jurídico, e não apenas ao direito processual, ou mais especificamente, ao processo civil”.

Aqui, portanto, mais uma vez, está-se diante de uma norma fundamental que possui muito mais uma função pedagógica ou simbólica do que efetiva capacidade de inovar acrescentando ou mesmo detalhando direitos ou deveres processuais.

A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental de todo o ordenamento jurídico brasileiro sendo, em grande medida, o alicerce dos demais direitos fundamentais, que podem, nesse contexto, serem entendidos como desdobramentos e concretização desta cláusula

constitucional.

Partindo da premissa de que o princípio da dignidade da pessoa humana é concretizado nos demais direitos fundamentais, Leonardo Carneiro da Cunha²⁶³ afirma que a aplicação do referido princípio ao processo coincide com a aplicação do devido processo legal, sendo certo que um processo “em que se assegurem o contraditório, a boa-fé, a imparcialidade, a publicidade, a exigência de fundamentação, e enfim que se respeitem as garantias fundamentais do processo, atende a dignidade da pessoa humana”.

A norma, portanto, não é apenas dirigida ao juiz, mas a todos os sujeitos do processo e, especificamente em relação à figura do magistrado, influencia tanto no plano processual propriamente dito quanto no momento da tomada de decisão.

Em outras palavras, o juiz deve atentar para a dignidade da pessoa humana durante a condução do processo e da prática dos atos processuais, bem como deve respeitar e promover a dignidade da pessoa humana em suas decisões.

São exemplos de desdobramentos processuais da dignidade da pessoa humana as normas que impedem a penhora de salário, de instrumentos e utensílios para o exercício de qualquer profissão, do vestuário e utensílios domésticos (art. 833 do CPC), os dispositivos que permitem a parte se recusar a exhibir nos autos documentos que digam respeito a “negócios da própria vida da família” ou que puderem “violiar a honra” (art. 404, incs. I e II do CPC), que possuem o claro intuito de resguardar os direitos fundamentais de privacidade e honra, assim como, de maneira geral, todas as normas processuais voltadas ao exercício dos direitos fundamentais.

Ademais, a dignidade da pessoa humana pode ser invocada no corpo da própria decisão de mérito. Assim, por exemplo, na falta de uma norma específica que tutele determinado direito fundamental, deve o juiz promover esta proteção com fundamento no princípio da dignidade da

pessoa humana.

A proporcionalidade já comentada no item 6.1.3.1, “f”, consiste em uma técnica de solução de conflito de princípios de igual hierarquia constitucional que permite ao juiz, sopesando os valores em jogo, decidir por sacrificar determinado direito ou garantia em razão das necessidades de atendimento de outro direito ameaçado no caso concreto.

Não se trata de um princípio processual, tendo origem e ampla aplicação no Direito Público notadamente administrativo e constitucional.

Willis Santiago Guerra Filho²⁶⁴ aduz que a identificação da proporcionalidade como um princípio jurídico se configurou no campo de Direito Administrativo e voltava-se a limitar o poder de polícia. A aplicação da proporcionalidade sustentada nesse campo, naquele momento histórico, fundamentava a noção atualmente consagrada no sentido de que o Estado só está autorizado a interferir na esfera individual do cidadão, limitando sua liberdade, na medida em que for necessária para que se mantenha a liberdade e segurança de todos.

Guerra Filho ainda destaca que coube ao Tribunal Constitucional alemão elevar ao nível constitucional o princípio da proporcionalidade, ressaltando, nesse campo, o papel do tribunal na resolução dos conflitos entre direitos fundamentais, citando inclusive a primeira decisão do “Bundesverfassungsgericht”, que consagra a proporcionalidade como técnica de resolução de conflitos entre direitos fundamentais, donde se depreende a seguinte construção:

O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para que seja atingido o fim almejado. O meio é adequado, quando com seu auxílio se pode promover o resultado desejado; ele é exigível, quando o legislador não poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria um meio não prejudicial ou portador de uma limitação menos perceptível a direito fundamental²⁶⁵.

O princípio da proporcionalidade, portanto, dirige-se não apenas ao juiz, a teor do art. 8º do CPC, mas também ao próprio legislador, processual inclusive.

No plano processual, conforme já asseverado no item 6.1.3.1, “f”, a proporcionalidade tem lugar quando o juiz deparar com a impossibilidade de atender plenamente o contraditório e ampla defesa que demanda tempo e dilação de prazo para o réu, em situações de urgência onde este tempo aniquilaria o direito do autor.

Essa preocupação, inclusive, também se encontra na lei processual a exemplo do art. 9º, § 1º inc. I, do Código de Processo Civil, que autoriza a já comentada postergação do contraditório em situações de urgência²⁶⁶.

A par de impor a observância da proporcionalidade, o art. 8º do CPC determina que o juiz observe a razoabilidade.

Apesar de, em linguagem laica, as expressões proporcional e razoável poderem ser usadas no mesmo sentido, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se diferenciam em uma linguagem técnico-jurídica, segundo Virgílio Afonso da Silva²⁶⁷, pela sua origem e pela sua estrutura.

Isso porque, enquanto a proporcionalidade tem origem na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão e implica uma análise acerca de três elementos independentes, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, a razoabilidade limita-se apenas à compatibilidade do meio empregado e aos fins visados pelo legislador, confundindo-se, nessa medida, apenas com o subprincípio da adequação, mas nunca com a proporcionalidade como um todo.

Igualmente, Gustavo Ferreira Santos²⁶⁸ sustenta que a proporcionalidade e a razoabilidade “não são conceitos fungíveis. Cada um, além de uma fundamentação própria, possui elementos caracterizadores que marcam uma diferença operacional: a razoabilidade trata da legitimidade da escolha dos fins em nome dos quais agirá o Estado, enquanto a proporcionalidade

averigua se os meios são necessários, adequados e proporcionais aos fins já escolhidos”.

No entanto, apesar das distinções, o art. 8º do Código de Processo Civil autoriza que o juiz se valha tanto do princípio da proporcionalidade quanto da razoabilidade quando da interpretação e aplicação da lei processual na condução do processo, e da própria lei material quando do proferimento de sua decisão.

Ao aplicar estas normas extremamente abstratas e genéricas deve o juiz atentar para a necessidade de justificativa racional de tal utilização.

Em outras palavras, não basta constar da decisão a justificativa de que o seu sentido e sua conclusão estão fundamentados na razoabilidade ou na proporcionalidade previstas no art. 8º, cabendo ao juiz fundamentar concretamente em que medida tais princípios estão influenciando o processo de tomada de decisão.

Incide, nesse contexto, o art. 489, § 1º, inc. II do CPC, que impõe ao juiz, ao utilizar conceitos jurídicos indeterminados, o dever de explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

O art. 8º do CPC também incorpora princípios gerais da Administração Pública referidos no art. 37 da Constituição Federal, que dispõe: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Aqui, mais uma vez, não se está diante de normas processuais civis, mas sim de normas voltadas à disciplina da atuação e postura do juiz enquanto agente público integrante de “um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal”.

A legalidade, publicidade e eficiência estão repetidas no art. 8º do Código, o que não exclui a necessidade de observância pelo juiz também dos princípios da moralidade e impessoalidade.

O dever do juiz de observar a legalidade é decorrência do devido processo legal já referido no item 6.1.4.10 supra, valendo apenas, neste passo, reiterar que o princípio da legalidade não implica “apenas” a observância da lei, mas do ordenamento jurídico como um todo, seus valores e princípios constitucionais, conforme deixa claro entre outros dispositivos o art. 1º do Código e o próprio art. 8º, ora em comento.

A publicidade é mais uma vez referida, tal como está nos arts. 5º, inc. LX, e 93, IX, da Constituição Federal, assim como no art. 11 do CPC, não trazendo, nesse campo, a norma do art. 8º nenhum acréscimo ou detalhamento concreto.

Ademais, o art. 8º determina expressamente que o juiz se oriente e promova a eficiência, como, aliás, deve se pautar todo agente público por força da Constituição Federal.

A eficiência já referida nos comentários à norma fundamental constante do art. 4º do Código de Processo Civil e ao próprio princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, constante do art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal, se traduz, em síntese, no dever do juiz de buscar a entrega de uma tutela jurisdicional justa, efetiva e em tempo razoável, evitando a prática de atos processuais inúteis ou desnecessários e proporcionando àquele que tem razão não apenas o reconhecimento judicial desta posição, como também a concretização no plano dos fatos do direito reconhecido no pronunciamento jurisdicional.

6.2.9 Arts. 9º e 10 do CPC: O contraditório prévio e substancial e a vedação de decisões surpresa

O princípio do contraditório expressamente consagrado no art. 5º, inc. LV da Constituição Federal, é detalhado por duas normas fundamentais no Código de Processo Civil: os arts. 9º e 10.

O art. 9º, em seu caput, dispõe que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” e nessa medida deixa

claro que o direito constitucionalmente garantido de influir e participar da construção da decisão judicial deve ser exercido anteriormente à tomada desta decisão.

Em outras palavras, o Código de Processo Civil deixa fora de dúvidas que a garantia constitucional do contraditório só é atendida quando a parte tenha ciência e possa apresentar suas razões antes de a decisão jurisdicional ser proferida, não sendo suficiente que a informação e a possibilidade de reação sejam oportunizadas após a tomada de decisão.

A conclusão já poderia decorrer diretamente da norma constitucional constante do art. 5º, inc. LV, mas é no mínimo didático, pedagógico e, portanto, saudável que o Código deixe clara a necessidade de contraditório prévio.

A norma fundamental, ademais, é concretizada em determinadas situações, para que não haja dúvidas de que a parte que potencialmente possa vir a ser prejudicada deva ser previamente cientificada e possa reagir, influir e participar da decisão antes que esta seja tomada, exercendo contraditório prévio, portanto.

É o caso da responsabilização dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, admissível pelo direito material (ex.: art. 50 do Código Civil), que pressupõe a instauração do incidente de desconsideração, em que o sócio será citado para demonstrar não ter responsabilidade pela dívida ou, mais amplamente, exercer contraditório prévio à decisão que imponha sua responsabilização²⁶⁹.

A mesma preocupação com a prévia informação da parte, que exemplifica a exigência de contraditório prévio, encontra-se no art. 373, § 1º do CPC, que determina que “a inversão do ônus da prova deve ser comunicada à parte previamente para que ela possa se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Tais situações, entre muitas outras que aqui poderiam ser exemplificadas, ao homenagearem o contraditório prévio impedem que a parte seja “pega de surpresa” por uma decisão judicial que determine, por exemplo, a responsabilização do sócio ou redistribua o ônus da prova sem que a parte prejudicada tenha tido a oportunidade de participar simplesmente por não ter sido cientificada da situação, o que claramente ofende a garantia constitucional.

A exigência do contraditório prévio estabelecida no art. 9º, caput do CPC, cede lugar em algumas situações excepcionais.

As exceções, nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno²⁷⁰, “representam hipóteses de prestação de tutelas jurisdicionais que, por sua própria natureza, seriam frustradas pelo tempo necessário ao estabelecimento do prévio contraditório ou se mostram aprioristicamente desnecessárias pela evidência do direito afirmado (e comprovado) pelo autor”.

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 9º estabelece que não se aplica o disposto no caput: a) à tutela provisória de urgência; b) às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incs. II e III; e c) à decisão prevista no art. 701 do CPC.

A primeira situação, certamente a hipótese mais comum de exceção à norma que estabelece o contraditório prévio, tem lugar em situações onde o tempo do perfazimento do contraditório é incompatível com a situação a ser tutelada, que restaria impossível de ser protegida caso as providências tipicamente ligadas ao contraditório, como a comunicação da parte e o prazo para sua manifestação, fossem previamente realizadas.

Nesse contexto de urgência, caracterizada pelo risco de inutilidade ou inefetividade do provimento final em razão do tempo natural necessário à promoção do contraditório prévio, o art. 9º, parágrafo único, inc. I, do CPC, autoriza o juiz a proferir decisão antes de ouvir a parte contrária.

É o caso, por exemplo, de um pedido de fornecimento de medicamento

ou qualquer outro tratamento de saúde em que reste configurada a impossibilidade de concessão de prazo para prévia manifestação da parte contrária, sob pena de morte ou agravamento do estado de saúde do autor.

Nessas situações, por força da exceção prevista no art. 9º, parágrafo único, inc. I do CPC, o juiz pode determinar o início do tratamento de saúde ou fornecimento do medicamento antes mesmo de dar ao réu a oportunidade de se manifestar.

Ainda assim, vale registrar que a tutela concedida com fulcro no art. 9º, parágrafo único, inc. I, além de excepcional, é provisória, isto é, sujeita a confirmação, modificação ou cassação em um segundo momento, após a realização do contraditório.

Portanto, ainda que excepcionado o contraditório prévio, o direito ao contraditório em si permanece possível de ser exercido, em um momento ulterior (após decisão que concede a tutela de urgência). Nestes casos, portanto, o contraditório é postergado, mas não totalmente suprimido.

Outra situação em que é expressamente admitida a tomada de decisão sem prévio contraditório está no art. 9º, parágrafo único, inc. II, que autoriza o juiz a conceder tutela de evidência sem a oitiva prévia do réu, nas hipóteses do art. 311, incs. II e III.

A tutela de evidência, já abordada item 4.2.2, “b”, desta Introdução, se caracteriza pela possibilidade de o magistrado, antes do final do procedimento, permitir que o autor usufrua o bem jurídico pretendido, em função da altíssima probabilidade de vitória, demonstrada, de plano.

Contudo, apesar de ser concedida com base nesta grande probabilidade, a tutela de evidência possui as características de toda tutela provisória, notadamente, a modificabilidade e a sujeição à confirmação ao final do processo, podendo, inclusive, ser revogada, caso a situação que aparentemente demonstrava a altíssima possibilidade de vitória do autor, ao final, se mostre destituída de fundamento.

Portanto, aqui o sistema permite que, em razão da grande probabilidade de vitória do autor, o juiz provisoriamente e sem a prévia oitiva do réu, reconheça o direito deste e tutele o bem jurídico por ele pleiteado.

Entretanto, em que pese a altíssima probabilidade de vitória do autor, o direito ao contraditório do réu resta preservado, podendo ser exercido a posteriori.

A terceira exceção, estabelecida no art. 9º, parágrafo único, inc. III do CPC, está ligada à tutela de evidência no procedimento monitório, onde fica autorizada a expedição do mandado de pagamento direcionado ao réu antes que este seja previamente ouvido.

Contudo, este mandado de pagamento não representa uma ordem definitiva e, de rigor, não retrata uma condenação, pois, no âmbito do procedimento monitório em que esta ordem é expedida, o réu tem o direito de, ao invés de cumprir a determinação judicial, opor defesa, via embargos (art. 702 do Código de Processo Civil).

Tais embargos, em primeiro lugar, suspendem os efeitos da ordem de pagamento proferida sem o contraditório prévio e, ademais, abre a discussão a respeito do direito retratado no documento apresentado pelo autor.

Desta feita, a decisão referida no art. 9º, parágrafo único, inc. III do CPC, ainda que tomada antes da oitiva do réu no procedimento monitório, não suprime seu direito ao contraditório, que pode ser plenamente exercido pelo réu, via embargos.

Ademais, este exercício obriga o juiz a decidir sobre o direito do autor, não estando esta segunda decisão vinculada, ou sequer influenciada, pelo decidido na primeira manifestação jurisdicional.

Assim, não há prejuízo ao réu pelo não exercício do contraditório prévio, o que torna também essa exceção compatível com o sistema processual.

Ademais, complementando a norma do art. 9º, o Código de Processo Civil

no art. 10 se preocupa em estabelecer que o contraditório além de prévio seja substancial, isto é, efetivamente relacionado com os fundamentos considerados pelo juiz como relevantes e determinantes para a tomada de decisão.

Nesse sentido, dispõe o art. 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

O intuito da norma, conforme ressaltado por Welder Queiroz dos Santos²⁷¹, é evitar a prolação das denominadas “decisões surpresas”, assim entendidas as “decisões judiciais que contenham questões de fato ou de direito que não tenham sido previamente oportunizadas ao debate” e que, por força do princípio do contraditório e do art. 10 do Código de Processo Civil, são vedadas pelo Direito brasileiro.

Desta feita, caso surja uma questão nova ainda não debatida pelas partes, antes de considerá-la e tomá-la como fundamento da decisão, o juiz deve dar a oportunidade para que as partes se manifestem.

Portanto, não basta que às partes seja dada oportunidade de serem previamente ouvidas, fazendo-se necessário que nesta oportunidade tenha havido prévio debate sobre os pontos tidos pelo juiz como fundamentais para o proferimento de sua decisão.

Assim, em um caso, por exemplo, em que as partes tenham debatido a situação litigiosa à luz do Código Civil, não pode o juiz sem previamente ouvi-las entender que, por tratar-se de relação de consumo, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, com base neste diploma, ditar a solução da lide.

Nestas situações, caso o juiz entenda tratar-se de relação de consumo e, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Civil, tal como debatido pelas partes, deve, antes de aplicar o CDC, dar a

oportunidade às partes para que estas se manifestem sobre a aplicação, interpretação e alcance da lei consumerista à causa.

Uma decisão do juiz fundamentada em dispositivos e razões jurídicas não expressa e previamente debatidas pelas partes é uma decisão nula por ferir o disposto no art. 10 do CPC, ora em comento²⁷².

A referida lógica do contraditório prévio e efetivo se aplica inclusive nas situações em que o juiz não só pode como deve verificar e decidir de ofício, ou seja, independentemente de provocação das partes, como nulidades processuais e prescrição²⁷³.

Nessas hipóteses, a aplicação do art. 10 não leva à conclusão no sentido de que o juiz está proibido de decidir sobre determinadas questões de ofício, mas apenas impõe que as partes possam se manifestar sobre a questão antes da tomada da decisão.

Assim, detectando o juiz que o direito do autor pode estar prescrito, antes de decidir sobre a prescrição deve o juiz conceder um prazo para que as partes “digam sobre” a prescrição, oportunidade em que estas, no exercício do contraditório, podem esclarecer que a prescrição não se operou por qualquer motivo.

Essa necessidade, repita-se, se aplica a qualquer situação em que o juiz vislumbre a aplicabilidade de um fundamento não debatido pelas partes, sendo nula a decisão que não promova o contraditório prévio e efetivo exigido pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

6.2.10 Art. 11 do CPC: Princípios da publicidade e motivação

O art. 11 do Código de Processo Civil dispõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” e, portanto, simplesmente repete o art. 93, IX da Constituição Federal.

Por essa razão, é inevitável a remissão aos itens 6.1.4.5 e 6.1.4.6, dedicados aos referidos princípios da publicidade e motivação,

respectivamente.

A concretização da referida norma constitucional está em um parágrafo que acabou sendo inserido no art. 489 do Código de Processo Civil em vez de complementar o caput do art. 11, certamente o local mais apropriado.

Portanto, da leitura do caput do dispositivo não há nenhum acréscimo ou concretização, ou mesmo conclusão mais específica a ser tirada que não aquelas já referidas nos itens 6.1.4.5 e 6.1.4.6, do presente capítulo, dedicados aos comentários dos princípios da motivação e publicidade, que inclusive também se dedica ao disposto no art. 489, § 1º do CPC, que estabelece algumas situações em que não se considera fundamentada a decisão jurisdicional.

6.2.11 Art. 12: Ordem cronológica de julgamento

O último dispositivo integrante do Capítulo I do CPC dedicado às normas fundamentais do Processo Civil brasileiro encerra uma regra, não absoluta, que impõe o julgamento dos processos na ordem cronológica que venham a ser apresentados e levados à conclusão.

O dispositivo, em última análise, busca concretizar o princípio da isonomia, impondo que todos, indistintamente, sejam tratados com igualdade evitando, de um lado, privilégios e, de outro, prejuízos injustificados quando da tramitação dos feitos.

Leonardo Carneiro da Cunha²⁷⁴, a par da referência ao princípio da igualdade, sustenta que a ordem cronológica concretiza o princípio da impessoalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal e, com apoio na doutrina de Antônio do Passo Cabral²⁷⁵, demonstra que o respeito à ordem cronológica concretiza, de igual modo, o princípio da razoável duração do processo, “evitando prolongamento indefinido para julgamento de processos conclusos há muito tempo”.

Portanto, como regra geral, tanto a ordem em que os processos devem ser levados à conclusão como a sequência em que os julgamentos devem

ser proferidos pelo juiz devem observar a ordem cronológica.

Nesse contexto, merece destaque o art. 153 do CPC, que dispõe que “o escrivão ou chefe de secretaria deverá obedecer à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais”.

Cumprе destacar, todavia, que a expressão “preferencialmente”, constante do dispositivo, revela a possibilidade de, à luz de situações concretas, o juiz poder flexibilizar a ordem cronológica.

Essa flexibilização se justifica sempre que a alteração da ordem cronológica do julgamento for apta a viabilizar a administração dos feitos e a facilitar o proferimento de decisões de maneira mais célere, racional e eficiente.

É o caso, por exemplo, do juiz que, diante de uma causa altamente complexa do ponto de vista jurídico ou fático/probatório que atinja o “topo da lista”, não fique totalmente impedido de decidir outras causas “mais simples” enquanto busca a solução para a causa complexa.

A regra, portanto, confia ao juiz a possibilidade de realizar a gestão dos feitos, mitigando o rigor da ordem cronológica, para fins de maximização dos princípios da eficiência processual e da própria duração razoável do processo, que poderiam ficar seriamente comprometidos caso a regra fosse absoluta e chegasse ao “topo da lista” um processo altamente complexo que impediria o proferimento de decisão em todos os demais feitos conclusos.

A par de estabelecer, ainda que não de maneira absoluta, a regra do julgamento cronológico, o art. 12 do Código de Processo Civil, em seus parágrafos, estabelece uma série de deveres auxiliares voltados a efetivação e fiscalização da norma constante do caput.

Assim, são exigências dos dispositivos, decorrentes da ordem cronológica: a) a elaboração de lista de processos aptos a julgamento; e b) a publicização desta lista, que deverá estar permanentemente à disposição

para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores.

Tais regras têm por objetivo estabelecer mecanismos concretos para que a ordem cronológica seja respeitada e que sua observância seja fiscalizada pelos interessados.

Além da flexibilização constante do caput, decorrente do termo “preferencialmente”, o próprio Código, no art. 12, § 2º, exclui da regra do caput uma série de decisões aptas a serem proferidas fora da ordem cronológica, tais como as sentenças homologatórias de acordo; o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos; as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça; entre outras.

Obviamente, nestas situações expressamente abarcadas pela lei, a desobediência à ordem cronológica não ofende a regra geral do art. 12 do CPC ou mesmo o princípio da isonomia.

Capítulo 7 Funções Essenciais à Justiça

A Constituição Federal, a par de organizar os três poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário, dedica, no mesmo Título, um quarto capítulo, denominado “Funções Essenciais à Justiça”.

A previsão encontra-se no Capítulo IV, do Título IV, “Da Organização dos Poderes”, que disciplina as “Funções Essenciais à Justiça”, assim entendidas as Instituições, tidas pela Constituição Federal como fundamentais para o Estado Democrático de Direito, cujos papéis e missões ali delineados se voltam a interagir, fiscalizar e, dentro de suas esferas de atribuições, contribuir para a observância da ordem jurídica por todos, inclusive pelos próprios órgãos e Poderes do Estado.

Quatro são as funções essenciais à Justiça, nos termos da Constituição: a) o Ministério Público; b) a Advocacia Pública; c) a Defensoria Pública; e d) a Advocacia.

Nota-se que, das quatro instituições referidas, três são públicas, no sentido de mantidas pelo Estado e integradas por servidores ou agentes públicos (isto é, funcionários de carreira ingressos em seus quadros por prévia aprovação em concurso público de provas e títulos): a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e o Ministério Público.

Assim, a única instituição tida pela Constituição Federal como essencial à Justiça cujos integrantes não compõem uma carreira pública é a Advocacia, o que não implica dizer que o advogado não exerça um múnus público, uma vez que “indispensável à administração da Justiça”.

Por essa razão, a atividade do advogado privado é regulamentada em lei e fiscalizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos mais adiante comentados.

As demais funções essenciais à Justiça são estruturadas e mantidas pelo

Estado, que tem o dever de, além de criá-las, prover estrutura e condições para que seus membros possam exercer suas funções, com independência, nos termos determinados pela Constituição, ou mais amplamente pelo ordenamento jurídico.

É fundamental, para o entendimento do Direito Processual Civil, a compreensão das missões constitucionais e da estrutura de cada uma destas instituições essenciais à Justiça que, apesar de não existirem exclusivamente para atuarem no processo civil, exercem neste ambiente funções indispensáveis à formação e ao desenvolvimento do processo.

Assim, considerando a inércia da jurisdição, não seria exagero afirmar que, sem as “funções essenciais à Justiça”, o processo não poderia existir e se desenvolver válida e regularmente, pois a provocação, indispensável para o início de qualquer processo, deve ser feita, como regra geral, pelos integrantes destas instituições, bem como é fundamental para o válido desenvolvimento do feito a participação de seus representantes.

Os itens a seguir serão dedicados a um panorama geral da estrutura e das missões institucionais de cada uma das “funções essenciais à Justiça”, com foco, especialmente, no papel de cada uma destas instituições no processo civil.

7.1 Ministério Público

A origem do Ministério Público está no direito penal, uma vez que este ente estatal, historicamente, é consagrado pelo ordenamento jurídico como o titular da ação penal, assim entendido o poder de dar início ao processo penal, cujo mérito é a apuração da prática de um fato delituoso e, em caso positivo, a fixação da pena ao acusado²⁷⁶.

A lógica da titularidade da ação penal difere da regra geral do Direito Processual Civil, que, salvo exceções, autoriza apenas o titular do direito lesado ou ameaçado a buscar em juízo sua proteção ou reparação²⁷⁷.

Isso porque, quando da prática de um crime, ainda que seja possível a

identificação de alguém que veio a ter seu patrimônio lesado – a vítima –, o sistema jurídico entende ter sido ofendida toda a sociedade, sendo interesse de todos a persecução penal do criminoso.

A representação em juízo deste interesse social na acusação, no julgamento e na eventual punição do criminoso é realizada pelo Ministério Público no âmbito do processo penal.

A compreensão desta gênese até hoje presente na definição das missões institucionais do Ministério Público é fundamental para o entendimento de suas funções, inclusive no processo civil.

Isso porque, ao lado da defesa do interesse social pela via da ação penal, o ordenamento jurídico atribui ao Ministério Público a defesa destes interesses também por outras vias, extraprocessuais e processuais civis.

Nesse sentido, deve ser compreendida a norma constante do art. 127 da Constituição Federal, que afirma ser o Ministério Público “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

O dispositivo é complementado, entre outras normas, pelo art. 129, também da Constituição Federal, que dispõe serem funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los,

na forma da lei complementar respectiva; VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Da leitura dos dispositivos constitucionais, nota-se que, a par da titularidade da ação penal, referida no inc. I do art. 129, outras funções são extraprocessuais, como as dispostas, por exemplo, nos incs. VI, VII e VIII, o u exercitáveis pela via do processo civil, tais como, especialmente, a propositura da ação civil pública, prevista no inc. III.

Ademais, o inc. IX do referido artigo permite que a lei confira ao Ministério Público outras funções compatíveis com sua finalidade, o que é feito pelo Direito Processual Civil, em especial ao atribuir ao MP o papel de fiscal da ordem jurídica, conforme se verá a seguir.

Para esta Introdução interessam, especialmente, as funções do Ministério Público no processo civil.

Nesse contexto, ver-se-á adiante que os dois principais papéis do Ministério Público no processo civil são: a) ser autor de ações coletivas voltadas à tutela de direitos difusos ou coletivos, de titularidade, portanto, de toda a sociedade ou de um grupo expressivo desta; e b) atuar como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam incapazes ou qualquer outra questão de interesse público ou social, assim definido pela lei ou pela própria Constituição.

Os principais diplomas legais que definem e disciplinam a esfera de atribuições do Ministério Público, complementares às já referidas normas constitucionais, são: a) a Lei Complementar n. 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; b) a

Lei n. 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público; c) as leis que regem o processo coletivo, dentre as quais se destacam a Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90); e, obviamente, d) o Código de Processo Civil, que dedica o Título V, do Livro III, da Parte Geral ao papel desta instituição no processo civil (arts. 176 a 181 do CPC).

O art. 176 do CPC praticamente repete a letra da Constituição ao dispor que: “O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis”, ao passo que o art. 177 do Código não inova, apenas determinando que: “O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais”.

Já o art. 178 do CPC dispõe que o Ministério Público atuará como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam: “I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana”, tema que será pormenorizado no subitem 7.1.2, “b”, infra.

Outro papel fundamental do MP no Processo Civil é previsto na Lei Complementar n. 75/93, devendo dela ser destacado o art. 6º, que dispõe sobre os instrumentos de atuação, e, especialmente, o inc. VII, que consagra o dever-poder do Ministério Público de promover o inquérito civil e a ação civil pública para: a) a proteção dos direitos constitucionais; b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos.

Ademais o art. 6º, inc. VIII, da Lei Complementar n. 75/93 estabelece a possibilidade de o MP “promover outras ações, nelas incluído o mandado de

injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos”.

O papel do Ministério Público como autor de ações coletivas será pormenorizado no item 7.1.2, “a”, infra, e o papel de Ministério Público fiscal da ordem jurídica, no item subsequente (7.1.2, “b”).

Antes disso, para melhor entendimento, serão tecidas breves considerações sobre a estrutura e as carreiras do Ministério Público.

7.1.1 Estrutura e carreiras integrantes do Ministério Público

Tal como a estrutura do Poder Judiciário, o Ministério Público é dividido em duas esferas federativas, coexistindo, portanto, o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos estaduais.

Assim, ao lado do Ministério da União, cada Estado da federação tem por dever organizar e estruturar, por lei, seu próprio Ministério Público.

O Ministério Público da União subdivide-se organizacionalmente em: a) o Ministério Público Federal; b) o Ministério Público do Trabalho; c) o Ministério Público Militar; e d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

O primeiro possui atuação perante a Justiça federal comum, ao passo que cada um dos braços especializados do Ministério Público, o do Trabalho e o Militar, atua justamente perante a Justiça especial equivalente.

Já o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem atuação perante a Justiça Comum do Distrito Federal e Territórios, enquanto cada Ministério Público estadual atua perante a Justiça comum de cada Estado.

Conforme já asseverado, o ingresso nos quadros do Ministério Público, qualquer que seja a esfera – federal ou estadual – só pode se dar por concurso público de provas e títulos.

Via de regra, o concurso de ingresso no Ministério Público Federal é para o cargo de procurador da República, ao passo que o ingresso nos quadros do Ministério Público estadual é para a carreira de promotor de Justiça.

Em segundo grau de jurisdição, são representantes do Ministério Público Federal os procuradores regionais da República, com atuação perante os tribunais regionais federais; e os membros dos Ministérios Públicos estaduais atuantes perante os tribunais de Justiça são denominados procuradores de Justiça.

A chefia do Ministério Público da União é realizada pelo Procurador-Geral da República.

Já os Ministérios Públicos dos Estados são chefiados pelos seus respectivos Procuradores-Gerais de Justiça.

O art. 43 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93) estabelece um rol de deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei, dentre os quais se destacam, no que tange à esfera processual civil, os de: a) indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal; b) obedecer aos prazos processuais; c) assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua presença.

Para garantir o livre exercício das suas funções, sem ingerência de qualquer outro Poder ou autoridade, a lei concede ao membro do Ministério Público determinadas garantias.

Nesse contexto, destaca-se o art. 38 da Lei n. 8.625/93, que estabelece que os membros do Ministério Público se sujeitam ao regime jurídico especial e têm as seguintes garantias: I – vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público; III – irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o disposto na Constituição Federal.

A vitaliciedade somente pode ser afastada por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, em casos extremamente graves e expressamente previstos em lei.

Tais garantias se justificam, especialmente, em razão de estar na esfera de atribuições do membro do MP o dever de fiscalizar e punir os próprios membros dos demais Poderes e autoridades constituídas, tanto na esfera penal quanto na esfera civil.

De outro lado, ao membro do Ministério Público é vedado o exercício de determinadas atividades tidas pela lei como incompatíveis com as funções de promotor, procurador de justiça ou procurador da República.

Nesse sentido, a Lei n. 8.625/93, em seu art. 44, proíbe aos membros do Ministério Público: I – receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; II – exercer advocacia; III – exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista; IV – exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de Magistério; V – exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.

É nesse contexto de deveres, prerrogativas, garantias e vedações estabelecidos na Lei e na Constituição que o membro do Ministério Público exerce seu mister, como dito, não apenas, mas também no Processo Civil.

Aos dois principais papéis do Ministério Público no processo civil serão dedicados os subitens a seguir.

7.1.2 Especialmente sobre os papéis do Ministério Público no Processo Civil

a) Ministério Público, autor de ações coletivas

Uma das principais funções do Ministério Público no processo civil, voltada ao atingimento de sua missão institucional, notadamente a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis, nos termos estabelecidos pelo art. 127 da Constituição Federal, é poder atuar como autor de processos coletivos.

Esse método de prestação jurisdicional, conforme já asseverado no item 4.2.3, em apertada síntese, caracteriza-se por voltar-se a tutelar direitos metaindividuais, por meio da autorização para agir em juízo, dada a órgãos e entidades tidas pela lei como representativas de grupos sociais ou de toda a sociedade, aliada à atribuição de eficácia erga omnes ou ultra partes às decisões proferidas naquela sede²⁷⁸.

Considerando que o direito tutelado pelo Ministério Público quando desta atuação não pertence à instituição, mas, sim, a toda a sociedade, a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos difusos e coletivos deve apoiar-se em expressa previsão legal.

Nesse contexto, destacam-se, entre outras, as previsões expressas no art. 82, inc. I, da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); no art. 92 do Código de Defesa do Consumidor; e no art. 201, inc. V, da Lei n. 8.069/90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Todas as previsões legislativas supracitadas dispõem sobre a legitimidade do Ministério Público para tutelar direitos difusos ou coletivos, em especial de grupos e categorias de pessoas tidas pelo próprio ordenamento jurídico como vulneráveis.

Por direitos ou interesses difusos, devem ser entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

Os direitos ou interesses coletivos, por sua vez, caracterizam-se por serem transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

Por fim, também tutelável pela via de processo coletivo são os direitos individuais homogêneos, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum,

de natureza divisível e que abarcam um grupo de indivíduos.

A vulnerabilidade de determinados grupos também decorre do expresse reconhecimento pelo ordenamento jurídico, como é o caso dos próprios consumidores, idosos, crianças e adolescentes, indígenas, entre outros.

Vale ressaltar que a legitimidade do Ministério Público nestes casos não é exclusiva, havendo outros sujeitos, públicos e privados, com legitimidade para atuarem como autores de ações coletivas, por exemplo: outras instituições “essenciais à Justiça” (como a Defensoria Pública e a Advocacia Pública), sindicatos e associações constituídos há mais de um ano, além da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que pode ser entendida como a entidade representante da Advocacia.

De todo modo, quando as ações coletivas vierem a ser propostas por outros legitimados, é papel do Ministério Público atuar como fiscal da ordem jurídica nestes processos.

Em síntese, a atuação do Ministério Público como autor de ações coletivas na defesa de interesses difusos e coletivos historicamente vem se mostrando de fundamental importância para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo os instrumentos aqui brevemente referidos as principais formas de atuação do MP no atingimento de suas finalidades institucionais pela via do processo civil.

b) Ministério Público, fiscal da ordem jurídica

Conforme já asseverado, uma das missões institucionais do Ministério Público no processo civil é atuar como fiscal da ordem jurídica.

Em outras palavras, pode ser exigida a participação do Ministério Público sempre que a lei ou a própria Constituição identificarem esta necessidade em razão do interesse social.

Nesse sentido, o art. 178 do Código de Processo Civil dispõe que o

Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; II – interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Entretanto, o CPC não encerra taxativamente as hipóteses em que o Ministério Público deve atuar, deixando clara esta necessidade nos casos dos processos que envolvam interesses de incapazes e litígios coletivos de posse de imóveis, bem como abrindo, tanto no caput quanto no inc. I, a possibilidade de atuação do MP como fiscal da ordem jurídica, em outras hipóteses que envolvam interesse público ou social, além daquelas previstas em outros diplomas legais.

São casos previstos em outros diplomas legais, por exemplo, o art. 12 da Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), o art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e o art. 92 do Código de Defesa do Consumidor, sendo todos temas que escapam ao objeto desta Introdução.

Ademais, sempre que o processo envolva o interesse público ou social, o Ministério Público deve atuar como fiscal da ordem jurídica.

Essa intervenção consiste: a) na necessidade de intimação do Ministério Público para que este possa ter ciência da existência do processo que envolva interesse público ou social ou outra situação tida pela lei como determinante para sua atuação; b) na possibilidade de manifestação do membro do Ministério Público no processo antes do julgamento; e c) na admissibilidade de ampla participação do membro do MP nas demais etapas e fases do processo, sendo-lhe facultados a participação em audiências, a requisição de provas, a interposição de recursos e quaisquer outros atos voltados à tutela do bem jurídico que justifiquem sua presença no processo.

A intimação do Ministério Público é exigência do art. 178 do CPC, que dispõe que o órgão será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica.

O dispositivo é complementado pelo art. 179 do Código, que estabelece que, nos casos em que a lei exigir a intervenção, o Ministério Público: I – terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II – poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Essa intervenção, em princípio, traduz-se na apresentação de um parecer, manifestação pela qual o membro do Ministério Público expõe sua opinião, fundamentando-a juridicamente e requerendo as providências que entender necessárias para correta tutela dos direitos e interesses por cuja proteção tem por missão zelar.

Conforme deixa claro o já citado art. 179 do Código, a intervenção do Ministério Público não se limita à apresentação do parecer, podendo seu representante provocar a atividade probatória, requerer as medidas processuais pertinentes, recorrer e participar amplamente do processo.

Apesar de ser sobremaneira importante a efetiva participação do membro do Ministério Público nos processos em que a lei assim o exigir, caso, devidamente intimado, não apresente o parecer no prazo de 30 dias, o feito deve prosseguir.

Nesse sentido, o art. 180, § 1º, do CPC dispõe que, findo o prazo de 30 dias para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo.

Caso não ocorra a prévia intimação do Ministério Público quando o ordenamento jurídico assim o exigir, o processo é nulo, conforme deixa claro o art. 279 do CPC. Entretanto, nos termos do § 2º do citado dispositivo, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

A razão de ser desta prévia oitiva do Ministério Público sobre a existência de prejuízo ao interesse público é viabilizar o eventual aproveitamento do processo em que não se deu a intimação do membro do MP, notadamente

nos casos em que, apesar de participar da referida oportunidade de intervenção, o bem jurídico ou sujeito que justificava a participação do Ministério Público foi, em última análise, protegido²⁷⁹.

7.2 Advocacia Pública

A submissão do Estado ao poder jurisdicional implica, em última análise, a possibilidade de este vir a ser demandado em juízo, ocupando a posição de réu, bem como ter de buscar o Judiciário para exercer suas pretensões e direitos contra os particulares, atuando nesta hipótese na qualidade de autor.

Essa potencial e comum posição de parte processual do Estado leva à necessidade de este sujeito praticar atos processuais por intermédio de seus representantes e advogados, dada a exigência de capacidade postulatória para fins de exercício dos direitos processuais.

O Estado em juízo é comumente denominado “Fazenda Pública”, assim entendida, conforme ensina Leonardo José Carneiro da Cunha em um dos principais trabalhos sobre o tema²⁸⁰, “a referência a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações públicas”.

Via de regra, todos os entes acima referidos, quando partes em uma relação processual, são representados pelos membros da Advocacia Pública, instituição tida pela Constituição federal como “essencial à Justiça”.

A União é representada pela Advocacia-Geral da União – AGU, que, conforme dispõe o art. 131 da Constituição Federal, “representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”.

Depreende-se da norma supracitada que a missão institucional da Advocacia Pública não se esgota na atividade de representação processual dos entes públicos, uma vez que também integra sua atribuição a atividade

de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Para o Direito Processual Civil, por óbvio, é a atividade de representação em juízo a primordial, haja vista que é nesta função que o membro da Advocacia Pública atua no processo, defendendo os interesses do Estado e praticando atos processuais em nome deste.

Em resumo, toda vez que uma das entidades abrangidas pelo conceito de Fazenda Pública precisar ir a juízo dando início a um processo, apresentar defesa como réu, participar de audiência, atividades probatórias ou recorrer, é o membro da Advocacia Pública que representará o Estado e praticará o ato processual.

A Advocacia Pública, no plano federal, é prevista no art. 131 da Constituição Federal, que cria e estabelece os contornos constitucionais da Advocacia-Geral da União instituição que, “diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”.

Já no plano estadual, a Constituição Federal, em seu art. 132, prevê que “os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas”.

Apesar da inexistência de uma previsão constitucional para a instituição de advocacias públicas no plano municipal, nada impede – e muitas razões inclusive recomendam – que também estas unidades federativas possuam um quadro permanente de advogados públicos.

São integrantes destas instituições os advogados públicos, servidores públicos de carreira, ingressos nos quadros da Administração Pública,

necessariamente, por concursos de provas e títulos (art. 131, § 1º, e art. 132, parágrafo único, da Constituição Federal), os quais, no âmbito de suas atribuições constitucionalmente definidas, deverão observar e fazer observar a ordem jurídica e atuarem no assessoramento jurídico e na representação judicial do Estado, visando a defesa do interesse público, da legalidade, ou mais amplamente do próprio Estado Democrático de Direito constitucionalmente consagrado.

O Código de Processo Civil dedica um capítulo à Advocacia Pública, dispondo no art. 182 que “incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta”.

Portanto, cada unidade federativa possui o dever de criar e estruturar seus quadros de advogados públicos integrantes da Advocacia Pública, ressalvados os Municípios, uma vez que esta obrigação constitucional não alcança estes entes federativos.

No âmbito federal, a representação da União, de suas autarquias e fundações públicas se dá por meio de três carreiras integrantes ou vinculadas à Advocacia-Geral da União AGU: a) os advogados da União; b) os procuradores da Fazenda Nacional; e c) os procuradores federais.

Os advogados da União, como o próprio nome sugere, são os representantes da União, na qualidade de pessoa jurídica de direito público, ou seja, todos os órgãos que integram a Administração Pública direta federal, salvo se a matéria litigiosa for fiscal, caso em que a União será representada em juízo pelos procuradores da Fazenda Nacional.

Já a Administração Pública federal indireta, ou seja, as autarquias e fundações públicas criadas pela União, pessoas jurídicas de direito público com personalidade jurídica própria e, portanto, com capacidade de ser parte, é representada pelos procuradores federais, à exceção do Banco

Central do Brasil, que, apesar de ser autarquia federal, é representado em juízo por um quadro de procuradores próprio.

Em síntese, a Advocacia Pública federal é composta por quatro carreiras que representam a União em juízo: a administração direta, pelos advogados da União; os interesses fiscais da União, pelos procuradores da Fazenda Nacional; e a administração indireta, pelos procuradores federais ou procuradores do Banco Central do Brasil.

Assim, se a ação for ajuizada contra a própria União por estar sendo questionada a conduta de um de seus órgãos (Presidência da República, Ministérios, Secretarias, Polícia Federal), seu representante em juízo será o advogado da União, membro da Advocacia-Geral da União.

Se a matéria discutida em um processo que envolva a União for fiscal, provavelmente envolvendo atos da Receita Federal ou de outros órgãos da União com atribuições fiscais, a representação da União em juízo se dará pelo Procurador da Fazenda Nacional.

Já se a questão envolver uma autarquia ou fundação pública federal, como o INCRA, o INSS, o CADE, as Universidades públicas federais e as “agências reguladoras” (ANAC, ANATEL, ANTT, entre muitas outras), a representação destes entes públicos será realizada pelo procurador federal.

No âmbito estadual, cada Estado deve criar e estruturar suas respectivas Procuradorias Estaduais, integradas pelos procuradores do Estado, que possuem a função de representar, ativa e passivamente, o Estado federado em juízo, não havendo, ao contrário do que ocorre no âmbito da União, uma divisão entre carreiras quando a matéria é ou não é fiscal. A representação das autarquias estaduais em juízo é matéria reservada a lei estadual, havendo Estados em que esses entes são representados pelos procuradores do Estado e outros em que se opta pela criação de carreiras específicas para a representação processual.

Igualmente, se existente no âmbito municipal a estrutura de advocacia

pública, a representação processual se dará em moldes similares à dos Estados, ou seja, por intermédio de procuradorias municipais, composta de procuradores do Município, servidores ingressos nos quadros da municipalidade por concurso público de provas e títulos.

Caso o Município não possua estrutura de procuradoria, sua representação processual se dará pelo prefeito que, para fins de regular capacidade postulatória, deverá constituir advogado nos autos do processo em que o Município seja parte.

7.3 Defensoria Pública

Conforme já estudado no capítulo dedicado às normas processuais na Constituição Federal, o art. 5º, inc. LXXIV, impõe ao Estado dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A denominada gratuidade da justiça não engloba apenas a isenção de custas ou demais despesas processuais, mas também a representação gratuita por profissional habilitado sempre que a parte não tiver condições de pagar um advogado privado.

Concretizando o princípio consagrado no referido art. 5º, inc. LXXIV, o art. 134, também da Constituição Federal, estabelece que “a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal”.

A expressão assistência jurídica integral e gratuita, nesse contexto, extrapola a atividade no âmbito do processo civil da Defensoria Pública, sendo certo ademais que, além de atuar na esfera processual civil, o membro da Defensoria Pública também atua no processo penal, bem como

em atividades extraprocessuais²⁸¹.

Especificamente no que se refere ao processo civil, portanto, cabe ao membro da Defensoria Pública atuar como procurador da parte que necessita ir ao Judiciário e, contudo, por estar na condição de hipossuficiente, demonstra-se incapaz de arcar com os custos do processo, entre os quais o pagamento de um advogado privado.

O Código de Processo Civil refere-se à Defensoria Pública em seu art. 185, dispondo que esta “exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”.

Para melhor compreensão do papel da Defensoria Pública no processo civil, contudo, além do conhecimento das normas constitucionais e do CPC, faz-se necessário destacar alguns pontos da Lei Complementar n. 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados.

Especificamente no que se refere à atuação do defensor público no processo civil, dispõe seu art. 4º, inc. I, que é função institucional da Defensoria Pública, dentre outras, prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus.

Nesse contexto, feitas as devidas adaptações, o membro da Defensoria Pública atuará como representante da parte hipossuficiente para fins de regularidade da capacidade postulatória, praticando, assim, todos os atos processuais em nome da parte que representa.

Especialmente no plano processual, que, repita-se, não é o único em que atua a Defensoria Pública, merece destaque o disposto no art. 4º, inc. V, da Lei Complementar n. 80/94, que dispõe que é função institucional da Defensoria Pública, entre outras: exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos

os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses.

Ademais, em concorrência com a legitimidade do Ministério Público, a Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, incs. VII e VIII, poderá promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes, bem como exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inc. LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Complementam o rol de deveres previsto na Lei Complementar n. 80/94 que geram impactos diretos na atividade da Defensoria Pública no processo civil, individual ou coletivo, os deveres do defensor público de: a) promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela (art. 4º, X); b) exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado (art. 4º, XI); bem como c) exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei (art. 4º, XVI).

Assim, em apertada síntese, pode-se afirmar que cabe à Defensoria Pública, no processo civil: a) atuar na defesa dos hipossuficientes nos processos em que estes sejam parte; e b) promover ou, mais amplamente, atuar em processos de jurisdição coletiva quando o grupo, classe ou categoria de pessoas representados sejam integrados total ou parcialmente por pessoas hipossuficientes.

7.3.1 Estrutura e carreiras integrantes da Defensoria Pública

Tal como a organização do Ministério Público, da Advocacia Pública e do próprio Poder Judiciário, a Defensoria Pública deve ser criada e estruturada no âmbito da União e dos Estados, cabendo à Defensoria Pública da União a representação dos hipossuficientes perante a Justiça federal e às Defensorias Públicas estaduais o mesmo papel perante os órgãos da Justiça dos Estados.

Nesse sentido, são abrangidas pelo conceito de Defensoria Pública: a) a Defensoria Pública da União; b) a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; e c) as Defensorias Públicas dos Estados.

A própria Lei Complementar n. 80/94 cria e estrutura a Defensoria Pública da União, ao passo que cabe a cada Estado, por lei própria, disciplinar a criação e a estruturação de suas respectivas Defensorias, respeitando as normas gerais estabelecidas na Lei Complementar e, obviamente, as diretrizes traçadas pela Constituição Federal.

O membro da Defensoria Pública é o defensor público, que só pode ingressar na carreira mediante aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 112 da LC n. 80/94).

Denomina-se defensor público federal o membro da Defensoria Pública da União.

Cada Estado da federação, além de estruturar a própria Defensoria, deve criar e preencher, por meio de concurso público, os cargos de defensor público estadual.

A Lei Complementar n. 80/94 estabelece algumas garantias para os defensores públicos, sejam eles estaduais ou federais, dentre as quais se destacam as garantias previstas nos arts. 43, 88 e 127, que dispõem serem garantias dos membros da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Estados: I – a independência funcional no desempenho de suas

atribuições; II – a inamovibilidade; III – a irredutibilidade de vencimentos; IV – a estabilidade.

Em contrapartida, a mesma Lei complementar estabelece os deveres dos defensores públicos, dentre os quais se destacam, no que tange ao processo civil: a) atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a sua presença; b) interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou tribunal e promover revisão criminal, sempre que encontrar fundamentos na lei, na jurisprudência, ou prova dos autos, remetendo cópia à Corregedoria-Geral.

Em resumo, conforme já asseverado, uma vez regularmente constituído nos autos do processo como procurador da parte, o defensor público deve atuar como seu representante na defesa de seus interesses, zelando, a exemplo de todos os procuradores judiciais, pelos deveres de lealdade e boa-fé e limitados pela vontade da parte que assiste.

7.4 Advocacia

Nos termos do art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, o que implica dizer que a prática de atos processuais, apesar de constituir um direito das partes e de todos os sujeitos que vierem a intervir no processo, depende, para o seu efetivo exercício, de uma regular representação pelo advogado integrante desta função, tida pela Constituição Federal como “essencial à Justiça”.

Em outras palavras, os direitos das partes devem ser exercidos por intermédio de um advogado, sendo inadmissível que a parte pratique atos processuais sem esta assistência profissional.

As exceções, raríssimas no sistema judiciário brasileiro, dizem respeito ao processo penal (mais precisamente ao pedido de habeas corpus) e, mais amplamente, ao processo do trabalho. No processo civil, apenas o procedimento especial dos juizados especiais admite a postulação sem a representação por advogado, ainda assim para as causas abaixo de 20

salários mínimos²⁸².

A exigência de regular representação por advogado é categorizada pelo Direito Processual Civil como capacidade postulatória, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e condição necessária para validade de todo e qualquer ato processual praticado pela parte.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, no art. 103, dispõe que “a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, devendo para tanto ser regularmente constituído nos autos do processo pelo instrumento de procuração judicial assinado pela parte”.

Nesse contexto, é advogado o bacharel em Direito regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Nos termos do art. 44 da Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, esta, “serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa”, tem por finalidade: “I – defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; II – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil”.

Denota-se, portanto, conforme inclusive destacado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau²⁸³, que se trata de “um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro”, e que, portanto, “a Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidades institucionais”.

Na busca pela consecução desta finalidade institucional, a OAB, na qualidade de representante da Advocacia, entendida no contexto de “função essencial à Justiça”, pode, por exemplo, ajuizar ações civis públicas ou, mais amplamente, ações coletivas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da legitimidade conferida ao Ministério Público, há pouco comentada²⁸⁴.

Igualmente integram o quadro de funções da OAB importantes atividades típicas de órgão de fiscalização de classe: a) a realização e o controle da inscrição dos bacharéis em Direito, mediante prévia aprovação em um exame de admissibilidade; b) a regulamentação do exercício da advocacia; e c) a fiscalização dos membros integrantes de seus quadros.

A atividade de regulamentação da advocacia é exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece em seu Código de Ética que são deveres do advogado, entre outros: a) preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade; b) atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; c) velar por sua reputação pessoal e profissional; d) empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional.

A par do Código de Ética, a Lei n. 8.906/94, em seu art. 34, estabelece as condutas que constituem infrações disciplinares, entre as quais: a) exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos; b) estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário; c) prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio; d) acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione; e) abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia.

O descumprimento destes deveres pode levar à imposição de sanções ao advogado faltante, cabendo ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB

processo de apuração do ilícito e aplicação de sanção, que pode variar desde advertência até exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

O estudo do papel do advogado no processo civil obviamente não está esgotado neste item, uma vez que, sendo o profissional por intermédio do qual as partes exercem seus direitos e praticam quase todos os atos processuais, muitas das normas atinentes à atuação do advogado serão objeto de considerações ulteriores, dado que muitas delas se confundem com as próprias normas processuais, que têm no advogado um dos principais destinatários.

Capítulo 8 Ação

8.1 Considerações iniciais

O direito de ação é um dos pilares do Direito Processual Civil, na medida em que, considerando a inércia da jurisdição, o processo só pode existir se houver provocação, sendo o exercício do direito de ação, exatamente, o modo de se provocar o Poder Judiciário.

Trata-se de uma garantia constitucional, com natureza de cláusula pétrea e, portanto, inafastável por lei ou qualquer outro ato normativo, inclusive emenda à Constituição²⁸⁵, bem como de obrigatória observância por parte dos órgãos jurisdicionais.

Nesse sentido, a lei não pode mitigar ou inviabilizar o direito de ação, ou seja, afastar do Poder Judiciário a análise de lesão ou ameaça a direito, bem como, uma vez acionado, é vedado ao juiz se negar a dar uma resposta jurisdicional ao pedido veiculado na ação.

Portanto, a par de dar início ao processo, integra o direito de ação o direito a um pronunciamento de mérito, ou mais amplamente o direito à prestação da tutela jurisdicional pleiteada, desde que obviamente o autor demonstre ter razão.

Entretanto, dois pré-requisitos devem ser preenchidos pelo autor da ação, pois condicionam a análise do mérito pelo juiz, uma vez acionado: a legitimidade e o interesse de agir, neste contexto caracterizados como condições da ação, a seguir estudadas.

Antes disso, faz-se necessária a análise da estrutura e dos elementos que compõem a ação: as partes, a causa de pedir e o pedido.

Ademais, dada a importância da ação para a própria existência e a formação do processo, bem como os demais desdobramentos decorrentes de sua regular propositura, é preciso, já nesta Introdução, conhecer a

dinâmica da regularidade e eventuais defeitos no exercício do direito de ação.

Este capítulo, em síntese, será dedicado ao conceito de ação, ao estudo dos elementos e das condições da ação e, por fim, à análise da denominada carência de ação, assim entendido o vício decorrente da falta de uma de suas condições.

8.2 Conceito de ação e sua evolução histórica

O conceito de ação, já referido nas linhas anteriores, consiste no direito de provocar o Estado-juiz, exigindo dele a tutela jurisdicional, bem como, conforme se verá a seguir, no direito de agir durante o curso do procedimento, uma vez iniciado, e de receber uma resposta jurisdicional apta a tutelar o direito material lesado ou ameaçado.

Tal conceito foi objeto de intensos debates jusfilosóficos e dogmáticos ao longo da história do Direito Processual, e sua concepção atual é fruto da superação de algumas teorias doutrinárias, tais como a teoria civilista da ação e a teoria concreta, atualmente suplantadas pela teoria abstrata do direito de ação.

Moacyr Amaral Santos²⁸⁶, em sua clássica obra, sintetiza os três estágios da concepção do direito de ação, dividindo-os em: a) teoria civilista; b) teoria concreta do direito de ação; e c) teoria abstrata do direito de ação.

O referido autor²⁸⁷ destaca que a teoria civilista (ou imanentista), abarcada pela generalidade da doutrina até meados do século XIX, via a ação como o próprio direito material levado a juízo para a busca de sua proteção jurisdicional contra lesão ou ameaça.

A crítica que levou a teoria civilista a ser superada é a de que, segundo esta ótica, a ação se prenderia indissolúvelmente ao direito material que por meio dela se quer tutelar, o que leva, inevitavelmente, à conclusão de que “não há direito sem ação e não há ação sem direito”.

Por essa razão, na atualidade, a teoria civilista encontra-se superada, tendo contribuído para tanto polêmica doutrinária travada por Windscheid e Muther na metade do século XIX²⁸⁸.

Windscheid e Muther travaram uma disputa doutrinária sobre a natureza da ação, prevalecendo ao final a teoria de Muther, para quem a ação consiste em um direito à tutela do Estado²⁸⁹, um direito subjetivo público, portanto que não se confunde com o direito lesado.

Um estágio seguinte da evolução histórica da teoria da ação encontra-se com a consagração da teoria concreta, que passa a considerar a ação um direito autônomo, que não tem, necessariamente, por base um direito objetivo violado. Entretanto, conforme asseveram Cintra, Dinamarco e Grinover²⁹⁰, “como a existência da tutela jurisdicional só pode ser satisfeita através da proteção concreta, o direito de ação só existiria quando a sentença fosse favorável”, sendo esta a razão de sua superação.

As críticas às teorias civilista e concreta do direito de ação levaram à concepção da ação como direito abstrato, que existe independentemente da existência do direito material afirmado em juízo, sendo suficiente para caracterizar o direito de ação que o autor mencione seu interesse e peça sua proteção em juízo²⁹¹.

Com a consagração da teoria abstrata, sustenta-se, na atualidade, que a ação é um direito subjetivo público, distinto do direito subjetivo pleiteado em juízo, que tem por sujeito passivo o Estado e que existe independentemente da existência do direito material a que se pretende tutelar.

Nas palavras de Moacyr Amaral Santos, é simplesmente o direito de pedir ao Estado a prestação de sua atividade jurisdicional em um caso concreto. Ou, simplesmente, o direito de invocar o exercício da função jurisdicional²⁹².

A estas características de autonomia e abstração, foi somada a concepção da ação à instrumentalidade, deixando clara a ideia de que a

ação está a serviço do direito material.

Nas palavras de Cintra, Dinamarco e Grinover²⁹³, a ação é “o direito ao provimento jurisdicional, qualquer que seja a natureza deste – favorável ou desfavorável, justo ou injusto – e, portanto, direito de natureza abstrata”, além de autônomo, pois “independe da existência do direito subjetivo material”, e instrumental, pois “sua finalidade é dar solução a uma pretensão de direito material”.

Ademais, para a correta compreensão do direito de ação, deve-se ter em mente que este não se esgota com o exercício da provocação, pois a ação também deve ser entendida como um direito de agir durante o curso do procedimento.

Nesse sentido, importantíssima a lição de Cassio Scarpinella Bueno²⁹⁴, para quem “a ação não pode ser entendida apenas e tão somente como o rompimento da inércia jurisdicional”, pois “não se consuma como a apresentação da ‘petição inicial’”. O autor conclui, com maestria, que a “ação é exercitável, é exigível ao longo do processo, isto é ao longo de toda a atividade processual”²⁹⁵.

Ademais, de nada adiantaria o direito de provocar o Poder Judiciário e agir no curso do procedimento se também não integrasse o direito de ação a garantia de receber uma resposta jurisdicional.

Nesse sentido, conforme inclusive já afirmado em linhas anteriores, a ação deve ser vista como um direito que, a um só tempo, viabiliza o acesso ao Judiciário e o direito a uma resposta jurisdicional justa, efetiva e em tempo razoável.

Assim, em síntese, pode-se dizer que o direito de ação garante: a) o direito de provocar o Poder Judiciário a prestar jurisdição; b) o direito a uma resposta jurisdicional; e c) o direito de participar do procedimento, pois também exercitável ao longo do processo, sendo certo que se trata de: d) um direito subjetivo público, pois exigível contra o Estado; e) autônomo,

dado que não se confunde com o direito material discutido em juízo; f) abstrato, pois existe independentemente da existência deste; e g) instrumental, exatamente porque encontra sua utilidade ao se colocar “a serviço” do direito material que objetiva tutelar.

8.3 Elementos da ação

Para uma melhor compreensão da ação e do próprio processo, é fundamental a identificação dos elementos da ação que pautarão a atividade processual das partes e do próprio órgão jurisdicional.

Por elementos da ação, devem ser entendidos as partes, causa de pedir e o pedido.

Conforme assevera Cassio Scarpinella Bueno²⁹⁶, os elementos da ação “devem ser entendidos como os componentes mínimos e suficientes da ação que as identificam como tais e, conseqüentemente, as distinguem de quaisquer outras ações”.

Nesse sentido, é fundamental o correto entendimento de todos os elementos da ação, para verificar, por exemplo, a ocorrência de litispendência, que impede a repropositura de ação idêntica²⁹⁷, sendo certo que a verificação desta identidade se dá na medida em que coincidam todos os elementos da ação.

Da mesma forma, a identificação das partes, do pedido e da causa de pedir é fundamental para definir e limitar a abrangência da coisa julgada, ou seja, o alcance da definitividade do julgamento, que torna um específico litígio indiscutível em qualquer outro processo.

Ademais, especialmente a definição do pedido é crucial para: a) definir a espécie de processo; b) definir a espécie de procedimento; e, além disso, c) limitar a atividade jurisdicional, que deve ficar adstrita ao pedido.

Isso porque, a depender da espécie do pedido, se de tutela jurisdicional declaratória ou tutela jurisdicional executiva, por exemplo, estar-se-á diante de duas espécies de processo absolutamente distintas²⁹⁸.

Da mesma forma, em outras situações, é o valor do pedido que vai determinar a possibilidade ou necessidade de sujeição da ação ao procedimento especial dos juizados especiais, bem como será a natureza dele, se de tutela possessória ou de consignação em pagamento, por exemplo, que definirá a eventual submissão do feito a um procedimento especial.

Além disso, por força do princípio da inércia jurisdicional, que ensina que o juiz não pode agir se não quando provocado e nos limites da provocação, fundamental é a identificação do pedido para que se saiba, desde já, sobre o que o juiz deve decidir e aquilo que está fora de sua esfera de decisão, dado que não pedido e, portanto, não provocado.

Nesse sentido, é expressa a letra do art. 490 do CPC ao proibir o juiz de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Os subitens a seguir serão dedicados a cada um dos elementos da ação.

a) Partes

Todo litígio pressupõe ao menos dois sujeitos interessados em um mesmo bem jurídico, o que leva, vedada a autotutela e ausente uma forma consensual de resolução da lide, à necessidade de busca de tutela jurisdicional.

Essa busca, representada pela propositura da ação, necessariamente deve identificar, de um lado, o sujeito que exerce a pretensão e, de outro, aquele que oferece a resistência.

Decorre desta afirmação o conceito de partes: quem pede e contra quem é feito o pedido.

O autor, ou parte ativa, é aquele que exerce o pedido, ao passo que o réu, ou parte passiva, é o sujeito contra quem o pedido é exercido.

É importante, neste passo, que seja feita a distinção entre partes no

direito material, isto é, as partes da relação jurídica litigiosa e as partes da relação processual, assim entendidos os sujeitos que figuram como autor e réu no processo.

Como regra geral, as partes do direito material são os mesmos sujeitos da relação processual até porque, conforme se verá adiante, ninguém pleiteará em nome próprio direito alheio, o que leva à necessidade de as partes em juízo serem exatamente os mesmos sujeitos em conflito no plano do direito material.

Nesse sentido, figuram como partes – autor e réu no plano processual –, em uma “ação de cobrança”, o credor e o devedor no plano material, assim como, em uma “ação de execução fiscal”, estará de um lado, como autor (exequente), o ente estatal credor do tributo devido e de outro, como parte processual passiva – réu –, o contribuinte ou, mais precisamente, o devedor no plano do direito material.

A não coincidência entre estes dois planos, material e processual, salvo expressa autorização legal, leva à ilegitimidade de partes, fenômeno que, conforme se verá adiante, implica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Entretanto, excepcionalmente, a lei pode autorizar alguém a pleitear em nome próprio – como parte na relação processual – a proteção de um direito alheio, gerando a possibilidade, repita-se excepcional e condicionada a expressa previsão legal, de existir uma não coincidência entre as partes do processo e aquelas integrantes da relação material discutida em juízo.

É o caso, por exemplo, de uma associação de servidores públicos que possui autorização legal para pleitear em juízo, como parte autora, uma vantagem ou gratificação pecuniária que, de rigor, não lhe pertence, pois, na verdade, pertence a seus associados.

Em outras palavras, o direito de receber a vantagem pecuniária é de cada um dos servidores, sendo estes a parte credora à luz do direito

material; apesar disso, em decorrência da expressa autorização legal, a parte processual – autora – será a associação.

Como dito, via de regra, o desencontro entre os planos material e processual leva à caracterização da ilegitimidade de partes, uma das condições da ação que, por sua vez, impedem o exame do mérito.

Nesse sentido, o art. 18 do Código de Processo Civil dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

A legitimidade será mais bem estudada no item 8.4, “a”, infra.

b) Pedido

O segundo elemento da ação é o pedido.

De rigor, a identificação do pedido é de duas ordens, o que implica dizer que, visto de perto, o pedido na verdade tem duas acepções.

Em outras palavras, a provocação do autor contém não um, mas dois pedidos: a) um dirigido ao Estado-juiz para que este preste tutela jurisdicional; e b) outro dirigido contra o réu, consistente na entrega do bem jurídico em poder deste para si.

O pedido veiculado pelo autor dirigido ao Estado-juiz é o pedido imediato, assim entendido o pedido de tutela jurisdicional e a definição da espécie de tutela pretendida pelo autor, se declaratória, condenatória, constitutiva ou executiva²⁹⁹.

Nesse contexto, cumpre ao autor esclarecer se busca tutelar o bem jurídico almejado por meio da tutela de conhecimento ou de execução, por já ser detentor do título executivo. Caso a tutela pretendida seja de conhecimento, o autor também deve identificar qual a subespécie objetivada, se declaratória, constitutiva ou condenatória³⁰⁰.

Obviamente, a identificação da espécie de tutela jurisdicional pretendida vai influenciar o processo, o procedimento e, sobretudo, a decisão judicial,

pois a atividade a ser desenvolvida pelo magistrado e pelas partes deverá ser pautada pela natureza da pretensão, sendo absolutamente distintas as fases e os atos processuais voltados ao conhecimento e julgamento do pedido, se comparados aos atos voltados à concretização no plano dos fatos de um direito. Não por acaso, é a partir da tutela jurisdicional pretendida que é possível classificar o processo, denominando-se “processo de conhecimento” aquele em que se busca a tutela jurisdicional de conhecimento, por exemplo.

Ademais, é corrente na doutrina a classificação da ação segundo a espécie de tutela jurisdicional pretendida pelo autor, o que permite a categorização das ações em: a) ação de conhecimento meramente declaratória; b) ação de conhecimento de natureza constitutiva ou desconstitutiva; c) ação de conhecimento de cunho condenatório; e d) ação executiva, esta última, quando o titular do direito afirmado em juízo é (ou afirma ser) detentor de um título executivo³⁰¹.

Além disso, é de nossa tradição, a partir do pedido, “denominar” a ação, sendo certo que, considerando a natureza da ação como o direito de provocar o Poder Judiciário e requerer tutela jurisdicional, tal nomenclatura, apesar de tradicional, não pode ser tida como uma exigência legal³⁰².

Nesse sentido, um eventual erro na denominação da ação não impede o prosseguimento do feito, nem sequer constitui um vício que precise ser corrigido.

Ademais, a pretensão delineada pelo autor no pedido imediato limita a atividade jurisdicional, sendo vedada ao juiz uma providência de natureza distinta da pleiteada.

Assim, um pedido de mera declaração não pode redundar em uma condenação do réu, visto que esta não foi pretendida pelo autor e, até por este motivo, nem sequer foi respondida pelo réu. Da mesma forma, caso o autor requeira a condenação do réu, isto é, um julgamento de procedência que reconheça sua pretensão, fica o magistrado vedado de conceder uma

tutela jurisdicional executiva não requerida.

Vale lembrar que, conforme determina o princípio da inércia jurisdicional, o juiz não age senão quando provocado e nos limites da provocação. O pedido é, exatamente, o elemento da ação definidor destes limites da provocação, restando vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. É o que deixa claro o art. 492 do Código de Processo Civil, neste contexto uma regra concretizadora do princípio da inércia jurisdicional.

Outra acepção de pedido consiste no entendimento deste como o bem jurídico pretendido pelo autor, que pode ser desde uma quantia em dinheiro ou uma entrega de coisa até a proteção a um direito intangível, como a saúde, a honra, a imagem ou a privacidade. A esta acepção, dá-se o nome de pedido mediato.

O pedido mediato, assim entendido o bem ou direito que o autor pretende ver tutelado pelo Estado-juiz, define o objeto do processo e, nesse sentido, pode ser visto como o mérito do processo, isto é, aquilo sobre o que as partes irão litigar e sobre o que o juiz vai decidir.

A identificação do pedido mediato também é fundamental para fins de definição do conteúdo da decisão, que deve ser integralmente respondida pelo juiz, que, entretanto, não pode se exceder, analisando ou decidindo sobre bens e direitos não pleiteados e, portanto, não integrantes do mérito do processo.

c) Causa de pedir

A causa de pedir, assim entendida os fundamentos e fatos de direito do pedido, é o terceiro elemento da ação.

Nesse sentido, é imprescindível para a identificação da ação o fato ou fatos responsáveis pelo surgimento da pretensão, e os fundamentos de

direito que justificam o ajuizamento da ação.

A doutrina, tradicionalmente, subdivide a causa de pedir em causa de pedir próxima e causa de pedir remota.

Causa de pedir remota consiste no fundamento de fato; e causa de pedir próxima, nos fundamentos de direito, ou seja, as consequências ou a qualificação jurídica dos fatos, que justificam a demanda.

Os fatos (causa de pedir remota), em certa medida, vão, assim como o pedido, delimitar o foco de conhecimento e julgamento do magistrado, pois o juiz está preso aos fatos narrados pelo autor ou àqueles eventualmente trazidos pelo réu.

Os fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) seriam a qualificação jurídica destes fatos, o efeito ou as consequências jurídicas dos fatos integrantes da causa de pedir remota.

Nesse contexto, vale destacar que a fundamentação jurídica não pode ser confundida com o “enquadramento legal” dos fatos. Não é motivo de improcedência ou limitação do juiz, por exemplo, a formulação da pretensão com base no Código de Defesa do Consumidor que, eventualmente, não se aplique ao caso por não se estar diante de relação de consumo. Neste caso, se o juiz entender, a partir dos fatos apresentados pelo autor, ser aplicável o Código Civil, a lide poderá ser por ele julgada com base neste diploma.

Em outras palavras, se, de um lado, ao juiz é vedado considerar ou investigar fatos não integrantes da causa de pedir do autor, bem como extrair consequências jurídicas diversas daquelas por este suscitadas, nada impede que, apesar de a pretensão estar fundamentada em determinado dispositivo de lei, o juiz analise estes mesmos fatos à luz de outros dispositivos que entenda aplicáveis à hipótese.

Nesse contexto, aplica-se a máxima *jura novatio curia*, que em tradução livre significa que “o juiz conhece o direito”, o que implica dizer que, apresentados os fatos e a fundamentação jurídica, o juiz poderá decidir de

acordo com as normas integrantes do ordenamento jurídico, ainda que não expressamente aduzidas pelas partes.

Nestas situações, contudo, é importante, como visto no item 6.2.9, que o juiz dê oportunidade para que as partes se manifestem sobre o fundamento ainda não debatido, por exigência do art. 10 do Código de Processo Civil.

Tal como a identificação das partes e do pedido, a definição da causa de pedir é fundamental para que se verifique a identidade de ações, inclusive para fins de verificação de eventual litispendência ou coisa julgada, situações que impedem a repropositura da mesma ação e a extinção do processo sem resolução do mérito caso a ação seja reproposta³⁰³.

Isso porque a identificação das partes e do pedido, por si só, não é suficiente para caracterizar a identidade de ações, sendo, para tanto, necessária também a coincidência entre as causas de pedir.

Assim, uma demanda promovida pelo Banco Y contra uma pessoa JWM, em que o autor pretende receber a quantia de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não é necessariamente idêntica a outra em que este mesmo banco pretenda receber a mesma quantia de JWM, desde que a segunda demanda tenha uma causa de pedir distinta.

Nesse sentido, se por um lado é vedado o ajuizamento de uma “ação de cobrança” idêntica, posto que entre os mesmos sujeitos (Banco Y e JWM), com o mesmo pedido (condenação em R\$ 500.000,00) e a mesma causa de pedir (mesmo contrato de empréstimo, por exemplo), por outro é perfeitamente possível o ajuizamento de outra demanda por Banco Y contra JWM, se o pedido de condenação em R\$ 500.000,00 estiver fundamentado em outro contrato, de leasing, por exemplo.

Da mesma forma, duas pretensões oriundas de um mesmo fato podem justificar o ajuizamento de duas ações distintas que não se identificam.

A título de exemplo, pode-se imaginar uma demanda que RCT mova contra determinada empresa alegando que esta tenha indevidamente

utilizado sua imagem em uma campanha publicitária. Este mesmo fato pode, a um só tempo, gerar o direito de uma indenização por dano moral e outra relativa a eventuais lucros aferidos pela empresa com o uso irregular da imagem.

É possível, nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil, que estes dois pedidos sejam cumulados, isto é, formulados e julgados em um mesmo processo, sendo possível, todavia, que duas ações distintas sejam ajuizadas, uma para a indenização por danos morais e outra em razão do eventual direito aos lucros indevidamente aferidos pelo réu em razão da utilização da imagem do autor.

8.4 Condições da ação

As condições da ação são requisitos que devem ser observados para que se possa exigir a prestação jurisdicional e, portanto, devem estar presentes para que o Estado-juiz possa se pronunciar sobre o pedido³⁰⁴.

Tais condições, que estão previstas em lei, segundo Cintra, Dinamarco e Grinover decorrem, em última análise, do princípio da economia processual, pois, quando se percebe, a partir da afirmação do próprio autor ou dos elementos trazidos por este, que a tutela jurisdicional requerida não poderá o u não precisará ser concedida, o pedido nem sequer deverá ser analisado³⁰⁵.

Portanto, a ação só pode ser proposta se preenchidas determinadas condições e, caso ajuizada uma demanda em que falte uma destas condições, o juiz não deverá analisar o mérito.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, são condições da ação o interesse e a legitimidade, pois, conforme estabelece o dispositivo, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

O interesse de agir, previsto no art. 17 do CPC, é disciplinado nos arts. 19 e 20, ao passo que o art. 18 do Código se ocupa de detalhar a legitimidade, todos a seguir analisados.

As condições da ação possuem duplo destinatário.

O primeiro deles é o próprio sujeito que deseja ajuizar uma ação, que deve antes disso verificar se possui interesse e legitimidade para tanto.

Já o segundo destinatário das regras relativas às condições da ação é o juiz, que deve, antes de dar seguimento ao feito, verificar a presença do binômio interesse-legitimidade, cujo não preenchimento implicará a extinção do processo sem uma análise de mérito.

Em outras palavras, considerando que as condições da ação impedem, nos termos do art. 17 do CPC, a propositura da ação, se esta for equivocadamente proposta, não haverá condições de o processo prosseguir e muito menos razão para o mérito ser julgado.

Em função disso, e considerando a gravidade do vício relativo à ausência de uma das condições da ação, sua verificação deve ser realizada de ofício pelo juiz, isto é, independentemente de provocação da parte interessada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se verá adiante mais detalhadamente.

Os itens a seguir serão dedicados a uma análise pormenorizada de cada uma das condições da ação, bem como à dinâmica de sua verificação e decretação.

a) Legitimidade de partes

Legitimidade é a pertinência subjetiva entre a relação jurídica litigiosa objeto do processo e as partes ativa e passiva da relação processual.

Nessa linha, a regra geral do sistema processual é a de que as partes do processo (autor e réu) devem ser as mesmas da relação jurídica de direito material discutida em juízo, isto é, o credor e o devedor em uma ação de cobrança, o comprador e o vendedor em um litígio em que se discuta o contrato de compra e venda, e assim por diante.

Tal legitimidade, portanto, decorre diretamente da titularidade do direito

material discutido em juízo e funciona como regra geral. Por este motivo, é classificada como legitimidade ordinária.

Nesse sentido, a legitimidade ordinária está prevista na regra geral do art. 18, sendo, portanto, a coincidência entre a titularidade do direito material discutido e a posição ocupada pelo sujeito na relação processual.

No entanto, conforme afirmado quando da apresentação das partes como elementos da ação³⁰⁶, excepcionalmente a lei pode autorizar alguém a pleitear em nome próprio, como parte em uma relação processual, a proteção de um direito alheio, gerando a possibilidade de não coincidência entre as partes da relação material discutida em juízo e as partes – v.g. credor e devedor – do processo, ou seja, autor e réu.

Por essa razão, é correto afirmar que, ao lado da legitimidade ordinária acima referida, o sistema processual admite uma legitimidade extraordinária.

A legitimidade ordinária decorre da titularidade do direito afirmado em juízo, ou seja, da coincidência entre as posições de parte no direito material e parte no direito processual. Para ficar nos exemplos já referidos, o credor é legitimado ativo ordinário para propor a ação de cobrança da dívida, assim como aquele que sofreu o prejuízo é legitimado ordinário para propor a ação indenizatória.

Já na legitimidade extraordinária, não há coincidência entre os planos material e processual. Ela decorre, pura e simplesmente, de uma expressa autorização legal.

Assim, por exemplo, a lei autoriza um sindicato ou associação de servidores públicos a pleitear em juízo o pagamento de uma gratificação para todos os integrantes de determinada categoria.

No referido exemplo, o sindicato será parte – autora – de um processo, apesar de não ter, no plano do direito material, o direito de receber salários ou remuneração, direito este que, se existir, pertence aos servidores

representados pelo sindicato no processo.

Portanto, neste contexto, por força de uma expressa autorização legal, o sindicato ou associação pode pleitear em juízo direito alheio no exercício da legitimidade extraordinária.

Vale ressaltar que, conforme asseverado anteriormente, a pertinência subjetiva tem de se dar tanto do ponto de vista do autor como do ponto de vista do réu, dando origem à classificação da legitimidade como ativa ou passiva.

A legitimidade ativa é a relativa ao autor, que deve ser o titular do bem jurídico que pretende ver tutelado pelo processo (legitimidade ativa ordinária) ou estar expressamente autorizado a defendê-lo, mesmo não sendo o titular (legitimidade ativa extraordinária).

Ademais, a pretensão do autor deve ser exercida contra aquele que efetivamente possa, à luz do direito material, atendê-la, ou seja, contra o sujeito legitimado passivo.

O legitimado passivo é aquele que sofrerá os reflexos diretos do acolhimento do pedido, em seus bens ou, mais amplamente, em sua esfera jurídica, isto é, aquele que terá de atender o pleito do autor caso o pedido deste seja acolhido.

Conforme se verá adiante, a ausência de legitimidade exigida pelo art. 17 do Código de Processo Civil impede a análise do mérito do processo, determinando sua extinção.

Nesse sentido, o art. 485, inc. VI, do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando: "(...) VI – verificar ausência de legitimidade (...)".

Por se tratar de um vício gravíssimo, classificável como matéria de ordem pública, a ilegitimidade de partes pode ser verificada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme deixa claro o art. 485, § 3º, do Código.

Entretanto, em que pese a gravidade do vício e a proibição legal do

prosseguimento do feito e julgamento de mérito, no que se refere à ilegitimidade passiva o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de correção do vício, admitindo a substituição do réu originariamente apontado pelo autor pelo sujeito verdadeiramente legitimado passivo para a ação.

Assim, se o réu alegar, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, apontando o verdadeiro legitimado passivo, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu (art. 338 do CPC).

Para viabilizar a providência descrita acima, o art. 339 determina que, quando o réu alegar sua ilegitimidade, deverá indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que disso tiver conhecimento.

Desta alegação, será o autor intimado para, no prazo de quinze dias, manifestar se aceita a indicação e para, em caso positivo, proceder à alteração da petição inicial para a substituição do réu.

Assim, se é certo que a ilegitimidade sempre impede o exame do mérito, não é correta a afirmação de que a ilegitimidade passiva leva a automática extinção do processo, pois, nos termos dos dispositivos citados, tal irregularidade pode vir a ser corrigida, viabilizando o prosseguimento do feito contra o “novo” réu.

b) Interesse de agir

A par da legitimidade, o Código de Processo Civil exige que o autor tenha interesse para que possa propor a demanda.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, o interesse de agir existe quando o provimento jurisdicional postulado for efetivamente capaz de ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação.

Nesse sentido, conclui o referido autor que “só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o provimento pedido, na medida em que se tenha utilidade e essa aptidão”³⁰⁷.

Além da utilidade, a presença do interesse de agir decorre da necessidade do provimento jurisdicional.

Para Cassio Scarpinella Bueno³⁰⁸, o interesse de agir nesse sentido representa a “necessidade de requerer, ao Estado-juiz, a prestação jurisdicional com vista à obtenção de uma posição de vantagem”, vantagem esta que nada mais é do que a utilidade referida por Cândido Rangel Dinamarco.

Portanto, a presença do interesse de agir passa pela verificação da presença de duas circunstâncias, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, sendo inadmissível a análise de demandas tidas, de plano, como inúteis ou desnecessárias.

Cândido Rangel Dinamarco inclui ainda como condição da ação a adequação da medida, assim entendida a escolha da técnica processual adequada à concessão da tutela do bem jurídico litigioso. Assim, faltaria interesse de agir ao autor sempre que a medida jurisdicional requerida não fosse aquela tida como adequada pelo sistema processual.

É nesse contexto de utilidade-necessidade e adequação que deve ser entendida a exigência do interesse a que se refere o art. 17 do CPC como condição para que a ação seja proposta.

O art. 19 do Código de Processo Civil deixa claro que o interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II – da autenticidade ou da falsidade de documento.

O dispositivo faz alusão a tutela jurisdicional meramente declaratória³⁰⁹, garantindo o direito de pleitear uma mera declaração sem que este requerimento esteja, necessariamente, somado a um pedido de providência ou inovação³¹⁰.

Rigorosamente, o interesse do autor em uma decisão meramente declaratória reside na certeza a ser alcançada pela definitividade da decisão

judicial que se pronuncia sobre o mérito, no caso sobre o pedido de declaração da existência ou inexistência da relação jurídica objeto do processo.

A tutela jurisdicional meramente declaratória, em síntese, caracteriza-se por visar, única e exclusivamente, a retirada do mundo jurídico de uma incerteza acerca da existência ou inexistência da relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de um documento, residindo nesta certeza o interesse de agir do autor.

Ademais, nos termos do art. 20 do CPC, “é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito”.

8.5 Formas de arguição e verificação e consequências da decretação das irregularidades relativas às condições da ação

De tudo que restou dito no presente capítulo, a primeira e principal conclusão é a de que o sujeito que não possua interesse e legitimidade não deve propor a ação.

Entretanto, o sistema processual, a par de proibir este indesejável ajuizamento, ocupa-se de disciplinar o destino do processo, caso a ação seja proposta por alguém sem interesse e legitimidade.

A ausência das condições da ação redundará no fenômeno denominado carência de ação, que impede o exame do mérito e implica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Em síntese, pode-se afirmar que a carência de ação: a) impede o exame do mérito; b) deve levar à extinção do processo sem resolução do mérito; c) deve ser arguida pelo réu, na primeira oportunidade em que este vier a se manifestar nos autos do processo; d) ainda que não arguida pelo réu ou qualquer outro interessado, pode ser verificada de ofício pelo juiz; bem como, e) ainda que tal verificação e decretação deva se dar o quanto antes, caso o processo se desenvolva irregularmente, nada impede que a carência seja verificada e decretada em outro momento, a qualquer tempo e grau de

jurisdição.

Todas essas conclusões decorrem do fato de a ausência de uma das condições da ação representar um vício insanável e gravíssimo, o que significa dizer que a carência de ação é matéria de ordem pública³¹¹.

Como toda matéria de ordem pública, pode e deve ser verificada de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O fato de poder ser verificada e decretada de ofício pelo juiz não implica dizer que o réu não possa arguir a carência de ação e requerer a extinção do processo sem resolução do mérito. Aliás, ao contrário, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 337 que cabe ao réu alegar a carência, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos do processo, ou seja, em preliminar de contestação.

Entretanto, por ser a carência de ação matéria de ordem pública, caso o réu perca esta oportunidade, a preclusão, assim entendida a perda da oportunidade de arguir determinado vício, excepcionalmente não se opera, o que significa que, mesmo perdida esta oportunidade ideal, é possível a arguição em qualquer outro momento processual, bem como é admitida esta verificação de ofício pelo juiz a qualquer tempo.

8.5.1 Especialmente sobre a dinâmica de arguição de ilegitimidade passiva

Especificamente em relação à ilegitimidade passiva, o Código de Processo Civil estabelece uma dinâmica própria de verificação, arguição e decretação.

Isso porque, ao contrário da ausência de interesse ou de legitimidade ativa, que são vícios impossíveis de serem superados, a ilegitimidade passiva pode ser corrigida pela substituição do réu original pelo sujeito passivo correto.

Por essa razão, a arguição ou verificação de ilegitimidade passiva não implica a automática extinção do processo sem resolução do mérito.

O Código de Processo Civil dispõe que, antes disso, seja viabilizada a substituição do réu, assim entendida a saída da parte ilegítima e a entrada do sujeito passivo legitimado para a causa.

Nesse sentido, dispõe o art. 339 do Código de Processo Civil que, “quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação, no que é complementado pelo § 1º que reza: ‘o autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu’”.

Desta feita, caso a ação seja proposta contra uma parte ilegítima e esta indique o sujeito legitimado, ao autor deve ser dada a oportunidade de se manifestar podendo: a) emendar a inicial e requerer a substituição; ou b) insistir na continuidade da ação contra o réu, inclusive acrescentando o sujeito por ele indicado.

A emenda e consequente substituição permitem a correção da ilegitimidade e o prosseguimento do processo, livre do vício, rumo ao julgamento de mérito.

Entretanto, a discordância do autor em relação à indicação do réu transfere para o juiz a definição sobre a legitimidade passiva, que, caso afastada, levará ao desenvolvimento do processo e, se acolhida, implicará sua extinção sem julgamento de mérito.

8.6 Especialmente sobre a subsistência da categoria condições da ação no Código de Processo Civil de 2015

O art. 17 do Código de Processo Civil disciplina as denominadas condições da ação, identificando-as com o binômio interesse e legitimidade, nesse sentido rompendo com uma tradição do Direito Processual Civil pátrio, refletida no CPC de 1973, a qual, inspirada na doutrina de Enrico Tullio Liebman, identificava como três as condições da ação: interesse de

agir, legitimidade de partes e possibilidade jurídica do pedido.

No sistema atual, o reconhecimento da possibilidade jurídica do pedido em uma decisão judicial categoriza uma decisão de mérito³¹².

Outro ponto, em uma comparação entre o CPC de 2015 e o sistema do Código de 1973, que merece destaque é o fato de não mais haver uma referência expressa à categoria “condições da ação”, o que leva parte da doutrina a concluir que, tendo em vista o desaparecimento no texto normativo desta expressão, desaparece o tema “condições da ação”³¹³.

Entretanto, o desaparecimento da expressão condições da ação não justifica o abandono do estudo desta categoria tradicionalmente referida em nossa cultura jurídica processual, sobretudo porque o CPC continua se valendo das subcategorias legitimidade e interesse de agir, mantendo ademais a mesma estrutura e dinâmica destes institutos, que podem ser resumidas em: a) quando irregulares, impedem o exame do mérito; e, até por isso, b) podem ser alegadas pelas partes e conhecidas de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, o próprio conceito e a classificação da legitimidade e do interesse permanecem os mesmos no sistema atual.

Nesse sentido, a única mudança sensível é a categorização da outra (controvertida) subcategoria, a possibilidade jurídica do pedido que, no sistema do CPC de 2015, constitui decisão de mérito, formando coisa julgada material³¹⁴.

No sistema vigente, portanto, caso o magistrado entenda que o pedido formulado é juridicamente impossível, deverá extinguir o processo com resolução do mérito, julgando improcedente o pedido, fundamentando sua impossibilidade jurídica, o que dará ensejo à formação de coisa julgada material.

Portanto, no Código de Processo Civil, duas são as condições da ação, cuja falta implicará extinção do processo sem resolução do mérito:

legitimidade, ativa e passiva; e interesse de agir³¹⁵.

Conforme ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini³¹⁶, as condições da ação e os pressupostos processuais formam um conjunto denominado “pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional”, e a falta de qualquer um deles implica extinção do processo sem resolução do mérito³¹⁷.

À mesma conclusão chegam aqueles que entendem não mais existirem as condições da ação enquanto categoria autônoma, o que significa dizer que a polêmica possui implicações muito mais teóricas do que práticas.

Capítulo 9 Processo

9.1 Processo: método, relação processual e procedimento

Uma vez estudada a lide e a necessidade jurídica e social de sua solução, bem como enfrentadas as questões relativas às formas como o Direito admite essa resolução, restou claro que, ao lado das formas autocompositivas, que dependem da vontade das partes litigantes, como a autocomposição e a heterocomposição, o sistema jurídico estabelece a possibilidade de resolução do litígio pelo Estado, independentemente da vontade das partes, por meio da jurisdição.

A jurisdição, conforme já estudado, pode ser conceituada como o poder por meio do qual o Estado, de uma maneira inevitável, inafastável, imparcial, impositiva, imperativa, e substitutiva da vontade das partes³¹⁸, dita a resolução da lide.

Entretanto, para que o exercício do Poder Jurisdicional seja legítimo, o Estado apenas pode desempenhá-lo quando requerido por uma das partes interessadas, mediante o exercício do direito de ação, estudado no Capítulo 8, sendo certo que, a parte contrária, contra quem é feito o pedido, possui, entre outros direitos, o de ampla defesa e ao contraditório, devendo para tanto tomar ciência da demanda contra si formulada.

Portanto, para que a lide seja solucionada por meio do exercício do poder jurisdicional, faz-se necessário o estabelecimento de um método de atuação do Estado-juiz, com a participação dos sujeitos interessados em função de uma imposição constitucional.

Esse método de atuação do Estado no exercício do poder jurisdicional com a participação dos sujeitos interessados é o processo.

O desenvolvimento desse método implica, necessariamente: a) a formação de um vínculo jurídico entre os sujeitos interessados e o Estado-

juiz; b) a possibilidade de as partes ligadas por esse vínculo manifestarem seus interesses, exercerem seus poderes e direitos e cumprirem eventuais deveres dele decorrentes, e; c) na necessidade de esse exercício de direitos, poderes e deveres ser organizado racionalmente para a consecução do objetivo principal.

Portanto, em primeiro lugar, dada a necessidade do estabelecimento de um vínculo jurídico entre todos, impõe-se a formação de uma relação jurídica entre o Estado-juiz, que exerce jurisdição, e as partes interessadas na solução da lide, o autor da ação, que realiza o pedido e provoca o Poder Judiciário e o réu, que oferece resistência e tem o direito de defesa perante este.

A relação jurídica processual, portanto, é o vínculo jurídico entre os sujeitos do processo – Estado-juiz, autor e réu – formada com a finalidade de permitir que esses sujeitos exerçam legitimamente seus poderes, direitos e deveres.

Humberto Theodoro Jr.³¹⁹ ensina que o processo é uma relação jurídica, pois apresenta tanto o elemento material (um vínculo entre as partes e o juiz) quanto o elemento formal (regulamentação pela norma jurídica), produzindo uma nova situação jurídica para os que nele se envolvem.

Os integrantes da relação jurídica processual têm garantidos, por lei e pela própria Constituição Federal, em razão do simples fato de integrá-la, o direito de participarem do processo em todas as suas etapas, por meio dos atos processuais e, por outro lado, também por integrarem essa relação, possuem alguns deveres jurídicos impostos pela legislação processual.

O desenvolvimento da relação jurídica se dá mediante a prática de atos processuais por esses sujeitos e seus auxiliares de uma forma e em uma sequência preestabelecida em lei. A esta sequência concatenada de atos processuais praticados pelas partes, pelo juiz e pelos seus auxiliares dá-se o nome de procedimento.

O procedimento tem início com a formalização do pedido, pelo protocolo da petição inicial, e se encerra com o proferimento da sentença, ou mais amplamente, com a prestação da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o procedimento é o caminho constituído por todos os atos que sucedem a provocação inicial e que desenvolvem o processo preparando-o para o proferimento da decisão judicial.

Portanto, duas são as formas de se enxergar, regulamentar e estudar o processo: a partir da perspectiva da relação jurídica processual; e pela análise do procedimento.

Em outras palavras, o processo, pode ser visto e estudado como uma relação jurídica voltada à solução do litígio que se desenvolve em procedimento.

O estudo do processo enquanto relação jurídica leva à análise dos poderes, direitos e deveres dos sujeitos que a integram – Estado-juiz, autor e réu – bem como dos pressupostos fundamentais para formação (existência) e desenvolvimento válido e regular do processo.

Igualmente integra o estudo da relação jurídica processual a análise das razões e formas de sua extinção.

O estudo do procedimento, por sua vez, implica o conhecimento e sistematização da forma, dos prazos e dos momentos em que esses poderes e direitos podem (ou devem) ser exercidos, bem como de que maneira os deveres devem ser cumpridos.

O conhecimento e a sistematização dessas duas formas de abordar a mesma realidade processual é um dos grandes desafios do estudioso do processo.

O estudo da relação jurídica processual tem início neste capítulo em que se pretende analisar os direitos, poderes, deveres dos sujeitos processuais, no que será complementado pelo capítulo seguinte dedicado aos pressupostos de formação e desenvolvimento válido e regular do processo,

bem como às hipóteses estabelecidas em lei sobre a suspensão do desenvolvimento da relação processual, e quando a relação processual deve ser extinta.

O estudo do processo enquanto procedimento implica a análise da forma, lugar, tempo e momento da prática dos atos processuais uma vez que estes, combinados em sequência, formam o procedimento.

De antemão, cumpre aqui ser destacado que não há um procedimento único capaz de resolver todo e qualquer litígio e prestar todas as espécies de tutela jurisdicional.

Em outras palavras, o Direito Processual Civil estabelece algumas espécies de procedimentos voltados à prestação da tutela jurisdicional adequada para cada situação litigiosa, conforme será demonstrado no subitem a seguir.

9.1.1 Classificação do processo e procedimento

A depender da situação litigiosa, o processo, assim entendido o método de prestação da tutela jurisdicional voltado à solução da lide, bem como o procedimento, enquanto sequência de atos voltados ao desenvolvimento desse método, pode variar, assumindo diversas formas.

Essa variação se dá, sobretudo, em função da finalidade do processo, isto é, do objetivo a ser alcançado pelas partes e pelo juízo mediante a atividade processual, bem como em razão da natureza da situação litigiosa discutida em juízo.

Assim, a estrutura do processo e as etapas do procedimento têm de, necessariamente, ser diferentes caso o objetivo das partes e do juízo seja a demonstração da existência de determinados fatos e, conseqüentemente, a declaração da existência de uma relação jurídica (tutela jurisdicional de conhecimento) se comparada a um pleito de realização (concretização) no plano dos fatos de um direito, atividade típica da tutela jurisdicional executiva³²⁰.

Em outras palavras, a prestação da tutela jurisdicional de conhecimento e a prestação de tutela jurisdicional executiva, dadas as diferenças, peculiaridades e finalidades de cada uma delas, implicam um método de atuação jurisdicional e de participação das partes distintos.

A espécie de tutela jurisdicional pleiteada pelo autor durante muito tempo levou à classificação do processo em três modalidades: “processo de conhecimento”, “processo de execução” e “processo cautelar”, o primeiro voltado à prestação da tutela jurisdicional de conhecimento, de cunho meramente declaratório, condenatório ou constitutivo; o segundo voltado à prestação da tutela jurisdicional executiva e o terceiro voltado à tutela de determinadas situações de urgência.

Essa era a estrutura original do Código de Processo Civil de 1973 que, atualmente, não se sustenta à luz do atual Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Aliás, após as reformas sofridas pelo próprio CPC/73, o sistema codificado passou a admitir a prestação da tutela executiva e de urgência (não apenas cautelar) no bojo do mesmo processo em que se pleiteia e presta a tutela jurisdicional de conhecimento.

Portanto, a classificação do processo de acordo com a tutela jurisdicional pretendida já não se justificava após as reformas do CPC/73, e não se justifica à luz da atual sistemática procedimental do Código de Processo Civil, uma vez que um mesmo processo instrumentaliza a prestação das três espécies de tutela jurisdicional, quando muito, em fases distintas.

Assim, em vez de se falar em “processo de conhecimento” e “processo de execução”³²¹, fala-se em “fase de conhecimento” e “fase executiva”, fases estas integrantes de um mesmo processo que, por sua vez, também admite o pedido, análise e concessão de provimentos de urgência³²².

Portanto, é mais coerente com o sistema processual a classificação das fases procedimentais, de acordo com o principal objetivo das partes e do

juízo em cada um dos momentos do processo, do que a classificação do processo propriamente dito.

Nesse contexto, é possível se falar em uma “fase de conhecimento” em que a atividade das partes e do juízo é voltada ao exercício, pelas partes, dos direitos de requerer, alegar e provar, e pelo juízo, da atividade cognitiva, voltada ao conhecimento do litígio, das alegações das partes e dos fatos relevantes para sua solução, para que então a lide possa ser julgada.

Cassio Scarpinella Bueno³²³ ensina que “parece ser mais correto, à luz do modelo constitucional de processo civil, que, no particular, tem sido muito bem implementado pelas profundas transformações legislativas pelas quais vem passando o Código de Processo Civil³²⁴ nos últimos quinze anos, empregar a palavra ‘processo’ sem adjetivações”, e conclui “o que aceita eventuais adjetivações é a atividade jurisdicional que o autor pede para ser prestada no caso concreto”³²⁵.

Em outras palavras, pode-se concluir que o processo, enquanto método de atuação do poder jurisdicional, como regra, não deve ser classificado como “processo de conhecimento”, “processo de execução” ou “processo cautelar” conforme até recentemente se estruturava o próprio Código de Processo Civil de 1973, sobretudo porque um mesmo processo é apto a prestar as três espécies de tutela jurisdicional, estas sim classificáveis e distintas entre si, tal como demonstrado no item 4.2 desta Introdução.

Entretanto, não obstante a categoria “processo” não admitir, rigorosamente, uma classificação, o procedimento, isto é, a sequência de atos por meio dos quais o processo se desenvolve, pode ser classificado.

Nesse contexto, configuram-se dois grupos distintos: o procedimento comum; e os procedimentos especiais.

O procedimento comum é aquele que, em tese, é projetado para todas as formas de situação litigiosa e, portanto, em princípio, completo, maleável

e adaptável a toda sorte de conflitos.

Já os procedimentos especiais são procedimentos previstos de forma expressa em lei e especificamente criados para resolver determinadas situações litigiosas previamente concebidas pelo legislador.

Em outras palavras, os procedimentos especiais são desenhados pelo legislador especialmente para uma específica situação litigiosa.

O Código de Processo Civil dedica todo um Título³²⁶ compreendido entre os arts. 539 e 770 à previsão e regulamentação de procedimentos especiais.

Nesse campo, está prevista uma série de procedimentos de jurisdição contenciosa, tais como das “ações possessórias” e das “ações de inventário e partilha” além de procedimentos de jurisdição voluntária a exemplo do procedimento “divórcio e separação consensuais”, de “interdição” e de “constituição de tutela e curatela”, entre outros.

Em razão dessa previsão expressa no próprio Código de Processo Civil, sempre que a situação carecedora de tutela jurisdicional for especificamente tratada de uma forma peculiar pela lei, as partes interessadas e o juízo deverão pautar-se no que tange ao desenvolvimento do procedimento de acordo com estas regras especiais.

Ademais, nada impede que qualquer outra lei federal diferente do Código de Processo Civil preveja a existência de um procedimento especial para tutelar determinada situação jurídica litigiosa.

Assim, por exemplo, especificamente para tutelar a pretensão do cidadão voltada à anulação ou à declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, a Lei n. 4.717/65 estabelece o procedimento da “ação popular”, bem como para tutelar litígios de menor complexidade, no âmbito dos juizados especiais, as Leis ns. 9.099/95 e 10.259/2001 estabelecem um procedimento especial, mais simples para os processos em curso perante esses órgãos.

Da mesma forma, a Lei n. 12.016/2009 estabelece o procedimento do “Mandado de Segurança”, assim como as Leis ns. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) disciplinam o procedimento de jurisdição coletiva³²⁷.

Portanto, a primeira característica de um procedimento especial é sua expressa previsão legal, sendo certo que, na ausência de uma previsão de procedimento especial, a situação litigiosa é tutelada pelo procedimento comum.

É certo, contudo, que, por mais complexa que seja a lei definidora do procedimento especial, esta dificilmente é completa a ponto de regulamentar todas as etapas do procedimento, sendo comum a existência de lacunas e momentos procedimentais não disciplinados na lei especial, que, quando verificadas, atraem a incidência das regras do Código de Processo Civil relativas ao procedimento comum.

Assim, na falta de dispositivo especial que regule a questão, aplicam-se subsidiariamente as regras do procedimento comum previstas no CPC.

Nesse sentido, o art. 318, parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que “o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução”.

9.2 Relação processual: os sujeitos do processo

Por sujeitos do processo devem ser compreendidos o juiz, seus auxiliares, bem como as partes e seus respectivos advogados. Cada um dos itens subsequentes será dedicado ao estudo dos poderes, direitos e deveres de todos esses sujeitos.

No estudo dos deveres do juiz, serão sistematizados todos os atos que o juiz deve praticar ou, mais amplamente, tudo aquilo que o juiz deve fazer no curso do processo em razão das imposições do sistema processual.

Já o estudo dos poderes do juiz implica a análise de todas as

possibilidades e posições jurídicas que a Constituição e a lei lhe outorgam para que cumpra seus deveres.

Ver-se-á ademais que, para a prática de atos processuais, o exercício de seus poderes e cumprimento de seus deveres, o juiz conta com alguns auxiliares cuja função e atribuições serão estudadas na sequência.

Por fim, o capítulo se encerra com o estudo dos direitos e deveres das partes, ou seja, com a análise das posições jurídicas que podem ser ocupadas pelos sujeitos do processo, autor e réu, do que estes podem exigir do Judiciário e dos limites do exercício desses direitos.

Considerando que o exercício de direitos pelas partes deve se dar, necessariamente, por meio de seus respectivos advogados, o capítulo se encerra com a análise das funções e posição ocupadas por eles na relação processual.

9.2.1 Do juiz: deveres e poderes do juiz

Já restou demonstrado que o Estado, ao retirar dos próprios sujeitos do litígio a possibilidade de imporem sua vontade pela própria força, atraiu para si e concentrou em suas mãos o poder de ditar a solução de todos os conflitos jurídicos que venham a existir, o poder jurisdicional.

Dada a necessidade jurídica e social de que esses litígios sejam solucionados, decorre também a obrigação do Estado de apresentar esta solução sempre que provocado, ou seja, o Estado tem o dever de prestar a tutela jurisdicional.

Considerando que o Estado é uma ficção jurídica, ou seja, uma abstração, o exercício desses poderes, para fins de cumprimento de seus deveres, dá-se por intermédio de pessoas físicas regularmente investidas nesse poder jurisdicional, o juiz.

O juiz, portanto, nada mais é, do que a pessoa investida no poder de, em nome do Estado, exercer jurisdição resolvendo, mediante o processo, os litígios que lhes sejam apresentados.

É sob essa perspectiva que devem ser estudados os deveres e os poderes do juiz: a pessoa regularmente investida no poder jurisdicional que em nome do Estado deve prestar a jurisdição, atendendo e realizando os direitos das partes, nos termos garantidos pela lei e pela Constituição.

Em apertada síntese, os deveres do juiz decorrem das normas constitucionais e obviamente das leis processuais que as detalham e regulamentam a forma como o Estado se compromete a prestar a tutela jurisdicional.

Entre esses deveres, a seguir pormenorizados destacam-se principalmente o dever de conduzir o processo nos termos da lei e da Constituição, em decorrência do princípio do devido processo legal e de prestar a jurisdição de uma maneira justa, motivada e em tempo razoável, em decorrência das regras que garantem aos cidadãos a inafastabilidade do controle jurisdicional, e os direitos decorrentes dos princípios da motivação, publicidade e razoável duração do processo, entre outros.

Já os poderes do juiz são todos aqueles necessários à consecução desses objetivos ou, em última análise, necessários à condução do processo e à prestação jurisdicional nos termos e da forma determinada pela Constituição Federal.

Antes de serem estudados os poderes do juiz, devem ser estudados os seus deveres.

Isso porque, enquanto agente público, o juiz só possui poderes para o cumprimento de seus deveres, de acordo com a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello³²⁸, que adota a nomenclatura dever-poder porque esta “ressalta sua índole própria e atrai atenção para o aspecto subordinado do poder em relação ao dever, sobressaindo, então, o aspecto finalístico”.

Assim, a compreensão dos poderes do juiz só pode ser sentida à luz de seus deveres a seguir analisados.

9.2.1.1 Deveres do juiz

Enquanto sujeito investido da autoridade jurisdicional do Estado, o juiz é encarregado de, em nome deste, se desincumbir dos deveres impostos ao Poder Judiciário pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, são deveres do juiz, primordialmente: a) prestar jurisdição de uma maneira justa, efetiva, motivada e em tempo razoável; b) conduzir o processo zelando por sua validade e regularidade, c) tratar as partes com igualdade; d) promover a qualquer tempo a autocomposição; e) obstar que as partes, em conluio, atinjam, por meio do processo, objetivos proibidos por lei, e; f) preservar e ser o primeiro fiscal de sua imparcialidade; g) ater-se aos limites do litígio nos termos propostos pelas partes.

Pormenorizando, detalhando e algumas vezes repetindo os ditames constitucionais, o Título IV da Parte Geral do Código de Processo Civil, entre os arts. 139 e 143, regulamenta, no plano infraconstitucional, os deveres, poderes e responsabilidades do juiz.

Os subitens a seguir serão dedicados a cada um dos deveres e responsabilidades, e o item subsequente abordará os poderes.

a) Dever de prestar jurisdição

O dever de prestar jurisdição de maneira justa, efetiva, motivada e em tempo razoável decorre diretamente da posição do juiz como a pessoa investida da jurisdição e, por conta disso, o principal sujeito responsável pela prestação jurisdicional.

Esse dever é uma consequência direta do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal, já estudado³²⁹, que garante a todo cidadão não apenas o direito de procurar o Poder Judiciário e exercer sua pretensão de proteção contra lesão ou ameaça a direito, como também garante o direito a uma resposta ou, mais amplamente, a uma prestação jurisdicional.

A partir do momento em que o Estado promete e garante esse direito a todos, ele deve, por intermédio de seus agentes, atender aqueles que o demandam. O agente responsável por esse atendimento é o juiz.

Ademais, nos termos da própria Constituição Federal que, conforme já estudado, estabelece outras normas complementares, a garantia da inafastabilidade não é qualquer resposta que deve ser prestada pelo juiz, e sim uma resposta justa, efetiva e em tempo razoável.

Justa no sentido de uma resposta de acordo com o ordenamento jurídico; e efetiva, no sentido de ter de ser, essa prestação jurisdicional, verdadeiramente capaz de tutelar, ou seja, proteger o direito litigioso, reconhecido como lesado ou ameaçado.

É também exigência da Constituição³³⁰ que a resposta jurisdicional seja fundamentada, sendo, portanto, dever do juiz explicar e demonstrar as razões de fato e de direito que o levaram a tomar aquela decisão.

Por fim, decorre também desse dever primordial de todo o magistrado, a necessidade de essa resposta se dar em tempo razoável, sendo, em decorrência disso, dever do juiz evitar e combater atrasos injustificados e incidentes processuais inúteis ou desnecessários.

No que tange à duração razoável do processo, o inc. II do art. 139 dispõe expressamente que é dever do juiz zelar pela mesma, no que é complementado pela norma constante do inc. III, que dispõe que o juiz deve “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”.

Por força desses dispositivos, o juiz deve fazer observar e observar ele mesmo a determinação constitucional da duração razoável do processo, buscando, nos limites das possibilidades fáticas e jurídicas, prestar a jurisdição no tempo mais adequado possível e fazendo seus auxiliares e as próprias partes, igualmente, buscarem essas celeridade e eficiência, combatendo etapas mortas e diligências inúteis ou desnecessárias³³¹.

O dever do juiz de sempre prestar jurisdição, a par de decorrer do art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, está também estampado no art. 140 do Código de Processo Civil que dispõe que “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”.

Com isso, quer-se dizer que o juiz é obrigado a decidir ainda que não haja regra legal ou constitucional específica, jurisprudência, ou qualquer outra fonte primária aplicável ao caso.

Nessas hipóteses, ainda assim, o juiz deve buscar sua resposta no ordenamento jurídico, trazendo, em sua fundamentação, todos os princípios e demais elementos normativos que o levaram a decidir naquele sentido, nunca podendo, todavia, recusar-se a decidir os casos que lhe sejam apresentados.

Essa recusa implicaria uma violação direta da garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o dever de prestar jurisdição é expressamente estendido à tutela jurisdicional executiva pelo art. 139, inc. IV, que estabelece como dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Resta clara, da referida norma, a conclusão no sentido de que o dever do juiz de prestar jurisdição não se encerra com a declaração sobre qual parte litigante tem razão e nem mesmo com a determinação para que a parte derrotada cumpra o comando judicial, sendo também dever do magistrado, em caso de desobediência a esse comando, atuar para que a ordem judicial produza efeitos no plano dos fatos por meio dos mecanismos processuais e procedimento típicos da tutela jurisdicional executiva, sempre nos limites requeridos pela parte.

b) Dever de conduzir o processo e de zelar por sua regularidade

Para atingir o dever primordial de prestar jurisdição, outro dever atribuído ao magistrado é o de conduzir o processo zelando sempre por sua validade e regularidade.

De rigor, sob um olhar mais detalhado, ver-se-á que se trata de dois deveres: b.1) o dever do juiz, de ofício, de conduzir o processo; e b.2) o dever do juiz de zelar pela validade e regularidade do processo.

Diz-se “de ofício” esse dever do juiz de realizar essa dupla tarefa de condução e cuidado com a regularidade do processo, pois esses deveres decorrem diretamente da sua função, cabendo ao juiz, nessa qualidade, determinar o andamento do processo nos termos ditados pelo Código de Processo Civil, sempre fazendo-se observar seus ditames, prazos e formas.

Em outras palavras, uma vez provocado pelo autor que exerce o direito de ação, o juiz tem o dever de lhe ofertar a prestação jurisdicional, devendo para tanto, de ofício, isto é, independentemente de outras provocações ou pedidos específicos, conduzir o processo³³².

Nesse sentido, é expresso o art. 2º do Código de Processo Civil: “O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

Por exceções previstas em lei, devem ser entendidas aquelas que proíbem expressamente o juiz agir de ofício, devendo este aguardar a provocação.

Também independe de provocação, sendo dever do juiz agir “de ofício”, a detecção e correção de nulidades processuais, assim entendidas a desobediência à forma e demais ditames legais e constitucionais, sobretudo quando a nulidade causa intolerável prejuízo à parte³³³.

Decorrencia disso é o dever do juiz de sempre verificar vícios ou irregularidades de ofício e, na medida do possível, sempre procurar corrigi-los diretamente ou determinar sua correção pela parte, porque, para tanto,

o juiz sequer precisa aguardar ser provocado³³⁴.

Tais deveres, de rigor, decorrem do princípio do devido processo legal que dispõe que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal, assim entendidos o processo e o procedimento que sejam desenvolvidos de acordo com a lei e com a Constituição; sendo dever do juiz, portanto, determinar e zelar por essa observância até como forma de garantir a validade e legitimidade de sua decisão.

O art. 139, inc. IX, do CPC é expresso nesse sentido quando dispõe ser dever do magistrado “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”.

c) Dever de tratar as partes com igualdade

Outro importante dever do juiz, em todo e qualquer processo, que merece destaque nesta sede, é expresso nos arts. 139 e 143 do CPC, qual seja, o de tratar as partes com igualdade.

O dever de tratar as partes com igualdade, além de expresso no art. 139, inc. I do CPC, tem, obviamente, fundamento constitucional (art. 5º caput da CF), além de ser uma das normas fundamentais do Código de Processo Civil, consagrada no art. 7º.

Até por isso, o princípio da igualdade foi exaustivamente examinado nos itens 6.1.4.11 e 6.2.7, do Capítulo 6.

Em consonância com as referidas normas fundamentais, o art. 139, inc. I do Código, deixa claro ser primordial que o juiz, quando da condução do processo, garanta o mesmo tratamento e conceda as mesmas oportunidades aos litigantes no curso do procedimento.

Trata-se da já referida garantia³³⁵ de “paridade de armas” que se traduz na necessidade de igualdade de meios, instrumentos e oportunidades, que está expressa e diretamente ligada pelo art. 7º do Código ao dever do juiz de promover o efetivo contraditório.

Por essa razão, inclusive, o dever de tratamento igualitário não se resume a uma igualdade formal, podendo o juiz, sempre que detectar situações em que uma das partes esteja sendo excessivamente onerada ou impedida de exercer plenamente o contraditório, determinar medidas voltadas à promoção do contraditório efetivo e do equilíbrio da relação processual.

Assim, atendendo às circunstâncias do caso concreto e de cada um dos sujeitos do processo, pode o juiz, exatamente com o intuito de promover a isonomia, dilatar o prazo para uma das partes ou redistribuir o ônus da prova, sempre que estas atitudes ao fim promovam o equilíbrio entre os sujeitos da relação processual³³⁶.

d) Dever de promover a autocomposição

O Código de Processo Civil também é claro no sentido de que o juiz, além de ter competência para impor a solução do litígio no exercício da jurisdição, também possui o dever de tentar a solução da lide por meios autocompositivos.

Essa é a determinação constante no art. 139, inc. V, do Código, que, além de deixar expresso esse dever, dispõe que, para tanto, o magistrado pode contar com a colaboração de conciliadores e mediadores judiciais, auxiliares do juízo, a seguir estudados.

Trata-se, ademais, de uma norma fundamental do Código de Processo Civil que, em seu art. 3º, §§ 2º e 3º, consagra o princípio da preferência pelos meios autocompositivos.

A busca da conciliação e mediação, pelo juiz e seus auxiliares, permite, a um só tempo, reduzir a atividade processual dispensando as atividades probatória e decisória quando obtida a solução consensual, bem como permite a composição da lide de um modo construído e aceito pelas partes em substituição à decisão imposta pelo juiz³³⁷.

Tal papel, que, repita-se, não é apenas do magistrado, pode ser exercido a qualquer momento, cabendo aqui o destaque para o disposto no art. 359 do Código, que estabelece que “instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem”.

Sempre que obtida a solução consensual o processo deve ser extinto com resolução do mérito³³⁸ o que claramente demonstra a possibilidade de o processo atingir seu objetivo de solucionar o conflito, sem que o juiz tenha propriamente exercido jurisdição, no sentido de impor a solução para a lide.

e) Dever de obstar que as partes, em conluio, atinjam, por meio do processo, objetivos proibidos por lei

Dispõe o art. 142 do CPC que “convencendo-se, pelas circunstâncias da causa, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá sentença que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé”.

Assim, sempre que o juiz se deparar com o intuito das partes litigantes de, em conluio, fraudar a lei ou atingir finalidade ou objetivo vedado pelo ordenamento jurídico, é seu dever “proferir decisão que obste a consecução deste objetivo”.

A regra, de rigor, afirma uma obviedade dado que seria absolutamente inaceitável que o processo – método exercício do poder jurisdicional nos termos da lei e da Constituição – servisse como um instrumento de burla ao próprio ordenamento jurídico.

Ademais, vale destacar que nos termos do Código Civil são nulos os atos simulados e praticados em fraude à lei, sendo portanto, também por esta razão, uma decorrência lógica destes dispositivos o dever do juiz de evitar que o processo e sua própria atuação se preste a concorrer, ou mesmo a

“legitimar”, a prática de tais atos, combatidos e vedados pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido dispõe o art. 166 do referido diploma que: “É nulo o negócio jurídico quando: III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito”, assim como estabelece o art. 167 também do Código Civil que “É nulo o negócio jurídico simulado (...)”.

Desta feita, sempre que o comportamento das partes, os atos processuais e os demais elementos constantes dos autos do processo denotem que a vontade das partes ou o próprio litígio está sendo simulado com o intuito de se fraudar a lei deve o juiz proferir decisão que obste o atingimento desta finalidade pelas partes.

Ademais, por claramente contrariar o princípio da boa-fé³³⁹, a parte final do art. 142 do Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de punir as partes com as penas previstas para a litigância de má-fé, cabendo portanto, nestes casos, ao juiz, além de obstar o objetivo almejado pelas partes, penalizá-las, fazendo uso do poder sancionatório a seguir estudado³⁴⁰.

f) Dever de zelar pela sua imparcialidade

Também é dever do juiz zelar e ser o primeiro fiscal de sua própria imparcialidade.

A imparcialidade, conforme visto, é uma das características da jurisdição, fundamental para que, não apenas a decisão, mas todo o processo seja legítimo.

Um juiz parcial, assim entendido aquele que possua relação ou interesse na vitória de uma das partes, tem o dever de imediatamente se afastar do processo até porque, caso continue conduzindo o procedimento e profira decisão, estará esta eivada de nulidade.

Por essas razões, o magistrado deve, sempre que perceber, autodeclarar-se suspeito ou impedido nos termos do art. 144 e 145 do Código de

Processo Civil, que serão analisados no item 10.3, “b”.

Portanto, sempre que se deparar com um processo em que seja parte uma das pessoas arrolados nesses dispositivos ou mesmo quando o juiz, por um outro motivo qualquer, entenda possuir interesse na causa que prejudique sua imparcialidade, deve pronunciar seu afastamento.

Caso o juiz assim não o faça, conforme veremos adiante, as partes possuem o direito de provocar esse afastamento, sendo, contudo, essa medida necessária apenas quando o magistrado for realmente suspeito ou impedido e falte com o seu dever de autodeclaração dessa condição.

g) Dever de adstrição ao pedido

Por fim, mas não menos importante, deve ser destacado o dever do juiz, quando de seu julgamento de se ater aos limites propostos pelas partes, sendo, por via de consequência, vedado ao magistrado conhecer de matéria ou julgar questões que não lhe foram apresentadas pelas partes interessadas.

Tal dever, expresso no art. 141 do CPC, é decorrência da já comentada inércia jurisdicional, segundo a qual o Poder Judiciário não age senão quando provocado e nos limites da provocação, sendo, desta feita, vedado ao magistrado extrapolar esses limites julgando matéria para a qual não tenha sido provocado.

A adstrição do juiz ao pedido ou, mais amplamente, a inércia jurisdicional que limita a atuação do juiz à provocação das partes, garante, a um só tempo, a preservação da imparcialidade do magistrado que não pode conhecer e julgar questões por ele mesmo inseridas no processo, bem como garante às partes a observância de seus direitos de ação e de defesa, dado que estas podem ter a certeza de que apenas obterão o pronunciamento jurisdicional sobre exatamente aquilo que propuseram e debateram no curso do processo.

O sistema processual civil autoriza apenas excepcionalmente a

possibilidade do juiz de decidir sobre questões que não tenham sido objeto de pedido expresso, entre as quais a responsabilidade por custas e demais despesas processuais, honorários advocatícios, juros legais e correção monetária, além das prestações sucessivas que se vencerem no curso do processo.

Fora destas hipóteses expressamente arroladas pela lei, o juiz não pode extrapolar o objeto da provocação, sendo nula a decisão que desrespeite o dever de adstrição ao pedido³⁴¹.

9.2.1.2 Dos poderes do juiz

Conforme demonstrado, o juiz, entre outros deveres, tem o dever de prestar jurisdição, obrigando-se, para tanto, a conduzir o processo nos termos da lei, zelando pelo seu desenvolvimento válido e regular.

Dessa forma, até para que o juiz alcance seus objetivos e cumpra seus deveres, o ordenamento jurídico lhe concede alguns poderes.

Cândido Rangel Dinamarco³⁴² afirma que o juiz tem todos os poderes gerais de “direção do processo, julgamento da pretensão das partes e de imposição dos efeitos de sua decisão” e, mais adiante, aduz que a síntese dos poderes-deveres do juiz reside no binômio “dirigir e tutelar”.

Nesse contexto, são poderes do juiz: a) o decisório; b) ordinatório; c) o instrutório; d) o sancionatório; e) o poder executório.

Os poderes de direção se expressam por meio dos poderes ordinatório, instrutório e sancionatório, ao passo que o dever de tutelar propriamente dito é atingido pelos poderes decisório e executório.

Sobre cada um desses poderes serão tecidas breves considerações a seguir.

a) Poder decisório

O mais óbvio poder do juiz é o decisório. Trata-se da principal

decorrência do dever do juiz de prestar jurisdição e constitui a essência de sua função.

Por poder decisório deve ser entendido não apenas o poder de decidir o mérito, isto é, declarar quem tem razão no litígio, pois é do juiz também o poder de decidir os destinos e os rumos do processo.

Cabe ao juiz, portanto, decidir todos os pontos controvertidos e questões relevantes para o andamento e julgamento do feito.

Nesse sentido, é o juiz quem vai decidir se a parte tem direito à prática deste ou daquele ato processual, sobre a necessidade ou desnecessidade de audiência, sobre a eventual hipótese de suspensão do processo ou sobre a aplicação deste ou daquele dispositivo procedimental ao caso.

Além disso, cabe ao juiz, quando entender adequado nos termos da lei, em vez de decidir o mérito, decidir pela extinção do processo sem a resolução do mérito³⁴³.

Em suma, integra o poder decisório do juiz: a.1) o poder de decidir o mérito, julgando o pedido formulado; a.2) decidir todas as questões incidentes que surjam no curso do processo e que sejam capazes de influir no desenvolvimento do mesmo; a.3) decidir sobre a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificar que essa necessidade se impõe.

Mais adiante³⁴⁴, ver-se-á que os atos decisórios do juiz são denominados sentença quando extinguem o processo, com ou sem resolução do mérito, ao passo que os demais atos decisórios que, no curso do processo, resolvem questões incidentes são denominados decisões interlocutórias.

b) Poder ordinatório

O poder ordinatório decorre diretamente do dever do juiz de conduzir o processo zelando pela sua validade e regularidade nos termos já referidos no item antecedente.

Diz-se ordinatório pois este poder permite ao juiz “por ordem”, dar

andamento ao processo e, portanto, corresponde, nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco³⁴⁵, ao poder de “direção do processo”.

Assim, apesar de ser inerte e apenas estar autorizado a agir quando provocado, o juiz, uma vez provocado, tem o dever-poder de dar andamento ao processo, de ofício.

Nesse sentido, o art. 2º do Código de Processo Civil dispõe que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

Isso quer dizer que cabe ao juiz determinar o andamento do processo independentemente de novas provocações das partes, ordenando a prática dos atos processuais necessários ao prosseguimento do feito rumo à prestação jurisdicional³⁴⁶.

A esse poder de ordenar a prática dos atos processuais necessários ao andamento do processo dá-se o nome de poder ordinatório.

Ademais, está inserida também no poder ordinatório a capacidade do juiz de verificar de ofício, isto é, independentemente de provocação da parte interessada, os erros procedimentais e os vícios ligados à forma dos atos processuais, pois cabe a ele, pelo só fato de ser juiz e condutor do processo, zelar pela observância das regras procedimentais ou, mais amplamente, pelo respeito ao devido processo legal.

Com isso, se quer dizer que o juiz tem, por força do poder ordinatório, não apenas o poder de determinar a prática dos atos processuais necessários ao andamento do feito, como também o de fiscalizar e cuidar para que essa prática seja, do ponto de vista formal, correta e de acordo com as regras processuais.

De rigor, esse aspecto do poder ordinatório se desdobra em três: b.1) sempre verificar, de ofício e independentemente de provocação, a regularidade do processo e dos atos processuais; b.2) sempre que detectado um vício, corrigi-lo ou determinar a quem de direito que realize a

correção; b.3) caso verifique a impossibilidade de correção, extinguir o processo sem resolução do mérito³⁴⁷, exercendo, neste caso, também o poder decisório.

c) Poder instrutório

Por instrução do processo deve ser entendida a produção das provas necessárias para o julgamento da causa.

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco³⁴⁸, “instruir é preparar”, no caso do processo de conhecimento, preparar o processo para o julgamento da lide, razão pela qual conclui que a instrução no processo de conhecimento é “o conjunto de atividades de todos os sujeitos processuais, destinadas a produzir a convicção no espírito do juiz”.

Cabe ao juiz, no exercício do poder instrutório, conduzir a produção das provas necessárias ao conhecimento dos fatos controvertidos relevantes para o julgamento da causa.

As provas são os mecanismos processuais voltados à demonstração da ocorrência ou inoccorrência de fatos alegados pelas partes, controvertidos e relevantes para o julgamento da lide.

A importância da atividade probatória para o processo é enorme dado que é por esses mecanismos de esclarecimento dos fatos e de convencimento do juiz que este chegará ao descobrimento da verdade sobre os fatos controvertidos e relevantes para o julgamento de mérito.

Como cabe ao juiz, ao final do processo, o dever de motivadamente decidir o litígio, nada mais natural do que ser dele o poder de preparar esse futuro e inevitável julgamento.

Dizer que o juiz tem poder instrutório implica dizer que ele tem o poder de: c.1) determinar a produção de provas de ofício ou a requerimento de uma das partes; c.2) indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias; c.3) conduzir e participar de toda atividade probatória.

As duas primeiras conclusões estão expressamente previstas no art. 370 do Código de Processo Civil que, em seu caput, reza que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e, em seu parágrafo único, dispõe que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Ademais, no artigo dedicado ao arrolamento dos poderes do juiz, resta consignado que o juiz tem o poder de “determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa (...)”³⁴⁹.

Assim, além de autorizar as provas requeridas por uma das partes o juiz, independentemente de requerimento, caso entenda necessário para seu convencimento e esclarecimento da verdade de um fato relevante para o julgamento de mérito, pode determinar a produção da prova “de ofício”.

Por outro lado, caso entenda inútil ou desnecessária a produção de uma prova requerida por uma das partes, pode o magistrado indeferir tal requerimento nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o que também pode ser entendido como expressão do poder decisório – no sentido de decidir questões incidentes –, conforme tratado no subitem “a”, supra.

Ademais, o juiz deve participar da produção probatória, fazendo perguntas às testemunhas, interrogando as partes em audiência, questionando o perito e até, diretamente, realizando inspeções judiciais em pessoas ou locais capazes de revelar fatos importantes para o julgamento da causa.

Assim, a par de ser um dos destinatários da prova, o juiz, por ser dotado de poder instrutório, é o diretor e condutor de toda a atividade probatória que se desenvolve com sua participação e sob sua supervisão.

d) Poder sancionatório

Conforme já demonstrado especialmente nos itens 6.2.5 e 6.2.6 do Capítulo 6, não é dado às partes exercerem seus direitos processuais como recorrer, alegar e provar de uma maneira ilimitada e desarrazoada.

Cabe a esses sujeitos processuais praticarem os atos processuais a que têm direito, no curso do procedimento, dentro dos limites estabelecidos em lei que, genericamente, podem ser abarcados pelos denominados deveres de cooperação e boa-fé³⁵⁰.

O Código reputa litigante de má-fé aquele que pratica uma das condutas descritas no art. 80³⁵¹ e sanciona a parte litigante de má-fé com multa de até 10% do valor da causa, nos termos do art. 81.

O referido dispositivo atribui ao juiz a tarefa de sancionar o litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento.

Ademais, outras condutas e omissões das partes e até de terceiros que eventualmente estejam envolvidos em alguma atividade ou incidente processual são categorizadas pelo Código de Processo Civil como atos atentatórios à dignidade da justiça igualmente passíveis de punição pelo magistrado.

O Código de Processo Civil considera ato atentatório a dignidade da justiça, por exemplo, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC³⁵².

Também cabe ao juiz no uso do poder sancionatório punir as partes que pratiquem atos tidos por lei como atentatórios à dignidade da justiça.

Nesse contexto, o juiz deve: d.1) verificar se a ação ou omissão da parte ou do terceiro está caracterizada como ilícito processual (litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça); d.2) se for o caso, deverá aplicar a multa e demais penalidades previstas em lei.

A aplicação de todas essas sanções à parte ou a terceiros é de responsabilidade do juiz, que deve exercer o poder sancionatório “de ofício”, o que implica dizer que, a imposição de penalidades por litigância de má-fé

ou por prática de ato atentatório à dignidade da justiça independe de requerimento ou provocação por qualquer interessado.

e) Poder executório

Conforme já restou demonstrado no capítulo concernente à classificação da tutela jurisdicional, a proteção a ser concedida pelo Estado-juiz não se resume à declaração sobre qual das partes possui razão no litígio, e não se encerra com a determinação para que a parte condenada faça ou deixe de fazer alguma coisa.

Isso porque, caso o comando jurisdicional não seja voluntariamente obedecido pela parte à qual tenho sido imposto, subsiste o dever do Estado-juiz de tutelar a situação litigiosa, a esta altura, já acertada no que tange à qual das partes litigantes tem razão.

Nesse contexto, surge a necessidade de prestação da tutela jurisdicional executiva pelo Estado que, para tanto, dota o juiz do denominado poder executório.

O poder executório decorre da característica da imperatividade da jurisdição³⁵³, devendo ser entendido como o poder de praticar ou determinar a prática de atos de concretização, materialização e realização, no plano dos fatos dos direitos e comandos contidos em suas decisões.

Isso porque de nada adiantaria uma declaração ou, mais amplamente, o reconhecimento do direito em uma decisão judicial, se não possuísse o juiz também o poder de efetivar esses comandos e condenações.

Por esse motivo, o juiz possui o poder executório, cujo exercício pode se dar em diversos momentos processuais de acordo com a necessidade e natureza do comando, sendo certo que existem processos e procedimentos específicos, inteiramente vocacionados ao exercício do poder executório e à prática de atos executivos pelo juiz e por seus auxiliares.

São exemplos de atos judiciais executivos típicos da utilização do poder

executório: a) a busca e apreensão de pessoas ou coisas; b) o arresto, sequestro ou bloqueio de bens e aplicações financeiras do devedor; c) o desfazimento de obras; d) a interdição de atividades tidas pelo magistrado como nocivas ou ilícitas.

Em todas essas situações, a prática do ato volta-se a concretizar no plano fático um comando jurisdicional, sendo possível que, para essa efetivação material, o juiz conte com a ajuda de auxiliares e até mesmo do aparato policial do Estado.

9.2.2 Auxiliares da Justiça

Para o exercício de seus deveres-poderes, o juiz não está sozinho, pois conta, dentro e fora da estrutura do Poder Judiciário, com auxiliares da Justiça, assim entendidos sujeitos que, apesar de não serem dotados de poder jurisdicional, possuem competência para, sob o comando e supervisão do juiz, praticarem atos processuais voltados ao desenvolvimento do processo e à efetivação da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o juiz dispõe de grande número de auxiliares, nem todos integrantes dos quadros permanentes do Poder Judiciário.

Por esse motivo, pode-se dividir os auxiliares da Justiça em dois grandes grupos: a) os auxiliares permanentes; b) os auxiliares eventuais.

Os auxiliares permanentes são servidores do Poder Judiciário, via de regra, ingressos por meio do concurso público e que, uma vez integrantes da estrutura judiciária, vinculam-se a um juízo e passam a atuar no processo auxiliando o magistrado, sob seu comando e supervisão.

Os principais auxiliares permanentes da Justiça são: a) o escrivão (ou chefe de secretaria); b) o escrevente; c) o oficial de justiça.

Além dos auxiliares permanentes, também podem ser considerados, em sentido mais amplo, auxiliares da Justiça outros sujeitos que, apesar de não vinculados à estrutura do Poder Judiciário, nem hierarquicamente subordinados ao juiz, o auxiliam pontualmente em determinados processos.

Esses auxiliares podem ser classificados como auxiliares eventuais, exatamente por sua participação ou auxílio se dar apenas em situações ocasionais e específicas.

São auxiliares eventuais, por exemplo, o perito judicial, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o contabilista.

Ademais, ganham relevo no atual modelo de Processo Civil brasileiro a figura de dois auxiliares da Justiça cuja função é basicamente tentar solucionar a lide por métodos consensuais, os mediadores e conciliadores cuja previsão e atribuições encontram-se definidas entre os arts. 165 a 175 do Código de Processo Civil.

Os mediadores e conciliadores devem, preferencialmente, ser auxiliares permanentes, ou seja, integrantes do quadro do Poder Judiciário na qualidade de servidores públicos, mas nada impede que, sobretudo na falta deste quadro completo, a função seja exercida por sujeitos estranhos ao corpo de servidores do Judiciário mas de algum modo a ele vinculados, atuando, na hipótese, como auxiliares eventuais.

Escapam ao objeto desta Introdução ao estudo do Direito Processual Civil a análise pormenorizada de todas as atribuições e regras atinentes aos auxiliares da Justiça, sendo suficiente a noção geral acerca do papel dos principais auxiliares no desenvolvimento do processo.

9.2.2.1 Dos auxiliares permanentes

Conforme já afirmado, auxiliares permanentes do juízo são funcionários públicos, servidores do Poder Judiciário que, por não serem dotados de poder jurisdicional, agem sob o comando e supervisão do juiz ao qual são hierarquicamente subordinados.

O Código de Processo Civil disciplina as funções dos auxiliares da Justiça a partir dos art. 149.

Neste passo, serão destacadas as funções do escrivão, do chefe de

secretaria, do oficial de Justiça, dos mediadores e dos conciliadores dada a importância da atividade destes auxiliares do juízo para a atividade processual.

a) Do escrivão ou chefe de secretaria e dos escreventes

O escrivão ou chefe de secretaria é o principal auxiliar do juiz, cabendo a ele coordenar todos os trabalhos da secretaria do juízo.

Os principais atos praticados na secretaria do juízo são: a) os atos de documentação, como a juntada de documentos e autuação de petições; b) atos de movimentação processual, como a efetivação da carga e vista dos autos e a conclusão do processo; c) atos de comunicação, uma vez que cabe ao escrivão, sempre que determinado pelo juiz, realizar as citações e intimações das partes por meio de publicação ou pelo correio.

Ademais, é na secretaria que são armazenados e mantidos os autos do processo, sendo de responsabilidade do chefe de secretaria a conservação e arquivamento desses autos.

O art. 152 do CPC disciplina a atividade do escrivão ou chefe de secretaria atribuindo a este o dever de: "I – redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; II – efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária; III – comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo; IV – manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório (...); V – fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; VI – praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios".

Para cumprimento de seus deveres, o escrivão conta com o auxílio dos escreventes, igualmente auxiliares da Justiça integrantes da estrutura do

Poder Judiciário que, a depender do tribunal ao qual sejam vinculados, também são denominados analistas ou técnicos judiciários.

Por não serem dotados de poder jurisdicional, o escrivão, o chefe e os escreventes não são dotados de poder decisório, executório ou qualquer outro poder tipicamente jurisdicional, devendo praticar os atos processuais nos limites da lei e sob a condução e supervisão do magistrado.

Como servidores auxiliares da Justiça e subordinados ao juiz, o escrivão e os escreventes devem proceder à prática de seus atos de acordo com os comandos e decisões proferidas pelo magistrado e, nas hipóteses de prática de atos ordinatórios de ofício, deverá o juiz titular editar ato a fim de regulamentar tal atribuição³⁵⁴.

b) Do oficial de justiça

Eventualmente, a prática de atos processuais pode vir a ter de se dar fora da sede do juízo, ou seja, fora do edifício do fórum ou tribunal.

Isso porque nem todas as atividades processuais podem ser praticadas no espaço do fórum por absoluta impossibilidade fática ou por ser excessivamente oneroso.

É o caso de uma busca e apreensão determinada judicialmente, da remoção de pessoas ou coisa, ou mesmo a prática de atos comunicação a uma pessoa não encontrada pelo serviço de correios.

Para essas situações, o juiz conta com um auxiliar específico: o oficial de justiça.

O oficial de justiça, portanto, é o auxiliar do juízo que possui como atribuição a prática de atos fora do edifício do fórum ou tribunal sempre que assim determinado pelo juiz e, portanto, nos limites e termos ditados por este.

Via de regra, os comandos judiciais dirigidos às partes ou que tiverem de ser praticados fora do espaço do fórum ou tribunal são concretizados pelo

oficial de justiça.

Tais determinações são contidas no mandado judicial, que nada mais é do que o documento que contém a ordem (comando) judicial que deve ser cumprida pelo oficial de justiça.

Assim, o oficial de justiça munido do mandado judicial tem o dever-poder de cumpri-lo, estando autorizado, inclusive, a utilizar a força, com o auxílio policial, para efetivar os comandos expressos pelo juiz.

Nos termos do art. 154 do Código de Processo Civil, incumbe ao oficial de justiça: “I – fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora; II – executar as ordens do juiz a que estiver subordinado; III – entregar o mandado em cartório após seu cumprimento; IV – auxiliar o juiz na manutenção da ordem; V – efetuar avaliações, quando for o caso; VI – certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber”.

Do dispositivo transcrito, denota-se que, além de praticar determinados atos processuais fora da sede do juízo, incumbe ao oficial de justiça o dever de documentação de tais atividades para fins de conhecimento pelo juiz e demais sujeitos do processo das circunstâncias de sua realização, bem como para a preservação da memória dos atos processuais inicialmente praticados fora dos autos do processo.

Pelo fato de o oficial de justiça ser um auxiliar, não dotado de poder jurisdicional, sua atividade está sempre subordinada à prévia decisão ou determinação judicial para que ele execute alguma das providências determinadas.

A desobediência aos comandos do juiz, bem com o desrespeito à lei, atrai a incidência do art. 155 do CPC que impõe a responsabilização do

oficial de justiça que, sem justo motivo, recusar-se a cumprir, no prazo, os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que está subordinado ou que praticar ato nulo com dolo ou culpa.

Desta feita, atos e omissões ilegais, intencionalmente praticadas pelo oficial de justiça, que venham causar prejuízo às partes ou ao Poder Judiciário, geram o dever deste de indenizar os sujeitos prejudicados.

c) Os conciliadores e mediadores

Conforme já asseverado, o método jurisdicional, impositivo e substitutivo da vontade das partes, não é a única forma de solução de litígios, uma vez que, ao lado deste, o ordenamento jurídico admite e até estimula outros métodos de resolução da lide, notadamente aqueles frutos de acordo de vontade entre as partes.

Prova do estímulo do sistema processual à realização da autocomposição é o já citado art. 139, inc. V, do CPC, que estabelece ser dever do juiz promovê-la a qualquer tempo e, sobretudo, os §§ 2º e 3º do art. 3º do Código, que consagra o princípio da preferência pela solução consensual como norma fundamental do Processo Civil brasileiro³⁵⁵.

Para tanto, o Código deixa claro que o juiz, ao promover a autocomposição, deverá preferencialmente contar com o auxílio de conciliadores e mediadores.

Ademais, o art. 334 do Código de Processo Civil estabelece que “se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”.

Em outras palavras, como regra geral, o juiz deve, antes mesmo de dar oportunidade ao réu apresentar defesa, proporcionar às partes a oportunidade de, em audiência, buscarem a solução consensual pela mediação ou conciliação.

Nos termos do § 1º do art. 334 do Código, a referida audiência não será conduzida pelo magistrado, detentor do poder jurisdicional, mas sim por um auxiliar da Justiça: o conciliador ou mediador.

Os conciliadores e mediadores, nesse contexto, são os profissionais, auxiliares da Justiça que têm como função primordial conduzir a audiência de conciliação e mediação e buscar a solução consensual do litígio.

Uma vez obtida a resolução da lide mediante o acordo de vontades entre as partes, a atuação do juiz, no exercício do poder jurisdicional, limitar-se-á a homologar o acordo e extinguir o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, sem a necessidade de maiores investigações, bem como sem efetivamente ter de decidir a lide que, por força do acordo, deixa de existir³⁵⁶.

Para viabilizar a atividade de conciliação que, além de resolver os litígios nos termos ditados pelas próprias partes interessadas, contribui para diminuir a sobrecarga do Poder Judiciário, o Código de Processo Civil, no art. 165, determina que os tribunais deverão criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

Ademais, nos termos do art. 167 do Código de Processo Civil, os tribunais deverão manter um cadastro em que serão inscritos os conciliadores, os mediadores e também câmaras privadas de conciliação para que se mantenha o registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional.

Apesar de não integrarem a estrutura do Poder Judiciário e, portanto, não poderem ser considerados auxiliares permanentes da Justiça, os integrantes das câmaras privadas de conciliação podem ser considerados auxiliares eventuais por colaborarem pontualmente sempre que nomeados pelo juiz do processo.

Paralelamente, é dever dos tribunais estruturar seus órgãos com auxiliares permanentes, servidores públicos, portanto, integrantes de seus quadros, aptos a auxiliar o juiz a promover a mediação e conciliação entre as partes, sendo essencial para a estrutura Judiciária a existência de conciliadores e mediadores especializados e dedicados à solução consensual de conflitos.

9.2.2.2 Auxiliares eventuais

A par de prever a existência de um quadro de pessoal integrante da estrutura permanente do Poder Judiciário, integrantes das carreiras de auxiliares permanentes da Justiça, o Código de Processo Civil disciplina a atividade de outros sujeitos que eventualmente podem atuar no processo e colaborar com o Poder Judiciário.

Esses profissionais são auxiliares da justiça não integrantes da estrutura do Poder Judiciário e, por isso, classificados como auxiliares eventuais.

Apesar da importância desses profissionais para o feito, no mais das vezes, a natureza da respectiva atuação não justifica a presença deles nos quadros do Judiciário nem os custos que isso representaria, razão pela qual tais auxiliares são nomeados pontual e especificamente para atuarem em um determinado processo e, via de regra, são remunerados pelas partes.

O Código de Processo Civil disciplina as funções e atividade dos seguintes auxiliares eventuais da Justiça: a) perito; b) tradutores e intérpretes; c) administradores e depositários.

a) Perito

Existem situações em que, para o esclarecimento dos fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da lide, faz-se necessária a realização de um exame ou análise sobre pessoas, coisas ou vestígios por profissional portador de conhecimentos técnicos especializados de outra área do conhecimento humano que não o Direito.

O sistema processual civil prevê a ocorrência desse tipo de situação e, por isso, o Código de Processo Civil, entre os arts. 464 e 480, ocupa-se de disciplinar o cabimento e o procedimento de realização da prova pericial.

Cabe ao perito, auxiliar da Justiça nomeado pelo juiz, realizar a perícia colaborando, dessa forma, com o esclarecimento da verdade.

O perito, portanto, é o profissional portador de conhecimentos técnicos especializados capazes de esclarecer a verdade sobre fatos relevantes e controvertidos para o julgamento do litígio.

Por não integrar os quadros do Poder Judiciário, mas sim atuar eventualmente nos processos em que for nomeado, o perito deve ser classificado como um auxiliar eventual da Justiça.

A nomeação do perito é uma livre escolha do juiz que pode escolher, entre os profissionais portadores de conhecimento técnico, aquele de sua confiança.

Contudo, a par de observada a capacidade técnica do profissional, o juiz deve observar, quando da nomeação do perito, se este possui algum vínculo com as partes ou, mais amplamente, interesse no litígio, uma vez que ao perito se aplicam as mesmas hipóteses de impedimentos e suspeição aplicáveis ao próprio magistrado.

O art. 466 do Código de Processo Civil estabelece que: "o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso". Entre esses encargos, destacam-se: a) o dever de realizar a perícia e apresentar o laudo pericial com suas conclusões; b) o dever de escusar-se por impedimento ou suspeição, conforme determinado pelo art. 367 do CPC; c) o dever de responder as perguntas formuladas pelas partes e pelo juiz; e d) o dever de comparecer em audiência quando assim determinado pelo magistrado.

O estudo pormenorizado da prova pericial, isto é, do procedimento de realização da atividade do perito voltada ao esclarecimento dos fatos, com

a participação das partes e do juiz, seus prazos e etapas estão regulados entre os arts. 464 e 480 do CPC e escapam ao objeto deste item.

Uma vez nomeado e realizado seu trabalho, o perito faz jus a receber honorários periciais que nada mais são do que sua remuneração, via de regra, paga pela parte sucumbente³⁵⁷.

b) Tradutores e intérpretes

Dispõe o art. 192 do Código de Processo Civil que todos os atos processuais devem ser praticados em língua portuguesa, uma vez que o juiz, advogados e demais agentes do processo não estão obrigados a conhecer línguas estrangeiras.

O dispositivo, entretanto, não impede que documentos ou mesmo depoimentos em língua estrangeira sejam apresentados ou requeridos pelas partes, sobretudo nas hipóteses em que esses elementos probatórios são fundamentais para a demonstração da verdade dos fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da lide.

A exigência do Código de Processo Civil, nessas hipóteses, é que os atos praticados em língua estrangeira e os documentos não redigidos em língua portuguesa sejam traduzidos para o vernáculo.

Ademais, pode acontecer de a parte depoente ou testemunha ser portadora de deficiência que a impede de se comunicar pela linguagem falada, mas, apta a perceber a realidade, consiga exprimir sua vontade e se comunicar pela linguagem de sinais. Nesses casos, igualmente, faz-se necessária a tradução do seu depoimento.

Os intérpretes e tradutores são os auxiliares do juízo responsáveis por proceder a essa tradução.

Nesse sentido, dispõe o art. 162 do Código de processo Civil que “o juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para: I – traduzir documento redigido em língua estrangeira; II – verter para o português as

declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional; III – realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado”.

Portanto, o tradutor é o auxiliar do juízo com o encargo de traduzir documento redigido em língua estrangeira ao passo que o intérprete é aquele responsável por verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional, bem como realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado.

c) Administradores e depositários

Em determinadas situações, para a correta e efetiva prestação jurisdicional, faz-se necessária a prática de atos de detenção ou retenção de coisas ou de universalidades patrimoniais, nos termos determinados por uma decisão judicial.

É o caso, por exemplo, da busca e apreensão de um veículo objeto de uma ação voltada à restituição desse bem ao seu verdadeiro dono, ou da penhora de parte do patrimônio do devedor para futura alienação judicial do bem.

Via de regra, o ato de apreensão deve ser realizado pelo oficial de justiça nos termos do art. 154, inc. III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, uma vez apreendido o bem, tornam-se necessárias a guarda e conservação deste pelo período compreendido entre a apreensão judicial e a prática do ato subsequente.

Essa atividade de guarda e conservação incumbe ao depositário, auxiliar da Justiça com a responsabilidade de preservar os bens apreendidos judicialmente.

As atribuições do depositário estão regulamentadas no art. 159 do Código de Processo Civil que dispõe que “a guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo”.

Nesse contexto, o depositário deverá ser nomeado pelo juiz e, uma vez designado, assume o dever de conservação da coisa, respondendo pelos prejuízos que causar à parte, devendo indenizá-la nos casos de deterioração ou perecimento da coisa.

Outras vezes, a apreensão ou constrição patrimonial pode recair sobre universalidades patrimoniais ou bens que precisam ser administrados.

É o caso, por exemplo, da penhora sobre frutos e rendimentos de um bem imóvel, como o aluguel de salas de um prédio comercial para satisfação de uma dívida cujo devedor é o proprietário dos imóveis.

Na hipótese, a efetiva percepção desses frutos civis e entrega do dinheiro para o credor demandam muito mais que a simples guarda e conservação, mas também a administração destes bens.

Voltando ao exemplo da penhora sobre os aluguéis de salas comerciais, supracitado, o papel do administrador seria, sob a supervisão e fiscalização do juiz, anunciar a intenção de alugar esses imóveis, celebrar os contratos de locação, receber o valor dos inquilinos e entregá-los ao juízo para futura entrega ao credor.

A nomeação do depositário e do administrador, conforme o caso, deve ser feita pelo juiz, sendo certo que, ao assumir esse encargo, o nomeado assume os deveres de guarda, conservação e administração, conforme o caso.

O não cumprimento desses deveres autoriza a determinação, pelo juiz, de medidas executivas, além de poder implicar sanções de natureza civil, penal e processual, nesse caso, com a possibilidade de imposição de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça, como a multa.

Por outro lado, o depositário ou administrador tem o direito de ser remunerado pela conservação e guarda da coisa apreendida judicialmente e de ser ressarcido pelos valores despendidos com tal atividade.

9.2.3 Partes

O estudo das partes enquanto sujeitos da relação processual pode ser dividido em duas etapas: o estudo dos direitos e deveres das partes; e o estudo dos requisitos formais necessários para que as partes possam ser consideradas válida e regularmente presentes na relação processual e, portanto, capazes de, de forma legítima, exercer seus direitos e se desincumbir de seus deveres.

A análise dos requisitos formais indispensáveis para que as partes válida e regularmente integrem a relação processual e atuem no processo leva à análise e sistematização dos três requisitos que devem estar preenchidos para que os atos praticados pela parte, e o processo em si, sejam considerados livres de vícios ou nulidades; requisitos estes que serão estudados e sistematizados no capítulo dedicado aos pressupostos processuais, mais precisamente nos itens 10.3, “e”, “f” e “g”, uma vez que a tríplice capacidade são pressupostos processuais de validade.

A denominada tríplice capacidade, portanto, compreende: a) a capacidade de ser parte; b) a capacidade processual de estar em juízo; c) a capacidade postulatória. Enquanto pressupostos processuais de validade, os três itens serão estudados no Capítulo 10.

Já o estudo dos direitos e deveres das partes nos leva à análise do elenco de possibilidades e exigências que a parte, com apoio na lei e na Constituição Federal, pode fazer em relação ao Estado-juiz, à parte contrária e a eventuais terceiros que atuem no processo.

Entretanto, o exercício desses direitos, como todo exercício de direitos aliás, não é ilimitado ou incondicionado, possuindo as partes também o dever de respeitar determinados limites, não praticando certos atos

proibidos por lei.

O presente item, em um primeiro momento, voltar-se-á ao estudo e à sistematização dos direitos das partes e à análise dos deveres das partes no processo e as consequências do eventual descumprimento desses deveres.

Na sequência, serão tecidas considerações sobre a substituição e sucessão das partes originárias, tema disciplinados pelo Código de Processo Civil entre os arts. 108 e 112.

9.2.3.1 Direitos das partes

Preenchida a tríplice capacidade, a parte se torna presente na relação jurídica processual e, por estar regularmente representada, capaz de exercer seus direitos processuais participando, requerendo ou, mais amplamente, influenciando no desenvolvimento do procedimento.

O estudo das partes, enquanto sujeitos do processo, envolve, ao lado da sistematização da tríplice capacidade, a análise, ainda genérica, dos direitos das partes.

Disse-se genérica essa análise, pois, nesse primeiro momento, não será estudado nenhum dos direitos específicos de cada uma das partes, em cada etapa do processo, mas apenas os grandes conjuntos de direitos e posições jurídicas que podem ser exercidas e ocupadas pelas partes ao longo do desenvolvimento da relação processual.

De rigor, aliás, tais direitos são decorrência dos princípios constitucionais estudados no Capítulo 6, em especial: a) o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que garante às partes não apenas o direito de ação, como também o de participação no processo e a uma resposta jurisdicional justa, efetiva e em tempo razoável; b) o princípio da motivação, que consagra o direito de essa resposta jurisdicional ser devidamente fundamentada; c) o princípio do contraditório e ampla defesa, que garante a ambas as partes c.1) o direito à informação, reação, cooperação e participação no processo, bem como c.2) o direito à produção de provas

para demonstrar a veracidade de suas alegações de fato; d) o princípio do devido processo legal, que, de maneira ampla, garante o direito das partes de ter observadas todas as normas processuais no curso do procedimento.

Portanto, de forma genérica, pode-se afirmar que as partes possuem no curso do procedimento, com base na lei e na própria Constituição Federal, os direitos de requerer, alegar e provar.

É por meio de requerimentos, alegações e produção probatória que as partes atuam, participam e cooperam com o processo, buscando um julgamento favorável de mérito.

Conforme já asseverado, não cabe a esta Introdução investigar todos os direitos das partes, ou seja, todas as formas de requerimento, possibilidades e momentos de alegações e todas as formas e procedimentos em matéria probatória.

Isso porque o objetivo deste item é sistematizar os aspectos comuns a todos esses direitos e, em especial, demonstrar: a) que não obstante o assento constitucional dessas garantias, há limites formais e procedimentais para o exercício de cada um dos direitos processuais, não sendo essas possibilidades algo desregulado, ilimitado e incondicionado; b) que caso não exercidos tais direitos processuais por meio dos atos processuais, no momento, prazo e da forma estabelecidas em lei, o direito processual da parte pode ser extinto; c) que tais direitos, como todos os demais, não configuram possibilidades infinitas, devendo ser exercidos dentro de alguns parâmetros, em especial, os de lealdade e boa-fé das partes.

O objetivo deste item, portanto, é: a) sistematizar, ainda que genericamente, os direitos de as partes serem informadas e poderem requerer, alegar e provar; b) analisar o conceito de preclusão processual, assim entendida a perda do direito da parte por conta de seu não exercício no momento, prazo e forma adequadas; c) analisar também os deveres das partes, notadamente os deveres de lealdade e boa-fé que funcionam como um parâmetro limitativo do exercício dos direitos pelas partes.

a) Generalidades sobre os direitos das partes de requerer, alegar e provar

Conforme já asseverado, é da natureza do processo, enquanto procedimento em contraditório, a possibilidade de as partes participarem dele, sendo essa participação, ou pelo menos sua possibilidade, a condição para que a imposição do resultado do processo seja considerada legítima pelo sistema jurídico.

De maneira bem ampla, as modalidades de participação das partes podem ser resumidas às atividades de requerer, alegar e provar.

A atividade de requerer, nesse contexto, deve ser compreendida como uma série de possibilidades que têm em comum justamente o ato das partes de veicularem um pedido, ou mais amplamente, uma provocação ao Poder Judiciário.

Por pedido, nesse contexto, pode ser compreendida toda a sorte e espécies de provocações e requerimentos das partes dirigidas ao Juízo, a começar pelo próprio pedido de tutela jurisdicional sobre o bem jurídico pretendido pelo autor.

Entre esses pedidos, certamente um dos mais importantes para o processo e fundamental, haja vista que marca seu surgimento, é a própria “ação”, sendo certo que, em função de sua importância para o estudo do Direito Processual, além de breves considerações em um item apartado deste capítulo, foi dedicado outro capítulo para o estudo e sistematização de seus fundamentos, elementos e condições de exercício.

Ademais, o direito de requerer, nessa concepção amplíssima como direito genérico das partes, não se resume ao pedido de prestação de tutela jurisdicional que inaugura o processo.

Por força de as partes terem o direito de participar e influenciar o procedimento e o julgamento, o sistema processual prevê uma série de

possibilidades para que elas requeiram e provoquem incidentes processuais e desdobramentos procedimentais.

Nesse diapasão, as partes possuem, entre outros, o direito de: a) questionar a parcialidade do juiz; b) provocar o ingresso de terceiros na relação processual; c) solicitar a exibição de documentos ou coisas em poder destes para fins de provar suas alegações de fato, e, após a decisão; d) formular pedido de novo julgamento, mediante interposição de recursos.

Ademais, o próprio direito de defesa, conforme se verá em um dos itens a seguir, pode ser considerado integrante desse conceito amplíssimo de requerer.

Isso porque a apresentação de defesa, nada mais é do que a veiculação, via de regra pelo réu, de um requerimento ou, mais precisamente, um pedido de julgamento favorável aos seus interesses.

Ao lado da defesa, outro requerimento, muito comum e capaz de influenciar sobremaneira os destinos do processo, são os recursos.

Os recursos, decorrência direta do princípio do duplo grau de jurisdição estudado no item 6.1.4.8, nada mais são do que um pedido de rejuízo da causa pelo inconformismo da parte derrotada, sendo, portanto, em quase todas as situações litigiosas, possível para a parte derrotada a provocação de um novo julgamento, via de regra, por uma instância superior ao órgão prolator da decisão.

Portanto, é por meio de requerimentos que as partes atuam no processo, cooperam com a solução do litígio e influenciam no desenvolvimento e no destino do procedimento, sendo essa possibilidade de realizar requerimentos, pedidos e provocações que torna o processo democrático e desenvolvido em contraditório, contrapondo esse modelo a um processo inquisitório, em que as partes apenas apresentariam o problema e ficariam paralisadas esperando a solução jurisdicional, o que é inadmissível à luz de nosso sistema constitucional.

Entretanto, como regra geral, o sistema não admite simplesmente a provocação pelas partes, ou seja, a simples apresentação desarrazoada e imotivada de pedidos.

Isso porque não basta as partes levarem a pretensão, defesa ou, mais amplamente, sua intenção ao juiz esperando que este e seus auxiliares investiguem as razões e busquem os fundamentos desses pedidos e requerimentos.

De rigor, é ônus das partes apresentar essas razões e fundamentar suas manifestações e requerimentos.

Em outras palavras, é direito e ônus das partes, ao formularem seus requerimentos, trazer todas suas alegações, de fato e de direito, explicitando os motivos de seu pedido ou defesa.

Por esse motivo, por exemplo, é inadmissível uma petição inicial que pretenda provocar o Poder Judiciário, veiculando um pedido de tutela jurisdicional, sem que dessa petição constem as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido do autor, a denominada causa de pedir³⁵⁸.

Da mesma forma, é ônus do réu trazer em sua defesa todas as alegações que, sob sua perspectiva argumentativa, excluem a pretensão do autor e que são capazes de tornar o pedido do autor improcedente.

Aliás, conforme se verá com mais vagar adiante, o réu possui não apenas o direito de trazer suas razões e alegações de fato e de direito em sua defesa, como também possui o ônus de fazê-lo já na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos do processo, sob pena de perder o direito de realizar tais alegações.

A necessidade de fundamentar suas manifestações mediante alegações de fato e de direito está presente não apenas na petição inicial e na defesa, pois deve estar presente em todos os requerimentos e pedidos realizados pelas partes.

Assim, por exemplo, sempre que a parte pretender realizar a produção

de uma prova, deve demonstrar fundamentadamente para o juiz a razão e a necessidade dessa prova, o fato que com essa atividade se pretende provar e a importância dele para o julgamento da lide.

Da mesma forma, todos os recursos devem vir acompanhados das denominadas razões recursais, ou seja, das alegações do recorrente que demonstrem os motivos pelos quais a decisão recorrida está errada e merece ser reformada, sendo certo que um recurso que não aponte os vícios e equívocos da decisão recorrida sequer será processado e julgado.

As alegações das partes podem ser divididas de várias formas. Uma divisão que traz consequências práticas interessantes é a que separa as alegações de fato e de direito.

Por alegações de direito devem ser entendidas aquelas ligadas a interpretação, alcance e desdobramentos do texto normativo, e a compatibilidade deste com a Constituição Federal, por exemplo.

Uma outra categoria de alegações diz respeito à alusão aos acontecimentos fáticos em que se baseia o pedido ou a defesa.

A principal consequência advinda dessa divisão é a necessidade ou desnecessidade de produção de provas.

Isso porque a existência, vigência e o conteúdo das normas jurídicas independem de prova, uma vez que se presume de conhecimento do juiz.

A única exceção que merece alguma consideração é a previsão do art. 376 do Código de Processo Civil que exige a produção de provas de direito estrangeiro, direito municipal e direito consuetudinário, sendo certamente essas hipóteses exceções que confirmam a regra.

Assim, em quase todas as situações litigiosas em que as alegações das partes se resumem a fundamentos de direito, como constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, interpretação e alcance de dispositivos legais, aplicação ou inaplicabilidade de determinada lei ao caso litigioso, a lide será considerada exclusivamente de direito, o que tornará

desnecessária a produção de provas e permitirá que o juiz extinga o processo e julgue a lide sem que elas tenham de ser produzidas.

Outra conjuntura bastante distinta ocorre quando as partes, em suas razões de pedir ou de defesa, apresentam alegações de fato, hipótese em que a prova da veracidade dessas alegações e verificação da efetiva ocorrência dos fatos narrados pelas partes tornam-se imprescindíveis para o julgamento da lide.

Desta feita, os fatos alegados pelas partes, que sejam controvertidos e relevantes para o julgamento da causa, deverão ser objeto de atividade probatória, assim, entendida a atividade de verificação e demonstração da ocorrência desses fatos para o juiz no curso do processo.

Por fatos controvertidos devem ser entendidos aqueles que têm mais de uma versão nos autos do processo, via de regra, uma versão trazida pelo autor e outra narrada pelo réu.

Ademais, para que seja realizada a atividade processual probatória, o fato a ser provado deve ser relevante para o julgamento da lide, ou seja, capaz de atrair ou afastar a incidência de normas jurídica e, por via de consequência, determinar o conteúdo e sentido do julgamento.

Os fatos só podem ser considerados efetivamente ocorridos pelo juiz se restarem provados no curso do processo, o que implica, em outras palavras, a exigência de que as provas estejam expressamente documentadas nos autos do processo.

Por esse motivo, a atividade probatória não é apenas um direito constitucionalmente garantido pelo princípio da ampla defesa, constante do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, como também se traduz em um ônus que recai sobre a parte que, ao alegar determinado fato, atrai para si a incumbência de demonstrar a veracidade de suas alegações mediante a produção de provas no momento, prazo e forma adequados e de acordo com a lei, sob pena de, em não se desincumbindo desse ônus, não poder

ver o fato alegado ser considerado como ocorrido pelo magistrado.

A atividade probatória e o estudo de todos os meios de prova disciplinados no sistema processual escapam ao objeto desta Introdução, pois ocupam, na realidade, um importantíssimo e autônomo capítulo da teoria processual, cuja sistematização não pode ser realizada nesta obra.

Entretanto, em complemento às ideias genericamente aqui colocadas, serão tecidas breves considerações sobre a atividade probatória e o ônus da prova no subitem “e”, infra.

b) Especialmente sobre os direitos de ação e a uma resposta jurisdicional do autor

Conforme já asseverado, o direito de requerer, nesse contexto, é amplíssimo e engloba, em primeiro lugar, o direito de ação garantido constitucionalmente pelo art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, que deve ser entendido como o direito de provocar a jurisdição e exigir a prestação da tutela jurisdicional, dando início ao processo.

O tema, portanto, já foi tratado no Capítulo 8, dedicado ao estudo da ação; bem como no item 6.1.4.1, do Capítulo 6, dirigido ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e seus respectivos desdobramentos no plano processual.

O direito de requerer tutela jurisdicional, tal como garantido pelo ordenamento constitucional brasileiro, não se limita a ter o direito de provocar, ingressar no Judiciário com o pedido, ou dar início ao processo.

O direito de ação deve ser entendido como direito à prestação jurisdicional justa, efetiva, adequada e em tempo razoável (CF, art. 5º, LXXVIII), além de necessariamente ser desenvolvido dentro do modelo constitucional traçado para o processo, o que inclui as garantias do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório (art. 5º, LV), da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX), do juiz natural (art. 5º, XXXVII), entre outras.

Portanto, o Estado-juiz não satisfaz o direito de ação quando recebe a pretensão do jurisdicionado, e nem cumpre seu dever por completo quando se pronuncia acerca do direito posto em juízo, pois “ao lado de uma jurisdição, tem de haver uma juris-satisfação”³⁵⁹.

Nas palavras de Marinoni³⁶⁰, “não há como admitir, no Estado constitucional, que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva possa se limitar ao ato que instaura o processo, como esse direito fundamental pudesse ser apenas o direito de propor a ação ou pedir a tutela jurisdicional. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva é o direito de agir em juízo em busca da tutela jurisdicional efetiva do direito material, e isso está a quilômetros de distância dos antigos conceitos de ir a juízo e de direito de pedir a tutela jurisdicional”.

Tal concepção resta consagrada no Código de Processo Civil que, em seu art. 4º, dispõe que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”³⁶¹.

Portanto, é correta a conclusão no sentido de que o direito de ação é exercido e atendido em algumas etapas, tendo como a primeira o direito à provocação, seguida do direito de recebimento dessa provocação, do desenvolvimento do processo e, ao final, a entrega da tutela jurisdicional, assim entendida a efetiva e completa proteção do direito reclamado em juízo.

c) Especialmente sobre o direito à ciência da existência do processo e do andamento do procedimento

É uma decorrência direta do princípio do contraditório constitucionalmente garantido o direito das partes de terem ciência da existência do processo bem como de serem informadas no andamento do feito.

A ciência prévia e inequívoca das partes é a única maneira de oportunizar

o exercício dos demais direitos decorrentes do contraditório e dos demais princípios e regras integrantes do sistema processual, haja vista que, sem estar informadas do desenvolvimento do processo, as partes não têm como reagir ou, mais amplamente, cooperar e participar, apresentando os demais requerimentos, alegações, e provas.

Por essa razão, são imprescindíveis para o regular desenvolvimento do processo a prática pelo Poder Judiciário de atos de comunicação processual, notadamente as citações e intimações.

Por citação deve ser entendido o ato de comunicação processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual e, a partir de então, apresentar defesa, alegação, provas ou, ainda, proposta de solução consensual da lide.

Trata-se de um ato fundamental para fins de existência e validade da relação processual, conforme se verá no capítulo dedicado aos pressupostos processuais.

Isso porque, de rigor, é a citação que configura a existência jurídica do processo em relação ao réu, sendo, por um lado, a forma de atingimento e cumprimento do direito à ciência e, de outro, o marco inicial da possibilidade de exercício de outros direitos processuais pelo réu.

Já a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Portanto, a prévia intimação é condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo certo que, de rigor, as citações e intimações cumprem um duplo papel:

O primeiro, de dar às partes efetiva ciência do ato praticado no procedimento para que uma delas (ou ambas) possa tomar as providências que entenda necessárias, quer apresentando novos requerimentos e recursos, quer até mesmo cumprindo a determinação judicial, se for o caso.

Além disso, outro papel relevantíssimo exercido pelos atos de

comunicação processual é dar início à contagem do prazo para que as partes tomem a referida providência que entendam cabível. Nesse sentido, conforme se verá adiante, são justamente a citação e a intimação o marco imprescindível para a abertura de contagem desse prazo.

O início e a fluência do prazo para as partes são imprescindíveis para a marcha do processo rumo ao atingimento de seu objetivo final, pois a perda do prazo ou, mais amplamente, da oportunidade processual, somente possível após a prévia e regular citação ou intimação, autoriza a, legitimamente, decretar-se a perda do direito da parte por força da preclusão, a seguir estudada.

A indispensabilidade do direito à ciência e a importância da prévia citação ou intimação para o regular andamento do feito nos levam ao estudo dos atos de comunicação processual, tema que será retomado no item 12.6, assim como dos direitos das partes enquanto ônus processuais e a possibilidade de preclusão, a seguir analisados.

d) Especialmente sobre o direito de defesa

A defesa segundo Cândido Rangel Dinamarco³⁶² é o contraposto negativo do direito de ação, ou seja, “o conjunto de poderes e faculdades que permitem ao demandado opor-se à pretensão do autor, pleiteando sua rejeição”.

Nesse sentido, “o direito de defesa é exercido mediante todos os atos permitidos ao réu no processo, destinados a trazer elementos ao juiz e convencê-lo a não conceder a tutela pedida pelo adversário”³⁶³.

Além de fazer, com apoio na doutrina de Dinamarco, a associação entre ação e defesa, Heitor Vitor Mendonça Sica³⁶⁴ afirma que a defesa é o pedido de tutela jurisdicional formulado pelo réu que não se diferencie qualitativamente do pedido de tutela jurisdicional formulado pelo autor.

Nesse contexto, tal como o direito de ação, o direito de defesa pode ser considerado inserido no amplíssimo direito de requerer que possuem as

partes, uma vez que apresentar a defesa nada mais é do que o ato do réu requerer um julgamento favorável aos seus interesses.

Todavia, o direito de defesa merece aqui algumas considerações, em especial sobre seu status constitucional e sua imprescindibilidade para fins de validade do processo, o que não quer dizer que o direito de defesa não possa ser “perdido” pelo não exercício no momento, prazo e forma adequados.

Isso porque, ao contrário da ciência, ou seja, do direito à informação, que é imprescindível para fins de validade do processo e da própria existência da relação jurídica processual na perspectiva jurídica do réu, a defesa ou, mais amplamente, a reação ou oferecimento de resistência, por ser ato da parte, deve ser sempre possibilitada, sendo o seu efetivo exercício um ônus do réu³⁶⁵.

Tal como todos os demais requerimentos, a defesa, enquanto requerimento de improcedência do pedido, deve, talvez até com mais razão, trazer todos os fundamentos e alegações possíveis tanto no que tange à perspectiva estritamente jurídica quanto em relação à perspectiva dos fatos alegados pelo autor.

Em outras palavras, a reboque do direito de defesa do réu, são trazidos os direitos de alegar e fundamentar as razões de sua defesa e provar os fatos alegados, especialmente se a versão de tais fatos divergir da versão narrada pelo autor.

Além de direito do réu, a defesa também possui uma carga de ônus o que implica dizer que, se não realizada no momento, prazo e forma adequados, pode configurar-se a preclusão conforme se verá no item 12.6.6.

Sem adentrar nos detalhes formais e procedimentais relativos ao exercício do direito de defesa, o que escaparia aos objetivos deste item, é importante ressaltar que o nosso sistema consagra o princípio da

concentração da defesa que atribuirá ao réu o ônus de trazer, já na primeira oportunidade que lhe couber falar no processo, todas as alegações de defesa, sob pena de preclusão, assim entendida a perda da oportunidade de se trazer o argumento de defesa em um outro momento processual.

É decorrente do princípio da concentração da defesa, o princípio da impugnação específica dos fatos que impõe ao réu o ônus de, também na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, contrapor todos os fatos alegados pelo autor sob pena de esses fatos serem presumidos verdadeiros.

Apresentada a defesa e trazidos todos os argumentos de direito e de fato pelo réu, em havendo o conflito entre as versões expostas, nascerá para ambas as partes, autor e réu, o ônus de provar o alegado, cuja distribuição será analisada no item subsequente.

e) Direito de provar e o ônus da prova

Inevitavelmente, o julgamento da lide depende da confirmação da ocorrência de alguns fatos, bem como do momento e da forma em que aconteceram.

Isso porque é a partir de um quadro fático que a incidência dos dispositivos normativos acontece, sendo sempre o primeiro passo de um procedimento voltado ao julgamento da lide a verificação da ocorrência de fatos determinantes para sua configuração e solução.

Via de regra, a notícia dos acontecimentos fáticos relevantes para o julgamento da lide é trazida a juízo pelas partes quando da formulação de requerimentos, uma vez que, conforme já afirmado neste capítulo, a par do direito de requerer, a parte tem o ônus de fundamentá-los e de aduzir suas alegações em juízo, nesse âmbito compreendida a necessidade de alegações de fato.

Entretanto, a mera alegação dos fatos pelas partes não é suficiente para demonstração de sua ocorrência e consideração pelo juiz.

Isso porque, para que o fato alegado seja considerado ocorrido, faz-se necessária sua demonstração por meio de provas.

Prova, em síntese, é o conjunto de atividades voltadas à verificação e demonstração da verdade dos fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da lide no curso do processo.

Assim, uma vez alegados fatos relevantes e, em eles se tornando controvertidos, isto é, caso tenham mais de uma versão apresentada pelas partes litigantes, faz-se necessário o recurso à atividade probatória.

A prova só pode ser dispensada excepcionalmente em hipóteses em que ambas as partes apesar de estarem litigando sobre um determinado bem jurídico, não discordam acerca da situação fática, mas apenas das consequências jurídicas desses fatos.

Nesses casos, temos a denominada lide exclusivamente de direito que, exatamente por inexistir a controvérsia acerca dos fatos, dispensa a atividade probatória (art. 374, II e III, do CPC).

O art. 374, inc. I, do Código de Processo Civil também dispensa a atividade probatória em relação a fatos notórios, assim entendidos aqueles cujo conhecimento é público, como a realização de um grande evento esportivo a exemplo da Copa do Mundo ou das Olimpíadas em um determinado local.

Fora dessas hipóteses excepcionais, os fatos relevantes para o julgamento do litígio só podem ser considerados pelo juiz se sobre eles se fizer a prova suficiente de sua ocorrência, sendo certo ademais que tal prova deve, necessariamente, se dar no curso do procedimento, em contraditório, e restar devidamente documentada nos autos do processo.

Essa exigência de realização dentro do processo, com a ampla possibilidade de participação de ambas as partes e de estar devidamente documentada nos autos do processo decorre da interpretação do art. 371 do Código de Processo Civil que dispõe que “o juiz apreciará a prova constante

dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em função dessa determinação, a doutrina afirma que “aquilo que não estiver nos autos não está no mundo”, que deve ser entendida como a proibição de o juiz considerar outros elementos probatórios não existentes nos autos e pelos quais as partes não tiveram o direito de se manifestar.

Desta feita, todas as vezes que as partes, em seus requerimentos e alegação, fizerem referência à ocorrência de um fato, decorrerá automaticamente a necessidade de se produzir prova sobre esse fato, sob pena de o juiz não poder levá-lo em consideração.

Nesse sentido, a produção de prova, além de ser um direito, é um ônus da parte que deve, sempre que alegar a ocorrência de um acontecimento relevante para um julgamento favorável ao seu interesse, demonstrá-lo no processo por meio da prova.

O objeto da prova, em síntese, são os fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da lide, podendo o juiz dispensar a atividade probatória quando não houver controvérsia acerca da ocorrência dos fatos ou caso o fato seja considerado irrelevante para a resolução do litígio.

Considerando a importância e a relevância da atividade probatória para o destino do processo, o direito de prova é uma garantia constitucional, integrante do princípio da ampla defesa, conforme já asseverado no item 6.1.4.3.

Densificando e detalhando o direito constitucional à prova, o Código de Processo Civil se ocupa em 116 artigos da disciplina da atividade probatória (arts. 369 a 484).

Os referidos dispositivos tipificam sete meios de prova: a) depoimento pessoal das partes; b) confissão; c) prova pericial; d) prova documental; e) exibição de documento ou coisa; f) prova testemunhal; g) inspeção judicial.

A par disso, decorre diretamente do princípio da ampla defesa o direito

da parte de demonstrar suas alegações de fato por outros métodos não previstos pelo legislador, desde que tais métodos sejam lícitos, dada esta limitação à admissibilidade de provas obtidas ilicitamente imposta pela própria Constituição Federal no art. 5º, inc. LVI, que consagra o princípio da vedação das provas obtidas por meios ilícitos já estudado³⁶⁶.

Neste passo, mais uma vez, escapa ao objeto desta Introdução a análise de cada um dos meios de prova individualmente considerados, seu procedimento e desdobramentos.

Entretanto, um ponto que deve ser conhecido desde logo pelo estudioso do Direito Processual Civil diz respeito ao ônus da prova.

Por ônus da prova deve ser entendida a distribuição entre as partes do encargo de demonstrar os fatos favoráveis a suas pretensões, isto é, a indicação feita pela lei de quem deve se encarregar de produzir a prova e, por via de consequência, de quem sofrerá os prejuízos caso a prova não venha a ser produzida.

Tal distribuição é feita pelo art. 373 do CPC, que determina que o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

São fatos constitutivos todos aqueles que, ao ocorrerem, dão origem a uma relação jurídica entre as partes que, uma vez existente, dá suporte à pretensão do autor.

A título exemplificativo, pode-se fazer referência a um contrato de compra e venda celebrado entre as partes que fundamenta eventual pedido de pagamento do preço, pelo vendedor, ou entrega da mercadoria, pelo comprador.

Da mesma forma, um atropelamento ou acidente automobilístico é o fato constitutivo de uma demanda indenizatório movida contra o causador do dano.

Já os fatos impeditivos são aqueles que, quando ocorridos, viciam a relação jurídica obstando que ela produza os efeitos pretendidos pelo autor. Nesse sentido, constitui um fato impeditivo a menoridade ou incapacidade civil de uma das partes ao celebrarem um negócio jurídico que baseie o pedido deduzido em juízo, ou um vício de vontade, como a coação ou erro, quando da celebração de um contrato entre as partes, que impede a produção de efeitos deste negócio jurídico e o pleito por seu adimplemento em sede judicial.

Fatos modificativos consistem em acontecimentos posteriores à formação da relação jurídica que têm o condão de alterar os contornos ou os efeitos dessa relação. Um bom exemplo é a celebração de uma novação entre as partes, modificando o conteúdo de uma relação jurídica, tais como descontos no valor originalmente estipulado ou dilação de prazo para pagamento.

Já os fatos extintivos são aqueles que implicam, nos termos do direito material, o fim da relação jurídica até então existente e que, portanto, se comprovados, levam ao não acolhimento da pretensão do autor. O melhor exemplo de fato extintivo do direito do autor é o pagamento.

Assim, é do autor ou, mais amplamente, de quem realiza o pedido, o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos do direito pleiteado, voltando aos exemplos citados: a existência do contrato e da dívida em uma ação de cobrança ou a ocorrência do acidente e dos prejuízos dele oriundos em uma ação reparatória.

Nessas hipóteses, caso o réu se limite a negar a ocorrência desses fatos aduzidos pelo autor, não haverá para o réu qualquer ônus de produção probatória.

Entretanto, se o réu, em suas alegações de defesa, aduza fatos novos caracterizados como impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ele atrai para si o ônus de provar a ocorrência desses fatos.

Nesse sentido, é ônus do réu demonstrar a ocorrência de coação ou outro vício de vontade, fato impeditivo, que invalida o negócio jurídico; alegar a novação (fato modificativo), ou o pagamento da dívida (fato extintivo), objeto da cobrança.

Excepcionalmente, nos termos do art. 373, § 1º do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Um bom exemplo de inversão do ônus da prova está previsto no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) que autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, hipótese em que incumbirá ao fornecedor do serviço ou do produto o ônus de provar a inoccorrência dos fatos constitutivos narrados pelo autor.

Nos casos de modificação da distribuição tradicional do ônus da prova, o juiz deve dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído conforme expressamente dispõe o art. 373, § 1º, do Código.

Independentemente de quem possui o ônus da prova, é garantido a ambas as partes participar da produção das provas requeridas pela parte contrária ou mesmo determinadas de ofício pelo juiz.

Assim, por exemplo, independentemente de quem provocou o depoimento de uma testemunha, ambas as partes possuem o direito de participar da audiência em que ele se dará, podendo dele participar efetivamente, realizando perguntas ou arguindo a impossibilidade de aquela pessoa testemunhar por ser suspeita, incapaz ou impedida.

A par de funcionar como um mecanismo de distribuição da incumbência de provar, o ônus da prova também funciona como regra de julgamento.

Nesse sentido, à luz das provas produzidas no processo, o juiz deve concluir como ocorridos os fatos alegados e suficientemente provados pela parte que possuía o ônus da prova ou considerar como não ocorridos os fatos alegados, porém não provados pela parte.

f) Direitos das partes e ônus processual

Tão importante quanto as partes poderem participar do processo e exercer amplamente seus direitos de requerer, alegar e provar é o estabelecimento de condições formais e procedimentais, bem como de prazos, para que estes direitos sejam exercidos.

Isso porque a possibilidade incondicionada e procedimentalmente ilimitada de se praticar os atos processuais a que as partes têm direito implicaria a total impossibilidade de conclusão do feito que ficaria, a todo momento, sujeito a reviravoltas e a retrocessos procedimentais, impedindo o julgamento de mérito e a conclusão do processo.

Por esse motivo e considerando a necessidade de que o processo marche para frente rumo a um encerramento, até para que se atinja seu principal objetivo de prestar a tutela jurisdicional, os direitos das partes são, por um lado, garantidos pela Constituição Federal e pela lei, mas, por outro, condicionados a determinados aspectos que, se não obedecidos, implicam a perda do direito.

O fato de haver condições formais e prazos para esses direitos serem exercidos leva a doutrina a caracterizar os direitos processuais como verdadeiros ônus.

Ônus processual, segundo Arruda Alvim³⁶⁷, significa que “aquele a quem é dirigida a norma deve praticar o ato, conforme a determinação normativa, sob pena de, não o fazendo, ou se praticar mal, vir a sofrer, ele mesmo,

normalmente, um dado prejuízo”.

Mais adiante, o citado autor conclui que “a ideia de ônus consiste em que a parte deve, no processo, praticar determinados atos em seu próprio benefício”, pois, por conseguinte, “se ficar inerte, possivelmente esse comportamento acarretará consequência danosa para ela”³⁶⁸.

No mesmo sentido, Cândido Rangel Dinamarco³⁶⁹ assevera que “há ônus quando o cumprimento de uma faculdade é necessário ou ao menos conveniente para a obtenção de uma vantagem ou para evitar uma situação desvantajosa”, e, conclui: o ônus não é imposto para o bem de outro sujeito, mas para o bem do sujeito a quem se dirige.

Assim, da mesma forma que existe no sistema uma série de garantias constitucionais e direitos consagrados, este mesmo sistema encarrega os respectivos titulares a exercerem-nos no momento, prazo e forma adequados, sob pena de preclusão.

Nesse contexto, preclusão é a perda do direito de praticar um determinado ato processual por força de seu titular não o ter exercido no momento, forma e prazo adequados ou, em outras palavras, não ter corretamente se desincumbido do ônus.

Portanto, ao estudioso e operador do Direito Processual não basta a consciência da existência dos direitos das partes, sendo igualmente imprescindível compreender a forma, prazo e demais condições para a prática do ato para que o ônus seja corretamente desincumbido, haja vista que a irregularidade, como regra, acarreta a perda do direito processual até então existente.

Por esse motivo, é importantíssima a análise das regras procedimentais e formais para a prática dos atos processuais e o conhecimento e sistematização da contagem dos prazos processuais, tema que será retomado no Capítulo 12, sem contar a necessidade de conhecimento e obediência de normas específicas para a prática de determinados atos para

os quais a lei, expressamente, prescreve uma forma especial ou outra condição, tema que escapa ao objeto desta Introdução ao estudo do Direito Processual Civil.

Por ora, deve ficar desde já registrado que a prática dos atos deve observar todos os prazos e demais requisitos legais sob pena de o direito consagrado e garantido como da parte ser extinto pelo não exercício, por força da preclusão.

g) Especialmente sobre direitos processuais e alegações que não precluem

Por mais que o sistema de preclusão seja importantíssimo e até imprescindível para a marcha processual e prestação da tutela jurisdicional, o processo não pode conviver com determinados vícios e nulidades³⁷⁰, ainda que o melhor momento procedimental para sua alegação, verificação e decretação já tenha passado.

Em outras palavras, conforme será mais bem detalhado no Capítulo 13 dedicado às nulidades do processo e dos atos processuais, determinadas matérias podem ser verificadas, alegadas e, se for o caso, decretadas em qualquer momento procedimental, o que implica dizer que sobre essas matérias não recaem os efeitos da preclusão.

A essas questões sobre as quais não recaem a preclusão dá-se o nome de “matérias de ordem públicas” que, pela gravidade e influência negativa para o processo, podem ser alegadas e verificadas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pelo mesmo motivo, são as matérias de ordem pública verificáveis de decretáveis “de ofício” pelo juiz, ou seja, independentemente de provocação das partes interessadas.

A razão do não atingimento pela preclusão e consequente possibilidade de verificação e decretação em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz, decorre do fato de as nulidades e os vícios

classificáveis como “matéria de ordem pública” terem o condão de contaminar todo o procedimento e, em especial, o julgamento que, mesmo transitado em julgado, fica sujeito à ação rescisória³⁷¹.

Exatamente sobre essa potencial contaminação da nulidade sobre os demais atos processuais, inclusive a decisão final, o sistema pressupõe que sobre as questões de ordem pública é melhor a decretação a qualquer tempo, ainda que não no primeiro momento.

Isso não quer dizer que o ideal não seja imediatamente o momento da caracterização do vício, até porque, considerando a contaminação, é provável que os atos processuais subsequentes tenham de ser refeitos.

Entretanto, quando a matéria for considerada de ordem pública, a perda desse momento ideal não implicará a extinção do direito de alegar como decorreria nas demais situações abarcadas pela regra geral do atingimento pela preclusão processual.

9.2.3.2 Deveres das partes

O Código de Processo Civil, em princípio pode ser considerado, um diploma muito mais voltado a estabelecer e detalhar o exercício de direitos processuais do que um sistema voltado à imposição deveres aos sujeitos processuais e, em especial, às partes.

Isso ocorre tendo em vista que, como sujeitos diretamente interessados no julgamento da lide, as partes atuam no processo praticando atos processuais com o intuito de obter um julgamento favorável, sendo até desnecessário que a lei imponha o dever da parte de praticar este ou aquele ato processual.

É suficiente para que as partes atuem e participem do procedimento o sistema de consagração de direitos e imposição de ônus, com a perda desse direito caso não exercido no tempo e modo adequados.

Por esse motivo, grande parte dos dispositivos do Código de Processo

Civil que impõem deveres aos sujeitos processuais é voltada aos juízes, auxiliares da Justiça e terceiros que de algum modo contribuam com o processo.

Entretanto, alguns dispositivos codificados impõem deveres às partes que, ao contrário do ônus, não implicam a possibilidade de escolha pela parte que queira optar por arcar com as consequências processuais eventualmente negativas, mas na necessidade de obrigatoria observância sob pena de punição e cumprimento forçado.

A possibilidade de punição e imposição do cumprimento forçado do comando legal, inclusive pela força se necessário, em contraposição à simples perda do direito pelo não exercício, é a principal distinção entre o ônus processual das partes e os deveres das partes.

Em outras palavras, ao contrário da maioria das regras processuais cuja observância pelas partes constituem um ônus sob pena de, no máximo, perda do direito processual, sempre que a lei classificar uma conduta processual como dever das partes, a obediência a este comando deve passar a ser obrigatória sob pena de punição ou cumprimento forçado, sanções, portanto, mais graves que a simples perda do direito à prática de um ato processual.

O principal dispositivo que estabelece verdadeiros deveres para as partes é o art. 77 do Código de Processo Civil, que dispõe: "além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I – expor os fatos em juízo conforme a verdade; II – não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III – não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI – não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”.

Portanto, rigorosamente, o estabelecimento de deveres das partes constitui verdadeiras limitações aos direitos de requerer, alegar e provar que, apesar de constitucionalmente garantidos, não são direitos absolutos e incondicionados, e sim, como todos os direitos, limitados pela proibição do abuso.

Se analisadas de perto, as condutas vedadas pelo art. 77 do CPC são limitações ao direito de requerer (não formular pretensões ou defesas cientes de que são destituídas de fundamento), alegar (expor os fatos conforme a verdade), e provar (não produzir provas inúteis ou desnecessárias à declaração ou defesa de direito).

Ademais, também constitui dever das partes, agir com urbanidade, respeito e cordialidade quando de suas manifestações e prática de atos processuais sendo, nos termos do art. 78 do CPC, “vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”.

Outro dever das partes, nos termos do art. 77, inc. IV, do CPC transcrito no parágrafo anterior, é cumprir com exatidão os provimentos e comandos jurisdicionais, nada mais natural considerando a imperatividade de que é revestida a função jurisdicional³⁷².

Tal como o cumprimento de todo e qualquer dever, o descumprimento da determinação constante do art. 77, inc. IV, configura, segundo o § 2º do dispositivo, ato atentatório à dignidade da Justiça punível com multa de até 20% sobre o valor da causa, além de atrair a incidência da tutela jurisdicional executiva voltada à realização do comando judicial, com o uso da força quando necessário.

Além do art. 77, § 2º já referido, o Código de Processo Civil cria um sistema de punição voltado a sancionar a parte que praticar atos contrários aos seus deveres.

Esses atos são tipificados no art. 80 do CPC como de litigância de má-fé exatamente por serem atos contrários aos deveres arrolados no art. 77 e sintetizados pelo dever de lealdade e boa-fé.

Nesse sentido, o art. 80 do Código afirma: “considera-se litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Se comparados o rol do art. 77 com o do art. 80, verificar-se-á que se trata de dois lados de uma mesma realidade, estabelecendo o art. 77 a forma como as partes devem litigar, e o art. 80 classificando as condutas contrárias e estes deveres como atos de má-fé e, portanto, proibidos.

Como deveres que são, a atividade contrária à lealdade e boa-fé, nos termos do art. 80, implica verdadeira punição à parte, nos termos estabelecidos especialmente no art. 81 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o referido dispositivo estabelece que “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Nota-se, portanto, que, além da punição propriamente dita mediante imposição da multa, o Código impõe ao litigante de má-fé o dever de

indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos por ela, devendo ele arcar com os custos da reparação dos danos e todos os prejuízos causados pelos atos praticados com má-fé.

A par de punição mediante a multa e o dever de indenização nos termos do art. 81 do CPC, outras consequências negativas devem ser impostas à parte litigante de má-fé, a começar pela declaração de ineficácia dos atos processuais vedados pelo Código, cabendo ao juiz todo esse controle.

Nas palavras do professor Humberto Theodoro Jr.³⁷³, a lei, além de não tolerar a má-fé, arma o juiz com poderes para combatê-la, bem como combater a prática de atos fraudulentos.

Nesse sentido, o juiz, no uso do poder sancionatório, estudado no item 9.2.1.2, “d”, deverá, de ofício e independentemente de provocação, punir a parte nos termos do art. 81, já comentados, bem como inibir a prática de atos processuais manifestamente protelatórios e fraudulentos como determinado pelo art. 142 do Código³⁷⁴.

Ademais, outros deveres e sanções específicas às partes em determinados processos ou fases procedimentais são previstos no sistema processual, a exemplo do que traz o art. 774, parágrafo único e art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, sendo certo que a sistematização de todos esses dispositivos escapa ao objeto desta Introdução³⁷⁵.

Capítulo 10 Pressupostos Processuais de Existência, Constituição e Desenvolvimento Válido e Regular do Processo

10.1 Considerações iniciais

Decorre do princípio do devido processo legal a necessidade de observância de determinados requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico para que a relação processual possa se formar, existir juridicamente e se desenvolver válida e regularmente.

Nesse contexto, os pressupostos processuais devem ser entendidos como os requisitos lógicos e jurídicos necessários à existência e validade da relação processual; à falta dos quais, a relação processual não tem existência ou validade.

A doutrina, via de regra, divide os pressupostos processuais em três categorias: a) pressupostos processuais de existência; b) pressupostos processuais de validade; c) pressupostos processuais negativos.

Os pressupostos processuais de existência, segundo Alexandre Freitas Câmara³⁷⁶, “são os elementos necessários para que a relação processual possa se instaurar. A ausência de qualquer deles deve levar à conclusão de que não há processo instaurado na hipótese”.

Por pressupostos processuais de validade (ou de desenvolvimento válido do processo), segundo a lição de Humberto Theodoro Jr.³⁷⁷, devem ser entendidos aqueles requisitos a serem atendidos depois que o processo se estabeleceu regularmente (tornou-se existente), “a fim de que possa ter curso também regular, até a sentença de mérito ou providência jurisdicional definitiva”.

Já os pressupostos processuais negativos, segundo Cassio Scarpinella Bueno, são “determinados acontecimentos que não devem fazer-se

presentes sob pena de comprometimento da validade do processo”³⁷⁸.

Teresa Arruda Alvim destaca que os pressupostos processuais “são elementos cuja presença é imprescindível para a existência e validade da relação processual e, de outra parte, cuja inexistência é imperativa para que a relação processual exista validamente, no caso dos pressupostos processuais negativos”³⁷⁹.

Portanto, os vícios relacionados aos pressupostos processuais impedem o desenvolvimento válido e regular do processo, ou mesmo sua existência jurídica, o que leva à necessidade de correção desse vício ou à extinção do processo sem resolução do mérito quando impossível sua correção³⁸⁰.

São pressupostos processuais de existência: a) a jurisdição; b) o pedido; e c) a citação do réu.

São pressupostos processuais de validade: a) competência absoluta; b) imparcialidade; c) petição inicial apta; d) citação válida; e) capacidade de ser parte; f) capacidade processual (de estar em juízo); g) capacidade postulatória, a seguir explicadas.

São pressupostos processuais negativos: a) litispendência; b) coisa julgada; c) perempção; d) convenção de arbitragem.

A conceituação de cada um desses pressupostos e as consequências processuais de eventuais irregularidades a eles relacionadas são o objeto deste capítulo.

10.2 Pressupostos processuais de existência

A relação processual é formada a partir da provocação pelo autor dirigida ao Estado-juiz para que este preste a tutela jurisdicional³⁸¹.

Nessa afirmação, encontram-se demonstrados dois dos três pressupostos processuais de existência: o pedido e a jurisdição.

Assim, em primeiro lugar, sem que haja pedido, é absolutamente impossível falar-se em relação processual, haja vista que a jurisdição é

inerte, só agindo o juiz quando provocado e nos limites da provocação.

A expressão pedido, nesse contexto, traduz ambas as ideias dado que, de rigor, por pedido pode ser entendido tanto a provocação ao Estado-juiz (pedido imediato), quanto a medida da provocação, isto é, a definição do bem jurídico pretendido (pedido mediato)³⁸².

O pedido, enquanto pressuposto processual de existência, impede a caracterização de uma relação processual juridicamente existente antes de sua formulação.

Antes da provocação veiculada no pedido, a relação processual simplesmente não existe.

Tal como não se pode conceber processo juridicamente existente sem pedido, igualmente é inexistente o processo desenvolvido perante um órgão que não seja dotado de jurisdição.

Cândido Rangel Dinamarco³⁸³, inclusive, sintetiza essas duas realidades em um único enunciado ao afirmar que se tem existente uma relação jurídica processual a partir de quando a demanda é levada ao órgão jurisdicional. Antes disso, não se considera formado processo algum.

Nesse sentido, Alexandre Freitas Câmara³⁸⁴ aduz que “pode-se dizer que é inexistente o processo se o mesmo se desenvolve fora de um órgão estatal apto ao exercício da jurisdição (juízo)”.

Trata-se de um pressuposto lógico, que condiciona a existência do processo ao fato de o órgão, perante o qual seja instaurado, ser dotado, pelo sistema jurídico, de poder jurisdicional e a investidura do sujeito que o conduz e decide a lide nesta qualidade.

Por essa razão, qualquer procedimento ou atividade voltada a solucionar a lide conduzida por outros órgãos (não jurisdicionais) ou por outro sujeito que não o magistrado, investido na função, do ponto de vista jurídico, não pode ser classificado como processo, sequer existente.

O terceiro pressuposto processual é a citação, cuja importância se revela

na medida em que é este ato de comunicação que torna existente a relação processual para o réu.

Assim, ainda que exista relação processual entre autor e Estado-juiz desde a provocação pelo autor ao órgão jurisdicional, a relação processual só se torna completa e triangular quando realizada a citação.

É por essa razão que só a partir da citação e consequente ciência do réu acerca de existência do processo este começa a sofrer os efeitos da relação processual, tais como constituição do devedor em mora e a caracterização da coisa, objeto do processo, como litigiosa.

É imperioso ressaltar que a citação é pressuposto processual de existência da relação processual na perspectiva jurídica do réu. Diz-se jurídica dado que o réu já pode ter ciência do ajuizamento da demanda antes da citação, por outros meios extraoficiais, como consulta ao site do tribunal ou até mesmo pela imprensa, sendo tal ciência indiferente para fins de existência jurídica.

A única forma de superação da inexistência da citação é o comparecimento espontâneo do réu formalmente aos autos do processo.

Isso porque, nos termos do art. 239, § 1º do CPC, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Assim, de duas, uma: ou o réu é citado ou comparece espontaneamente ao processo antes da efetivação da citação, sendo certo que antes que uma dessas situações se concretize, não há que se falar sequer em existência da relação processual na perspectiva jurídica deste sujeito.

10.3 Pressupostos processuais de validade

Apesar de fundamental e indispensável, a verificação dos pressupostos processuais de existência, por si só, não é suficiente para que o processo seja tido por regular a ponto de, a partir disso, poder atingir todos seus

objetivos.

Em outras palavras, não basta o processo existir juridicamente para que possa vir a ter o mérito julgado.

Isso porque decorre do próprio princípio do devido processo legal ³⁸⁵, que sintetiza muitos outros princípios e regras do sistema processual, a necessidade de observância de determinadas normas jurídicas tidas como fundamentais para que o processo possa se desenvolver válida e regularmente.

A esse conjunto de requisitos fundamentais dá-se o nome de pressupostos processuais de validade, ficando desde já aqui registrado que a inobservância de um único desses pressupostos impede o desenvolvimento válido e regular do processo que, caso indevidamente ocorra, gera a nulidade da decisão nele proferida.

Por esse motivo, conforme se verá adiante, a irregularidade deve ser corrigida, inclusive de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição ³⁸⁶ e, caso o vício seja tido por incorrigível, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito.

Os pressupostos processuais de validade são: a) competência absoluta; b) imparcialidade; c) petição inicial apta; d) citação válida; e) capacidade de ser parte; f) capacidade processual (de estar em juízo); g) capacidade postulatória.

Os subitens a seguir serão dedicados a cada um dos pressupostos processuais de validade.

a) Competência absoluta

Como uma decorrência do princípio constitucional do juiz natural que, nos termos dispostos no art. 5º, inc. LIII, da Constituição Federal assegura que “ninguém será processado e sentenciado senão por autoridade competente”, um dos pressupostos processuais de validade é justamente a

competência do juízo.

Competência, na clássica lição de Moacyr Amaral Santos³⁸⁷, é o “poder de exercer jurisdição nos limites estabelecidos em lei”, sendo competente o juiz quando, no âmbito de suas atribuições, tiver poderes jurisdicionais sobre determinada causa³⁸⁸.

Em outras palavras, competência é a aptidão dada pela Constituição Federal e pela lei para que o órgão jurisdicional atue na resolução de um determinado litígio.

É a partir dessa distribuição, feita pelas normas constitucionais e legais, que se identifica o “juiz natural” de uma determinada causa, com a exclusão dos demais órgãos jurisdicionais.

A categorização da competência como pressuposto processual de validade, em última análise, implica dizer que apenas o juiz competente, assim identificado pelo sistema processual pode, legitimamente, processar e julgar a causa, sendo nulas as decisões proferidas fora desses parâmetros.

Por essa razão, em primeiro lugar cabe ao autor se dirigir ao juízo competente para julgar a causa quando da provocação do Poder Judiciário, bem como cabe ao juiz sempre verificar, de ofício, sua competência, não atuando no processo em que detecte ser incompetente.

Nesse contexto, o norte, tanto para as partes, quanto para os próprios órgão jurisdicionais, está na Constituição Federal e na lei que distribuem a competência mediante regras que levam em consideração alguns critérios de repartição, quais sejam: a) a matéria; b) a função; c) a pessoa; d) o valor da causa; e) o território³⁸⁹.

A distribuição de competência em razão da matéria (a) leva em consideração a natureza da relação material discutida em juízo, se originariamente disciplinada pelo direito civil, administrativo, do trabalho, eleitoral etc. É o critério utilizado, por exemplo, para definir a competência

da Justiça especializada e da Justiça comum.

O critério funcional (b) leva em consideração as diversas funções necessárias em um mesmo processo como realizar a execução, conhecer de pedidos de urgência ou julgar recursos.

Um terceiro critério levado em consideração é a pessoa (c), ou seja, a qualidade dos sujeitos litigantes em que se destaca a repartição de competência em função de um dos litigantes ser a União, suas autarquias e fundações públicas que, por esse motivo, atraem a competência da Justiça federal, ou entes públicos estaduais e municipais que, via de regra, são processados e julgados pelas denominadas varas da Fazenda Pública.

O valor da causa, que nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, em apertadíssima síntese, deve refletir o valor do bem jurídico pretendido pelo autor, também é levado em consideração para identificação do órgão competente, uma vez que determinados órgãos jurisdicionais, como os juizados especiais, têm suas atribuições limitadas a determinados valores.

Por fim, o quinto critério de repartição da competência é o territorial, cuja aplicação, segundo Humberto Theodoro Jr., “decorre da necessidade de definir, dentre os vários juízes do país, de igual competência em razão da matéria e do valor, qual poderá conhecer de determinada causa”³⁹⁰.

Como regra, o critério territorial leva em consideração o domicílio do réu, havendo, entretanto, situações em que outros elementos territoriais, com domicílio do autor, local do fato que originou a lide ou localização da coisa objeto da disputa, igualmente, influenciam na definição do juízo competente.

Ademais, antes de tudo isso, hão de ser identificados os limites da própria jurisdição brasileira, isto é, se algum órgão jurisdicional nacional poderá atuar na resolução do litígio, tema tratado pelo Código de Processo Civil entre os arts. 21 e 25.

Uma vez identificada a possibilidade ou necessidade de atuação da

jurisdição brasileira, resta identificar qual dos órgãos integrantes do Poder Judiciário é o competente para processar e julgar a causa, sendo certo que esse regramento tem origem no próprio texto constitucional que se preocupa com as normas fundamentais de organização do Poder Judiciário e, por via de consequência, da atribuição de competência desses órgãos.

Estão consagrados na Constituição Federal, entre os arts. 106 e 126, os critérios de repartição de competência entre as diversas Justiças por ela criadas (do Trabalho, Eleitoral, Militar, Comum Federal e Comum Estadual). Também na Constituição estão estabelecidas as atribuições dos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (art. 102) e o Superior Tribunal de Justiça (art. 105).

O conhecimento desses critérios e das normas constitucionais e legais que distribuem a competência entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, e de sua aplicação ao caso concreto, é indispensável para que se identifique o juízo competente e, por via de consequência, respeite-se este pressuposto processual de validade sem o qual o processo não pode se desenvolver legítima e regularmente.

Portanto, enquanto pressuposto processual de validade, a competência deve ser observada sob pena de impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo e nulidade da decisão proferida por juiz absolutamente incompetente.

Entretanto, desde já se faz necessária uma distinção entre a natureza e critérios de repartição de competência do juízo que vai dividir a (in)competência em absoluta e relativa.

Isso porque apenas a competência absoluta é pressuposto processual de validade com o tratamento jurídico processual aqui delineado.

São critérios de repartição de competência absoluta: a) as normas de repartição de competência previstas na Constituição Federal, como a competência dos tribunais superiores e da Justiça federal; b) os critérios de

repartição em razão da matéria, da pessoa, e funcional; c) em razão do valor e do território, nesses casos, apenas quando a lei expressamente dispuser nesse sentido.

Como pressupostos processuais de validade, os critérios supramencionados sempre devem ser respeitados, sob pena de nulidade do processo e, sobretudo, das decisões nele proferidas e, até por esse motivo, podem ser verificadas de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, por serem critérios de competência absoluta a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil.

Já os critérios de competência relativa **não** constituem pressupostos processuais de validade e, por esse motivo: a) as partes podem derogar e modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações; b) não podem ser decretadas de ofício pelo juiz; c) quando não oportunamente suscitadas pelas partes, terminam por ser prorrogadas.

A prorrogação de competência deve ser entendida como o fenômeno que transforma um juiz relativamente incompetente em juízo competente por força da não arguição pela parte interessada em sua decretação, fato que nunca ocorre quando se estiver diante do desrespeito a um critério de repartição de competência absoluta.

Os critérios tidos pelo sistema processual como de competência relativa são: o valor da causa e o territorial.

Ainda assim, em determinadas situações, a lei dispõe em sentido contrário e estabelece a natureza absoluta mesmo em se tratando desses critérios.

É o caso, por exemplo, do art. 3º, § 3º, da Lei n. 10.259/2001 que estabelece a competência dos juizados especiais federais dispondo que “no

foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta”.

Da mesma forma, o § 2º do art. 47 do CPC, ao se valer do critério territorial para se estabelecer o foro competente para a “ação possessória imobiliária”, qual seja, o da situação da coisa, dispõe que tal competência é absoluta.

Sempre que a lei expressamente dispuser que o critério de repartição de competência nela consagrado é de natureza absoluta, estar-se-á diante de um pressuposto processual de validade que deve ser respeitado sob pena da impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo e nulidade das decisões proferidas pelo juiz absolutamente incompetente.

Isso ocorre, repita-se, sempre nos casos de competência em razão da matéria, função e pessoa e também nas hipóteses expressamente previstas em lei relacionadas a território e valor.

Por outro lado, fora dessas hipóteses, o desrespeito aos critérios território e valor, por não infringir um pressuposto processual de validade, não implica a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo e muito menos a nulidade das decisões proferidas.

É o caso, por exemplo, do art. 46 do Código de Processo Civil que, ao disciplinar o critério territorial, dispõe que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

Nessas hipóteses, de duas uma: ou o réu alega a incompetência relativa na primeira oportunidade que lhe cabe falar nos autos (em preliminar de contestação), demonstrando, por exemplo, residir em outra cidade; ou essa competência se prorrogará, tornando-se o juízo, relativamente incompetente, competente para aquela causa.

Essa conclusão decorre justamente do fato de a competência territorial prevista no dispositivo ser categorizada como um critério de repartição de

competência relativa cujo desrespeito não implica nulidade automática do processo e não autoriza o juiz a conhecê-la de ofício.

Portanto, só podem ser categorizados como pressupostos processuais de validade, a cujo tratamento está sendo dedicado este capítulo, os critérios de competência absoluta, que são: a) as normas de repartição de competência previstas na Constituição Federal, como a competência dos tribunais superiores e da Justiça federal já referidas; b) os critérios de repartição em razão da matéria, da pessoa e funcional; c) os critérios em razão do valor e do território, nesses casos apenas quando a lei expressamente dispuser nesse sentido.

Dada a gravidade do vício e a consequente nulidade da decisão proferida por juiz absolutamente incompetente, cabe em primeiro lugar e o quanto antes, ao próprio juiz, verificar de ofício sua competência, declinando-a sempre que verificar que o feito não está dentro da sua esfera de atribuições.

Em outras palavras, o juiz tem o dever de, antes de mais nada verificar sua própria competência.

Contudo, o fato de o juiz ter o dever de decretar sua incompetência absoluta, inclusive de ofício e a qualquer momento, obviamente, não impede que a parte interessada o faça.

Portanto, a incompetência absoluta também pode ser arguida pela parte em qualquer tempo e grau de jurisdição, apesar de o Código de Processo Civil determinar que a parte o faça na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, que é a preliminar de contestação.

Entretanto, por se tratar de um vício gravíssimo e não tolerado pelo sistema jurídico, a perda dessa oportunidade ideal não implica perda do direito de fazer essa arguição por simples petição em qualquer outro momento, tendo a (in)competência absoluta status de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão processual nos termos demonstrados no

item 9.2.3.1, “g”, do Capítulo 9.

b) Imparcialidade

Outro pressuposto processual de validade decorrente do princípio do juiz natural previsto no art. 5^ª, inc. LIII, da Constituição Federal é a imparcialidade.

Nesse sentido, para que o processo possa se desenvolver válida e regularmente, é vedado ao juiz ter qualquer interesse na causa, bem como relação próxima com qualquer uma das partes e seus respectivos advogados.

Com a finalidade de regulamentar as hipóteses em que esta relação compromete a imparcialidade do juiz, os arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil arrolam hipóteses de impedimentos e suspeição do magistrado.

O impedimento é a proibição de atuação do juiz no processo em que se verifique a ocorrência de hipóteses objetivamente constatáveis nos termos do art. 144 do Código de Processo Civil.

Já a suspeição decorre de hipóteses que, igualmente, maculam a imparcialidade do juiz, mas que são de verificação um tanto quanto mais subjetiva.

Nos termos do art. 144 do Código de Processo Civil, são hipóteses de impedimento: a) o fato de o juiz ter intervindo como mandatário da parte, oficiado como perito, funcionado como membro do Ministério Público ou prestado depoimento como testemunha; b) conhecido em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; c) quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; d) quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; e) quando for

sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; f) quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; g) em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; h) em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; i) quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Conforme se depreende da leitura das situações elencadas, as hipóteses arroladas são de fácil e objetiva demonstração e caracterização, como é o caso do casamento, filiação e demais situações relacionadas a parentesco facilmente comprovadas por meio de certidões e outros documentos públicos.

Da mesma forma, é simples a comprovação da condição de parte do juiz em outra ação contra as partes ou advogados destas (art. 144, IX), bem como a condição de já ter atuado no processo como perito, membro do Ministério Público, advogado das partes ou testemunha (art. 144, I).

Já o art. 145 do CPC, ao estabelecer as hipóteses de suspeição do juiz, vale-se de conceitos vagos e indeterminados cuja definição e caracterização variam de acordo com o caso concreto e admitem toda a sorte de instrução probatória.

Nos termos do citado dispositivo, são hipóteses tidas como caracterizadores da suspeição do juiz: a) o fato de este ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; c) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau,

inclusive; d) interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Ademais, nos termos do art. 145, § 1º, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

Não cabe neste passo definir os conceitos de “amizade íntima” ou “inimizade” até porque essa definição depende de verificação e demonstração de fatos concretos.

É suficiente, nesta sede, o registro de que a caracterização dessas situações impede a atuação do magistrado no processo e que, caso ela se concretize, torna nulo seu desenvolvimento e suas decisões.

Vale ressaltar que, apesar de arrolado como hipótese de suspeição, o fato de o juiz ser credor ou devedor de uma das partes (art. 145, III) é objetivamente constatável, via de regra, por contratos e outros documentos criadores de relações obrigacionais.

De todo modo, considerando ser pressuposto processual de validade, a imparcialidade do juiz deve ser em primeiro lugar por ele mesmo verificada.

Portanto, o juiz tem o dever de, de ofício, afastar-se do processo sempre que verificar uma das hipóteses de suspeição ou impedimento nos termos da lei.

Ao verificar ser suspeito ou impedido, o juiz deve encaminhar o processo ao seu substituto legal.

Obviamente, o fato de o juiz ter o dever de verificar sua própria imparcialidade e afastar-se, de ofício, em caso de suspeição ou impedimento, não impede a parte de verificar essas situações e requerer o afastamento do magistrado caso ele não o faça desde logo.

Nessas hipóteses, as partes podem provocar e requerer o afastamento do juiz por suspeição ou impedimento.

O art. 146 do Código de Processo Civil dispõe que a parte interessada poderá, no prazo de quinze dias, a contar do conhecimento do fato, alegar o

impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Por outro lado, mesmo que as partes não suscitem e o juiz não declare sua parcialidade de ofício, a ofensa a este pressuposto processual de validade torna viciado o processo e nula as decisões proferidas pelo juiz suspeito ou impedido.

Até por esse motivo, a imparcialidade pode ser arguida e decretada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

c) Petição inicial apta

A petição inicial é o primeiro ato do procedimento pelo qual o autor manifesta formalmente seu intuito de provocar a jurisdição e dar início ao processo.

Em outras palavras, é por meio da petição inicial que o autor exerce o direito de ação, assim entendido o direito de exigir do Estado-juiz a prestação jurisdicional³⁹¹.

Podemos, portanto, elencar quatro funções básicas da petição inicial, todas, por óbvio, intimamente interligadas, quais sejam: a) provocar a jurisdição e romper a inércia jurisdicional; b) formalizar o exercício e direito de ação e, por via de consequência; c) dar início à relação processual; e d) delimitar o objeto (mérito) do processo.

Desta feita, é função da petição inicial não apenas romper a inércia jurisdicional, mas também ditar os contornos dessa provocação, haja vista que o Estado-juiz não age senão quando provocado e nos limites da provocação.

Por limites da provocação, nesse contexto, deve ser entendida a identificação de todos os elementos da ação, ou seja, a) identificação das partes, quem pede (autor) e contra quem é feito o pedido (réu); b) da

causa de pedir, elementos de fato e de direito que fundamentam; c) e, principalmente, o pedido assim entendido o bem da vida pretendido (pedido mediato) e a espécie de tutela jurisdicional desejada pelo autor (pedido imediato)³⁹².

Assim, podemos concluir que a petição inicial é o veículo da ação, sendo este o momento em que o autor deve formalizar e definir todos os seus contornos, pois, caso contrário, a manifestação do autor não será apta a, legitimamente, dar início ao processo.

A par disso, é a petição inicial o ato inaugural da relação jurídica processual, sendo este o momento do processo em que o autor deve identificar e preencher os pressupostos processuais próprios deste instante procedimental.

Nesse sentido, é na petição inicial que deve constar, por exemplo a identificação do juízo competente, pressuposto processual de validade conforme demonstrado no subitem “a”, supra, bem como a comprovação da sua regular capacidade processual e postulatória, ambas a serem estudadas nos subitens “f” e “g”, infra.

A par disso, obviamente e conforme já ressaltado, é a petição inicial o ato que identifica e delimita o pedido e, a partir dessa delimitação, deve também constar na inicial a definição do valor atribuído à causa, elemento tido pelo sistema processual pátrio como indispensável à propositura de qualquer demanda judicial³⁹³.

Da mesma forma que, quando da ausência ou deficiência da identificação dos elementos da ação, os erros e imperfeições na caracterização dos pressupostos processuais pelo autor, já na petição inicial, impedem que esse ato dê início validamente ao processo.

Por essas razões, o sistema processual regulamenta detalhadamente a forma e o conteúdo da petição inicial que, se não observados, impedem a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

O art. 319 do CPC dispõe que são requisitos da petição inicial: I – o juízo a que é dirigida; II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV – o pedido com as suas especificações; V – o valor da causa; VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Caso não disponha das informações previstas no inc. II do art. 319, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do(s) réu(s), o § 1º do dispositivo possibilita o autor a, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção.

Assim, para a obtenção dessas informações, é comum a expedição de ofício a órgãos públicos como o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Receita Federal do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN e cartórios de registro de pessoas jurídicas.

A regra se justifica haja vista que o não conhecimento pelo autor de todos os dados do réu exigidos pelo art. 319 do Código não pode implicar, automática e sumariamente, na impossibilidade de ajuizamento da demanda³⁹⁴.

Ademais, conforme dispõe o § 2º do art. 319 do CPC, a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

Complementando o rol de requisitos estabelecidos no art. 319, o art. 320 do Código exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, assim entendidos aqueles sem os

quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento de contrato em uma ação que se volta a declarar sua nulidade³⁹⁵, aos quais pode ser acrescentado o instrumento de procuração que constitui o advogado do autor para fins de comprovação da regular capacidade postulatória³⁹⁶.

Todos esses requisitos são fundamentais para o desenvolvimento válido e regular do processo e, por essa razão, a petição inicial apta representa um pressuposto processual de validade.

Nesta esteira, a ausência de qualquer um dos requisitos da petição inicial implica a denominada inépcia da inicial que, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC, impede o desenvolvimento válido e regular do processo e, em alguns casos, implica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Entretanto, sempre que o vício causador da inépcia da inicial for considerado sanável, a extinção do processo sem resolução do mérito não deve ser a primeira opção do magistrado, que deverá, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, dar a oportunidade para que o autor corrija o vício no prazo de quinze dias.

Corrigido o vício e tornada apta a petição inicial, o processo passa a ter condições de se desenvolver válida e regularmente.

Por outro lado, caso o autor não corrija o vício no prazo adequado, o processo deverá ser extinto sem a resolução do mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que a inépcia da inicial impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

d) Citação válida

A par de a realização da citação ser um pressuposto processual de existência sem o qual o processo é inexistente sob a ótica jurídica do réu³⁹⁷, sua regularidade é indispensável para o desenvolvimento válido do processo

e das decisões nele proferidas.

Por regularidade da citação deve ser entendida sua realização pela modalidade adequada com o cumprimento e a observância de todos os requisitos e formalidades previstos em lei, tema exhaustivamente disciplinado em nada menos do que 22 artigos do Código de Processo Civil (arts. 238 a 259).

Sem adentrar em todos os aspectos do ato citatório, o que escaparia ao objeto deste item e até mesmo desta Introdução, cumpre salientar, neste passo, que todos os pormenores formais da citação influenciam no desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Nesse sentido, três pontos se destacam: a) a disciplina das modalidades da citação; b) a ordem de preferência de cada uma dessas modalidades, a depender do tipo de situação litigiosa; c) o procedimento e requisitos formais do ato citatório em si mesmo considerado.

Todos os temas são objeto de análise no item 12.2.1, “e”, do Capítulo 12 dedicado aos atos de comunicação processual.

Nesta sede em que se analisa a citação como pressuposto processual de validade, é suficiente registrar que a observância e o cumprimento de toda a disciplina da citação prevista nos arts. 238 a 259 do Código de Processo Civil precisam ser rigorosamente obedecidos, sob pena de nulidade do ato citatório, e dos atos processuais subsequentes.

Assim, por exemplo, na hipótese em que a lei exige citação por oficial de justiça (art. 247 do CPC), sua realização pelo correio a torna inválida. Da mesma forma, a realização da citação por edital em casos em que a citação pessoal era possível vicia o ato citatório, tornando-o nulo e contaminando a relação processual.

Portanto, a categorização da citação válida como pressuposto processual de validade remete o operador do processo ao estudo da disciplina da citação pelo Código de Processo Civil, o que, no presente trabalho, é feito

no já aludido item 12.2.1, “e”, do Capítulo 12, ao qual remetemos o leitor.

De toda sorte, já nesta sede cumpre destacar que, assim como na hipótese de inexistência, a nulidade da citação pode ser superada pelo comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o que implica dizer que, mesmo sendo nula e realizada fora dos ditames legais, caso a citação tenha atingido sua finalidade, qual seja, comunicar o réu da existência do processo, o vício torna-se indiferente para fins de validade e regularidade. Portanto, em síntese, caso o réu compareça espontaneamente, supre-se o vício da citação.

Outro ponto importante relacionado ao estudo da citação, enquanto pressuposto processual de validade, é o fato de sua nulidade ou irregularidade nunca levar à extinção do processo sem resolução do mérito, como ocorre em outras situações de vícios relacionados aos pressupostos, como a falta de capacidade postulatória ou inépcia de inicial, que, se não corrigida pelo autor a contento, pode levar à extinção do feito.

Isso porque, reconhecida a nulidade da citação, a consequência é a decretação da nulidade de todos os atos processuais subsequentes prejudiciais ao réu e a devolução da oportunidade para que este apresente defesa de modo que o processo retroaja ao momento anterior à citação nula e, a partir de então, retome seu fluxo rumo ao julgamento de mérito.

Por ser vício gravíssimo, a nulidade da citação é matéria de ordem pública, devendo ser verificada e reconhecida de ofício pelo juiz, independentemente de provocação da parte interessada, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pelo mesmo motivo, o vício pode ser arguido pela parte ré invalidamente citada em qualquer fase do processo, sendo essa alegação apreciada pelo juiz e, caso reconhecida, apta a gerar as consequências acima aludidas, quais sejam, a nulidade dos atos subsequentes prejudiciais e a devolução do prazo para apresentação de defesa.

e) Capacidade de ser parte

Capacidade de ser parte é a qualidade que autoriza todos os entes a figurarem como sujeitos da relação processual.

Trata-se de uma categoria amplíssima, uma vez que tal qualidade é atribuída a todas as pessoas físicas, pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado, bem como a alguns entes despersonalizados que, para o Direito Processual Civil, possuem capacidade de serem partes, isto é, serem autores ou réus em um processo.

A amplitude da capacidade de ser parte decorre da regra constitucional do amplo acesso à Justiça, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos, indistintamente, o direito de provocar o Poder Judiciário solicitando a proteção jurisdicional em casos de lesão ou ameaça a direitos.

Se todos podem, por força da referida norma constitucional, acionar o Poder Judiciário, pode-se concluir, por via de consequência, que todos possuem capacidade de serem partes em um processo.

A pessoa física, por exemplo, não precisa preencher nenhum outro requisito ou qualidade jurídica para ter capacidade de ser parte, bastando nascer para, a partir daí, adquirir essa capacidade até a sua morte.

Com a morte, a pessoa física perde a capacidade de ser parte devendo o processo: a) ou ser extinto, caso o direito litigioso seja considerado por lei intransmissível³⁹⁸; ou b) deverá ocorrer a sucessão de partes, substituindo-se a parte falecida por seu espólio, seus herdeiros ou sucessores³⁹⁹.

Portanto, não há nenhum requisito jurídico, como maioridade, capacidade de exercício, nacionalidade, ou de qualquer outra ordem, para que uma pessoa física seja capaz de figurar como parte em uma relação processual.

Assim como as pessoas físicas, também as jurídicas, de direito público ou de direito privado, possuem capacidade de ser parte podendo, portanto,

figurar como autora ou ré, em uma relação processual.

As pessoas jurídicas de direito público são os entes estatais, assim entendidos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como suas respectivas autarquias e fundações públicas.

A União é a pessoa jurídica de direito público interno que representa, nos planos interno e externo (internacional) a República Federativa do Brasil.

Enquanto pessoa jurídica de direito público interno, sujeita ao ordenamento jurídico e, portanto, aos preceitos constitucionais e legais, é enorme a quantidade de relações jurídicas em que uma das partes é a União.

Naturalmente, parte dessas relações jurídicas formadas entre a União e outros sujeitos acaba por se tornar litigiosa.

Conforme já asseverado inúmeras vezes ao longo desta Introdução, o surgimento da lide torna necessária a resolução jurisdicional por meio do processo.

Desta feita, sempre que uma relação jurídica que envolva a União se tornar litigiosa, caberá a esta oferecer, ou contra esta ser oferecida, uma ação, dando-se início ao processo, no qual a União será uma das partes⁴⁰⁰.

A adoção, pela Constituição Federal de 1988, da forma federativa, dá origem aos Estados-membros da federação, que, assim como a União, têm personalidade jurídica de direito público interno e, portanto, são sujeitos de direitos e obrigações.

Aos Estados-membros é reconhecida a capacidade de ser parte pelo simples motivo de que uma parcela das relações jurídicas por eles integradas pode se tornar litigiosa, fazendo com que o Estado-membro precise buscar o Poder Judiciário como autor ou vir a ter contra si um pedido formulado, hipótese em que tal Estado-membro atuará como réu⁴⁰¹.

A referida qualidade de pessoa jurídica de direito público interno com capacidade de ser parte, também é atribuída aos Municípios, uma vez que

estes, em nosso sistema federativo, têm autonomia e personalidade jurídica própria.

Posição semelhante ocupa o Distrito Federal que encerra as competências e possíveis posições jurídicas atribuídas pela Constituição Federal aos Estados-membros e Municípios.

Além de terem personalidade jurídica e capacidade de serem parte, as pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios podem, mediante edição de lei, criar outras pessoas jurídicas, igualmente de direito público, a eles vinculadas, mas com autonomia e independência para serem sujeito de direitos e obrigações.

Esses entes, regulamentados pelo Direito Administrativo, são denominadas autarquias e fundações públicas que, na medida em que têm capacidade de serem sujeitos de direitos e obrigações, adquirem, no plano processual, a capacidade de ser parte.

Todos esses entes, não obstante serem a representação formal do Estado, submetem-se ao poder jurisdicional e, portanto, sempre que qualquer sujeito de direitos entender que o Poder Público ofendeu ou ameaça direito seu, pode exercer ação contra aqueles entes, incluindo-os no polo passivo da relação processual.

Ademais, salvo situações muito específicas, esses entes são alcançados pela vedação da autotutela, devendo, portanto, sempre que pretenderem atingir o patrimônio ou direitos de outros sujeitos, exercer essa pretensão perante o Poder Judiciário como autores da ação.

Também têm capacidade de ser parte as pessoas jurídicas de direito privado, isto é, as empresas, associações e sociedades regularmente constituídas pelo Direito Civil e Direito Empresarial.

Inúmeras são as formas de constituição e administração dessas pessoas jurídicas de direito privado que, uma vez regularmente constituídas e capazes de figurarem como sujeitos de direitos e obrigações, adquirem no

plano processual, capacidade de serem partes.

Ademais, a constituição irregular das pessoas jurídicas de direito privado não exclui totalmente a capacidade de estas serem partes, uma vez que o ordenamento jurídico processual reconhece a capacidade de ser parte destes entes despersonalizados.

Os entes despersonalizados são entidades jurídicas que não são enquadráveis pelo Direito nem como pessoas físicas, nem como pessoas jurídicas, mas que, apesar de não serem exatamente sujeitos de direito e obrigações, podem, para o Direito Processual, figurar no processo como autores ou réus em determinadas situações.

São entes despersonalizados, além das sociedades de fato irregularmente constituídas, o espólio, a massa falida e as heranças jacente ou vacante.

Os referidos fenômenos, rigorosamente, não são pessoas, sequer jurídicas, e sim universalidades patrimoniais outrora integrantes do patrimônio de uma pessoa física ou jurídica, que, pela morte ou decretação da falência, deixou de existir.

Nesse sentido, a massa falida é a universalidade de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma pessoa jurídica no momento da decretação de sua falência e que, a partir de então, deixa de existir, sendo sucedida por esse ente despersonalizado, com capacidade de ser parte para que atue como autora, ré ou assistente nos processos em que esses bens, direitos e obrigações sejam objeto de litígio.

Já o espólio é a universalidade patrimonial de uma pessoa física que venha a falecer. Tais bens, direitos e obrigações, salvo os de natureza personalíssima, deverão ser, nos termos do Direito Civil, transmitidos para os sucessores e herdeiros legítimos, sendo certo que, entre a morte e a efetiva identificação desses novos titulares dos direitos transmissíveis, situações litigiosas que envolvam esse patrimônio podem ser verificadas.

Portanto, enquanto não concluída a partilha do patrimônio do de cujus entre os herdeiros e sucessores, seu espólio tem capacidade de ser parte reconhecida pelo Direito Processual Civil podendo, desta feita, atuar como sujeito processual nas relações em que os direitos, deveres e obrigações que fazem parte desse patrimônio sejam objeto de disputas judiciais.

A ausência de herdeiros e sucessores dá origem à configuração da denominada herança vacante que, se não reclamada por nenhum sujeito legitimado para suceder o de cujus no prazo de cinco anos, será transferida para o Município.

Enquanto não decorrido esse prazo e efetivamente transferidos para o Município os bens integrantes do patrimônio do de cujus, admite-se a capacidade de ser parte da própria herança jacente ou vacante nos processos em que se discutam os bens, os direitos e as obrigações que a integram.

A capacidade de ser parte é um pressuposto processual de validade na medida em que não é possível se conceber o desenvolvimento da relação jurídica processual sem que esse requisito esteja corretamente preenchido.

Portanto, a própria formação regular da relação processual pressupõe a existência de um pedido formulado por alguém com capacidade de ser parte e o direcionamento desse pedido contra outrem que, igualmente, possua tal capacidade.

Com a eventual perda da capacidade por um desses entes integrantes do polo ativo ou passivo da relação processual, por exemplo, com morte da pessoa física ou falência da pessoa jurídica, instaurar-se-á uma crise no processo, pois, se, até então, a capacidade de ser parte estava preenchida, a partir deste evento, um dos polos estaria carente desse requisito.

Esta crise pode implicar: a) a extinção do processo, caso o direito litigiosos seja considerado por lei intransmissível⁴⁰²; ou b) a sucessão de partes, substituindo-se a parte falecida por seu espólio, seus herdeiros ou

sucessores⁴⁰³.

Nessa segunda hipótese, a operação de sucessão de partes funcionará como uma técnica processual voltada a corrigir a ausência da capacidade de ser parte para que, uma vez regularizado esse requisito, o processo volte a se desenvolver válida e regularmente, contra o sucessor da parte originária.

A essa técnica é dedicado o item 10.3.1, “a”, do presente capítulo.

f) Capacidade processual (de estar em juízo)

Ao contrário da capacidade de ser parte, amplíssima e atribuída a todas as pessoas independentemente de preenchimento de requisitos ou categorias jurídicas, a capacidade processual está ligada à capacidade de exercício de seus direitos ou de regular representação nos casos das pessoas físicas incapazes, pessoas jurídicas e entes despersonalizados.

Assim a regularidade da capacidade processual exige o preenchimento de certos requisitos jurídicos sem os quais a parte não poderá ser tida como válida e regularmente presente no processo.

O fenômeno tem variantes caso a parte seja pessoa física, jurídica de direito público, jurídica de direito privado ou ente despersonalizado, conforme se verá nas linhas abaixo.

Para fins de preenchimento da capacidade processual das pessoas físicas, de duas uma: a) ou se trata de uma pessoa maior e capaz e, por via de consequência, com capacidade de exercício e capacidade processual; ou b) por tratar-se de uma pessoa física menor, ou por qualquer outro motivo incapaz de exercer direitos, necessário se faz a regular representação nos termos disciplinados no art. 71 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, dispõe o art. 70 do CPC que “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”.

Já o art. 71 do Código estabelece que “o incapaz será representado ou assistido por seus pais, ou por tutor ou curador, na forma da lei”.

A lei à qual o dispositivo faz referência não é a processual, mas a civil, sendo regra que a representação processual do incapaz seja feita pelo mesmo representante – pai, tutor ou curador – constituído para a prática dos atos jurídicos em geral.

A primeira opção da lei processual, nesse sentido, coincidente com a disciplina estabelecida no Direito Civil, é que a representação do menor que venha a figurar como parte em um processo seja feita pelos seus pais. Trata-se, portanto, de um dos desdobramentos do poder familiar.

A ausência dos pais do menor, quer por força da morte destes, quer por força da desconstituição do poder familiar por motivos graves, previstos em lei e judicialmente reconhecidos, gera a necessidade de nomeação de um tutor para fins de representação do menor nos atos jurídicos em geral e, no plano do processo, para fins de regularização da capacidade processual do menor.

É denominado curador o representante dos demais incapazes cuja incapacidade de exercício não decorre da menoridade. Assim, aos enfermos que por força da enfermidade não puderem exprimir sua vontade, será constituído curador como representante legal, inclusive para fins processuais.

Em relação ao menor de 18 anos, porém maior de 16, em decorrência da capacidade relativa deste reconhecida pelo Direito Civil, verifica-se uma certa peculiaridade no plano processual.

Nesse sentido, esses sujeitos, em vez de serem representados, são “assistidos” pelos seus pais ou tutores, conforme determina o art. 71, sempre nos termos da lei civil.

Ainda no que tange à capacidade processual dos incapazes, o art. 72, inc. I, dispõe que ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, deverá ser constituído um curador especial, enquanto durar a incapacidade.

O curador especial, portanto, faz as vezes dos pais ou do tutor ausente ou cujo interesse colida com o do incapaz parte em um processo. O parágrafo único do referido artigo dispõe que a curatela especial deverá ser exercida pela defensoria pública, instituição essencial à Justiça cuja finalidade é exatamente a defesa dos hipossuficientes⁴⁰⁴.

A necessidade de curador especial é estendida ao réu revel preso, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, nos termos do art. 73, inc. II, do Código, nestes casos, enquanto não for constituído advogado pelo réu revel.

Assim, verificada a revelia de réus presos ou citados fictamente por edital ou hora certa, deverá ser intimada a Defensoria Pública para que um de seus membros atue como curador especial.

Já a capacidade processual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, bem como dos entes despersonalizados, é um requisito ligado à representação.

A representação processual desses entes é disciplinada no art. 75 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, as pessoas ali indicadas estarem regularmente constituídas na relação processual sob pena de irregularidade.

O art. 75 do CPC dispõe em seu inc. I que a União será representada em juízo, ativa e passivamente, pelos membros da Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, ao passo que os Estados e o Distrito Federal o serão por seus procuradores (art. 75, inc. II).

As referidas pessoas jurídicas, todas de direito público, não poderiam ter em lei outra indicação de representantes, uma vez que, conforme já estudado no Capítulo 7, é a Constituição Federal, ao disciplinar as “Funções Essenciais à Justiça”, que prevê a existência da Advocacia-Geral da União (AGU) e das Procuradorias estaduais com atribuição de representar esses entes em juízo.

No plano federal, os membros da AGU representantes da União em juízo são os advogados da União e os procuradores da Fazenda Nacional, estes últimos dedicados exclusivamente às causas fiscais⁴⁰⁵.

No plano estadual, o mesmo papel cabe aos procuradores dos Estados, carreira que deve ser criada e estruturada por cada um dos Estados-membros por expressa previsão constitucional e cujos integrantes possuem, entre outras funções, a de representar o Estado em juízo.

Já a obrigatoriedade de existência de uma estrutura de procuradoria e carreira de procuradores não é exigida constitucionalmente para os municípios.

Em primeiro lugar, é bom que fique claro que nada impede e, muito pelo contrário, razões de ordem prática até sugerem que os municípios sejam representados por procuradores de carreira. Entretanto, inexistente norma jurídica que obrigue os municípios a manterem um quadro permanente de procuradores.

Assim, no plano municipal, a situação pode variar, havendo municípios que fazem a opção política de criar e estruturar uma procuradoria e existindo, por outro lado, municípios que optam por não manter um quadro permanente de procuradores ocupados da defesa e representação processual em juízo.

Essa dicotomia se reflete no Código de Processo Civil que, em seu art. 75, inc. III, estabelece que será representado em juízo, ativa e passivamente, “o Município, por seu prefeito ou procurador”.

Assim, caso o Município tenha estrutura de procuradoria, sua representação processual se dá em termos muitos parecidos com a dos Estados-membros, isto é, por procuradores de carreira. Do contrário, a função de representação judicial do Município fica delegada ao prefeito, chefe do poder executivo municipal.

Mais adiante, ver-se-á que, além de representantes, os procuradores das

peças jurídicas de direito público também encerram em si a qualidade de advogado dessas entidades para fins de preenchimento da capacidade postulatória, salvo nos casos da representação do Município pelos prefeitos que devem, nesse caso, contratar um advogado⁴⁰⁶.

Outra categoria de pessoas jurídicas de direito público são as autarquias e a fundação de direito público, entes criados por lei pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e que têm autonomia e independência.

A representação desses entes não é disciplinada exaustivamente pelo Código de Processo Civil, que se limita dizer que ela cabe a quem a lei do ente federado designar⁴⁰⁷.

Portanto, cabe ao ente político que cria a autarquia ou fundação de direito público definir em lei o representante dessas pessoas em juízo.

No plano federal, todas as autarquias e fundações criadas pela União são representadas judicialmente pelos procuradores federais, membros da Advocacia-Geral da União, salvo o Banco Central, única autarquia federal que possui quadro de procuradores próprios.

Nos Estados e Municípios, a variação é maior exatamente pela possibilidade de escolhas legislativas que cada um desses entes pode fazer. Nesse sentido, é possível que o Estado atribua a representação judicial de suas autarquias aos próprios procuradores do Estado ou crie um quadro próprio de procuradores autárquicos ou fundacionais.

Da mesma forma, no plano municipal é a lei de cada Município que definirá a forma de representação judicial desses entes.

As pessoas jurídicas de direito privado têm sua representação disciplinada no art. 75, inc. VIII que faz referência ao ato de sua constituição. No silêncio do ato constitutivo, a representação judicial da sociedade ou associação será realizada pelos seus diretores, necessariamente identificados no estatuto, contrato social ou outra forma de ato constitutivo.

Na qualidade de representante, cabe ao diretor da pessoa jurídica ou àquele detentor de tal função, nos termos dos atos constitutivos, praticar os atos e manifestações em nome desta, o que inclui a assinatura da procuração que constitui o advogado da pessoa jurídica nos autos do processo e a presença em audiência para prestar depoimento em nome da sociedade ou associação.

Nesse passo, é importante destacar a possibilidade de o representante da pessoa jurídica constituir um representante, prática amplamente admitida no dia a dia do foro por meio da constituição de um preposto.

O preposto, nesse contexto, deve ser entendido como o representante do representante da pessoa jurídica, sendo plenamente possível, portanto, a constituição pelo diretor, ou por quem o ato constitutivo designar, de um preposto mediante uma carta de preposição.

No que tange às pessoas jurídicas estrangeiras, o art. 75, inc. IX, dispõe que, na ausência de ato constitutivo no Brasil que identifique o diretor ou representante, estas deverão ser representadas em juízo pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Ademais, o art. 75 do Código de Processo Civil também disciplina a representação processual dos entes despersonalizados com capacidade de ser parte.

A massa falida será representada nos termos do art. 75, inc. V, pelo administrador judicial, assim entendido o “auxiliar da Justiça” constituído pelo juiz do processo falimentar e que, portanto, entre outras atribuições, passa a ser o representante da massa falida nos autos do processo em que esta seja parte.

Situação semelhante ocorre com o inventariante, nomeado pelo juiz do processo de inventário e partilha para administrar os bens, direitos e obrigações do espólio e, se for o caso, representá-lo nos processos em que

o espólio figure como autor ou réu.

Já nos casos de herança jacente ou vacante, cabe o juiz que reconhece essa condição nomear um “curador” que funcionará, nos termos do art. 75, inc. VI, do CPC como o representante legal da herança jacente ou vacante em juízo.

É de se notar que em todos esses casos, o administrador da massa falida, o inventariante e o curador da herança jacente ou vacante não são nomeados exclusivamente para serem os representantes judiciais desses entes despersonalizados em juízo, uma vez que são os responsáveis por toda a administração dessas universalidades de bens, direitos e obrigações.

Ser o representante em juízo, para fins de cumprimento da capacidade processual é apenas uma das funções desses sujeitos.

Já as sociedades de fato, assim entendidas a sociedade e a associação irregulares, bem como outros entes organizados sem personalidade jurídica, que, não obstante a inexistência ou irregularidade de sua constituição, têm capacidade de ser parte, devem ser representadas judicialmente pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.

Por fim, o art. 75, inc. X, dispõe que o condomínio deverá ser representado pelo administrador ou síndico, ou seja, pela mesma pessoa responsável nos termos da convenção condominial por praticar os atos jurídicos em geral desse ente, como contratar e demitir funcionários, contrair e quitar obrigações.

Considerando que a capacidade processual é pressuposto processual de validade, sua regularidade é indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Por esse motivo, o art. 76 do Código aduz que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o órgão jurisdicional suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, tema que será tratado no item 10.3.1, “b”.

Portanto, exige-se a regularidade desse requisito que pode ser verificada, inclusive, de ofício pelo juiz sendo certo que, conforme se verá adiante, a detecção de irregularidades ligadas a esse pressuposto implica a necessidade imediata de sua correção, podendo até, no caso de manutenção da situação irregular, levar à extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil⁴⁰⁸.

g) Capacidade postulatória

Conforme já asseverado no Capítulo 7, dedicado a “Funções Essenciais à Justiça”, nos termos do art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da Justiça.

Portanto, por mais que se considere que o direito discutido em juízo e o próprio direito de praticar os atos processuais sejam da parte, fato é que elas exercem esses direitos e, efetivamente, participam do processo e praticam atos processuais por meio de um advogado.

Nesse contexto, o advogado deve ser entendido como o bacharel em Direito inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, que, para fins de regularidade da capacidade postulatória, deve estar constituído pela parte nos autos do processo.

Essa regular constituição nos autos do processo se dá pela juntada de um documento denominado mandato judicial assinado pela parte ou seu representante.

O mandato (ou procuração) judicial é regulamentado pelos arts. 104 e 105 do Código de Processo Civil.

A indispensabilidade da procuração judicial é expressa no art. 104 do Código que admite, excepcionalmente, a prática de atos por advogado sem esse instrumento de constituição apenas em casos urgentes e para que se evite preclusão, prescrição ou decadência, ou seja a perda do direito pela

inércia processual.

Ainda assim, mesmo nessas hipóteses em que se admite a prática de atos pelo advogado sem regular e prévia constituição, a juntada da procuração deverá se dar em quinze dias prorrogável por outros quinze, no máximo, sendo certo que, não juntada a procuração nesse prazo, os atos praticados pelo advogado serão tidos como ineficazes, devendo o advogado responder por eventuais prejuízos causados (art. 104, § 2º, do CPC).

Portanto, como regra geral, a atuação do advogado pressupõe a prévia constituição deste mediante assinatura pela parte do instrumento de procuração judicial que deverá estar juntada aos autos do processo.

A exceção admite a prática de atos pelo advogado sem a prévia juntada de procuração judicial aos autos do processo, sendo certo que, mesmo nesses casos, a eficácia plena do ato processual fica condicionada à juntada a posteriori de tal instrumento.

Uma vez constituído o advogado nos autos do processo mediante a juntada da procuração judicial, este passa a ter, nos termos do art. 105 do CPC, o poder de praticar todos os atos processuais em nome da parte que representa sendo, entretanto, necessários poderes especiais e expressos para que o advogado possa receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica.

O dispositivo não proíbe que o advogado pratique tais atos em nome da parte, mas apenas exige que conste da procuração cláusula específica outorgando tais poderes.

A regular capacidade postulatória é imprescindível para fins de validade dos atos processuais e da própria relação jurídica processual constituindo verdadeiro pressuposto processual de validade cuja regularidade deve ser verificada pelo juiz, inclusive de ofício, e corrigida caso detectado algum

vício⁴⁰⁹.

A não correção do defeito implicará a impossibilidade de a parte sem regular capacidade postulatória participar do processo e praticar ato processuais o que leva: a) à extinção do processo sem resolução do mérito caso a parte sem advogado seja o autor, ou; b) ao prosseguimento do processo à revelia do réu, caso seja esta a parte sem capacidade postulatória.

10.3.1 A correção da tríplice capacidade mediante sucessão de partes, representantes e procuradores

Conforme já asseverado, a regularidade da tríplice capacidade das partes é imprescindível para fins de desenvolvimento válido e regular do processo.

Essa imprescindibilidade decorre do fato de a capacidade de ser parte, capacidade processual e capacidade postulatória serem verdadeiros pressupostos processuais, sem os quais o processo não pode se desenvolver válida e regularmente.

Ocorre que, em algumas situações, apesar de, em um primeiro momento, todos os requisitos estarem preenchidos e regulares, determinados eventos ou manifestação de vontade das partes ou de seus procuradores podem gerar a perda ulterior de uma daquelas capacidades.

São exemplos desse fenômeno a morte da parte, de seu representante ou de seu advogado, assim como a perda da capacidade de uma desses sujeitos após já iniciado o processo.

Ademais, existe a possibilidade de mudança de advogado por opção, quer da própria parte, quer do advogado.

A morte ou perda da capacidade da parte ou de seu representante implica imediata necessidade de substituição destes para que seja reestabelecida a regularidade relativa à capacidade de ser parte ou capacidade processual, assim como a morte ou perda da capacidade do advogado gera a necessidade de sua substituição para fins de regularização

da capacidade postulatória.

Da mesma forma, se a parte pretende, por qualquer motivo, mudar de advogado ou este não mais tem a intenção de ser seu procurador, para fins de regularização da capacidade postulatória, outro advogado deve ser constituído nos autos.

O objetivo deste item, portanto, consiste em analisar: a) as consequências e a forma de sucessão em caso de morte da parte; b) a forma de regularização da capacidade processual em caso de perda da capacidade da parte até então capaz ou da pessoa que a representava; c) a forma de regularização da capacidade postulatória em caso de morte ou perda da capacidade do advogado; e d) as formas de substituição do advogado por vontade da parte ou do causídico, temas que no Código de Processo Civil são regulados entre os arts. 108 e 111.

a) Sucessão de parte

O Direito Processual Civil não poderia deixar de regulamentar as consequências processuais advindas da morte da parte no curso do processo.

Tal evento, obviamente, tem reflexos processuais, haja vista que com a morte desaparece a condição de sujeito de direito e, por via de consequência, a capacidade de ser parte.

De rigor, pela morte da parte, podem advir duas consequências: a) a extinção do processo, caso o direito litigioso seja considerado por lei intransmissível⁴¹⁰; ou b) a sucessão de partes, em caso de direitos patrimoniais e transmissíveis, hipótese aqui estudada.

O tema é disciplinado pelo art. 110 do CPC que dispõe: “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou seus sucessores”, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

A remissão ao art. 313 do Código refere-se à necessidade de suspensão

do processo até a regularização da capacidade de ser parte pela sucessão.

Tal suspensão é coerente com o sistema do Código que inadmite o prosseguimento do feito enquanto o requisito estiver irregular⁴¹¹.

Assim, caso o direito discutido no processo seja patrimonial e disponível, na hipótese de morte da parte, suspende-se o processo, para que se substitua a parte falecida por seu espólio, seus herdeiros ou sucessores.

Considerando que a identificação desses herdeiros e sucessores pode demandar a formação, o desenvolvimento e o julgamento em um outro processo, de inventário e partilha, o tempo de suspensão poderia ser demasiadamente grande, razão pela qual o sistema processual atribui capacidade de ser parte e admite a sucessão da parte falecida pelo seu espólio.

O espólio, conforme já asseverado, apesar de não ser sujeito de direitos, mas sim uma universalidade patrimonial administrada pelo inventariante até que seja realizada a partilha, sucede a parte falecida até que sejam identificados os sucessores no processo, pela sentença que julga a partilha.

Portanto, a morte da parte pode gerar até duas sucessões em um mesmo processo: em primeiro lugar, desta pelo seu espólio que, após a partilha, é sucedido pelo herdeiro ou sucessor nela identificado.

Outro fenômeno que pode gerar a possibilidade de sucessão da parte é por ato inter vivos, ou seja, a alienação do bem ou direito objeto do processo.

Primeiramente, é bom esclarecer que se trata de uma situação excepcional dado que, como regra, as partes originais devem ser as mesmas até o fim do processo.

Nesse sentido, o art. 108 do CPC que dispõe: “no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”.

Assim, como regra, a alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre

vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, permanecendo legítima a parte original, isto é, o alienante, salvo se a parte contrária consentir com a sucessão deste pelo adquirente ou cessionário.

Em síntese, o “novo” titular do direito litigioso não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária (art. 109, caput e § 1º, do CPC).

Sem que a sucessão de partes por força do ato inter vivos seja admitida pela parte contrária, o máximo que o adquirente ou cessionário, “novo” titular do direito discutido no processo, poderá fazer é atuar como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, réu originário, nos termos autorizados pelo art. 109, § 2º, do CPC.

Independentemente dessa sucessão e mesmo que o adquirente ou cessionário atue como assistente litisconsorcial⁴¹², o art. 109, § 3º, do CPC deixa claro que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias o alcançam.

b) Substituição do representante da parte

Conforme já demonstrado no item 10.3, “f”, supra, nas hipóteses em que a pessoa física seja incapaz nos termos da lei civil, faz-se necessário, para fins de validade e regularidade do processo, que ela seja representada por seus pais ou, na falta destes, por um tutor ou curador que devem, nesses casos, atuar na qualidade de representante da parte.

O mesmo fenômeno da representação, para fins de regularidade da capacidade processual de estar em juízo, ocorre quando a parte for pessoa jurídica, hipótese em que deverá ser representado por seu diretor, ou pessoa designada em seu ato constitutivo como tal.

A morte ou perda da capacidade do representante da parte é regulada pelo art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil na medida em que implica a suspensão do processo até a efetiva regularização⁴¹³.

Em síntese, o dispositivo determina a suspensão do processo até que a capacidade processual da parte seja regularizada com a constituição de um novo representante, ou seja, um tutor para o menor no caso de morte de seus pais; ou de um novo tutor ou novo curador no caso de morte de um desses representantes.

No caso de morte do representante da pessoa jurídica, o art. 313, inc. I, do CPC também determina a suspensão do processo até a constituição de um novo representante.

Entretanto, caso a pessoa jurídica tenha mais de um representante, a morte de um deles não acarreta a suspensão do processo.

c) Substituição do advogado

O Código de Processo Civil disciplina a possibilidade ou até a necessidade de substituição do advogado em três situações.

A primeira delas quando a parte, por qualquer motivo, entende por desconstituir seu advogado, hipótese em que deverá constituir, imediatamente, outro que assuma o patrocínio da causa.

Essa é a determinação do art. 111 do CPC que, portanto, não admite a simples revogação do mandato que constitui o advogado sem a nomeação de outro.

Caso essa nomeação não se dê imediatamente, verificar-se-á a irregularidade da capacidade postulatória levando à extinção do processo, se a providência couber ao autor; ou à revelia do réu, se a providência couber a este.

Entretanto, ainda assim, por se tratar de vício sanável, antes de decretar a extinção do processo, o juiz deve intimar a parte para que regularize a situação.

Outra hipótese que leva à necessidade de a parte constituir outro advogado decorre da morte do causídico.

Falecido o advogado, desaparece a capacidade postulatória até então existente, fato que gera a suspensão do processo para sua regularização.

De rigor, a suspensão só ocorre caso o advogado falecido seja o único constituído pela parte nos autos do processo, pois, caso mais de um advogado represente a parte, a morte de um deles não lhe retira a capacidade postulatória.

Assim, caso falecido o único advogado da parte, faz-se necessária a constituição de um novo patrono, ficando o processo suspenso, sem, portanto, a contagem de prazo e sem que seja possível a prática de atos processuais.

O § 3º do art. 313 do CPC dispõe que a parte possui o prazo de 15 dias para que constitua o novo advogado.

Após o referido prazo, caso o advogado falecido e não substituído seja do autor, o processo será extinto sem resolução do mérito. Caso seja o réu a parte que passe a, pela morte do advogado, ficar sem capacidade postulatória, ao fim do prazo de 15 dias fixado no § 3º do art. 313 do CPC, o processo prosseguirá “à revelia” do réu.

Por revelia, nesse contexto, deve ser entendida a impossibilidade de a parte praticar qualquer ato processual até que regularize sua situação processual e constitua um novo advogado.

Por fim, o art. 112 do Código prevê e regulamenta a possibilidade de o advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo, gerando a necessidade de sua substituição pela parte.

Para tanto, nos termos do referido dispositivo cabe ao advogado que renuncia ao mandato comunicar a renúncia à parte a fim de que esta nomeie sucessor.

A comunicação deverá ser provada pelo advogado renunciante nos autos do processo.

Caberá ao advogado, nos termos do art. 112, § 1º, do Código, continuar

representando a parte, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, durante os dez dias seguintes, salvo se antes disso a parte constitua outro procurador nos autos do processo.

A parte, portanto, uma vez devidamente comunicada, possui o prazo de dez dias para constituir novo advogado.

As consequências do descumprimento do referido prazo é a perda da capacidade postulatória o que implica extinção do processo se o renunciante for o advogado do autor; ou prosseguimento do processo à revelia do réu, se for este que, a partir da renúncia, ficar sem advogado constituído nos autos.

Tal como no caso de morte do advogado, se houver mais de um procurador representando a parte, subsistindo a capacidade postulatória, dispensam-se tanto a comunicação quanto a necessidade de constituição de um novo mandatário (art. 112, § 2º, do CPC).

10.4 Pressupostos processuais negativos

Se, por um lado, certos requisitos são fundamentais para a existência e desenvolvimento válido e regular do processo; por outro, determinadas situações não podem estar configuradas sob pena de impedir este regular andamento do feito rumo ao julgamento de mérito. A esse grupo de fenômenos dá-se o nome de pressupostos processuais negativos.

Desta feita, ao contrário dos pressupostos processuais de existência e validade que devem estar presentes para que o processo possa se desenvolver válida e regularmente rumo ao julgamento de mérito, os pressupostos processuais negativos são fenômenos que não podem ser verificados, sob pena de o processo ter de ser extinto sem a resolução do mérito.

São pressupostos processuais negativos: a) a litispendência; b) a coisa julgada; c) a perempção; d) a convenção de arbitragem.

A configuração de uma dessas situações deve levar à extinção do

processo sem resolução do mérito.

Os itens subsequentes serão dedicados a cada um dos quatro pressupostos processuais negativos.

a) Litispendência

O art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil reza que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, no que é complementado pelo § 2º do mesmo dispositivo que ensina que, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A razão de ser da litispendência, enquanto pressuposto processual negativo, é impedir que uma mesma lide seja apreciada e julgada por mais de um órgão jurisdicional o que, além de gerar uma inútil duplicidade de esforços, pode acarretar incongruências e decisões contraditórias.

Assim, uma lide só poderá ser apreciada pelo Poder Judiciário uma única vez, em um único processo sendo a possibilidade de rejuízo do mesmo litígio apenas possível pela via recursal ou, mais amplamente, por mecanismos de impugnação às decisões judiciais.

Para que se evite a multiplicidade de apreciação, o Código de Processo Civil impede que a mesma ação seja reproposta, caracterizando a litispendência como um pressuposto processual negativo.

Como forma de identificar a duplicidade de ações, o CPC se vale dos elementos da ação, sendo uma ação idêntica a outra quando lhes forem comuns as partes, a causa de pedir e o pedido.

A verificação da litispendência determina a extinção da ação idêntica à já proposta sendo certo que, obviamente, a primeira ação ajuizada não é atingida por essa reprodução e permanece intacta, devendo se desenvolver e ter seu mérito julgado.

Por esse motivo, faz-se necessária a definição de qual das ações

idênticas deve ser considerada a primeira a ser proposta, sendo apenas as demais levadas à extinção pela litispendência.

A solução é encontrada na leitura do art. 240 do Código que considera ser a “primeira ação” aquela em que se realizar a citação em primeiro lugar.

Assim, detectada a existência de duas ou mais ações com as mesmas partes, mesmos fundamentos de fato e de direito e mesmo pedido, deve-se verificar em qual dos processos foi realizada primeiramente a citação válida, devendo este prosseguir e os demais serem extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

A existência da litispendência é um vício gravíssimo e insanável e, por esse motivo, pode ser arguido e verificado de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Obviamente, isso não impede que o réu suscite o vício e requeira a extinção do processo, até porque este tem mais condições de conhecer a existência da litispendência do que o juiz por já ter sido citado no primeiro processo.

O Código determina que o réu o faça desde logo, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, isto é, já na “preliminar de contestação”⁴¹⁴.

Entretanto, por ser um vício gravíssimo, mesmo que o réu não o faça nessa oportunidade, poderá fazê-lo em outra⁴¹⁵.

b) Coisa julgada material

As mesmas razões que levam o sistema processual a impedir a repetição de uma ação idêntica a outra já pendente perante um órgão do Poder Judiciário impedem a repropositura de uma ação já proposta e definitivamente julgada.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil categoriza como pressuposto processual negativo a coisa julgada material.

A coisa julgada material pode ser definida como a qualidade que reveste a decisão de mérito que a torna imutável e indiscutível no processo em que a decisão foi proferida e em qualquer outro processo.

São requisitos para a formação da coisa julgada material: 1) a apreciação do mérito, ou seja, um pronunciamento sobre o pedido; e 2) o esgotamento dos recursos, quer porque os recursos cabíveis não foram interpostos, quer porque todos os recursos possíveis foram interpostos e julgados.

O não cabimento de qualquer recurso, somado ao pronunciamento de mérito, gera a coisa julgada material.

Por outro lado, se por algum motivo o processo vier a ser extinto sem resolução do mérito, ainda que dessa decisão não caibam mais recursos, não haverá a formação da coisa julgada material que, repita-se, depende de um pronunciamento sobre o pedido (mérito).

À imutabilidade da decisão judicial que extingue o processo sem resolução do mérito dá-se o nome de coisa julgada formal.

Contudo, a coisa julgada, categorizada pelo sistema como pressuposto processual negativo e geradora do impedimento da repropositura da ação, é a coisa julgada material, sendo certo que a formação da coisa julgada meramente formal **não** impede a repropositura da mesma ação.

Desta feita, o esgotamento dos recursos contra uma decisão que extingue o processo sem a apreciação do mérito, que gera apenas a coisa julgada formal, não impede a repropositura da mesma ação em um outro processo, desde que, obviamente, corrigido o vício que deu causa à extinção do primeiro.

Nesse sentido, o caput do art. 486 do Código de Processo Civil, que dispõe que “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”.

Portanto, apenas quando julgado o mérito e esgotados os recursos, forma-se a coisa julgada material, esta **sim**, pressuposto processual

negativo que impede a repropositura da ação mesma ação novamente.

A forma de identificação da identidade de ações é a mesma da litispendência, ou seja, considera-se uma ação idêntica à outra quando lhes forem comuns as partes, a causa de pedir e o pedido.

Tal como a litispendência, a preexistência da coisa julgada representa um vício processual gravíssimo e insanável, passível de ser arguido pela parte e decretado de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo levar à extinção do processo sem a resolução do mérito.

c) Perempção

Conforme asseverado anteriormente, nos termos do art. 486 do CPC, caso a extinção do processo se dê sem a resolução do mérito, não se forma a coisa julgada material, podendo a mesma ação ser reproposta desde que corrigido o vício que deu causa à primeira extinção.

Entre essas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, está a do “abandono da causa” pelo autor.

O tema será tratado com mais vagar no item 11.4.1, “c”, do capítulo seguinte, devendo desde já ficar compreendido que por “abandono da causa” devem ser entendidas as omissões do autor que deixa de praticar atos indispensáveis para o andamento do feito tais como recolher ou complementar as custas de ajuizamento ou fornecer dados indispensáveis para a citação do réu.

Por implicar uma extinção sem resolução do mérito e, portanto, uma coisa julgada meramente formal, a extinção por abandono não impede a repropositura da mesma ação.

Contudo, o sistema processual impõe um limite quantitativo à possibilidade dessa repropositura ainda que o mérito não seja apreciado.

Nesse sentido, dispõe o § 3º do art. 486 que “se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor

nova ação contra o réu com o mesmo objeto”.

Assim, a propositura e o subsequente abandono da causa pelo autor, por três vezes, geram a denominada perempção, pressuposto processual negativo que, uma vez caracterizado, impede o processamento e julgamento da ação idêntica ajuizada pela quarta vez.

O Código deixa claro que a perempção não implica a perda do direito pelo autor das três ações anteriores ao dispor que lhe fica ressalvada a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

De todo modo, como pressuposto processual negativo, verificada a perempção, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito.

Da mesma forma que a litispendência e a coisa julgada, a perempção representa um impedimento grave e insanável, passível de ser arguido pela parte e decretado de ofício pelo juiz em quaisquer tempo e grau de jurisdição.

d) Convenção de arbitragem

Nos termos já sistematizados por ocasião do estudo dos meios de resolução da lide (Capítulo 3, supra), as pessoas capazes de contratar poderão optar por submeter o litígio relativo a direitos patrimoniais disponíveis à arbitragem, em vez de buscarem a solução junto ao Poder Judiciário.

As partes interessadas em submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral podem fazê-lo pela convenção de arbitragem que, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.307/96, que regulamenta a arbitragem no Brasil, é um gênero que tem como espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

A cláusula compromissória é a convenção por meio da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato (art. 4º da Lei n. 9.307/96).

Já o compromisso arbitral, nos termos do art. 9º da Lei de Arbitragem, é a convenção pela qual as partes submetem um litígio já existente à arbitragem.

A existência de compromisso arbitral ou de cláusula compromissória impede a apreciação do litígio pelo Poder Judiciário dado que ele será processado e julgado pelo juízo arbitral eleito pelas partes.

Por essa razão, a existência de uma dessas espécies de convenção de arbitragem representa um pressuposto processual negativo que impede o desenvolvimento válido e regular do processo perante o juízo estatal.

Contudo, ao contrário dos demais pressupostos processuais, a convenção de arbitragem não configura uma matéria de ordem pública e, por esse motivo, não pode ser decretada de ofício pelo juiz, dependendo necessariamente de provocação da parte interessada.

O Código de Processo Civil deixa claro esse tratamento dado a esse pressuposto processual negativo ao dispor, no § 5º do art. 337, que “o juiz não poderá conhecer de ofício a convenção de arbitragem”.

Nos termos do inc. X, do mesmo art. 337, o CPC dispõe que o momento adequado para que o réu apresente essa arguição é a “preliminar de contestação”.

Caso o réu não o faça, opera-se a preclusão sobre tal alegação que, portanto, não poderá mais ser realizada, tornando-se possível o desenvolvimento válido e regular do processo perante o Poder Judiciário, não obstante a existência da convenção de arbitragem.

Nesse sentido, lapidar a letra do § 6º, art. 337, que reza: “a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral”.

Por outro lado, caso alegada oportunamente e demonstrada pelo réu a existência do compromisso arbitral, o juiz, acolhendo tal alegação, deverá

extinguir o processo judicial sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VII, do Código.

10.5 Formas de arguição e verificação de consequências da decretação das irregularidades relativas aos pressupostos processuais

Dada a importância sistemática dos pressupostos processuais, a regularidade desses requisitos de desenvolvimento válido e regular do processo constituem matéria de ordem pública.

Conforme já asseverado nesta Introdução, por matéria (ou questões) de ordem pública devem ser entendidos todos vícios gravíssimos cuja caracterização contamina a relação processual, tornando nulo o processo e, sobretudo, as decisões nele prolatadas.

Em função dessas consequências graves, os pressupostos processuais têm duas características: a) a verificação da regularidade relacionada aos pressupostos processuais não depende de provocação ou requerimento da parte interessada, podendo ser verificada e decretada de ofício pelo juiz; b) a análise e eventual decretação de nulidade relacionada aos pressupostos processuais não precluem, ou seja, podem ser verificadas e decretadas em quaisquer tempo e grau de jurisdição.

O fato de o juiz possuir o dever de verificar e decretar os vícios relacionados aos pressupostos processuais de ofício, obviamente, não impede que a parte interessada realize a arguição dessas irregularidades, provocando as respectivas verificação e decretação pelo magistrado.

Essa arguição, apesar de não precluir e poder ser feita pela parte a qualquer momento, via de regra, deve ser feita na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos do processo.

Entretanto, por constituir matéria de ordem pública, a não arguição pela parte na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos do processo não implica preclusão ou impossibilidade de arguir posteriormente.

De todos os pressupostos processuais, o único que não tem o regime jurídico de questão de ordem pública é a alegação de convenção de arbitragem. Isso porque, nos termos do art. 337, §§ 5º e 6º, do CPC, esse pressuposto processual negativo não pode ser verificado e decretado de ofício pelo juiz e, se não alegado pela parte interessada – no caso, o réu em preliminar de contestação –, esta perde o direito de realizar tal arguição, sendo essa alegação, portanto, sujeita à preclusão.

Assim, à exceção da convenção de arbitragem, os demais vícios relacionados aos pressupostos processuais, são matéria de ordem pública podendo ser arguidos pelas partes, ou decretados de ofício pelo juiz em quaisquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, como regra geral, as irregularidades relacionadas com os pressupostos processuais impedem o exame de mérito.

Isso, porém, não implica dizer que a verificação desses vícios deva levar à imediata extinção do processo sem a resolução do mérito, haja vista que, sempre que possível, a opção do magistrado, antes de extinguir o processo, deve ser tentar corrigir o vício ou determinar que a parte interessada o faça.

Assim, detectado o vício relacionado aos pressupostos processuais, quer por provocação da parte, quer de ofício pelo juiz, deverá o magistrado verificar se se trata de um vício passível de correção ou de um vício insanável, ou seja, incorrigível.

Na hipótese de vícios insanáveis, dada a impossibilidade de correção somada ao impedimento de o processo se desenvolver válida e regularmente rumo ao julgamento de mérito, não haverá outra solução a não ser a imediata extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. IV, V e VII, do Código de Processo Civil.

São hipóteses de vícios insanáveis que implicam imediata extinção do processo sem resolução do mérito a verificação de litispendência, de coisa julgada e de perempção, por exemplo.

Já os vícios sanáveis não implicam imediata extinção do processo em função exatamente da possibilidade de correção.

Nessas hipóteses, de duas uma: ou o próprio juiz corrige a irregularidade de ofício; ou o juiz deverá intimar a parte para que esta corrija o vício relacionado ao pressuposto processual.

Considerando as peculiaridades de cada pressuposto processual, os subitens a seguir farão uma síntese das formas de arguição e verificação de consequências da decretação das irregularidades relativas aos pressupostos processuais, um a um.

Antes disso, duas premissas precisam ser fixadas: a) o fato de os vícios poderem ser decretados de ofício não implica dizer que a parte interessada não deva fazê-lo e, portanto; b) cabe à parte arguir o vício na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.

Assim, ainda que a parte interessada não sofra as consequências da preclusão e não perca o direito de arguir a irregularidade relacionada aos pressupostos processuais a qualquer momento, esta arguição deverá ser feita pela parte o quanto antes, preferencialmente na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.

A primeira oportunidade que o réu possui para falar nos autos é a preliminar de contestação disciplinada no art. 337 do Código de Processo Civil que dispõe: "Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, entre outras matérias: a) inexistência ou nulidade da citação; b) incompetência absoluta e relativa; c) inépcia da petição inicial; d) perempção; e) litispendência; f) coisa julgada; g) convenção de arbitragem".

Por outro lado, considerando que nem todos os vícios relacionados aos pressupostos processuais são argúveis pelo réu e que nem todos eles se configuram, necessariamente, no início do processo, sempre que surgir uma irregularidade caberá à parte interessada argui-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.

É o caso, por exemplo da suspeição e do impedimento, vícios relacionados à imparcialidade do juiz que poderão surgir a qualquer momento em função da possibilidade de substituição do magistrado no curso do procedimento.

Por essa razão, nesse caso, dispõe o art. 146 do CPC que “a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo” no prazo de quinze dias.

Considerando que cada um dos pressupostos processuais tem um regime de arguição, verificação e decretação, na sequência far-se-á uma análise específica da dinâmica de cada um deles.

a) Competência absoluta

É matéria de ordem pública, devendo ser verificada e decretada pelo juiz de ofício.

Caso não verificada e decretada pelo juiz de ofício, deve ser alegada pelo réu em preliminar de contestação.

Por ser matéria de ordem pública, a não alegação nessa oportunidade não impede que a parte interessada o faça em um outro momento.

Da mesma forma, o magistrado pode decretar a incompetência absoluta a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Verificada a incompetência absoluta, o processo não deve ser extinto sem resolução do mérito uma vez que, por tratar-se de vício sanável, os autos deverão ser remetidos ao juízo competente para regular processamento e julgamento.

A correção desse vício, por meio da remessa ao juízo competente deve ser feita pelo próprio juiz, de ofício ou a requerimento.

b) Imparcialidade

É matéria de ordem pública, devendo ser verificada e decretada pelo juiz

de ofício. Caso isso não aconteça, deve ser alegada pela parte nos termos do art. 146 do CPC.

Por ser matéria de ordem pública, a não alegação nesta oportunidade não impede que a parte interessada o faça em outra oportunidade.

Apresentada a arguição de suspeição ou impedimento, o juiz pode reconhecer a irregularidade e afastar-se do processo.

Reconhecido o vício de parcialidade, o processo não deve ser extinto sem resolução do mérito uma vez que, por tratar-se de vício sanável, os autos deverão ser remetidos ao substituto legal do juiz suspeito ou impedido, para regular processamento e julgamento.

c) Petição inicial apta

Caracterizada a inépcia da inicial, o processo não pode se desenvolver válida e regularmente.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, o juiz deve verificar a aptidão da petição inicial de ofício, antes mesmo de determinar a citação do réu (art. 321 do CPC).

Caso o juiz não realize essa verificação, o réu poderá alegar a inépcia da inicial na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, a preliminar de contestação.

Se o vício causador da inépcia da petição inicial for sanável, o processo não deverá ser extinto imediatamente, devendo o autor ser intimado para corrigir o vício em quinze dias, nos termos do art. 321 do CPC.

Caso o autor corrija o vício no referido prazo, o pressuposto processual resta regularizado e, desta feita, o processo passa a poder se desenvolver válida e regularmente.

Na hipótese de, no prazo assinalado pelo juiz, o autor não corrigir o vício da petição inicial, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito, nos termos determinados pelos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do

Código de Processo Civil.

d) Citação válida

O vício de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser verificado pelo juiz de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Da mesma forma, o réu poderá arguir esse vício a qualquer tempo, sendo o momento ideal a preliminar de contestação (art. 337, inc. I, do CPC).

Apesar de gravíssimo, o vício da citação nunca implica extinção do processo sem resolução do mérito.

Sempre que verificado esse vício, os atos subsequentes à citação deverão ser declarados nulo e ao réu deve ser dada nova oportunidade para apresentação da defesa.

Ademais, o vício da citação pode ser suprido pelo comparecimento espontâneo do réu.

e) Capacidade de ser parte

É inconcebível a formação de uma relação processual sem o preenchimento, nos dois polos, de sujeitos com capacidade de ser parte.

Entretanto, no curso do processo, por morte da parte pessoa física ou falência da parte pessoa jurídica, o processo pode passar a ser irregular sob esse aspecto.

Nesses casos, de duas uma: a) caso o direito litigioso seja considerado por lei intransmissível, o processo deverá ser extinto sem análise do mérito⁴¹⁶; ou b) caso o direito seja patrimonial e transmissível, deverá haver a sucessão de partes, substituindo-se a parte falecida por seu espólio, seus herdeiros ou sucessores⁴¹⁷.

Ambas as situações podem ser verificadas e decretadas de ofício pelo juiz em quaisquer tempo e grau de jurisdição, o que não impede que a parte interessada provoque uma das atitudes cabíveis.

Na hipótese de sucessão de partes, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do art. 313, § 2º, do CPC, até que o sucessor seja habilitado⁴¹⁸.

f) Capacidade processual (de estar em juízo)

A irregularidade da representação da parte pode ser verificada de ofício pelo juiz ou por provocação da parte, em quaisquer tempo e grau de jurisdição.

Por ser um vício sanável, tal irregularidade não implica automática extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o juiz conceder prazo para que a parte regularize sua representação processual.

Caso essa irregularidade decorra da morte ou perda da capacidade da parte ou de seu representante, o processo deverá ficar suspenso, nos termos do art. 313, § 2º, do CPC.

Regularizada a representação no prazo assinalado pelo juiz o processo poderá se desenvolver válida e regularmente.

Caso não sanado o vício, a consequência processual poderá ser: a) a extinção do processo se a irregularidade de representação for da parte autora; ou b) o prosseguimento do processo à revelia do réu, caso seja esta parte a que permaneça com a capacidade processual irregular apesar de lhe ter sido dada a oportunidade de corrigir o vício.

g) Capacidade postulatória

A irregularidade da capacidade postulatória pode ser verificada de ofício pelo juiz ou por provocação da parte, em quaisquer tempo e grau de jurisdição.

Por ser um vício sanável, tal irregularidade não implica automática extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o juiz conceder prazo para que a parte regularize sua capacidade postulatória.

Caso essa irregularidade decorra da morte ou perda da capacidade do

advogado, o processo deverá ficar suspenso por quinze dias, nos termos do art. 313, § 3º, do CPC.

Regularizada a capacidade postulatória com a constituição de um advogado no prazo assinalado pelo juiz, o processo poderá se desenvolver válida e regularmente.

Caso não sanado o vício, a consequência processual poderá ser: a) a extinção do processo se a irregularidade estiver ligada à parte autora; ou b) prosseguimento do processo à revelia do réu, caso seja esta parte a que permaneça com a capacidade postulatória irregular apesar da oportunidade que teve de corrigir o vício.

h) Litispendência

Por se tratar de matéria de ordem pública, a litispendência pode ser verificada e decretada de ofício pelo juiz.

Não detectada de ofício pelo juiz, a parte pode alegar a existência da litispendência a qualquer tempo, mas deverá fazê-lo, preferencialmente, na preliminar de contestação.

Por representar um vício insanável, a verificação da litispendência implica extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

i) Coisa julgada material

Por se tratar de matéria de ordem pública, a existência de coisa julgada pode ser verificada e decretada de ofício pelo juiz.

Não detectada de ofício pelo juiz, a parte pode alegar a existência da coisa julgada a qualquer tempo, mas deverá fazê-lo, preferencialmente, na preliminar de contestação.

Por representar um vício insanável, a verificação da coisa julgada implica extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc.

V, do CPC.

j) Perempção

Por se tratar de matéria de ordem pública, a caracterização da perempção pode ser verificada e decretada de ofício pelo juiz.

Não detectada de ofício pelo juiz, a parte pode alegar a existência da perempção a qualquer tempo, mas deverá fazê-lo, preferencialmente, na preliminar de contestação.

Por representar um vício insanável, a verificação da perempção implica extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

k) Convenção de arbitragem

A convenção de arbitragem é o único pressuposto processual que não configura uma questão de ordem pública.

Por essa razão, o juiz não pode verificar e decretar de ofício a existência da convenção de arbitragem, cabendo apenas à parte interessada fazê-lo.

O réu possui o ônus de alegar a existência da convenção de arbitragem na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos do processo (preliminar de contestação) sob pena de perder a oportunidade de realizar tal arguição, nos termos do art. 337, §§ 5º e 6º, do CPC.

Caso arguida e comprovada pelo réu a existência da convenção de arbitragem, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. VII, do Código.

Se o réu não o fizer, por não haver outra oportunidade para fazê-lo, o processo poderá se desenvolver válida e regularmente perante o Poder Judiciário (art. 337, § 6º, do CPC).

Capítulo 11 Formação, Suspensão e Extinção do Processo

11.1 Considerações iniciais

O processo, enquanto relação jurídica desenvolvida em procedimento voltada à solução da lide, nasce, se desenvolve e se extingue por meio da prática de atos processuais pelos sujeitos do processo.

É importante e possui uma série de desdobramentos processuais, a identificação do momento do nascimento do processo, ou seja, dos atos que instauram a relação jurídica processual, assim como é fundamental identificar a forma e o conteúdo do ato processual que extingue o processo.

Ademais, determinados fatores que eventualmente surjam durante o curso do procedimento podem fazer com que o processo, já instaurado, seja impedido de avançar corretamente, não sendo o caso, contudo, de ser extinto. Nestas hipóteses de crise, o processo deve ser suspenso até que, corrigido o vício, possa voltar a caminhar.

A função dos arts. 312 a 317 do Código de Processo Civil é identificar e disciplinar a prática dos atos e fatos processuais relevantes para a formação, a suspensão e a extinção do processo, bem como dispor sobre as principais consequências da efetivação de cada um destes atos processuais.

O objetivo deste capítulo é estudar estes eventos fundamentais para a formação, o desenvolvimento e o fim da relação jurídica processual.

11.2 Da formação do processo

Como toda relação jurídica, a relação processual nasce pela prática de um ato jurídico por um sujeito de direito que, a partir de então, o vincula a um ou mais sujeitos.

Considerando que a relação processual é triangular por,

necessariamente, envolver, no mínimo, três sujeitos, (autor, Estado-juiz e réu), neste caso específico, na realidade, faz-se necessário mais de um ato jurídico para que a relação se complete.

Assim, é comum, na doutrina processual, a afirmação de que a relação jurídica processual se forma por etapas: na primeira etapa, forma-se a relação processual entre autor e Estado-juiz; e, apenas na segunda etapa, a relação se completa e torna-se triangular, passando a integrar também o réu.

A primeira etapa da formação da relação jurídica processual se dá por meio da prática de um ato, pelo autor, consistente no ajuizamento da demanda pela petição inicial. Isso porque, conforme já estudado, nas características da jurisdição, o Poder Judiciário é inerte, não agindo senão quando provocado, sendo, desta feita, o ato inaugural da relação processual sempre e necessariamente um ato da parte autora, a petição inicial.

A petição inicial, portanto, é o primeiro ato do procedimento e o ato processual de inauguração da relação processual.

Trata-se da provocação do Poder Judiciário ou, em outras palavras, o ato que materializa o direito de ação fazendo surgir o dever de o Estado-juiz prestar jurisdição por meio do processo.

Dada sua importância para o surgimento do processo, a petição inicial é detalhadamente regulamentada pelo Código de Processo Civil⁴¹⁹ e sua regularidade considerada um pressuposto processual de validade do processo⁴²⁰.

Assim, até para que se garanta a validade e a regularidade do processo, é imprescindível que a petição inicial esteja apta, assim entendida a petição inicial de acordo com o disposto no Código de Processo Civil, notadamente, em seus arts. 319 a 321.

Nos termos demonstrados no capítulo anterior⁴²¹, a irregularidade da petição inicial impede o desenvolvimento válido e regular do procedimento,

devendo, o autor, regularizá-la sob pena de extinção do processo.

Entretanto, mesmo irregular, a petição inicial faz nascer uma relação jurídica processual entre o autor e o Estado-juiz, sendo certo que a possibilidade de desenvolvimento válido e regular do procedimento dependerá da regularidade da petição inicial apresentada em juízo.

Esta apresentação se dá pelo protocolo da petição inicial na secretaria ou no órgão do Poder Judiciário equivalente com atribuição para receber a peça inaugural, ou por meio eletrônico nos portais (sites ou sítios) dos Tribunais.

Nesse sentido, o art. 312 do Código de Processo Civil, que dispõe que: “considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada (...)”.

Uma vez protocolada a petição inicial, caberá ao juiz ao qual ela tenha sido dirigida, em primeiro lugar, analisar sua regularidade e, em sendo considerada apta a validamente instaurar a relação processual, determinar a sua triangularização estabelecendo a prática do ato processual voltado a integrar o réu a esta relação processual, qual seja, a citação.

Entretanto, é bom que se deixe claro que a mera apresentação da petição inicial não implica, necessariamente, a citação do réu e a consequente integração deste à relação processual, podendo o processo, em caso de vícios graves contidos na petição inicial, ser, de plano, extinto, antes mesmo que a relação processual se complete.

Daí ser correta a afirmação da doutrina no sentido de que a relação processual já existe, ainda que de forma linear e incompleta, entre autor e Estado-juiz, antes mesmo do ingresso do réu.

Contudo, para que o processo seja considerado juridicamente existente, na perspectiva do réu, e para que possa produzir efeitos na esfera jurídica deste sujeito, faz-se necessária a prática de outro ato processual para integrá-lo à relação processual, a citação.

Portanto, antes da citação, a relação processual já existe, mas apenas

entre autor e Estado-juiz, sendo este ato de comunicação processual imprescindível para que o processo exista juridicamente e possa legitimamente surtir efeitos na esfera jurídica do réu.

Nesse sentido, a segunda parte do já referido art. 312 do Código de Processo Civil, que dispõe que “(...) a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado”.

Dada a importância do ato citatório para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, a citação é detalhadamente regulada no Código de Processo Civil (entre os arts. 238 e 259), sendo certo que a desobediência a estas regras, que venha a prejudicar o réu, implica uma nulidade bastante grave que contamina praticamente todos os demais atos processuais subsequentes.

Uma vez regularmente citado, o réu passa a integrar a relação processual que, a partir daí, é considerada, pelo sistema, completa e apta ao desenvolvimento rumo ao julgamento do pedido.

11.3 Suspensão do processo

Naturalmente, o processo é formado para que se desenvolva por meio da prática dos atos processuais, pelos seus sujeitos, até sua extinção, com resolução do mérito, assim entendida a solução do litígio entre as partes.

Ocorre que, determinados atos ou fatos jurídicos podem impedir o prosseguimento do processo rumo ao julgamento do pedido, impondo a necessidade de suspensão do processo ou mesmo sua extinção sem resolução do mérito.

Os fatores que levam à extinção do processo sem resolução do mérito serão estudados no item subsequente, sendo este item dedicado ao estudo das hipóteses de suspensão do processo.

Por suspensão do processo, deve ser entendida a paralisação do prosseguimento do processo com a consequente impossibilidade de prática

de atos processuais e da contagem de prazos processuais.

A suspensão do processo, portanto, impossibilita o desenvolvimento natural do procedimento, restando proibida, nos termos do art. 314 do CPC, a prática de qualquer ato processual, exceção feita aos atos processuais reputados urgentes e voltados a evitar dano irreparável, conforme se verá adiante.

Como medida excepcional que é, a suspensão do processo só pode ocorrer quando caracterizado um dos fatores especificamente previstos em lei, mais precisamente, no art. 313 do Código de Processo Civil, sendo certo que nada impede outros dispositivos do próprio Código ou outra lei federal de prever outras hipóteses de suspensão do feito.

Ainda assim, a mera ocorrência, no mundo dos fatos, de uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPC, por si só, não é suficiente para que o processo seja considerado suspenso, uma vez que, para tanto, faz-se necessário o reconhecimento deste fato por expreso pronunciamento judicial.

Portanto, a suspensão do processo se dá sempre que ficar caracterizada uma das hipóteses descritas em lei somada ao seu reconhecimento nos autos do processo por decisão judicial que, expressa e fundamentadamente, declara a suspensão.

O objetivo dos itens subsequentes é a análise das hipóteses de suspensão do processo e dos efeitos desta suspensão, bem como as condições para que ela se encerre e o processo volte a se desenvolver.

11.3.1 Hipóteses de suspensão do processo relacionadas à tríplice capacidade das partes

A grande maioria das hipóteses de suspensão do processo está arrolada no art. 313 do Código de Processo Civil, que possui oito incisos, sendo certo que, conforme deixa bem claro o último destes incisos, qualquer outra lei ou dispositivo do CPC pode estabelecer outras causas de suspensão.

Dispõe o art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil, que se suspende o processo “pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante ou de seu procurador”.

De rigor, o inc. I do art. 313 elenca seis hipóteses de suspensão do processo, três por morte e três por perda da capacidade: a) morte da parte; b) morte do representante da parte; c) morte do procurador, ou seja, advogado da parte; d) perda da capacidade processual da parte; e) perda da capacidade do representante da parte; e f) perda da capacidade do advogado da parte.

Apesar de estarem arroladas no mesmo inciso, existem consequências práticas diferentes se for verificada a morte ou a perda da capacidade da parte, se comparada com a morte de seus representantes ou procuradores.

Por essa razão, as hipóteses serão analisadas em separado nos subitens a seguir.

a) Suspensão por morte da parte

Com a morte da parte, o processo deixa de possuir, em um dos polos, um sujeito com capacidade de ser parte, não estando, por este motivo, apto a se desenvolver.

Conforme se verá a seguir⁴²², na hipótese de o direito objeto do processo ser intransmissível, o caso é de extinção do processo sem resolução do mérito, não fazendo sentido nenhum o processo prosseguir para se discutir um direito personalíssimo que pertence exclusivamente a alguém já falecido.

Entretanto, se o direito for patrimonial e transmissível, deverá ocorrer a sucessão de parte, já tratada no item 10.3.1, “a”, supra, devendo ficar suspenso o processo até a regularização desta sucessão.

Por direito transmissível, devem ser entendidos todos os direitos patrimoniais passíveis de transferência causa mortis aos herdeiros ou

sucessores do de cujus.

A suspensão do processo por morte da parte ocorre, portanto, nas hipóteses em que o direito discutido no processo seja transmissível, ou seja, passível de ser transferido aos herdeiros ou sucessores da parte falecida.

A princípio, o processo deveria ficar suspenso até a habilitação destes herdeiros ou sucessores, mas, como o sistema processual atribui capacidade de ser parte também ao espólio, é admitida, da mesma forma, a suspensão do processo até a habilitação deste ente despersonalizado.

Em suma, com a morte da parte, o processo cujo objeto é um direito transmissível deve ficar suspenso até a habilitação dos herdeiros, dos sucessores ou do espólio.

A habilitação é um procedimento regulamentado entre os arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil, podendo ser requerida pela parte sobrevivente em relação ao espólio, aos herdeiros ou aos sucessores ou por estes em relação à parte contrária ao de cujus.

Por tratar-se de procedimento jurisdicional, a habilitação, por mais rapidamente que seja requerida, não depende, para que se finalize e se permita a sucessão processual, apenas da vontade da parte ou dos seus sucessores.

Até mesmo por este motivo, o Código não estabelece prazo predeterminado de suspensão nos casos de morte da parte, devendo o processo ficar suspenso até que seja concluído o procedimento de habilitação.

Entretanto, o § 2º, inc. I, do art. 313 dispõe que, falecido o réu, o autor deve promover a citação do espólio ou do sucessor no prazo designado pelo juiz, que deve ser de dois a seis meses.

Falecido o autor, o art. 313, § 2º, inc. II, impõe a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Realizada a habilitação, o processo volta a ter, em ambos os polos, sujeitos com capacidade de ser parte, portanto, a partir de então, deve cessar a suspensão do feito.

b) Suspensão por morte do representante da parte

Conforme demonstrado no item 10.3, “f”, supra, nas hipóteses em que a parte pessoa física seja incapaz, nos termos da lei civil, faz-se necessário, para fins de validade e regularidade do processo, que ela seja representada por seus pais ou, na falta destes, por um tutor ou curador, que devem atuar na qualidade de representante da parte.

O mesmo fenômeno da representação, para fins de regularidade da capacidade processual de estar em juízo, ocorre quando a parte for pessoa jurídica, hipótese em que deverá ser representada por seu diretor ou pessoa designada por lei ou em seu ato constitutivo.

A segunda hipótese descrita no art. 313, inc. I, do CPC ocorre quando o representante da parte, seja o pai, o tutor ou o curador da pessoa física incapaz, isto é, o representante da pessoa física, morre deixando a parte, até então representada, sem representação.

Considerando que capacidade processual constitui pressupostos processuais de validade, a ausência de representação da parte impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

No entanto, trata-se de uma irregularidade sanável pela parte, bastando a constituição de um novo representante, razão pela qual o processo não deve ser extinto sem resolução do mérito automaticamente.

Ante a impossibilidade de desenvolvimento, por um lado, e a impossibilidade de extinção automática, por outro, a solução do sistema

processual é a suspensão do procedimento até a regularização da “crise de representação”.

Em síntese, a razão de ser do dispositivo é, nestes casos, a necessidade de se interromper o desenvolvimento do procedimento até que a capacidade processual da parte seja restabelecida, com a constituição de um novo representante.

Assim, caso venham a falecer os pais do menor, deve-se suspender o processo até que seja constituído um tutor.

No caso de morte do tutor da parte por ele representada, da mesma forma, o processo deve ser suspenso até que outro seja constituído, devendo acontecer o mesmo nos casos de morte do curador.

Tal como na habilitação, a constituição do tutor ou do curador demanda procedimento jurisdicional especial, nos termos dos arts. 759 a 763 do CPC, que, por não depender exclusivamente da parte, não há um prazo mínimo ou máximo fixado pelo Código de Processo Civil para que o processo fique suspenso.

Nos casos de pessoa jurídica, a morte que afeta o desenvolvimento do processo e determina sua suspensão é a morte do seu representante, assim entendida a pessoa identificada na lei ou em seu ato constitutivo como tal.

Entretanto, caso a pessoa jurídica possua mais de um representante, a morte de um deles não acarreta a suspensão do processo.

Assim, por exemplo, a morte de um procurador do Estado não afeta nenhum processo em que o Estado seja parte, uma vez que todos os procuradores do Estado são considerados, por lei, seus representantes, o mesmo acontecendo nas situações em que a pessoa jurídica tenha mais de um diretor.

Assim, nos casos de morte do único representante da parte pessoa jurídica, o Código impõe a necessidade de o processo ficar suspenso até a constituição de um novo representante pelo refazimento do contrato social

ou do estatuto da pessoa jurídica.

c) Suspensão por morte do advogado da parte

Outra morte que afeta o prosseguimento do feito, determinando a suspensão do processo, é a morte do advogado de uma das partes, pois tal acontecimento retira desta a capacidade postulatória até então existente.

Nesses casos, a exemplo da morte do representante, a suspensão só ocorre se o advogado falecido for o único constituído pela parte nos autos do processo, pois, caso mais de um advogado a represente, a morte de um deles não lhe retira a capacidade postulatória.

Assim, se falecido o único advogado da parte, faz-se necessária a constituição de um novo patrono, determinando, o art. 313, inc. I, do CPC, que o processo fique suspenso sem, portanto, a contagem de prazos e sem a possibilidade da prática de atos processuais.

Ao contrário da substituição das partes e de seus representantes, a constituição de um novo advogado e consequente regularização da capacidade postulatória, depende única e exclusivamente da parte, bastando, para tanto, que esta leve nova procuração aos autos do processo apresentando o novo patrono.

Até por isso, nestes casos, o § 3º do art. 313 do CPC dispõe que a parte tem prazo de 15 dias para que constitua o novo advogado. Após o referido prazo, sem a constituição de novo mandatário, caso o advogado falecido e não substituído seja do autor, o processo será extinto sem resolução do mérito. Se o réu for a parte que passe, pela morte do advogado, a ficar sem capacidade postulatória, ao fim do prazo de 15 dias, o processo prosseguirá “à revelia” do réu.

Por revelia, neste contexto, deve ser entendida a impossibilidade de a parte praticar qualquer ato processual até que regularize sua situação no processo e constitua novo advogado.

d) Suspensão por perda da capacidade da parte, de seu representante legal ou de seu advogado

Tal como a morte, a perda da capacidade da parte, de seu representante ou de seu advogado também impacta no processo, impondo sua suspensão até a regularização da situação.

A parte que, maior e capaz, perca, por qualquer motivo, sua capacidade processual, passa, de imediato, a precisar de um representante no processo, mais precisamente, de um curador.

Assim, caso a parte venha a perder a capacidade por força de uma doença ou acidente, ficando em coma, senil ou, por qualquer outro motivo, incapaz de perceber a realidade ou de expressar sua vontade, o processo deve ser suspenso até a constituição de um curador que passará a atuar no processo como seu representante.

A constituição do curador deve se dar por via de um processo judicial, portanto o § 1º do art. 313 do CPC não fixa o prazo que deve durar a suspensão do processo.

Situação semelhante ocorre quando o representante da parte, do menor, do incapaz ou da pessoa jurídica, perde, no curso do processo, sua própria capacidade.

Assim, se os pais, o tutor, o curador, o diretor da pessoa jurídica ou qualquer outro representante desta for acometido por enfermidade ou fatalidade que retire dele a capacidade de manifestar sua vontade, o processo deverá ser suspenso até que um novo representante seja constituído.

Situação semelhante ocorrerá quando a perda da capacidade for do advogado da parte, o que, na prática, redundará em perda da capacidade postulatória.

Nesse caso, a única distinção é que, ao contrário do § 1º do art. 313 do CPC, que não estabelece prazo para a parte regularizar a representação, o §

3º do mesmo dispositivo dispõe que, em caso de perda da capacidade do advogado, a parte tem o prazo de 15 dias para nomear outro, constituindo-o nos autos do processo por meio de uma nova procuração.

Nos dois casos, a suspensão do processo só se impõe se o representante ou o advogado da parte que perder a capacidade for o único autorizado a, regularmente, atuar no processo, pois, caso existam outros representantes ou procuradores, o processo não deverá ser suspenso.

11.3.1.1 Dos efeitos da decretação da suspensão do processo por morte ou perda da capacidade das partes, de seus representantes ou seus procuradores

Conforme já demonstrado, a morte ou a perda da capacidade das partes, de seus representantes ou seus procuradores implica a automática perda da capacidade de ser parte, capacidade processual (de estar em juízo) ou capacidade postulatória, conforme o caso.

Entretanto, apesar de esta perda ser automática, obviamente, a suspensão, por depender de reconhecimento judicial expresse, não será imediatamente decretada no processo.

Assim, é natural que, entre o evento determinante para a suspensão, a morte ou a perda da capacidade, e o seu reconhecimento judicial nos autos do processo, decorra um tempo, sendo possível, inclusive, que alguns atos processuais venham a ser praticados nesse período.

Entretanto, estes atos processuais, independentemente do período que decorra entre o evento que gera a suspensão e seu reconhecimento judicial, não são válidos e precisarão ser refeitos.

Isso porque, apesar do “atraso” no reconhecimento judicial da necessidade de suspensão, o processo já deveria ter sido suspenso desde a data do evento, possuindo, a decisão que determina a suspensão, eficácia retroativa.

Em suma, apesar de ser indispensável para a efetiva suspensão do

processo o expresse reconhecimento judicial determinando-a, é certo que tal decisão retroage à data do evento, da morte ou da perda da capacidade, devendo, todos os atos praticados neste período, serem refeitos.

Para exemplificar, pode-se imaginar uma situação em que o advogado do réu tenha falecido no dia 3 de fevereiro sem que a parte tenha tido ciência do fato e, dada a inexistência dessa notícia nos autos do processo, não tenha sido determinada a suspensão.

Por ausência de pronunciamento judicial reconhecendo a morte do advogado, e a consequente necessidade de suspensão do processo, este prosseguiu e teve proferida uma decisão judicial prejudicial ao réu, que foi intimado para cumpri-la, dando-se início à contagem do prazo para recursos. Como o advogado do réu, a quem são naturalmente dirigidas as intimações, havia falecido, de rigor, ninguém teve ciência da decisão, cujo prazo para recursos foi “perdido” pelo réu.

Apenas após decorrido o prazo do recurso contra a referida decisão, foi dada ao juiz a notícia de que o advogado da parte faleceu meses antes da intimação e, em razão deste fato, o magistrado suspendeu o processo e concedeu o prazo de 15 dias para que o réu constituísse novo advogado, nos termos do art. 313, § 3º, do CPC.

Considerando que tal decisão, que decreta a suspensão do processo, tem eficácia retroativa, a intimação e a “perda do prazo” para o recurso não possuem efeitos, dado que o processo se considera suspenso desde a data do evento, no exemplo, 3 de fevereiro.

Assim, constituído novo advogado no prazo de 15 dias, a intimação deverá ser refeita e o prazo para recorrer da decisão, reaberto.

11.3.2 Demais hipóteses de suspensão do processo

Além das situações em que se configuram vícios relacionados aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente, à tríplice capacidade das partes, o art. 313 do Código de

Processo Civil prevê outros casos de suspensão do processo.

Não há um critério uniforme ou uma razão comum a todas as hipóteses de suspensão do processo, pois estas variam desde a simples possibilidade de suspensão por comum acordo entre as partes a fenômenos absolutamente externos ao ambiente processual, como calamidades públicas e greves dos servidores do Poder Judiciário.

As referidas hipóteses de suspensão do processo são: a) pela convenção das partes; b) pela arguição de impedimento ou de suspeição; c) pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; d) por prejudicialidade; e) por motivo de força maior e; f) por parto, adoção ou paternidade do único advogado da causa.

Os subitens a seguir se ocuparão de cada uma delas.

a) Suspensão por convenção das partes

O Código de Processo Civil, em seu art. 313, inc. II, autoriza a suspensão do processo por convenção das partes.

A hipótese envolve, portanto, uma possibilidade de negócio processual entre as partes, quando ambas entram em consenso sobre a desnecessidade de prosseguimento do feito.

Via de regra, essa hipótese tem lugar quando as partes vislumbram a possibilidade de celebrarem um acordo e encerrarem o litígio, sendo possivelmente desnecessário o prosseguimento do processo rumo a um julgamento de mérito.

Nesse caso, ambas as partes devem, por meio de seus representantes, revelar ao juiz a intenção de suspenderem o processo, o que, a partir do deferimento, pelo juiz, implica a impossibilidade de andamento do feito e da prática de atos processuais, pelo juízo e pelas partes, durante o período de suspensão acordado.

O § 4º do art. 313 do Código, entretanto, proíbe que esta suspensão por

acordo entre as partes exceda o período de seis meses.

Assim, findo o prazo de seis meses, o juiz, no uso de seu poder ordinatório, deve determinar, de ofício, o prosseguimento do processo, conforme expressamente dispõe o art. 313, § 4º, do CPC.

Obviamente, se neste período as partes celebrarem transação resolvendo o litígio por acordo de vontades, o processo será extinto com resolução do mérito, por sentença, nos termos do art. 486, inc. III, do Código de Processo Civil.

b) Suspensão por arguição de impedimento ou suspeição

O inc. III do art. 313 do CPC estabelece a hipótese de suspensão do processo quando arguida a suspeição ou o impedimento do juiz.

Tal arguição, nos termos do art. 146 do Código, é manejável pela parte quando esta entender que o juiz não é imparcial por ser suspeito ou impedido.

Tanto a suspeição quanto o impedimento comprometem a imparcialidade do juiz, que, conforme asseverado no item 10.3, "b", supra, é pressuposto processual de validade e, nesse sentido, tem de estar regular, sob pena de impedir o desenvolvimento válido e regular do processo e de tornar nulas as decisões proferidas por juiz suspeito ou impedido.

Por via de consequência, cabe ao próprio juiz suspeito ou impedido afastar-se do feito e encaminhar o processo ao seu substituto legal e, caso não o faça, a parte interessada possui o direito de arguir este vício, nos termos do art. 146 do CPC.

Enquanto se estiver questionando a imparcialidade do juiz, não há sentido no prosseguimento do processo, uma vez que este pode, posteriormente, ser declarado impedido, suspeito e, portanto, incapaz de processar e julgar o feito.

Assim, apresentada a arguição de suspeição ou impedimento por uma

das partes, nos termos do art. 146 do Código, o procedimento voltado ao julgamento de mérito ficará paralisado até o julgamento da questão.

De rigor, não se trata de suspensão total e completa do processo, uma vez que as partes e o órgão jurisdicional competente para julgar a arguição praticarão atos processuais voltados à instrução e ao julgamento deste incidente.

Na hipótese, como o questionamento a respeito da parcialidade recai sobre a pessoa do juiz, obviamente não cabe a este processar e julgar a arguição, cabendo ao tribunal ao qual ele esteja vinculado, conduzir o procedimento e proferir o julgamento sobre a parcialidade ou imparcialidade do juiz questionado.

Portanto, apresentada a arguição de suspeição ou impedimento, o juiz apontado como suspeito ou impedido deve suspender o processo, abstendo-se de praticar atos processuais e remetendo os autos para o tribunal ao qual é vinculado para o processamento e o julgamento desta questão, cujas peculiaridades procedimentais escapam ao objeto deste item.

Pode o juiz, todavia, uma vez apresentada a arguição de suspeição ou impedimento, afastar-se do processo encaminhando os autos, desde já, ao seu substituto legal, hipótese em que, de rigor, o processo não ficará suspenso, dado que prosseguirá perante o substituto legal do juiz suspeito ou impedido.

c) Suspensão pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas

O art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que se suspende o processo “pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas”.

O incidente de resolução de demandas repetitivas, disciplinado pelos arts. 976 a 987 do CPC, tem lugar quando houver multiplicidades de processos idênticos, ou seja, quando detectados casos múltiplos, assim

entendidos aqueles que envolvem um grande grupo de interessados na solução de uma mesma questão de direito, geradora, por este motivo, de inúmeras demandas individuais com o mesmo fundamento jurídico.

É o caso, por exemplo, de vários processos em que inúmeros contribuintes questionem o percentual de determinado imposto, ou diversos consumidores de serviços de telefonia discutam a legalidade da cobrança de determinada tarifa, ou um grupo de servidores públicos, integrantes da mesma categoria, questionem, pelo mesmo fundamento jurídico, determinado reajuste salarial.

Tais questões atingem individualmente um grande grupo de jurisdicionados (contribuintes de determinado tributo, consumidores de certos serviços, aposentados) e, em caso de conflito ou ambiguidades na interpretação e na aplicação do direito, proporcionam enorme quantidade de ações propostas com pedido e causa de pedir semelhantes.

Muitas vezes, inclusive, é comum que as diversas demandas sejam propostas contra um mesmo sujeito, em especial, entes públicos (União, autarquias, empresas públicas, fazendas estaduais e municipais) ou empresas privadas prestadoras de serviços públicos, representando um motivo a mais para o tratamento coletivo, uma vez que, nessas hipóteses, além da demanda representada na petição inicial, também as respostas do réu, notadamente, a contestação, tendem a ser padronizadas, o que justifica um procedimento mais simples, se comparado com o procedimento de uma demanda inédita ou única, e, mais do que isso, um conteúdo da decisão equivalente.

Para que se dê tratamento justo, racional e uniforme a essas questões jurisdicionalizadas em massa, o incidente de resolução de demandas repetitivas volta-se a, em um primeiro momento, “centralizar” a resolução da questão jurídica repetitiva para, na sequência, aplicar esta decisão concentrada aos demais processos que envolvam a mesma questão jurídica.

Assim, quando várias demandas tiverem identidade em relação ao pedido ou a causa de pedir, com múltiplos processos discutindo a interpretação ou a constitucionalidade de uma mesma lei, tem lugar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

O incidente de resolução de demandas repetitivas é caracterizado, em apertada síntese: a) pela seleção de um processo paradigma, representativo da controvérsia, para julgamento concentrado da questão jurídica repetitiva; b) pela suspensão dos demais processos que envolvam a mesma questão jurídica; e c) pelo julgamento do processo paradigma e, a partir de então, aplicação do precedente consagrado nos demais processos, até então suspensos.

A razão de ser da suspensão de processos que envolvam a mesma questão jurídica é evitar o andamento do feito e o proferimento de decisão sobre um tema cuja solução está a cargo do órgão competente para processar e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Esta suspensão deverá ser determinada pelo relator do incidente que, nos termos do art. 982, inc. I, do Código, suspenderá os processos pendentes que tramitem no Estado ou na região.

Tal suspensão deverá durar até o julgamento do incidente, dado que, uma vez decidida a questão na sede concentrada, o entendimento firmado no julgamento de casos repetitivos deve ser aplicado em todos os processos que veiculem questão idêntica e estavam, até então, sobrestados.

Nesse sentido, dispõe o art. 985, determinando que: "julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986."

d) Suspensão por existência de questão prejudicial

A hipótese prevista no art. 313, inc. V, do Código de Processo Civil envolve a possibilidade de suspensão do processo por força da prejudicialidade.

Por prejudicialidade deve ser entendida a possibilidade de um julgamento do mérito de um processo ser capaz de influenciar e até de tornar inútil ou desnecessário o julgamento de mérito em outro processo.

Dois exemplos, a seguir, talvez esclareçam o conceito de prejudicialidade.

O primeiro deles é o caso em que se discute, em determinado processo, o dever de um sujeito, apontado como pai de uma criança, pagar alimentos a esta, quando ocorre, em outro processo, uma discussão acerca da própria relação de paternidade.

Nesse contexto, obviamente, a ação declaratória de paternidade possui o condão de prejudicar, isto é, influenciar e até tornar totalmente improcedente a ação de cobrança de prestações alimentícias, nos casos de não reconhecimento da paternidade.

Da mesma forma, um processo em que se discute a cobrança de prestações previstas em um contrato pode ser diretamente influenciado pelo julgamento de mérito de outro processo em que se discuta a validade do referido contrato.

Nessas duas hipóteses, dada a relação de prejudicialidade entre as ações de cobrança (de alimentos ou de prestações contratuais) em relação às ações declaratórias de paternidade e de validade do contrato, o art. 313, inc. V, do CPC determina a suspensão das ações de cobrança até que as ações prejudiciais, isto é, as declaratórias, sejam julgadas.

Assim, apenas depois do julgamento das ações prejudiciais – nos exemplos acima, as ações declaratórias de paternidade e a ação em que se discute a validade do contrato – o processo suspenso voltará a se

desenvolver. Isso se, obviamente, o julgamento das referidas ações prejudiciais, não prejudicarem o julgamento do feito.

Em suma, havendo a possibilidade de o julgamento de mérito em um processo prejudicar, tornar inútil ou desnecessário o julgamento de mérito de outra ação, o processo ameaçado deve ficar suspenso até o julgamento da ação fundamental para seu desfecho.

Voltando aos exemplos dados, pode-se afirmar que: a ação de cobrança das prestações fica suspensa até o julgamento da ação que analisa a validade ou a nulidade de todo o contrato, voltando o primeiro a correr caso naquela sede reste declarado válido o contrato, pois, se declarado inválido, a ação de cobrança ficará prejudicada, devendo ser extinta e julgada improcedente, por sentença.

O mesmo vale para a ação de alimentos, que deverá ser paralisada enquanto não julgada a ação declaratória de paternidade, voltando o processo de cobrança de alimentos a se desenvolver caso na ação declaratória seja reconhecido o vínculo entre o sujeito e a criança. Entretanto, se, na ação declaratória, a paternidade for reconhecida como inexistente, deverá ser extinta a ação de alimentos, por força da prejudicialidade.

Por fim, cumpre ressaltar que o § 4º do art. 313 do Código estabelece que a suspensão do processo por prejudicialidade não poderá exceder o prazo de um ano, findo o qual o juiz deverá determinar o seu prosseguimento, sendo, portanto, este prazo de um ano o período ideal para que a causa prejudicial seja julgada.

A prejudicialidade também é a razão de ser da suspensão do processo, por força do art. 313, inc. VII, do Código de Processo Civil, que determina o sobrestamento do feito quando “se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo”.

A peculiaridade digna de destaque da hipótese é que a questão de fato

prejudicial está sob a jurisdição do tribunal marítimo, e não de outro órgão integrante do Poder Judiciário.

e) Suspensão do processo “por motivo de força maior”

A doutrina clássica conceitua força maior como o evento “que torna impossível a prática de atos processuais impedindo o funcionamento normal dos tribunais”⁴²³.

Na lição de Pontes de Miranda⁴²⁴, trata-se de “circunstâncias invencíveis por todos os interessados e por todos os que tiverem de praticar os atos processuais”.

Assim, quando determinados eventos capazes de impedir a prática de atos processuais, bem como o funcionamento normal do fórum, decorrerem em determinada localidade, o processo deve ser suspenso.

São hipóteses de fenômenos classificáveis como motivo de força maior que autorizam a suspensão do processo, catástrofes naturais, como enchentes e inundações que atinjam determinada cidade ou região e a greve dos servidores do Judiciário.

Em tais situações, via de regra, a suspensão do processo é decretada pelo presidente do tribunal, uma vez que o motivo de força maior não atinge apenas um processo individualmente considerado, mas todo o conjunto de processos que tramitam em determinada cidade ou determinado foro.

Assim, quando verificado o motivo de força maior determinante para a suspensão do processo, a presidência do tribunal deve editar um ato geral e abstrato regulamentando a suspensão e, se for o caso, o seu prazo final, sendo importante que, em cada processo, este ato seja juntado para fins de documentação e futura prova inequívoca de que o processo esteve suspenso durante o período.

Obviamente, se quando da edição do ato da presidência não for possível

ter certeza do dia da volta à normalidade e, portanto, da duração da suspensão, esta fará referência apenas ao início da suspensão, sendo necessário outro ato geral e abstrato da lavra do mesmo órgão determinando o fim da suspensão.

f) Suspensão nos demais casos que o Código regula

Por fim, o art. 313, em seu inc. VIII, estabelece que a suspensão do processo poderá ocorrer em outras hipóteses previstas no Código de Processo Civil, às quais podem ser acrescentadas quaisquer outras hipóteses estabelecidas em lei.

Um bom exemplo que, aliás, se aproxima da suspensão determinada pelo art. 313, inc. IV, do Código, que a determina quando admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, encontra-se no art. 1.036, § 1º, do CPC, cuja compreensão pressupõe também a leitura do caput.

Determina o art. 1.036 do Código de Processo Civil que, “sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça”.

Já o § 1º do dispositivo, por sua vez, reza que “o presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso”.

O julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos tem a mesma razão de ser do incidente de resolução de demandas repetitivas, qual seja, multiplicidade de processos que envolvem a mesma questão.

A diferença é que, enquanto o incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR é processado e julgado pelos tribunais de segundo grau de jurisdição, os recursos especial e extraordinário repetitivos são julgados pelos tribunais superiores, STJ e STF, respectivamente.

Contudo, salvo a distinção no que diz respeito à instância competente para processar e julgar, tanto o IRDR quanto os recursos especial e extraordinário repetitivos possuem a mesma finalidade e a mesma dinâmica, quais sejam: a) seleção de um processo paradigma, representativo da controvérsia, para solução da questão múltipla; b) suspensão dos processos idênticos, que envolvam a mesma questão jurídica; e c) aplicação do precedente consagrado nos demais processos, até então sobrestados.

Por essa razão, tal como a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas leva à suspensão dos processos que envolvam a mesma questão de direito, a admissão de um recurso especial ou extraordinário pelo regime de julgamento de recursos repetitivos impõe a suspensão dos demais processos que versem sobre a questão afetada, nos termos do art. 313, inc. VIII, c/c art. 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil.

g) Suspensão por parto ou adoção pela advogada ou paternidade do advogado

A Lei n. 13.363, de 25 de novembro de 2016, acrescentou outras duas hipóteses de suspensão do processo, ambas relacionadas ao fato de o único advogado constituído nos autos do processo tornar-se mãe ou pai, quer biológico, quer por força da adoção.

Nesse contexto, o inciso IX do art. 313 do CPC dispõe que se suspende o processo pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa.

O referido dispositivo é complementado pelo § 6º do art. 313 do Código,

também incluído pela Lei n. 13.363/2016, que estabelece que o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

A suspensão estabelecida no art. 313, IX do Código só tem lugar quando a advogada que se tornar mãe for a única constituída nos autos do processo, sendo assim inaplicável nas causas onde a parte constituir dois ou mais advogados nos autos.

Já o inciso X, também do art. 313 do CPC estabelece a suspensão do processo quando “o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai”.

Nesse caso, nos termos do § 7º do art. 313 do Código, o período de suspensão é de 8 (oito) dias, contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

É importante destacar que também nesta situação a suspensão do processo só ocorre caso o advogado que se tornar pai seja o único constituído pela parte nos autos do processo.

11.4 Extinção do processo

Se é possível ter uma certeza sobre algo que, inevitavelmente, ocorrerá em todo e qualquer processo, é que ele será extinto.

Em outras palavras, por mais que a relação processual e o mérito do processo possam variar e, em razão disso, o procedimento poder tomar os mais diversos rumos e desdobramentos, a extinção é o idêntico destino reservado a todas as relações processuais. Trata-se de uma certeza assim como a morte o é para todos os seres vivos.

Os arts. 485 e 487 do Código de Processo Civil elencam as razões que levam à extinção do processo.

Entre os dois elencos de hipóteses, existe uma grande diferença: enquanto o art. 485 do CPC estabelece as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, o art. 487 do Código estabelece as hipóteses de extinção com resolução do mérito.

Conforme já asseverado, o mérito do processo é o bem jurídico objeto do litígio, isto é, o bem ou o direito identificado pelo autor em seu pedido e sobre o qual o réu exerce sua resistência, sendo sua resolução a grande razão de ser do processo.

Assim, obviamente, é natural que o processo nasça e se desenvolva rumo a um julgamento de mérito não fazendo sentido, a priori, um processo se desenvolver para que tenha um fim diferente, sem que o juiz sequer se manifeste sobre o pedido do autor.

Entretanto, considerando que determinados requisitos e condições devem ser observados e preenchidos antes do julgamento do mérito, caso o processo não os preencha, o juiz deve extingui-lo sem julgar o mérito, até porque, nestas hipóteses, se o magistrado o julgasse, este julgamento estaria contaminado pela irregularidade decorrente da ausência dos requisitos elementares para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Tais requisitos de admissibilidade de julgamento de mérito são exatamente as condições da ação e os pressupostos processuais, categorias já estudadas em capítulos anteriores, notadamente os Capítulos 8 e 10 desta Introdução.

Desde aquele momento, restou dito que, não preenchidas as condições da ação ou não atendidos os pressupostos processuais, fica impedida a análise do mérito e que, em sendo insanável o vício, o processo deverá ser extinto sem a análise do mérito.

Por estas razões e seguindo este raciocínio, o art. 485 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, em dez incisos, arrolando, uma a uma, as condições da ação e os pressupostos processuais.

Apenas se vencidas estas exigências, poderá o juiz, legitimamente, julgar o mérito.

As hipóteses de extinção do processo com resolução do mérito, por sua vez, são arroladas no art. 487 do Código de Processo Civil e serão, a seguir, analisadas.

De antemão, deve ser destacado que nem todas as hipóteses de resolução do mérito encerram exatamente o julgamento, assim entendido a decisão judicial sobre a procedência ou a improcedência do pedido.

Isso porque também é categorizado pelo sistema processual como hipóteses de extinção do processo com resolução do mérito a homologação, pelo juiz, de manifestações de vontade das partes que levam à solução da lide.

Fato é que, uma vez provocado o Poder Judiciário, pelo autor, e iniciado um processo, este deverá ser extinto pelo juiz por meio de uma sentença, ato pelo qual o magistrado decreta a extinção com ou sem resolução do mérito, neste último caso, sempre que verificada a ausência de uma das condições da ação ou irregularidades ligadas aos pressupostos processuais, arroladas no art. 485 do Código.

Desde já, é importante que seja feita uma distinção entre os efeitos decorrentes da extinção do processo com ou sem resolução do mérito no que se refere: a) classificação da coisa julgada; b) classificação da sentença; e, principalmente, c) possibilidade de repositura da mesma ação.

A extinção do processo sem resolução do mérito se dá por sentença terminativa e, uma vez esgotados os recursos, forma coisa julgada

meramente formal que, conforme asseverado no item 10.4, “b”, do capítulo anterior, não impede a repropositura da ação.

Já a extinção do processo com resolução do mérito é expressa por meio de uma sentença definitiva e gera coisa julgada material, pressuposto processual negativo que impede e repropositura da mesma ação já julgada.

Tal conclusão decorre da regra constitucional constante no art. 5º, inc. XVI, da Constituição Federal, estudada no Capítulo 6, item 6.1.4.13, que, em síntese, significa que uma vez proposta a ação e sendo o processo extinto com resolução do mérito, forma-se a coisa julgada material, o que impede, por força da definitividade da jurisdição, a repropositura da mesma ação.

Em outras palavras, uma única sentença que extinga o processo com resolução do mérito é suficiente para formar a coisa julgada material e impedir a reabertura da discussão sobre aquele litígio.

Contudo, exatamente por não adentrarem no mérito, as sentenças proferidas com base no art. 485 do CPC, não formam coisa julgada material e não impedem a repropositura da ação.

Isso porque a definitividade típica da coisa julgada material pressupõe um pronunciamento de mérito, isto é, uma sentença em que o juiz de fato resolva e se pronuncie sobre o pedido.

Assim, se qualquer causa prevista no art. 485 do Código impedir esta análise de mérito, o processo deve ser extinto sem este pronunciamento, sendo certo que, uma vez corrigido o vício, a mesma ação que ainda não teve o seu mérito julgado, poderá ser reproposta⁴²⁵.

Até pela admissibilidade desta repropositura, o Código de Processo Civil estabelece que, sempre que for possível superar o vício que impede o exame do mérito, por meio da correção da irregularidade, de modo a tornar o processo apto a ter o mérito julgado, o juiz deve fazê-lo, evitando a extinção por sentença terminativa.

Nesse contexto, tem lugar o princípio da preferência pela resolução do mérito tratado no item 6.2.4 do Capítulo 6, que, em síntese, deve ser entendido como a necessidade de se buscar sempre que possível a extinção do processo com um pronunciamento definitivo sobre o litígio.

Nas palavras de Fredie Didier Jr.⁴²⁶, o princípio da primazia do exame do mérito implica dizer que “o órgão julgador deve priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra”.

Por via de consequência, sempre que o vício que impeça o julgamento de mérito for sanável, ou seja, corrigível, deve ser realizada sua correção de modo a viabilizar o exame do mérito.

Nesse sentido, lapidar a letra do art. 317 do CPC, que estabelece que “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

Ademais, exatamente pela possibilidade de repropositura da ação em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, o art. 488 do Código de Processo Civil dispõe que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Em outras palavras, a preferência do sistema processual é claramente pelo pronunciamento de mérito, uma vez que esta espécie de provimento resolve o litígio de maneira definitiva, impedindo a rediscussão e a repropositura da mesma ação em outro processo.

Feitas essas observações introdutórias, resta conhecer as hipóteses em que o Código impõe a extinção do processo com e sem resolução do mérito.

O objetivo dos subitens a seguir é estudar cada uma das hipóteses de extinção do processo, já o ato do juiz que determina esta extinção, a sentença, será estudo no capítulo seguinte no item dedicado a tipologia e estrutura dos pronunciamentos judiciais.

11.4.1 Extinção do processo sem resolução do mérito

Uma vez compreendidas as condições da ação e os pressupostos processuais de validade e negativos, fica extremamente simples a compreensão das causas que levam à extinção do processo sem resolução do mérito.

Isso porque, de rigor, o rol constante do art. 485 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o tema, arrola situações nas quais o processo deve ser extinto por falta de condições da ação, por caracterização de vícios relacionados aos pressupostos processuais negativos, por caracterização de vícios ligados aos pressupostos de validade insanáveis ou mesmo sanáveis, porém não efetivamente sanados pela parte interessada da forma e no prazo estabelecido pelo juiz.

Por serem vícios graves, que contaminariam um eventual julgamento de mérito, as matérias arroladas no art. 485 do CPC podem ser verificadas e decretadas de ofício pelo juiz, isto é, independentemente de provocação da parte interessada, em quaisquer tempo e grau de jurisdição.

A única exceção à possibilidade de reconhecimento de ofício está ligada à hipótese de extinção por convenção de arbitragem prevista no art. 485, inc. VII, do Código que, por força do disposto no art. 337, § 5º, só pode, quando existente, levar à extinção do processo sem resolução do mérito se alegado pelo réu em preliminar de contestação⁴²⁷.

Todas as demais hipóteses, portanto, podem ser reconhecidas de ofício, em quaisquer tempo e grau de jurisdição, por serem matérias de ordem pública.

A par disso, o art. 485, inc. VIII, do Código prevê uma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por vontade do autor, que expressa sua desistência, sendo certo que tal desistência deverá ser homologada pelo juiz e, conforme se demonstrará mais detalhadamente adiante, depende da concordância do réu para que surta os efeitos desejados.

a) Indeferimento da petição inicial

A primeira hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, prevista no art. 485, inc. I, do CPC, diz respeito ao indeferimento da petição inicial.

A petição inicial, regulada nos art. 319 e 320 do Código de Processo Civil, é a peça inaugural de todo e qualquer processo, sem a qual este não se inicia.

Trata-se, a um só tempo, do veículo da ação e do primeiro ato do procedimento, devendo, nos termos dos dispositivos citados, ser apresentada, por escrito, contendo todos os requisitos exigidos em lei.

Conforme já asseverado no item 10.3, “c”, a aptidão da petição inicial é um pressuposto processual de validade sem o qual o processo não pode se constituir e se desenvolver válida e regularmente.

Desta feita, não se trata de uma opção do autor preencher ou não os requisitos da petição inicial, sendo uma imposição legal o preenchimento de todos os requisitos sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Tais requisitos fazem todo o sentido se pensada a petição inicial como o veículo da ação e o primeiro ato do procedimento.

Como veículo da ação, cabe à petição inicial identificar todos os seus elementos, partes (ativa e passiva), causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato)⁴²⁸.

Nesse sentido, dispõem os incs. II, III e IV do art. 319, que exigem a identificação: a) das partes, isto é, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; b) da causa de pedir, ou seja, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido; e c) do pedido com as suas especificações.

Entretanto, o desconhecimento de algum dado exigido pelo art. 319, inc. II, do Código não deve necessariamente inviabilizar o exercício do direito de ação.

Assim, a ausência de um dos dados legalmente exigidos, desde que justificada pelo autor, deve ser tolerada pelo juiz sempre que possível a individualização da parte passiva e viável o desenvolvimento da relação processual, não obstante a falta de determinada informação legalmente exigida⁴²⁹.

A exteriorização da causa de pedir, na letra do art. 319, inc. III, os fundamentos e fatos de direito do pedido, também devem se dar na petição inicial.

O terceiro elemento da ação, que deve estar estabelecido clara e precisamente na petição inicial, é o pedido. Tal identificação deve se dar tanto em relação ao pedido mediato, ou seja, qual bem jurídico é pretendido, quanto imediato, assim entendida a espécie de tutela jurisdicional requerida pelo autor⁴³⁰.

A par de identificar os elementos da ação, o art. 319 do CPC exige que a petição inicial contenha outros elementos ligados aos pressupostos processuais de validade, como o apontamento do juízo ou tribunal a que a ação é dirigida, conforme o inciso I.

Nesse passo, deverá o autor observar as regras de repartição de competência⁴³¹, uma vez que a ação só poderá ser processada e julgada pelo órgão jurisdicional dotado de poder para apreciar a causa.

Ademais, determina o art. 319 do Código que a petição inicial deverá indicar: a) o valor da causa (inc. V); b) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inc. VI); c) a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (inc. VII).

Em complemento, o art. 320 do CPC exige que a petição inicial venha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, entre

os quais pode ser exemplificada a procuração judicial que constitua o advogado do autor, fundamental para fins de regularização da capacidade postulatória do autor.

Ausente um dos requisitos da petição inicial, configura-se sua inépcia e, por se estar diante de um pressuposto processual de validade, resta vedado o desenvolvimento do processo enquanto presente o vício da petição inicial.

Entretanto, esta inépcia não deve levar imediatamente à extinção do processo. Isso porque a extinção sem resolução do mérito é um ato extremo que, a um só tempo, não resolve o litígio e torna toda a atividade processual praticamente inútil.

Por essa razão, o art. 321 do CPC determina que, antes de indeferir a petição inicial, o juiz deve dar uma chance ao autor para que este corrija o vício, emendando a petição inicial, obviamente, sempre que este vício seja passível de correção.

Contudo, quando detectados, desde logo, vícios insanáveis, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código, se impõe de plano.

É o caso, por exemplo da verificação da ausência de uma das condições da ação (interesse e legitimidade ativa) ou de um dos pressupostos processuais negativos, litispendência, coisa julgada ou perempção, de ofício, pelo próprio juiz.

Ademais, é possível que a petição inicial seja indeferida com resolução do mérito como quando, por exemplo, detectada a prescrição ou a decadência ou, ainda, quando for aplicável o art. 332 do Código, sendo certo que, nessas hipóteses, por haver rejeição do pedido e julgamento de mérito, não se estará diante do indeferimento previsto no art. 485, inc. I, e sim diante de uma das hipóteses arroladas no art. 487 do CPC, notadamente em seus incs. I e II, a serem analisados adiante⁴³².

b) Extinção por negligência das partes

O inc. II do art. 485 do Código dispõe que o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito sempre que este “ficar parado por mais de um ano por negligência das partes”.

Trata-se de um desdobramento do fato de o processo ou, mais amplamente, a atividade jurisdicional, não estar à disposição das partes a ponto de estas poderem determinar seu andamento ou sua duração.

É preciso se ter em mente que o andamento do processo é ditado pelo juiz, que, para isso, conta com os seus auxiliares, não devendo ser todo o tempo em que o processo ficar “parado”, necessariamente, atribuído às partes.

De rigor, aliás, a regra é que o tempo em que o processo fica parado seja atribuído ao Poder Judiciário.

Isso porque integra nosso sistema o princípio do impulso oficial, que estabelece caber ao juiz promover o andamento do feito de ofício⁴³³.

Portanto, sempre que o ato subsequente a ser praticado no procedimento seja uma atribuição do juiz ou de seus auxiliares, o processo nunca poderá ser extinto sem resolução do mérito por estar “parado”.

O disposto no art. 485, inc. II, do CPC, portanto aplica-se quando este não andamento se der por negligência das partes.

Assim, por exemplo, findo o prazo de suspensão do processo estabelecido na convenção das partes a que faz referência o art. 313, inc. II do CPC e cujo período máximo é de seis meses dos termos do § 4º do mesmo dispositivo⁴³⁴, caso as partes, intimadas a dar prosseguimento ao feito, permaneçam inertes, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito, por negligência.

Considerando tratar-se de hipótese excepcional na qual o processo não atinge seu objetivo primordial, o § 1º do art. 485 do Código exige que, antes de decretada a extinção do processo, as partes sejam pessoalmente intimadas para, em cinco dias, suprirem a falta.

A referida intimação, ao contrário da regra geral, não deve ser feita na pessoa do advogado das partes, mas sim pessoalmente, ou seja, deverá ser dirigida à própria parte.

A razão de ser desta exceção é exatamente a possibilidade de a inércia ser causada pelo advogado da parte, sem que esta tenha ciência do fato.

Assim, a extinção do processo com base no art. 485, inc. II, do CPC só pode ocorrer quando caracterizada a negligência de ambas as partes que, intimadas pessoalmente, não supram o vício em cinco dias.

c) Extinção por abandono do autor

Situação semelhante à do art. 485, inc. II, anteriormente comentado, ocorre na hipótese do inciso III, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

No fundo, trata-se de uma hipótese específica de negligência, praticada unilateralmente pelo autor quando, por trinta dias, não realiza os atos ou diligências que deveria.

Assim, são exemplos de posturas do autor que podem levar à extinção do processo por abandono, com base no art. 485, inc. III, do CPC, a omissão do autor em regularizar a representação processual, o não recolhimento ou a não complementação das custas de ajuizamento⁴³⁵, e a não promoção da citação do litisconsorte necessário⁴³⁶.

Tal como a extinção por negligência das partes, a hipótese de extinção por abandono é igualmente excepcional, uma vez que a regra geral é o impulso oficial, que se traduz no dever de o juiz, de ofício, no uso do poder ordinatório, uma vez provocado, determinar o desenvolvimento do processo rumo à solução da lide.

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco⁴³⁷ aduz que, “em um sistema no qual o impulso oficial é a regra ordinária (art. 2º), sendo extraordinárias

as exigências de impulso pelas partes, o conceito de abandono da causa é regido pela extraordinariedade e só se caracteriza quando forem omitidos atos rigorosamente indispensáveis ao prosseguimento do processo”.

Ademais, a extinção, com base no art. 485, inc. III, do Código, só pode ser aplicada pelo juiz após a intimação pessoal do autor.

Dessa forma, o juiz não pode extinguir o processo sem resolução do mérito antes de dar a oportunidade para que o autor pratique o ato ou realize a diligência necessária ao andamento do feito.

Por óbvio, caso o autor realize tudo que estiver ao seu alcance para que o ato seja praticado ou a diligência seja realizada, não estará caracterizado o abandono e, portanto, será inaplicável o dispositivo.

d) Extinção por ausência de pressupostos processuais de validade

O art. 485, inc. IV, do CPC determina a extinção do processo sem resolução do mérito sempre que não preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Tais pressupostos, que foram estudados e sistematizados no Capítulo 10, são: a) petição inicial apta, esta já expressamente prevista como causa de extinção no inc. I; b) a citação válida; c) a competência absoluta do juízo; d) a imparcialidade do juiz; e) a capacidade de ser parte; f) a regularidade de representação; e g) a capacidade postulatória.

De antemão, dois pontos que merecem destaque são: 1) nem todos os pressupostos processuais determinam a extinção do processo sem resolução do mérito; e 2) sempre que for possível a correção do vício, a preferência deve ser dada à retificação e, apenas em último caso, à aplicação do art. 485, inc. IV, do Código com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Há hipóteses de vícios ligados ao desenvolvimento válido e regular do processo que **nunca** levam à extinção sem resolução do mérito. São elas:

a) a irregularidade na citação; b) a incompetência do juízo; c) a imparcialidade do juiz; d) a irregularidade de representação ou de capacidade postulatória do réu.

Isso porque, ainda que verificada a irregularidade da citação, o processo não deverá ser extinto, mas, no máximo, ter anulados os atos processuais a partir da citação nula, reabrindo-se o prazo para a defesa.

Da mesma forma, não implicam sua extinção sem resolução do mérito, a configuração de incompetência absoluta e a parcialidade do juiz suspeito ou impedido, pois, nessas hipóteses, impõem-se a anulação dos atos praticados pelo juiz incompetente, suspeito ou impedido, e a remessa para o juízo competente e imparcial, mas nunca a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, os vícios relacionados à capacidade postulatória e à regularidade na representação do réu não levam à extinção do processo.

Isso porque, ainda que tais requisitos não estejam preenchidos pelo sujeito passivo, o processo deve prosseguir à sua revelia, e não ser extinto, o que, aliás, poderia beneficiar o réu irregularmente representado.

Portanto, os vícios relacionados aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo que implicam a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, são: a) a irregularidade de representação e de capacidade postulatória do autor; b) a não habilitação do espólio, dos herdeiros ou dos sucessores da parte autora falecida; e c) a inépcia da petição inicial, já aludida no inc. I do art. 485 do Código.

Ainda assim, tal como na hipótese de indeferimento da inicial, antes de o processo ser extinto sem resolução do mérito, ao autor deve ser dada a oportunidade de corrigir o vício, regularizando sua representação ou capacidade postulatória.

Para tanto, deverá o autor ser intimado para, em quinze dias, regularizar

a representação ou constituir novo advogado.

Apenas se o autor se omitir neste período o processo deverá ser extinto, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Já em caso de morte da parte, o prazo para a habilitação do espólio, dos herdeiros ou dos sucessores deverá ser fixado pelo juiz, sendo certo que, findo este prazo sem a sucessão de partes, o processo deverá ser extinto com fundamento no art. 485, inc. IV, c/c o art. 313, § 2º, inc. II, do Código de Processo Civil.

e) Extinção por existência de litispendência, coisa julgada ou perempção

O art. 485, inc. V, do CPC traz outras três hipóteses de extinção do processo ligadas aos pressupostos processuais estudados item 10.4 do capítulo anterior, mais especificamente, os pressupostos processuais negativos.

O dispositivo determina que o processo seja extinto sem resolução do mérito quando caracterizada perempção, litispendência ou coisa julgada.

Há litispendência, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, quando se repete ação que está em curso e, coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil).

A perempção, por sua vez, forma-se quando o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, o que o impedirá de propor a ação pela quarta vez.

Os três fenômenos foram exaustivamente tratados no item 10.4 integrante do Capítulo 10, razão pela qual, neste passo, faz-se necessária apenas a síntese da extinção do processo por litispendência, coisa julgada ou perempção.

Nessas hipóteses, tal como nas condições da ação, de rigor, não se está

diante de vícios sanáveis, ou seja, passíveis de correção por um ato ou manifestação de vontade do autor.

Ainda assim, por força do princípio do contraditório, se detectado, de ofício, pelo juiz ou arguido pelo réu, antes da extinção do processo, deve o autor ser intimado para se manifestar sobre a caracterização ou não da litispendência, perempção ou coisa julgada, se não para corrigir o vício, que é insanável, para argumentar e demonstrar, por exemplo, que a ação pendente é, em alguma medida, diferente da já ajuizada ou transitada em julgado, não sendo o caso, portanto, de extinção do processo por força do art. 485, inc. VII.

Aplica-se, na hipótese, o art. 10 do Código, que dispõe: “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Entretanto, caso, após a oitiva do autor, restar claro que se trata de ação idêntica a ação já ajuizada, pendente, transitada em julgado ou extinta por três vezes sem resolução do mérito por abandono do autor, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VII, do Código de Processo Civil.

f) Extinção por ausência de condições da ação

O inc. VI do art. 485 do Código estabelece as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por carência de ação, assim entendida a ausência de uma das condições da ação, legitimidade e interesse processual.

Tais temas já foram objeto de análise e sistematização no Capítulo 8.

Naquela ocasião, restou dito que a legitimidade é a pertinência subjetiva entre a relação jurídica litigiosa objeto do processo e as partes ativa e passiva da relação processual, ao passo que o interesse de agir é a existência da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional

pleiteado, sendo inadmissível a análise de demandas tidas, de plano, como inúteis ou desnecessárias⁴³⁸.

Ao contrário dos vícios arrolados nos incs. I, II, III e IV do art. 485 do Código até aqui estudados, a ausência de condições da ação, via de regra, não encerra hipóteses de vícios sanáveis, dado que não é, em tese, possível que o autor pratique um ato ou realize uma manifestação que o torne legítimo ou configure seu interesse de agir, até então inexistente.

Por essa razão, como regra, a hipótese de extinção do processo por ausência de interesse e legitimidade não precisa ser precedida de uma intimação prévia e específica para que o autor corrija o vício, como em hipóteses anteriormente estudadas.

A única hipótese de correção dos vícios arrolados no art. 485, inc. VI, do Código é o caso de ilegitimidade passiva.

Isso porque, nos termos do art. 338 do CPC, “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”.

O dispositivo é complementado pelo art. 339, também do Código, que determina que “quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”, no que é complementado pelo § 1º, que autoriza “o autor, ao aceitar a indicação, proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu”.

Assim, da leitura dos dispositivos citados, depreende-se que a ilegitimidade passiva é um vício sanável desde que o réu original alegue sua ilegitimidade, indique o verdadeiro legitimado e que o autor, além de aceitar a indicação, tome as providências cabíveis para inseri-lo na demanda, ou seja, emende a petição inicial e requeira a citação da parte

legítima.

Tomadas estas providências e corrigido o vício de ilegitimidade, o processo não deverá ser extinto, e sim prosseguir contra o “novo” réu legitimado passivo.

Ademais, caso seja este vício de ofício detectado pelo juiz, antes da extinção, por força do princípio do contraditório, deve ser dada ao autor a oportunidade de demonstrar sua legitimidade, a legitimidade passiva do réu, ou seu interesse de agir.

Nesse ponto, tal como em todas as manifestações de ofício pelo juiz, aplica-se a regra do art. 10 do CPC, que proíbe o juiz de “decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Caso, mesmo tendo sido dada a oportunidade para manifestação do autor, este não demonstre satisfatoriamente a existência de legitimidade ou interesse, aplica-se o disposto no art. 485, inc. VI, do CPC devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

g) Extinção por acolhimento de alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência

Outra hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito ocorre, nos termos do art. 485, inc. VII, quando houver o acolhimento de alegação de existência de convenção de arbitragem.

Conforme já observado no item 3.1.3.1, as partes, desde que maiores e capazes, podem convencionar que, em vez de submeterem o litígio ao Poder Judiciário, este deverá ser apreciado e julgado por um árbitro privado livremente escolhido pelas partes em comum acordo.

A opção pela arbitragem pode ser celebrada pelas partes de duas

formas: pela cláusula compromissória ou pelo compromisso arbitral.

Na cláusula compromissória, as partes, em um contrato, comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativos ao contrato.

Já o compromisso arbitral é a convenção por meio da qual as partes submetem um litígio já existente à arbitragem de uma ou mais pessoas.

Portanto, a princípio, a existência do compromisso arbitral ou da cláusula compromissória impede o próprio ajuizamento da ação por qualquer das partes.

A hipótese, prevista no art. 485, inc. VII, do CPC, portanto, apenas terá lugar quando uma das partes quebrar o compromisso firmado, buscando o Judiciário em vez de, nos termos do acordo celebrado, procurar a solução do litígio perante o árbitro.

Ajuizada a ação por uma das partes, cabe à outra alegar e provar a existência da convenção de arbitragem que impede o julgamento de mérito pelo juiz e, por via de consequência, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Conforme estudado no Capítulo 10, a convenção de arbitragem é um dos quatro pressupostos processuais negativos que, quando existente e demonstrado, impede o exame do mérito.

Apesar disso, o art. 337, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil impede o exame de ofício, pelo juiz, da existência do compromisso arbitral.

Assim, ao contrário de todos os demais pressupostos processuais e demais vícios enumerados no art. 485 do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito por força da existência da convenção de arbitragem só pode ser decretada pelo juiz se a parte interessada, no caso, o réu, alegar a existência deste fato impeditivo na primeira oportunidade de falar nos autos, no caso, a preliminar de contestação.

Caso alegada e demonstrada pelo réu a existência da convenção de

arbitragem, o acolhimento dessa alegação pelo juiz leva à extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC, uma vez que o litígio entre as partes, em função do compromisso, deve ser apreciado pelo juízo arbitral.

O art. 485, inc. VII, do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito quando o juízo arbitral reconhecer sua competência que, nesse contexto, impede o exame do mérito pelo Poder Judiciário.

Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery⁴³⁹ esclarecem que o dispositivo consagra a regra segundo a qual cabe ao árbitro ou ao tribunal arbitral decidir sobre sua própria competência⁴⁴⁰.

Assim, resta clara da leitura da parte final do dispositivo em comento a conclusão no sentido de que o Direito Processual Civil brasileiro reconhece a competência do árbitro para decidir sobre sua própria competência, e, mais do que isso, admite que tal decisão arbitral impacte diretamente no processo judicial, extinguindo-o.

h) Extinção por desistência da ação

O art. 485, inc. VIII, do CPC prevê a possibilidade de extinção do processo por desistência da ação.

A desistência é o ato unilateral de manifestação de vontade do autor em que ele, expressamente, exterioriza seu desejo de não mais obter a tutela jurisdicional originalmente pleiteada. Nas palavras de Candido Rangel Dinamarco⁴⁴¹, a desistência é a “revogação explícita da demanda”.

Tal como todas as hipóteses arroladas no art. 485 do CPC, a desistência dá origem à extinção do processo sem resolução do mérito o que, em tese, não impede que a mesma ação seja proposta.

Assim, por mais que a sentença terminativa, que extingue o processo sem resolução do mérito, seja favorável ao réu, fato é que, a extinção por

desistência não representa o máximo que o réu poderia obter no processo.

Isso porque, caso a sentença seja definitiva e extinga o processo com resolução do mérito, o réu obtém uma dupla vantagem, pois, não apenas terá a sentença favorável a si, como também deixa de se sujeitar definitivamente à propositura da mesma demanda.

Em outras palavras, por mais que a sentença que acolha a desistência do autor seja favorável ao réu, este pode ter interesse jurídico em outra espécie de sentença que também não acolhe a pretensão do autor mas extingue o processo com resolução do mérito, hipótese em que a demanda não poderá mais ser proposta por força da formação da coisa julgada material decorrente da sentença que resolve o mérito⁴⁴².

Por esse motivo, o § 4º do art. 485 do Código estabelece que, oferecida a contestação, o juiz não poderá mais extinguir o processo pela desistência sem o consentimento do réu.

Portanto, dois são os possíveis regimes da extinção do processo pela desistência da ação, mostrados a seguir.

O primeiro deles verifica-se no caso de não apresentada defesa via contestação, hipótese em que o autor pode apresentar seu pedido de desistência, devendo o magistrado homologá-lo independentemente de concordância do réu.

Uma segunda situação ocorre quando foi apresentada a contestação, hipótese em que, uma vez requerida a extinção por desistência da ação, deverá o réu ser intimado para manifestar sua concordância.

Caso esta concordância seja apresentada, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Entretanto, se o réu discordar, o juiz não poderá extinguir o processo com apoio no art. 485, inc. VIII, apesar do requerimento unilateral do autor nesse sentido.

i) Extinção pela morte da parte e intransmissibilidade do direito discutido em juízo

O inc. IX do art. 485 do Código de Processo Civil dispõe que haverá extinção do processo sem resolução do mérito quando “em caso de morte da parte a ação for considerada intransmissível por disposição legal”.

O dispositivo tem aplicação nos processos em que o direito litigioso, isto é, o objeto do processo, não pode ser transmitido para nenhum herdeiro ou sucessor.

Nesses casos, o processo deve ser extinto sem a resolução do mérito, em função da perda do seu objeto e de sua própria razão de ser, ou seja, da desnecessidade do julgamento em função da intransmissibilidade do direito a ser julgado.

Um bom exemplo da aplicação dessa regra é na ação de divórcio em que, no curso do processo, ocorrer a morte de uma das partes. Nesta hipótese, obviamente em razão do falecimento da parte, o juiz deve, de imediato, extinguir o processo sem resolução do mérito pela total e absoluta desnecessidade de a ação de divórcio, voltada à extinção do vínculo matrimonial, ser julgada.

Da mesma forma, deve se extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IX, do Código, quando o direito pleiteado for personalíssimo, como nos casos de pretensão em receber alimentos ou tomar posse em um cargo público em função da aprovação em concurso de provas e títulos.

Por outro lado, nos processos em que o direito for patrimonial e transmissível e que venha a ocorrer a morte da parte, o art. 485, inc. IX, não tem aplicação pois, em função desta transmissibilidade, o sistema processual determina a sucessão de partes, na qual os herdeiros e sucessores da parte falecida ingressam no processo no lugar desta, observando o procedimento da habilitação disciplinado nos arts. 687 a 692

do Código de Processo Civil⁴⁴³.

j) Extinção em outras hipóteses previstas no Código

Por fim, o rol do art. 485 prevê a possibilidade de outros dispositivos esparsos no Código de Processo Civil estabelecerem outras hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

É o que ocorre, por exemplo no art. 116, parágrafo único, do CPC, que dispõe que “nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”⁴⁴⁴.

Da mesma forma, o art. 787 do Código, ao disciplinar o processo de execução, estabelece que “se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”.

Ademais, vale ressaltar que qualquer lei federal, ainda que fora do Código de Processo Civil, pode prever outras hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, o que ocorre principalmente nas leis que disciplinam procedimentos especiais.

Assim, por exemplo, a Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) estabelece, em seu art. 10, que a inicial será, desde logo, indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração, de 120 dias, o que implica a extinção do processo sem o exame do mérito.

11.4.2 Extinção do processo com resolução do mérito

O art. 487 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o processo deve ser extinto com resolução do mérito.

Conforme já asseverado, a extinção do processo com resolução do mérito

se dá por sentença definitiva e gera coisa julgada material impedindo a rediscussão do pedido em qualquer outro processo.

Obviamente, a resolução do mérito pressupõe a regularidade da ação e do processo, devendo estar preenchidos e regulares todas as condições da ação e os pressupostos processuais, de validade e negativos.

A ausência destes requisitos impede o julgamento de mérito e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Entretanto, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, o que deixa clara a preferência do sistema processual pela resolução de mérito, especialmente por ser esta a forma de se solucionar definitivamente a lide.

a) Extinção por julgamento do pedido

A primeira hipótese prevista no inc. I do art. 487 dispõe sobre o que talvez seja a forma mais natural e a verdadeira razão de ser do processo, o julgamento do pedido.

Trata-se, se não da única, da principal razão de ser do processo, motivo pelo qual, uma vez acolhido ou rejeitado o pedido, o processo deve ser finalizado.

É comum na prática forense a utilização das expressões “procedência ou improcedência da ação” que, nesse contexto, devem ser entendidas como equivalentes ao acolhimento ou à rejeição do pedido, apesar de a ação e o pedido, nela veiculado, conceitualmente, não se confundirem.

Ademais, é possível e muito comum, o acolhimento parcial do pedido que, por óbvio, implica a rejeição de parte da demanda.

Outro ponto que merece aqui uma observação é a necessidade e o dever do juiz de, no momento de extinção do processo e apreciação do pedido,

realizar uma apreciação completa, assim entendida uma resposta a todos os pedidos formulados, acolhendo-os ou rejeitando-os, sempre fundamentadamente.

Contudo, não é dado ao juiz ir além, haja vista a regra da inércia jurisdicional que estabelece a adstrição do juiz ao pedido.

Nesse sentido, dispõe o art. 492 do CPC, que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”⁴⁴⁵.

Outra hipótese, prevista no art. 487 do Código, que, de rigor, equivale a rejeição do pedido, é destacada no inciso II do dispositivo, que impõe a extinção do processo com resolução do mérito “quando o juiz reconhecer a prescrição ou decadência”.

A prescrição é a perda da pretensão à tutela de um direito, em virtude da inércia de seu titular, no prazo previsto em lei. Tal conceito deve ser entendido em conjunto com a letra do art. 202 do Código Civil, que dispõe que “violado o direito, nasce para seu titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que se referem os arts. 205 e 206”.

Já a decadência é a perda do próprio direito por força da inércia de seu titular no lapso temporal estabelecido em lei. A decadência também é regulada pelo Código Civil, entre os arts. 207 a 211.

Nenhum dos dispositivos se ocupa em conceituar a decadência, devendo ser destacada, nesta sede, a letra do art. 210 do CC, que dispõe que “deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei”.

A distinção entre os dois fenômenos gera algumas polêmicas doutrinárias, sendo certo que, nesse passo, pelo menos para efeitos processuais, tanto a prescrição quanto a decadência recebem o mesmo tratamento, justificando a extinção do processo com resolução do mérito.

De rigor, reconhecer a prescrição ou decadência é uma hipótese específica de julgamento de improcedência do pedido pela extinção do

direito do autor, mas considerando a controvérsia doutrinária sobre o tema, o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil deixa fora de dúvidas tratar-se de pronunciamento de mérito, por sentença definitiva que forma coisa julgada material.

Os prazos de prescrição e decadência são estabelecidos e disciplinados no direito material, destacando-se, nesse contexto, os art. 205 e 206 do Código Civil⁴⁴⁶.

O art. 487, inc. II, do Código de Processo disciplina as consequências processuais nas hipóteses em que o direito pleiteado já esteja extinto pela prescrição ou decadência, determinando o proferimento de sentença definitiva, com resolução do mérito, formando-se coisa julgada material.

O dispositivo deixa claro que a prescrição e a decadência podem ser reconhecidas e decretadas de ofício pelo juiz, independentemente de provocação da parte interessada.

Entretanto, é preciso ressaltar que o princípio do contraditório impõe que, caso o juiz entenda ser o caso de extinguir o processo por força da prescrição ou da decadência, deverá dar oportunidade para que as partes se manifestem sobre esta possibilidade, a teor do art. 487, parágrafo único, do Código.

b) Extinção por homologação de transação, renúncia e o reconhecimento jurídico do pedido

O julgamento do pedido pode se tornar desnecessário em função do acordo de vontades entre as partes ou de atos unilaterais de disposição do direito litigioso que extingam a lide.

Assim, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, a transação, a renúncia e o reconhecimento jurídico do pedido implicam a extinção do processo com resolução do mérito.

A transação é o acordo de vontades por meio do qual as partes,

mediante concessões recíprocas, extinguem o litígio estabelecendo, neste acordo, os termos dessa resolução.

A renúncia é o ato voluntário do autor que deixa de exercer a pretensão e expressamente “abre mão” do direito⁴⁴⁷.

Conforme já asseverado, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação não se confunde com a desistência da ação, uma vez que esta última não implica extinção do processo com resolução do mérito.

Já o reconhecimento jurídico do pedido é a aceitação, pelo réu, do pleito do autor, o que implica o acolhimento da pretensão.

É importante destacar que, nas três hipóteses aqui comentadas, não é exatamente a renúncia, a transação ou o reconhecimento jurídico do pedido que extingue o processo, uma vez que se faz necessária a homologação destes atos dispositivos por sentença.

Em outras palavras, é a sentença homologatória que extingue o processo com resolução do mérito.

Nesses casos, ao contrário das hipóteses previstas no art. 487, incs. I e II, os moldes em que a lide é solucionada não são ditados pelo juiz, mas sim pelas partes.

Por isso, não cabe ao juiz examinar os contornos e a compatibilidade do conteúdo do acordo com o ordenamento jurídico.

Para proferir a sentença meramente homologatória, o juiz deve apenas verificar se as partes são maiores e capazes ou estão legitimamente representadas, se os direitos são disponíveis e transacionáveis, e se as partes estão exercendo os atos de disposição livremente e realmente cientes das consequências destes atos.

Tal como na hipótese de julgamento propriamente dito, a sentença meramente homologatória de transação, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido é definitiva, fazendo coisa julgada material, impedindo a rediscussão do direito transacionado, renunciado ou reconhecido em

qualquer outro processo.

Capítulo 12 Atos Processuais

12.1 Atos jurídicos em geral, atos jurídicos processuais e fatos processuais

De maneira geral, ato jurídico pode ser conceituado como toda manifestação de vontade capaz de provocar consequências na órbita do Direito, criando, modificando ou extinguindo relações jurídicas.

Nesse contexto, os atos jurídicos processuais são todas as manifestações de vontade das partes, do juiz, dos auxiliares da Justiça ou de terceiros que atuem no processo capazes de constituir, modificar ou definir a relação jurídica processual.

É por meio de atos processuais, portanto, que a relação processual e o procedimento têm início, desenvolvem-se e são extintos.

Isso porque é por meio da prática de atos processuais que todos os sujeitos do processo atuam no exercício de seus direitos e poderes, desincumbem-se dos ônus processuais, bem como cumprem seus deveres no processo⁴⁴⁸.

Portanto, dois são os critérios básicos para a identificação dos atos processuais: a) serem atos de exteriorização de vontade; e b) a partir de sua prática trazerem alguma consequência para o processo.

Além dos atos processuais, outros acontecimentos podem influenciar o desenvolvimento, a modificação ou até mesmo determinar a extinção do processo, sem a concorrência da vontade humana. Nestes casos, em que não há manifestação de vontade, o acontecimento que influencia o processo é denominado fato jurídico processual.

Entretanto, em que pese a influência direta a partir da ocorrência do fato processual, via de regra, as consequências processuais são realmente sentidas no processo após o reconhecimento formal de sua ocorrência nos

autos do processo, pelo juiz ou por um de seus auxiliares.

Assim, por exemplo, a morte do advogado de uma das partes, que nada mais é do que um evento natural independente de manifestação de vontade humana, gera diversos efeitos no curso do processo, como sua suspensão e a abertura do prazo de 15 dias para que a parte constitua novo advogado, mas, de rigor, o desencadeamento destes efeitos se dá a partir da formalização deste fato e seu reconhecimento formal no processo, por meio de um pronunciamento declaratório do magistrado.

Da mesma forma, os atos jurídicos, em geral praticados fora do âmbito do processo, podem vir a ter influência direta no desenvolvimento ou extinção do processo. Nestes casos, igualmente, a regra é que tal influência só venha a ser concretizada a partir do reconhecimento formal de sua prática nos autos do processo.

A celebração de um compromisso arbitral, por exemplo, determina a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como a novação da dívida objeto de um litígio pode impedir o prosseguimento do processo voltado a sua cobrança. Entretanto, tais efeitos só serão concretizados no processo quando tiverem sua ocorrência formalmente manifestada e reconhecida nele, por meio da alegação ou notícia nos autos.

Da mesma forma, em uma ação de divórcio, a morte de um dos cônjuges representa um fato processual que resolve a relação processual, devendo o processo ser extinto, sendo certo que se faz necessário que tal reconhecimento e, conseqüente extinção, seja declarado por sentença.

Em suma, a par dos atos processuais em si mesmos considerados, praticados pelos sujeitos do processo (partes, juízes, seus auxiliares e terceiros), “dentro” do processo e intencionalmente voltados a influenciá-los, os fatos processuais e os atos jurídicos em geral também podem trazer conseqüências para o processo, desde que formalmente reconhecidos nos autos.

O objetivo do presente capítulo é analisar as regras gerais para a prática dos atos processuais, isto é, seus requisitos gerais de validade e produção de efeitos, tais como forma, tempo e lugar, assim como os prazos processuais para o exercício de tais atos.

12.2 Classificação dos atos processuais

O Código de Processo Civil, ao classificar os atos processuais, vale-se do critério subjetivo, dividindo-os em atos processuais das partes, do juiz e dos auxiliares da Justiça.

12.2.1 Classificação segundo o sujeito que os pratica

a) Atos da parte

O direito à ampla participação e ao exercício do contraditório e o do dever de cooperação das partes, em apertada síntese, levam à possibilidade e muitas vezes à necessidade de que estas pratiquem atos processuais.

Genericamente, as partes possuem os direitos de requerer, alegar e provar, já estudados no item 9.2.3.1, "a". Os atos processuais são a formalização do exercício destes direitos.

Alguns poucos aspectos dos atos das partes são genericamente disciplinados entre os arts. 200 e 202 do Código de Processo Civil, sendo certo que, rigorosamente, os aspectos mais relevantes, no que tange aos atos das partes, estão disciplinados em dispositivos esparsos que se ocupam de regular e estabelecer os requisitos específicos de determinados atos destes sujeitos, sobretudo os mais importantes.

Nesse contexto, destacam-se a disciplina da petição inicial entre os arts. 319 e 321, da contestação entre os arts. 335 e 342, da apelação contra a sentença nos arts. 1.009 a 1.114 e do recurso de agravo entre os arts. 1.115 e 1.020, todos do Código de Processo Civil, assim como o art. 146 do

CPC, que detalha a forma e o conteúdo da arguição de impedimento ou suspeição do juiz.

Isso sem contar os arts. 369 a 484, em que o Código disciplina a prática de atos pelas partes e demais sujeitos do processo voltados à participação na atividade probatória.

Portanto, o estabelecido nos arts. 200 a 202 do CPC está muito longe de esgotar a disciplina dos atos das partes.

De toda sorte, além de terem de respeitar os referidos dispositivos, vale destacar, neste passo, a necessidade de observância pelas partes dos requisitos exigidos por lei para a prática dos atos processuais em geral, tais como serem escritos em língua portuguesa, ou traduzidos se originalmente escritos em língua estrangeira.

Apenas um aspecto formal é destacado na seção destinada genericamente a disciplinar os atos das partes: o que veda o lançamento nos autos de cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo, nos termos do art. 202 do CPC.

Não cabe analisar, neste item, todos os possíveis atos das partes, sendo importante ficar desde já registrado que, a par da observância de todos os aspectos formais genericamente tratados neste capítulo, é essencial, para fins de validade e efetividade do ato processual praticado pela parte, a observância do prazo processual pertinente e a eventual disciplina específica do ato a ser praticado.

O descumprimento, pela parte, do prazo processual, salvo justo motivo, implica preclusão temporal a seguir estudada, bem como o desrespeito a aspectos formais relevantes, levam ou podem levar nulidade dos atos processuais.

Nesse contexto, ainda cumpre destacar um aspecto relacionado à prática dos atos processuais pelas partes previstos nos arts. 190 e 191 do Código

de Processo Civil, que preveem, respectivamente, a possibilidade de realização de negócios processuais entre as partes e a possibilidade de estas acordarem a respeito de um calendário processual, aos quais será dedicado o subitem a seguir.

b) Especialmente sobre os negócios processuais

Dispõe o art. 190 do Código de Processo Civil que “versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”.

Nesse contexto, as partes podem celebrar “negócios processuais” assim entendidos acordos sobre questões procedimentais, com a supervisão do juiz, possível sempre que estas forem plenamente capazes e o direito objeto do processo for disponível.

O referido dispositivo, conforme assevera Fredie Didier Jr.⁴⁴⁹, consagra a atipicidade dos negócios processuais, sendo certo que, a par desta previsão genérica, o Código consagra diversos negócios processuais típicos como a já referida possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes tratadas no item 11.3.2, “a”.

Portanto, a par da possibilidade de as partes celebrarem acordos sobre o procedimento nos casos tipificados em lei, a priori, elas possuem liberdade para dispor e transacionar sobre qualquer outro aspecto procedimental, desde que sejam maiores e capazes, e os direitos objeto do processo sejam disponíveis.

Obviamente, cabe ao juiz controlar a licitude destes negócios processuais recusando cláusulas abusivas e disposições nulas de pleno direito ou inviáveis do ponto de vista prático.

O controle pelo juiz dos negócios processuais celebrados pelas partes nada mais é do que uma expressão do poder ordinatório⁴⁵⁰.

Já o art. 191 do CPC estabelece a possibilidade de as partes e o juízo elaborarem um “calendário processual”.

O referido dispositivo reza que “de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso”.

Importante destacar, de antemão, a necessidade de concordância e homologação pelo juízo do calendário processual conforme deixa claro o dispositivo.

Uma vez elaborado e homologado o calendário processual, este vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados, conforme dispõe o § 1º do dispositivo.

Ademais, conforme determina o § 2º do mesmo art. 191, a elaboração do calendário processual torna desnecessária a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário.

O estabelecimento do calendário, portanto, influencia não apenas os prazos processuais, que passam a ser determinados pelo calendário elaborado, como também exerce influência sobre toda a dinâmica procedimental, uma vez que dispensa os atos de comunicação para a fluência e contagem dos prazos ali estabelecidos.

c) Atos do juiz e dos auxiliares da Justiça

O juiz, como condutor do processo e órgão responsável pelo julgamento do mérito, é dotado pelo sistema processual de uma série de poderes, notadamente dos poderes decisório, instrutório, ordinatório, sancionatório e executório⁴⁵¹.

Nesse sentido, a prática de atos processuais pelo juiz é imprescindível para que o magistrado exerça seus poderes e cumpra com os seus deveres.

Para tanto, o juiz conta com o auxílio dos auxiliares da Justiça que, sob a sua supervisão e comando, praticam atos processuais voltados ao desenvolvimento do processo e à efetivação das decisões judiciais.

Nesse contexto, destacam-se o escrivão e o chefe de secretaria responsáveis por uma série de atos, tais como os atos de documentação, e atos de movimentação, como abertura de vista dos autos para as partes e conclusão destes autos para o juiz. Já o oficial de justiça é auxiliar responsável pela prática de atos processuais fora da sede do fórum⁴⁵².

Os arts. 203 a 205 do Código de Processo Civil disciplinam os atos do juiz, ao passo que os arts. 206 a 211 regulamentam os atos dos auxiliares da Justiça.

Este subitem é voltado à análise dos principais aspectos dos atos que podem ser praticados pelos sujeitos do processo, salvo os atos decisórios do juiz aos quais será dedicado um subitem específico.

Os arts. 203 a 205 do Código de Processo Civil regulamentam os atos do juiz.

De rigor, os atos ali disciplinados são os pronunciamentos do juiz de primeiro grau e dos tribunais, sendo certo que o juiz pratica outros atos ali não arrolados.

Isso porque os atos do juiz podem ser classificados em atos decisórios, ordinatórios, instrutórios e executórios. Assim, tais atos não se limitam a pronunciamentos e muito menos a decisões.

A efetiva participação do juiz na atividade probatória, por exemplo, leva-o a praticar atos instrutórios, assim entendidos aqueles praticados no curso da atuação do magistrado na produção das provas necessárias ao conhecimento dos fatos controvertidos e relevantes para o julgamento da causa.

São exemplos de atos instrutórios praticados pelo juiz a inspeção judicial, que consiste na vistoria realizada pessoal e diretamente pelo juiz em

peças ou coisas, a fim de esclarecer algum fato que interesse à decisão da causa, bem como a participação do magistrado na audiência conduzindo-a e nela atuando, inquirindo as partes e as testemunhas, se for o caso.

Considerando que o juiz também é o responsável pela condução do processo voltado à prestação da tutela jurisdicional executiva, assim entendida aquela voltada à realização, no plano dos fatos do direito representado no título⁴⁵³, o juiz também pratica atos executórios como a constrição patrimonial, o bloqueio de bens e a alienação de bens penhorados.

É certo que, neste plano, o juiz conta com o auxílio de alguns auxiliares da Justiça, como o oficial de Justiça já comentado e o leiloeiro, especificamente nos casos de alienação judicial em hasta pública, o que não impede de o magistrado praticar diretamente atos executórios, tais como a “penhora on-line” de dinheiro e aplicações financeiras na conta corrente do executado.

Esse bloqueio é realizado pessoal e diretamente pelo juiz, sendo um típico caso de prática de ato executório pelo próprio magistrado.

Além disso, o juiz pratica inúmeros atos ordinatórios até como forma de desenvolver o processo e preparar a decisão.

Os atos ordinatórios são praticados de ofício pelo juiz e voltados à condução do processo, bem como a verificação da validade e regularidade do procedimento e da relação processual.

Como regra geral, os atos ordinatórios são praticados por meio de despachos, pronunciamentos conceituados pelo art. 203, § 3º do CPC, como aqueles praticados pelo juiz no processo, de ofício ou a requerimento da parte, que não tenham conteúdo decisório, haja vista que os atos com conteúdo decisório são definidos nos §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo como sentenças e decisões interlocutórias.

A atividade ordinatória, de dar andamento ao feito por meio da prática

de atos processuais, além de ser exercida pelo juiz por despachos, poderá ser realizada por seus auxiliares, notadamente pelos servidores do Judiciário como o escrivão, o escrevente e cargos equivalentes que, nos termos do § 4º do art. 203 do CPC, podem praticar atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independentemente de despacho ou ordem judicial, sempre sob a supervisão do juiz.

Nesse sentido, os atos dos auxiliares são praticados sempre dentro dos limites estabelecidos pelas decisões e pronunciamentos do magistrado e influenciam, sobretudo, a marcha processual, uma vez que não possuem conteúdo decisório.

Tais atos são principalmente os atos de documentação, movimentação e comunicação processual, que, mesmo sem conteúdo decisório, possuem um relevante grau de influência no desenvolvimento do processo.

São atos de documentação a serem praticados pelos auxiliares da Justiça a autuação, assim entendida a formação dos autos do processo, a ser realizada pelo escrivão ou o chefe de secretaria, que, nos termos do art. 206 do Código, deverá, ao receber a petição inicial de processo, autuar, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, assim como a numeração e rubrica de todas as folhas dos autos, bem como a lavratura de termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes que, nos termos do art. 207, deverão constar dos autos datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria.

Ademais, também é função dos auxiliares da justiça a prática dos atos de comunicação, em especial as citações e intimações, indispensáveis para o início da contagem dos prazos processuais e, por via de consequência, do andamento do feito⁴⁵⁴.

Nesse contexto, destacam-se também os atos a serem praticados pelo oficial de justiça, sempre que sua prática se fizer necessária fora do fórum ou da sede do juízo.

d) Especialmente sobre os atos decisórios do juiz

Conforme já asseverado no item 9.2.1.2, “a”, o poder decisório do juiz deve ser entendido, não apenas como o poder de decidir o mérito, isto é, declarar quem tem razão no litígio, pois é do juiz também o poder de decidir os destinos e os rumos do processo.

Cabe ao juiz, portanto, decidir todos os pontos controvertidos e questões relevantes para o andamento e o julgamento do feito.

Nesse sentido, é o juiz quem vai decidir se a parte tem direito à prática deste ou daquele ato processual, sobre a necessidade ou desnecessidade de audiência, sobre a eventual hipótese de suspensão do processo⁴⁵⁵, sobre a validade do negócio processual apresentado pelas partes, ou sobre a aplicação deste ou daquele dispositivo procedimental ao caso.

Além disso, cabe ao juiz, quando entender adequado nos termos da lei, em vez de decidir o mérito, determinar a extinção do processo sem a resolução do mérito⁴⁵⁶.

Em suma, integram o poder decisório do juiz: a) decidir o mérito, julgando o pedido formulado; b) decidir todas as questões incidentes que surjam no curso do processo e que sejam capazes de influir no desenvolvimento dele; e c) decidir sobre a extinção do processo sem resolução do mérito, quando verificar que esta necessidade se impõe.

Isso implica dizer que o juiz não profere apenas uma única decisão no processo, mas tantas quantas forem as questões que surjam no curso do procedimento.

A par deste variável número de questões e, por via de consequência, de decisões, existe a certeza de que o juiz irá proferir uma específica decisão: a que declara extinto o processo.

O ato decisório do juiz que declara extinto o processo é denominado sentença, ao passo que as demais decisões proferidas no curso do processo

são denominadas “decisões interlocutórias”.

Nesse sentido, o art. 203, § 1º do CPC que dispõe que “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, ao passo que o § 2º do dispositivo reza que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

Portanto, o traço fundamental que distingue as sentenças das decisões interlocutórias é a tendência que possui a sentença de extinguir o processo, ao passo que as decisões interlocutórias decidem questão incidente no curso dele, sem, contudo, sequer pretender extingui-lo.

Nota-se que o art. 203, § 1º citado, considerando, de um lado, que contra a decisão que extingue o processo cabe recurso, o que implica a possibilidade de revisão da decisão e, portanto, continuidade do processo em segundo grau de jurisdição e, de outro lado, que o processo pode prosseguir para efetivação da decisão quando esta não é cumprida, estabelece que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum.

O dispositivo, portanto, excepciona a possibilidade de o processo prosseguir em fase recursal ou na fase de cumprimento de sentença, sendo estas fases processuais posteriores indiferentes para a caracterização do ato que declarou extinto o processo, ou, mais precisamente, a fase de conhecimento em primeiro grau de jurisdição, como sentença.

Ademais, é indiferente para a conceituação da sentença se o juiz julgou ou mais amplamente resolveu o mérito uma vez que é igualmente sentença, o ato do juiz que extingue o processo sem resolução do mérito por uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC estudadas no item 11.4.1.

O que ocorre, no caso, é a possibilidade de classificação da sentença que distingue a sentença definitiva da sentença terminativa.

As primeiras se caracterizam por possuírem um conteúdo arrolado no art. 487 do Código de Processo Civil, o que implica dizer que as sentenças definitivas extinguem o processo com resolução do mérito.

Essa nomenclatura, ademais, decorre da impossibilidade de repropositura da ação, pela formação da coisa julgada material típica da resolução do mérito, que inviabiliza a rediscussão deste litígio em qualquer outro processo, sendo o decidido em uma sentença definitiva, imutável.

Já as sentenças terminativas se caracterizam por extinguirem o processo sem resolução do mérito por uma das hipóteses previstas no art. 485 do Código.

Nesse contexto, o conteúdo da sentença terminativa não reflete uma análise do juiz sobre o pedido, nem qualquer pronunciamento acerca do mérito processual. A sentença terminativa apenas declara extinto o processo em razão da verificação de um vício processual insanável, ou sanável, porém não sanado, pela parte⁴⁵⁷, o que não impede a repropositura da mesma ação desde que corrigido o vício.

Já nos tribunais, dada a tendência de o pronunciamento destes órgãos jurisdicionais de segundo grau ou de jurisdição superior serem colegiados, tais atos são denominados acórdãos, conforme o art. 204 do CPC.

Entretanto, em algumas situações, um único membro do tribunal emite, singularmente, alguns pronunciamentos que são denominados decisões monocráticas se possuírem conteúdo decisório ou, simplesmente, despachos no caso contrário.

e) Especialmente sobre os atos de comunicação processual

Importantíssimos para a dinâmica da relação processual e o desenvolvimento do processo são os atos de comunicação processual.

Isso porque, por força do princípio do contraditório consagrado na Constituição Federal e no Código de Processo Civil como uma das normas fundamentais do processo civil brasileiro, a prévia ciência da existência do processo e da prática de atos processuais, pretéritos e futuros, representa um direito fundamental das partes.

De rigor, conforme demonstrado no item 10.2 do Capítulo 10, a ciência do réu acerca da propositura da demanda é um pressuposto processual sem o qual a relação processual sequer pode ser tida como existente na perspectiva jurídica do réu.

Essa ciência é viabilizada por meio de um ato de comunicação processual denominado “citação”, que, em função de sua posição sistemática, é sobremaneira importante para toda a dinâmica processual.

O Código de Processo Civil conceitua a citação no art. 238 ao estabelecer que “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação é, portanto, o ato de comunicação que complementa a relação processual, tornando-a triangular com a integração do réu ao processo.

Nesse contexto, o Código estabelece que a citação é indispensável para fins de existência e validade da relação processual, podendo sua falta ser suprida apenas em caso de comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1º, do CPC). Nessas situações em que o réu, por tomar ciência da existência do processo por outros meios (por consultas em sites do Poder Judiciário; por terceiros; ou mesmo pela imprensa), opta por comparecer em juízo antes mesmo da realização da citação, esse ato de comunicação torna-se desnecessário, haja vista que sua finalidade precípua, de comunicar, terminou sendo realizada por outros meios sem que houvesse prejuízo para o réu.

Por outro lado, cumpre destacar que, caso essa ciência informal não seja acompanhada de um comparecimento espontâneo, a citação, enquanto ato

de comunicação, deve ser tida como indispensável para fins de existência e validade da relação processual. Assim, ainda que se prove que o réu teve ciência da existência da relação processual por outros meios informais, a não realização da citação, somada ao não comparecimento espontâneo, torna a relação processual juridicamente inexistente para o réu⁴⁵⁸.

Dada a importância da citação para o processo, o Código de Processo Civil a regula exhaustivamente em 22 artigos (arts. 238 a 259 do CPC).

Os referidos dispositivos ocupam-se de elencar as modalidades de citação, estabelecer a ordem de preferência por cada uma delas, a par de estabelecer a forma pela qual cada uma deve ser realizada.

No que tange às modalidades de citação, estão previstas seis no Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 246: a) pelo correio; b) por oficial de justiça; c) pelo escrivão ou chefe de secretaria; d) por meio eletrônico; e) por hora certa; e f) por edital.

A citação pelo correio, nos termos do art. 247 do Código, é a regra geral, ou seja, a forma preferencial de realização do ato citatório.

Nessa modalidade, o Poder Judiciário conta com o auxílio direto da Empresa de Correios e Telégrafos que, no exercício de seu mister habitual de entrega de correspondências, entrega os mandados de citação expedidos pelo juízo.

Para fins de documentação nos autos do processo, a citação pelo correio sempre deve vir acompanhada de um aviso de recebimento, documento a ser assinado pelo destinatário da citação e devolvido pelos correios para o Poder Judiciário para ser juntado aos autos do processo.

Nesse sentido, a regra constante do art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que “a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.

Quando frustrada a citação pelo correio, bem como em outras hipóteses em que tal modalidade preferencial é vedada, o Código de Processo Civil

determina a realização da citação pelo oficial de justiça.

Essa modalidade se caracteriza pela participação do oficial de justiça, auxiliar do juízo incumbido de praticar atos externos ao edifício do fórum que, munido da ordem judicial expressa no mandado citatório, deverá procurar pessoalmente o réu para dar-lhe ciência da existência do processo.

Tal modalidade tem lugar quando frustrada a citação pelo correio, nos termos do art. 249, bem como nos casos arrolados pelo art. 247, ambos do Código de Processo Civil, notadamente: a) nas ações de estado; b) quando o citando for incapaz; c) quando o citando for pessoa de direito público; d) quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência.

Nesse sentido, é nula a citação pelo correio das pessoas e nas hipóteses arroladas pelo art. 247 do Código.

Ademais, para fins de regularidade da citação e, conseqüentemente, da validade do processo, o oficial de justiça, nos termos do art. 251 do Código de Processo Civil, deve, ao realizá-la, ler o mandado e entregar a contrafé ao citando e, além disso, obter a nota de ciência ou certificar que o citando não a apôs no mandado.

Essa certidão deverá ser juntada aos autos do processo para fins de documentação da efetivação e regularidade da citação feita pelo oficial de justiça.

Caso o réu compareça em juízo no cartório antes da realização do ato citatório via correios ou oficial de justiça, a citação deste poderá ser realizada pelo próprio escrivão ou chefe de secretaria, nos termos do art. 246, inc. III, do Código. Nessa hipótese, o escrivão ou chefe de secretaria faz as vezes do oficial de justiça, visto que o réu se encontra no edifício do fórum.

Já as citações por edital e por hora certa são excepcionais e, nessa condição, o simples fato de se realizarem sem a observância dos requisitos

que a fazem excepcionalmente cabível as torna inválidas, ainda que cumpridos todos os requisitos formais.

Nesses casos, portanto, além de cabíveis, essas modalidades de citatórias devem observar rigorosamente os ditames legais sob pena de nulidade.

A citação por hora certa tem lugar quando o oficial de justiça, por duas vezes, procurar o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, suspeitando haver ocultação com o intuito de frustrar a citação pessoal (art. 252 do CPC).

Portanto, são dois os requisitos: um, objetivo (tentativa do oficial de justiça de citar o réu pessoalmente por duas vezes); e outro, subjetivo (suspeita de ocultação).

Presentes ambos os requisitos, o oficial de justiça deverá, nos termos do mesmo art. 252 do Código, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no primeiro dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

O oficial de justiça deverá retornar ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência no dia e hora designados e, mesmo se o citando não estiver presente, o oficial de justiça dará por feita a citação.

A não observância dos requisitos de cabimento, quer objetivo (tentativa de citação pessoal por duas vezes), quer subjetivo (suspeita de ocultação do citando), bem como o desrespeito ao procedimento previsto no art. 252 do Código implicam a invalidade da citação por hora certa com as consequências daí decorrentes.

Ademais, como forma de dar real ciência ao réu da realização da citação por hora certa, o art. 254 determina que, "feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo

ciência”.

Excepcionalíssima também é a citação por edital, que pressupõe: o não conhecimento ou a incerteza a respeito do citando (art. 256, inc. I, do CPC); o não conhecimento, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontrar o citando (art. 256, inc. II, do CPC); ou a caracterização de outras hipóteses expressas em lei (art. 256, inc. III, do CPC).

A hipótese do art. 256, inc. I, do Código de Processo Civil se impõe, por exemplo, quando, nos casos de invasão de imóvel, o proprietário desconheça a identidade de seus invasores, situação em que deverá promover a citação contra esse grupo de pessoas, desconhecidas, por edital.

A hipótese mais comum de citação por edital decorre do inc. II do art. 256, ou seja, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando ou, mais precisamente, quando desconhecido o endereço do réu.

Portanto, o desconhecimento do endereço do réu não inviabiliza o exercício do direito de ação exatamente pela possibilidade de formação da relação processual e seu desenvolvimento válido e regular por meio da citação por edital.

É bom que se deixe claro que a presença dos requisitos, nesse caso, o desconhecimento pelo autor do endereço do réu, é imprescindível para a regularidade da citação, sendo inadmissível a validade desse ato quando, posteriormente, verificar-se que o autor o conhecia e o ocultou para evitar a citação pessoal.

Nesse caso, aplica-se o disposto no art. 258 do CPC, que, além de cominar a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, impõe ao autor que falseou a verdade multa de cinco vezes o valor do salário mínimo.

Tal como na citação por hora certa, além de ser cabível a citação por

edital, devem-se observar rigorosamente os requisitos estabelecidos no Código, em especial os do art. 257, que estabelece a necessidade de: a) afirmação do autor ou certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; b) publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; c) determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; d) advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

A correta observância de todos os requisitos e formalidades legais decorre da dupla necessidade já referida: a) realização da citação pela modalidade cabível; b) respeito aos requisitos formais exigidos por lei para cada uma das modalidades.

Nesse contexto, um requisito formal exigido em lei é o respeito ao art. 250 do Código de Processo Civil, que disciplina o conteúdo do mandado citatório, que deverá conter: I – os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências; II – a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução; III – a aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver; IV – se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento; V – a cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória; VI – a assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

A falta de um desses requisitos formais gera a nulidade da citação e, por via de consequência, compromete a relação processual desenvolvida a partir desse ponto.

Nesse sentido, caso faltante, por exemplo, a menção do prazo para

contestar, sob pena de revelia a que se refere o art. 250, inc. II, deverá a citação ser considerada nula com as consequências daí advindas a serem referidas adiante.

Outro ponto ligado à regularidade e validade da citação diz respeito ao seu destinatário.

Nesse aspecto, deve ser observado o art. 242, que dispõe: “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”.

Assim, o desrespeito a essa norma também implica nulidade do ato citatório e as consequências daí advindas a seguir sistematizadas⁴⁵⁹, salvo se observada a disciplina constante dos parágrafos do art. 242 do Código⁴⁶⁰.

Dando sequência à disciplina dos atos de comunicação processual, o Código de Processo Civil dedica os arts. 260 a 268 às “cartas”, expressão utilizada para denominar os atos de comunicação entre órgãos judiciários com competência territorial, ou mesmo de jurisdições (países) distintas.

São três as espécies de carta, de acordo com o art. 260 do Código de Processo Civil: a) carta de ordem; b) carta precatória; e c) carta rogatória.

As cartas de ordem são utilizadas pelo tribunal (superiores ou de 2º grau de jurisdição) para fins de comunicação entre esses órgãos de superior hierarquia e os juízos de primeiro grau.

Já as cartas precatórias são utilizadas para fins de comunicação entre juízes do mesmo grau de jurisdição, porém com competência territorial diferente.

As cartas rogatórias, por sua vez, são o mecanismo de comunicação entre o Poder Judiciário brasileiro e os órgãos jurisdicionais de outros países.

Assim, sempre que necessária a comunicação entre órgãos do Poder Judiciário (nacional ou estrangeiro), esta deve se dar por meio das cartas precatória, rogatória ou de ordem.

Atualmente, o Código de Processo Civil, além de disciplinar os requisitos formais que devem estar contidos nas cartas, estabelece que estas devem, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico (art. 263 do CPC).

Denomina-se deprecante o juízo que expede a carta e juízo deprecado, aquele para o qual a carta se destina.

Inúmeras podem ser as finalidades de uma carta precatória, rogatória ou de ordem, sendo as principais: a) a realização de um ato de comunicação (carta citatória); b) a produção de prova perante o juízo deprecado (carta instrutória); e c) a realização de um ato executivo (carta executória).

Assim, caso a lei vede a citação pelo correio e exija a citação por oficial de justiça e o réu não resida na comarca, seção judiciária ou região metropolitana do juízo que pretende realizar a citação, este deve solicitar por carta precatória citatória que o juízo do domicílio do réu a realize por meio de seus oficiais de Justiça.

Da mesma forma, sendo necessária a prática de um ato instrutório, como a oitiva de uma testemunha ou a realização de uma perícia, em um território distinto do qual se localiza o tribunal de 2ª grau que precisa produzir a prova, este pode solicitar ao juízo do local onde a prova deve ser colhida (deprecado), para que pratique o ato de produção probatória, situação em que tal comunicação dar-se-á por meio de carta de ordem, como dito. Já a oitiva de uma testemunha fora do país deverá ser requerida pelo Poder Judiciário brasileiro por meio de carta rogatória.

Ademais, cumpre ressaltar que as cartas são sobremaneira úteis para fins de prática de atos executivos fora da esfera territorial de competência do juízo que pretende praticá-lo. Nessas situações em que a penhora, a busca e apreensão ou qualquer ato executivo precise ser realizado fora da comarca ou seção judiciária do juízo que conduz o processo, este deve, por meio de carta, solicitar a prática do ato executório ao juízo deprecado.

O Código de Processo Civil, no art. 268, estabelece que a carta, uma vez

cumprida, deve ser devolvida ao juízo deprecante em 10 dias, sendo certo que se trata de um prazo impróprio, o que implica dizer que, caso esse prazo venha a ser ultrapassado, não há preclusão ou consequências processuais que acarretem ineficácia ou nulidade da carta ou do ato praticado em seu cumprimento.

O terceiro tipo de ato de comunicação disciplinado pelo Código de Processo Civil são as intimações.

Do ponto de vista prático, a intimação é o ato de comunicação mais comum e praticado em maior quantidade no dia a dia do foro.

Isso porque, nos termos do art. 269 do Código de Processo Civil, “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. Assim, ao contrário da citação, que consiste em um ato único dirigido ao réu no início do processo e das cartas que só se fazem necessárias quando a prática de atos processuais se dê fora da sede do juízo, as intimações são praticadas rotineiramente, quer para dar ciência às partes de atos já praticados, quer para que atos futuros, cuja lei impõe ou faculta a participação das partes ou de terceiros, sejam comunicados aos sujeitos do processo por meio de intimações.

O Código de Processo Civil estabelece que as intimações deverão ser realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico, devendo ser dirigidas aos advogados das partes regularmente constituídos nos autos.

Nesse sentido, integra o conjunto de funções a serem desempenhadas pelo advogado receber as intimações e comunicar a parte, tomar as providências ou praticar o ato processual subsequente.

É preciso salientar que a intimação é o principal meio de dar ciência às partes dos atos praticados ou por vir, sendo, nessa medida, indispensável para a mecânica processual.

Isso porque a prévia ciência é condição sine qua non para o início do prazo processual ou, mais amplamente, imposição de ônus ou deveres para

as partes ou terceiros⁴⁶¹.

Assim, salvo hipóteses em que essa ciência se dá por outros meios, como a carga, vista ou remessa dos autos, a intimação é o mecanismo para que a comunicação seja realizada e o processo se desenvolva.

É nesse sentido que deve ser entendido o art. 272, § 6º, do Código, que dispõe que “a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação”.

Conforme já ressaltado, as intimações devem ser dirigidas aos advogados das partes. Apenas nas hipóteses em que a parte não possuir advogado constituído nos autos a intimação deverá se dar na pessoa da própria parte ou de seu representante, por meio eletrônico ou pelo correio. Frustradas as tentativas de intimação eletrônica ou pelo correio, a intimação pode ser realizada por oficial de justiça (art. 275 do CPC).

Realizada a intimação de forma válida, dá-se início à contagem do prazo contra a parte intimada e se considera devidamente comunicada e ciente, a parte ou terceiro, do ato que estes venham a ter o dever ou ônus de praticar ou participar.

Nesse sentido, é correto afirmar que a realização da intimação é indispensável para fins de andamento do feito e desenvolvimento do processo rumo ao julgamento de mérito.

12.2.2 Atos processuais formais, orais e materiais

Outra classificação determinante para a compreensão das regras relativas aos atos processuais é a que os divide em atos formais, orais e materiais.

Em primeiro lugar, vale destacar que a referência aos atos formais não

pode levar à conclusão de que os demais atos processuais (orais e materiais) também não necessitem de regular documentação e formalização nos autos do processo.

Na verdade, o que ocorre é que os atos ditos formais apenas passam a ter existência jurídica quando formalizados nos autos do processo. Antes disso, a eventual existência fática destes atos é absolutamente indiferente do ponto de vista jurídico processual.

Assim, uma “petição inicial”, tal como uma “contestação”, ainda que materializada e assinada pelo advogado da parte, só passa a ter existência jurídica processual a partir de sua apresentação em juízo (protocolo) e posterior juntada do documento aos autos do processo.

Da mesma forma, uma sentença só pode ser assim classificada, do ponto de vista de sua existência jurídica processual, a partir de sua juntada aos autos do processo, não bastando a redação, impressão e assinatura do documento pelo magistrado.

Em apertada síntese, portanto, os atos processuais formais têm sua existência jurídica vinculada a sua documentação nos autos do processo, pelo protocolo e pela juntada, no caso dos atos das partes, ou tão somente a juntada, no caso de atos dos juízes e seus auxiliares.

Por outro lado, a par dos atos formais, existem outros atos processuais que podem ser classificados como materiais. Nestes casos, a existência jurídica do ato processual e o momento de sua prática não se confundem com sua documentação nos autos do processo, sendo esta, como regra, realizada em um momento posterior à prática.

A título de exemplo, podemos apontar o ato de citação do réu ou a penhora de um bem no processo de execução. Nestes casos, o ato é realizado, via de regra, fora da sede do juízo, sendo a juntada de seu comprovante (mandado citatório ou do termo de penhora) uma mera documentação posterior, que não constitui elemento de formação do ato,

mas, no máximo, de produção de algum de seus efeitos.

Com isso se quer dizer que, ao contrário da sentença ou da contestação, em que sua existência apenas ocorre após a documentação, os atos materiais ocorrem “fora” do processo e desde já podem ser considerados existentes antes mesmo da documentação, que, para outros fins, que não para sua existência jurídica, têm de ser formalizados nos autos.

Por esse motivo, por exemplo, considera-se realizada a citação, para fins de produção dos efeitos previstos no art. 240 do CPC, a partir da ciência do réu que a recebe e aporta sua assinatura no mandado citatório apresentado pelo oficial de justiça ou correio.

Contudo, a juntada do mandado citatório é indispensável não apenas para fins de documentação e comprovação da realização do ato, como também para a produção de alguns de seus efeitos, como a abertura do prazo de resposta do réu nos termos do art. 231, inc. I, do Código.

Ademais, também encerram outra categoria de atos processuais os atos orais, praticados, via de regra, em audiência na presença do magistrado e das partes que podem ser considerados desde já praticados, fazendo-se necessária, para fins de documentação, sua transcrição, assim entendida a redução a termo das expressões pronunciadas pelos sujeitos do processo.

Portanto, de um lado temos os atos formais em que a documentação (juntada) é substância do ato e condição para sua existência, em contraposição aos atos materiais e orais que existem desde sua prática, sendo sua documentação muito mais ligada à comprovação nos autos do processo do que à existência propriamente dita.

Tal distinção é relevante, uma vez que determinadas regras relativas ao tempo e lugar dos atos processuais estabelecidos, especialmente nos arts. 217 (os atos devem ser praticados na sede do juízo) e 212 (os atos processuais deverão ser realizados das 6 às 20 horas) do CPC, só fazem sentido no contexto dos atos processuais orais e materiais, uma vez que os

atos formais têm de ser praticados no horário de expediente, ou mais precisamente o horário de funcionamento do protocolo, sendo, por outro lado, indiferente o local e horário da juntada de uma sentença, por exemplo.

Por fim, deve ser destacada a possibilidade e, futuramente, talvez a realidade maciça do processo civil do século XXI, que é a prática de atos processuais pela via eletrônica.

Tal possibilidade, regulada especialmente pelos arts. 193 a 199 do Código de Processo Civil, que estabelecem os requisitos de forma, tempo e lugar para a prática dos atos processuais por esta via, é sensivelmente diferente dos atos formais praticados no ambiente físico.

A título de exemplo, pode ser apontada a absoluta indiferença para fins da prática dos atos processuais na forma eletrônica do horário de funcionamento do protocolo, dado que o ato processual eletrônico pode ser praticado até as 23h59 do dia do vencimento do prazo.

Da mesma forma, a concepção do “lugar” dos atos processuais não nos remete a uma sede ou endereço físico, mas, sim, a um ambiente definido por um endereço eletrônico (sítio ou site).

Nos números seguintes, serão analisadas as normas referentes a forma, tempo e lugar dos atos processuais previstas entre os arts. 188 e 217 do Código de Processo Civil.

Contudo, desde já deve ser esclarecido que nem todas as normas se aplicam a todas as espécies de atos, havendo regras que se aplicam aos atos formais, mas que são inaplicáveis aos orais, materiais ou eletrônicos, por exemplo.

O item final deste capítulo é dedicado a um tema fundamental: os prazos processuais, cuja observância é indispensável para a efetividade do ato praticado considerando que, como regra, o ato praticado fora do prazo não tem o condão de surtir os efeitos que normalmente se espera.

Já o capítulo seguinte será dedicado aos vícios, defeitos e irregularidades dos atos processuais, bem como suas consequências para o processo.

12.3 Forma dos atos processuais

Em princípio, o sistema processual consagra certa margem de liberdade no que tange à forma dos atos processuais, uma vez que conforme dispõe o art. 188 do CPC “os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.

Entretanto, é certo que os inúmeros atos, sobretudo os mais importantes, possuem uma forma detalhadamente desenhada em lei. É o caso, por exemplo, da petição inicial, cujos requisitos estão previstos nos arts. 319 e 320 do CPC e devem ser observados sob pena de inadmissibilidade desta, e da sentença, cujos elementos essenciais, de obrigatória observância pelo magistrado, encontram-se previstos no art. 489 do Código.

Fora destas hipóteses especificadas em lei, aplica-se o comando geral do art. 188 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da liberdade das formas, que comporta, como dito, inúmeras exceções.

Sobre o ponto, Cândido Rangel Dinamarco⁴⁶² explica que o sistema do Código de Processo Civil é um equilíbrio entre a liberdade e a legalidade das formas, e que o processo é um sistema formal, e não formalista. O referido processualista conclui que não deve haver “indulgências exageradas que possam prejudicar a segurança nas relações entre os sujeitos e, portanto, a boa qualidade dos resultados a serem oferecidos afinal pelo juiz”.

Portanto, três conclusões podem ser retiradas da leitura do art. 188 do Código de Processo Civil: a) salvo disposição legal em contrário, a parte pode praticar o ato com liberdade no que tange à forma; b) em havendo disposição legal em sentido contrário, deve ser observada a forma prescrita em lei; c) mesmo que desobedecida a forma prescrita em lei, o ato poderá

ser considerado válido se atingir sua finalidade⁴⁶³.

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece alguns requisitos genéricos e características referentes a todo e qualquer ato processual.

Nesse contexto, destaca-se a exigência do art. 192 do Código que determina que todos os atos processuais sejam praticados em português ou, se redigidos em língua estrangeira, traduzidos para a língua pátria.

Ainda no campo dos requisitos genéricos para a prática de todo e qualquer ato processual, há que se ter em mente, por exemplo, a necessidade de competência para tal prática, sobretudo no caso do magistrado.

O tema, tratado com mais vagar no Capítulo 15, pode ser aqui resumido como a atribuição dada por lei para que a autoridade judiciária conheça da matéria e pratique o ato processual, sendo certo que a falta de competência para tanto implica a invalidade do ato jurisdicional, sobretudo os decisórios.

Sob a perspectiva da parte, dois requisitos genéricos para a prática de todo e qualquer ato processual se impõem, a capacidade processual e a capacidade postulatória, exigindo-se, em outras palavras, a capacidade de exercício ou regular representação, além do patrocínio de um advogado, dada a indispensabilidade deste profissional para a validade dos atos processuais praticados pelas partes⁴⁶⁴.

Por essas razões, não por acaso, o estudo dos requisitos de validade dos atos processuais leva ao estudo dos pressupostos processuais, sobretudo os de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que a maneira por meio da qual o processo se desenvolve é, exatamente, pela prática de atos processuais pelos sujeitos que devem observar as formas estabelecidas em lei e preencher os requisitos genéricos para a prática de todos os atos.

Desta feita, o estudo da forma e da própria validade dos atos processuais exige a pré-compreensão dos pressupostos processuais ao qual se dedicou

o Capítulo 10.

Ademais, concretizando o princípio da publicidade previsto no art. 5º, inc. LX e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o art. 189 do Código de Processo Civil estabelece que os atos processuais são públicos, correndo, todavia, em “segredo de justiça os processos: I – em que o exija o interesse público ou social; II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”.

Além de estabelecer a obrigatoriedade de os atos processuais serem públicos, salvo exceções, e necessariamente, escritos em português, o Código de Processo Civil regulamenta o tempo e o lugar dos atos processuais, normas que devem, igualmente, ser obedecidas pelos sujeitos do processo para fins de validade e eficácia dos atos processuais.

Os itens a seguir serão dedicados às referidas regras atinentes ao tempo e lugar dos atos processuais.

Além disso, considerando que o cumprimento dos prazos processuais é fundamental para a eficácia destes, também será dedicado um item ao tema.

De outra parte, o estudo da forma dos atos processuais se complementa com o estudo da consequência de sua inobservância, isto é, das nulidades processuais analisadas no capítulo subsequente.

12.4 Do lugar dos atos processuais

O estudo das normas relativas ao lugar dos atos processuais, de rigor, envolve a análise de dois aspectos distintos e complementares entre si.

O primeiro, estabelecido no art. 217 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a necessidade da prática de atos na sede do juízo. Já o

segundo enfoque deve ser dado ao estudo às limitações territoriais do juízo ao seu respectivo foro.

O art. 217 do CPC estabelece que “os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz”.

É na secretaria do juízo, localizada no edifício denominado fórum, em se tratando de órgãos de primeiro grau de jurisdição, e nas secretarias dos tribunais, nos casos dos órgãos de segundo grau de jurisdição ou graus superiores, onde se encontram, fisicamente, os autos dos processos e onde os atos processuais devem, precipuamente, ser praticados.

Ademais, é neste endereço onde se encontra toda a estrutura do Judiciário sendo, como regra, as audiências de conciliação ou de mediação, e a de instrução e julgamento realizadas no fórum, assim como é na sede do tribunal em que se realizam as sessões de julgamentos colegiados, com a possibilidade de participação das partes.

Entretanto, salvo a hipótese excepcional em que a parte a ser citada ou o bem a ser penhorado encontre-se coincidentemente no edifício do fórum ou tribunal, os atos materiais acabarão por ser praticados fora da sede do juízo.

Para isso, a estrutura judiciária prevê a existência do oficial de justiça, auxiliar da Justiça que, munido da ordem (mandado) judicial, tem, por ofício, o dever de praticar os atos materiais fora da sede do juízo (art. 154 do CPC).

Por outro lado, os atos formais, especialmente das partes, que se consideram praticados pelo protocolo da manifestação processual, podem ser formalizados fora da sede do juízo.

Isso porque é comum na realidade do dia a dia do foro a admissão do protocolo integrado em que se considera praticado o ato, ainda que este

não seja protocolado na sede do juízo, mas em qualquer estabelecimento reconhecido pelo Poder Judiciário como apto a, em seu nome, receber os protocolos e encaminhá-los ao fórum competente.

Ademais, no que tange aos atos eletrônicos, o lugar para a prática deles deve ser entendido como o ambiente virtual, isto é, o endereço eletrônico disponibilizado pelo Judiciário, sendo, nestas hipóteses, a localização física da parte ou do juiz, absolutamente indiferente para todos os fins.

Assim, a regra estabelecida no art. 217, rigorosamente, só tem aplicação plena em se tratando de atos orais, notadamente os praticados pelas partes e pelo juiz em audiência, bem como as sessões de julgamentos dos recursos no âmbito dos tribunais.

Ainda assim, o próprio art. 217 prevê a possibilidade de atos orais serem praticados fora da sede do juízo, “em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz”.

A prática de atos processuais fora da sede do juízo, em razão de deferência, encerra uma prerrogativa outorgada a determinadas pessoas, ocupantes de determinados cargos descritos no art. 454 do Código, que, por expressa autorização legal, podem recusar-se a irem a sede do juízo, o que obriga o juiz dirigir-se ao local determinado pela autoridade.

Tal prerrogativa está estabelecida no art. 454 do CPC, que dispõe que “são inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função: I – o presidente e o vice-presidente da República; II – os ministros de Estado; III – os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União; IV – o procurador-geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público; V – o advogado-geral da União, o procurador-geral do Estado, o procurador-geral do Município, o defensor público-geral federal e o defensor público-

geral do Estado; VI – os senadores e os deputados federais; VII – os governadores dos Estados e do Distrito Federal; VIII – o prefeito; IX – os deputados estaduais e distritais; X – os desembargadores dos tribunais de Justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal; XI – o procurador-geral de justiça; XII – o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil”.

Nesses casos, o juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha.

Igualmente, podem efetuar-se fora da sede do juízo atos processuais em razão “de interesse da justiça, ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.”

Ambas as expressões encerram conceitos indeterminados que devem ser tratados conforme o caso concreto, cabendo ao juiz verificar a viabilidade ou necessidade da prática de ato processual externo à sede do juízo.

Um exemplo pode vir a ser a tomada de um depoimento pessoal da parte ou inquirição de testemunha enferma que, comprovadamente, não possa deixar o hospital sob pena de agravamento de seu estado de saúde.

Entretanto, cumpre ressaltar que a prática de atos fora da sede do juízo, salvo exceções, deve, tal como na hipótese de atos materiais, respeitar os limites territoriais do foro do juízo.

Caso a prática do ato extrapole os limites da comarca ou seção judiciária, o ato processual deve ser praticado pelo juiz local, provocado pelo juiz condutor do processo por meio de carta, precatória, rogatória ou de ordem, conforme se verá a seguir.

12.4.1 A sede do juízo e os atos praticados fora dos limites territoriais

Também pode ser considerada a sede do juízo o território sobre o qual está estabelecida a competência do órgão jurisdicional.

Em outras palavras, cada juiz possui sua competência atrelada a determinada “porção territorial” denominada foro, que, nas justiças estaduais, é definida como “comarca” e na Justiça federal, como “seção” ou “subseção” judiciária.

O juiz apenas pode realizar atos processuais dentro dos limites territoriais do foro, ou seja, em sua comarca ou seção judiciária.

Caso o juiz considere necessário praticar atos processuais fora destes limites, deverá remeter uma carta precatória ao juiz do local do ato a ser praticado solicitando sua realização fora de sua competência territorial.

Assim, por exemplo, quando o caso concreto exigir a prática de um ato processual fora da sede do juízo, como a oitiva de uma testemunha que resida em outra cidade, ou a penhora de um bem que fique fora da seção judiciária ou comarca do juiz, este deverá expedir uma carta precatória que, neste contexto, deve ser entendida como pedido de um juiz (deprecante) para outro (deprecado), para que este pratique em seu foro o ato processual útil para o processo.

Da mesma forma, caso o tribunal, como regra, sediado nas capitais, precise praticar um ato em outra localidade, o Código de Processo Civil autoriza a expedição das cartas de ordem que, à exceção de serem expedidas por um órgão jurisdicional de segundo grau, e não por um juiz de primeiro grau de jurisdição, têm as mesmas características e funções de uma carta precatória.

As cartas precatórias e rogatórias são disciplinadas entre os arts. 260 a 268, dentre os quais se destaca o art. 263, que determina que “as cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei”.

Assim, o pedido, via carta precatória, de um juiz para outro, deverá,

preferencialmente, ser realizado por meios eletrônicos, evitando-se a formação de “autos” de carta precatória.

Os principais atos realizados via carta precatória são: a citação de um réu residente fora da sede do juízo perante o qual se desenvolve o processo (carta precatória citatória); a oitiva de uma testemunha ou a prática de um ato voltado à produção de uma prova (carta precatória instrutória) ou a realização da penhora ou qualquer ato executivo ou de constrição patrimonial (carta precatória executória).

Entretanto, excepcionalmente, o art. 255 do Código de Processo Civil autoriza a realização de citação ou intimação em comarcas que se situem próximas umas às outras, desde que haja fácil comunicação entre elas, a fim de tornar o rito processual mais célere, evitando o uso de cartas precatórias nestes casos.

Nesse sentido, reza o referido dispositivo que “nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos”.

Vale ressaltar que o dispositivo estabelece, de rigor, duas hipóteses de dispensa de carta precatória: a) nas comarcas contíguas desde que de fácil comunicação; e b) entre as comarcas integrantes de uma mesma região metropolitana, sendo certo que, dentro destas regiões, qualquer ato processual pode ser praticado pelo oficial de justiça fora dos limites territoriais do juízo perante o qual se desenvolve o processo.

12.5 Tempo dos atos processuais

O tempo dos atos processuais pode ser estudado sob duas óticas. A primeira delas relativa ao momento em que estes atos podem ser praticados, em que a regra é a prática do ato processual em dias úteis, das 6 às 20 h, ressalvadas as férias forenses, nos termos do art. 212 do CPC.

Por outro lado, um outro aspecto temporal dos atos processuais é o

respeito aos prazos estabelecidos em lei, pelo juiz ou por convenção das partes que, se descumpridos, implicam a perda do direito de praticá-lo ou a ineficácia do ato praticado fora do prazo, conforme se verá a seguir.

Quanto ao primeiro aspecto, de certa forma, bastante simples, cumpre salientar que a genérica previsão da possibilidade de os atos processuais poderem ser praticados das 6 às 20 h merece algumas observações.

A primeira delas diz respeito à limitação constitucional prevista no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, que estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Assim, caso a prática do ato processual, como a penhora ou a citação, implique a necessidade da entrada na residência do indivíduo, a par da ordem judicial expressa nesse sentido, faz-se necessário que o ingresso seja feito durante o dia ficando limitado pela norma constitucional o horário estabelecido no art. 212 do CPC.

Ademais, caso o ato processual precise, para ser praticado, de formalização por protocolo, a parte não tem efetivamente o direito de praticá-lo das 6 às 20 h uma vez que o protocolo apenas poderá ser realizado no horário de funcionamento do serviço judiciário, ou seja, o horário do expediente do fórum, tema regulado pela lei judiciária local, que, via de regra, estabelece um horário um pouco mais reduzido.

Essa limitação é expressamente prevista e admitida pelo Código de Processo Civil, que, em seu art. 213, parágrafo único, estabelece que “o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo”.

Por outro lado, se os atos processuais a serem praticados forem eletrônicos, não se aplica o disposto no art. 212, caput, uma vez que se admite a prática destes atos durante as 24 horas do dia. Nesse sentido,

dispõe o art. 213 que “a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”.

Ademais, mesmo os atos processuais sujeitos ao limite temporal estabelecido no art. 212 do CPC admitem, excepcionalmente, sua realização fora deste horário notadamente quando, iniciados antes das 20h, seu adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.

É o caso, por exemplo, de uma audiência iniciada às 14h e que, às 20h, está na fase final de tomada do último depoimento testemunhal, hipótese em que, com fulcro no art. 212, § 1º, do CPC, o juiz poderá se estender e conduzir a audiência após o referido horário.

Igualmente, dispõe o art. 212, § 2º, do CPC que “independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal”.

Assim, os atos materiais, sobretudo aqueles praticados fora da sede do juízo, poderão ser praticados antes ou além dos limites temporais estabelecidos no art. 212, caput, desde que respeitado o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Já a disciplina dos prazos processuais, por possuir inúmeras peculiaridades e grande importância para a eficácia dos atos processuais e o desenvolvimento do processo, impõe uma análise mais pormenorizada nos itens subsequentes.

12.6 Prazos processuais

É fundamental para a dinâmica do processo e para o desenvolvimento do procedimento a fixação, por lei, pelo juiz ou por convenção das partes de prazos para a prática dos atos processuais pelos sujeitos do processo.

Os prazos processuais, neste contexto, ligam-se a ideia de ônus,

sobretudo, das partes envolvidas no processo. O tema, tratado no item 9.2.3.1, “f”, supra, em última análise, decorre da necessidade de imposição de limites temporais e procedimentais para a prática dos atos processuais sob pena de o procedimento não avançar rumo à solução do litígio.

Em outras palavras, conforme já afirmado, a possibilidade incondicionada e proceduralmente ilimitada de se praticar os atos processuais a que as partes têm direito, implicaria a total impossibilidade de conclusão do feito, que ficaria, a todo momento, sujeito a reviravoltas e retrocessos procedimentais, impedindo o julgamento de mérito e conclusão do processo.

Por esse motivo, e considerando a necessidade de que o processo marche, para frente, rumo a um encerramento, até para que se atinja seu principal objetivo de prestar a tutela jurisdicional, os direitos das partes são, por um lado, garantidos pela Constituição Federal e pela lei, mas, por outro, condicionados a determinados aspectos que, se não obedecidos, implicam a perda do direito.

Um desses aspectos fundamentais é o prazo processual que, quando não obedecido, implica a perda do direito de praticar o ato processual e a ineficácia do ato intempestivo.

Esta é a importância do estudo dos prazos processuais, verdadeira condição de eficácia do ato processual que deve ser praticado dentro do limite temporal estabelecido pelo ordenamento jurídico.

12.6.1 Os prazos processuais no Código de Processo Civil

Até para que se tenha segurança e se respeite o devido processo legal, como regra geral, os prazos para a prática dos atos processuais são estabelecidos em lei, dentre as quais, por óbvio se destaca o Código de Processo Civil.

Isso não impede, contudo, que, em algumas situações, por expressa disposição legal ou por simples falta de lei fixando um prazo, o juiz

estabeleça o prazo processual.

Além disso, o Código de Processo Civil admite que as partes convençionem sobre prazos processuais.

A possibilidade de fixação do prazo por lei, pelo juiz ou pelas partes, permite a classificação dos prazos em: a) legais; b) judiciais; e c) convencionais, conforme se verá no item seguinte.

Os prazos processuais são disciplinados, com detalhes, entre os arts. 218 a 232 do CPC, que se ocupam, precipuamente, de: a) definir as condições para o início da contagem do prazo; b) estabelecer a forma de contagem dos prazos, ou seja, sua fluência; c) regulamentar o vencimento do prazo; d) disciplinar os principais desdobramentos do descumprimento deste prazo, bem como; e) a eventual possibilidade de suspensão e interrupção da contagem dos prazos processuais.

Os itens a seguir se ocuparão de cada um destes detalhes, sendo certo que, antes de adentrar nestas questões, cumpre esclarecer alguns pontos ligados, especificamente, à classificação dos prazos processuais, que, conforme se verá a seguir, podem ser de várias espécies.

12.6.2 Classificação dos atos processuais

A depender de alguns fatores, os prazos processuais podem ser classificados em: a) legais, judiciais e convencionais; b) dilatórios e peremptórios; c) próprios e impróprios.

a) Classificação segundo a fonte de fixação

Como regra geral, os prazos para a prática dos atos processuais são fixados em lei. Todo prazo que estiver estabelecido em lei será classificado como prazo legal.

Inúmeros são os exemplos de prazos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, dentre os quais se destacam o prazo estabelecido no art. 335, que estabelece 15 dias para apresentação da resposta do réu, e art.

1.003, § 3º, do CPC, que estabelece o prazo de 15 dias para a interposição de recurso, ressalvados embargos de declaração.

A fixação de prazos pela lei é a maneira mais simples de se promover a segurança jurídica e a igualdade processual no sentido de que a previsão do prazo em uma norma, de maneira objetiva, geral e abstrata, assegura um tratamento isonômico para todos, além de proporcionar o maior grau de previsibilidade possível.

Contudo, o Código de Processo Civil permite que, em algumas situações, o juiz fixe o prazo, o que permite a classificação destes prazos como prazos judiciais.

Via de regra, o CPC deixa com o juiz a incumbência de fixar o prazo processual quando algumas peculiaridades da situação concreta podem influenciar no tempo minimamente necessário para a atuação das partes ou do auxiliar da Justiça responsável pelo ato.

Nesse contexto, duas situações se destacam: a) as peculiaridades do ato em si mesmo considerado; b) as peculiaridades do local onde o ato deve ser praticado.

Configura um exemplo de prazo judicial que varia de acordo com a peculiaridade do ato em si mesmo considerado a indefinição pela lei do prazo para a apresentação do laudo pericial que, nos termos do art. 465 do CPC, deve ser fixado pelo juiz. Assim, de acordo com a complexidade da perícia a ser realizada, deve o juiz fixar o prazo para que o laudo deva ser apresentado, não havendo prazo legal nesta hipótese.

Já as eventuais dificuldades decorrentes do local onde se desenvolve o processo ou da prática do ato são levadas em consideração, por exemplo, pelo art. 222 do Código de Processo Civil, que dispõe que “na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses”.

Nesta hipótese, em razão das situações excepcionais expressamente

previstas em lei, o juiz pode flexibilizar os prazos legais em função de dificuldades específicas, tais como a dificuldade de transporte na comarca, seção ou subseção judiciária, como em cidades do interior de Estados ou localidades, cujo acesso só se dá por meio de avião ou pela via fluvial, dada a inexistência de malha rodoviária, hipótese em que o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses.

Mais adiante, ver-se-á que situações excepcionais podem, ainda, autorizar a suspensão da contagem do prazo⁴⁶⁵.

Por fim, um outro método de fixação de prazos processuais é por meio de convenção das partes que, além de genericamente poderem pactuar a suspensão do processo⁴⁶⁶, podem, em comum acordo com o juiz, estabelecer um calendário processual para a prática dos atos, predefinindo, portanto, o momento e o prazo para a prática de uma série ou de todos os atos processuais futuros.

Os prazos estabelecidos pelas próprias partes do processo devem ser classificados como prazos convencionais.

Não havendo qualquer prazo específico para a prática de um ato processual fixado em lei, pelo juiz ou convencionado pelas partes, aplica-se subsidiariamente o art. 218, § 3º, do CPC, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a prática de ato processual a cargo da parte.

b) Prazos dilatatórios e peremptórios

Uma classificação consagrada na doutrina e utilizada pelo Código de Processo Civil divide os prazos processuais em dilatatórios e peremptórios.

O critério distintivo, nesta hipótese, é a possibilidade de modificação do prazo, sendo os prazos peremptórios mais rígidos, e os prazos dilatatórios mais flexíveis, no que tange a sua redução ou ampliação.

Nesse contexto, os prazos peremptórios são aqueles que, a priori, não admitem prorrogação, ao passo que os prazos dilatatórios podem ser

modificados, isto é, dilatados pelo juiz.

Cândido Rangel Dinamarco⁴⁶⁷ aduz que a distinção entre os prazos dilatatórios e peremptórios varia de acordo com o grau de imperatividade, sendo peremptórios os prazos absolutos que não admitem variação, e dilatatórios os prazos que comportam reduções ou ampliações.

Contudo, conforme assevera Humberto Theodoro Jr.⁴⁶⁸, o Código de Processo Civil não determinou um critério especial para identificar, dentre os prazos processuais, quais são dilatatórios e quais são peremptórios.

Pode-se afirmar com certo grau de certeza que são peremptórios os prazos para contestar, recorrer e embargar a execução por exemplo⁴⁶⁹, mas, de rigor, tal categorização não decorre de expressa previsão legal, mas, sim, de uma interpretação sistemática.

De outro lado, o prazo para “falar sobre documentos” estabelecido no art. 437, § 1º, do Código, ou para manifestar-se sobre o laudo pericial estabelecido no art. 477, § 1º, do CPC, pode, sem maiores problemas, sobretudo considerando a quantidade de documentos apresentados ou a complexidade do laudo do perito, ser dilatado pelo juiz, sendo exemplos de prazos dilatatórios, portanto⁴⁷⁰.

Ademais, a possibilidade de dilação do prazo, em algumas situações, é expressamente prevista em lei.

É o caso, por exemplo, do art. 334 do Código, que dispõe que “se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”.

Resta claro da leitura do dispositivo que o prazo de vinte dias pode ser majorado pelo juiz sem que possa falar-se em qualquer vício ou nulidade, sobretudo nos casos em que a pauta de audiências do órgão jurisdicional imponha a realização a posteriori dela ou quando a quantidade de sujeitos

envolvidos no litígio imponha maior lapso temporal para que se obtenha uma solução consensual.

A prorrogação de prazos dilatórios pode ser feita pelo juiz, a requerimento da parte interessada, independentemente da concordância do adversário.

Já os prazos peremptórios, como dito, em regra, não admitem flexibilização, assim entendida sua redução ou prorrogação. Nesse sentido, o prazo de 15 dias para recorrer ou para embargar a execução é improrrogável pelo magistrado.

Contudo, a rigidez do prazo peremptório é relativizada pelo Código de Processo Civil, especialmente nos arts. 191 e 222, § 1º, do CPC.

O primeiro artigo citado dispõe sobre a possibilidade de as partes em comum acordo com o juiz estabelecerem calendário para a prática dos atos processuais.

O dispositivo não ressalva a impossibilidade de o calendário dispor sobre prazos peremptórios.

Portanto, eventualmente, ao estabelecerem um calendário com base no art. 191 do CPC, as partes podem modificar eventuais prazos peremptórios⁴⁷¹.

Ademais, o art. 222, § 1º, do CPC admite a redução inclusive de prazos peremptórios desde que o juiz o faça com a anuência das partes, sendo certo que, com apoio neste dispositivo, as partes podem reduzir o prazo peremptório, mas não o dilatar.

Outro ponto que merece ser destacado é a possibilidade de suspensão de prazos por expressa autorização legal, como no caso do art. 222, § 1º, do CPC, que dispõe sobre a suspensão dos prazos por calamidade pública.

Estas hipóteses excepcionais de suspensão implicam consequentemente a prorrogação de prazos, inclusive peremptórios.

Às hipóteses de suspensão dos prazos, será dedicado o item 12.6.5, infra.

c) Prazos próprios e impróprios

Outra forma de classificação dos prazos processuais, consagrada na doutrina e na jurisprudência pátria, opõe os prazos próprios e os prazos impróprios.

Os primeiros implicam, se descumpridos, a preclusão temporal, assim entendida a perda do direito de praticar o ato processual, conforme estabelecido no art. 223 do CPC, ou a ineficácia do ato intempestivo.

Já os denominados prazos impróprios são aqueles que, mesmo se descumpridos, não implicam preclusão ou mais amplamente aqueles cuja inobservância não implica consequência ou efeito processual⁴⁷².

Via de regra, os prazos impróprios estão ligados à atuação do juiz e de seus auxiliares.

Nesse sentido, pode-se afirmar que são impróprios os prazos estabelecidos no art. 226 do CPC, que dispõe que “o juiz proferirá: I – os despachos no prazo de 5 (cinco) dias; II – as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias; III – as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias”, assim como o art. 228, que estabelece que “incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 (um) dia e executar os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias”.

Por serem todos esses prazos categorizados como impróprios, a prática deles pelo juiz e seus auxiliares fora do prazo estabelecido em lei não acarreta impossibilidade ou ineficácia do ato intempestivo.

Entretanto, o fato de não haver preclusão processual para a prática dos referidos atos não implica dizer que o descumprimento dos prazos pelo juiz e seus auxiliares não acarrete nenhuma consequência.

Isso porque, conforme reza o art. 143 do CPC, o juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando “(...) II – recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte”.

Da leitura do dispositivo, nota-se que o atraso deve ser realizado com culpa ou dolo e sem justo motivo.

Ademais, nos termos do art. 235 do Código, “qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei”.

Já os prazos para os auxiliares da Justiça são fiscalizados pelo próprio juiz que, nos termos do art. 233 do Código, deve verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei, hipótese em que, constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma da lei.

De todo modo, o ato processual sujeito a um prazo impróprio nunca será tido por ineficaz mesmo quando praticado fora do prazo, podendo seu descumprimento levar à aplicação de sanções disciplinares ou civis ao juiz ou servidor, mas nunca à impossibilidade de prática ou ineficácia do ato judicial praticado fora do prazo.

Assim, quando, por exemplo, o art. 366 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença deverá ser proferida em audiência ou no prazo de 30 dias após seu encerramento, o descumprimento deste prazo, com a prolação da sentença no 31^o ou 50^o dia após a audiência, não implica nulidade ou invalidade do ato decisório.

Já o prazo próprio de 15 dias para interposição, pela parte, do recurso de apelação, estabelecido no art. 1.003, § 5^o, do Código, deve ser cumprido, sob pena de preclusão, o que implica dizer que uma apelação interposta no 16^o dia não será conhecida, pois tida como absolutamente ineficaz.

Conforme já asseverado, situações excepcionais podem autorizar a prorrogação de prazos próprios para as partes e até impróprios para o juiz, senão para ressalvar a eficácia do ato, o que seria desnecessário, dada a ausência de preclusão, para resguardar o magistrado ou serventuário de

eventuais sanções civis ou administrativas.

Nesse contexto, merece destaque o art. 227, que estabelece que “em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido”.

12.6.3 Fluência e contagem dos prazos processuais

Fundamental para a marcha dos prazos processuais é a definição clara e precisa do momento em que estes começam a ser contados, bem como a forma desta contagem.

Nesse sentido, é imprescindível a definição de três pontos: a) o termo inicial (*dies a quo*); b) o termo final (*dies ad quem*); e c) a fluência.

Por termo inicial, deve ser entendido o marco temporal expressamente estabelecido em lei como o momento do início do prazo processual.

O termo inicial é, via de regra, o ato de comunicação processual, ou mais amplamente a ciência pelas partes, ou um ato de movimentação como, por exemplo, a carga dos autos pela parte ou a “conclusão” dos autos para o juiz.

Em síntese, como regra, o termo inicial dos prazos processuais pressupõe a prévia ciência da parte, o que se dá pelos atos de citação, intimação ou qualquer outro ato que implique a ciência inequívoca da parte dos atos e termos do processo, como a “vista” ou “carga” dos autos do processo.

A citação, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, o que, por sua vez, pode dar início à contagem do prazo para apresentação das respostas do réu nos casos previstos no art. 335, inc. III, do CPC.

A intimação, conforme o art. 269 do CPC, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Outros atos processuais, por implicarem inequívoca ciência da parte e,

inclusive, dispensar a intimação, podem estabelecer o termo inicial do prazo processual.

Nesse sentido, são atos que marcam o termo inicial do prazo para as partes a “vista dos autos”, “a carga dos autos”.

Ademais, dos atos praticados em audiência as partes saem dela intimadas, o que implica dizer que eventuais prazos dali decorrentes têm, por termo inicial, a própria data da audiência.

Assim, por exemplo, nos termos do art. 335, inc. I, do CPC, o termo inicial para o réu oferecer contestação será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

Já os prazos para o juiz, via de regra, decorrem da conclusão dos autos ao seu gabinete ou da própria audiência por ele presidida.

É importantíssima para a compreensão da contagem dos prazos a distinção entre o termo inicial e o início da contagem do prazo.

Conforme dito, termo inicial é o marco temporal indispensável para que se dê início à contagem do prazo, sendo certo que a contagem propriamente dita só será realizada a partir do primeiro dia útil seguinte ao termo inicial.

Nesse sentido, dispõe o art. 224 do Código de Processo Civil, que “salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. Neste contexto, por “dia do começo” deve ser entendido o “termo inicial”.

Assim, por exemplo, caso a intimação ocorra em uma terça-feira, o início da contagem do prazo de 15 dias se dará no dia seguinte, quarta-feira, salvo se esta for feriado, assim como, caso a intimação se realize em uma sexta-feira, a contagem do prazo só terá início na segunda-feira seguinte.

Ademais, uma vez iniciada a contagem dos prazos processuais, só serão

considerados os dias úteis conforme dispõe o art. 219 do Código de Processo Civil.

Para todos os efeitos não se consideram dias úteis, conforme deixa claro o art. 216 do CPC, todos os feriados declarados por lei, assim como os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.

Tão importante quanto dar início e computar os prazos processuais é estabelecer seu vencimento (termo final do prazo) até porque, especialmente no que tange aos prazos próprios, o seu descumprimento implica a perda do direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial a teor do art. 223 do CPC.

O termo final do prazo, é isto, o dia de seu vencimento é último dia da contagem podendo ser o prazo prorrogado para o primeiro dia útil seguinte se, neste dia, o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica no caso dos atos processuais eletrônicos.

A prática do ato processual deverá observar o horário de expediente forense ou o horário das 23h59 se o ato tiver de ser praticado eletronicamente.

O sistema processual, contudo, minimiza a consequência da perda do prazo caso fique comprovado que seu descumprimento se deu por justa causa, assim entendido um obstáculo ou evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, tais como um acidente ou mal súbito do advogado ou procurador responsável pela prática do ato no dia do vencimento do prazo.

No caso dos atos processuais eletrônicos, considera-se justa causa o problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, conforme deixa claro o art. 197 do Código.

Nos termos do § 2º do art. 223 do Código de Processo Civil, verificada a

justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar, evento denominado na prática forense como “devolução de prazo”.

12.6.4 Prazos especiais

Quatro dispositivos do CPC estabelecem prazos especiais a serem contados em dobro.

Três das hipóteses de prazo em dobro incidem quando presentes na relação processual determinados sujeitos específicos: o Ministério Público, a Fazenda Pública, a Defensoria Pública.

A quarta hipótese é prevista no art. 229 do Código, que concede prazo em dobro aos litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos.

Assim, nos termos dos arts. 180, 183 e 186 do CPC, o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública, respectivamente, possuem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

Uma outra peculiaridade no que diz respeito ao prazo para a prática de atos processuais por estes entes diz respeito ao termo inicial, uma vez que os membros das referidas Instituições possuem a prerrogativa de serem intimados pessoalmente conforme determinado pelos arts. 180, 183 e 186, § 1º, do CPC.

Portanto, ao contrário das demais partes do processo, cujo termo inicial do prazo se dá por qualquer ato de ciência, notadamente intimações por publicação em meio eletrônico ou órgão oficial, o prazo contra os referidos entes depende de uma intimação pessoal, por oficial de justiça, carga, vista dos autos ou por meio eletrônico.

Ademais, nos termos do art. 229 do CPC, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Três pontos merecem destaque no que diz respeito a este prazo em dobro.

O primeiro deles é o de que este prazo só tem lugar se os litisconsortes tiverem procuradores diferentes e de escritórios de advocacia distintos, possuindo, portanto, prazo simples os litisconsortes representados pelo mesmo advogado ou escritório de advocacia.

Além disso, cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo dois réus, é oferecida defesa por apenas um deles, ou seja, se apenas um dos litisconsortes estiver efetivamente representado por advogado nos autos do processo, hipótese em que o único prazo em dobro será o da resposta.

Ademais, nos termos do § 2º do próprio art. 229, não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos em função da disponibilidade ampla e irrestrita dos autos do processo para todos os advogados simultaneamente.

O termo inicial para a contagem do prazo para os litisconsortes, tenham ou não procuradores diferentes, deve ser contado de maneira independente (art. 231, § 2º, do CPC), exceção feita ao prazo de respostas dos réus que apenas tem início após a intimação do último dos litisconsortes por expressa determinação do art. 231, § 1º, do Código.

Assim, o prazo para a apresentação de respostas do réu, em caso de litisconsórcio passivo, termina para todos no mesmo dia, independentemente de terem ou não procuradores diferentes, razão pela qual o referido prazo é classificado como prazo comum.

12.6.5 Suspensão e interrupção dos prazos processuais

Além de apenas serem considerados os dias úteis na contagem dos prazos processuais, determinados eventos e situações expressamente previstos em lei influenciam a contagem do prazo processual, suspendendo ou interrompendo sua fluência.

São as denominadas hipóteses de suspensão e interrupção de prazos processuais.

A distinção entre a suspensão e interrupção do prazo é relevante, dado que, no primeiro caso, findo o período de suspensão, o prazo volta a correr pelo período restante, ou seja, computando-se os dias que decorreram entre o início da contagem e a suspensão.

Já a interrupção do prazo implica a sua contagem pela totalidade quando da volta de sua fluência, sendo indiferente a quantidade de dias decorridos entre o início da contagem e a interrupção.

Assim, por exemplo, se um prazo de 15 dias for suspenso após decorridos 10 dias úteis de seu início, finda a suspensão, a parte tem o prazo restante, neste caso, de cinco dias para praticar o ato. Se o mesmo prazo de 15 dias for interrompido no décimo dia da contagem, ao fim da interrupção o prazo será totalmente reestabelecido, ou seja, a parte terá os mesmos 15 dias originais.

A interrupção de prazo é prevista, por exemplo, no art. 1.026 do Código, que estabelece que “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso” e no art. 1.044, § 1º, do CPC, que dispõe que “a interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes”.

Já a suspensão dos prazos processuais é mais comum e prevista em diversos dispositivos da seção do Código dedicada aos prazos, tais como os arts. 220 e 221, a seguir comentados.

Ademais, influencia diretamente a contagem dos prazos processuais a suspensão do processo, assim entendida a paralisação do prosseguimento do processo com a consequente impossibilidade de prática de atos processuais, pois, exatamente em função da inviabilidade de se praticar atos processuais, fica impedida a contagem do prazo para a prática destes

atos.

Portanto, são causas de suspensão dos prazos processuais: a) todas as hipóteses de suspensão do processo nos termos do art. 313 do CPC⁴⁷³; b) a existência de obstáculo criado em detrimento da parte (art. 221 do CPC); c) o recesso forense compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive (art. 220 do CPC); d) o período de execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição (art. 221, parágrafo único, do CPC).

Desta feita, em primeiro lugar, suspende-se a contagem dos prazos processuais nas seguintes hipóteses de suspensão do processo ("a"): I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II – pela convenção das partes; III – pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV– pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V – quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI – por motivo de força maior; VII – quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do tribunal marítimo; todas arroladas no art. 313 e analisadas no item 11.3.

Ademais, sempre que for caracterizado um obstáculo em detrimento da parte ("b"), o art. 221 do Código autoriza a suspensão do prazo.

São exemplos de obstáculos ensejadores da suspensão do prazo com base nesta regra o fato de os autos estarem "desaparecidos" ou em carga com algum outro sujeito, bem como na hipótese de estes autos estarem erroneamente conclusos e, portanto, em poder do juiz, o que impede a parte de ter acesso a eles e praticar os atos processuais.

Por fim, outros dois eventos suspendem a contagem dos prazos

processuais: o recesso forense ("c") e a suspensão determinada pela execução de programas de autocomposição promovidos pelo Poder Judiciário ("d").

O recesso forense é o período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro em que o Judiciário, por expressa autorização legal, não é aberto ao público, o que, portanto, inviabiliza a prática de atos processuais e consequentemente da contagem dos prazos.

Ademais, admite-se a suspensão dos prazos processuais durante a realização de programas destinados a promover a autocomposição que devem ser realizados pelos tribunais nos termos genericamente previstos no art. 165 do Código.

Verifica uma das hipóteses anteriores, a fluência do prazo durante o período em que se configura a motivação da suspensão não ocorre, sendo necessária a cessação da causa suspensiva para que o prazo volte a correr.

Além disso, conforme já asseverado, os prazos que vencerem em dia que não houver, por qualquer motivo, expediente forense ou que este se inicie posteriormente ou se encerre mais cedo do que o normal, têm o seu vencimento prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o que não chega a ser uma causa de suspensão, mas, apenas, uma prorrogação do prazo.

12.6.6 Descumprimento dos prazos processuais e preclusão

O descumprimento dos prazos processuais acarreta consequências sérias e negativas, sobretudo se o prazo desrespeitado for estabelecido contra a parte e, portanto, classificado como próprio.

Isso porque, salvo a já comentada ocorrência de justa causa, o art. 223 do CPC estabelece que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial.

O fenômeno denominado preclusão temporal, em última análise, implica, quando configurada a perda do direito da parte de praticar o ato processual

ou a ineficácia do ato praticado após sua ocorrência.

Nesse contexto, considerando, por exemplo, que o prazo do recurso de apelação é de 15 dias, o fim deste período sem sua apresentação implica a perda do direito de recorrer. Igualmente, uma apelação apresentada após o referido prazo não gera os efeitos que comumente dela se espera, qual seja, viabilizar a reanálise da decisão, uma vez que, por força da intempestividade, o recurso é ineficaz e não será conhecido.

A par da preclusão temporal, o sistema processual também estabelece a perda do direito de praticar um ato e exercer um direito no processo por força da preclusão consumativa e da preclusão lógica.

Ambas, como toda preclusão, implicam a perda de um direito, mas, ao contrário da preclusão temporal, tal perda ocorre, não por força do decurso de um prazo processual, mas em razão de outros fatores.

A preclusão consumativa decorre da própria prática do ato ou exercício do direito que, uma vez exercido, esgota e consome a possibilidade de fazê-lo ou de refazê-lo, ainda que dentro do prazo.

Em outras palavras, a prática do ato processual em um menor prazo, por si só, leva à perda do direito de praticá-lo novamente, mesmo que restem alguns dias para seu vencimento.

Assim, por exemplo, se a parte apresenta a contestação, cujo prazo é de 15 dias, no 11^o dia do prazo, esta apresentação gera a preclusão consumativa que implica a perda do direito de a parte contestar ou modificar a contestação apresentada, ainda que dentro dos quatro dias restantes.

Já a preclusão lógica se caracteriza pela prática de um ato incompatível com o posterior exercício de um direito processual, como a perda do direito de recorrer quando a parte renuncia ao recurso ou expressamente aceita a decisão.

Em outras palavras, a parte, uma vez aceitando expressamente a

decisão, perde o direito de recorrer, ainda que “dentro do prazo” genericamente estabelecido.

Uma situação próxima a esta ocorre quando a parte, com base na autorização prevista no art. 225 do CPC, renuncia expressamente o prazo estabelecido em seu favor.

Nesta hipótese, o ato de “renúncia ao prazo” por si só, antes mesmo de sua fluência e vencimento, implica a perda do direito de praticar o ato processual.

Capítulo 13 Nulidades do Processo e dos Atos Processuais

13.1 Generalidades

Uma vez estudados os requisitos formais para a prática válida e regular dos atos processuais pelos sujeitos do processo, é necessário voltar-se à análise das consequências processuais nas hipóteses de inobservância desses requisitos, ou seja, quais as implicações e sequelas para o processo do desrespeito das regras de forma e demais condições para a prática dos atos processuais.

Tal estudo é sistematizado pela análise das nulidades do processo e dos atos processuais, e encontra-se regulamentado no Código de Processo Civil, entre os arts. 276 e 283.

O estudo das nulidades pode ser dividido em três grandes grupos de questões.

O primeiro se refere à identificação dos defeitos, que, uma vez existentes, implicam invalidade do ato processual.

Um segundo grupo de questões ocupa-se da classificação das nulidades, sendo certo que nem todos os desrespeitos aos requisitos formais de validade têm os mesmos impactos no processo e, portanto, o mesmo tratamento quando da declaração de invalidade do ato.

O terceiro grupo de questões volta-se à análise das consequências da declaração de nulidade do ato processual nos demais atos do processo que, porventura, tenham sido praticados.

Os itens a seguir se dedicarão ao estudo de cada um desses grupos.

13.2 Caracterização das nulidades

Os fatores determinantes para a decretação da nulidade de um ato

processual, de rigor, já foram estudados, notadamente nos Capítulos 10 e 12.

Isso porque as condições para que um ato venha a ser considerado válido são exatamente o respeito: a) aos pressupostos processuais de validade (Capítulo 10); e b) aos requisitos formais para a prática de todo e qualquer ato processual analisado no capítulo anterior.

Assim, as condições que devem ser observadas para que o ato processual seja considerado válido são exatamente: a) em relação ao juiz, sua competência para análise da causa e imparcialidade; b) em relação às partes, a capacidade de ser parte, a capacidade processual de estar em juízo, a capacidade postulatória; e, além disso, c) para todos os sujeitos do processo, a observância da forma prescrita em lei, o uso do vernáculo ou a tradução do ato para o português; e o respeito às regras de tempo e lugar para a prática dos atos processuais.

Além desses requisitos genéricos, comuns a todos os atos processuais, a lei pode estabelecer outros requisitos específicos para a prática de determinados atos, a exemplo dos já citados arts. 319 e 320, que disciplinam a forma da petição inicial, e do art. 489, que disciplina os requisitos formais da sentença.

É a desobediência a esse conjunto de regras estabelecidas pelo Código como condição de validade do processo e da prática de atos processuais que leva a alguma forma de invalidade ou nulidade dos atos processuais, sendo certo que, a depender da regra desobservada o sistema atribui diversos graus de nulidade e, por via de consequência, diferentes efeitos processuais nos termos a seguir estudados.

13.3 Classificação das nulidades

Existem várias formas de se classificar a nulidade dos atos processuais, sendo as aqui tratadas as mais importantes do ponto de vista prático.

a) Nulidades absolutas e nulidades relativas

Uma primeira forma de se classificar as nulidades as divide em nulidades absolutas e nulidades relativas.

Nulidades absolutas seriam as espécies mais graves e praticamente intoleráveis pelo sistema, ao passo que as nulidades relativas são aquelas que, apesar de passíveis de classificação como vícios processuais, por serem menos graves, o sistema pode vir a tolerá-las, a depender da situação concreta.

Apesar de ambas serem espécies de um mesmo fenômeno, classificar a nulidade como absoluta ou relativa tem diversas consequências processuais.

Isso porque as nulidades absolutas, por serem tidas como muito graves pelo sistema processual, via de regra, contaminam todo o processo bem como a decisão de mérito nele proferida, salvo, conforme se verá adiante, se o ato absolutamente nulo atingir sua finalidade e não causar prejuízo.

Já as nulidades classificadas como relativas, por serem menos graves, caso não arguidas no momento adequado, convalidam-se, ou seja, os atos relativamente nulos passam a ser considerados válidos apesar do vício.

Como decorrência dessa distinção, o regime de verificação e decretação das nulidades difere a depender se a nulidade é absoluta ou relativa.

Nas nulidades absolutas, a uma pela gravidade do vício e, a duas, pela sua vocação de contaminar todo o processo e tornar nula inclusive a decisão judicial, o sistema não só autoriza, como determina que sejam elas decretadas inclusive de ofício pelo juiz, independentemente de provocação da parte interessada, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Portanto, as nulidades absolutas são matérias de ordem pública⁴⁷⁴ e, por isso, devem ser verificadas e decretadas de ofício pelo juiz.

Já as nulidades relativas não devem ser decretadas pelo juiz de ofício e, caso não arguidas pela parte prejudicada e na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, importam na convalidação do ato processual

relativamente nulo, o que, em outras palavras, implica dizer que o sistema tolera sua existência.

Essa distinção resta clara da leitura do art. 278 do Código de Processo Civil, que em seu caput dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, assim entendida a perda da oportunidade de essa arguição ser realizada em outro momento.

Entretanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo diz: “não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício”.

Portanto, é possível concluir que a regra constante do caput do art. 278 se aplica às nulidades relativas, ao passo que o parágrafo único do dispositivo deixa clara a ressalva no que tange às nulidades absolutas, na expressão do Código “aquelas que o juiz deve decretar de ofício”.

Nesse sentido, a lição de Teresa Arruda Alvim, autora de uma das principais obras sobre o tema⁴⁷⁵, ao asseverar que “é necessário que se identifique o vício e que este vício seja classificado, para que se possa saber qual seu regime jurídico. Pela expressão regime jurídico, ainda segundo a autora⁴⁷⁶, devem ser entendidas as “regras que dizem respeito à possibilidade de decretação de ofício e à preclusão”.

Contudo, não obstante a importância da distinção entre nulidades absolutas e relativas, o sistema processual, salvo raras exceções, não discrimina expressamente quais as nulidades absolutas e quais as nulidades relativas, cabendo, em grande medida, à doutrina e à jurisprudência essa distinção e a sistematização desses dois grupos.

Apesar de haver uma tendência doutrinária no sentido de que a regra geral seja a categorização da nulidade como nulidade relativa, é certo que um grande grupo de vícios processuais deve ser classificado como nulidades absolutas, atraindo, por via de consequência, não apenas a possibilidade de verificação de ofício pelo juiz bem como sua arguição e decretação em

quaisquer tempo e grau de jurisdição, como também acarretando sérias consequências aos demais atos processuais subsequentes e ao próprio processo e seu produto final, a tutela jurisdicional.

Assim, com certa margem de certeza, pode-se afirmar que são nulidades absolutas: a) os vícios relacionados aos pressupostos processuais, como a imparcialidade do juiz e falta de capacidade postulatória; b) a ausência de uma das condições da ação; c) o desrespeito aos princípios e regras constitucionais do processo, como a motivação e o contraditório; d) todos os demais vícios aos quais a lei expressamente comina a pena de nulidade absoluta em caso de descumprimento de seu comando, como nos casos dos arts. 279 e 280 do Código de Processo Civil.

Em todas essas situações, ainda que a lei ou norma constitucional não preveja expressamente a cominação de nulidade, ou o faça sem esclarecer que se trata de uma nulidade absoluta, a interpretação sistemática permite concluir tratar-se de nulidades absoluta, podendo ser decretada em quaisquer tempo e grau de jurisdição, por provocação da parte interessada ou até mesmo de ofício pelo juiz.

Assim, por exemplo, apesar de o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, estabelecer que “toda decisão judicial deva ser motivada, sob pena de nulidade”, sem, entretanto, deixar claro qual espécie de nulidade originada, é imperioso concluir que uma decisão judicial que desrespeite essa norma constitucional está eivada de nulidade absoluta.

Situação ainda menos explícita ocorre com a norma prevista no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, que estabelece que todos têm o direito ao contraditório e ampla defesa, sem sequer determinar expressamente que as decisões praticadas sem o prévio contraditório são nulas, o que não impede o intérprete concluir, a partir de uma leitura sistemática, que o desrespeito ao contraditório gera uma nulidade absoluta do processo e das decisões judiciais nele proferidas.

O mesmo ocorre com os vícios relacionados às condições da ação e aos

pressupostos processuais que, por impedirem o exame do mérito e contaminarem o julgamento de mérito indevidamente realizado, são nulidades absolutas decretáveis em quaisquer tempo ou grau de jurisdição, de ofício ou a requerimento da parte interessada.

Por fim, caso a lei expressamente defina a situação ou vício como grave e classifique-o como nulidade absoluta, saber-se-á, de antemão e com segurança que o regime aplicável por ocasião da verificação do vício será esse.

A lei assim o faz, por exemplo, nos casos de citações e intimações, atos de comunicação processual, importantíssimos não apenas para que as partes tenham ciência da existência ou do andamento do processo, como também para abertura da contagem dos prazos processuais.

Nesse sentido, o art. 280 do Código de Processo Civil deixa claro que “as citações e intimações serão nulas, quando feitas sem a observância das prescrições legais”.

Já as nulidades relativas têm um outro regime jurídico, diretamente oposto ao das nulidades absolutas, sobretudo porque: a) não podem ser verificadas e declaradas de ofício pelo juiz, pois dependem de provocação da parte; b) caso não arguidas pela parte na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, operara-se a preclusão e ocorre a convalidação do ato relativamente nulo.

Por convalidação deve ser entendido o fenômeno de transformação e aceitação como válido de um ato, a princípio, relativamente nulo por força da ausência de provocação da parte e consequente caracterização da preclusão.

Portanto, quando a nulidade é relativa, aplica-se o art. 278, caput do Código de Processo Civil que dispõe que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

A melhor fórmula para verificar se a nulidade é absoluta ou relativa, portanto, é verificar se o vício do ato impede o exame do mérito e contamina a eventual decisão judicial, pois, nesses casos, estar-se-á diante de uma nulidade absoluta o que, por sua vez, autoriza o juiz a verificar e decretar o vício de ofício.

Por outro lado, se o vício processual não é grave a ponto de impedir o exame do mérito, a nulidade se convalida em caso de não arguição pela parte e, portanto, deve ser classificada como relativa, impedindo o juiz de examiná-la e decretá-la de ofício.

b) Nulidades cominadas e nulidades não cominadas

Outra forma de classificar as nulidades é dividi-las em nulidades cominadas e nulidades não cominadas.

Segundo esse critério classificatório, as nulidades cominadas são aquelas cujo vício está prévia e expressamente estabelecido em lei, ao passo que as nulidades não cominadas não estão expressamente previstas em lei e que, portanto, decorrem de uma interpretação sistemática.

Exemplos do primeiro grupo, para ficar nas nulidades e regras já referidas no item anterior, seriam, a desobediência da forma nas citações e intimações do art. 280 do CPC e a exigência de motivação das decisões judiciais do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal que, por mais que não deixe claro que se trata de nulidade absoluta ou relativa, estabelece expressamente a “pena de nulidade”.

Outras situações ocorrem em que o ato viciado assim o é, apesar de nenhuma norma jurídica estabelecer textualmente que a desobediência de determinado requisito formal implique “pena de nulidade”, mas que, apesar disso, a decretação da nulidade se impõe.

Nesses casos, está-se diante de uma nulidade não cominada.

As nulidades não cominadas, portanto, decorrem sempre de uma

interpretação sistemática à luz de outras regras e, sobretudo, dos princípios do sistema processual ou da própria interpretação a contrario sensu da norma.

É o caso, por exemplo, do art. 492 do Código de Processo Civil, que proíbe o juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado, que, apesar de não cominar expressamente a nulidade, impõe a conclusão no sentido de que é nula a sentença que decide sobre objeto diverso ou extrapola o montante pleiteado.

Rigorosamente, do ponto de vista prático, pouco importa a expressa previsão legal da cominação da nulidade ou o fato de esta ser “não cominada” em lei, haja vista que, conforme demonstrado, a falta de cominação expressa não inviabiliza a decretação da nulidade, que pode decorrer de uma interpretação sistemática.

Entretanto, obviamente, a cominação da nulidade na norma, sobretudo se esclarecer tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, facilita a interpretação e a aplicação do dispositivo, evitando polêmicas na doutrina e na jurisprudência.

c) Nulidades sanáveis e nulidades insanáveis

Outra importante classificação das nulidades refere-se à possibilidade de correção do vício, critério que oporá as nulidades insanáveis e as nulidades sanáveis.

As nulidades sanáveis são aquelas cujo vício, do ato ou do processo, é passível de correção por meio da repetição ou do refazimento do ato viciado, ao passo que as nulidades insanáveis encerram vícios cuja correção se revela impossível.

Exemplos de nulidades insanáveis são a verificação da coisa julgada e perempção, pressupostos processuais negativos que impedem o exame do mérito⁴⁷⁷.

Via de regra, quando verificadas nulidades insanáveis, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485 do CPC.

Até por isso, considerando ser o julgamento de mérito o grande objetivo do processo, sempre que possível, o juiz deve determinar que a parte corrija, ou deve, ele mesmo, corrigir o ato viciado, desde que o vício, obviamente, seja sanável.

Nesse sentido, os vícios podem ser corrigidos pelo próprio juiz ou pela parte interessada, por sua iniciativa própria ou quando determinado pelo magistrado.

Exemplos de vícios processuais que podem e até devem ser corrigidos pelo próprio magistrado são as hipóteses de incompetência absoluta, suspeição e impedimento.

Isso porque, nessas hipóteses, tais vícios, gravíssimos, implicariam a nulidade de todo o processo e das decisões judiciais nele proferidas, cabendo sempre ao magistrado verificar sua própria competência e sua imparcialidade, evitando de ofício, e independentemente de provocação, a prática de atos nulos.

Assim, caso verificado o vício de incompetência absoluta, de suspeição ou de impedimento, deverá o magistrado, independentemente de provocação ou participação das partes, evitar a prática de atos processuais viciados determinando a remessa do processo para um juiz competente e imparcial⁴⁷⁸.

Já em outras situações é imprescindível e de interesse da parte que o vício seja sanado com a sua participação.

É o caso, por exemplo, de um vício relacionado à elaboração da petição inicial, que, conforme já estudado no item 10.3, “c”, enquadra-se como um pressuposto processual de validade, devendo ser a petição inicial apta para que o processo possa se formar e desenvolver-se válida e regularmente.

Portanto, uma primeira conclusão a que se pode chegar é a de que,

identificado um vício de elaboração da petição inicial, o processo não pode avançar regularmente.

Entretanto, por se tratar de um vício passível de correção, a irregularidade da petição inicial exemplifica uma espécie de vício sanável, cabendo, portanto, a possibilidade de correção, obviamente não pelo magistrado, e sim pelo autor sendo este o responsável pela regularidade da petição inicial.

Nessa hipótese específica, portanto, o juiz deverá intimar o autor para corrigir o vício da petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos disciplinados nos arts. 321 e 485 do Código de Processo Civil, já analisados⁴⁷⁹.

13.4 Critérios orientadores da decretação das nulidades

Por mais graves que sejam as nulidades, mesmo as absolutas, sua ocorrência e verificação não implicam, automática e necessariamente, a decretação da anulação do ato.

Isso porque o sistema processual brasileiro estabelece algumas normas que, em última análise, autorizam o aproveitamento dos atos nulos desde que este ato, não obstante viciado, atinja seu objetivo e não cause prejuízo às partes e ao processo.

É nesse sentido que devem ser compreendidas as regras constantes nos arts. 277⁴⁸⁰, 282, § 1º⁴⁸¹ e 283⁴⁸² do Código de Processo Civil que consagram o princípio da instrumentalidade das formas.

Para Cândido Rangel Dinamarco⁴⁸³, um dos principais doutrinadores do tema, o princípio da instrumentalidade das formas é corrente no processo civil moderno, significando o reconhecimento da eficácia do ato processual irregular quando haja atingido o objetivo pelo qual a lei o exige e, de todo modo, sempre que a irregularidade não haja resultado em prejuízo às partes.

Teresa Arruda Alvim, nessa linha, assevera que “as formas são meios

para se atingirem fins. Estes, se atingidos, não fazem com que a ausência de atenção à forma gere nulidade”⁴⁸⁴.

No mesmo sentido, Antônio do Passo Cabral⁴⁸⁵ ensina que “o maior princípio, aquele de maior importância na teoria das nulidades sem sombra de dúvida é o princípio da instrumentalidade das formas. Segundo esta máxima, os atos processuais não serão nulos se, mesmo praticados de outra maneira, atingirem seus objetivos. Os atos irregulares por inobservância da forma somente serão pronunciados nulos se seu objetivo não tiver sido alcançado. Vale dizer, nem sempre um ato defeituoso será invalidado”.

Assim, sempre que detectado o vício do ato processual, o juiz, antes de reconhecê-lo e decretar a nulidade, deve verificar se o ato atingiu sua finalidade, apesar da irregularidade formal.

Um bom exemplo é o caso da citação, um dos atos mais importantes para o processo, uma vez que fundamental para sua própria formação válida e regular, e até por isso, um ato extremamente formal regulado por nada menos do que 22 artigos do Código, mas que, ainda que irregular, não precisa ter essa nulidade decretada se atingir sua finalidade precípua, que é dar ciência ao réu da existência da relação processual e oportunizar sua participação no processo.

Em outras palavras, apesar de o vício da citação ser uma espécie de nulidade absoluta que contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive o julgamento de mérito que torna-se nulo caso demonstrada nulidade do ato citatório, caso a citação formalmente viciada e em desacordo com as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil atinja sua principal finalidade, essa nulidade da citação não precisará ser decretada.

Portanto, caso o réu, apesar do vício do ato citatório, compareça ao processo e apresente defesa sem sofrer, assim, qualquer prejuízo, o vício de

citação não precisará ser decretado e nenhum ato subsequente será tido como contaminado.

A máxima expressão do princípio da instrumentalidade encontra-se prevista no art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe que “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”.

Um outro princípio orientador da decretação das nulidades está esculpido no art. 276 do Código de Processo Civil que dispõe: “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”.

Assim, não é dado à parte causadora do vício processual, posteriormente, pretender arguir a nulidade em seu favor.

Nesse sentido, por exemplo, não poderia o próprio autor, ao sentir que o mérito do processo está prestes a ser julgado em seu desfavor, alegar a inépcia da petição inicial por ele mesmo apresentada, como também não é dado ao réu pretender a extinção do processo por irregularidade de sua própria capacidade processual ou capacidade postulatória, até porque, nessas hipóteses, os atos nulos seriam apenas os praticados pelo próprio réu, e não todos os atos do processo.

Em suma, em função dos princípios do aproveitamento (art. 282, § 1º, e art. 283), da instrumentalidade das formas (art. 277) e da proibição de alegação da nulidade em favor da parte que lhe deu causa (art. 276), o magistrado, antes de decretar a nulidade do ato, deve considerar: a) se o ato atingiu a finalidade; b) se o ato nulo não causou prejuízo à parte ou ao processo; c) se a nulidade beneficiaria a parte que lhe deu causa.

Ausente o prejuízo e tendo sido atingida a finalidade do ato, o sistema processual orienta o magistrado a aproveitar o ato nulo não determinando o seu refazimento ou decretando sua nulidade.

13.5 Normas orientadoras das consequências da decretação das nulidades sobre os demais atos do processo

Além de definir, com base nos critérios normativos já elencados, acerca da decretação ou não da nulidade em função da irregularidade do ato processual, cabe ao magistrado decidir de que forma a anulação de um ato processual repercute nos demais atos do processo, conforme expressamente determinado pelo art. 282 do Código de Processo Civil que dispõe que “ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.

Para essa definição, dois princípios, aparentemente contraditórios, devem ser levados em consideração pelo magistrado toda vez que este decida por anular um determinado ato processual: a) o princípio do aproveitamento; e b) o princípio da contaminação.

Tais princípios decorrem do fato de o procedimento ser uma sequência concatenada de atos processuais interdependentes, o que implica dizer que, a prática de um determinado ato processual viabiliza e influencia a prática de atos subsequentes.

Assim, todas as vezes que se decreta a nulidade de um ato processual, resta saber em que medida os atos praticados posteriormente ao ato nulo são atingidos por essa nulidade ou se podem ser aproveitados.

A análise do magistrado, nesses casos, deve ser focada na dependência ou independência dos atos processuais subsequentes em relação àquele declarado nulo.

Nesse sentido, se o ato posterior tiver uma relação direta de dependência com aquele declarado nulo, tais atos subsequentes serão atingidos pela nulidade do ato antecedente e terão de ser, na mesma decisão, também declarados nulos.

É o caso, por exemplo, do reconhecimento da nulidade da citação que,

por razões óbvias, atinge todos os atos subsequentes prejudiciais ao réu não regularmente citado, tais como a decretação da revelia, audiência sem a sua participação e eventual sentença de procedência da demanda.

Trata-se de uma típica hipótese de aplicação do princípio da contaminação consagrado na primeira parte do art. 281 do Código de Processo Civil, assim redigida: “anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam”.

Por outro lado, caso o ato declarado nulo não tenha nenhuma relação com alguns atos posteriores, dada esta independência, não haverá a decretação da nulidade desses atos posteriores, aplicando-se o princípio do aproveitamento, nos termos do art. 281 segunda parte, verbis “a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”.

Assim, caso a intimação de uma das testemunhas tenha sido realizada com inobservância às prescrições legais, não haverá necessidade de decretação de nulidade de todos os atos processuais subsequentes pelo só fato de terem sido, posteriormente, praticados outros atos no curso do procedimento, como a juntada de um laudo pericial ou uma inspeção judicial.

Nessas hipóteses, os únicos atos que precisariam ser retificados seriam a própria intimação da testemunha e a eventual audiência de instrução.

13.6 Dinâmica da verificação e declaração da nulidade dos atos processuais

Considerando todas as variantes que podem influenciar a decretação da nulidade dos atos processuais, é importante que o juiz e as próprias partes realizem esta verificação em algumas etapas.

A primeira etapa seria a identificação do vício e a categorização da nulidade em absoluta ou relativa, dada a extrema distinção entre as duas espécies.

Isso porque, enquanto as nulidades absolutas podem ser verificadas e declaradas de ofício em quaisquer tempo e grau de jurisdição, as nulidades relativas só podem ser verificadas e decretadas por provocação da parte.

Ademais, não arguidos pela parte interessada, os atos processuais eivados de vícios classificados como nulidade relativa se convalidam, o que implica dizer que um ato relativamente nulo, quando não atacado tempestivamente, torna-se válido. Por outro lado, as nulidades absolutas nunca se convalidam e podem ser detectadas em qualquer momento do processo.

Após a verificação da nulidade e consideração acerca da sua natureza, o terceiro passo do magistrado deve ser analisar se, apesar de viciado, o ato processual atingiu sua finalidade.

Isso porque, independentemente da espécie de nulidade, se relativa ou absoluta, caso o ato processual viciado haja atingido sua finalidade e não causou prejuízo algum às partes e ao processo, a nulidade não deve ser decretada nos termos dos arts. 277 e 282, § 1º, do CPC.

Assim, mesmo quando detectada a irregularidade formal, o juiz não deve decretar a nulidade do ato se este atingiu sua finalidade e não causou prejuízo às partes.

Uma vez verificado que a nulidade ocorreu e que, em função disso, a finalidade do ato não foi atingida, o juiz deve decretar a nulidade se houver provocação da parte ou a possibilidade de decretação de ofício, nos casos de nulidade absoluta.

Ao decretar a nulidade, o passo subsequente deverá ser verificar e declarar que atos processuais posteriores ficaram contaminados e, portanto, devem igualmente ser declarados nulos, bem como verificar quais atos processuais subsequentes podem ser aproveitados por não estarem diretamente vinculados ao ato nulo.

Por fim, deve o magistrado classificar a nulidade como sanável ou

insanável para, a partir dessa classificação: a) determinar a correção do vício e o refazimento do ato, caso a nulidade seja sanável; ou b) extinguir o processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, sempre que os vícios forem sanáveis, deverá o juiz no ato de decretação da nulidade, ordenar as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados, conforme determinado pelo art. 282 do Código de Processo Civil.

Nas hipóteses de nulidades insanáveis, o magistrado deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil⁴⁸⁶.

Capítulo 14 Os Custos Financeiros do Processo

14.1 Generalidades

Como costuma ocorrer com toda atividade humana, a atividade jurisdicional gera custos, sendo papel do Direito Processual Civil disciplinar a responsabilidade pelo pagamento destes valores.

Os custos do processo decorrem das atividades desenvolvidas: pelo próprio Poder Judiciário, por intermédio de seus membros, juízes e servidores; por outros sujeitos, auxiliares eventuais do juízo, como peritos, tradutores e intérpretes; e pelos advogados das partes, indispensáveis para a efetiva participação destas na atividade processual.

De rigor, portanto, é possível classificar os custos do processo em três grandes categorias: a) os valores devidos ao próprio Poder Judiciário em função da atividade jurisdicional; b) os honorários advocatícios devidos aos advogados das partes; e c) outras despesas processuais, assim entendidos outros custos decorrentes da participação de terceiros que eventualmente venham a colaborar com o Poder Judiciário.

O estudo dos custos do processo também deve englobar a questão relativa à impossibilidade de algumas pessoas arcarem com tais valores em função de suas condições econômicas, fator que não pode implicar vedação do acesso à Justiça ou impossibilidade de exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Por essa razão, nesta hipótese, o sistema processual admite a possibilidade de concessão de “Justiça gratuita”, o que, em última análise, importa na possibilidade de dispensa de recolhimento dos valores incidentes a título de custas judiciais, honorários e demais despesas.

Ademais, por expressa disposição legal, determinados sujeitos litigantes, por serem entes públicos, possuem regime diferenciado de tratamento no

que diz respeito ao pagamento de custas de demais despesas processuais e, por isso, merecerão destaque em item apartado.

Desta feita, os itens a seguir se ocuparão de cada uma das modalidades de custos do processo, taxas judiciais, honorários advocatícios e demais despesas processuais, no que serão seguidos do estudo sobre a gratuidade da Justiça e sobre o tratamento diferenciado dado aos órgãos estatais, quando litigantes.

14.2 Custas judiciais

A primeira categoria de custo aqui estudada são as custas judiciais devidas ao Estado ou, mais precisamente, ao Poder Judiciário.

Em primeiro lugar, faz-se necessário destacar que possuem natureza de taxa, uma espécie de tributo.

Tributo, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional, é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais adiante, o mesmo CTN, em seu art. 77, define como taxas os tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Nesse sentido, é correto concluir-se que as custas judiciais são uma espécie de taxa incidente pelo usuário do “serviço público” jurisdicional. Portanto, trata-se dos valores devidos ao Estado por aquele que se vale do serviço jurisdicional.

A natureza tributária das custas atrai a incidência de determinadas regras de Direito Tributário que precisam ser observadas para que as taxas sejam consideradas devidas.

Nesse contexto, a principal consequência da classificação das custas

judiciais como taxas é a necessidade de estarem prévia e expressamente previstas em lei, por decorrência do princípio da legalidade estrita típica do Direito Tributário.

A lei deve, portanto, definir todos os seus contornos, isto é, hipóteses de incidência, quantificação e forma de recolhimento.

Em contrapartida, a inexistência de lei determinando o recolhimento da taxa implica a impossibilidade de sua cobrança ou exigência por qualquer outro meio normativo, como regimento interno dos tribunais, portarias ou regulamentos infralegais.

A lei que rege a incidência e disciplina os contornos das taxas judiciais não é o Código de Processo Civil, nem sequer necessariamente uma lei federal. Isso porque as custas devidas ao Poder Judiciário dos Estados devem ser previstas e reguladas por uma lei estadual, editada por cada Estado-membro da federação.

Nesse sentido, cada Estado possui a sua lei de custas, cujo objeto é instituir e disciplinar as custas devidas à Justiça estadual.

A lei federal disciplina as custas dos processos perante as Justiças administradas pela União (Justiça federal comum, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça federal militar), bem como perante os tribunais superiores.

Assim, por exemplo, a lei que as disciplina no âmbito da Justiça federal é a Lei n. 9.289/96, que “dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça federal de primeiro e segundo graus”.

Portanto, não há uma regra geral preestabelecida e válida para todo o território nacional que institua a incidência de custas e seu respectivo valor para a prática de determinado ato processual aplicável a todos os processos em todas as “Justiças”, podendo haver variação de acordo com o Estado da federação.

Por essa razão, a existência de custas quando da interposição do recurso

de agravo de instrumento, por exemplo, poderá variar, sendo incidente na Justiça federal e em alguns Estados e não incidentes em outros por ausência de previsão legal no âmbito da lei de custas das unidades federativas.

Como se está diante do regime da estrita legalidade, característica do Direito Tributário, a não previsão de incidência das custas em lei implica a impossibilidade de sua cobrança, conforme já asseverado.

A par de estabelecer a incidência das taxas judiciais, cada lei voltada a instituir e regulamentar as custas deve também disciplinar a forma de se calcular o seu valor, podendo definir um valor fixo ou, como é mais comum, estabelecer um percentual incidente sobre o valor da causa.

Contudo, para evitar a existência de custas em valores exorbitantes, que dificultem ou mesmo impeçam a prática de um ato processual ou até o ajuizamento de uma ação, os valores devidos a título de custas devem possuir um teto máximo, que caso ultrapassado quando do cálculo do valor não precisa ser recolhido.

Assim, por exemplo, a Lei n. 9.289/96, ao estabelecer os valores devidos na primeira e na segunda instâncias da Justiça federal, determina que “as custas de ajuizamento das ações cíveis em geral deverão ser equivalentes a um por cento sobre o valor da causa, com o mínimo de dez UFIR e o máximo de mil e oitocentos UFIR”.

Via de regra, o recolhimento das custas judiciais estabelecidas em lei deve ser previamente realizado pela parte que pratica o ato descrito na norma como gerador da incidência da taxa.

Como a lei processual geralmente exige a comprovação deste recolhimento concomitantemente à prática do ato, sua prova deve acompanhar a peça processual que formaliza o ato.

A título de exemplo, quando do ajuizamento da ação, na hipótese de a lei estadual exigir o recolhimento de custas, o autor deverá comprovar seu

pagamento concomitantemente à apresentação desta petição, anexando a esta a prova (recibo) de recolhimento.

Da mesma forma, no âmbito da Justiça federal, em que se exige o prévio recolhimento de custas para a interposição do recurso de agravo, o recolhimento destes valores deve ocorrer antes desta interposição, devendo ser juntada ao instrumento do agravo a comprovação do pagamento dos valores exigidos em lei.

O não recolhimento prévio das custas ou a não comprovação concomitante dele implica a impossibilidade da admissão do ato e a natural produção de efeitos, sendo certo que, se o recolhimento for a menor, ou comprovado justo impedimento em se proceder ao recolhimento, antes de decretar a ineficácia do ato o magistrado deve dar à parte oportunidade de supri-lo em cinco dias⁴⁸⁷.

Conforme se verá em item próprio, a parte que adiantar o recolhimento das custas e que, ao final, sair-se vencedora no processo tem o direito de ser ressarcida pela parte derrotada, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, que assevera que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”, expressão que deve, neste contexto, alcançar também as custas judiciais adiantadas pela parte vitoriosa.

14.3 Honorários advocatícios

Outra categoria de custos decorrentes do processo, exaustivamente regulada pelo Código de Processo Civil e pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, refere-se aos honorários advocatícios, assim entendidos os valores devidos aos advogados das partes em razão dos serviços prestados por estes no curso do processo.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal n. 8.906/94), “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

Portanto, de rigor, duas são as espécies de honorários: a) os honorários contratuais, decorrentes de um negócio jurídico realizado entre o advogado e seu cliente; e b) os honorários de sucumbência, que decorrem da atividade desenvolvida pelo advogado no curso do processo e não se confundem com os honorários contratados entre o advogado e a parte por ele representada.

Os honorários contratuais, como o próprio nome sugere, são regulados pelo Direito Civil, mais especificamente pelo Direito dos contratos, que sofre, em parte, influência da lei federal que institui o estatuto da OAB.

Os honorários contratuais não integram, desta feita, o objeto de disciplina e de estudo do Direito Processual Civil, até porque os serviços prestados ou, mais amplamente, contratados pelo advogado não serão necessariamente voltados à atividade processual.

Já os honorários de sucumbência, por decorrerem diretamente da atividade do advogado em juízo, são objeto de disciplina do Direito Processual Civil, que os regulamenta especificamente nos arts. 85 e seguintes.

O caput do citado art. 85 dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que já revela a natureza sucumbencial da verba honorária nestes casos.

Desta feita, a fixação dos honorários de sucumbência na decisão constitui um dever do juiz, que deverá cumpri-lo ainda que não haja pedido expresso da parte ou do advogado. Caso a sentença silencie, além dos recursos cabíveis para corrigir o vício, o § 18 do art. 85 assegura o cabimento de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários.

Assim, a par dos honorários eventualmente contratados entre o advogado e a parte por ele representada, sempre decorre do processo o direito de o advogado da parte vencedora receber, da parte derrotada, honorários de sucumbência.

O caput do art. 85 deixa claro tratar-se de um direito do advogado, dispondo que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, no que é complementado por nada menos que 19 parágrafos que disciplinam minuciosamente as situações cabíveis e as formas como os honorários deverão ser calculados.

Nesse contexto, destaca-se o § 2º do art. 85, que estabelece percentuais máximos e mínimos, dispondo que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

O referido dispositivo deve ser lido em conjunto com outros parágrafos do mesmo art. 85, por exemplo o § 8º, que reza que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Ademais, o § 6º do art. 85 do Código deixa claro que “os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Escapa ao objeto desta Introdução o estudo pormenorizado de todas as variantes das incidências da verba honorária, devendo ficar claro que: a) em todos os processos, independentemente de conteúdo econômico, serão devidos honorários advocatícios; b) o direito de perceber honorários advocatícios pertence ao advogado e não à parte vencedora; c) a sentença deve, independentemente de pedido expresso, condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor; d) via de regra, o valor fixado deverá ser entre dez e vinte por cento do valor da condenação; mas, e) caso o

objeto do processo não possua conteúdo econômico, os honorários podem fugir deste critério.

Ademais, a presença da Fazenda Pública na relação processual influencia sobremaneira a disciplina dos honorários, razão pela qual a esta hipótese será dedicado item específico *infra*⁴⁸⁸.

Outro ponto que merece estudo destacado é a forma de cálculo e pagamento de honorários na hipótese de sucumbência recíproca, o que será realizado no item 14.6.1, *infra*.

14.4 Demais despesas processuais

A par dos valores devidos ao Poder Judiciário em função das taxas estabelecidas em lei e dos honorários devidos ao advogado das partes nos termos acima comentados, outras despesas podem surgir no curso do processo.

Essas despesas, por definição, são todos os valores devidos ou pagos a outros sujeitos atuantes no processo que não sejam o próprio Poder Judiciário e os advogados das partes, remunerados por regime próprio.

Isso ocorre, por exemplo, no caso de produção de uma prova pericial, em que o juiz nomeia um profissional portador de conhecimentos técnicos especializados para realizar o exame ou perícia, o qual deverá ser remunerado em função da prestação deste serviço.

Isso também acontece no caso de nomeação de intérpretes, tradutores ou quaisquer outros sujeitos que participem ou prestem serviços em prol do processo, quer por requerimento da parte, quer por determinação de ofício do juiz.

Estas categorias, classificadas como despesas processuais, são disciplinadas pelos arts. 82 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o art. 84 do Código dispõe que “as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do

assistente técnico e a diária de testemunha”.

Assim, a prática de qualquer ato, por qualquer pessoa, que implique custos econômicos financeiros deverá ser considerada despesa processual e receber o tratamento dispensado pelo Código.

Deste tratamento, deve ser destacado que, nos termos do art. 82 do CPC, compete à parte que requereu a prática do ato adiantar o recolhimento das custas decorrentes, sendo ônus do autor recolher os valores quando a prática do ato gerador da despesa for determinado de ofício pelo juiz, conforme o § 1º.

Entretanto, deve ficar claro que este ônus do adiantamento não pode ser confundido com a responsabilidade pelo efetivo pagamento, uma vez que esta só será definida a partir da identificação da parte derrotada, esta sim verdadeiramente responsável pelo pagamento das despesas processuais, conforme deixa claro o art. 82, § 2º, do CPC.

Assim, se uma prova pericial vier a ser requerida pelo autor ou determinada de ofício pelo juiz, as despesas dela decorrentes devem ser, a priori, adiantadas pelo autor, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC. Mas, caso este se sagra vencedor na demanda, deverá o réu ser condenado a ressarcir-lo sobre os valores despendidos a este título.

Portanto, tal como no regime das custas devidas ao Judiciário, não há que se confundir o ônus de adiantamento com o verdadeiro dever de recolhimento.

14.5 Ônus de prévio recolhimento das custas e demais despesas processuais

Conforme asseverado no item precedente, o fato de a parte ser responsável pelo recolhimento prévio das custas processuais não quer dizer que seja necessariamente a responsável por suportar este pagamento.

Isso porque o ônus de adiantar as custas e demais despesas para fins de comprovação concomitante do seu recolhimento decorre da iniciativa do

sujeito em praticar o ato processual ensejador da despesa, ao passo que a responsabilidade pelo pagamento decorre da sucumbência.

Assim, conforme será demonstrado mais detalhadamente a seguir, se a parte que praticou o ato processual e previamente recolheu o valor dele decorrente sagrar-se vencedora ao final do processo, terá o direito de receber da parte derrotada o valor adiantado.

A disciplina do ônus do prévio recolhimento encontra-se no art. 82 do CPC, que dispõe que, “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.

Caso o juiz determine de ofício a prática do ato ou este seja requerido pelo Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica, incumbe ao autor adiantar as despesas relativas ao ato, conforme determina o § 1º do mesmo art. 82.

Entretanto, a par do regime geral, algumas situações peculiares são previstas no CPC, no que tange ao adiantamento das custas.

Nesse sentido, o art. 95, ao vislumbrar a hipótese de a perícia ser requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz, dispõe que o valor desta deverá ser rateado e adiantado por ambas.

Já o art. 91, ao tratar da hipótese em que a parte requerente do ato que implica despesa é a Fazenda Pública, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, reza que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento destes entes serão pagas ao final pelo vencido, no que é complementado pelo § 1º, que dispõe “as perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova”.

Ademais, nos casos de gratuidade da Justiça, a perícia poderá ser custeada por recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular.

14.6 Responsabilidade pelo pagamento das custas, honorários e demais despesas processuais em razão da sucumbência

Conforme asseverado nos itens antecedentes, o ônus de adiantamento das custas e despesas não deve ser confundido com o dever de pagamento decorrente da derrota da parte no processo.

Assim, vale ressaltar que, além de perder o direito discutido em juízo, é consequência da sucumbência processual: a) ressarcir a parte vencedora pelo valor das taxas judiciais por esta antecipado; b) pagar os honorários ao advogado da parte vencedora, a serem fixados pelo juiz, observado o art. 85 do CPC; e c) pagar ao vencedor as demais despesas processuais que este antecipou.

Esses efeitos da sentença independem de pedido específico da parte e devem ser resolvidos pelo juiz quando da decisão que extingue o processo por expressa determinação legal.

Nesse sentido, destacam-se o disposto no arts. 82, § 2º, e 85 do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou” e que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

A omissão permite o requerimento de complementação da decisão judicial, pela parte vencedora, pela via recursal. Caso transitada em julgado a decisão com omissão no que tange aos honorários, admite-se, inclusive, o ajuizamento de ação autônoma pelo advogado contra a parte vencida, com fundamento no § 18 do art. 85 do Código.

Como a extinção do processo pode se dar por outros motivos que não apenas uma decisão que julgue o mérito e, portanto, identifique claramente um vencido e um vencedor, o Código de Processo Civil regulamenta uma série de situações específicas em que a regra da sucumbência não é aplicável.

É o caso, por exemplo, da extinção do processo com resolução do mérito por homologação de acordo. Nesta hipótese, aplica-se o art. 90, § 2º, do CPC, que dispõe que, havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Nada impede, contudo, que as partes disponham em outro sentido.

Especialmente no que tange aos honorários, entretanto, o citado dispositivo não se aplica, haja vista que, conforme estabelecido pelo art. 24, § 4º, da Lei n. 8.906/94 (o Estatuto da OAB), o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

O dispositivo tem aplicação, especialmente, quando o acordo celebrado entre as partes se der em uma fase avançada do processo, como a executiva ou recursal, ou seja, após o julgamento da lide e fixação dos honorários advocatícios pelo juiz em favor do advogado da parte vencedora.

Desta feita, considerando que, conforme já demonstrado no item 14.3, tanto nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil quanto nos do Código de Processo Civil, uma vez fixados na decisão judicial, os honorários pertencem ao advogado, sendo o acordo entre as partes res inter alios, não tendo, portanto, o condão de atingir direito de terceiros, no caso dos advogados das partes.

A impossibilidade de a transação entre as partes atingir o direito do advogado de receber os honorários decorre exatamente da afirmação já realizada, também no item 14.3, no sentido de que o direito de perceber

honorários advocatícios pertence ao advogado, e não à parte vencedora.

Nesse contexto, salvo quando participe do acordo, transacionando sobre o seu direito aos honorários, independentemente da transação entre as partes, o advogado poderá exigir da parte vencida o montante fixado em seu favor na decisão judicial.

O art. 90 do CPC também dispõe sobre a distribuição da responsabilidade pelo pagamento das despesas e dos honorários em caso de renúncia, desistência e reconhecimento jurídico do pedido, determinando que deverão ser pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (determinação, aliás, coerente com o sistema de sucumbência).

O § 4º do referido dispositivo estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade; já o § 1º deixa claro que, se a desistência, a renúncia ou o reconhecimento for parcial, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Por fim, cumpre ressaltar a disciplina da repartição da responsabilidade pelo pagamento das custas, despesas e honorários no caso de litisconsórcio, assim entendida a existência de mais de um autor ou mais de um réu na relação processual⁴⁸⁹.

Nesses casos, determina o art. 87 do Código que, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”, devendo a sentença distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas. Havendo omissão na decisão judicial, os litisconsortes vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Por fim, cumpre ressaltar a responsabilidade pelas despesas processuais

nas hipóteses de extinção do processo por perda do objeto, assim entendida a desnecessidade de julgamento do pedido por força de um fato superveniente, situação em que as despesas deverão ser suportadas pela parte que der causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do Código.

14.6.1 Especialmente sobre a sucumbência recíproca

É possível que a resolução de mérito reconheça parcialmente o direito afirmado pelo autor, o que implica dizer que, em contrapartida, o réu também foi vitorioso em parte da demanda.

Nestas hipóteses, os arts. 82, § 2º, e 85 do Código de Processo Civil não solucionam a distribuição dos deveres de pagamento, dado que impossível verificar um único vencido ou vencedor, em função da sucumbência recíproca.

A situação peculiar é disciplinada pelo art. 86 do Código, que estabelece que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Assim, na hipótese de o pedido ser relativo à cobrança de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e o réu venha a ser condenado a pagar R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os custos adiantados pelas partes deverão ser somados, depois divididos entre elas, de modo que cada parte suporte efetivamente metade das despesas e custas. Na mesma hipótese, caso a condenação seja ao pagamento, pelo réu, de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), este deverá arcar com 80% do total de despesas, ao passo que o autor deverá pagar os 20% restantes.

Obviamente, considerando que as partes, por força do art. 82, § 2º, do CPC, adiantaram parte das despesas, admite-se a compensação dos valores adiantados quando do acerto de contas ao final do processo.

Quanto a essa possibilidade de compensação, contudo, mais uma vez partindo da premissa de que o montante fixado a título de honorários pertence ao advogado, e não à parte, a sucumbência recíproca não autoriza

a compensação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, é expresso o art. 85, § 14, do CPC, ao dispor que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

A responsabilidade por pagamento proporcional das custas e despesas processuais não é levada às últimas consequências pelo Código de Processo Civil, haja vista que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86.

Assim, voltando à situação hipotética aventada acima, caso o autor que requereu a condenação do réu ao pagamento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) obtenha a seu favor uma sentença condenando-o ao pagamento de R\$ 99.000,00, apesar de, rigorosamente, ter o autor sido sucumbente em parte de seu pedido (em exatamente 1%), não terá que arcar com os custos proporcionais desta sucumbência mínima.

Em outras palavras, o art. 86, parágrafo único, do Código equipara, para fins de responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a parte que venceu praticamente tudo à parte realmente vitoriosa na totalidade.

14.7 Regime das custas, honorários advocatícios e demais despesas nos processos que envolvem entes públicos

Apesar de a regra ser a necessidade de recolhimento prévio das custas do processo e responsabilização da parte sucumbente por todas as despesas processuais nos termos suprarreferidos, há situações em que os atos processuais podem ser praticados sem este prévio recolhimento das despesas por ele geradas, bem como situações em que a qualidade da parte influencia no montante devido à parte vencedora.

Isso ocorre em função de certos entes, tais como a União, Estados-

membros, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas e Ministério Público, possuírem tratamento diferenciado dado pelo Código de Processo Civil.

Esse tratamento diferenciado configura-se por: a) isenção de custas judiciais; b) faixa de valores diferenciados para fins de fixação de honorários advocatícios; c) inexistência de ônus do adiantamento das demais despesas.

A isenção de custas judiciais deve ser entendida como a dispensa da Fazenda Pública de recolher aos cofres do Poder Judiciário as taxas judiciais previstas em lei como incidentes em decorrência de ato processual por ela praticado.

Tal isenção é prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/80, que reza: "A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito".

A razão de ser de tal isenção reside no fato de o Poder Judiciário ser órgão do Estado e, portanto, de rigor, estar-se diante de uma hipótese em que o Estado-litigante estaria recolhendo valores para si mesmo.

Isso porque, em última análise, os valores devidos por estes entes públicos acabariam sendo revertidos para o próprio ente ou, no máximo, para um órgão integrante de outra esfera ou Poder.

Entretanto, a Fazenda Pública, apesar de isenta de recolher as taxas incidentes sobre os atos processuais a que der causa, possui dever de, quando derrotada, ressarcir o montante adiantado a este título pela parte contrária.

Nesse sentido, o parágrafo único do já citado art. 39 da Lei n. 6.830/80 dispõe que, "se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária".

No que se refere às demais despesas, a Fazenda Pública, o Ministério

Público e a Defensoria Pública estão dispensadas de adiantar os valores, nos termos do art. 91 do Código de Processo Civil⁴⁹⁰.

Contudo, em caso de derrota e identificação do ente público como a parte sucumbente, surge para ele o dever de pagamento, tal como todos os demais sujeitos derrotados.

Portanto, a isenção de pagar as custas judiciais e a dispensa de adiantar as demais despesas não implicam dizer que os entes identificados no art. 91 do CPC estejam livres da responsabilidade de pagar os valores desembolsados pela parte contrária, incluindo os honorários de seus respectivos advogados, quando derrotadas.

Assim, se a decisão impuser a derrota da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas respectivas autarquias e fundações públicas, estes entes deverão ser condenados a ressarcir a parte contrária no pagamento das custas e demais despesas, bem como a pagar os honorários do advogado do vencedor.

Nesse aspecto, a única e verdadeira distinção ocorre no que tange aos critérios de fixação de honorários do advogado da parte vencedora: em vez dos percentuais de 10 a 20% previstos no art. 85, § 2º, do CPC, aplica-se uma tabela estabelecida no § 3º do mesmo dispositivo.

Assim, conforme o § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, “nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incs. I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos; IV – mínimo de três e máximo de cinco

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 100.000 (cem mil) salários mínimos; V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos”.

14.8 Gratuidade da Justiça

Por mais que a atividade jurisdicional implique custos que, em princípio, devem ser suportados pelas partes, a falta de condições econômico-financeiras de um sujeito que tenha interesse ou necessidade de ir a juízo, ou contra si ajuizada uma demanda, não pode suprimir seus direitos fundamentais de acesso à Justiça, ao contraditório e à ampla defesa.

Por essa razão, a Constituição Federal consagra o princípio da gratuidade da Justiça em seu art. 5º, inc. LXXIV, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O dispositivo, conforme já asseverado no item 6.1.4.12, assegura: a) o direito das partes de serem assistidas, gratuitamente, por profissionais habilitados a prestar tal serviço; b) o direito à isenção de custas ou, mais precisamente, a possibilidade de praticar os atos processuais sem o prévio recolhimento das taxas devidas ao Poder Judiciário; c) o direito de praticar outros atos processuais que gerem despesas sem, entretanto, ter que antecipar o pagamento.

Portanto, a concessão da gratuidade da Justiça para aqueles que demonstrarem ter este direito impacta na disciplina das custas, dos honorários advocatícios, bem como na forma de custeio das demais despesas processuais.

O Código de Processo Civil regulamenta no plano infraconstitucional a garantia de justiça gratuita àqueles que não possuem condições de arcar com as custas judiciais, honorários advocatícios e demais despesas

processuais sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família.

O art. 98 do CPC assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O § 1º do citado dispositivo deixa clara a abrangência que pode vir a ter a gratuidade, dispondo que a concessão do benefício compreende: I – as taxas ou as custas judiciais; II – os selos postais; III – as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV – a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V – as despesas com a realização de exame de código genético – DNA e de outros exames considerados essenciais; VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII – os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Conforme se depreende do dispositivo, há uma ampla dispensa, que engloba: a) as custas devidas ao Poder Judiciário a título de taxas judiciais; b) os honorários do advogado; c) todas as demais despesas, como as decorrentes de indenização devida à testemunha, honorários periciais e a remuneração do intérprete ou do tradutor.

O Código de Processo Civil admite a concessão do benefício de gratuidade parcial, isto é, dispensa de recolhimento para a prática de um ou

mais atos (art. 98, § 5º), além da possibilidade de parcelamento dos valores devidos, a teor do art. 98, § 6º.

Assim, se a condição econômica do litigante lhe permitir pagar parte das despesas geradas pelo processo, o juiz deve conceder o benefício parcialmente, isentando-o do custeio em relação a um ou mais atos processuais, ou reduzir o percentual de despesas processuais.

Se o problema for apenas de disponibilidade financeira naquele momento, sendo possível o pagamento da despesa de forma parcelada, aplica-se o art. 98, § 6º, que autoriza o juiz a conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Concedida a gratuidade, esta se reflete, em primeiro lugar, na isenção de custas processuais, não estando o beneficiário da concessão obrigado a recolher previamente os valores devidos ao Estado a título de taxas judiciais.

Assim, o beneficiário, isento de tal pagamento, mesmo quando der causa ou requerer a prática do ato em que incidam custas, poderá praticá-lo sem o prévio recolhimento do montante previsto em lei.

A ideia é reforçada pelo caput do próprio art. 82 do Código, que dispõe que, “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final (...)”.

O mesmo ocorre com a isenção do adiantamento dos valores devidos em função de outras despesas processuais, havendo uma regra especial no que se refere à perícia, conforme será tratado no item “c”, infra.

Já a impossibilidade de pagar um advogado atrai o dever do Estado de prestar a assistência jurídica ao hipossuficiente, sendo certo que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade

da justiça em relação às custas judiciais e demais despesas, conforme deixa claro o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, mesmo a parte assistida por advogado privado pode requerer a gratuidade para não ter que arcar com o recolhimento de custas e demais despesas processuais.

A impossibilidade de pagar um advogado, por sua vez, atrai o dever de atuação da Defensoria Pública, instituição por meio da qual o Estado presta este serviço público aos necessitados de assistência jurídica integral e gratuita e que, nos termos do art. 135 da Constituição Federal, tem por missão, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV do art. 5º da Constituição Federal⁴⁹¹.

Nestas hipóteses, portanto, o hipossuficiente econômico não pagará ao defensor público, uma vez que este é remunerado pelo Estado exatamente para prestar o serviço de assistência jurídica gratuitamente à população.

Contudo, a isenção de custas não desonera o beneficiário da justiça gratuita dos encargos da sucumbência, podendo este vir a ser condenado a ressarcir a parte contrária naquilo que ela adiantou a título de custas, bem como a pagar o advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do Código.

A dinâmica da concessão e da eventual condenação do beneficiário da justiça gratuita em caso de derrota será detalhada nos subitens a seguir.

a) Dinâmica da concessão da Justiça gratuita no que tange às custas judiciais

Nos termos do art. 98, § 1º, inc. I, do CPC, a gratuidade da justiça compreende “as taxas ou as custas judiciais”.

Tais custas, conforme já asseverado, são tributos devidos ao Estado (Poder Judiciário) em função da prestação do serviço jurisdicional.

Assim, ao beneficiário da justiça gratuita é dado o direito de praticar atos processuais previstos na “lei de custas” da respectiva justiça sem proceder ao prévio recolhimento.

Entretanto, esta isenção, pelo menos a priori, não alcança a responsabilidade pelo ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária caso o beneficiário da justiça gratuita seja derrotado.

Isso porque o art. 98, § 2º, do Código dispõe que “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.

Obviamente, o dever de ressarcimento do montante adiantado pela parte vencedora a título de custas está abrangido pelo dispositivo.

Assim, ainda que o vencido seja beneficiário da justiça gratuita, a sentença o condenará a pagar ao vencedor as taxas judiciais por este recolhidas nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

A hipótese ademais atrai a incidência do art. 98, § 3º, que dispõe: “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Do exposto, pode-se concluir que: a) o beneficiário da Justiça gratuita é isento de recolher as custas judiciais dos atos que vier a praticar; mas b) não é desobrigado a ressarcir o vencedor pelas despesas que este adiantou; e, c) independentemente da concessão do benefício, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou; d) caso o vencido, apesar de beneficiário da justiça gratuita, possua ou venha a

adquirir condições econômicas para pagar as despesas adiantadas pela parte contrária, no prazo de cinco anos contados da formação da coisa julgada, deverá ressarcir o vencedor; e) passados os cinco anos sem o pagamento, a obrigação se extingue pela prescrição.

A seguir, ver-se-á que a dinâmica também se aplica aos honorários e demais despesas processuais sempre que o beneficiário da Justiça gratuita vier a ser derrotado.

b) Dinâmica da concessão da Justiça gratuita em relação aos honorários advocatícios

Conforme já asseverado, a concessão do benefício da gratuidade da justiça assegura ao hipossuficiente econômico a representação em juízo pelo defensor público, integrante da Defensoria Pública que presta esta assistência sem ser remunerado pela parte.

Na hipótese de, ao final do processo, a parte representada pela Defensoria Pública sair-se vencedora, incide normalmente o art. 85 do CPC, que determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que implica dizer que a parte derrotada deverá pagar o montante fixado pelo juiz na decisão à instituição pública.

Contudo, caso a parte hipossuficiente seja derrotada, nos termos do mesmo art. 85, ela se torna devedora do advogado do vencedor.

Nesse caso, aplica-se o já citado art. 98, § 2º, do CPC, que determina que “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.

Em outras palavras, mesmo aquele que vier a ter o benefício da Justiça gratuita reconhecido e tenha, por isso, sido representado pela Defensoria Pública e ficado isento de custas e do adiantamento das despesas deverá, se derrotado, ser condenado a pagar as despesas adiantadas pela parte contrária e os honorários do advogado do vencedor.

Obviamente, se o derrotado não tiver patrimônio suficiente para tanto, no plano fático este pagamento não irá ocorrer, o que não implica dizer que este não seja devedor das custas e dos honorários.

Aplicar-se-á à hipótese o § 3º do art. 98 do CPC, que dispõe que, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Assim, se derrotada, a parte beneficiada pela concessão da justiça gratuita deverá sempre ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários, devendo pagá-los imediatamente, caso possua condições econômico-financeiras para tanto, podendo ser cobrada a qualquer momento, dentro do período de cinco anos.

Caso não realize tal pagamento e decorrido o prazo de cinco anos, extingue-se o direito da parte vencedora e de seu advogado de receberem o montante, mesmo sem nada terem recebido, por força da prescrição estabelecida no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

c) Dinâmica da concessão da Justiça gratuita em relação às demais despesas processuais

Assim como ocorre com as custas judiciais, o beneficiário da Justiça gratuita é isento do ônus de adiantar os valores devidos a título de outras despesas processuais, como as decorrentes da participação de terceiros no processo.

Esses atos, portanto, a priori, podem ser praticados sem o prévio custeio, mas, considerando a possibilidade de isso implicar uma prestação de serviço

por terceiro, como um tradutor ou perito, sem a regular e natural contraprestação, o Estado pode vir a ser instado a custear tal despesa.

Assim, de rigor, no que se refere à prática de atos processuais por profissionais prestadores de serviços úteis ou necessários ao processo, duas são as possibilidades: a) o ato deve ser praticado sem prévia remuneração, vindo o profissional a ser remunerado, ao final do processo, pela parte sucumbente; ou b) o Estado, que não é parte, pode vir a ser obrigado a custear tal serviço⁴⁹².

Essa obrigação do Estado decorre do já referido art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que, muito mais do que uma simples isenção de custas ou representação pela Defensoria Pública, determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse contexto, a expressão “assistência integral” alcança eventuais perícias, traduções ou outros serviços necessários para a defesa do beneficiário.

Por esse motivo, o art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que, “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

O dispositivo, apesar de regulamentar especificamente o custeio da perícia, pode vir a ser aplicado quando a responsabilidade pelo pagamento de outras despesas a terceiros colaboradores eventuais da Justiça for do beneficiário da gratuidade.

Portanto, o Código de Processo Civil estabelece a responsabilidade do Estado de custear tais despesas.

Se o beneficiário da justiça gratuita ao final for o vencedor, a parte contrária, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, deverá, na sentença, ser condenada a pagar as despesas adiantadas que, no caso, não o foram pela parte contrária, e sim pelo Estado.

Nesse contexto, por óbvio, esta obrigação de ressarcir favorece o Estado, que havia arcado com o montante, conforme deixa claro o art. 95, § 4º, do Código, que reza: “na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º”.

Por outro lado, caso a perícia ou outra despesa processual tenha sido adiantada pela parte contrária ao beneficiário da justiça gratuita, sendo este sucumbente, deverá ser condenado a ressarcir a parte vencedora, nos termos do art. 98, § 2º, do Código.

Tal como nos valores adiantados a título de custas judiciais, o beneficiário poderá ser cobrado pelo vencedor em até cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão. Caso, findo este prazo, o beneficiário condenado a ressarcir a parte contrária ainda não reúna condições patrimoniais para efetuar o pagamento, extingue-se tal obrigação, pela prescrição.

14.8.1 Aspectos procedimentais do requerimento e da concessão da Justiça gratuita

Os arts. 99 e 100 do CPC disciplinam a forma e os desdobramentos procedimentais do requerimento de concessão de justiça gratuita pelas

partes, bem como a análise pelo juiz e recurso contra a decisão que concede ou que denega o benefício.

Considerando esta recorribilidade, o art. 102 do Código complementa a disciplina, estabelecendo as consequências na hipótese de revogação do benefício, a priori, concedido.

Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade deve ser formulado pelo autor já na petição inicial e pelo réu na contestação. Qualquer outro sujeito que venha a intervir no processo poderá requerer a justiça gratuita em sua primeira manifestação.

Entretanto, considerando a hipótese de a ausência de condições financeiras para o custeio das despesas processuais surgir durante o processo, o § 1º do art. 99 admite a formulação do pedido em outro momento, por simples petição.

Feito o requerimento, o Código de Processo Civil determina sua avaliação pelo juiz sem o prévio contraditório, o que não implica dizer que a parte contrária não possa impugnar o pedido.

Dessa avaliação pode, por óbvio, surgir uma decisão concessiva ou denegatória do pedido de gratuidade.

Para tanto, o juiz deverá levar em consideração os elementos dos autos que evidenciem a presença ou a falta dos pressupostos legais para a concessão de justiça gratuita, sendo certo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência quando deduzida por pessoa natural, por força do art. 99, § 3º, do CPC.

Tal presunção, contudo, é relativa e, caso o juiz entenda, pelos elementos constantes dos autos, que a parte que requer o benefício tenha ou possa ter condições de arcar, ainda que parcialmente, com as custas, honorários e demais despesas processuais, deverá, antes de indeferir o pedido, permitir que a parte requerente faça prova do alegado.

Nesse contexto, poderá a parte juntar seu extrato bancário, declaração

de imposto de renda à Receita Federal do Brasil, holerite, contracheque ou equivalente, assim como prova de suas despesas ordinárias, tudo com o intuito de comprovar a impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família.

Depreende-se da interpretação do dispositivo que, enquanto a concessão da gratuidade pode se dar desde logo por força da presunção estabelecida em favor do requerente ou por força dos elementos constantes dos autos, o juiz não pode denegar o benefício antes de dar à parte a oportunidade de provar sua condição de hipossuficiência.

De toda forma, a decisão, com base na presunção estabelecida no art. 99, § 3º, nos elementos constantes dos autos ou nas provas produzidas pelo requerente, desafia recurso.

Se deferido o pedido de gratuidade, o art. 100 do Código determina que a parte contrária poderá oferecer impugnação à referida concessão no prazo máximo de quinze dias.

Após o oferecimento da impugnação prevista no art. 100, o juiz está autorizado a rever a decisão e, se passar a entender que não estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, o benefício poderá ser revogado.

Assim como a decisão que denega o pedido, a decisão que revoga o benefício ordinariamente acolhido nos termos do dispositivo citado igualmente desafia o recurso.

Em ambos os casos, se interposto o recurso, reabre-se a possibilidade de concessão do benefício pela instância superior⁴⁹³.

Obviamente, ainda que a lei federal ou estadual, conforme o caso, preveja a incidência de custas judiciais pela interposição do recurso, a parte que requer a justiça gratuita, exatamente por alegar não ter condições econômicas de arcar com as despesas processuais, ficará isenta do prévio recolhimento. Nesse sentido, é expresse o art. 101, § 1º, do CPC.

Confirmada a revogação do benefício ou, mais amplamente, tornando-se definitiva a decisão que declare que a parte não possui o direito à gratuidade da Justiça, ainda que tenha tido este direito reconhecido em algum momento do processo, o art. 102 do Código de Processo Civil determina que esta “deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei”.

A conclusão é natural, considerando que, em última análise, restou reconhecido que a parte tinha condições de suportar os custos do processo.

Nesse contexto, a não efetivação do recolhimento pode levar, nos termos do parágrafo único do dispositivo, à extinção do processo sem resolução de mérito se a providência couber ao autor, ou à impossibilidade de realização de atos processuais ou diligências requeridas pela parte condenada a pagar, enquanto não efetuado o depósito.

Capítulo 15 Competência

15.1 Generalidades

Uma questão que se coloca em todos os processos, sem exceção, diz respeito à definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a causa.

Isso porque, conforme já estudado no Capítulo 5 desta Introdução, o Poder Judiciário se estrutura e se divide em diversos órgãos jurisdicionais, entre os quais o Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores, as “Justiças” federal, do trabalho, eleitoral e militar, bem como as Justiças de cada um dos Estados da federação e do Distrito Federal, sendo o exercício do poder jurisdicional repartido, pela lei e pela Constituição Federal, entre estes diversos órgãos.

Além disso, o princípio do juiz natural constitucionalmente consagrado (art. 5º, inc. LX) estabelece que “ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente”, sendo imperativo e, inclusive, um pressuposto processual de validade, que o órgão jurisdicional competente seja identificado nos termos das normas e critérios estabelecidos pela lei e pela própria Constituição Federal⁴⁹⁴.

A exigência imposta pelo princípio do juiz natural e a organização do Poder Judiciário são duas premissas fundamentais para a compreensão da finalidade, utilidade e importância das normas de repartição de competência.

Nesse contexto, as normas de repartição de competência dividem a função jurisdicional entre os vários órgãos do Poder Judiciário, levando em conta que essa estrutura judiciária: a) possui vários organismos jurisdicionais autônomos entre si, que formam as diversas “Justiças” previstas pela Constituição Federal; b) possui, em cada “Justiça”, órgãos de

primeiro e segundo graus de jurisdição; c) possui tribunais superiores; d) se divide por todo o território nacional e dos Estados em seções judiciárias ou comarcas; e) pode possuir em uma mesma comarca, ou na mesma seção judiciária, mais de um órgão judiciário de igual grau de jurisdição, alguns especializados em determinada matéria ou integrantes da estrutura dos juizados especiais, órgãos com atribuição para processar e julgar causas de menor complexidade pela via de um procedimento simplificado.

Segundo Cintra, Dinamarco e Grinover⁴⁹⁵, a operação tendente a determinar a competência, diante de cada caso concreto, se faz através de sucessivas etapas, cada uma representando um problema a ser resolvido, observada a seguinte sequência:

1ª) Competência de Justiça: “qual a Justiça competente?”

2ª) Competência originária: “dentro da Justiça competente, o conhecimento da causa cabe ao órgão superior ou ao inferior?”

3ª) Competência de foro: “se a atribuição é do órgão de primeiro grau de jurisdição, qual a comarca ou seção judiciária competente?”

4ª) Competência de juízo: “se há mais de um órgão de primeiro grau com as mesmas atribuições jurisdicionais, qual a vara competente?”

5ª) Competência interna: “quando numa mesma vara ou tribunal servem vários juízes, qual ou quais deles serão competentes?”

A esta metodologia devem ser acrescentadas duas questões prévias: a) se há possibilidade jurídica de atuação da jurisdição brasileira; e b) se a causa encerra hipótese de competência originária de algum tribunal superior.

O estudo completo e pormenorizado da identificação da competência do órgão jurisdicional deve levar em consideração não apenas a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, mas também as leis de organização judiciária dos Estados e, até mesmo, o regimento interno dos tribunais, diplomas que escapam ao objeto desta Introdução⁴⁹⁶.

Nesse sentido, este capítulo será dedicado aos principais critérios e normas estabelecidos na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, sem adentrar em outros pormenores úteis e necessários para identificação correta do juízo competente constantes das legislações estaduais e normas regimentais dos tribunais.

As diversas fontes do Direito Processual Civil estabelecem normas de repartição de competência instituindo critérios gerais e abstratos para definição do órgão competente (matéria, pessoa, função, território e valor da causa) além de, excepcionalmente, definir que situações específicas devem ser processadas em julgadas por determinado órgão jurisdicional.

É a compreensão destas normas específicas e excepcionais e dos critérios gerais e abstratos previstos na Constituição Federal e na lei que permite ao intérprete e aplicador do Direito Processual Civil identificar o juiz competente para processar e julgar a causa, pois são estes os parâmetros normativos aplicáveis no enfrentamento das sete questões integrantes do método para a identificação do órgão competente.

15.2 Parâmetros normativos para a definição da competência

Conforme afirmado no item antecedente, estão na Constituição Federal, na lei e, em menor medida, na legislação estadual e regimento interno dos tribunais as normas que estabelecem a repartição de competência entre os órgãos jurisdicionais.

São estas fontes do Direito Processual Civil que estabelecem os parâmetros normativos definidores da competência dos órgãos jurisdicionais.

É possível dividir estes parâmetros normativos em dois grandes grupos: a) normas excepcionais e específicas; e b) critérios genéricos de repartição de competência.

As normas excepcionais e específicas, como a própria expressão sugere, são parâmetros normativos especiais, isto é, especialmente desenhados

pelo legislador para determinadas situações concretas. É o caso, por exemplo, da norma constante do art. 102, inc. I, "d", que estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento do mandado de segurança e do habeas data contra atos do Presidente da República ou da norma prevista no art. 105, inc. I, "b", que diz ser competente o Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento dos mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal.

Nota-se que, nestes casos, a norma, rigorosamente, não se vale de um critério genérico, mas sim opta por estabelecer concretamente no dispositivo definidor da competência todos os elementos que a determinam, detalhando o "tipo" de procedimento (mandado de segurança, habeas data etc.) e especificando quais autoridades atraem a competência (Presidente da República, Ministro de Estado, comandantes da Marinha, Exército ou Aeronáutica).

Justamente por serem pormenorizadamente estabelecidas pelo legislador, as normas de definição de competência que se valem deste tipo de parâmetro normativo são excepcionais e incidem apenas nestes casos prévia e especificamente previstos em lei.

Como regra geral, portanto, o sistema processual, em vez de detalhar e concretizar a competência de cada órgão jurisdicional, opta por estabelecer critérios gerais e abstratos que, quando aplicados conjuntamente, permitem a identificação do juízo competente.

Essa aplicação deve se dar por meio de uma metodologia adequada, o que implica dizer que, além do conhecimento dos critérios e da identificação destes em cada situação concreta, é importante que estes critérios sejam aplicados da maneira apropriada, sendo corretamente utilizados para "responder" as questões relacionadas à definição da competência em que, inclusive, a ordem em que elas são enfrentadas importa para tal definição.

As questões integrantes do método são, nesta ordem⁴⁹⁷:

Questão 1: Verificação da possibilidade de atuação da jurisdição brasileira.

Questão 2: Verificação da competência originária dos tribunais superiores.

Questão 3: Verificação da Justiça competente.

Questão 4: Verificação da competência do tribunal de segundo grau da respectiva justiça.

Questão 5: Verificação do foro competente.

Questão 6: Verificação da eventual competência dos juizados especiais – onde houver juizados instalados.

Questão 7: Verificação da competência de “vara especializada” – onde houver mais de uma vara.

Para que se identifique o órgão jurisdicional competente, faz-se necessário: a) conhecer e verificar a incidência de normas específicas e excepcionais definidoras de competência; b) conhecer os critérios genéricos de repartição de competência e identificá-los no caso concreto; c) utilizar tais normas específicas e critérios genéricos de repartição de competência nas respostas às questões integrantes do método de aplicação das normas de repartição de competência.

As normas específicas (“a”), justamente por serem excepcionais, são de sistematização difícil e escapam ao objeto desta Introdução, sendo suficiente, nesse passo, a referência a três dispositivos que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais regionais federais: respectivamente, os arts. 102, inc. I, 105, inc. I, e 108, inc. I, todos da Constituição Federal, sendo as alíneas destes dispositivos o principal parâmetro normativo para a identificação da competência destes órgãos jurisdicionais⁴⁹⁸.

Já os critérios genéricos de repartição de competência (“b”) e a

metodologia de aplicação das normas de repartição de competência ("c"), exatamente por possuírem uma incidência mais ampla, merecem um estudo pormenorizado, o que será feito nos subitens a seguir.

15.2.1 Critérios genéricos de repartição de competência

A lei processual se vale de cinco critérios genéricos de repartição de competência: a) matéria; b) pessoa; c) funcional; d) território; e e) valor da causa.

Estes critérios deverão ser utilizados para: a) identificar a Justiça competente (questão 3, infra); b) identificar o "foro competente" (questão 5, infra); c) identificar a competência dos juizados especiais (questão 6, infra); e d) identificar a competência das varas especializadas (questão 7, infra).

Apenas as questões 1, 2 e 4 do método acima exposto, quais sejam, identificação da jurisdição brasileira e competência originária dos tribunais superiores e de segundo grau, não se valem dos critérios genéricos aqui estudados, mas sim de normas excepcionais e específicas.

Portanto, salvo os casos de competência originária de tribunais, todas as causas sujeitas a jurisdição brasileira têm seu juiz natural identificado a partir da correta aplicação dos referidos critérios genéricos de repartição de competência.

Os critérios matéria ("a"), pessoa ("b") e funcional ("c") são úteis primeiramente para identificação da "Justiça" competente e eventual competência originária de algum tribunal.

Ademais, uma vez identificada a "Justiça", estes critérios, somados ao territorial ("d") e valor da causa ("e"), serão necessários para identificar o foro competente (questão 5) e para verificar, eventualmente, a competência dos juizados especiais e das varas especializadas (questões 6 e 7, do método acima explicado).

Portanto, para avançar rumo à identificação do juiz natural respondendo

às questões integrantes do método é imprescindível a compreensão e aplicação dos cinco critérios genéricos de repartição de competência.

a) Competência em razão da matéria (critério material)

O critério matéria ("a") leva em consideração para a repartição de competência a natureza da relação material discutida em juízo. Nestas situações, portanto, o operador do Direito preocupado em definir o órgão competente vai verificar se a situação litigiosa é regulamentada pelo Direito do trabalho, tributário, civil, eleitoral, militar, ambiental ou administrativo, por exemplo.

Trata-se de um dos principais critérios para a definição da "questão 3" (verificação da Justiça competente) uma vez que a competência das Justças especializadas são estabelecidas pela Constituição Federal exatamente em função da matéria litigiosa, sendo competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas em matéria trabalhista, a Justiça eleitoral para processar e julgar os litígios eleitorais e a Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares tal como estabelecido no art. 124 da Constituição Federal.

Esse critério, por via transversa, também influencia na definição da competência da Justiça comum (federal e estadual), uma vez que esta se define por exclusão, sempre que a matéria não for da competência de nenhuma das "Justças especializadas".

Ademais, conforme se verá adiante, muitas localidades, por possuírem um grande número de varas da justiça comum, acabam especializando algumas destas em razão da matéria, dando origem às varas especializadas em direito de família, sucessões, previdenciária, entre outras.

Nessas situações, novamente a natureza da relação litigiosa, ou seja, a matéria discutida em juízo, é imprescindível para a identificação do juízo competente.

b) Competência em razão da pessoa (critério pessoal)

Outro critério fundamental para a definição da Justiça competente e, dentro desta, do órgão jurisdicional com atribuição para processar e julgar a causa, é o critério pessoal ("b"), que leva em consideração a qualidade dos sujeitos litigantes, se pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado ou se maiores e capazes ou incapazes.

É o critério pessoal, por exemplo, o principal parâmetro para definir a repartição da competência entre a Justiça comum federal e comum estadual, pois compete à Justiça federal processar e julgar as pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Pública federal, ou seja, a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas.

Por exclusão, as demais pessoas são processadas e julgadas pelos órgãos da Justiça estadual, salvo se a matéria ou determinada norma excepcional estabelecer a competência de outra Justiça ou de um tribunal superior, por exemplo.

Além disso, no âmbito da Justíças estaduais, via de regra, os entes públicos estaduais e municipais são processados e julgados por varas especiais, conhecidas como "varas da Fazenda Pública", que se valem nesse contexto também do critério pessoal.

Ademais, o critério pessoal pode ser utilizado para influenciar a definição da competência de determinados órgãos da Justiça comum, existindo situações em que determinadas pessoas não podem figurar como autoras perante certos órgãos jurisdicionais, como no caso das pessoas jurídicas de direito público nos juizados especiais, ou mesmo como partes (autor ou réu), a exemplo dos incapazes também perante os juizados.

Em suma, em todas estas situações, a qualidade dos sujeitos litigantes é um dos fatores determinantes para a definição do órgão jurisdicional competente, devendo, este fator, sempre ser levado em consideração para a identificação do juiz natural da causa.

c) Competência funcional

O critério funcional ("c") leva em consideração as diversas funções exercidas no processo, tais como realizar a execução de determinados créditos (p. ex.: competência para processar a execução fiscal); conhecer pedidos de urgência (p. ex.: competência para julgar o pedido de suspensão de segurança) ou julgar recursos, por exemplo.

Esse critério pouco influencia na definição da "Justiça" competente, mas, uma vez definida esta questão e o foro competente, o critério funcional pode ser determinante para identificação da "vara especializada" ou órgão jurisdicional competente para a causa.

Nesse contexto, por exemplo, é muito comum que o Judiciário crie varas especializadas em execuções fiscais, onde o critério é exatamente o funcional, assim como é do presidente do respectivo tribunal a competência para apreciar e julgar o pedido de suspensão de segurança, sendo este outro exemplo em que a função exercida pelo órgão jurisdicional no processo é o fator determinante para o estabelecimento da competência.

Ademais, o critério funcional está presente em várias normas excepcionais e específicas de definição de competência originária de tribunais que se baseiam exatamente na função que o órgão jurisdicional vai exercer, por exemplo, processar e julgar alguma causa pela via de um procedimento específico, tais como mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção ou ação direta de constitucionalidade.

d) Competência territorial

O quarto critério de repartição da competência é o territorial, cuja aplicação, segundo Humberto Theodoro Jr., "decorre da necessidade de definição, entre os vários juízes do país, de igual competência em razão da matéria e do valor, qual poderá conhecer de determinada causa"⁴⁹⁹.

Como regra, o critério territorial leva em consideração o domicílio do réu,

havendo, entretanto, situações em que outros elementos territoriais, como domicílio do autor, local do fato que originou a lide ou localização da coisa objeto da disputa, igualmente, influenciam na definição do juízo competente.

Ao critério territorial será dedicado um subitem específico a seguir⁵⁰⁰.

e) Competência em razão do valor da causa

Por fim, o valor da causa (“e”) também é levado em consideração para identificação do órgão competente, uma vez que determinados órgãos jurisdicionais, como os juizados especiais, têm suas atribuições limitadas a determinados valores.

Em apertada síntese, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor do bem jurídico pretendido pelo autor, sendo a identificação deste valor um requisito indispensável da petição inicial, conforme exigido pelo art. 319, inc. V do Código de Processo Civil⁵⁰¹.

Em certas situações, é exatamente o valor da causa o fator determinante para identificação do órgão jurisdicional competente, sendo este, por exemplo, o principal critério utilizado pela lei processual para definir a competência dos juizados especiais e, portanto, para responder a “questão 6” integrante do método aqui proposto.

Assim, a partir da identificação do valor da causa na própria petição inicial é possível definir se a causa pode ser processada e julgada pelos juizados especiais, caso existam estes órgãos no foro competente, ou se a competência deste está, de plano, excluído, mesmo que a localidade possua juizados instalados.

15.3 Metodologia de aplicação das normas de repartição de competência

Conforme afirmado nos itens antecedentes, sete “questões” precisam ser enfrentadas para que seja possível identificar o órgão jurisdicional

competente, sendo certo que estas “respostas” estão estabelecidas ora excepcional e expressamente em normas específicas consagradas na Constituição Federal e na lei, ora em critérios genéricos aplicáveis ao caso concreto estabelecidos nestas fontes do Direito Processual.

As questões a serem enfrentadas são as seguintes:

Questão 1: Verificação da possibilidade de atuação da jurisdição brasileira.

Questão 2: Verificação da competência originária dos tribunais superiores.

Questão 3: Verificação da Justiça competente.

Questão 4: Verificação da competência do tribunal de segundo grau da respectiva justiça.

Questão 5: Verificação do foro competente.

Questão 6: Verificação da eventual competência dos juizados especiais – onde houver juizados instalados.

Questão 7: Verificação da competência de “vara especializada” – onde houver mais de uma vara.

As respostas a estas questões encontram-se na lei processual que, conforme demonstrado no item anterior, se utiliza basicamente de dois tipos de parâmetro normativo: normas específicas de identificação de competência e critérios genéricos de repartição de competência.

Vale destacar que o enfrentamento das questões deve obedecer à ordem estabelecida no método acima, não fazendo sentido, por exemplo, verificar a competência de uma vara especializada, tal como exigido na questão 7, antes de identificar a “Justiça” competente, bem como não há nenhuma razão para se verificar a competência dos juizados especiais, muitas vezes definida pelo valor, antes de identificar foro competente, pois nem todos os locais possuem este tipo de órgão jurisdicional.

Dentro dessa lógica, obviamente, o primeiro passo é verificar a

possibilidade de atuação da jurisdição brasileira, uma vez que, se negativa a resposta a esta questão, as demais, simplesmente, não se colocam.

O Código de Processo Civil regula os limites da jurisdição nacional entre os arts. 21 e 25, sendo estas normas objeto de análise do item 15.4 infra.

Uma vez identificada a possibilidade de atuação do Poder Judiciário brasileiro, o passo seguinte é a verificação da competência originária dos tribunais superiores (questão 2, tratada no item 15.5).

Trata-se de hipóteses excepcionalíssimas dado que, conforme já visto no Capítulo 5 desta Introdução, a função destes tribunais de sobreposição é, via de regra, recursal.

Assim, apenas excepcionalissimamente, quando expressamente previsto na Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça atuam como o juiz natural competente para processar e julgar a causa originariamente.

São normas de tipo excepcionais e específicas que definem a competência originária destas cortes, sendo apenas a existência destas previsões normativas especiais capazes de estabelecer esta atribuição.

Portanto, por mais que se procure uma lógica, nas hipóteses constitucionalmente arroladas, fato é que, por se tratar de situações excepcionais, cabe ao operador do Direito verificar se a situação concreta se encaixa perfeitamente na situação descrita na norma constitucional ou não se submete ao processamento e julgamento pelos tribunais superiores.

Essas situações excepcionais e específicas estão arroladas nos já citados arts. 102, inc. I, e 105, inc. I, da Constituição Federal, sendo ambos rols taxativos, não admitindo interpretações ampliativas ou extensivas.

Desta feita, apenas as causas expressamente arroladas na Constituição Federal são de competência originária dos tribunais superiores, tema que será retomado no item 15.5, infra.

Excluídas as hipóteses de competência dos tribunais superiores, cabe ao

operador do Direito, ocupado com a definição do juiz competente, identificar a “Justiça” perante a qual a causa deve submeter-se (questão 3), valendo-se, para tanto, notadamente dos critérios material e pessoal, conforme será pormenorizado no item 15.6.

Ademais, após a identificação da “Justiça” competente, cabe o enfrentamento da análise da eventual competência originária dos tribunais locais (questão 4); do foro competente (questão 5); e da eventual competência dos juizados e varas especializadas (questões 6 e 7), cuja definição se vale de praticamente todos os critérios genéricos de repartição de competência conforme será visto especialmente nos itens 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10.

15.4 Limites da jurisdição nacional

Antes de adentrar nas questões relativas à repartição de competência entre os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, uma questão logicamente antecedente é a verificação da possibilidade de atuação da jurisdição brasileira.

A questão é regulamentada pelos arts. 21 a 26 do Código de Processo Civil, no capítulo denominado “Dos limites da jurisdição nacional”, que estabelece situações em que os órgãos do poder jurisdicional estão autorizados a atuar sempre que provocados sem, necessariamente, excluir a possibilidade de atuação de órgãos estrangeiros, assim como estabelece hipóteses em que apenas a jurisdição nacional está autorizada a processar e julgar a causa.

Às situações em que a jurisdição brasileira pode atuar, sem que isso, por si, exclua a atuação de órgãos estrangeiros, dá-se o nome de competência concorrente, ao passo que as causas em que apenas a jurisdição brasileira pode atuar é denominada de competência exclusiva.

A competência concorrente é regulada nos arts. 21 e 22 do Código de Processo Civil.

O primeiro dispõe que compete “à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: a) o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; b) no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; c) o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil”.

Ademais, nos termos do art. 22 do CPC, compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: d) de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; ou o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos; e) decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil; f) em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional.

Por se tratar de competência concorrente, as hipóteses arroladas nos arts. 21 e 22 do Código não excluem necessariamente a possibilidade de os litígios serem processados e julgados por órgãos jurisdicionais de outros Estados soberanos.

A escolha de atuação da jurisdição nacional será feita pelo autor, vez que sem esta provocação certamente a autoridade judiciária brasileira não vai atuar em função do princípio da inércia jurisdicional.

Entretanto, a vontade das partes pode limitar a atuação da jurisdição brasileira, desde que estas expressamente pactuem que submeterão o litígio a outra jurisdição.

Nesse sentido, dispõe o art. 25 do Código que “não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional”.

O dispositivo, portanto, se ocupa em preservar a autonomia da vontade das partes, impedindo que a autoridade brasileira processe e julgue causa quando “houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em

contrato internacional”.

Portanto, a vontade das partes pode afastar a atuação da jurisdição brasileira mesmo que se trate de hipótese admitida genérica e abstratamente pelos arts. 22 e 23 do CPC, desde que não se trate de hipótese de competência exclusiva.

As hipóteses de competência exclusiva são estabelecidas pelo art. 23 do CPC, que estabelece que “compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II – em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional; III – em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

Nesses casos, a competência da jurisdição brasileira é exclusiva, uma vez que é inadmissível o processamento e julgamento da causa por órgãos estatais de qualquer outro país.

Portanto, nestas hipóteses, o sujeito interessado em reivindicar a coisa ou disputar os bens situados no Brasil deve necessariamente buscar a autoridade judiciária brasileira competente.

A “eleição do foro estrangeiro” prevista no art. 25, conforme já afirmado, não se aplica nas hipóteses de competência exclusiva.

O art. 24 do Código integra o capítulo “Dos limites da jurisdição nacional”, mas, rigorosamente, não trata da repartição de competência ou da limitação à atuação da jurisdição brasileira.

O dispositivo, partindo do pressuposto que a competência concorrente não exclui a atuação da jurisdição estrangeira, estabelece que a eventual pendência de uma causa perante o Judiciário estrangeiro não induz a

litispendência capaz de obstar o ajuizamento da causa no Brasil, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil⁵⁰².

15.5 Identificação da competência originária dos tribunais superiores mediante a aplicação das normas específicas e excepcionais

Conforme já demonstrado no Capítulo 5, cada uma das “Justiças”, comum (federal e estadual), do trabalho, eleitoral e militar, possui um tribunal superior, respectivamente o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar.

Acima de todos estes encontra-se o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e órgão de cúpula de todo o Poder Judiciário.

Estas cortes, em regra geral, possuem competência recursal, cabendo-lhes, portanto, precipuamente julgar recursos ordinários e extraordinários interpostos contra decisões dos órgãos das instâncias inferiores onde, via de regra, o processo tem início e a causa é julgada pela primeira vez.

Entretanto, excepcionalissimamente, a Constituição Federal estabelece a competência originária destes tribunais superiores, hipóteses em que a ação desde já deve ser endereçada a estas cortes.

Todos os casos de competência originária dos tribunais superiores decorrem de normas expressa e específicas constantes da lei ou, no caso do STJ e do STF, necessariamente do texto da Constituição Federal.

A competência do Supremo Tribunal Federal está disposta no art. 102 da CF, que estabelece em seu inc. I hipóteses de competência originária, ou seja, ações que em razão da matéria, pessoas envolvidas ou função a ser desempenhada, devem ter início já na Corte Suprema.

A par disso, os incisos II e III do art. 102 da CF estabelecem a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, que atua nestas

hipóteses como uma instância de revisão.

A análise pormenorizada de cada uma das hipóteses, de competência originária e recursal do STF, escapa ao objeto desta Introdução, sendo, neste campo, suficiente o registro desta previsão constitucional, que dada a posição de supremacia hierárquica destas normas exclui a possibilidade de apreciação das causas arroladas no art. 102 da Constituição Federal por qualquer outro órgão do Poder Judiciário.

Situação semelhante ocorre com o Superior Tribunal de Justiça, que possui sua competência disciplinada pelo art. 105 da Constituição Federal.

Os incisos II e III do art. 105 estabelecem a competência recursal do STJ, ao passo que o inc. I do referido artigo estabelece as causas de competência originária deste tribunal superior.

Identificada a competência originária destas cortes superiores, as demais questões relacionadas à repartição de competência, como foro e “Justiça” competente, simplesmente não se colocam, uma vez que estes tribunais são únicos, possuem sede em Brasília e jurisdição sobre todo o território nacional.

15.6 Repartição de competência entre as “Justiças” mediante aplicação dos critérios genéricos de repartição de competência

Vencidas as questões relacionadas à possibilidade de atuação da Jurisdição brasileira e descartada a atuação excepcional dos tribunais superiores decorrentes de norma expressa e específica constante da Constituição Federal, cabe ao operador do Direito, ocupado da identificação do juízo competente para a causa, primeiramente identificar a “Justiça” competente.

A repartição de competência entre as Justiças é realizada pela Constituição Federal e pela lei, que se valem, precipualemente, dos critérios matéria, pessoa e funcional.

É a matéria o critério definidor da competência das Justiças

especializadas e, por exclusão, também de Justiça comum.

A competência da Justiça do Trabalho, por exemplo, é definida no art. 114 da Constituição Federal, que estabelece, verbis: “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I) as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II) as ações que envolvam exercício do direito de greve; III) as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; IV) os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; V) os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI) as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; VIII) a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX) outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”.

A Justiça Militar tem sua competência definida no art. 124 também da Constituição Federal, que estabelece: “à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei”.

No que tange à Justiça Eleitoral, a Constituição Federal, em seu art. 121, se limita a estabelecer que a “lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais”.

A lei complementar a que se refere a Constituição, porém, ainda não foi editada, sendo pacífico na doutrina e jurisprudência que o Código Eleitoral, lei ordinária anterior à Constituição de 1988, foi recepcionado como lei complementar.

Assim, os arts. 22, 23, 29, 30 e 35 do Código Eleitoral disciplinam a

competência da Justiça Eleitoral, além de reparti-la entre seus diversos órgãos. Todos os dispositivos definem a competência da Justiça Eleitoral pelo fato de a matéria envolvida no feito ser relacionada com as eleições para cargos do executivo e legislativo federais, estaduais e municipais, como registro de candidatura, propaganda eleitoral, inelegibilidade, financiamento de campanha etc.

Já a repartição entre os órgãos da Justiça eleitoral é realizada pelos mesmo dispositivos do Código Eleitoral, que se vale, além do critério matéria, em grande medida, do critério funcional, estabelecendo, por exemplo, que compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente: “o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus Diretórios Nacionais e de candidatos a Presidência e Vice-Presidência da República” (art. 22, inc. I); e ao Tribunal Regional Eleitoral processar e julgar originariamente: “o registro e o cancelamento do registro dos Diretórios Estaduais e Municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a Governador, Vice-Governadores, e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas” (art. 29, inc. I).

O estudo pormenorizado das matérias de competência da Justiça Eleitoral, obviamente, escapa o objeto desta Introdução até porque sequer pertencem ao campo de estudo do Direito Processual Civil.

Excluídas as matérias de competência das Justiças especializadas, todas as demais são de competência da “Justiça comum”.

Entretanto, considerando que a Justiça comum ainda se subdivide em Justiça federal e Justiças estaduais, é necessária a utilização dos critérios genéricos de repartição de competência para identificar qual destas duas “Justiças” é competente para processar e julgar a causa.

Nesse passo, o principal dispositivo é o art. 109 da Constituição Federal, pois este define a competência da Justiça federal, sendo a competência das Justiças estaduais estabelecida por exclusão.

O art. 109 da Constituição Federal se vale precipuamente dos critérios matéria, pessoa e funcional.

O critério matéria é consagrado, por exemplo, no art. 109, inc. XI, que determina ser da competência da Justiça federal processar e julgar as causas que versem sobre “a disputa sobre direitos indígenas”.

O critério funcional é previsto no art. 109, inc. VIII, que estabelece ser da competência da Justiça federal processar e julgar “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal”.

Entretanto, é o critério pessoal o principal definidor da competência da Justiça federal em função do art. 109, inc. I, que estabelece ser da competência dos juízes federais “processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

O rol do art. 109 é taxativo, o que implica dizer que apenas as causas ali expressamente previstas são da competência da Justiça federal.

Fora destas hipóteses de competência da Justiça federal e das demais Justiças especializadas, por exclusão, competirá à Justiça estadual processar e julgar a causa.

Contudo, considerando que cada Estado da federação organiza sua própria “Justiça”, definir o que compete à Justiça estadual não é suficiente, surgindo, conseqüentemente, a questão: qual “Justiça estadual” é a competente?

Essa resposta depende da aplicação do critério territorial, tema a ser enfrentado no item seguinte (15.8).

Antes disso, necessária se faz a verificação da eventual e excepcional atuação dos tribunais de segundo grau da justiça estadual ou federal.

15.7 Identificação da competência originária dos tribunais de segundo grau

Uma vez identificada a “Justiça” competente para processar e julgar a causa, faz-se necessário, conforme ensinam Cintra, Dinamarco e Grinover⁵⁰³, identificar dentro desta se a causa é de competência do tribunal ou dos juízos de primeiro grau.

Isso porque algumas situações excepcionais não são submetidas aos órgãos jurisdicionais de primeiro grau, pois se sujeitam a processamento e julgamento diretamente pelos tribunais.

Trata-se, repita-se, de situação rara e excepcional, pois, tal como a competência originária dos tribunais superiores abordadas no item 15.5, a competência dos tribunais de segundo grau de jurisdição, em regra, é recursal, só existindo competência originária quando houver norma legal ou constitucional expressa nesse sentido.

Portanto, o parâmetro normativo definidor da competência dos tribunais de Justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais e tribunais regionais do trabalho são do tipo normas excepcionais e específicas.

É o caso, por exemplo, do art. 108 do Constituição Federal, que estabelece ser da competência originária dos tribunais regionais federais processamento e julgamento: a) dos juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e dos membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) das revisões criminais e das ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região; c) dos mandados de segurança e dos habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal; d) dos habeas corpus, quando a autoridade coautora for juiz federal; e) dos conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal.

Já a competência originária dos tribunais de Justiça estaduais, em regra, é estabelecida pelas constituições estaduais dos respectivos Estados.

Isso porque, como regra, tais órgãos têm competência recursal, atuando no julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos juízes de primeiro grau, sendo possível o estabelecimento de competência originária destas cortes quando as Constituições estaduais consagrarem normas excepcionais e específicas de identificação de competência.

15.8 Identificação do foro competente mediante aplicação do critério territorial de repartição de competência

Ressalvadas as hipóteses de competência originária de algum tribunal, a definição da “Justiça” competente não permite a total identificação do juiz natural.

Nesse contexto, o passo seguinte é identificar o foro competente para o processamento do feito.

Foro, na lição de Cândido Rangel Dinamarco⁵⁰⁴, é a base territorial de cada órgão judiciário. Na Justiça estadual o foro é denominado comarca e na Justiça federal o foro é denominado seção judiciária.

A competência territorial é disciplinada basicamente no Código de Processo Civil entre os arts. 46 e 53. Os referidos dispositivos combinam uma regra geral e uma série de dispositivos especiais.

A regra geral é estabelecida no art. 46, que estabelece ser competente o foro do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis.

Assim, ações de cobrança, reparação de danos, indenizações em geral, bem como ações cujo objeto sejam bens móveis, o autor deve propor a ação no foro do domicílio do réu.

Entretanto, a regra do foro do domicílio do réu tem uma série de exceções, por exemplo, a regra do art. 47 do CPC, que estabelece ser

competente “o foro de situação da coisa”, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis.

Assim, quando a causa versar sobre bens imóveis, é indiferente para fins da definição do foro competente o domicílio do réu, uma vez que o foro do local da coisa é o fator territorial determinante para fins de definição de competência.

O art. 53 do CPC também arrola uma série de normas especiais de repartição de competência por força do critério territorial.

Nesse sentido, nos termos do referido dispositivo, é competente o foro:

I – para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

- a) de domicílio do guardião de filho incapaz;
- b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;
- c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

II – de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

III – do lugar:

- a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
- b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;
- c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;
- d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;
- e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;
- f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação

de dano por ato praticado em razão do ofício;

IV – do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V – de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

Ademais, outras regras especiais restam dispostas no Código de Processo Civil, notadamente no art. 49, que estabelece que “a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias”, e no art. 50, que determina que “a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente”.

No que tange às causas em que a União, suas autarquias e fundações públicas sejam parte, é competente o foro de domicílio do réu quando os entes federados forem autores (art. 51 do CPC e art. 109, § 1º, da CF) e o domicílio do autor, o local do fato, ou mesmo o Distrito Federal nas causas em que as pessoas jurídicas de direito público sejam rés, conforme os arts. 51 do Código e 109, § 2º, da Constituição Federal.

Vale o destaque de que, via de regra, o critério territorial é categorizado como competência relativa, cuja não observância, tal como será visto no item 15.11, não acarreta nulidade do processo e das decisões judiciais proferidas, podendo ser convalidada caso não suscitada pelo réu, ou mesmo modificada por convenção das partes, conexão ou continência⁵⁰⁵.

15.9 Identificação da competência dos juizados especiais mediante aplicação dos critérios matéria e valor da causa

Os juizados especiais são órgãos da Justiça comum (federal e estadual) com competência para julgar causas de menor complexidade, assim

definidas em lei, notadamente as Leis n. 9.099/95, n. 10.259/2001 e n. 12.153/2009.

Cumprе ressaltar de antemão que a eventual submissão da causa à competência dos juizados especiais só se impõe nas hipóteses em que no foro competente existam juizados instalados.

Em outras palavras, nas comarcas e seções judiciárias em que não existirem juizados especiais, mas apenas “varas comuns”, ainda que a matéria ou o valor sejam de competência daqueles órgãos, a causa será processada e julgada por estas.

É por essa razão que, antes de investigar a competência dos juizados especiais é preciso estabelecer o foro competente, nos termos dos critérios arrolados no item anterior.

O valor da causa é o principal critério definidor da competência dos juizados especiais, tanto na Justiça federal quanto na Justiça estadual.

Na Justiça estadual o art. 3º, inc. I, da Lei n. 9.099/95 define a competência dos juizados especiais cíveis de acordo com o valor da causa, estabelecendo que compete a estes órgãos processar e julgar as causas cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos, assim como a Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2º, estabelece que a competência para os juizados especiais da Fazenda Pública é para causas até 60 salários mínimos.

Na Justiça federal o valor da causa também é utilizado para definição da competência dos juizados especiais federais, pois, nos termos do art. 3º da Lei n. 10.259/2001, compete a estes órgãos julgar as causas contra a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais de até 60 salários mínimos.

O valor da causa deve corresponder ao valor do pedido, ou mais amplamente do proveito econômico pretendido pelo autor, sendo a identificação deste valor um requisito indispensável da petição inicial,

conforme exigido pelo art. 319, inc. V, do Código de Processo Civil⁵⁰⁶.

Assim, a partir da identificação do valor da causa na própria petição inicial é possível definir se a causa pode ser processada e julgada pelos juizados especiais, caso existam estes órgãos no foro competente, ou se a competência destes está de plano excluído, mesmo que a localidade possua juizados instalados.

Ademais, algumas situações, independentemente do valor da causa, podem ser processadas e julgadas pelos juizados especiais em razão da matéria.

Assim dispõe, por exemplo, o art. 3º, inc. III, da Lei n. 9.099/95, que estabelece competir aos juizados processar e julgar as “ações de despejo para uso próprio”.

De outro lado, algumas matérias e situações litigiosas específicas estão, de plano, excluídas da competência dos juizados independentemente do valor da causa.

É o caso, por exemplo, do disposto no art. 3º, § 1º, inc. III, da Lei n. 12.152/2009, que exclui da competência dos juizados especiais “as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares”, e no art. 3º, § 1º, inc. III, da Lei n. 10.259/2001, que possui vedação semelhante no âmbito dos juizados especiais federais, entre outras situações.

Por fim, vale destacar que algumas causas são expressamente excluídas da apreciação dos juizados especiais por força do critério funcional, como é o caso das ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos a teor do art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei n. 10.253/2001 e do art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei n. 12.152/2009, por exemplo.

Assim, logo após identificado o foro competente, deve o operador do

Direito, ocupado com a definição do órgão jurisdicional competente, verificar se a referida comarca ou seção judiciária possui juizados especiais, submetendo a estes órgãos as causas que em razão da matéria ou valor devem ou podem ser processadas e julgadas por eles.

De outro lado, caso o foro competente não possua juizados especiais instalados, a causa será processada e julgada pelo órgão da justiça estadual ou federal (vara) ainda que a causa pudesse ser processada em julgada pelos juizados.

A competência dos juizados especiais como regra é relativa, mas pode ser absoluta por expressa disposição legal, a exemplo do art. 3º, § 3º da Lei n. 10.259/2001, que dispõe que “no foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta”⁵⁰⁷.

15.10 Identificação da vara competente mediante aplicação dos critérios matéria, pessoa ou função

A existência de juizados especiais não é a única hipótese de repartição de competência entre órgãos jurisdicionais com a mesma competência territorial.

Isso porque é muito comum, sobretudo nas comarcas e seções judiciárias de grande porte, a existência de mais de um órgão jurisdicional fora do sistema dos juizados especiais.

Nessas situações, a tendência é que cada uma das varas seja especializada em determinado tipo de litígio, ou seja, especializada no processamento e julgamento de determinada matéria (família, inventário e partilha, falências, previdência etc.), pessoa (Fazenda Pública estadual, Fazenda municipal, p. ex.) ou função (v.g., execução fiscal).

Trata-se de uma forma de otimizar a atividade jurisdicional especializando os órgãos judiciários em determinados tipos de causa.

Nesse contexto, em havendo mais de uma vara no mesmo foro, é muito provável que cada uma delas possua algum tipo de especialidade em

determinada matéria, pessoa ou função.

A repartição em razão da matéria permite, por exemplo, a criação de varas especializadas em direito de família, sucessões, previdenciário, empresarial, falências, entre muitas outras especialidades.

Ademais, o critério pessoa também é muito utilizado para definição da competência das varas especializadas especialmente no caso das “varas da Fazenda Pública”, que possuem competência para processar e julgar as causas em que os entes públicos sejam partes ou assistentes.

Já o critério funcional é responsável, por exemplo, por definir a competência das “varas de execuções fiscais”.

As fontes para o estabelecimento destes critérios são as leis de organização judiciária, que no âmbito federal encontra-se na Lei n. 5.101/66. Já no âmbito das Justiças estaduais, cada Estado possui sua própria lei de organização judiciária.

Assim, é a lei de organização judiciária a fonte do Direito Processual Civil que vai estabelecer, além da própria existência, a competência de cada uma das varas integrantes de uma mesma porção territorial, estabelecendo que critérios (matéria, pessoa, funcional) serão determinantes para essa definição⁵⁰⁸.

Por mais que existam na comarca ou seção judiciária varas especializadas, sempre haverá uma ou mais varas com competência residual, isto é, com competência para, por exclusão, processar e julgar as causas não sujeitas a nenhuma vara especializada. Via de regra, as varas com essa competência residual são denominadas de “varas cíveis”.

Vale salientar que algumas comarcas simplesmente não possuem essa subdivisão, pois, em razão do diminuto número de processos nestas localidades, existe uma única vara, sendo nesta hipótese esse órgão jurisdicional competente para todas as causas daquela “Justiça”.

Assim, uma vez identificados a Justiça e o foro competente, salvo o caso

de comarcas de vara única, cabe ao operador do Direito, ocupado na identificação do órgão jurisdicional competente, verificar se há vara especializada no processamento e julgamento da causa em função dos critérios funcional, pessoa ou matéria ou, se é caso de, por exclusão, submeter a causa a vara cível.

Sempre que identificado mais de um órgão para o processamento e julgamento da causa, a definição de qual entre estes será o responsável pelo feito será realizada via distribuição por sorteio.

15.11 O desrespeito às normas de competência e respectivas consequências processuais

Tão importante quanto conhecer as normas de repartição de competência e aplicá-las corretamente é sistematizar as consequências processuais nas situações em que estas regras venham a ser desrespeitadas.

Em outras palavras, são necessários a sistematização e o estudo dos desdobramentos e sequelas processuais nos casos em que o processo é conduzido e a decisão é proferida por um juiz incompetente.

Neste passo, de antemão, vale destacar que nem todas as irregularidades relacionadas à repartição de competência trazem as mesmas consequências processuais, uma vez que o Código de Processo Civil separa os critérios de definição da competência em duas categorias: a competência absoluta e a competência relativa.

A distinção entre ambas é pressuposto fundamental para a sistematização das consequências processuais nos casos de desobediência às regras de repartição de competência.

15.11.1 Competência absoluta e relativa

Conforme afirmado no item anterior, duas são as categorias de normas relacionadas à repartição de competência: uma, mais grave, categorizada

como normas de competência absoluta, e outra, cujas consequências do desrespeito é menos grave, denominada competência relativa.

Os critérios categorizados como de competência absoluta devem ser rigorosamente observados, uma vez que o desrespeito a estas normas constitui vício grave que impede o desenvolvimento válido e regular do processo e tornam nulas as decisões proferidas pelo juiz absolutamente incompetente.

Isso porque a competência absoluta é um pressuposto processual de validade, conforme visto no item 10.3, “a”, do Capítulo 10 desta Introdução.

Por essa razão, a incompetência absoluta é matéria de ordem pública que deve ser verificada e decretada de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, de tão grave, a decisão de mérito transitada em julgado proferida por juiz absolutamente incompetente pode vir a ser rescindida, pela via da ação rescisória, a teor do art. 966, inc. II, do Código de Processo Civil.

São critérios de competência categorizados como absoluta: a) as normas excepcionais e específicas de identificação de competência previstas na Constituição Federal, como a competência dos tribunais superiores; b) os critérios de repartição em razão da matéria, da pessoa e funcional; c) os critérios valor da causa e territorial, nestes casos apenas quando a lei expressamente dispuser nesse sentido.

Como pressupostos processuais de validade, os critérios supramencionados sempre devem ser respeitados, sob pena de nulidade do processo e, sobretudo, das decisões nele proferidas e, até por este motivo, podem ser verificadas de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, por serem critérios de competência absoluta, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do Código de Processo

Civil⁵⁰⁹.

Já os critérios relacionados à incompetência relativa são vícios tidos pelo próprio sistema do Código como vícios menos graves, toleráveis, que não necessariamente impedem a condução do processo pelo juiz relativamente incompetente e não tornam nulas as decisões proferidas por ele.

Isso porque a incompetência relativa não é pressuposto processual de validade, não podendo sequer ser verificada e decretada de ofício pelo juiz, que só pode analisá-la caso suscitada pela parte.

Ademais, em se tratando de competência relativa podem as partes modificar a competência por convenção, elegendo foro onde será proposta a ação e, além disso, quando não oportunamente suscitada pela parte, a competência pode ser prorrogada.

Desta feita, a vontade das partes pode flexibilizar os critérios de competência relativa, e apenas esta vontade oportunamente manifestada pela parte interessada permite ao juiz manifestar-se sobre eventuais irregularidades a ela relacionadas.

Não suscitada oportunamente pela parte interessada a incompetência relativa, ocorre o fenômeno da prorrogação de competência, que, em última análise, torna competente o juízo a priori relativamente incompetente.

Portanto, justamente, em função da prorrogação de competência, a condução do processo e as decisões proferidas pelo juiz a priori relativamente incompetente não implicam nulidade ou trazem qualquer consequência processual, salvo, repita-se, se suscitada pela parte interessada.

São critérios de repartição de competência relativa o territorial – salvo exceções – e o valor da causa, que também pode ser excepcionado.

Um exemplo de competência definida por critério territorial que, contudo, possui natureza absoluta é estabelecido no art. 47, § 2º, do CPC, que dispõe que “a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação

da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”.

O critério valor da causa, conforme já assinalado, também pode vir a ser categorizado como competência absoluta por expressa determinação legal, como ocorre na definição da competência dos juizados especiais federais, a teor do art. 3º, § 3º, da Lei n. 10.259/2001.

De toda sorte, salvo expressa previsão legal em sentido contrário, os critérios território e valor possuem natureza relativa e o desrespeito não implica automática nulidade do processo ou das decisões preferidas por juiz relativamente incompetente e, até por isso, não se trata de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, bem como deve ser suscitada pela parte interessada (no caso o réu) até a preliminar de contestação sob pena de preclusão e prorrogação de competência.

Assim, ressalvadas as hipóteses em que a lei expressamente categoriza como absoluta, na definição da competência em razão do valor e do território, podem as partes modificar o juízo competente, por convenção, elegendo o juízo competente, ou pode esta incompetência relativa vir a ser simplesmente convalidada pela simples inércia do réu que não a suscite em preliminar de contestação⁵¹⁰.

15.11.2 Consequências processuais do desrespeito aos critérios de competência absoluta

A categorização da competência absoluta como pressuposto processual de validade cujo desrespeito constitui vício grave torna a questão matéria de ordem pública, devendo, por isso, ser verificada e decretada de ofício pelo juiz.

Caso não verificada e decretada pelo juiz de ofício, a incompetência absoluta deve ser alegada pelo réu em preliminar de contestação conforme determina o art. 337, inc. II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, por ser matéria de ordem pública, a não alegação nesta oportunidade não impede que a parte interessada o faça em outro

momento, assim como o magistrado pode decretar a incompetência absoluta a qualquer tempo e grau de jurisdição⁵¹¹.

Ademais, qualquer decisão proferida por juiz absolutamente incompetente é nula, sendo inclusive sujeita à rescisão a decisão de mérito transitada em julgado proferida neste contexto.

Assim, verificada a incompetência absoluta, de ofício ou a requerimento, os autos deverão ser remetidos ao juízo competente para regular processamento e julgamento e, caso esta verificação se dê após a prolação de alguma decisão por parte do juiz incompetente, outra decisão sobre o tema deverá ser proferida pelo juízo competente.

15.11.3 Consequências processuais do desrespeito aos critérios de competência relativa

Considerando que o desrespeito aos critérios de competência relativa é tido pelo sistema do Código como um vício menos grave com capacidade, inclusive, de vir a ser convalidado pela prorrogação de competência, o desrespeito a estes critérios não traz maiores consequências processuais, salvo se alegado pela parte interessada.

Exatamente por ter a capacidade de se convalidar, os vícios relacionados à competência relativa não contaminam a relação processual, não tendo a capacidade de torná-la nula ou sequer gerar a nulidade da decisão proferida pelo juiz relativamente incompetente.

Por esse motivo, o juiz sequer pode verificar e decretar a incompetência relativa de ofício.

A única consequência processual do desrespeito aos critérios de repartição de competência relativa é a remessa do processo para o juiz competente, desde que alegada pela parte interessada, dada a vedação de o juiz decretá-la de ofício.

Portanto, cabe à parte interessada suscitar a incompetência relativa até a preliminar de contestação, sob pena de preclusão.

Caso a parte não suscite a incompetência relativa em preliminar de contestação, ocorrerá a prorrogação de competência, fenômeno que convalida o vício de incompetência relativa e torna o juízo inicialmente relativamente incompetente em juízo competente.

Assim deve ser compreendido o art. 65 do Código de Processo Civil, que estabelece que “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.

Portanto, de duas uma: ou a incompetência relativa é suscitada e decidida logo no início do processo e, caso reconhecida, deverão os autos ser remetidos ao juízo competente; ou esta questão não é colocada preliminarmente pelo réu, hipóteses em que o vício se convalida não gerando nenhum tipo de nulidade ou seqüela processual.

15.12 Modificação da competência

Em cinco situações o sistema processual civil admite a denominada modificação de competência assim entendida, a possibilidade de alteração do juízo em princípio competente para a causa.

Nesse sentido, em algumas hipóteses, o próprio Código de Processo Civil determina ou permite que as regras de repartição de competência sejam flexibilizadas por circunstâncias expressamente previstas em lei ou mesmo por vontade das partes litigantes.

Portanto, a modificação de competência ora é imposta pela própria lei, ora é, apenas, por essa admitida.

São cinco as situações em que se admite a modificação de competência: a) por convenção das partes; b) por prorrogação de competência; c) por conexão; d) por continência; e e) por risco de decisões conflitantes.

As duas primeiras hipóteses são simplesmente admitidas pela lei, ou seja, podem ocorrer desde que haja convenção das partes ou inércia do réu que implica prorrogação.

Já a modificação em caso de conexão, continência ou risco de decisões conflitantes não é uma opção das partes, mas sim uma imposição da lei sempre que verificada uma das hipóteses.

De antemão, aqui, mais uma vez, faz-se necessário dividir a competência em absoluta e relativa.

Isso porque, considerando que a competência absoluta é um pressuposto processual de validade, a modificação de competência, mesmo quando verificada uma de suas hipóteses, é vedada, uma vez que a condução do processo e proferimento de decisão por juiz absolutamente incompetente é vício grave que torna nulo o processo e as respectivas decisões.

De outro lado, considerando que a incompetência relativa é considerada um vício de menor gravidade, cujo desrespeito não implica necessariamente nulidade, o sistema do Código de Processo Civil é mais tolerante com a possibilidade de modificação da competência.

Essa modificação, como dito, pode ser: a) imposta pela lei; ou b) realizada por vontade das partes litigantes.

A lei impõe a modificação de competência nos casos de conexão e continência ou risco de decisões conflitantes, ao passo que a vontade das partes pode modificar a competência via “convenção de foro” ou pela simples inércia do réu em não alegar incompetência relativa quando tiver oportunidade de fazê-lo.

Todas as hipóteses apenas têm lugar, repita-se, quando o critério flexibilizado pela lei ou vontade das partes que leve à modificação da competência for um critério de competência relativa, especialmente a territorial.

Três dispositivos do Código de Processo Civil deixam claro que a modificação de competência só tem lugar nos casos de competência relativa.

O art. 62 do Código reza que “a competência determinada em razão da

matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes”.

Já o art. 63 do CPC dispõe que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.

Ademais, o art. 54 estabelece que apenas a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.

Por conseguinte, as partes não podem por convenção alterar a competência absoluta e, ainda que esta não seja suscitada pelo réu, não ocorrerá prorrogação.

Ademais, mesmo que verificada conexão, continência ou risco de decisões conflitantes, a competência, definida por critérios de competência absoluta, não pode ser alterada.

Nesse sentido, podem as partes, por exemplo, por convenção, alterarem a regra geral de competência territorial, acordando o foro em que o litígio deve ser proposto independentemente do domicílio do réu e demais normas relativas a este critério, mas são vedados acordos que alterem a competência em razão da matéria, pessoa ou função.

Os subitens a seguir serão dedicados a alguns detalhes relativos a cada uma das situações que implicam modificação de competência.

15.12.1 Modificação por convenção das partes

O Código de Processo Civil admite, no art. 63, que as partes convençionem sobre a competência (relativa) fixada a partir dos critérios território e valor.

Dispõe o referido dispositivo que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.

A primeira observação que precisa ser feita neste passo diz respeito à limitação desta possibilidade de convenção às hipóteses em que a

competência em relação ao valor e ao território é relativa, regra geral que possui, contudo, algumas exceções.

A competência territorial é absoluta, por exemplo, quando disser respeito a direitos de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, situações em que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem, necessariamente, ser ajuizadas perante o foro de situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, em razão do que dispõe o § 2º do art. 47 do CPC⁵¹², as ações possessórias imobiliárias também não admitem modificação por convenção das partes.

Já a competência em razão do valor é absoluta, na definição da competência dos juizados especiais federais e dos juizados especiais da Fazenda Pública, a teor do que dispõe os arts. 3º, § 3º, da Lei n. 10.259/2001, e 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, e, portanto, nessas situações não se admite convenção das partes em sentido contrário.

Fora destas hipóteses em que a competência pelos critérios territorial e valor é absoluta, podem as partes, com apoio no art. 63 do Código, convencionarem em que foro causa pode ser ajuizada.

A eleição de foro é a hipótese mais comum de modificação de competência. Nesses casos, os sujeitos de uma relação jurídica podem pactuar, por meio de instrumento escrito, que qualquer litígio independentemente do domicílio atual ou futuro das partes ou de quem figurará como réu de processo deve ser processado em determinado foro.

Ademais, podem as partes convencionar que eventuais litígios, ainda que o valor seja da alçada dos juizados especiais, não poderão ser discutidos perante estes órgãos jurisdicionais.

Quatro parágrafos do art. 63 do CPC regulam alguns aspectos formais e procedimentais do negócio jurídico processual relativo a eleição do foro.

O § 1º do referido dispositivo exige que a eleição de foro conste em um instrumento escrito e faça alusão expressamente a um específico negócio jurídico, sob pena de não produzir efeito.

Assim, restam vedadas cláusulas de eleição de foros genéricas que estabeleçam determinado foro como competente para qualquer litígio que venha a existir entre as partes, bem como não produzem efeitos pactos de eleição de foro verbais.

O § 2º do art. 63 estabelece que o foro de eleição obriga os herdeiros e sucessores das partes, ficando estes sujeitos submetidos ao pactuado pelo de cujus independentemente do foro de seus respectivos domicílios ou mesmo do domicílio do autor da herança.

Já os §§ 3º e 4º do art. 63 versam sobre a eventual abusividade da cláusula de eleição de foro.

Fredie Didier Jr.⁵¹³, com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aduz que se considera abusiva a cláusula de eleição de foro no “contrato de consumo: I) se, no momento da celebração, a parte aderente não dispunha de inteligência suficiente para compreender o sentido e as consequências da estipulação contratual; II) se a prevalência de tal estipulação resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; III) se se tratar de contrato de obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com exclusividade por determinada empresa”.

Tal abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, bem como poderá ser alegada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 63, § 4º, do Código.

15.12.2 Modificação por prorrogação de competência

O fenômeno da modificação da competência por prorrogação, já referido no item 15.11.3, supra, tem lugar sempre que a ação é dirigida a um juízo

relativamente incompetente e o réu não argui esta incompetência relativa até a preliminar de contestação.

Já restou afirmado que a competência relativa é tida como um vício menos grave, tolerado pelo sistema processual e que não implica, necessariamente, nulidade do processo ou das decisões proferidas pelo juiz relativamente incompetente.

Em outras palavras, a incompetência relativa pode ser convalidada caso o réu não a suscite no momento adequado, que, conforme dito, é a preliminar de contestação. Após este momento procedimental opera-se a preclusão do direito do réu suscitar a incompetência relativa.

Ademais, vale lembrar que ao juiz é vedado reconhecer a incompetência relativa de ofício.

Assim, caso o réu permaneça inerte até a preliminar de contestação, tendo seu direito atingido pela preclusão e considerando que o magistrado não pode decretar a incompetência relativa de ofício, tem-se que a desobediência a estes critérios não pode mais ser suscitada, verificada e mesmo reconhecida no processo, passando a causa a ser processada e julgada definitivamente pelo juiz que, a princípio, era relativamente incompetente.

O fenômeno que transforma o juiz relativamente incompetente em competente para a causa, em razão da inércia do réu que não suscita a questão até a preliminar de contestação, é denominado prorrogação de competência.

Vale reiterar que a prorrogação de competência, aliás como todas as hipóteses de modificação da competência, só tem lugar caso o critério desrespeitado seja de natureza relativa, uma vez que os critérios de natureza absoluta, além de não precluírem e poderem ser detectados de ofício pelo juiz, são verdadeiros pressupostos processuais de validade, que não se convalidam e contaminam a relação processual e a decisão nela

proferida.

Desta feita, o fenômeno da prorrogação de competência tem lugar especialmente em casos de incompetência (relativa) territorial, em que o réu não alega o desrespeito aos critérios de repartição até a preliminar de contestação.

Assim, caso o réu seja demandado fora de seu domicílio, de duas uma: a) ou ele alega o desrespeito à regra do art. 46 do Código de Processo Civil até a preliminar de contestação; ou b) ele permanece inerte até esse momento e perde o direito de suscitar a incompetência relativa, caso em que se opera a prorrogação de competência que transforma o juiz de fora de seu domicílio competente para a causa.

15.12.3 Modificação por conexão, continência ou risco de decisões conflitantes

Ao contrário das hipóteses de modificação da competência por convenção das partes e mesmo por prorrogação de competência fruto da inércia do réu, em que o fator determinante é a vontade das partes, manifestada expressa ou tacitamente, o Código de Processo Civil estabelece três situações em que a modificação da competência é imposta pela lei.

Trata-se das hipóteses de conexão, continência ou quando verificado o risco de decisões conflitantes.

Por conexão, deve ser entendida a inter-relação entre duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, conforme estabelece o art. 55 do Código de Processo Civil.

Paulo Henrique dos Santos Lucon⁵¹⁴ conceitua conexão como “um fenômeno típico da relação de semelhança entre duas ou mais demandas que tenham um ou mais elementos constitutivos em comum, sem terem todos porque não seriam, nesse caso, conexas (ou semelhantes) mas iguais”.

É o caso, por exemplo, de duas causas que versem sobre aspectos de um

mesmo contrato: uma delas questionando a nulidade dele e outra, ajuizada pela parte contrária, exigindo seu cumprimento integral.

Nessas hipóteses, imaginando que as partes contratantes, "A" e "B", residam em comarcas distintas, a ação proposta por "A" questionando a nulidade do contrato deveria, pela regra do art. 46 do CPC, ser proposta perante o juízo do domicílio de "B", ao passo que a ação proposta por "B" deveria ser ajuizada na comarca onde "A" tem domicílio, o que geraria a possibilidade de o juiz do processo ajuizado por "A" declarar o contrato nulo e o juiz do processo ajuizado por "B" determinar o cumprimento integral do mesmo contrato.

Para evitar essas situações incompatíveis, a conexão, uma vez detectada, impõe a reunião de ambos os processos perante um dos juízos, ainda que pelas regras de repartição de competência (relativa) territorial cada uma das ações devesse ser ajuizada perante foros distintos.

Nesse sentido, Paulo Lucon⁵¹⁵ conclui, com acerto, que, "do ponto de vista essencialmente prático, o efeito especial da conexão de causas é tornar competente para o julgamento delas um juiz que, de outro modo, não o seria, o que faz com que surja uma norma própria de competência, usualmente conhecida por competência por conexão de causas".

Já a continência, nos termos do art. 56 do CPC, ocorre quando entre duas ou mais ações houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

É a típica situação que ocorre quando uma das partes contratantes ajuíza uma ação pretendendo ver declarada a nulidade de uma cláusula contratual, enquanto o outro sujeito contratante ajuíza uma ação pretendendo ver declarada a validade de todo o contrato.

Obviamente, a ação que versa sobre a nulidade de uma cláusula contratual está contida na ação que pretende ver declarado válido todo o contrato.

Nessas situações, a exemplo da conexão, proposta uma causa que contenha o objeto de uma ação já pendente por força da continência, o juiz da primeira ação será competente também para julgar a segunda⁵¹⁶.

Portanto, verificado um destes dois fenômenos, o Código de Processo Civil determina, nos arts. 54 e 55, § 1º, que ambas as causas inter-relacionadas pela conexão ou continência sejam julgadas pelo mesmo juízo como forma de evitar julgamentos contraditórios por juízos distintos.

Nessas situações, de rigor, o Código flexibiliza as regras de competência relativa de modo a permitir a reunião de processos perante o mesmo juízo ainda que, se aplicado rigorosamente os critérios de repartição, os juízos deveriam ser distintos.

Assim, se, por exemplo, dois processos forem ajuizados por duas partes contratantes residentes em comarcas diferentes, o que a priori geraria a necessidade de ajuizamento das ações em foros distintos – pela regra do art. 46 do CPC –, o segundo processo passa a ter sua competência modificada pela conexão ou continência, obrigando o ajuizamento da segunda ação perante o juízo da primeira, ainda que pelo critério de repartição de competência relativa outro fosse o foro competente para a causa.

Nesses casos, os processos devem ser reunidos perante o juízo prevento (art. 58 CPC), assim entendido aquele perante o qual a primeira ação foi registrada ou distribuída (art. 59 do Código).

Assim, voltando ao exemplo em que as partes de um mesmo contrato são “A” e “B”, e supondo que “A” resida em Caruaru (PE) e “B” em Recife (PE), na hipótese de “A” pretendendo ver declarado nulo o contrato ajuizar esta ação em Recife (domicílio de “B”), caso “B” pretenda ajuizar uma ação voltada a exigir o mesmo cumprimento por “A”, em vez de esta segunda ação vir a ser ajuizada em Caruaru (domicílio de “A”), ela terá sua competência modificada devendo ser ajuizada em Recife (juízo prevento),

por força da conexão.

Ademais, a preocupação com a existência de decisões incompatíveis entre si leva o Código a determinar a reunião de processos perante o mesmo juízo, ainda que não haja tecnicamente conexão ou continência, mas sempre que detectado “risco de decisões conflitantes”.

Assim dispõe o art. 55, § 3º do CPC, verbis: “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Trata-se, nas palavras de Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa⁵¹⁷, de uma “norma de fechamento” voltada a viabilizar o atingimento do escopo maior da reunião de processos pela conexão, qual seja, evitar-se decisões antagônicas em desprestígio ao Poder Judiciário.

É o caso, conforme ilustra Ronaldo Cramer⁵¹⁸, de uma ação de investigação de paternidade proposta por “A” contra “B” e uma ação de alimentos proposta por “B” contra “A”, em que as demandas não têm causas de pedir ou pedidos comuns, sendo inclusive as relações de direito material distintas (uma é filiação e outra alimentos) mas que, no entanto, é inegável o risco de decisões conflitantes porque “B” pode não ser considerado pai na primeira ação e vir a ser condenado a pagar alimentos por força da paternidade, se a segunda ação vier a ser processada e julgada por outro juízo.

Portanto, a lógica da reunião de processos perante o juízo preventivo tem lugar também nas situações em que exista o risco de decisões conflitantes, ainda que não se esteja diante tecnicamente de conexão ou continência.

15.13 Conflito de competência

A última preocupação do Código no capítulo dedicado à competência é com o conflito de competência que ocorre nos termos do art. 66 quando: I) dois ou mais juízes se declaram competentes; II) dois ou mais juízes se

consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; e III) surge entre dois ou mais juízes controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

São situações, portanto, em que há pronunciamentos jurisdicionais conflitantes acerca da incidência dos critérios de repartição ou modificação de competência que levam à possibilidade de uma mesma ação possuir dois juízes que entendam ser competentes ou, o contrário, causas em que nenhum juiz entende ser competente para processá-la e julgá-la.

Na primeira situação, descrita no art. 66, inc. I, do CPC, tem-se o denominado conflito positivo de competência, fazendo-se necessária a definição de qual dos juízos deve processar e julgar a causa.

Já o inc. II do art. 66 do CPC configura o denominado conflito negativo de competência, caracterizado pela existência de dois ou mais pronunciamentos judiciais de juízes que se declaram incompetentes para a causa, o que, por óbvio, igualmente, demanda a necessidade de uma definição sobre o ponto.

Ademais, o conflito de competência pode ocorrer quando a indefinição de qual órgão é competente para processar e julgar a causa é fruto da controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, a teor do art. 66, inc. III, do Código de Processo Civil.

O conflito oriundo desta regra pode ser positivo ou negativo, pois, conforme ensina Ronaldo Cramer⁵¹⁹, a controvérsia acerca da reunião ou separação de processos pode redundar em mais de um juiz declarando-se competente ou em vários juízes dando-se por incompetentes.

Sempre que caracterizada uma destas hipóteses deve o próprio juiz, de ofício, suscitar o conflito ou atribuir a causa a outro juízo.

Caso o juiz a quem se atribuiu a competência aceite tal atribuição e se dê por competente, deverá processar e julgar a causa. Caso contrário, suscitará o conflito.

O conflito terá de ser processado e julgado pelo tribunal que tenha competência sobre todos os juízos envolvidos, ou seja, o tribunal de segundo grau, caso o conflito seja entre órgãos integrantes da mesma "Justiça" e do mesmo Estado ou região, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, caso o conflito seja entre órgãos de "Justiças", Estados e regiões diferentes, conforme estabelece o art. 105, inc. I, "d", da Constituição Federal.

Por fim, se o conflito de competência ocorrer entre o próprio Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal, caberá ao Supremo Tribunal Federal resolvê-lo conforme estabelece o art. 102, inc. I, "o", da Constituição Federal.

Capítulo 16 Litisconsórcio

16.1 Litisconsórcio: conceito e cabimento

Se, em princípio, as relações jurídicas pressupõem a existência de dois sujeitos de direito, um em cada polo da relação (credor e devedor, comprador e vendedor, Fazenda Pública e contribuinte), em muitos casos as relações de direito material envolvem mais de duas pessoas, sendo, portanto, maiores do ponto de vista subjetivo.

Assim, no plano do direito obrigacional, por exemplo, o Código Civil admite amplamente a possibilidade de dívidas solidárias nos termos do arts. 264 e seguintes, bem como a existência de cotitulares de um mesmo direito, como nos casos de copropriedade.

Da mesma forma, caso um terceiro pretenda anular em juízo um negócio jurídico que lhe é prejudicial e que envolva outras duas pessoas, a demanda deve ser promovida contra esses dois sujeitos participantes do negócio jurídico que se pretende anular.

Tais como as relações jurídicas simples entre dois sujeitos, as relações jurídicas que envolvam várias pessoas podem se tornar litigiosas e levar à necessidade de solução pela via jurisdicional.

Por essas razões, o sistema processual civil admite e regulamenta a possibilidade de dois ou até mais sujeitos litigarem em um mesmo polo da relação processual.

Ao fenômeno dá-se o nome de litisconsórcio, regulado entre os arts. 113 e 118 do Código de Processo Civil.

O art. 113 do Código de Processo Civil dispõe sobre o cabimento do litisconsórcio e estabelece que “duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II

– entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III – ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito”.

Um exemplo de litisconsórcio com fundamento no art. 113, inc. I (“comunhão de direitos e obrigações”), no polo ativo, é uma demanda proposta por dois coproprietários em defesa da coisa, uma vez que a propriedade, nesse caso, é um direito comum a ambos, o que justifica a formação do litisconsórcio. No polo passivo, uma situação muito comum de litisconsórcio por comunhão de obrigações é a demanda proposta pelo credor contra os devedores solidários, que, nos termos do direito material, respondem conjuntamente pela dívida.

Outra situação de formação de litisconsórcio passivo com fundamento no art. 113, inc. I, do Código de Processo Civil é a demanda proposta pelo consumidor contra todos os responsáveis pelo dano causado pelo vício do produto, que, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, “respondem solidariamente pelos vícios da qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo”.

O cabimento do litisconsórcio também se justifica em casos de “conexão” (art. 113, inc. II, do CPC).

Nos termos do art. 55 do Código, “reputam-se conexas duas ou mais causas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Na doutrina, Paulo Henrique dos Santos Lucon⁵²⁰ conceitua conexão como “fenômeno típico da relação entre duas causas que tenham um ou mais elementos constitutivos em comum, sem serem todos porque não seriam, nesse caso, semelhantes (conexas), mas iguais”.

Assim, são conexas e podem ser formuladas em litisconsórcio com fundamento no art. 113, inc. II, do Código de Processo Civil as demandas indenizatórias propostas por dois sujeitos que tenham sofrido o mesmo acidente automobilístico, uma vez que, por mais que cada vítima proponha uma “ação” autônoma contra o causador do dano, o acidente constitui a

“causa de pedir” de ambas, o que as torna “ações conexas”.

Ademais, o art. 113, inc. II, do Código permite a formação do litisconsórcio quando houver “conexão pelo pedido”. Assim, se dois condôminos pretenderem anular em juízo uma decisão tomada em assembleia condominial, configurar-se-á a conexão pelo pedido, podendo, portanto, a demanda ser proposta por ambos em litisconsórcio.

Por fim, o Código de Processo Civil admite, no art. 113, inc. III, a formação do litisconsórcio por “afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito”.

Afinidade, segundo Paulo Henrique dos Santos Lucon⁵²¹, representa uma “conexão menos tênue”, consistente apenas na identidade parcial de elementos identificadores da demanda, como ocorre, por exemplo, quando há “coincidência da fundamentação jurídica do pedido”.

As demandas individuais propostas por servidores públicos integrantes de uma mesma categoria, em que cada um pretende, para si, ver reconhecido o direito à percepção de uma gratificação ou vantagem pecuniária, não são causas conexas, mas possuem afinidade suficiente para autorizar a formação do litisconsórcio entre dois ou mais autores, com fundamento no art. 113, inc. III, do Código de Processo Civil, simplesmente porque fundadas nas mesmas razões e fundamentos jurídicos.

Como regra geral, a possibilidade de o processo envolver mais de uma pessoa no mesmo polo não implica dizer que a formação do litisconsórcio seja obrigatória.

Há, porém, conforme se verá no item 16.2, “b”, infra, hipóteses em que a demanda tem de, obrigatoriamente, envolver mais de uma pessoa no mesmo polo.

De todo modo, ainda quando sem obrigatoriedade, razões de ordem sistemática, como a necessidade de coerência na resposta a dois ou mais sujeitos que se encontrem na mesma situação jurídica do ponto de vista do

direito material, e até de economia e eficiência processual, alcançada pela possibilidade de em um mesmo processo se resolver mais de um litígio, apontam pela utilidade, quando não, necessidade de formação do litisconsórcio.

Por essa razão, o Código de Processo Civil é bastante complacente com a formação do litisconsórcio, admitindo-o não apenas no caso de comunhão de direitos ou obrigações, mas também quando houver conexão ou afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Nesse sentido, nota-se que o Código de Processo Civil não exige que os dois litisconsortes sejam cotitulares da mesma relação jurídica, sendo a “comunhão de direitos e obrigações” apenas uma das hipóteses em que o litisconsórcio é admitido.

A par de referida hipótese, também se admite a formação do litisconsórcio quando entre as partes houver “conexão pelo pedido ou pela causa de pedir” (art. 113, inc. II, do CPC), sem que com isso se exija a cotitularidade do direito pleiteado, como dito.

É por isso que, por exemplo, admite-se que duas pessoas vítimas de um mesmo acidente de veículos possam propor, em conjunto, uma ação de indenização contra o causador dos danos, assim como, com fundamento no inc. III do art. 113, já comentado, dois servidores públicos podem, por ocuparem o mesmo cargo e exercerem a mesma função, praticar, cada um, sua pretensão contra o Estado em um mesmo processo, em litisconsórcio.

Entretanto, o art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil limita a formação do litisconsórcio quando o número de litigantes em um mesmo polo da relação comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

Assim, conforme dito, nada impede que dois ou até mais servidores públicos integrantes da mesma categoria e que exerçam a mesma função ajuízem, em conjunto, uma ação contra a Fazenda Pública, mas, caso essa

ação seja proposta por centenas ou até milhares de servidores, certamente a defesa da Fazenda restaria prejudicada e a própria solução da lide seria atrasada em demasiado. Nessas hipóteses, nos termos do dispositivo citado, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte interessada, poderá limitar o litisconsórcio.

Para que não haja real prejuízo à defesa, nos termos do art. 113, § 2º, do Código, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar, mesmo que o pedido seja indeferido.

A seguir, serão tecidas breves considerações acerca da classificação do litisconsórcio e da relação processual integrada por litisconsortes.

O estudo da classificação se faz necessário, haja vista que, a depender da espécie, a relação entre os litisconsortes e os desdobramentos procedimentais podem variar, conforme se verá na sequência.

Tal classificação tomará por base quatro critérios, o que permitirá a categorização do litisconsórcio: a) segundo a posição ocupada pelos litisconsortes; b) segundo a obrigatoriedade de formação do litisconsórcio; c) segundo o resultado do processo para os litisconsortes; d) segundo o momento da formação do litisconsórcio.

16.2 Classificação do litisconsórcio

a) Classificação segundo a posição das partes: litisconsórcio ativo, passivo e misto

Uma primeira maneira de se classificar o litisconsórcio é levando em consideração a posição em que a pluralidade de partes é verificada.

Classifica-se como litisconsórcio ativo a existência em uma mesma relação processual de mais de um autor, ao passo que se denomina litisconsórcio passivo a existência de mais de um réu.

Na hipótese de a pluralidade de partes existir em ambos os polos da

relação processual, o litisconsórcio é denominado misto.

Assim, se dois sujeitos optarem por litigarem em conjunto contra um ou mais sujeitos dentro das hipóteses autorizadas pelo art. 113 do Código, admite-se a formação do denominado litisconsórcio ativo caso haja apenas um réu; ou litisconsórcio misto caso a demanda proposta por mais de um autor seja contra mais de uma pessoa.

Já o litisconsórcio passivo é uma opção do autor que demanda, em sua petição inicial, a prestação da tutela jurisdicional contra mais de um réu.

Conforme se verá a seguir, em situações excepcionais, pela natureza da relação jurídica objeto do processo ou, ainda, por expressa determinação legal, o autor terá de, necessariamente, propor a demanda contra mais de um sujeito, formando, de modo obrigatório, um litisconsórcio passivo.

b) Classificação segundo a obrigatoriedade de sua formação: litisconsórcio necessário e facultativo

Dispõe o art. 114 do Código de Processo Civil que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Assim, nas hipóteses em que a natureza da relação jurídica ou a lei, expressamente, impuser a formação do litisconsórcio, cabe ao autor propor a demanda e requerer a citação de todos os sujeitos que obrigatoriamente devem estar no polo passivo da relação processual.

Um bom exemplo de obrigatoriedade de formação do litisconsórcio por força da natureza da relação jurídica ocorre quando a coisa pretendida pelo autor pertence a mais de um sujeito, o que, nos termos do direito material, denomina-se copropriedade.

Assim, nas hipóteses de copropriedade, é imperativa a formação de um litisconsórcio passivo, sendo logicamente impossível, por força da natureza

da relação jurídica litigiosa, que o autor demande a coisa pertencente a mais de um sujeito contra apenas um dos proprietários.

Da mesma forma, se alguém que pretenda contratar com o Estado deseje anular a contratação ilicitamente realizada entre o ente estatal e outra empresa concorrente, a pretensão de anulação do contrato existente entre esses sujeitos deve ser ajuizada necessariamente contra o Estado contratante e a empresa contratada. Não é admissível, nessa hipótese, que o contrato seja anulado por uma decisão judicial proferida em um processo proposto apenas contra uma das partes do contrato.

Em outras situações, a lei expressamente determina que mais de um sujeito seja citado, o que implica na obrigatoriedade de formação de um litisconsórcio passivo.

Um exemplo de litisconsórcio obrigatório por expressa disposição legal é encontrado no art. 6º da Lei n. 4.717/65, que disciplina a ação popular voltada a legitimar o cidadão a requerer a anulação de qualquer ato lesivo ao patrimônio público da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Nesse caso, o referido dispositivo determina que a ação será proposta contra as pessoas públicas, privadas e entidades, bem como contra as autoridades, funcionários e administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado ato questionado e contra os beneficiários do ato.

Portanto, a lei exige, expressamente, que todos os sujeitos discriminados na norma sejam partes no processo, fazendo surgir, necessariamente, o litisconsórcio.

É de se notar que, via de regra, o fenômeno do litisconsórcio necessário é atinente à formação do litisconsórcio passivo, uma vez que a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio no polo ativo geraria um dever de demandar o Poder Judiciário, o que contraria a lógica do direito de ação, ou a impossibilidade de um sujeito provocar o Poder Judiciário por

força da vontade de outrem, o que redundaria em uma intolerável ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Desta feita, a formação do litisconsórcio necessário é um fenômeno ligado ao polo passivo da relação processual.

Como regra geral, contudo, o litisconsórcio não é necessário, isto é, não haverá a obrigatoriedade de sua formação.

Portanto, via de regra, mesmo quando admissível a formação do litisconsórcio pelo art. 113 do Código de Processo Civil, é uma opção da parte autora litigar conjuntamente no polo ativo ou propor a ação contra mais de um réu, optando pela formação de um litisconsórcio passivo.

Assim, quando o litisconsórcio é classificado como facultativo, sua formação não é indispensável para fins de validade da relação processual.

Por outro lado, sempre que o litisconsórcio for classificado como necessário por força de lei ou da natureza da relação jurídica litigiosa, a desobediência à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio torna nulo o processo que não venha a ser proposto contra todos os réus, ou, no mínimo, ineficaz a decisão em relação àquele que não integrou a relação processual.

Em função da gravidade do vício, trata-se de matéria de ordem pública sobre a qual o juiz pode se manifestar, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Entretanto, apesar da gravidade, por se tratar de um vício sanável, caso o magistrado, de ofício ou por provocação, detecte a necessidade de formação do litisconsórcio, deverá intimar o autor para requerer e promover a citação dos demais sujeitos que, necessariamente, devem estar presentes na relação processual.

Apesar disso, não cabe ao magistrado promover esse ingresso de ofício, uma vez que, por força da inércia da jurisdição, para que o juiz atue citando alguém, faz-se necessário requerimento expresso do autor nesse sentido.

Portanto, a postura do juiz, ao detectar a obrigatoriedade de formação

do litisconsórcio, é dar oportunidade ao autor para requerer a citação, que, caso requerida e realizada, supre o vício original e permite o prosseguimento do processo (art. 115, parágrafo único, do CPC).

Caso o autor não o faça, considerando tratar-se de vício gravíssimo, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o art. 115 do Código de Processo Civil mitiga a nulidade decorrente da ausência de um dos litisconsortes necessários, dispondo que a sentença de mérito, quando proferida sem a citação de um dos litisconsortes, será: “I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados” (grifos nossos).

Assim, rigorosamente, a falta de citação de todos os litisconsortes necessários não torna nulo o processo em todos os casos, mas apenas naqueles em que a decisão tiver de ser a mesma para todos os sujeitos, o que nos remete, para exata compreensão do dispositivo, à análise também da classificação do litisconsórcio segundo o resultado, nos termos do item “c”, infra.

c) Classificação segundo o resultado: litisconsórcio unitário e simples

O fato de duas ou mais pessoas figurarem no mesmo lado da relação processual não implica dizer que todos esses sujeitos terão o mesmo destino quando do julgamento de mérito do processo.

Assim, quando o autor pleiteia uma indenização contra dois sujeitos que aponta como responsáveis pelo dano, é plenamente possível que um dos réus demonstre a inexistência de culpa, enquanto a responsabilidade do outro litisconsorte resta claramente demonstrada, o que levaria à condenação deste.

A própria regra da independência entre os litisconsortes que autoriza que

cada um atue no processo independentemente da concordância ou, mais amplamente, da conduta dos demais conduz a esta conclusão.

Sempre que o resultado do processo em relação a cada um dos litisconsortes puder ser diferente, esse litisconsórcio é classificado como simples.

Entretanto, em algumas situações, pela natureza da relação jurídica litigiosa, o resultado, ou seja, o julgamento de mérito, terá de ser igual para todos os litisconsortes.

A hipótese é prevista no art. 116 do Código de Processo Civil, que dispõe que “o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes”.

Assim, sempre que o resultado tiver de ser igual para todos os litisconsortes, o litisconsórcio deverá ser classificado como unitário, que, nesse contexto, se contrapõe ao litisconsórcio simples, que admite destinos diversos para os litigantes em um mesmo polo.

Assim, por exemplo, quando proposta por mais de um condômino, em um mesmo processo, uma ação voltada à anulação de uma ata de assembleia condominial, inevitavelmente, o resultado de procedência ou improcedência do pedido de anulação terá de ser igual para ambos os autores. Nessa hipótese, por força da relação jurídica litigiosa, é logicamente impossível a existência de resultados distintos para cada um dos autores, como a ata ser válida para um condômino e nula em relação ao outro.

Da mesma forma, o pedido de qualquer interessado voltado a anular um contrato entre a Administração Pública e uma empresa por nulidade na contratação gera um litisconsórcio unitário, na medida em que a nulidade contratual a ser declarada será uma só para ambas as partes, sendo inconcebível o contrato ser válido para o Estado e nulo para empresa por este contratada, ou vice-versa.

Por outro lado, conforme já asseverado, quando o resultado puder ser diverso para as partes, o litisconsórcio deverá ser classificado como simples.

Assim, por exemplo, se dois servidores públicos demandam em litisconsórcio ativo um pleito contra o Estado, é, em tese, possível restar provado que apenas um deles tenha direito à vantagem pleiteada, hipótese em que o pedido de um autor poderá ser julgado procedente e o do outro, improcedente.

Da mesma forma, uma demanda indenizatória pode ser proposta contra dois sujeitos e apenas um deles vir a ser considerado causador do dano e, portanto, condenado ao ressarcimento, sendo o outro sujeito demandado isento de qualquer responsabilidade quando do julgamento de mérito.

Por fim, vale ressaltar que o fato de o litisconsórcio ser simples não quer dizer que o resultado não possa ser o mesmo para ambos os litisconsortes. De rigor, o que vai caracterizar a espécie é a possibilidade de o resultado vir a ser diferente.

Já no litisconsórcio unitário os resultados diferentes são absolutamente inadmissíveis.

Em outras palavras, mesmo quando o litisconsórcio vier a ser classificado como simples, é possível que os dois litisconsortes obtenham o mesmo resultado, como no caso da ação indenizatória contra dois sujeitos apontados pelo autor como responsáveis, hipótese de litisconsórcio simples que, se demonstrada a culpa de ambos, implica, na prática, a imposição do mesmo resultado para os réus.

A distinção entre o litisconsórcio simples e o unitário está na absoluta impossibilidade de o resultado ser diferente para os litigantes no caso do unitário e, de outro lado, na possibilidade de este resultado ser distinto, no caso do litisconsórcio simples.

d) Classificação segundo o momento de sua formação: litisconsórcio inicial e ulterior

Outra maneira de se classificar o litisconsórcio diz respeito ao momento de sua formação.

Diz-se inicial o litisconsórcio formado desde o início da relação processual, quer porque dois ou mais sujeitos promoveram em conjunto a demanda na mesma petição inicial (litisconsórcio ativo inicial), quer porque o autor propôs a ação e requereu a citação de mais de um réu (litisconsórcio passivo inicial).

Entretanto, excepcionalmente, a formação do litisconsórcio pode ocorrer em um momento posterior ao da formação da relação processual, hipótese em que a doutrina classifica o litisconsórcio como ulterior.

A característica fundamental do litisconsórcio ulterior, que o difere do litisconsórcio inicial, é que aquele é formado em um outro momento do processo.

A razão dessa formação a posteriori pode ser, por exemplo, a detecção pelo juiz da obrigatoriedade de formação do litisconsórcio nos termos do art. 114 do Código, que o levaria a intimar o autor para promover o ingresso de outro réu.

Outro fenômeno que, na prática, implica a formação de um litisconsórcio ulterior é a admissibilidade do ingresso de um assistente litisconsorcial, modalidade de intervenção de terceiro por meio da qual um sujeito que, apesar de não ser parte originária do processo, possui interesse idêntico a uma das partes, o que autoriza a ingressar no processo, tornando-o litisconsorte da parte original, nos termos do art. 124 do Código de Processo Civil⁵²².

Aliás, várias situações categorizadas pelo Código de Processo Civil como modalidades de “intervenção de terceiros” implicam, em última análise, a formação de um litisconsórcio ulterior, a exemplo do que ocorre na denúncia da lide⁵²³, no chamamento ao processo⁵²⁴ e no incidente de desconsideração de personalidade jurídica⁵²⁵.

O tema é objeto de capítulo próprio desta Introdução⁵²⁶.

16.3 Poderes dos litisconsortes

Estarem litigando, em conjunto, de um mesmo lado da relação processual não implica dizer que os litisconsortes têm de tomar as mesmas atitudes ao longo do processo e agir apenas e tão somente em comum acordo.

Aliás, de rigor, a regra geral é que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, conforme dispõe o art. 117, 1ª parte, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, além de os litisconsortes poderem agir livremente sem a concordância ou anuência dos demais, os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros.

A independência insculpida no art. 117 do Código autoriza, destarte, que um litisconsorte, “sozinho” e independentemente da vontade do outro, recorra de uma decisão ou requeira a produção de provas, por exemplo.

Ademais, um dos litisconsortes pode até mesmo confessar ou reconhecer o pedido formulado pelo autor ou renunciar o direito em que se funda a ação, mas nenhuma dessas atitudes atinge a esfera jurídica do outro litisconsorte, que continua a poder produzir prova em contrário do fato confessado e a pleitear o direito renunciado ou reconhecido.

É nesse contexto que deve ser entendida a expressão “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros”, constante do art. 117 do Código de Processo Civil.

Ademais, via de regra, os atos de um litisconsorte, igualmente, não deverão beneficiar os demais litigantes omissos sempre que a alegação encerrar um argumento ou direito personalíssimo, isto é, que diga respeito a apenas um dos litisconsortes.

Entretanto, a produção de uma prova voltada a demonstrar a verdade de

um fato contrário ao interesse do autor, mesmo se requerida e produzida por apenas um dos réus, acaba por beneficiar o outro litisconsorte inerte, assim como um recurso interposto por apenas um dos litigantes pode, ao ser acolhido, anular a decisão recorrida, beneficiando, inclusive, aquele que não recorreu.

Essa possibilidade de beneficiar é ainda mais clara quando o litisconsórcio for unitário, assim entendido aquele cujo resultado tiver de ser o mesmo para todos os sujeitos integrantes do mesmo polo da relação processual.

Contudo, mesmo nos casos de litisconsórcio unitário, os atos unilaterais de um litisconsorte, como a confissão, a renúncia ou o reconhecimento jurídico do pedido, nunca poderão prejudicar o litisconsorte que não confessou, renunciou ou reconheceu o pedido formulado, que continua com amplos poderes para demonstrar a inoccorrência do fato confessado e a inexistência do direito reconhecido.

Até por esse motivo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Civil, “cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos”, o que reflete a ampla e irrestrita possibilidade de cada litisconsorte, enquanto litigante autônomo, exercer seus direitos processuais de modo autônomo, praticando os atos que lhes caibam, independentemente da postura dos demais litisconsortes.

16.4 Prazo dos litisconsortes

A existência de litisconsortes na relação processual pode levar à existência de prazos diferenciados para estes.

Isso porque, nos termos do art. 229 do Código de Processo Civil, “os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento”.

Portanto, conforme se depreende da regra transcrita no parágrafo anterior, não é o simples fato de existir litisconsórcio que autoriza os litisconsortes a terem prazo em dobro, haja vista que, caso eles sejam representados pelo mesmo advogado, ou advogados integrantes do mesmo escritório de advocacia, não farão jus ao referido prazo diferenciado.

Na hipótese de um dos litisconsortes ser revel e, na prática, apenas um litigante estar atuando naquele polo do processo, o prazo diferenciado cessa após o esgotamento do prazo (em dobro) para a resposta, isto é, exatamente após o momento em que a revelia é detectada⁵²⁷.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 229, não se aplica o benefício do prazo em dobro aos processos em autos eletrônicos, em razão da ampla disponibilidade desses autos aos advogados de todos os litisconsortes.

Além de poder ser em dobro, a depender da existência de procuradores distintos de escritórios de advocacia diferentes, outra distinção no que se refere ao prazo dos litisconsortes é que o vencimento do prazo da resposta dos réus sempre deve se dar no mesmo dia.

Em outras palavras, independentemente do dia em que cada litisconsorte foi citado, o prazo para resposta contra todos começa da data do último ato de comunicação ao litisconsorte.

A doutrina caracteriza essa hipótese como de prazo comum, assim entendido aquele que vence para todos no mesmo dia e, para tanto, começa a ser contado da data da última citação.

Nesse sentido, o art. 231, § 1º, do Código dispõe que, “quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incs. I a VI do caput que são: I – a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III – a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do

escrivão ou do chefe de secretaria; IV – o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital”⁵²⁸.

O prazo comum para contestar, ao contrário da regra do art. 229 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o prazo em dobro, aplica-se em todas as hipóteses de litisconsórcio passivo, independentemente de os réus estarem ou não representados por procuradores diferentes.

Por outro lado, o § 2º do art. 230 deixa claro que o prazo comum se refere exclusivamente ao prazo da contestação, pois, havendo mais de um litisconsorte intimado para a prática de outros atos processuais, o prazo para cada um é contado individualmente.

Capítulo 17 Intervenções de Terceiros

17.1 Considerações iniciais

Como se viu nos capítulos anteriores, o processo envolve as partes interessadas na resolução do litígio identificáveis como autor e réu da relação processual.

Ademais, para que façam jus a um pronunciamento de mérito, as partes têm de demonstrar legitimidade, ativa e passiva, ou seja, têm de possuir uma relação de pertinência subjetiva com o objeto litigioso⁵²⁹.

Dessa legitimidade decorre o direito de as partes, no exercício do contraditório e de seus poderes, direitos e deveres processuais, participarem do processo, influenciando, ou pelo menos podendo influenciar, tanto em seu andamento quanto no seu resultado.

É esta participação, potencial ou efetiva, que legitima e justifica racionalmente a submissão das partes ao resultado, imperativo e definitivo, do processo, sendo estes os sujeitos que serão primordialmente atingidos pela decisão judicial, tanto no que diz respeito à sua imutabilidade quanto no que tange aos seus efeitos.

A imutabilidade da decisão, atinge apenas as partes que integraram o processo, sendo estes os sujeitos impedidos de rediscutir o litígio, ou seja, o sentido e o alcance da decisão⁵³⁰.

De outro lado, por exclusão, qualquer outro sujeito de direitos que não tenha sido parte na relação processual não se submete à definitividade da decisão judicial, exatamente por não ter exercido o contraditório, participado do processo e tido a chance de influir no julgamento.

A estes sujeitos, que não são partes, dá-se o nome de terceiros.

O conceito de “terceiros” para o Direito Processual Civil, portanto, é

atingido por exclusão, uma vez que terceiro para o processo é, justamente todo aquele que não seja parte.

Assim, são terceiros todos aqueles que não figuram no processo como postulantes ou contra quem é feito o pedido.

Por não serem partes no processo e, por isso, não exercerem contraditório, os terceiros não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada, ou seja, não ficam sujeitos à autoridade e definitividade da decisão transitada em julgado.

Entretanto, indiretamente, os terceiros podem vir a ser atingidos pelos efeitos da decisão.

Nesse sentido, Arruda Alvim⁵³¹ afirma ser possível que “outras pessoas, que não são partes, sejam faticamente atingidas por uma decisão de mérito respeitante a um caso concreto”.

Da mesma forma, Cândido Rangel Dinamarco⁵³² afirma que, em razão da proximidade entre certos terceiros e o objeto da causa, pode-se prever que por algum modo o julgamento desta projetará algum efeito sobre sua esfera de direitos, e complementa aduzindo que o terceiro não ficará vinculado à autoridade da coisa julgada desfavorável, mas poderá sofrer efeitos reflexos em sua esfera jurídica.

Portanto, no que se refere à relação entre o resultado de um processo e os terceiros que dele não foram parte, há que se diferenciar a definitividade, no sentido da impossibilidade de rediscussão típica da coisa julgada, dos efeitos, sobretudo práticos, da decisão.

O aspecto da definitividade não atinge terceiros, que podem sempre discutir, em um processo posterior de que venham a ser parte, a decisão proferida em processo “alheio”, sobretudo quando essa decisão lhes prejudicar.

Já o aspecto ligado à repercussão de efeitos práticos na esfera de terceiros é perfeitamente possível, e até provável, que ocorra sobretudo

quando da efetivação do comando judicial.

Assim, por exemplo, o sublocatário de parte de um imóvel locado não é parte do processo em que se discute o despejo do sublocador/locatário proposto pelo locador, mas, se decretado o despejo do todo, inevitavelmente aquele que aluga uma parte será inevitavelmente despejado, uma vez que uma decisão dessa natureza reconhece o direito do locador a reaver o imóvel por inteiro, inclusive a parte sublocada.

Desse modo, se João Paulo celebra um contrato de locação com Francisco cujo objeto seja um prédio de 15 andares e este, por sua vez subloca o segundo andar para Amanda, obviamente, uma ação de despejo movida por João Paulo contra Francisco e julgada procedente irá atingir Amanda, que terá de deixar o segundo andar sublocado mesmo não tendo sido parte no processo.

Da mesma forma, a ação de um condômino contra o condomínio pode afetar a vida de todos os demais moradores, apesar de estes, individualmente, não estarem envolvidos diretamente no processo na qualidade de partes.

Assim, caso, por exemplo, o morador da unidade 102, em ação movida contra o condomínio, questione uma obra voltada à ampliação da garagem do edifício e obtenha judicialmente uma ordem judicial que impeça a continuidade dessa obra, todos os demais moradores sofrerão efeitos práticos dessa decisão, uma vez que a garagem, que a todos beneficiaria, deixará de ser construída.

A possibilidade de uma decisão judicial atingir a esfera jurídica de terceiros faz com que o Direito Processual Civil construa mecanismos voltados a legitimar e permitir que esses sujeitos, potencialmente atingidos, possam intervir e participar de um processo alheio.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil admite a intervenção de terceiros, legitimados para intervir sempre que puderem ser atingidos pelos

efeitos da decisão ou, de maneira mais ampla, a decisão do processo possa repercutir em sua esfera jurídica.

Tal intervenção consiste no ingresso do terceiro em uma relação jurídica processual já existente entre as partes originárias e pode se dar, de acordo com a modalidade e finalidade da intervenção, por requerimento do próprio terceiro ou por provocação de uma das partes originais⁵³³. Às primeiras modalidades dá-se o nome de intervenções voluntárias, e às segundas a denominação de intervenções provocadas.

A intenção de intervir, portanto, pode ser manifestada pelo próprio terceiro, que, ao tomar conhecimento de um processo envolvendo outros dois sujeitos e perceber que pode vir a ser atingido pela decisão proferida naquela seara, requer voluntariamente seu ingresso no processo alheio (intervenção de terceiro voluntária).

Ademais, uma das partes originárias do processo pode manifestar o interesse de provocar o ingresso de um terceiro na relação processual, via de regra com o intuito de legitimar não só a produção de efeitos sobre a esfera jurídica deste, como também submetê-lo à definitividade da decisão, algo impossível caso terceiro não integre a relação processual. São, por isso, denominadas intervenções de terceiros provocadas.

De rigor, conforme se verá adiante, a efetivação da intervenção de terceiros provocada implica o ingresso do terceiro na relação processual, facultando a este, até então estranho a esta relação, a possibilidade de exercer o contraditório, influir no desenvolvimento do processo e influenciar a decisão judicial. Por essa razão, é comum a afirmação da doutrina que a admissibilidade da intervenção de terceiro, uma vez efetivada, transforma o terceiro em parte do processo com todas as consequências daí advindas⁵³⁴.

O tema varia de acordo com a modalidade de intervenção de terceiros, pois, conforme ensina Cassio Scarpinella Bueno⁵³⁵, “quanto mais intenso o grau de influência da decisão sobre a relação material da qual faz parte o terceiro, maior a importância de sua participação (tornando-se, consoante o

caso, até mesmo parte) e, conseqüentemente, também maior o plexo de atividades que poderá desenvolver ao longo do processo”.

Por isso, preliminarmente ao estudo das modalidades de intervenção, há ser estabelecida a classificação dos terceiros de acordo com seu grau e tipo de interesse, o que será feito a seguir.

17.2 Classificação dos terceiros e das modalidades de intervenção

Como se disse no item anterior, o conceito de terceiro é amplíssimo, pois, tecnicamente, todos aqueles que não sejam parte no processo, assim entendidos aqueles que formulam o pedido e contra quem o pedido é formulado, são terceiros.

Entretanto, para fins de legitimidade para intervir, apenas um pequeno grupo de terceiros é aceito pelo Código de Processo Civil, ou seja, a grande maioria dos terceiros não está autorizada a intervir no processo alheio.

Na realidade, há várias categorias de terceiros, nem todos com interesse e legitimidade para intervir, assim como há um total de seis modalidades de intervenções de terceiros tipificadas pelo Código, que variam justamente em função da qualidade do terceiro que intervém e da finalidade da intervenção.

Este item se ocupa da classificação dos terceiros, ao passo que os itens seguintes voltar-se-ão a aprofundar e detalhar o cabimento, a finalidade e o procedimento de cada uma das modalidades de intervenção de terceiros.

Os terceiros podem ser classificados como (a) terceiros juridicamente desinteressados, (b) terceiros juridicamente interessados, (c) terceiros com interesse institucional e representatividade adequada, e (d) terceiros com interesse coincidente com os da parte.

Nesse contexto, cumpre desde já registrar que apenas aqueles terceiros integrantes dos grupos “b”, “c” e “d” possuem legitimidade para intervir, restando impossibilitados de participar do processo alheio os terceiros

juridicamente desinteressados.

São terceiros juridicamente desinteressados todos aqueles que não possuem relação jurídica com as partes e ligação com o objeto do litígio, sendo desta feita o resultado do processo juridicamente indiferente para eles.

Nesta categoria enquadra-se a esmagadora maioria dos sujeitos que, justamente pela total indiferença em relação ao objeto do litígio, não possuem legitimidade para intervir.

Portanto, para fins de possibilidade de intervenção de terceiros, são categorias relevantes os terceiros juridicamente interessados ("b"), os terceiros com interesse institucional e representatividade adequada ("c") e os terceiros que possuem interesse coincidente com uma das partes do processo ("d"), fato que torna esses terceiros extremamente interessados na resolução do conflito.

O terceiro juridicamente interessado ("b") possui uma relação jurídica com pelo menos uma das partes, quando não com ambas, podendo essa relação ser modificada, extinta ou, mais amplamente, atingida pela decisão judicial proferida no processo alheio.

Um exemplo esclarecedor é a posição do fiador de uma dívida que, nessa qualidade, é garantidor do pagamento e que, em um processo de cobrança que envolva o credor e devedor originários, é terceiro juridicamente interessado, por exemplo, na declaração de inexistência da dívida ou na definição de seu valor.

Conforme se verá adiante, a existência de interesse jurídico do fiador neste caso o legitima a intervir voluntariamente no processo que envolve credor e devedor principal.

Outro exemplo bastante ilustrativo de terceiro juridicamente interessado é o das seguradoras, que, pelo contrato de seguro, obrigam-se a cobrir os prejuízos sofridos pelo segurado e a indenizar pessoas prejudicadas por

este.

Assim, caso o segurado sofra um acidente automobilístico, por exemplo, caberá à seguradora arcar com os prejuízos causados no veículo do segurado, e, além disso, a depender dos termos do contrato, ressarcir os prejuízos daquele que vier a ser prejudicado pelo acidente.

Supondo que a discussão acerca da culpa de quem causou o acidente, bem como da extensão dos prejuízos, seja judicializada, esse processo, a priori, envolverá apenas os sujeitos envolvidos no acidente. Assim, neste contexto, a seguradora de uma das partes, tecnicamente, é terceiro, já que não é parte.

Contudo, ao contrário de terceiros alheios ao acidente e sem qualquer vínculo ou responsabilidade em relação às partes do processo, a seguradora é responsável pelo ressarcimento dos danos e, por isso, poderá ser atingida pelo resultado do processo. Exatamente por esse motivo, nessas situações, a seguradora deve ser classificada como um terceiro juridicamente interessado.

Por essas razões, conforme mais adiante será demonstrado, a qualidade de terceiro juridicamente interessado da seguradora a legitima para intervir voluntariamente no processo em que as partes discutem a responsabilidade e os prejuízos decorrentes do acidente de veículos, assim como uma das partes pode provocar a intervenção da seguradora, notadamente com o objetivo de, desde já, decidir sua responsabilidade e os deveres decorrentes do contrato de seguro.

Ainda no que tange aos terceiros juridicamente interessados, é preciso destacar que, caso o interesse do terceiro no resultado do processo não seja jurídico, isto é, seja meramente econômico, familiar ou afetivo, este não estará legitimado para intervir. Assim, torcedores de um clube de futebol, por mais que possam sofrer consequências práticas por uma decisão proferida em um processo em que o clube seja parte, não podem, por razões ou interesse afetivo, intervir no processo em favor de seu time

de coração.

Da mesma forma, o interesse meramente econômico não legitima terceiros a intervir⁵³⁶.

Assim, conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco⁵³⁷, o interesse do credor em ver seu devedor vitorioso em uma ação reivindicatória da qual seja autor, para que este permaneça com um patrimônio suficiente para saldar a dívida, é meramente econômico, o que a ordem jurídica até resguarda, mas não pela possibilidade de intervenção de terceiros.

Em outras palavras, o interesse do credor em ver seu devedor com um patrimônio maior é meramente econômico e não justifica sua intervenção nos processos em que o devedor seja parte.

Portanto, faz-se necessário que o interesse do terceiro seja jurídico, assim revelado por meio da existência de uma relação jurídica entre o terceiro que o associe juridicamente às partes e ao objeto do litígio.

Além do interesse jurídico revelado pela existência de uma relação jurídica entre o terceiro e uma das partes do processo, outro tipo de interesse capaz de legitimar um terceiro a intervir é o denominado interesse institucional (“c”).

Cassio Scarpinella Bueno⁵³⁸ ensina que o interesse institucional não pode ser confundido com o interesse jurídico (ou reduzido a ele). Assim, o interesse institucional “deve ser compreendido de forma ampla”, em perspectiva metaindividual, que ultrapassa a esfera individual do terceiro como pessoa ou entidade.

Essa possibilidade de intervenção de terceiros com interesse institucional e representatividade adequada é admitida pelo Código de Processo Civil, que, em seu art. 138, dispõe que “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar

ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.

Assim, terceiros que possuam interesse institucional e representatividade adequada podem intervir como *amici curiae*, com a finalidade de contribuir com a solução da questão de seu interesse⁵³⁹.

Por fim, é preciso fazer referência aos terceiros com interesse jurídico idêntico ao da parte (“d”), que de certa forma está enquadrado no conceito anterior de terceiro juridicamente interessado, mas, por ser mais intenso, termina por merecer um destaque na classificação.

Isso porque a intensidade do interesse do terceiro neste caso, conforme se verá adiante, influencia a modalidade de intervenção e os poderes que possui o terceiro ao intervir.

Em outras palavras, o terceiro com interesse idêntico ao da parte possui, a par da óbvia legitimidade para intervir, um maior rol de direitos processuais, de rigor idêntico ao da parte, justamente porque, no plano do direito material, este terceiro tem o mesmo direito defendido por ela.

Um exemplo bastante ilustrativo é o do coproprietário que fica de fora da relação processual, instaurada por demanda movida por outro coproprietário.

Assim, imaginando que João Paulo e Vicente sejam coproprietários de um imóvel ameaçado pela construção conduzida por Felipe em um terreno vizinho, ambos possuem legitimidade para buscar, em juízo, a tutela jurisdicional contra a lesão ou ameaça de seu direito causadas pela obra.

Obviamente, João Paulo e Vicente podem mover a ação em conjunto, neste caso, dando origem a um litisconsórcio ativo⁵⁴⁰.

Entretanto, a formação desse litisconsórcio ativo é facultativa⁵⁴¹, o que implica dizer que tanto João Paulo como Vicente podem ajuizar a ação em defesa da coisa de propriedade de ambos, individualmente.

Nesse contexto, o ajuizamento da ação por João Paulo contra Felipe tornaria, no plano processual, Vicente um terceiro, pois não figura no processo nem como autor nem como réu.

É forçosa a conclusão de que se trata de um terceiro com um interesse jurídico intenso, pois o resultado do processo João Paulo vs. Felipe influenciará diretamente em um bem jurídico que também é seu. É nesse contexto que se configura a qualidade de terceiros com interesse idêntico ao da parte, apto a conferir legitimidade para Vicente intervir.

Conforme se verá com mais vagar adiante, Vicente, neste exemplo, poderá intervir no processo na qualidade de assistente litisconsorcial⁵⁴², possuindo todos os poderes da parte autora, o que é coerente com os impactos que a decisão naquele processo poderia causar em sua esfera jurídica.

Desta feita, conclui-se preliminarmente que a partir da classificação dos terceiros é possível aferir não apenas a possibilidade ou não de sujeitos que não são parte intervirem no processo alheio, como também a modalidade de intervenção e, por via de consequência, a posição e os poderes do terceiro na relação processual na qual intervém.

Em outras palavras, as diversas espécies de relações jurídicas entre os terceiros interessados e as partes e o objeto litigioso, assim como a diversidade de objetivos do terceiro ao ingressar ou das partes ao provocar o ingresso destes, levam à existência de seis modalidades de intervenção de terceiros previstas em um capítulo próprio do Código de Processo Civil.

São modalidades de intervenção de terceiros tipificados pelo Código de Processo Civil em capítulo próprio⁵⁴³: a) a assistência simples; b) a assistência litisconsorcial; c) a denúncia à lide; d) o chamamento ao processo; e) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e f) o *amicus curiae*.

Dessas modalidades, as duas primeiras (“a” e “b”), são classificadas

como intervenções de terceiros voluntárias, isto é, decorrentes da manifestação de vontade do terceiro de ingressar no processo alheio.

Já a denúncia à lide ("c"); o chamamento ao processo ("d"), e o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica ("e") são modalidades de intervenção de terceiros provocadas, ou seja, requeridas por uma das partes originais do processo.

O *amicus curiae*, por sua vez, a depender da situação concreta, pode vir a ser classificado como intervenção provocada ou voluntária, uma vez que essa modalidade de intervenção pode se dar por iniciativa do terceiro que possua interesse institucional no objeto do processo, assim como por requerimento das partes ou determinação do juízo, situação em que pode ser classificada como modalidade de intervenção provocada.

Em comum todas as modalidades previstas no Código têm a capacidade de permitir o ingresso de um sujeito que originalmente não era parte da relação processual e, por via de consequência, viabilizar a participação e o envolvimento de sujeitos juridicamente interessados no julgamento da lide.

Ademais, cumpre registrar que, em outras passagens fora do capítulo especificamente dedicado às intervenções de terceiros, o Código de Processo Civil prevê outros mecanismos que em última análise permitem o ingresso de terceiros no processo alheio. É o caso, por exemplo, do recurso de terceiro prejudicado, dos embargos de terceiro e de algumas formas de provocação realizadas pelo réu quando de sua resposta, via preliminar de contestação ou mesmo na reconvenção.

Os itens a seguir se ocuparão do cabimento, finalidade, procedimento e efeitos de cada uma dessas modalidades de intervenção, a começar por aquelas tipificadas pelo Código de Processo Civil no capítulo próprio, às quais se dará, inclusive, maior atenção. Na sequência serão tecidas breves considerações sobre as modalidades de intervenção previstas em outras passagens do Código.

17.3 Modalidades de intervenção de terceiros voluntárias

17.3.1 Assistência simples

17.3.1.1 Conceito, cabimento e finalidade

Conforme vem se afirmando desde as considerações iniciais, é possível que sujeitos que não sejam parte da relação processual venham a sofrer os efeitos da decisão judicial proferida em processo alheio.

O impacto na esfera jurídica do terceiro, via de regra, decorre da relação jurídica que este possui com uma das partes, que acaba por gerar um interesse na vitória desta como forma de evitar que os referidos impactos sejam negativos.

Esse interesse, desde que jurídico, revelado pela existência de um vínculo jurídico entre o terceiro e uma das partes, assim como o potencial reflexo na esfera jurídica daquele, o legitima a intervir como assistente simples.

Portanto, a assistência simples é uma espécie de intervenção de terceiros voluntária, voltada a permitir que um terceiro juridicamente interessado na vitória de uma das partes intervenha e participe do processo praticando atos processuais e, por meio destes, auxilie a parte com a qual mantém relação jurídica e, em razão desta, tem interesse em que saia vitoriosa.

O art. 119 do Código de Processo Civil dispõe que, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”, sendo complementado pelo parágrafo único, que deixa claro que a assistência é admissível em qualquer procedimento e em qualquer grau de jurisdição.

Por se tratar de modalidade de intervenção de terceiros voluntária, cabe ao próprio terceiro requerer seu ingresso como assistente simples ao juiz.

Assim, para que seja admissível o requerimento de intervenção como

assistente simples, o terceiro requerente deve demonstrar a) possuir relação jurídica com a parte que pretende assistir, e b) a possibilidade de esta relação vir a ser alterada ou influenciada pela decisão judicial a ser proferida no processo em que o terceiro pretende intervir.

Dessa forma, o fiador de uma dívida que não seja parte no processo em que o credor pretende exercer a cobrança contra o devedor principal possui interesse e legitimidade para intervir como assistente simples, haja vista que a declaração de inexistência da dívida, por via de consequência, extingue a fiança.

Em outras palavras, o fiador possui legitimidade para intervir como assistente simples em um processo pendente entre credor e devedor principal uma vez que: a) existe uma relação jurídica entre a parte que o fiador pretende assistir (o devedor), qual seja, o contrato de fiança; e b) existe a possibilidade de a decisão na ação de cobrança repercutir na sua esfera jurídica, uma vez que o reconhecimento judicial da extinção da dívida extingue, por consequência, a fiança.

Outro exemplo é a já citada situação do sublocador de parte do imóvel locado.

Suponhamos que Maria Silvia celebre um contrato de locação com Adalberto, alugando deste um prédio de quinze andares e, por ter interesse apenas na utilização de doze andares, Maria Silvia subloque os outros três andares para Emílio.

Se, por qualquer motivo, Adalberto resolver reaver o imóvel de Maria Silvia e este se recusar a sair, inevitavelmente o proprietário terá de mover uma “ação de despejo” contra a locatária.

Neste processo promovido por Adalberto contra Maria Silvia, Emílio, por definição, é terceiro, uma vez que não é nem autor nem réu. Aliás, por não possuir relação jurídica com Emílio, Adalberto não irá propor ação contra ele, até porque a relação do autor com Maria Silvia engloba os quinze

andares do prédio e, por via de consequência, seu pedido apenas contra ela, por si, atende sua pretensão de reaver todo o imóvel.

Nesse contexto, temos claramente a possibilidade de um terceiro (Emílio) que possui: a) relação jurídica com uma das partes (contrato de sublocação com Maria Silvia) e b) interesse jurídico na vitória desta, uma vez que o acolhimento do pedido de Adalberto contra Maria Silvia (despejo dos quinze andares) impactaria diretamente na sublocação de Emílio, que seria indiretamente despejado dos três andares que ocupa em função da relação que possui com Maria Silvia.

Assim, Emílio, sublocador, possui interesse jurídico na vitória de Maria Silvia e, por isso, possui legitimidade para requerer sua intervenção como assistente simples dela.

É preciso destacar que o ingresso de Emílio como assistente simples não amplia o objeto do processo, que continua sendo o despejo dos quinze andares proposto por Adalberto.

O papel de Emílio ao ingressar será apenas e tão somente o de auxiliar (ajudar) Maria Silvia, nos termos e nos limites tratados a seguir.

A legitimidade e o interesse do terceiro podem ser verificados de ofício pelo juiz por se tratar de matéria de ordem pública, e, caso o magistrado perceba que o terceiro não preenche os requisitos autorizadores da intervenção, deverá indeferir liminarmente o pedido.

Não sendo o caso de indeferimento liminar, o art. 120 do CPC, decorrente do próprio princípio do contraditório, impõe a oitiva das partes, que podem se opor ou concordar com o requerimento de ingresso formulado pelo terceiro.

Em havendo discordância por uma das partes, caberá ao juiz, ouvido o terceiro, decidir pela admissibilidade ou inadmissibilidade do ingresso.

Mesmo no caso de não haver oposição por nenhuma das partes, caberá ao juiz apreciar o pedido, admitindo apenas o ingresso de terceiros

interessados e legitimados, pois, como dito, trata-se de matéria de ordem pública.

Contra a decisão que indefere pedido de ingresso do terceiro cabe recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. IX, do CPC) cujas peculiaridades, procedimento e desdobramentos escapam ao objeto desta Introdução.

17.3.1.2 Poderes do assistente simples

Uma vez admitida a intervenção do assistente simples, resta importante compreender as consequências dessa intervenção, a começar pelos seus poderes, isto é, como o terceiro, uma vez admitido como assistente simples, pode atuar no processo?

Nesse contexto, dois dados básicos são imprescindíveis para a compreensão dos poderes do assistente simples: a) o assistente simples pode praticar todos os atos processuais possíveis de serem praticados pela parte, porém, b) a prática de atos pelo assistente simples poderá ser limitada pela vontade manifestada pelo assistido.

Dizer que o assistente simples pode praticar todos os atos processuais possíveis de serem praticados pela parte, em última análise, implica dizer que o terceiro, uma vez ingressando nessa qualidade, pode requerer e participar da atividade probatória, recorrer de decisões desfavoráveis à parte assistida, apresentar toda a sorte de requerimentos e impugnações a que tem direito a parte, interpor e contra-arrazoar recursos, entre outras atividades.

Nesse passo, contudo, três observações se fazem importantes.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que ao terceiro não é dado o direito de ampliar o objeto do processo, isto é, fazer pedido em seu favor ou mesmo pleitear direito não pleiteado pela parte.

Em outras palavras, a assistência simples não amplia o objeto do processo, uma vez que o assistente simples ingressa no processo apenas

para ajudar, auxiliar uma das partes com quem possui uma relação jurídica, e, em função desta, possui interesse jurídico na vitória da parte que assiste.

Portanto, é vedado ao assistente formular pedidos ampliando o objeto da causa, e obviamente praticar atos de disposição (desistência, renúncia, reconhecimento jurídico do pedido).

Nesse sentido, o auxílio do assistente simples volta-se à obtenção pela parte do bem jurídico por ela pleiteado e definido, não cabendo ao terceiro (re)definir esse objeto.

São, portanto, atividades distintas definir o objeto da pretensão (ato exclusivo da parte) e praticar atos processuais voltados ao atingimento desse objetivo, atividade que o terceiro, assim como a parte, pode praticar.

Ademais, cumpre observar que, ao contrário das partes, que se supõem presentes na relação processual desde seu início, o terceiro pode ingressar no feito em qualquer momento e grau de jurisdição, sendo relevante registrar neste ponto que o ingresso tardio do terceiro não implica retrocesso do procedimento.

Nesse sentido, dispõe o art. 120, parágrafo único, do CPC que “o assistente recebe o processo no estado em que se encontra”.

Assim, caso o assistente requeira a intervenção após o encerramento da audiência de instrução, por exemplo, não é dado a ele requerer a produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes, uma vez que esses atos instrutórios só são admitidos até essa fase do procedimento.

Da mesma forma, o assistente simples não poderá interpor recursos cujos prazos e oportunidades já estejam superados pelo andamento do processo.

Como o requerimento pode ser formulado em qualquer momento do procedimento, são atribuíveis apenas ao assistente as dificuldades e restrições geradas pelo seu próprio “atraso” em intervir.

Assim, quanto antes for requerido o ingresso do assistente simples, mais

poderes ele possuirá, pelo menos no que diz respeito às limitações impostas pela fase do procedimento, restando sempre a limitação pela vontade do assistido, conforme se verá adiante.

Desta feita, respeitados o estágio procedimental e a vedação de o assistente simples ampliar o objeto do processo, o sistema processual admite que o terceiro pratique todos os atos processuais típicos da parte assistida.

Assim deve ser compreendido o art. 121 do Código de Processo Civil, que estabelece: “o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido”.

Entretanto, por ser um mero auxiliar e, portanto, coadjuvante da parte assistida, a vontade desta se impõe sobre a do assistente simples.

Nesse sentido dispõe o art. 122 do CPC, verbis “a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”.

Assim, um recurso interposto pelo assistente não implicará a reanálise da decisão caso a parte assistida aceite o decidido ou renuncie o direito de recorrer.

Nesse contexto, é importante deixar claro que a possibilidade de a parte obstar a prática de um ato pelo assistente simples não implica dizer que este precise da autorização prévia e expressa da parte para praticar um ato processual.

Na verdade, salvo manifestação expressa em sentido contrário, o terceiro está, a teor do citado art. 121 do Código, autorizado a praticar todos os atos processuais, devendo, portanto, qualquer limitação desses poderes ser manifestada pela parte assistida.

Até por isso, quando a parte assistida for revel, o art. 121, parágrafo

único, do CPC dispõe que, “sendo revel ou, de qualquer outro modo, omissa a parte assistida, o assistente será considerado seu substituto processual”.

Nessas hipóteses, o assistente pratica toda a sorte de atos que caberiam à parte assistida sem que esta sequer esteja presente, para concordar ou expressamente autorizar a atuação do assistente.

Ainda assim, nestes casos, o assistente simples obviamente não se torna titular do direito discutido em juízo, não podendo dele dispor ou renunciar, mesmo com a revelia da parte, que, se em qualquer momento se manifestar no processo, volta a ter o controle sobre os poderes do assistente.

Em suma, o silêncio da parte implica a possibilidade de o assistente praticar o ato processual em nome daquela, já que não depende de autorização prévia ou expressa, devendo a eventual limitação da vontade do terceiro pela vontade da parte ser por esta expressamente manifestada via renúncia, reconhecimento do pedido ou desistência da ação, por exemplo. Não pode o assistente simples contrariar os interesses do assistido, impugnando decisões aceitas pelo assistido, ou dando sequência a uma ação de que a parte assistida tenha desistido.

17.3.1.3 Coisa julgada e justiça da decisão para o assistente

Por não ser parte, o assistente simples, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil⁵⁴⁴, não é atingido pelos efeitos da coisa julgada.

Porém, o art. 123 do Código de Processo Civil dispõe que, “transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, como regra, em processo posterior, discutir a justiça da decisão”.

A regra geral, que possui exceções a seguir tratadas, sugere que o decidido no processo em que participou o terceiro como assistente simples não pode posteriormente ser questionado por ele, ainda que este sofra os efeitos da decisão.

O dispositivo faz sentido, uma vez que, não obstante ser terceiro, o

assistente simples participou do processo, o que, de certa forma, legitima a indiscutibilidade da decisão por esse sujeito em outro processo.

Sobre o tema, Arruda Alvim⁵⁴⁵ assevera que “a ideia de fazer referência à justiça da decisão decorre da participação ativa do assistente no processo em que esteve presente. Se o terceiro pode alegar fatos e produzir provas, que foram corretamente apurados pelo juiz, esses não podem ser desconhecidos e se devem impor em processo ulterior, do qual ele, que fora assistente simples, seja parte”.

Nesse contexto, Humberto Theodoro Jr.⁵⁴⁶ ensina que “o que o art. 123 impede é, diante de eventuais efeitos externos (práticos) da sentença prejudiciais à relação jurídica do terceiro (aquela que justificou a assistência), venha ele reabrir a discussão fundada em má apreciação dos fatos e provas examinados e julgados em sua presença”. E conclui: “esse quadro fático, salvo as exceções dos itens I e II do art. 123, não poderá voltar a discussão por iniciativa do assistente, em futuro processo, sobre cujo objeto a sentença anterior venha a repercutir, ainda que reflexamente”.

As exceções previstas no art. 123, incisos I e II, do CPC são intimamente ligadas às limitações impostas à prática de atos processuais por terceiros no processo em que intervieram, quer por força das limitações procedimentais, quer por força de limitações decorrentes da manifestação de vontade ou omissões da parte assistida.

Assim, considerando que o terceiro “recebe o processo no estado em que se encontra”, caso o estágio procedimental em que intervenha impeça que pratique atos fundamentais para a defesa de seu ponto de vista, como recorrer ou produzir provas, este poderá, em outro processo, como parte, discutir a “justiça da decisão”.

Da mesma forma, caso os atos de disposição de vontades da parte, como a aceitação da decisão ou a renúncia a recursos, inviabilizem a prática de

atos processuais pelo assistente, este não será atingido pela imutabilidade da “justiça da decisão”.

Ademais, a vedação de rediscutir a “justiça da decisão” não se aplica caso o terceiro tenha acesso a fatos ou provas após a extinção do processo, em especial quando ocultados, intencionalmente ou não, pela parte assistida.

Nesse sentido dispõe a exceção prevista no art. 123, II, do Código de Processo Civil, verbis: “transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: (...) II – desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu”.

Portanto, a impossibilidade de propor a rediscussão do decidido em outro processo pelo assistente simples depende da intensidade da participação deste no processo, sendo-lhe vedada a rediscussão caso sua atuação não tenha sido limitada pela parte assistida ou fase do procedimento, e autorizada quando atos ou omissões da parte ou o estágio procedimental do feito impeça a atuação plena do terceiro interveniente.

17.3.2 Assistência litisconsorcial

Tal como na assistência simples, o assistente litisconsorcial possui interesse jurídico na vitória de uma das partes, porém não por possuir relação jurídica com o assistido, mas por possuir uma relação jurídica (litigiosa – conflito de interesses) com o adversário do assistido.

Neste específico ponto, o Código de Processo Civil consagra a doutrina de Arruda Alvim⁵⁴⁷, para quem “o assistente litisconsorcial tem relação jurídica com o adversário do assistido. Existe, portanto, conflito de interesse entre terceiro, que pode vir a ser assistente litisconsorcial, a parte que ocupa o outro polo da relação processual (que ocupa o adversário do assistido)”.

Na verdade, o assistente litisconsorcial é titular da relação jurídica objeto

do processo e, por este motivo, poderia inclusive ter sido parte. É um sujeito que poderia ter sido litisconsorte (inicial e facultativo) e não foi⁵⁴⁸.

São exemplos de legitimados para intervir como assistente simples o coproprietário da coisa objeto do processo em que o outro coproprietário é parte, assim como os herdeiros nas ações em que o espólio seja parte.

Nesses casos, não se trata de um interesse jurídico reflexo pela existência de uma relação com o assistido e pelo potencial impacto dos efeitos da decisão proferida no processo em que este seja parte, mas de um interesse direto, e próprio, na vitória da parte assistida.

Portanto, o terceiro que intervém na qualidade de assistente litisconsorcial defende interesse próprio, o que vai distinguir a atuação e os poderes desse sujeito, se comparados às possibilidades de atuação e poderes do assistente simples estudados no item anterior.

Não obstante estas diferenças relacionadas à legitimidade, interesse e poderes do assistente litisconsorcial, o procedimento de ingresso do terceiro nesta qualidade é idêntico ao do ingresso do assistente simples.

Assim, por se tratar de intervenção de terceiros voluntária, cabe ao terceiro interessado requerer o ingresso, demonstrando seu interesse e legitimidade, cabendo ao juiz, ouvida as partes, decidir sobre a admissibilidade da intervenção.

Em caso de manifesta ilegitimidade, o juiz pode indeferir liminarmente o ingresso do terceiro, tal como autorizado nos casos de requerimento de assistência simples.

Contudo, no que se refere aos poderes do assistente, são muito distintas as formas de atuação e possibilidades de exercício de direitos pelo assistente litisconsorcial, que pode inclusive contrariar a vontade da parte assistida.

Nesse contexto, a relação entre a vontade da parte assistida e a do assistente litisconsorcial se aproxima muito mais da relação entre

litisconsortes do que entre parte e assistente simples⁵⁴⁹.

Isso ocorre exatamente porque o assistente litisconsorcial, por defender interesse próprio, ao intervir se torna parte, podendo, nessa qualidade, de maneira autônoma e independente, requerer, alegar, produzir prova e recorrer, ainda que por exemplo a parte assistida desista da ação ou apresente recurso.

17.4 Modalidades de intervenção de terceiros provocadas

Conforme abordado no item dedicado à classificação dos terceiros e das modalidades de intervenção, ao lado das duas modalidades de intervenções de terceiros voluntárias, que se caracterizam pela intenção do próprio terceiro de ingressar no feito, o Código de Processo Civil tipifica outras três modalidades como intervenções provocadas.

Tais intervenções caracterizam-se pelo fato de uma das partes provocar, isto é, requerer o ingresso de terceiros no processo, via de regra exercendo pretensão contra o terceiro e fazendo com que este, portanto, integre a lide.

É comum a essas modalidades, inclusive, o terceiro ser citado, e, por esta razão, uma vez concretizada a intervenção, é correto falar que o terceiro se torna parte⁵⁵⁰.

São modalidades de intervenção de terceiros provocadas; a) a denunciação à lide, b) o chamamento ao processo, e c) o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica.

Entre as três modalidades, há variações que vão desde a hipótese de cabimento até a finalidade e dinâmica da própria relação processual após admitida a intervenção.

Os subitens a seguir tratarão com mais vagar de cada uma das hipóteses e seus principais desdobramentos.

17.4.1 Denunciação da lide

17.4.1.1 Conceito, cabimento e finalidade

A razão de ser da denunciação da lide está diretamente ligada à existência dos institutos da evicção, direito de garantia e de regresso consagrados no direito material.

A evicção parte do pressuposto lógico segundo o qual aquele que transmite um direito é sempre garante de sua existência, e, se essa transmissão se der a título oneroso, o alienante se obriga a indenizar o adquirente caso este venha a perder a coisa.

Já o direito de regresso liga-se à obrigação de um sujeito de indenizar o prejuízo sofrido por outrem em uma demanda, por força da lei ou do contrato.

Percebe-se claramente que, em ambas as situações, além dos sujeitos integrantes diretos da relação conflituosa, há sempre alguém com a obrigação de garantir potenciais danos ou prejuízos eventualmente sofridos por uma das partes.

Assim, é típico dessas relações o envolvimento de mais de dois sujeitos interessados na resolução do conflito, pois além dos dois sujeitos principais sempre existirá um terceiro garantidor.

A caracterização de conflito nessas hipóteses, portanto, termina por envolver não dois, mas três sujeitos no litígio, quais sejam: a) o sujeito que exerce a pretensão; b) o sujeito que oferece resistência; e c) um terceiro, que possui relação jurídica com um destes e, em razão disso, tem a obrigação de garantia em caso de derrota desse sujeito.

No caso da evicção temos como sujeitos principais do litígio o proprietário (adquirente da coisa, "a") e aquele que entende ser sua a coisa alienada ("b"), e, como terceiro ("c"), o alienante, que por sua vez tem o dever de indenizar o adquirente, caso este perca a coisa.

Um exemplo talvez esclareça a relação entre os sujeitos na evicção:

Caso Dante (adquirente) adquira um imóvel de Mário (alienante), Mário

fica obrigado a indenizar Dante caso este venha a perder a coisa para outrem.

Assim, caso Paulo entenda ser sua a coisa adquirida por Dante, nada impede o ajuizamento de uma ação reivindicatória, que terá no polo ativo Paulo e no polo passivo Dante (atual proprietário e adquirente).

Nesse contexto, nota-se que Mário, alienante e responsável por indenizar Dante caso perca o imóvel, não é parte, não é autor nem réu, e, portanto, é terceiro sob a ótica dessa relação processual.

Trata-se, entretanto, de um terceiro juridicamente interessado por possuir uma relação jurídica com o réu, e pelo fato de poder ser atingido pelos efeitos da decisão proferida no processo Paulo vs. Dante.

Isso porque Mário poderá sofrer prejuízos em sua esfera jurídica em função do resultado do processo, pois terá de indenizar Dante caso este venha a ser derrotado.

O interesse jurídico de Mário, por si só já, o autoriza a intervir como assistente de Dante, mas o Código vai além e permite que o próprio Dante provoque o ingresso de Mário, com o intuito de vê-lo condenado a indenizá-lo caso perca o imóvel reivindicado por Paulo.

Essa provocação deve dar-se pela via da denúncia da lide, aqui tratada conforme estabelece o art. 125, inc. I, do Código de Processo Civil.

Desta feita, realizada a denúncia da lide, Mário ingressará no processo, o que, de um lado, lhe permitirá praticar atos processuais em favor de Dante e, de outro, permitirá que a mesma decisão que reconheça que o imóvel pertence a Paulo condene Mário a ressarcir os prejuízos sofridos por Dante.

Dessa forma, a denúncia da lide cumpre duplo papel: a) provocar o ingresso de Mário (alienante do bem litigioso), permitindo que este participe do processo em que se discute a propriedade do bem alienado, legitimando, por força de sua participação, que esta decisão também o

atinja; e b) permitir, caso o adquirente (denunciante) seja derrotado, que o alienante (denunciado) seja condenado a indenizá-lo.

A denunciação da lide, portanto, é uma modalidade de intervenção de terceiros provocada por uma das partes originais do processo e consiste em citar um terceiro, que mantém um vínculo com uma das partes para responder pela garantia dos prejuízos, em caso de derrota do denunciante.

A denunciação da lide amplia o objeto do processo, pois o juiz terá de decidir sobre o direito originalmente controvertido e, também, acerca de eventual direito de regresso que possua a parte derrotada em face do terceiro/denunciado.

Nesse sentido, o art. 125 do Código de Processo Civil diz ser admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, a par dos casos de evicção já comentados, também quando um terceiro “estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Esta segunda hipótese de cabimento, prevista no art. 125, inc. II, do CPC, permite a utilização da denunciação da lide como forma de viabilizar o exercício de direito de regresso decorrente de qualquer outra relação jurídica que legitime uma das partes originárias a pleitear o ressarcimento em face de um terceiro em caso de derrota.

É o caso, por exemplo, do dever de ressarcir decorrente do contrato de seguro que permite ao segurado receber da seguradora o montante equivalente aos prejuízos sofridos em razão do objeto da cobertura.

Assim, caso uma das partes tenha o direito de se valer do contrato de seguro e exigir da seguradora o ressarcimento pelos prejuízos sofridos, poderá promover a denunciação da lide, integrando a seguradora na relação processual e, com isso, obter a condenação desta a ressarcir-la dos prejuízos causados em caso de derrota.

Nessa medida, a denunciação da lide otimiza a atividade processual,

solucionando dois pontos distintos, ainda que intimamente ligados: a lide original e o eventual direito de regresso decorrente de sua resolução.

Entretanto, apesar de ser mais eficiente e econômico resolver o litígio original e a eventual questão ligada ao ressarcimento decorrente da evicção ou regresso, a denúncia da lide não é obrigatória.

Em outras palavras, caso a parte que potencialmente tenha direito a ser ressarcida em função da evicção ou regresso em caso de derrota não se valha da denúncia da lide, nada impede que esse ponto seja discutido em outro processo posteriormente formado entre o derrotado e o obrigado a indenizar.

Essa conclusão resta clara da leitura do art. 125, § 1º, do CPC, que dispõe que “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.

Nesse caso, obviamente, o terceiro em relação à ação original, poderá, como parte no processo em que se discute a evicção ou regresso, rediscutir amplamente a decisão firmada no processo original do qual não participou, uma vez que a coisa julgada fica restrita apenas às partes e, portanto, não o atinge.

17.4.1.2 Procedimento e dinâmica da relação processual após a denúncia à lide

Pela própria natureza da relação que dá causa à denúncia da lide, é possível concluir que o terceiro denunciado possui interesse na vitória da parte denunciante.

Isso porque o dever de ressarcir só surge em caso de derrota do denunciante, sendo, portanto, interesse do denunciado que este seja vitorioso na lide originária.

Desta feita, a posição do denunciado é dupla, pois: a) de um lado, em relação à lide original, será litisconsorte do denunciante, podendo formular

alegações, requerimentos e provas que complementem seu pedido ou defesa, agindo para que este saísse vencedor. De outro lado, b) no que tange especificamente ao pedido de ressarcimento formulado pelo denunciante contra o denunciado, estes serão, obviamente, adversários, podendo o denunciado se opor ao pedido, afirmando, por exemplo, não existir o dever de ressarcir decorrente da evicção ou o direito de regresso, conforme o caso.

Essa dupla atuação do denunciado é percebida a partir da leitura do art. 127 do CPC, que dispõe que, “feita a denúncia pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu”. Assim como, “feita a denúncia pelo réu: I – se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado”.

Portanto, resta claro que, realizada a denúncia da lide, dois litígios distintos se apresentam e precisarão ser julgados: a lide original, na qual denunciante e denunciado são litisconsortes, e eventualmente o direito de regresso que opõe o denunciado de um lado, e o denunciante, de outro.

A existência desses dois litígios dentro do mesmo processo é fundamental para que seja legítimo o cumprimento do disposto no art. 129, que determina que, “se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denúncia da lide”.

Assim, o pedido veiculado na denúncia será julgado na mesma sentença que julgou a causa primária que deu origem ao dever de o denunciado indenizar a parte derrotada.

Obviamente, se o denunciante for vencedor, a ação de denúncia não terá o seu pedido examinado, uma vez que restará prejudicado.

No que tange ao procedimento, dispõe o art. 126 do Código que “a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante

for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.

Caberá ao juiz verificar de ofício o cabimento da denunciação e, em caso positivo, determinar a citação do denunciado para que este apresente defesa.

Por assumir a posição de litisconsorte do denunciado na ação principal e de seu adversário na denunciação, o denunciado passa a ser tratado de acordo com o regime previsto no art. 117 do CPC⁵⁵¹, em que vigora a regra da independência.

Até por isso, o art. 128 dispõe que, se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com a defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva; se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso.

O julgamento da questão inserida no processo pela denunciação da lide, como dito, se dará na mesma sentença, salvo se esta restar prejudicada pelo julgamento da ação originária, a teor do art. 129 do Código, já comentado.

Por fim, cumpre registrar que o Código de Processo Civil, considerando a formação do litisconsórcio entre denunciante e denunciado no que se refere ao litígio original, permite ao adversário do denunciante, se julgado procedente o pedido da ação principal, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.

Em outras palavras, formulada a denunciação à lide pelo réu contra sua seguradora, no caso de derrota do denunciante, o autor vitorioso pode executar, além do réu original, também a seguradora denunciada.

17.4.2 Chamamento ao processo

17.4.2.1 Conceito, cabimento e finalidade

O chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiros que permite que o réu amplie o polo passivo da relação processual que ocupa, requerendo a citação de outros sujeitos responsáveis pela dívida objeto do litígio.

Nos termos do art. 130 do CPC, o réu, fiador ou devedor solidário demandado sozinho, pode realizar o chamamento ao processo do afiançado, dos demais fiadores e dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Todas as situações se caracterizam pelo fato de, apesar de a relação processual possuir apenas um ou alguns réus, outros sujeitos não demandados e, portanto, terceiros, não apenas “poderiam ter sido parte” como também são, no mínimo, igualmente responsáveis pela dívida.

No caso do devedor solidário demandado sozinho, são terceiros igualmente responsáveis pela dívida os demais devedores solidários, e, no caso em que o fiador é demandado sozinho, são responsáveis pela dívida o devedor principal, assim como os demais fiadores, quando existirem.

Ademais, além de corresponsáveis, esses sujeitos deixados de fora da relação processual podem vir a ser obrigados, por força do direito material, a ressarcir aquele que pagar a dívida por inteiro.

Isso porque, nos termos do art. 283 do Código Civil, “o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota (...)”.

Igualmente, caso o fiador pague a dívida, o art. 831 do Código Civil estabelece que “o fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”.

Por isso, nestas situações, o réu – devedor solidário ou fiador demandado sozinho –, ao realizar o chamamento ao processo, a par de trazer para o

polo passivo os demais devedores solidários, fiadores ou o devedor principal conforme o caso, permitirá que a mesma decisão que lhe condene reconheça em seu favor o direito de exigir dos chamados ao processo a parte que lhe caiba em razão do pagamento integral. No caso do devedor solidário, a quota-parte que cabia aos demais e, no caso do fiador que paga a dívida, o direito de exigir do devedor principal o todo, em razão da sub-rogação.

A finalidade do chamamento ao processo, portanto, é dupla, pois consiste em: a) integrar ao processo, no polo passivo, outros sujeitos responsáveis pela dívida, ainda que não demandados pelo autor; e b) viabilizar que o réu demandado sozinho possa exigir dos chamados o direito decorrente da sub-rogação, na hipótese de, sendo condenado, pagar por inteiro a dívida sozinho.

17.4.2.2 Procedimento e dinâmica da relação processual após o chamamento ao processo

Conforme exposto no subitem anterior, a legitimidade ativa para realizar o chamamento ao processo é exclusiva do réu.

O autor, caso tivesse interesse em demandar os demais devedores solidários, demais fiadores ou o devedor principal, bastaria indicá-los na petição inicial e, com isso, formar um litisconsórcio passivo inicial⁵⁵².

Portanto, são sempre do réu o interesse e a legitimidade para provocar o chamamento ao processo.

O art. 131 do Código estabelece que o réu deve requerer o chamamento na contestação.

Uma vez formulado o requerimento de chamamento pelo réu, caberá ao juiz inicialmente, de ofício, verificar o cabimento da intervenção de terceiro, devendo, em homenagem ao princípio do contraditório, ouvir o autor.

Admitida a intervenção, os terceiros serão citados e, com isso, passarão a integrar a relação processual, no polo passivo.

Portanto, realizado o chamamento, forma-se um litisconsórcio passivo, facultativo e ulterior⁵⁵³ entre o réu (chamante) e os terceiros chamados, que, por agora integrarem a relação processual, também poderão ser condenados a responder, em face do credor pela dívida.

Interessante notar que, de um lado, o interesse do terceiro/chamado é idêntico ao da parte ré que provocou o chamamento, uma vez que a ambos interessa demonstrar inexistência ou extinção da dívida, pelo pagamento ou prescrição, ou que o montante pleiteado pelo autor é excessivo, por exemplo.

Por outro lado, é certo que o réu que promoveu o chamamento também exerce pretensão contra o terceiro/chamado, sobretudo porque, caso venha a pagar a dívida por inteiro, poderá cobrar deste a parte que lhe cabe por força da sub-rogação estabelecida no direito material⁵⁵⁴.

Portanto, a relação entre o réu original, promotor do chamamento, e o terceiro/chamado é híbrida, pois, por um lado, ambos são réus, isto é, na demanda original proposta pelo autor, são litisconsortes passivos. Por outro lado, são adversários na lide inserida no processo pelo chamamento, podendo divergir sobre a existência e o alcance do dever decorrente da sub-rogação.

Ao juiz caberá decidir a lide original, e, caso a julgue procedente, deverá decidir também sobre o eventual direito de sub-rogação que decorra do pagamento da dívida pela parte original contra os terceiros chamados.

Nesse sentido, o art. 132 do CPC determina que a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.

Exemplificando, temos que, em uma dívida solidária contraída por Maria Eduarda e Giovana em face de Carolina, caso a credora – Carolina – demande apenas Maria Eduarda, esta poderá, em sua contestação, chamar

ao processo também Giovana – devedora solitária não demandada.

Nesse contexto, caso realizado o chamamento, Giovana passará a integrar a relação processual no polo passivo, inclusive formulando defesa contra o pedido de Carolina, na qualidade de litisconsorte de Maria Eduarda.

O juiz, na hipótese, quando proferir sentença deverá decidir sobre o litígio original, e, caso condene as devedoras a pagar, deverá também estabelecer que a ré que pagar a dívida sozinha poderá cobrar da outra a parte que lhe cabe em razão da sub-rogação.

Assim, no exemplo citado, Maria Eduarda, que realizou o chamamento, poderá, por força da instauração desta modalidade de intervenção de terceiro, obter, na mesma sentença que a condena, o direito de exigir de Giovana (terceiro/chamado) a quota-parte devida por esta.

Giovana, por sua vez, que não fora originalmente demandada mas passou a integrar a relação processual em razão do chamamento ao processo, poderá ser legitimamente condenada e reconhecida não apenas como devedora solidária, como também responsável por ressarcir a ré original (Maria Eduarda) que pagar a dívida sozinha.

Situação semelhante aconteceria caso Maria Eduarda fosse fiadora da dívida de Giovana com Carolina e viesse a ser demandada sozinha. Na hipótese o chamamento de Giovana por Maria Eduarda permitiria, caso esta venha a ser condenada a pagar a dívida, o exercício contra Giovana – terceiro, porém devedor principal – do direito decorrente da sub-rogação prevista no art. 831 do Código Civil e, com isso, valer-se da mesma sentença que a condena, para cobrar também a devedora original.

17.4.3 Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

17.4.3.1 Premissas para a compreensão

Três premissas precisam ser fixadas para a compreensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto entre os arts. 133 e 137

do Código de Processo Civil: a) as pessoas jurídicas são sujeitos de direito e possuem personalidade distinta e autônoma em relação às pessoas físicas que as criaram e as administram; b) em decorrência disso, existe uma relação de independência entre o patrimônio, direitos e obrigações da pessoa jurídica em relação às pessoas físicas que a instituíram e a dirigem; e c) em determinadas situações essa autonomia patrimonial pode ser relativizada, o que implica dizer que as pessoas físicas responsáveis pela administração da pessoa jurídica podem vir a ser responsabilizadas pela dívida desta, nos termos da lei.

Por força da primeira premissa (“a”), base de toda a teoria da personalidade jurídica, uma vez regularmente constituída uma pessoa jurídica, esta adquire personalidade distinta daqueles que a instituíram, sendo, portanto, para todos os fins, sujeitos de direitos e obrigações independentes no plano do direito material, e, conforme já asseverado, possuindo capacidade de ser parte para o direito processual⁵⁵⁵.

Vale registrar que essa personalidade distinta está condicionada à regular constituição da pessoa jurídica, nos termos do direito material.

Assim, sem o registro do ato constitutivo e obediência às demais formalidades legais, a pessoa jurídica será considerada mera sociedade de fato, sem personalidade jurídica e, portanto, sem autonomia em relação às pessoas físicas que a integram.

De outro lado, uma vez regularmente constituída, a pessoa jurídica pode, no plano do direito material, contratar, ser civilmente responsabilizada, adquirir direitos e contrair obrigações sem que tais situações jurídicas alcancem as pessoas dos sócios ou administradores.

Na hipótese de estas relações da pessoa jurídica se tornarem litigiosas, é possível que esta vá a juízo como autora ou venha a ser demandada como ré, sem que seus sócios, instituidores ou diretores figurem pessoalmente na relação processual. No máximo, nestes casos, o sócio ou diretor figurará no processo como representante da pessoa jurídica⁵⁵⁶, porém não como parte,

sendo, para todos os fins, terceiros para o direito processual.

Decorrencia lógica desta personalidade distinta e independente (“a”) – nos planos material e processual – é a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios ou diretores (“b”).

Tal como a independência da personalidade jurídica, a autonomia patrimonial é condicionada à regular constituição da pessoa jurídica nos termos do direito material⁵⁵⁷.

Portanto, uma vez regularmente constituída a pessoa jurídica, é o patrimônio desta, e não o de seus sócios ou diretores, que respondem por suas dívidas e obrigações, e, até por isso, no plano processual, será a pessoa jurídica aquela a ser demandada e eventualmente executada sem que seja necessário fazer com que seus sócios integrem a relação processual, sendo, em princípio, vedado que os atos executivos recaiam sobre o patrimônio destes sujeitos.

Entretanto, essa independência patrimonial não é absoluta, havendo situações em que deve ser desconsiderada, podendo as pessoas físicas responsáveis pela instituição ou administração da pessoa jurídica ser pessoalmente responsabilizadas pelas dívidas e obrigações desta (premissa “c”, estabelecida supra).

Em suma, no que se refere à responsabilidade patrimonial, a segunda premissa (“b”) é a regra geral e a terceira (“c”), a exceção.

O alcance da responsabilidade dos sócios e administradores e as hipóteses em que estes podem vir a ser responsabilizados pelas dívidas da pessoa jurídica que integram ou administram são regulados pelo direito material e, inclusive, variam de acordo com a espécie de sociedade.

A título exemplificativo, é possível citar a responsabilidade dos sócios das pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, que se caracteriza pela obrigação de os sócios integralizarem o capital social, que só podem ser relativizadas nas hipóteses previstas na lei material, a seguir tratadas. Já os

sócios de sociedades anônimas não possuem responsabilidade patrimonial pelas dívidas destas, recaiando a eventual responsabilidade, excepcionalmente, sobre as pessoas de seus administradores.

Destarte, as situações em que os sócios e diretores podem ser pessoalmente responsabilizados pelas obrigações das pessoas jurídicas que integram não pertencem ao Direito Processual Civil, dado que dispostas no direito material⁵⁵⁸.

Nesse contexto, o Direito Processual Civil ocupa-se apenas de regulamentar a relação processual nos casos em que o credor da pessoa jurídica pretender desconsiderar sua autonomia patrimonial e responsabilizar pessoalmente o sócio pelas obrigações daquela.

Considerando a autonomia da personalidade da pessoa jurídica, é correto concluir que, em princípio, só esta será a parte na relação processual, o que impõe a conclusão que os sócios ou administradores – pessoas distintas que são – devem ser classificados como terceiros.

São terceiros, contudo, em relação aos quais o credor da pessoa jurídica pode passar a exercer pretensão, o que só se legitima caso estes passem a integrar a relação processual, originalmente formada apenas com a presença da pessoa jurídica.

A forma de fazer com que os sócios integrem a relação processual da qual faz parte a pessoa jurídica, de modo a viabilizar a responsabilização destes mediante a decretação da desconsideração da pessoa jurídica, é a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto e regulado entre os arts. 133 e 137 do Código de Processo Civil.

Trata-se de modalidade de intervenção de terceiros, haja vista que, até então, o sócio não integrava a relação processual – nem como autor, nem como réu – sendo terceiro, portanto.

Tal modalidade encerra uma hipótese de intervenção de terceiros provocada, uma vez que a parte autora – credora da pessoa jurídica – é

aquela que requer a integração de seus sócios ou administradores à relação processual.

17.4.3.1.1 Pressupostos materiais para a desconsideração da personalidade jurídica

Considerando que, como regra geral, vigoram os princípios da autonomia patrimonial e independência da personalidade jurídica, é preciso que a exceção capaz de viabilizar a responsabilização dos sócios seja expressamente autorizada pelo Direito.

Preliminarmente, neste passo, fazem-se necessárias duas observações: a) é o direito material que disciplina as hipóteses e condições em que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada ou relativizada, e em decorrência disso; b) as condições e possibilidades de desconsideração podem inclusive variar de acordo com o ramo do direito material que regula a situação jurídica.

A primeira observação é importante para que se deixe claro que não é o Código de Processo Civil, ou mesmo o direito processual, que define em que situações o sócio deve ser responsabilizado.

Cabe ao Direito Processual Civil, portanto, apenas e tão somente disciplinar o procedimento por meio do qual o pedido de desconsideração pode ser formulado, instruído e julgado, observando-se as garantias fundamentais do processo, dentre as quais os princípios do contraditório e ampla defesa, em especial.

Ademais, cada ramo do direito pode disciplinar as hipóteses de desconsideração relacionadas às obrigações e relações jurídicas que alcançam, não existindo, portanto, uma única regra autorizadora da desconsideração.

Assim, as relações de direito civil e consequentemente as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica reguladas pelo Código Civil se aplicam às relações disciplinadas por este ramo do Direito, não alcançando,

por exemplo, as situações jurídicas reguladas pelo direito ambiental.

A título exemplificativo, podemos ressaltar que o art. 4º da Lei n. 9.605/98, que regulamenta a responsabilidade por danos ambientais, dispõe que “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. Tal regra, específica do direito ambiental, possui aplicabilidade restrita à responsabilidade dos sócios por danos ambientais, portanto.

No mesmo sentido, dispõe o art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor no que se refere à possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

Nota-se que nestes contextos específicos a mera dificuldade causada pela independência e autonomia patrimonial da pessoa jurídica pode autorizar a desconsideração, o que é conhecido na doutrina por teoria menor da desconsideração, em que apenas o aspecto objetivo – insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica – é levado em consideração⁵⁵⁹.

Por outro lado, nas relações civis, assim como na legislação de defesa da ordem econômica e na anticorrupção, vigora a teoria maior, segundo a qual, além da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, faz-se necessária a demonstração de requisitos subjetivos como o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nesse sentido, dispõe o art. 50 Código Civil, verbis: “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Portanto, pela teoria maior da desconsideração, regra para as relações civis e empresariais em geral, para que a desconsideração seja autorizada pelo juiz é preciso que reste demonstrado no processo que houve “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

Verificada uma das condições previstas no Código Civil e sendo a relação jurídica controvertida regida por este ramo do Direito, o juiz estará autorizado a reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica, desde que instaurado e regularmente processado o incidente nos termos do Código de Processo Civil.

A análise de todas as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica em todos os ramos do direito escapa ao objeto desta Introdução, até por não pertencerem ao próprio objeto de estudo do Direito Processual Civil, como dito.

São suficientes os exemplos acima citados não apenas para demonstrar a possibilidade de variação dessas condicionantes como também para ilustrar a existência de circunstâncias fáticas e jurídicas que precisam ser demonstradas no processo, em contraditório, como a participação de todos os interessados, sendo este o papel do Direito Processual Civil, neste contexto, e, particularmente, do incidente de desconsideração aqui tratado.

17.4.3.1.2 A desconsideração da personalidade jurídica inversa

Vale registrar que o direito material também admite a denominada desconsideração inversa da personalidade jurídica, assim entendida a possibilidade de a pessoa jurídica vir a ser responsabilizada pelas dívidas de seus sócios.

A hipótese em tudo se assemelha à desconsideração clássica até aqui tratada, uma vez que, nos casos de desconsideração inversa, o objetivo é, igualmente, relativizar os princípios da independência da personalidade e autonomia patrimonial. A diferença, neste caso, reside no fato de, em vez

de a pessoa física do sócio vir a ser responsabilizada pelas dívidas da pessoa jurídica, será esta responsabilizada pelas dívidas do sócio se instaurado o incidente e demonstrados os pressupostos.

Em algumas passagens subsequentes o texto fará referência expressa apenas à hipótese de desconconsideração da personalidade jurídica clássica, sendo certo que as conclusões e ponderações poderão, *mutatis mutandis*, ser transportadas para a situação da desconconsideração inversa, expressamente admitida pelo art. 133, § 2º, do CPC.

17.4.3.2 Hipóteses de cabimento, legitimidade e finalidade

Conforme exposto no item precedente, o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica tem lugar nas hipóteses em que o credor pretende relativizar os princípios da independência da personalidade e autonomia patrimonial em um específico processo de cobrança da dívida, quer para responsabilizar os sócios pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica, quer para responsabilizar estas pelas dívidas de seus sócios.

A razão de ser dessa modalidade de intervenção, desta feita, é o exercício da pretensão à responsabilização de outros sujeitos distintos do devedor, pelo credor autor da demanda.

Por outro lado, sob a perspectiva do sócio que pode vir a ser responsabilizado, é inegável que a instauração do incidente em certa medida lhe é benéfica, uma vez que lhe permitirá exercer o contraditório prévio e efetivo, antes da decisão que declare a existência dos pressupostos autorizadores da desconconsideração e determine (ou viabilize) a prática de atos executivos sobre o seu respectivo patrimônio pessoal.

Portanto, é possível afirmar que o incidente de desconconsideração possui dupla finalidade: a) viabilizar que o credor da pessoa jurídica exerça pretensão contra seus sócios ou administradores, responsabilizando-os pela dívida da empresa ou sociedade; e b) permitir que esses sócios exerçam o contraditório prévio e efetivo sobre o pedido contra eles formulados.

Para tanto, o sócio (ou a pessoa jurídica, no caso de desconsideração inversa) será citado e passará a integrar a relação processual, e, caso o juiz, entenda que, além de a demanda original ser procedente, estejam presentes os pressupostos da desconsideração, deverá, na mesma decisão que condena o devedor principal, reconhecer a possibilidade de desconsideração e viabilizar, também, uma futura execução contra os sócios tidos como responsáveis patrimoniais.

Nesse sentido, os arts. 133 e 134 do Código de Processo Civil estabelecem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento⁵⁶⁰, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Da leitura dos dispositivos, depreende-se, ademais, que não cabe ao juiz instaurar o incidente de ofício, devendo ser instaurado a pedido da parte interessada ou do Ministério Público, nas hipóteses em que este atue como fiscal da ordem jurídica⁵⁶¹.

Uma vez instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio, citado, passa a integrar a relação processual, podendo, juntamente com a pessoa jurídica que integra, oferecer defesa contra a demanda original e, além disso, opor-se ao pedido de desconsideração, demonstrando não estarem presentes os pressupostos materiais exigidos para que ela se opere.

17.4.3.3 Procedimento e dinâmica da relação processual após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Uma vez instaurado o incidente, o art. 135 do CPC estabelece que o sócio ou a pessoa jurídica, conforme o caso, será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze dias.

Tal dispositivo possui o claro intuito de viabilizar o exercício do

contraditório e ampla defesa do sócio cujo credor pretende responsabilizar, legitimando, por essa via, eventual decisão que reconheça a desconsideração e o responsabilize.

O objeto (mérito) do incidente de desconsideração é exatamente a existência das circunstâncias autorizadoras da lei material, tais como a confusão patrimonial e o desvio de finalidade previstos no Código Civil, nos casos regidos por esse plexo legislativo.

Por isso, a decisão do incidente, se procedente, autorizará, caso a pessoa jurídica venha a ser condenada, que também os sócios respondam pela dívida ou, se não reconhecer as hipóteses autorizadoras, rejeitará o pedido de responsabilização dos terceiros trazidos ao processo por força da intervenção.

Até por isso, nos casos de procedência, o sócio poderá atuar como assistente litisconsorcial da pessoa jurídica com o intuito de discutir também obrigação para a qual foi declarado responsável.

Portanto, uma vez citado e integrado à relação processual, o sócio pode procurar demonstrar a inexistência dos requisitos autorizadores de sua desconsideração ou, mais amplamente, a impossibilidade de sua responsabilização, e também se posicionar como litisconsorte da pessoa jurídica para demonstrar a inexistência ou extinção da dívida.

17.5 Amicus curiae

17.5.1 Generalidades

O art. 138 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de intervenção de terceiros na qualidade de amicus curiae, que pode, a depender da situação, ser voluntária, ou provocada, pela parte ou pelo próprio judiciário.

O referido dispositivo estabelece que “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a

repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecurável, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.

Conforme se depreende da leitura do dispositivo, a intervenção do terceiro na qualidade de *amicus curiae* pode decorrer: a) da iniciativa do próprio terceiro; b) por requerimento da parte, ou c) por determinação de ofício pelo juiz, o que nos permite classificar tal modalidade tanto como voluntária quanto como provocada, a depender da situação concreta⁵⁶².

O terceiro legitimado para intervir nessa qualidade são aqueles classificados como terceiro com interesse institucional e representatividade adequada.

A figura, relativamente nova no Direito brasileiro, teve inicialmente previsão nos processos de jurisdição constitucional com capacidade para produzir decisões com efeito vinculante e *erga omnes*⁵⁶³.

Tal previsão encontra-se no art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/99, que estabelece que, “em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria”.

Com a introdução do instituto da súmula vinculante, pela Emenda à Constituição n. 45/2004, o ordenamento jurídico brasileiro passou a admitir também no procedimento de formação deste enunciado a possibilidade de participação do *amicus curiae*.

Ambas as situações disciplinadas pela Constituição Federal se caracterizam por produzir pronunciamentos vinculantes e com efeito “*erga*

omnes”.

Nesse contexto, a participação do *amicus curiae* é uma forma de viabilizar a participação de terceiros com interesse (institucional) e legitimidade (decorrente da representação adequada) na formação do pronunciamento vinculante.

William Santos Ferreira⁵⁶⁴, ao tratar especialmente do papel do *amicus curiae* no procedimento de edição de súmula vinculante, afirma que deve ser “assegurada aos órgãos de classe e demais entidades representativas, desde que demonstrado o interesse direto dos representados na solução que será dada, a sua efetiva participação no processo, sendo pois um direito e não um favor, cuja base é o princípio do devido processo legal, e, por consequência e operacionalização dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem ser considerados à luz das peculiaridades desta forma coletiva de solução, o que em última análise, expõe, de maneira viva, as dificuldades do Estado Democrático de Direito, mas também que suas virtudes em muito superam os defeitos”.

Mais adiante o autor⁵⁶⁵ conclui, com precisão, que “a súmula vinculante por um lado concentra o debate e, de certa maneira, a solução dos conflitos (de massa) com aptidão para afastar uma avalanche de processos individuais e o risco de decisões divergentes; mas por outro lado, justamente em atenção a sua natureza coletiva, deve assegurar a participação efetiva do *amicus curiae*, não só porque este pode contribuir muito para o debate, mas também por ser forma de legitimação da decisão que será proferida”.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o sistema infraconstitucional também passou a admitir que determinados pronunciamentos produzam efeitos vinculantes, para além do processo em que o julgado se formou, como no caso do julgamento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, de assunção de competência e recurso especial e extraordinário repetitivos.

Nesses específicos procedimentos, conforme já asseverado, busca-se a formação de um precedente qualificado apto a ser aplicado aos demais processos que envolvam a questão jurídica objeto de julgamento⁵⁶⁶.

Nessas situações, o legislador passou a admitir a possibilidade de intervenção de terceiros nessa qualidade no processo de formação de tais pronunciamentos vinculantes.

Desta feita, a intervenção do amicus curiae no processo civil tem lugar sobretudo nos procedimentos capazes de produzir pronunciamentos vinculantes, de obrigatória observância pelos demais juízes e tribunais, nos termos dos arts. 927, 947, 985 e 1.040 do CPC.

Tal possibilidade se justifica pelo potencial efeito pamprocessual, para além do processo em que o julgado se formou, típico de procedimentos voltados a produzir decisões e pronunciamentos previstos especialmente no art. 927 do CPC.

Trata-se, nesse contexto, de uma maximização do princípio do contraditório em tais procedimentos, diretamente proporcional à força (autoridade) das decisões produzidas nesses ambientes.

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno⁵⁶⁷ faz uma precisa correlação entre os efeitos persuasivos ou vinculantes de determinadas decisões judiciais e a atuação do amicus curiae, em que, segundo o autor, por força da possibilidade de determinadas decisões, de modo mais ou menos intenso, afetar “o que se vai decidir e como se vai decidir”, existe a necessidade de um diálogo prévio, que assume um caráter de fator de legitimação das decisões jurisdicionais.

Mais adiante⁵⁶⁸, o autor arremata, destacando que “não se trata apenas de aprimorar a qualidade dessas decisões, mas, bem diferentemente, de legitimá-las, tornando-as adequadas ao nosso sistema constitucional, realizando o fim último do processo que é a apaziguação social”.

17.5.2 Legitimidade para intervir na qualidade de amicus curiae

A compreensão da legitimidade para intervir como *amicus curiae* impõe, em primeiro lugar, a definição sobre quem pode atuar nesta qualidade no processo alheio.

Além disso, considerando que a intervenção do *amicus curiae* pode se dar por requerimento da parte ou mesmo por determinação, de ofício, do juiz, essa legitimidade para provocar também merece algumas considerações.

A legitimidade do terceiro para intervir como *amicus curiae* decorre de seu interesse institucional e de sua representatividade adequada.

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno⁵⁶⁹, no mais completo trabalho sobre a figura do *amicus curiae* no Direito brasileiro, demonstra que, para atuar nessa qualidade, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, deve demonstrar, independentemente de previsão legislativa, cumulativamente: a) interesse institucional, conceito mais abrangente do que o interesse jurídico previsto na regulamentação do instituto da assistência; e b) adequada representação, assim entendida a representatividade dos postulantes⁵⁷⁰.

O autor⁵⁷¹ sugere como “um referencial importantíssimo mas não suficiente” o rol de legitimados pelo direito processual para propor ações coletivas, salientando todavia que não há como recusar que quaisquer interessados, “mesmo não admitido pela lei brasileira, como legitimados para propor ações coletivas, possam pretender desempenhar a função de *amicus curiae*”⁵⁷².

Arruda Alvim⁵⁷³ esclarece que a representatividade adequada diz respeito à capacidade objetiva do terceiro em contribuir com o julgador na solução do conflito. Nesse contexto, o autor destaca a necessidade de demonstração de pertinência temática entre o interesse institucional da pessoa jurídica e a causa de pedir presente no processo, sem, todavia, dizer respeito a direito propriamente seu, direto ou indireto.

É o caso, por exemplo, de pessoas jurídicas ligadas à indústria

farmacêutica que possuam interesse institucional para atuar como amici curiae em processos voltados a discutir as possibilidades e limites de pesquisas com células tronco ou animais, sobretudo se o procedimento – de controle concentrado de constitucionalidade, edição de súmula ou de formação de precedente vinculante – for capaz de atingir diretamente sua atividade.

É inegável que, nesse contexto, o amicus curiae atua na defesa de seu interesse, buscando influir na decisão judicial que direta ou indiretamente, possa repercutir em sua esfera jurídica, ainda que, repita-se, o objeto do processo não envolva exatamente direito seu.

A intervenção do amicus curiae pode se dar a requerimento do próprio terceiro interessado a teor do disposto no art. 138 do CPC, sendo, nesse contexto, uma modalidade classificada como voluntária.

De outro lado, o mesmo dispositivo citado admite que uma das partes provoque a intimação de terceiros para atuar nessa qualidade. Nestas situações a intervenção do amicus curiae deve ser classificada como provocada.

Cabe à parte requerente, nestes casos, demonstrar a necessidade da intervenção, assim como os requisitos legitimadores do terceiro, notadamente a representatividade adequada e a pertinência temática.

Ademais, o magistrado pode, de ofício, determinar a intervenção do amicus curiae.

A hipótese representa uma rara possibilidade de intervenção de terceiro por ordem do juiz⁵⁷⁴, admitida exatamente quando o magistrado entender que algum terceiro possui representatividade adequada e capacidade de contribuir para o esclarecimento de fatos ou pontos relevantes para o julgamento da causa.

17.5.3 Atuação do amicus curiae: limites e possibilidades

O Código de Processo Civil não define com precisão os poderes do amicus

curiae, dispondo, no art. 138, § 2º, que “caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir seus poderes”.

Contudo, considerando a natureza e finalidade dessa modalidade de intervenção de terceiros, é forçosa a conclusão no sentido de que os poderes de limitar e definir o papel do amicus curiae pelo juiz devem ser compreendidos à luz da finalidade da intervenção, qual seja, maximizar o debate e contribuir para o esclarecimento do objeto da controvérsia.

Portanto, a par da manifestação por escrito do amicus curiae no prazo de 15 dias previsto no caput do art. 138 do CPC, pode o juiz ou relator admitir que ele requeira ou participe da produção probatória, formulando quesitos para o perito ou inquirindo testemunhas, realize sustentação oral e participe de audiência pública, entre outras atividades voltadas à contribuição com o debate.

Há, de outro lado, certas restrições no que se refere ao poder de recorrer de o amicus curiae, uma vez que o Código limita a possibilidade de este apresentar apenas embargos de declaração e recurso contra a decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 138, §§ 1º e 3º, do CPC).

A restrição parece ser coerente com a finalidade da intervenção e com o fato de o amicus curiae não defender direito próprio no processo em que intervém, sendo, assim, a priori, suficiente a possibilidade de manejo de embargos de declaração, recurso que, nos termos do art. 1.022 do CPC, volta-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

Ademais, o art. 138, § 3º, do Código autoriza o amicus curiae a interpor recursos contra o julgamento de demandas repetitivas, procedimento vocacionado à produção de um precedente qualificado.

Por analogia, a autorização em comento também permite ao amicus

curiae interpor recurso contra decisões proferidas em outros procedimentos igualmente voltados à formação de um precedente qualificado, como o incidente de assunção de competência e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

17.6 Outras modalidades de intervenção de terceiros fora do capítulo específico do Código de Processo Civil

Todas as modalidades de intervenção de terceiros tratadas nos itens anteriores são tipificadas como tais pelo Código de Processo Civil e integram o Título III, “Da Intervenção de Terceiros”, do Livro III, “Dos Sujeitos do Processo”.

Entretanto, fora desse ambiente especificamente dedicado às modalidades de intervenção de terceiros, o CPC também admite a participação de sujeitos estranhos à relação processual, ingressando, portanto, no processo alheio.

Escapa ao objeto desta Introdução o estudo detalhado de cada uma dessas modalidades, até porque, para sua compreensão, se faz necessária a fixação de premissas ligadas a outras técnicas processuais aqui não tratadas, tais como respostas do réu, recursos e execução.

Por isso, os itens abaixo farão o registro e sucintas referências às técnicas processuais, que, apesar de estarem fora do capítulo dedicado às intervenções de terceiros, acabam por viabilizar, em última análise, a participação de sujeitos estranhos à relação processual no processo alheio.

Tais técnicas, a exemplo das intervenções tipificadas, pressupõem o interesse jurídico e a legitimidade do terceiro, como regra caracterizada pela relação jurídica com uma das partes ou interesse no objeto do processo.

São modalidades de intervenção de terceiros não tipificadas no capítulo específico do Código de Processo Civil, porém previstas em outras passagens do CPC: a) o recurso de terceiro prejudicado; b) a ampliação

subjetiva do processo via reconvenção; c) a integração de terceiros decorrente da alegação de ilegitimidade passiva; d) os embargos de terceiro; e e) a intervenção de terceiros por ordem do juiz.

Ademais, considerando a amplitude da cláusula que admite a celebração de negócios processuais, constante do art. 190 do Código de Processo Civil⁵⁷⁵, é possível o estabelecimento de intervenção de terceiros negocial⁵⁷⁶.

Os itens a seguir se dedicam a explicar sucintamente cada uma dessas modalidades, sendo certo que não integra o objeto de uma Introdução ao estudo do Direito Processual Civil a análise de todos os detalhes e desdobramentos decorrentes de sua admissão.

17.6.1 Recurso de terceiro prejudicado

Conforme já asseverado no item 6.1.4.8, uma das normas fundamentais do processo civil brasileiro é o princípio do duplo grau de jurisdição, que permite à parte prejudicada recorrer da decisão judicial que lhe seja desfavorável.

Recurso, na clássica lição do mestre José Carlos Barbosa Moreira⁵⁷⁷, é todo “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna”.

Via de regra, são as partes, ou mais precisamente a parte prejudicada pela decisão judicial, o sujeito legitimado e interessado em recorrer.

Ocorre que, conforme já asseverado nas considerações iniciais deste capítulo, sujeitos que não são partes no processo podem vir a sofrer os efeitos da decisão proferida no processo alheio.

Tanto assim que se admite que esses sujeitos atuem no processo intervindo voluntariamente na qualidade de assistente, simples ou litisconsorcial, a depender na natureza do vínculo e intensidade do interesse⁵⁷⁸.

Ocorre que, além de não ser obrigatória, a intervenção de terceiro via assistência não constitui uma etapa do processo e pode se dar em qualquer momento até a decisão. Ademais, os efeitos da decisão só são efetivamente operados após o proferimento desta.

Por essas razões, o Código admite, no art. 996, o recurso de terceiro prejudicado, assim entendido o mecanismo de impugnação contra decisão judicial manejado por um sujeito que não é parte do processo, mas que, apesar disso, veio a ser atingido pelos efeitos da decisão.

Para fins de demonstração da legitimidade para intervir como terceiro recorrente, exigem-se os mesmos requisitos autorizadores da intervenção como assistente, talvez nessa fase ainda mais fáceis de serem caracterizados, dado que a decisão já fora proferida, definidos seus efeitos e alcance.

Desta feita, não é qualquer sujeito estranho ao processo que pode se opor à decisão, impugnando-a com fulcro no art. 996 do CPC em comento, mas apenas aqueles que demonstrarem “a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.

Por isso, é comum na doutrina a afirmação de que o recurso de terceiro prejudicado pode ser manejado por aquele que poderia ter intervindo no processo⁵⁷⁹ e, apesar de não ter requerido sua intervenção, pode, neste momento procedimental, impugnar a decisão⁵⁸⁰.

Como recurso, essa modalidade de intervenção de terceiro permitirá a revisão, anulação, integração ou complementação da decisão, pela instância superior competente.

17.6.2 Ampliação subjetiva do processo via reconvenção

A priori, o réu se caracteriza por ser a parte contra quem é feito o pedido e, portanto, suas manifestações e requerimentos tendem a ser voltados à

prática e atos típicos de defesa⁵⁸¹.

Por essa razão, o conteúdo mais comum da resposta do réu é a defesa, assim entendida a reação à pretensão do autor.

Contudo, nada impede que, além da defesa, em seu sentido estrito, de mera resistência, o réu formule em seu favor pedido contra o autor mediante reconvenção.

Assim, por exemplo, em uma ação proposta por uma agência de turismo voltada à cobrança de uma dívida decorrente de um pacote de viagens adquirido por José, caso este entenda que, por força de problemas decorrentes da viagem, além de nada dever à agência, possui o direito de ser ressarcido pelos gastos que teve e pelos transtornos sofridos, pode, a par de oferecer defesa, propor via reconvenção um pedido de condenação da parte autora em ressarcir-lo.

O papel da reconvenção, portanto, é viabilizar a formulação de pedido do réu contra o autor. Nas palavras de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini⁵⁸², “reconvenção é uma nova ação, proposta pelo réu contra o autor, no processo já em curso e que foi iniciado pelo autor”.

Ocorre que o Código de Processo Civil, em seu art. 343, § 4º, admite que o réu, ao apresentar a reconvenção, o faça ao lado de outro sujeito estranho ao processo, em litisconsórcio, ampliando subjetivamente a relação processual. Neste caso, ambos os sujeitos (o réu original e o terceiro) formulam via reconvenção pedido contra o autor, o que implica o ingresso de outro sujeito, até então terceiro, no processo.

Nesta situação, portanto, admite-se que, alguém, em princípio estranho à relação processual, seja integrado a ela por força do pedido formulado na reconvenção, a teor do que estabelece o art. 343, § 4º, do CPC.

Assim, retomando o exemplo anterior, caso José, não obstante tenha sido demandado pela agência para pagar o valor decorrente do pacote de viagens sozinho, tenha viajado com Maria, havendo esta igualmente sofrido

prejuízos decorrentes dos problemas do pacote turístico, poderá Maria, juntamente com o réu originário, propor a reconvenção contra o autor.

Nesse caso, a reconvenção irá inserir no processo original outras duas pretensões contra a parte autora: a de José (réu original) e a de Maria (até então terceiro), que por esta via ingressa na relação processual alheia, sendo certo que admitir o exercício de pretensão por Maria é admitir uma intervenção de terceiro.

Portanto, ainda que fora do capítulo dedicado às intervenções de terceiros, o Código, ao admitir o ingresso de sujeitos estranho à relação processual via reconvenção, cria uma modalidade de intervenção voluntária, dado que é do terceiro a vontade de ingressar no processo alheio, formulando nesta sede sua pretensão.

Ademais, o CPC, no art. 343, § 3º, admite que o réu provoque o ingresso de um terceiro pela via da reconvenção.

Dispõe o referido dispositivo que “a reconvenção pode ser proposta contra o autor e contra o terceiro”.

Portanto, via reconvenção, o réu pode demandar, além do autor (parte original), outros sujeitos até então estranhos à relação processual, que passam a integrá-la em razão dessa provocação.

Admitido o pedido formulado pelo réu contra o autor e o terceiro, o primeiro, que já integra a relação processual, será intimado para apresentar defesa, ao passo que o terceiro deverá ser citado, ato que o integrará à relação processual.

A partir de então, o terceiro citado se torna parte, com todos os direitos e deveres daí decorrentes, formando-se em relação ao pedido formulado pelo réu um litisconsórcio entre o autor e o terceiro, cabendo ao juiz decidir o pedido que envolve pelo réu contra esses dois sujeitos.

17.6.3 Integração de terceiros decorrente da alegação de ilegitimidade passiva

Outra forma de a resposta do réu provocar a intervenção de terceiros é este alegar em preliminar de contestação sua ilegitimidade passiva.

Isso porque, conforme já visto no item 8.5.1 do Capítulo 8 desta Introdução, por força do art. 339 do Código de Processo Civil, o réu que alegar sua ilegitimidade passiva deve indicar o verdadeiro legitimado ou responsável pelo dano quando tiver conhecimento.

Esse sujeito indicado pelo réu é, até então, estranho à relação processual e, portanto, terceiro, mas, a depender da manifestação do autor, pode vir a integrar a relação processual.

Isso porque a dinâmica dos arts. 338 e 339 do Código estabelece que o autor será ouvido sobre a indicação, podendo: a) rejeitar a indicação do réu, mantendo-o na relação processual e não permitindo o ingresso do terceiro indicado; b) aceitar a indicação e proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu; ou c) optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Percebe-se que, das atitudes possíveis do autor, duas delas (“b” e “c”), em última análise, implicam a integração ao processo de um sujeito, até então, estranho à relação processual. Em outras palavras, será promovido o ingresso de um terceiro, o que pode ser classificado como modalidade de intervenção de terceiro provocada.

Admitido o ingresso do terceiro indicado pelo réu, em substituição processual ou em litisconsórcio passivo com o réu originário, este será citado e passará a integrar a relação processual como parte, com todos os direitos e deveres daí decorrentes.

17.6.4 Embargos de terceiro

Além dos sócios que, como visto no item 17.4.3, podem, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, vir a ser responsabilizados pelas dívidas da empresa, outros sujeitos, ainda que não sejam considerados

devedores e mesmo não sendo parte da relação processual, podem ter de responder pelos débitos da parte.

Nesse contexto, dispõe o art. 790 do CPC que: “são sujeitos à execução os bens: I – do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II – do sócio, nos termos da lei; III – do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV – do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V – alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI – cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII – do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica”.

O dispositivo e o tema, portanto, pertencem ao estudo da tutela jurisdicional executiva e, por isso, escapam ao objeto desta Introdução.

Ainda assim, neste passo, cumpre fazer o registro de que este sujeito, mesmo não sendo parte, pode vir a sofrer atos executivos – penhora, bloqueio de conta corrente, alienação judicial, p. ex. – sobre seu patrimônio para adimplir a obrigação alheia e, por esta razão, possui um mecanismo de intervenção e reação contra estes atos executivos.

Os embargos de terceiro, portanto, têm lugar quando, com fundamento no art. 790 do Código de Processo Civil, sejam praticados atos executivos contra terceiros tidos pela lei como responsáveis pela obrigação objeto do processo.

Parte da doutrina entende que os embargos de terceiro não são uma modalidade de intervenção de terceiros por darem origem a processo incidental, e não a um incidente processual⁵⁸³.

Contudo, é inegável que a apresentação dos embargos de terceiro impacta diretamente no processo em que se desenvolve a atividade executiva, e possui como objeto justamente um ato praticado contra o

terceiro no processo alheio.

Assim, independentemente da natureza da técnica e do fato de se tratar de um processo incidente ou incidente processual, os embargos de terceiro se encaixam na essência das intervenções de terceiros previstas no capítulo próprio do CPC, pois: a) os atos praticados em um determinado processo produzem efeitos na esfera jurídica de quem não é parte; e b) por esta razão, o terceiro passa a ter interesse e legitimidade para intervir e exercer contraditório e ampla defesa no processo, ainda que para tanto tenha de instaurar um processo incidental, direta e exclusivamente ligado ao processo original em que o ato executivo foi determinado.

Portanto, ainda que fora do capítulo dedicado à intervenção de terceiros, os embargos de terceiro podem ser considerados uma modalidade de intervenção no contexto tratado neste item.

Possui legitimidade para opor embargos de terceiro aquele que, não sendo parte do processo, venha a sofrer constrição (ou ameaça de constrição) sobre seu patrimônio por ordem judicial proferida no processo alheio.

Nesse sentido, estabelece o art. 674 do Código de Processo Civil que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

O art. 675, por sua vez, estabelece que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.

Interpostos os embargos, caberá ao juiz – que deve ser o mesmo juízo que determinou a prática do ato executivo atacado – ouvir a parte original

interessada, ou seja, aquela que possui interesse na manutenção do ato construtivo (arts. 977, § 4º, c/c o art. 679 do CPC), instruir o processo, produzindo provas e colhendo alegações dos sujeitos interessados, para ao final decidir acerca do acerto ou desacerto do ato executivo sobre o patrimônio do embargante.

Assim, dispõe o art. 681 do Código que, acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.

17.6.5 Intervenção de terceiros por ordem do juiz

Via de regra, a iniciativa da intervenção de terceiros é do próprio sujeito que intervém, nos casos de intervenção voluntária ou de uma das partes originais do processo, o que se denomina intervenções provocadas.

Entretanto, em algumas poucas situações o Código de Processo Civil possibilita ao juiz determinar a intervenção de terceiros.

Sobre o tema, Lia Carolina Batista Cintra⁵⁸⁴, em trabalho específico, indica tratar-se de um instituto conhecido e debatido em ordenamentos estrangeiros, como Itália e Espanha, e assevera que no Brasil, apesar de ausência de previsão genérica sobre a possibilidade, o Código de Processo Civil de 2015 passou a prever ao menos uma possibilidade (no art. 382, § 1º), além de surgirem, na doutrina, autorizadas vozes que identificam outras possibilidades.

Portanto, a possibilidade, ainda que rara, é admitida pelo CPC em algumas situações.

São hipóteses de intervenção de terceiros por ordem do juiz no direito brasileiro: a) a intervenção do amicus curiae; b) a citação do litisconsórcio necessário não demandado; c) a citação dos interessados na produção antecipada de prova.

Uma das hipóteses, a intervenção do amicus curiae por determinação do

juiz ou relator, expressamente prevista no art. 138 do Código de Processo Civil, foi tratada no item dedicado a essa modalidade⁵⁸⁵.

Ademais, pode o juiz determinar que o autor promova a citação do litisconsorte necessário⁵⁸⁶. Nestas situações, é bom que se deixe claro, não será o juiz que irá realizar a citação do litisconsorte necessário de ofício, mas deverá este determinar que o autor a requeira e forneça os subsídios para que o terceiro, tido como litisconsorte necessário, seja integrado à lide.

A hipótese se justifica, haja vista que é da natureza do litisconsórcio necessário a obrigatoriedade da presença de mais de um sujeito no polo passivo da relação processual, sob pena de nulidade da decisão⁵⁸⁷. Assim, caso o autor, por equívoco, deixe de demandar todos os litisconsortes necessários, a relação processual não poderá se desenvolver válida e regularmente, questão que cabe ao juiz fiscalizar e zelar de ofício.

Em resumo, nestas situações, temos que a demanda não foi formulada contra todos aqueles sujeitos que deveriam ser parte, existindo pessoas de fora da relação processual – terceiros, portanto – cuja presença é obrigatória, uma vez que a falta destes implica novidade.

Nestas situações, em cumprimento ao dever de zelar pelo desenvolvimento válido e regular do processo, deve o juiz intimar o autor para que este promova a integração do terceiro ao processo.

Uma vez regularmente citado, o terceiro assume a posição de parte, formando um litisconsórcio ulterior⁵⁸⁸, podendo exercer todos os direitos daí decorrentes, assim como a relação processual pode se desenvolver válida e regularmente, haja vista a correção do vício.

A terceira situação (“c”) em que o juiz pode promover a intervenção de um terceiro ao processo é nos casos previstos no art. 382, § 1º, do CPC, que dispõe, no contexto do procedimento de produção antecipada de prova, que “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de

interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso”.

Tal mecanismo, regulado a partir do art. 381 do CPC, tem por objetivo realizar a produção de prova antecipadamente, isto é, antes do momento procedimental adequado ou antes mesmo da instauração do processo principal, quando: “I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

Portanto, é possível que a prova produzida neste ambiente venha a ser utilizada para fundamentar uma demanda, em outro processo, em que o requerente munido da prova formulará pedido contra outrem.

Esse sujeito, que, potencialmente, será parte no processo seguinte, especificamente no procedimento de produção antecipada de prova, será terceiro, pois não integrará essa relação processual, sendo certo que se trata de um terceiro interessado na produção da prova, que, posteriormente, poderá vir a ser utilizada contra si.

É nessas situações que incide a regra do art. 382, § 1º, do Código, ora em comento, pois autoriza o juiz a citar os interessados na produção da prova, assim entendidos aqueles que podem vir a ser parte no processo em que a prova produzida antecipadamente poderá ser utilizada.

A identificação deste terceiro é possível haja vista que, para requerer a produção antecipada de prova, deve o autor, na petição, apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

A integração dos interessados ao procedimento de produção antecipada de provas permite que estes não só participem da produção da prova

requerida como também requeiram a produção de outras provas ligadas aos fatos que se pretende provar pela via desse procedimento.

Assim, por exemplo, caso a parte pretenda realizar, pelo procedimento previsto no art. 381 do Código, a produção de uma perícia médica justificando sua necessidade para fins de, posteriormente, requerer aposentadoria por invalidez junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, pode o juiz, desde logo, promover o ingresso do INSS no processo, franqueando-lhe a possibilidade de participação na produção antecipada da prova.

O INSS, neste contexto, seria um terceiro com interesse jurídico na produção da prova, pois viria a ser o réu no futuro processo em que a pretensão de aposentadoria por invalidez com base na prova produzida antecipadamente fosse formulada e, por isso, pode vir a ser integrado ao procedimento por ordem do juiz a teor do art. 382, § 1º, do Código de Processo Civil.

Referências

ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: RT, 2012.

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.

ARRUDA ALVIM, José Manoel. Manual de direito processual civil. 17. ed. São Paulo: RT, 2017.

ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: RT, 2017.

ASSIS, Araken de. Manual da execução. 17. ed. São Paulo: RT, 2014.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.

BONICIO, Marcelo José Magalhães. Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006.

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1.

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: tutela jurisdicional executiva. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 3.

BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006.

BRUSCHI, Gilberto; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015. São Paulo: RT, 2015.

CABRAL, Antônio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v. 1.

CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di diritto processuale civile. Nápoles: Casa Ed. Dott Eugenio Jovene, 1965.

CINTRA, Lia Carolina Batista. Intervenção de terceiros por ordem do juiz. São Paulo: RT, 2017.

CRUZ E TUCCI, José Rogério. O precedente judicial como fonte do Direito. São Paulo: RT, 2004.

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional. São Paulo: Atlas, 2009.

DANTAS, Rodrigo Dório. A litigância de má-fé e a responsabilidade do advogado. Florianópolis: Conceito Editorial, 2013.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 1.

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 2.

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil. 14. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. v. 3.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. v. I.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. v. II.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7. ed.

São Paulo: Malheiros, 2017. v. III.

DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. 15. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. v. 1.

FERREIRA, William Santos. Princípios fundamentais da prova cível. São Paulo: RT, 2014.

FERREIRA, William Santos. Súmula Vinculante – solução concentrada: vantagens, riscos e necessidade de um contraditório de natureza coletiva (amicus curiae). In: FERREIRA, William Santos et al. (Coord.). Reforma do Judiciário: primeiras reflexões sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005.

FIGUEIREDO, Simone; Diogo Carvalho (Coord.). Novo CPC anotado e comparado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito

civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo. São Paulo: Método, 2015.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

GOUVEIA, Lúcio Grassi de. A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva no Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 172, 2009.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada erga omnes, secundum eventum litis e secundum probationem. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 126, ago. 2005.

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: RCS Editores, 2007.

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da Constituição. 3. ed. São Paulo: RCS Editores, 2007.

LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. 2. ed. São Paulo: RT, 2005.

LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 5. ed. São Paulo: Castro Lopes, 2016.

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Relação entre demandas. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. São Paulo: RT, 2010.

MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 9. ed. São Paulo: RT, 2006.

MARINONI, Luiz Guilherme. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos. In: MACHADO, Fábio Cardoso; AMARAL, Guilherme Rizzo

(Org.). Polêmica sobre a ação. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed. São Paulo: RT, 2016.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência. São Paulo: RT, 2017.

MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela de direitos. São Paulo: RT, 2004.

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: RT, 2007. v. 1.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado. 5. ed. São Paulo: RT, 2003.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória (individual e coletiva). 3. ed. São Paulo: RT, 2003.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. 6. ed. São Paulo: RT, 2007. v. 2.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. São Paulo: RT, 2015. v. 1.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2016. v. 2.

MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: RT, 2015.

MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2. ed. São Paulo: RT, 2016.

MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. O precedente qualificado no processo civil brasileiro: formação, eficácia vinculante e impactos procedimentais. Sistemi processuali a confronto: il nuovo Codice di Procedura Civile del Brasile tra tradizione e rinnovamento. Publicações da Escola da AGU.

Brasília: Fórum, 2016.

MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia para a aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012.

MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Função nomofilática dos tribunais superiores no Brasil e na Itália e a necessidade de respeito aos seus precedentes. Curso de Introdução ao Direito Europeu. Publicações da Escola da AGU, n. 21, v. 2, Brasília, 2012.

MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Conceito, classificação e eficácia executiva da sentença no novo regime de execução de títulos executivos judiciais. In: SHIMURA, Sérgio; BRUSCHI, Gilberto Gomes (Coord.). Execução civil e cumprimento de sentença. São Paulo: Método, 2007. v. 2.

MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Reclamação. STF. Legitimação ativa. Atingidos por ADIN. Revista de Processo, São Paulo, RT, n. 142, dez. 2006.

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: RT, 2004.

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 12. ed. São Paulo: RT, 2016.

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.

NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1978. v. 1.

OMMATI, José Emílio Medauar. Embargos declaratórios e o Estado Democrático de Direito. In: NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: RT, 2005. v. 8.

PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. O princípio do devido processo legal:

direito fundamental do cidadão. Coimbra: Almedina, 2009.

RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2016.

ROSAS, Roberto. Da súmula à súmula vinculante. Revista dos Tribunais, São Paulo, RT, v. 98, n. 879, jan. 2009.

SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 1.

SANTOS, Welder Queiroz dos. Princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Método, 2006.

SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, RT, v. 91, n. 798, 2002.

STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016.

THEODORO JR., Humberto. As vias de execução do CPC brasileiro reformado. In: WAMBIER, Teresa Arruda Avim (Coord.). Aspectos polêmicos da nova execução 3. São Paulo: RT, 2006.

THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. v. I.

THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 58. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. I.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de direito processual civil. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. I.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de direito processual civil. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. II.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e ação rescisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. São Paulo: RT, 2008.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord.). Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada – hipóteses de relativização. São Paulo: RT, 2003.

- 1** Sobre a distinção entre regras e princípios, ver o item 6.1.1.
- 2** Sobre a admissibilidade excepcional da autotutela, ver o item 3.1.1.
- 3** Ver o item 3.1.2.

- 4** Sobre o denominado “processo administrativo”, que não é jurisdicional, ver o item “e”, infra.
- 5** NORONHA, E. Magalhães. Direito penal, 15. ed., p. 12.
- 6** Sobre o tema, ver o item 2.3.2, “a”.
- 7** Nesse sentido: ABBOUD. Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais, p. 101-102.
- 8** DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional, p. 44.
- 9** Sobre a classificação da jurisdição, ver o item 5.1.
- 10** NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, 12. ed., p. 54.
- 11** Sobre as peculiaridades do processo civil quando uma das partes da relação processual é o Poder Público: CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo, 13. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016; e RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2016.
- 12** Teoria Geral do Processo, 25. ed., p. 94.
- 13** Lei Federal n. 13.105/2015.
- 14** Sobre as normas e os critérios de repartição de competência, ver Capítulo 15 desta Introdução.
- 15** Lei Federal n. 13.105/2015.
- 16** Capítulo 6.
- 17** O princípio fundamental sobre o qual todos os outros se sustentam é o do devido processo legal (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, 12. ed., p. 106). Sobre o tema, com mais vagar, ver o item 6.1.4.10.
- 18** BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 92.
- 19** BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, 84.
- 20** Sobre o tema, ver o item 6.1.4.2.
- 21** Sobre o princípio do juiz natural, ver o item 6.1.4.7.
- 22** Sobre o tema, ver item 6.2.9, no Capítulo 6.
- 23** Art. 1.028 CPC, verbis: “Ao recurso mencionado no art. 1.027, inc. II, alínea “b”, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e procedimento, as disposições relativas à apelação e ao Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.
- 24** Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, p. 57-58.
- 25** O mesmo autor (op. e loc. cit.) cita o relevante rol de funções específicas da jurisprudência elencado pelo mestre Rubens Limongi França (Verbete “Jurisprudência”. In: SANTOS, Carvalho; DIAS, Aguiar. Jurisprudência. Repertório Enciclopédico de Direito Brasileiro. Rio de Janeiro Borsói, v. XXX, p. 291-293), a saber: a) interpretar a lei; b) vivificar a lei; c) humanizar a lei; d) suplementar a lei; e, e) rejuvenescer a lei.
- 26** Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, p. 65.
- 27** MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, p. 6.

- 28** Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 210.
- 29** Súmula Vinculante n. 27 do Supremo Tribunal Federal.
- 30** Sobre o papel dos precedentes como fonte do Direito: CRUZ E TUCCI, José Rogério. O precedente judicial como fonte do Direito, São Paulo: RT, 2004.
- 31** MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, p. 25.
- 32** MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, p. 33.
- 33** Nesse sentido: ROSAS, Roberto. Da súmula à súmula vinculante. Revista dos Tribunais, p. 44.
- 34** Sobre o tema: MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. O precedente qualificado no processo civil brasileiro: formação, eficácia vinculante e impactos procedimentais, in *Sistemi processuali a confronto: il nuovo Codice di Procedura Civile del Brasile tra tradizione e rinnovamento*. Publicações da Escola da AGU, p. 93-112.
- 35** Item 2.2, “f”, supra.
- 36** Comentários ao Código de Processo Civil, p. 226.
- 37** Manual de Direito Processual Civil, p. 106.
- 38** CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coord.). Comentários ao novo Código de Processo Civil, p. 66.

- 39** DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 11. ed., p. 206.
- 40** DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 11. ed., p. 197.
- 41** Nesse sentido, DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 11. ed., p. 193.
- 42** Código Penal: "Art. 354. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência".
- 43** DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo, 17. ed., p. 21.
- 44** Sobre o tema, ver o item 11.4.2, "b", que analisa a extinção do processo pela sentença homologatória de acordo entre as partes.
- 45** Sobre o tema, ver o item 11.4.2, "b", que analisa a extinção do processo em função da renúncia e do reconhecimento jurídico do pedido.
- 46** DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, 17. ed., v. 1, p. 276.
- 47** DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, 17. ed., v. 1, p. 276.
- 48** Sobre o princípio da preferência pela solução consensual de conflitos, ver item 6.2.3, no Capítulo 6, dedicado às normas fundamentais do Processo Civil brasileiro.
- 49** Sobre o tema, ver o item 11.4.2, "b".
- 50** DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 20. ed., p. 46.
- 51** Sobre o processo civil impactado pela presença da Fazenda Pública em juízo: CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016; e RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2016.
- 52** Sobre o tema, ver o item 2.3.2.
- 53** Sobre a jurisprudência e precedentes judiciais como fontes de Direito, ver o item 2.3.2, "e".
- 54** Sobre o tema, ver o Capítulo 8.
- 55** Sobre a inafastabilidade do controle jurisdicional enquanto direito fundamental consagrado pela Constituição federal, ver item 6.1.4.1, no Capítulo 6.
- 56** Nesse sentido: art. 3º, § 1º, do Código de Processo Civil: "É admitida a arbitragem na forma da lei."
- 57** Sobre o tema, ver itens 6.2.3, no Capítulo 6 e 10.4, "d", no Capítulo 10.
- 58** Sobre a tutela jurisdicional executiva, ver item 4.2.1, "b".

59 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo, p. 29.

60 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo, p. 33.

61 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e ação rescisória, p. 127.

62 Não serão acrescentadas ao lado destas três categorias as denominadas tutela jurisdicional executiva *latu sensu* e tutela mandamental, noticiadas por parte da doutrina processual, haja vista que, conforme assevera Humberto Theodoro Jr. (As vias de execução do CPC brasileiro reformado. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da nova execução 3, p. 314), a distinção entre estas categorias e a tutela jurisdicional condenatória é equivocada pois, “quando se classificava as sentenças em declaratórias, constitutivas e condenatórias, sempre se levava em conta o objeto (o conteúdo do ato decisório). Já quando se cogitou das sentenças executivas ou mandamentais, o que se ponderou foram os efeitos de certa sentença. Não pode, como é evidente uma classificação ora lastrear-se no objeto ora nos efeitos, sob pena de violar mezinha regra de lógica: toda classificação deve compreender todos os objetos do universo enfocado e deve observar um só critério para agrupar as diversas espécies classificadas”.

Razão assiste ao eminente processualista na medida em que, caso persista a repartição quintupla, e a consequente distinção entre a sentença condenatória e a executiva pelo critério da necessidade de ajuizamento da ação executiva, chegar-se-ia à conclusão de que não mais existem sentenças condenatórias no ordenamento jurídico pátrio, dado que, com a introdução do cumprimento de sentença que condena o devedor a pagar quantia, não há mais espaço para a ação de execução de sentença judicial cível.

Assim, considerando o sistema vigente, pode-se classificar a sentença, em relação a seu conteúdo, em: a) meramente declaratória; b) constitutiva; ou c) condenatória. As duas primeiras dotadas de capacidade para realizar o direito dentro do próprio ato, ao passo que a última necessita de atos processuais posteriores a sua prolação para a realização de seus efeitos no plano empírico.

63 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 296.

64 O dogma da coisa julgada – hipóteses de relativização, p. 146.

65 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela de direitos, p. 42.

66 Teoria geral do processo, 17. ed., p. 312.

67 Sobre a distinção entre as espécies de tutela jurisdicional, José Carlos Barbosa Moreira (O novo processo civil brasileiro, p. 3) ensina que “o exercício da função jurisdicional visa à formulação e atuação prática da norma jurídica concreta que deve disciplinar determinada situação. Ao primeiro aspecto desta atividade (formulação da norma jurídica concreta) corresponde, segundo a terminologia tradicional, o processo de conhecimento, ou de cognição; ao segundo aspecto, (atuação prática da norma jurídica concreta), o processo de execução”. O mesmo autor reconhece, na sequência (op. e loc. cit.), que as duas atividades não se contêm necessariamente em compartimentos estanques, havendo casos em que elas se conjugam no mesmo processo. Por isso, em vez de se classificar o processo, faz mais sentido classificar as espécies de tutela jurisdicional, que podem ser prestadas em um mesmo processo,

quando muito, em fases distintas.

68 ASSIS, Araken de. Manual da execução, 17. ed., p. 84.

69 ASSIS, Araken de. Manual da execução, 17. ed., p. 108.

70 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 3, p. 71.

71 Op. e loc. cit.

72 Sobre a finalidade e os aspectos gerais da jurisdição penal, ver o item 5.1.3, "d".

73 Apesar de não ser da vocação de uma constituição tipificar títulos executivos extrajudiciais, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu texto, esta natureza às decisões do Tribunal de Contas da União de que resultem imputação de débito ou multa, nos termos do art. 71, § 3º.

74 Item 3.2.2.1.

75 Sobre o tema, ver itens 6.1.4.2 e 6.1.4.3.

76 Sobre o princípio da definitividade das decisões jurisdicionais e suas condicionantes, ver item 6.1.4.13.

77 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., p. 159.

78 Curso Avançado de Processo Civil, v. 2, 16. ed., p. 861.

79 Antecipação da tutela, 9. ed., p. 341-342.

80 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência, p. 277.

81 Antecipação da tutela, 9. ed., p. 341-342.

82 LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro, 5. ed., São Paulo: Castro Lopes, 2016. p. 116.

83 Op. e loc. cit.

84 Tutela de urgência e tutela de evidência, p. 276.

85 Sobre o tema, item 2.3.2, "e", no Capítulo 2.

86 Sobre a legitimação para agir, ver o item 8.4, "a".

87 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública, 2. ed., p. 177.

88 Sobre o tema, ver o item 7.1, "a".

89 Conforme o item 7.3.

90 Ver o item 7.2.

91 É certo que a consecução desse objetivo não ocorre em todos os casos em que uma ação coletiva é proposta e julgada pelo Judiciário. Três fatores influenciam diretamente na extensão da coisa julgada: a) a natureza do direito em litígio, se difuso, coletivo ou individual homogêneo; b) o sentido da resposta jurisdicional, se procedente ou improcedente (coisa julgada secundum eventum litis); e c) o fundamento da decisão, nas hipóteses de improcedência, se improcedente por falta de provas ou improcedente

mesmo tendo sido produzida prova suficiente (coisa julgada secundum probationem); sendo certo que a sistematização destas variantes escapam ao objeto desta Introdução.

92 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante, p. 194.

93 Sobre o tema: MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia para a aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 341-490.

94 Conforme demonstrado no item 2.2, “f”.

95 Sobre o tema, 6.1.4.8.

96 A Emenda Constitucional n. 73/2013 cria outros quatro Tribunais Regionais Federais estabelecendo, portanto as 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões federais que, contudo, ainda não foram instaladas, sendo inexistentes na prática.

97 Sobre as hipóteses excepcionais em que os tribunais exercem jurisdição de primeiro grau, ver itens 15.5 e 15.7, infra.

98 Notadamente, Leis ns. 9.099/95 e 12.153/2009, no plano estadual, e Lei n. 10.259/2001, no plano federal.

99 DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo, 17. ed., p. 178.

100 ABBOUD, Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais, p. 94-96.

101 Sobre a autonomia do Direito Processual Constitucional, citando vasta doutrina nacional e estrangeira: ABBOUD. Georges. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais, p. 94-96.

102 Sobre o tema, ver item 2.3.2, “e”, supra.

103 Sobre o tema: MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Função nomofilática dos tribunais superiores no Brasil e na Itália e a necessidade de respeito aos seus precedentes, in Curso de Introdução ao Direito Europeu, Publicações da Escola da AGU, n. 21, v. 2, Brasília, 2012.

104 Art. 988, inc. III do Código de Processo Civil.

105 Sobre o ponto: MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Reclamação. STF. Legitimação ativa. Atingidos por ADIN. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 142, dez. 2006, p. 185-205.

106 Nesse sentido: STF PET 693:

“EMENTA: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. LEI N. 7.347/85. A competência do Supremo Tribunal Federal é de direito estrito e decorre da Constituição, que a restringe aos casos enumerados no art. 102 e incisos. A circunstância de o Presidente da República estar sujeito à jurisdição da Corte, para os feitos criminais e mandados de segurança, não desloca para esta o exercício da competência originária em relação às demais ações propostas contra ato da referida autoridade. Agravo regimental improvido”.

107 Sobre o tema, ver o item 2.2, “c”.

108 Art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal.

109 A Emenda Constitucional n. 73/2013 cria outros quatro Tribunais Regionais Federais estabelecendo, portanto, as 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões federais que, contudo, ainda não foram instaladas, sendo inexistentes na prática.

110 O item 6.1.4 será dedicado a este tema.

111 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 91. No mesmo sentido: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais, 5. ed., p. 62; BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 30. ed., p. 276; e CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 1162.

112 Op. e loc. cit.

113 Op. e loc. cit.

114 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 39.

115 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 42.

116 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 43.

117 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 1160.

118 Teoria processual da Constituição, 3. ed., p. 9.

119 Processo constitucional e direitos fundamentais, 5. ed., p. 67.

120 Sobre o conflito de princípios e sua solução através do princípio da proporcionalidade, ver item 6.3.1, "g".

121 Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 110.

122 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 1107.

123 Princípios que serão estudados nos itens 6.1.4.2 e 6.1.4.3, infra.

124 Sobre a categorização dos direitos fundamentais e seus principais desdobramentos, ver item 6.1.4.

125 Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 1168.

126 Op. e loc. cit.

127 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 1174.

128 Item 6.1.4.11.

129 Item 6.1.4.13.

130 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., cit.

131 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 476.

132 Ver item 6.1.4.1.

133 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 501.

134 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 7. ed., p. 43.

135 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais, 7. ed., p. 107 e seguintes.

136 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 7. ed., p. 51-52.

- 137** GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da Constituição, 3. ed., p. 9.
- 138** DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil, 2. ed., p. 22-23.
- 139** ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 116.
- 140** BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 30. ed., p. 405-407.
- 141** ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 7. ed., p. 165.
- 142** ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 7. ed., p. 170.
- 143** ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 118.
- 144** Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais, p. 64.
- 145** Sobre a tutela antecipada e provisória, ver item 4.2.2.
- 146** Sobre o tema: item 6.2.8, infra.
- 147** BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 30. ed., p. 299.
- 148** Sobre o papel da Defensoria Pública, ver item 7.3, infra.
- 149** Ver os itens 6.1.4.2 e 6.1.4.5.
- 150** Sobre o tema, ver o item 6.1.4.11.
- 151** GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais, 5. ed., p. 64.
- 152** ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, p. 90.
- 153** Instituições de Direito Processual Civil, 8. ed., v. I, p. 380.
- 154** Princípios do processo na Constituição Federal, 12. ed., p. 208.
- 155** Por todos: NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, 12. ed., p. 247.
- 156** BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 108.
- 157** Op. e loc. cit.
- 158** NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal, 12. ed., p. 279.
- 159** Instituições de Direito Processual Civil, 8. ed., v. I, p. 343-344.
- 160** DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 8. ed., v. I, p. 350-351.
- 161** Sobre o tema, item 6.2.7, infra.
- 162** Ver o item 6.1.4.5.
- 163** Princípios fundamentais da prova cível, p. 50.
- 164** Sobre as características da tutela jurisdicional de urgência e a dinâmica do contraditório postergado para depois da decisão, ver item 4.2.2, "a".

165 Os parâmetros de obtenção de provas mediante interceptação de comunicação telefônica são estabelecidos pela Lei n. 9.292/1996, que uma vez respeitados tornam a prova produzida lícita e admissível.

166 Princípios fundamentais da prova cível, p. 116.

167 HC 72.588, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 12-6-1996, DJ 4-8-2000, p. 3, Ement v. 1998-02, p. 289, RTJ 174-02, p. 491.

168 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, 12. ed., p. 327.

169 Op. e loc. cit.

170 Nesse sentido: OMMATI, José Emílio Medauar. Embargos declaratórios e o Estado democrático de direito. In: NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais, p. 270.

171 Sobre o tema item 9.2.3.1, "e".

172 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, 10. ed., v. 2, p. 326.

173 CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material".

174 O princípio do devido processo legal: direito fundamental do cidadão, p. 242.

175 Nesse sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil: teoria geral do Direito Processual Civil, v. 1, p. 130-131.

176 Constituição Federal, art. 5º, inc. X: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

177 Sobre o princípio da proporcionalidade, ver item 6.1.3.1, "f".

178 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 115.

179 Sobre os critérios de repartição de competência, ver item 15.2.1, *infra*.

180 Ver o Capítulo 5.

181 Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

182 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: II – julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; b) o crime político.

183 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: II – julgar, em recurso ordinário: a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos

Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

184 Nesse sentido, ressaltando não se tratar de uma garantia absoluta: NERY JÚNIOR, Nelson. *Princípios do processo civil na Constituição Federal*, 12. ed., p. 321.

185 Sérgio Cruz Arenhart e Luiz Guilherme Marinoni (*Curso de processo civil*, 6. ed., v. 2, p. 497), nessa linha, afirmam que “o legislador infraconstitucional não está obrigado a estabelecer para toda e qualquer causa uma dupla revisão em relação ao mérito, principalmente porque a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXXV, garante a todos o direito à tutela jurisdicional tempestiva, direito este que não pode deixar de ser levado em consideração quando se pensa em ‘garantir’ a segurança da parte através da instituição da dupla revisão”. Em outra obra, os autores, ao lado de Daniel Mitidiero (*Novo Curso de Direito Processual Civil*, 2. ed., v. 2, p. 518) aduzem que “o legislador infraconstitucional, porém, não se encontra obrigado a observar essa regra em todos os casos, tanto é assim que existem inúmeras exceções na lei processual. Assim é que algumas decisões, proferidas em determinadas ações, apenas contemplam excepcionalmente a possibilidade recursal, diante da existência de algum pressuposto específico, com acontece com as sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou superior a cinquenta OTN (art. 34 da Lei n. 6.830/1980), que somente admitem uma espécie de pedido de reconsideração ao juiz prolator da decisão (chamado pela lei de ‘embargos infringentes’) e embargos de declaração, também para o mesmo magistrado, além de – em caso de violação à regra constitucional – recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal”.

186 São consideradas causas de menor complexidade sujeitas aos Juizados Especiais Cível, pela Lei n. 9.099 de 1995: a) as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; b) as enumeradas no art. 275, inc. II, do CPC/73 (Lei n. 5.869/73), conforme determinado pelo art. 1.063 do Código de Processo Civil; c) a ação de despejo para uso próprio; d) as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao valor equivalente a quarenta vezes o salário mínimo.

No plano federal, a Lei n. 10.259 de 2001, define como causas de menor complexidade: causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimo, excluindo-se algumas matérias e ações identificadas no art. 3º, § 1º, da referida lei.

187 Teoria geral do processo, 2. ed., v. 1, p. 224-225.

188 BONICIO, Marcelo José Magalhães. *Proporcionalidade e processo*, p. 58.

189 Op. e loc. cit.

190 Sobre o tema, ver o item 9.2.3.2.

191 Ver o item 9.2.3.2.

192 Ver o item 9.2.2.

193 Conforme o item 9.2.1.1.

- 194** NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal, 12. ed., p. 107.
- 195** NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal, 12. ed., p. 106.
- 196** ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, p. 98.
- 197** NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal, 12. ed., p. 110.
- 198** SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidades, p. 123-124.
- 199** Op. e loc. cit.
- 200** Op. e loc. cit.
- 201** BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 3. ed., p. 9.
- 202** Op. e loc. cit.
- 203** SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 21. ed., p. 213.
- 204** CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, 7. ed., p. 427.
- 205** Teoria dos direitos fundamentais, p. 423.
- 206** Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 3. ed., p. 21-22.
- 207** Bandeira de Mello (Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 3. ed., p. 41-42) destaca que este último critério impede qualquer diferença, “conquanto real e logicamente explicável, que possui suficiência para discriminações legais”, não bastando o estabelecimento racional de um nexo entre a diferença e um consequente tratamento diferenciado. Para que não reste lesada a igualdade, “as vantagens calçadas em alguma peculiaridade distintiva hão de ser conferidas prestigiando situações conotadas positivamente ou, ao menos, compatíveis com os interesses acolhidos pelo sistema constitucional”.
- 208** Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 3. ed., p. 38.
- 209** Op. e loc. cit.
- 210** Sobre o tema, mais amplamente, ver o Capítulo 7.
- 211** O princípio do devido processo legal: direito fundamental do cidadão, p. 204.
- 212** Op. e loc. cit.
- 213** NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, 12. ed., p. 279.
- 214** Op. e loc. cit.
- 215** NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, 12. ed., p. 279.
- 216** Sobre o princípio da igualdade e paridade de armas, ver ainda o item 6.2.7, dedicado ao art. 7º do Código de Processo Civil.
- 217** Instituições de Direito Processual Civil, 8. ed., v. I, p. 340.
- 218** Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, 2. ed., p. 524.
- 219** Precedentes obrigatórios, 5. ed., p. 103.

220 O conceito, a natureza e a responsabilidade pelo custeio das despesas processuais serão tratados no Capítulo 14.

221 Item 7.3.

222 Sobre aspectos procedimentais mais detalhados sobre o tema ver item 14.8.

223 Ver o item 10.4.

224 Apenas excepcionalissimamente o sistema processual admite a rediscussão da coisa julgada, em hipóteses de detecção de vícios gravíssimos expressamente previstos em lei, notadamente no art. 966 do Código de Processo Civil, que arrola as hipóteses de cabimento de ação rescisória.

225 Sobre o caráter complementar e subsidiário do Código de Processo Civil em relação às normas processuais constitucionais ver item 2.3.2, “b”.

226 Item 6.2.9, *infra*.

227 Item 6.1.4.

228 O expresso comprometimento do CPC 2015 com o sistema constitucional não estava presente, por exemplo, no art. 1º do CPC de 1973, que dispunha que “a jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em todo território nacional, conforme as disposições que este Código estabelece” e, nesse sentido, demonstrava estar aquele diploma menos comprometido com a Constituição Federal e transmitia uma (falsa) ideia de que o Código “bastava por si só”, o que além de não ser uma conclusão correta e verdadeira não afastava a incidência das regras e princípios constitucionais, sobretudo após a promulgação da Constituição de 1988.

229 Novo Código de Processo Civil comentado, p. 30.

230 CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 2 e 3.

231 Sobre o direito de ação, ver Capítulo 8.

232 Curso avançado de Direito Processual Civil, 16. ed., p. 82.

233 *Op. e loc. cit.*

234 Sobre as funções essenciais à Justiça, ver Capítulo 7.

235 Sobre o princípio da cooperação, ver item 6.2.6, *infra*.

236 Política pública do Poder Judiciário Nacional para o tratamento adequado dos conflitos de interesses. In: PELUZO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (Coord.).

237 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 191.

238 BUENO, Cassio Scarpinella. A Nova Etapa da Reforma do Código de Processo Civil, v. 1, p. 323.

239 Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos. In: MACHADO, Fábio Cardoso; AMARAL, Guilherme Rizzo (Org.). Polêmica sobre a Ação, p. 236.

240 Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 266.

- 241** DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 131.
- 242** Lições de Direito Processual Civil, 23. ed., p. 260.
- 243** Op. e loc. cit.
- 244** Sobre as hipóteses de extinção do processo com e sem resolução do mérito, ver item 11.4.
- 245** Sobre o sistema de nulidade e seus princípios inerentes, ver Capítulo 13.
- 246** Curso de Direito Processual Civil, 38. ed., p. 26.
- 247** WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (Coord.). Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 70.
- 248** Op. e loc. cit.
- 249** Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 17. ed., p. 104.
- 250** A litigância de má-fé e a responsabilidade do advogado, p. 85.
- 251** Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 17. ed., p. 125.
- 252** DIDIER JR., Fredie. Op. e loc. cit.
- 253** A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva no Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, n. 172, p. 33.
- 254** Op. e loc. cit.
- 255** Op. e loc. cit.
- 256** A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva no Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, n. 172, p. 33-34.
- 257** Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 12. ed., p. 279.
- 258** Lezione sul Processo Civile, Bologna: Il Mulino, 1995, p. 70.
- 259** Op. cit., p. 221.
- 260** STRECK, Lenio Luiz; DIERLE, Nunes; CUNHA, Leonardo (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil, p. 53.
- 261** CABRAL. Antônio do Passo; CRAMER. Ronaldo (Coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 24.
- 262** Novo Código de Processo Civil comentado, p. 31.
- 263** STRECK, Lenio Luiz; DIERLE, Nunes; CUNHA, Leonardo (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil, p. 46-47.
- 264** Teoria processual da Constituição, p. 58.
- 265** Ver BfGE 30, 316, apud Willis Santiago Guerra Filho. Op. e loc. cit.
- 266** Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência.

267 O proporcional e o razoável, p. 27.

268 O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, p. 114.

269 Sobre o tema, ver item 17.4.3, no Capítulo 17.

270 Manual de Direito Processual Civil, p. 99.

271 Princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa, p. 93.

272 Nesse sentido: SANTOS, Welder Queiroz dos. Princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa, p. 230.

273 Sobre o tema, ver item 9.2.2.1, “b”.

274 STRECK, Lenio Luiz; DIERLE, Nunes; CUNHA, Leonardo (Org.). Comentários ao Código de Processo Civil, p. 57.

275 A duração razoável e a gestão do tempo do processo no projeto de novo Código de Processo Civil. Novas tendências do processo civil. In: FREIRE, Alexandre et al., apud CUNHA, Leonardo. Op. e loc. cit.

276 Sobre jurisdição penal e suas distinções em relação à jurisdição civil, ver o item 5.1.3, “d”.

277 Conforme o art. 18 do Código de Processo Civil: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”; sobre o tema, ver o item 8.4, “a”, infra.

278 Sobre o tema, ver o item 4.2.3.

279 O dispositivo representa uma hipótese de aplicação concreta do princípio do aproveitamento dos atos processuais, comentado mais detalhadamente no item 13.5.

280 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed., p. 6.

281 Nesse sentido, por exemplo, o art. 4º, inc. II, da Lei Complementar n. 80/94, que estabelece entre as funções institucionais da Defensoria Pública: “II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos”.

282 Nesse sentido: Lei n. 9.099/95, art. 9º, verbis: “Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória”.

283 ADI 3.026, DJ 29-9-2006.

284 Nesse sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. I, p. 228.

- 285** Conforme demonstrado mais detalhadamente no item 6.1.3, “b”.
- 286** SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 26. ed., v. 1, p. 156.
- 287** SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 26. ed., v. 1, p. 156.
- 288** SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 26. ed., v. 1, p. 156.
- 289** SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 26. ed., v. 1, p. 156.
- 290** Teoria geral do processo, 17. ed., p. 251.
- 291** Teoria geral do processo, 17. ed., p. 252.
- 292** SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 26. ed., p. 167.
- 293** Teoria geral do processo, 17. ed., p. 256.
- 294** Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 333-334.
- 295** BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 364.
- 296** Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 364.
- 297** Sobre o tema, ver o item 10.4, “a”.
- 298** Sobre o tema, ver o item 4.2.1.
- 299** Sobre a classificação da tutela jurisdicional, ver o item 4.2 supra.
- 300** Sobre o tema, mais amplamente, ver o item 4.2.1, “a”.
- 301** Sobre o tema, mais amplamente, ver o item 4.2.1.
- 302** Nesse sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 342.
- 303** Sobre o tema, ver o item 10.4.
- 304** DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo, 25. ed., p. 276.
- 305** Op. e loc. cit.
- 306** Ver o item, 8.3, “a”, supra.
- 307** DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 303.
- 308** Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, p. 411.
- 309** Sobre o tema, ver o item 4.2.1, “a.1”.
- 310** Outra parte da doutrina adota a classificação quádrupla, que acrescenta àquelas três espécies as sentenças mandamentais e executivas. Sobre o tema e sobre o porquê da classificação tripartite, ver o item 4.2.1, “a”, e, mais amplamente: MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Conceito, classificação e eficácia executiva da sentença no novo regime de execução de títulos executivos judiciais. In: SHIMURA, Sérgio; BRUSCHI, Gilberto Gomes (Coord.). Execução civil e cumprimento de sentença, v. 2, p. 139-162.

311 Sobre o conceito de “matéria de ordem pública” e as razões sistemáticas pelas quais ela não é atingida pela preclusão e deve ser verificada e decretada inclusive de ofício pelo juiz, ver item 9.2.3.1, “g”, no capítulo seguinte.

312 Nesse sentido: DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo Processo Civil, 2. ed., p. 116.

313 Nesse sentido, a autorizada doutrina de Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, 17. ed., v. 1, p. 304), para quem a legitimidade ad causum e o interesse de agir passam a ser estudados no capítulo sobre pressupostos processuais.

314 Sobre o tema, ver os itens 6.1.4.13 e 10.4, “b”.

315 Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., p. 39.

316 Curso avançado de processo civil, v. 1, p. 219.

317 Sobre o tema, ver os itens 11.4.1, “d”, “e” e “f”, infra.

- 318** Sobre as características da jurisdição, ver o item 3.2.2.1.
- 319** Curso de Direito Processual Civil, 58. ed., v. I, p. 725.
- 320** Sobre a distinção entre a tutela jurisdicional de conhecimento e de execução, ver item 4.2.1.
- 321** A expressão “processo de execução”, no atual sistema, subsiste apenas quando o direito estiver consagrado em um título executivo extrajudicial que, quando existente, viabiliza a instauração desta relação processual desde já voltada à prestação da tutela jurisdicional executiva (sobre o tema, ver o item 4.2.1, supra).
- 322** Sobre a tutela de urgência e provisória, ver item 4.2.2, “a”.
- 323** Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. 1, 6. ed., p. 433.
- 324** Lei n. 5.869, de 1973.
- 325** Op. e loc. cit.
- 326** Título III do Livro I da Parte Especial.
- 327** Sobre o tema, ver o item 4.2.3.
- 328** BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo, 32. ed., p. 73.
- 329** Ver o item 6.1.4.1.
- 330** Art. 93, inc. IX, conforme estudado no item 6.1.4.5.
- 331** Mais adiante, ver-se-á que, para consecução desta finalidade, o juiz tem os poderes ordinatórios e sancionatórios que lhe permitem evitar a prática de atos inúteis ou desnecessário e punir a parte que se utilize do processo para fins meramente protelatórios.
- 332** Sobre o tema, ver item 6.2.2, no Capítulo 6.
- 333** Sobre o tema, ver o Capítulo 13.
- 334** Sobre o tema nulidades, vícios e suas formas de correção, ver o Capítulo 13.
- 335** Ver item 6.2.7.
- 336** Sobre o tema, mais amplamente, ver item 6.2.7.
- 337** Sobre o tema, ver item 6.2.3.
- 338** Conforme se verá item 11.4.2, “b”.
- 339** Art. 5º do Código de Processo Civil.
- 340** Item 9.2.1.2, “d”.
- 341** Sobre o tema, ver item 6.2.2.
- 342** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 237.
- 343** Sobre o tema, ver o item 11.4.1.
- 344** Sobre o tema, ver o item 12.2.1, “d”.
- 345** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 207.

- 346** Sobre o tema, ver item 6.2.2.
- 347** Especificamente sobre este tema, ver item 11.4.1.
- 348** Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 7. ed., p. 39.
- 349** Art. 139, inc. VIII, do CPC.
- 350** Sobre o dever de boa-fé das partes, ver itens 6.2.5, 6.2.6 e 9.2.3.2.
- 351** Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
- 352** Outras hipóteses, cuja análise escapa ao objeto desta Introdução, estão previstas no art. 161, parágrafo único; art. 903, § 6º; entre outros dispositivos.
- 353** Ver o item 3.2.2.1.
- 354** Art. 152, § 1º, do CPC.
- 355** Tema tratado no item 6.2.3.
- 356** Sobre o tema, ver o item 11.4.2, “b”.
- 357** Sobre os honorários periciais e demais despesas do processo ver item 14.4.
- 358** Sobre o tema, ver os itens 8.3, “c”, e 10.3, “c”.
- 359** BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, 2. ed., p. 323.
- 360** Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela dos direitos. In: MACHADO, Fábio Cardoso e AMARAL, Guilherme Rizzo (Org.). Polêmica sobre a ação, p. 236.
- 361** Sobre o tema, ver item 6.2.4.
- 362** Instituições de Direito Processual Civil, 8. ed., v. I, p. 443.
- 363** Op. e loc cit.
- 364** O direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 49.
- 365** Sobre o conceito de ônus, ver item seguinte.
- 366** Item 6.1.4.4 do Capítulo 6.
- 367** ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil, 17. ed., p. 203.
- 368** ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil, 17. ed., v. 1, p. 657.
- 369** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 235.
- 370** Sobre o tema, ver o Capítulo 13.
- 371** A ação rescisória escapa aos objetivos de uma Introdução ao estudo do Direito Processual Civil, sendo suficiente ficar aqui registrado que se trata de uma ação voltada a desconstituir a coisa julgada

formada em um processo eivado de um vício gravíssimo e intolerável pelo sistema processual.

372 Sobre a imperatividade da jurisdição, ver o item 3.2.2.1.

373 Curso de Direito Processual Civil, v. I, 58. ed., p. 426.

374 Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.

375 Sobre o tema: DANTAS, Rodrigo Dório. A litigância de má-fé e a responsabilidade do advogado, 2013.

- 376** Lições de Direito Processual Civil, 23. ed., p. 262.
- 377** Curso de Direito Processual Civil, 58. ed., p. 144.
- 378** BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, v. I, p. 406.
- 379** ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença, 8. ed., p. 45.
- 380** Sobre o tema, ver o item 13.6, *infra*.
- 381** Sobre a formação da relação processual, ver o item 11.2, no capítulo seguinte.
- 382** Sobre o tema, ver o item 8.3, “b”, no Capítulo 8, dedicado à ação.
- 383** Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 7. ed., p. 250.
- 384** Lições de Direito Processual Civil, 23. ed., p. 262.
- 385** Sobre o tema, ver o item 6.1.4.10.
- 386** Sobre o tema, ver o item 13.6.
- 387** Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 26. ed., p. 207.
- 388** Primeiras linhas de Direito Processual Civil, 26. ed., p. 206.
- 389** Sobre a repartição de competência, ver Capítulo 15.
- 390** THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 58. ed., v. 1, p. 209.
- 391** Sobre a “ação” mais amplamente, ver o Capítulo 8.
- 392** Sobre os elementos da ação, ver item 8.3.
- 393** Nesse sentido, art. 292 do CPC verbis: “O valor da causa constará da petição inicial (...)”.
- 394** Ver-se-á mais adiante (item “d”, *infra*) que o não conhecimento e a não descoberta dos dados referidos por meio das diligências autorizam a citação ficta do réu.
- 395** DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. III, p. 458.
- 396** Sobre o tema, ver o item “g”, *infra*.
- 397** Ver o item 11.2.
- 398** Sobre o tema, ver o item 11.4.1, “i”.
- 399** Sobre as consequências processuais decorrentes da morte das partes e a sucessão processual, ver o item 10.3.1, “a”, *infra*.
- 400** A representação processual da União se dá por meio dos membros da Advocacia-Geral da União, função essencial à Justiça prevista com essa finalidade na Constituição Federal, cujo estudo pormenorizado encontra-se no item 7.2.
- 401** Sobre a representação dos Estados-membros em juízo, ver os itens 10.3, “f”, *infra*, e 7.2, *supra*.
- 402** Sobre o tema, ver o item 11.4.1, “i”.
- 403** Sobre as consequências processuais decorrentes da morte das partes e a sucessão processual, ver o item 10.3.1.

- 404** Sobre a Defensoria Pública, sua estrutura e funções, ver o item 7.3.
- 405** Sobre o tema, ver o item 7.2.
- 406** Ver item “g”, infra.
- 407** Art. 75, inc. IV, do CPC.
- 408** Sobre o tema, ver item 11.4.1, “d”, infra.
- 409** Sobre o tema, ver o item 10.3.1, “c”.
- 410** Sobre o tema, ver o item 11.4.1, “f”.
- 411** Sobre a suspensão do processo, nesta e em outras hipóteses, ver o item 11.3.
- 412** Sobre a assistência litisconsorcial, ver item 17.3.2, no Capítulo 17.
- 413** Sobre o tema, ver o item 11.3.1, “b”.
- 414** Art. 337, inc. VI, do CPC.
- 415** Sobre o tema, com mais vagar, ver o item 9.2.3.1, “g”, supra.
- 416** Sobre o tema, ver o item 11.4.1, “f”.
- 417** Sobre as consequências processuais decorrentes da morte das partes e a sucessão processual, ver o item 10.3.1.
- 418** Sobre o tema, ver o item 11.3.1, “a”.

- 419** Especialmente nos arts. 319 e 320 do CPC.
- 420** Sobre o tema, ver o item 10.3, "c".
- 421** Ver o item 10.3, "c".
- 422** Item 11.4.1, "i".
- 423** SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, p. 99.
- 424** Apud Moacyr Amaral Santos, op. e loc. cit.
- 425** Nesse sentido, o art. 486 do CPC: "Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação".
- 426** Curso de Direito Processual Civil, v. 1, p. 136.
- 427** Sobre o tema, ver o item 10.4, "d".
- 428** Sobre o tema, Capítulo 8, item 8.3.
- 429** Até mesmo a fundamental informação do endereço do réu, quando verdadeiramente desconhecido pelo autor, não inviabiliza completamente a propositura da demanda, dado que, nestes casos excepcionais, o art. 256, inc. II, do Código, admite a citação por edital.
- 430** Sobre o tema, ver o item 8.3, "b".
- 431** Sobre o tema, ver Capítulo 15.
- 432** Ver o item 11.4.2, infra.
- 433** Sobre o tema item 6.2.2, supra.
- 434** Sobre o tema, item 11.3.2, "a", supra.
- 435** Sobre o tema, ver o item 14.2.
- 436** Ver item 16.2, "b".
- 437** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 733.
- 438** Sobre os temas, com mais detalhes, ver o item 8.4, supra.
- 439** NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 1114.
- 440** No mesmo sentido, DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, 17. ed., v. 1, p. 645.
- 441** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 165.
- 442** Sobre a coisa julgada material e a impossibilidade de repropositura da demanda em decorrência desta, ver item 10.4, "b", no Capítulo 10.
- 443** Sobre o tema, ver o item 10.3.1, "a", supra.
- 444** Sobre o tema, ver o item 16.2, "b".
- 445** Sobre o dever de adstrição do juiz ao pedido, ver item 9.2.1.1, "g", supra.
- 446** Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Art. 206. Prescreve: § 1º Em um ano: I – a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos; II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador; b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; III – a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários; IV – a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da assembleia que aprovar o laudo; V – a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. § 2º Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. § 3º Em três anos: I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; II – a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; III – a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela; IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V – a pretensão de reparação civil; VI – a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição; VII – a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo: a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima; b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento; c) para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação; VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. § 4º Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; II – a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; III – a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

447 Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 4. ed., p. 265) conceitua a renúncia como “o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo que vinha afirmando ter e que, se realmente tivesse, por esta razão deixará de ter”.

- 448** Sobre o tema, ver o item 12.2.1, *supra*.
- 449** Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 17. ed., p. 135.
- 450** Mais amplamente sobre o poder ordinatório, ver o item 9.2.1.2, “b”.
- 451** Sobre o tema, ver o item 9.2.1.2.
- 452** Sobre estes auxiliares da Justiça, ver o item 9.2.2.
- 453** Sobre o tema, ver o item 4.2.1.
- 454** Sobre o tema, ver o item “e”, *infra*.
- 455** Sobre o tema, ver o item 11.3, *infra*.
- 456** Sobre o tema, ver o item 11.4.1.
- 457** Sobre a extinção do processo sem resolução do mérito, ver o item 11.4.1.
- 458** Sobre o tema, item 10.2 do Capítulo 10.
- 459** Item 13.4, *infra*.
- 460** CPC, art. 242: “§ 1º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. § 2º O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. § 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial”.
- 461** Sobre o tema, ver item 12.6.3, *infra*.
- 462** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 627.
- 463** Sobre este terceiro ponto, ver o item 13.4.
- 464** Sobre o tema, ver o item 10.3, “g”, *infra*.
- 465** Sobre o tema, ver o item 12.6.5.
- 466** Art. 313, inc. II, do CPC.
- 467** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 651.
- 468** Curso de Direito Processual Civil, v. I, 58. ed., p. 527.
- 469** Humberto Theodoro Jr., *op. cit.*, p. 528.
- 470** Nesse sentido, o art. 437, § 2º do CPC, verbis: “Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação”.
- 471** Nesse sentido: NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 702.

472 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 58. ed., v. I, p. 526.

473 Sobre o tema, ver o item 11.3.

474 Sobre o tema, ver o item 9.2.3.1, "g".

475 ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença, 8. ed., p. 185.

476 Op. e loc. cit.

477 Sobre o tema, ver o item 10.4, "b" e "c".

478 Sobre o tema, ver também o item 10.5, "a" e "b".

479 Ver o item 11.4.1, "a".

480 Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

481 Art. 282, § 1º: "O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte".

482 Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

483 Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., v. II, p. 705.

484 ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença, 8. ed., p. 141.

485 Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais, 2. ed., p. 44.

486 Sobre a extinção do processo sem resolução do mérito, ver item 11.4.1.

487 Nesse sentido, especificamente em relação aos recursos: art. 1.007 do CPC: § 2º “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”; e § 4º “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

488 Item 14.7, infra.

489 Sobre o tema, ver o Capítulo 16.

490 Especificamente no que se refere à perícia, o art. 91, em dois parágrafos, dispõe que: “§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público”.

491 Sobre o tema, ver os itens 6.1.4.12 e 7.3.

492 Considerando a possibilidade de concessão parcial de justiça gratuita (art. 98, § 5º, do CPC), uma terceira alternativa consiste na possibilidade de o juiz determinar que a parte, não obstante beneficiária da justiça gratuita, custeie especificamente o ato gerador da despesa, como os honorários do perito, por exemplo, sem que isso implique revogação da gratuidade concedida para os demais fins.

493 A forma, o prazo e o procedimento do recurso cabível contra esta decisão escapam ao objeto desta Introdução, sendo tal disciplina estabelecida no art. 101 do CPC, no que é complementada por uma série normas constantes do Livro III da Parte Especial do Código, dedicada aos processos nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais.

494 Sobre o princípio do juiz natural, ver item 6.1.4.7.

495 Teoria geral do processo, 25. ed., p. 232.

496 Assim, dispõe o art. 44 do Código de Processo Civil, verbis: "Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados".

497 Sobre o tema, com mais vagar, ver item 15.3, infra.

498 Item 15.5, infra.

499 Curso de Direito Processual Civil, v. I, 58. ed., p. 209.

500 Item 15.8, infra.

501 O art. 292 do CPC estabelece os parâmetros para a definição do valor da causa, sendo certo que a análise de todas essas situações escapa ao objeto do presente item.

502 Sobre a litispendência e as consequências processuais de sua verificação, ver item 10.4, "a", no Capítulo 10.

503 Op. e loc. cit.

504 Instituições de Direito Processual Civil, 8. ed., v. I, p. 561.

505 Sobre o tema, ver item 15.12.

506 O art. 292 do CPC estabelece os parâmetros para a definição do valor da causa, sendo certo que a análise de todas essas situações escapa ao objeto do presente item.

507 Sobre as consequências processuais decorrentes da distinção entre a competência absoluta e relativa, ver item 15.11.1, infra.

508 Nesse sentido, ver art. 44 do Código de Processo Civil, verbis: "Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados".

509 Sobre o tema, ver item 15.12.1, infra.

510 Sobre o tema, com mais vagar, ver itens 15.11.3 e 15.12, infra.

511 Nesse sentido, art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, verbis: "A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício".

512 Art. 47 do CPC, verbis: "A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta".

513 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 17. ed., p. 229.

514 Relação entre demandas, p. 80.

515 Relação entre demandas, p. 84.

516 Vale registrar que, na hipótese de vir a ser proposta uma ação cujo objeto já está abrangido por outra ação pendente, a segunda ação, porque já contida na primeira, deverá ser extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, conforme estabelecido pelo art. 57 do CPC. Não se trata, por óbvio, de uma norma de repartição de competência, mas sim de hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (sobre o tema, item 11.4.1, especialmente subitem “f”). A modificação de competência, portanto, ocorre quando a segunda ação – continente, cujo objeto maior contém o objeto de uma ação já pendente – é proposta posteriormente.

517 Novo CPC anotado e comparado, p. 97.

518 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 116.

519 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 116.

520 Relação entre demandas, p. 80.

521 Relação entre demandas, p. 93.

522 Sobre o tema, item 17.3.2, no Capítulo 17.

523 Item 17.4.1.

524 Item 17.4.2.

525 Item 17.4.3.

526 Capítulo 17, *infra*.

527 Art. 229: “§ 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles”.

528 Sobre a importância do prazo e a forma de contagem, inclusive o prazo da resposta do réu, ver item 12.6.

- 529** Sobre a legitimidade de partes, ver item 8.4, “a”.
- 530** Nesse sentido, o art. 506 do Código de Processo Civil: “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
- 531** Manual de Direito Processual Civil, 17. ed., p. 481.
- 532** Instituições de Direito Processual Civil, 7. ed., p. 429-430.
- 533** Em relevante trabalho sobre o tema, Lia Carolina Batista Cintra (Intervenção de terceiros por ordem do juiz) identifica as hipóteses de intervenção de terceiros por ordem do juiz, analisando o tema à luz dos direitos brasileiro e estrangeiro. Sobre o tema, serão tecidas breves considerações no item 17.6, infra.
- 534** Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., p. 88, que alerta, entretanto, que “o terceiro ao intervir, torna-se parte no processo. Nem sempre porém será parte da demanda”, uma vez que não é em todas as intervenções de terceiros que estes assumem a posição de demandante ou demandado.
- 535** Manual de Direito Processual Civil, 2. ed., p. 165.
- 536** ARRUDA ALVIM. Manual de Direito Processual Civil, 17. ed., p. 481.
- 537** Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 7. ed., p. 445.
- 538** Manual de Direito Processual Civil, 2. ed., p. 180.
- 539** Sobre o tema, ver com mais vagar, item 17.5, infra.
- 540** Sobre o tema, Capítulo 16, supra.
- 541** Sobre o tema, item 16.2, “b”, supra.
- 542** Item 17.3.2.
- 543** Sobre as hipóteses de intervenções de terceiros fora do capítulo próprio do Código de Processo Civil, ver item 17.6, infra.
- 544** CPC: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
- 545** Manual de Direito Processual Civil, p. 490.
- 546** Curso de Direito Processual Civil, v. I, 58. ed., p. 370.
- 547** Manual de Direito Processual Civil, 17. ed., p. 486.
- 548** ARRUDA ALVIM. Op. e loc. cit.
- 549** Sobre o tema, item 16.3 do Capítulo 16.
- 550** Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., p. 88.
- 551** Sobre o tema, item 16.3.
- 552** Sobre o tema, ver itens 16.2, “a” e “d”, do Capítulo 16.
- 553** Sobre o tema, ver item 16.2 do Capítulo 16.

554 Arts. 283 e 831 do Código Civil, supracitados.

555 Item 10.3, “e”, do Capítulo 10.

556 Sobre o tema, item 10.3, “f”, do Capítulo 10.

557 Os requisitos e formalidades para a regular constituição das pessoas jurídicas escapam ao objeto desta Introdução e do próprio Direito Processual Civil, sendo regulada pelo direito material, notadamente pelo Código Civil, por exemplo, entre os arts. 45, 985, 997 e 998, entre outros.

558 Por exemplo, Código Civil, art. 50, no que tange às obrigações civis; art. 4º da Lei de defesa do meio ambiente (Lei n. 9.605/98), no que se refere à responsabilidade por danos ambientais; e art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos danos causados por vício relacionado ao produto ou serviço.

559 Nesse sentido, BRUSCHI, Gilberto. NOLASCO, Rita Dias. e AMADEO, Rodolfo da Costa Manso. Fraudes patrimoniais e a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Processo Civil de 2015, p. 140.

560 Quando requerido na petição inicial, hipótese admitida expressamente pelo 134, § 2º, do Código, o sócio sequer chega a ser caracterizado como terceiro, sendo inclusive desnecessária a instauração do incidente. Nestes casos o sócio será desde logo citado tornando-se parte já no início do processo.

561 Sobre o tema, ver item 7.1.2, “b”, no Capítulo 7.

562 Nesse sentido, CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo Processo Civil brasileiro, p. 88.

563 Art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

564 Súmula Vinculante – solução concentrada: vantagens, riscos e necessidade de um contraditório de natureza coletiva (*amicus curiae*), in Reforma do Judiciário: primeiras reflexões sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004, FERREIRA, William Santos et al., p. 822.

565 Op. e loc. cit.

566 Sobre os pronunciamentos vinculantes no Processo Civil Brasileiro ver item 2.3.2, “e”, no Capítulo 2 desta Introdução e nosso “O Precedente Qualificado no Processo Civil Brasileiro: formação, eficácia vinculante e impactos procedimentais” in Sistemi Processuali a confronto: il Nuovo Codice di Procedura Civile del Brasile tra tradizione e rinnovamento, Publicações Específicas da Escola da AGU, v. 8, 2016, p. 100.

567 *Amicus curiae* no processo civil brasileiro, p. 623-625.

568 Op. cit., p. 633.

569 *Amicus curiae* no processo civil brasileiro, p. 647-649.

570 Sobre as diversas aplicações dos referidos conceitos a casos concretos, especialmente nas ações direta de constitucionalidade, com inúmeras referências à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: BUENO, Cassio Scarpinella. Op. cit., p. 141-156.

571 Op. cit., p. 648.

572 Op. cit., p. 647.

573 Manual de Direito Processual Civil, p. 539.

574 Tratando de outras possibilidades de intervenção de terceiros por ordem do juiz distintas do amicus curiae: CINTRA, Lia Carolina Batista. Intervenção de terceiros por ordem do juiz.

575 Sobre o tema, item 12.2.1, "b".

576 Admitindo expressamente a possibilidade de intervenção de terceiro negociada: CINTRA, Lia Carolina Batista. Intervenção de terceiros por ordem do juiz, p. 171, e DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, p. 478.

577 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 233.

578 Sobre o tema, itens 17.3.1 e 17.3.2, supra.

579 Nesse sentido: DIDIER JR., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3, p. 137.

580 Especialmente sobre a possibilidade de recurso pelo amicus curiae, ver item 17.5.2, supra.

581 Sobre o tema, item 16.3.3.1, "d".

582 Curso Avançado de Processo Civil, v. 2, p. 161.

583 Nesse sentido: DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, p. 476.

584 Intervenção de Terceiros por Ordem do Juiz, p. 32.

585 Item 17.5, supra.

586 Item 16.2, "b", do Capítulo 16.

587 Sobre o tema, ver item 16.2, "b", no Capítulo 16.

588 Item 16.3.2, "d", no Capítulo 16.